

MEMAHAMI HUKUM

Dari Konstruksi sampai Implementasi

Editor:
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.
Ninuk Triyanti, S.H., M.H.

Memahami Hukum

Dari Konstruksi sampai Implementasi

RAJAWALI PERS

RAJAWALI PERS

MEMAHAMI HUKUM

Dari Konstruksi sampai Implementasi

Kumpulan Tulisan dalam Peringatan
Ulang Tahun yang Ke-40
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Editor:
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.
Ninuk Triyanti, S.H., M.H.

RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Arinanto, Satya

Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi/editor, Satya Arinanto, Ninuk Triyanti.—Ed. 1,—2.—Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

xxiv, 578 hlm., 24 cm
ISBN 978-979-769-278-0

1. Hukum. I. Satya Arinanto. II. Ninuk Triyanti

340

Hak cipta 2009, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2009.1062 RAJ
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Ed.)
Ninuk Triyanti, S.H., M.H. (Ed.)
MEMAHAMI HUKUM: DARI KONSTRUKSI SAMPAI IMPLEMENTASI

Cetakan ke-2, Januari 2011

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh Stephen Rinaldy

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:
Jl. Janur Kuning I, Blok WF I No. I, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240
Tel/Fax : (021) 4520951 – 45847329
E-mail : rajapers@rajagrafindo.com http: //www.rajagrafindo.com

Perwakilan:

Bandung-40243 Jl. H. Kurdi Selatan I No. 18 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Kumbang III No. 4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. **Padang**-25156, Perum. Palm Griya Indah II No. A. 9, Korong Gadang Taruko, Telp. (0751) 498443. **Medan**-20215, Jl. Amaliun No. 34/68, Telp. (061) 7323082. **Makasar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 9/3, Komp. Perum Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 9, Telp. (0511) 3352060. **Denpasar,** Jl. Trengguli No. 80 Penatih, Telp. (0361) 8607995

TENTANG EDITOR

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.

Lahir di Surabaya 16 November 1965. Guru Besar Tata Negara dan Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Pengajar pada program Pascasarjana Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan. Di samping itu juga menjadi pengajar pada beberapa Fakultas Hukum Swasta di Jakarta maupun luar Jakarta.

Pendidikan tinggi yang pernah diikuti antara lain adalah Program Non-Gelar Pendidikan Ahli Teknik Jurusan Penggunaan Komputer Institut Teknologi Bandung (ITB), Program sarjana Fakultas Hukum UI, Program Magister dan Program Doktor di Pascasarjana UI. Pendidikan lanjutan lainnya adalah pendidikan bidang Peradilan Tata Usaha Negara FH UI, Program International Human Rights Law pada The University of Notre Dame Law School, Indiana USA. Kegiatan profesional yang pernah diikuti antara lain pernah menjadi anggota *Asia-Pasific Comparative Constitutional Law Standing Committee* yang berpusat di Melbourne Australia (1994-1996). Pada tahun 1997 juga mengikuti *Visiting Young Asia Scholars* pada The University of Melbourne Law School, Australia. Menjadi anggota Tim Pakar di Puri Consulting, Departemen Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Departemen Dalam Negeri. Dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Dalam bidang pemerintahan dipercaya sebagai Sekretaris Umum Panitia Pengawas Pemilu 1999 tingkat Pusat (Panwaspus) dan menjadi Penjabat Pelaksana Tugas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan pada Kantor Meneg HAM RI tahun 2000.

Penulis aktif dalam berbagai aktivitas akademik baik dalam fora nasional maupun internasional, di antaranya menjadi *visiting Professor* dalam rangka *Asia Link Program For Human Rights Education in Indonesia and Mongolia* pada The School of Law, The Queen's University of Belfast Northern Ireland UK tahun 2008.

Beberapa prestasi yang pernah diraih antara lain terpilih sebagai Peneliti Muda Berprestasi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Budaya dan Kemanusiaan yang diberikan dalam rangka Dies Natalis UI yang ke-48 tahun 1998 dan ke-50 tahun 2000. Semasa studi S1 pernah menjadi Mahasiswa Berprestasi I tingkat Fakultas Hukum UI dan Mahasiswa Berprestasi II Tingkat Universitas Indonesia.

Ninuk Triyanti, S.H., M.H.

Lahir di Magetan 26 November 1969. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 1992-2003 dengan jabatan akademik Lektor. Saat ini bekerja di Biro Hukum Departemen Dalam Negeri. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Unibraw tahun 1992 dan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada tahun 1998. Aktif dalam berbagai seminar dan pelatihan serta menulis dalam berbagai jurnal ilmiah dan media massa.

RAJAWALI PERS

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Pranata hukum merupakan sarana yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin dinamis dengan spektrum yang luas. Dengan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari yang sentralistik menuju paradigma yang desentralistik membutuhkan pranata hukum yang sesuai dengan paradigma pemerintahan tersebut. Paradigma ini memberikan ruang yang luas bagi perkembangan demokratisasi lokal, keanekaragaman daerah maupun keberadaan kultur lokal. Dinamika ini menuntut pula perubahan dalam cara berhukum, yang tidak hanya dalam ranah pembentukan peraturan perundang-undangan saja, namun jauh lebih luas dari itu adalah bagaimana melaksanakan hukum untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Pembangunan hukum yang responsif, akomodatif dan rasional merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pembangunan hukum harus dilakukan secara paralel terhadap tiga komponen utama dalam hukum yang meliputi materi hukum, aparatur pelaksana hukum dan budaya hukum masyarakat. Sebagai sebuah institusi yang hidup, hukum haruslah dipandang sebagai bagian yang *inherent* dengan masyarakat di tempat hukum itu berada, sehingga masyarakat merupakan basis tujuan utama bagaimana hukum itu dibangun dan dioperasionalkan. Hal ini menjadi sangat penting ketika kita melihat dalam konteks kekinian di mana semangat otonomi daerah dan otonomi masyarakat menguat dan perlu untuk mendapatkan penghormatan yang layak.

Saya menyambut gembira penerbitan buku "*MEMAHAMI HUKUM: Dari Konstruksi sampai Implementasi*" yang diterbitkan secara khusus dalam rangka peringatan ulang tahun ke-40 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Buku ini dengan isi yang menyentuh hampir semua bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum ekonomi, memberikan wawasan yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.

Dengan substansi yang demikian itu, saya mempunyai keyakinan bahwa buku ini akan sangat berguna bagi aparatur penyelenggara pemerintahan di pusat maupun pemerintah daerah dan DPRD.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasar atas hukum. Namun kita belum bisa menjawab secara pasti, negara hukum yang bagaimanakah yang dianut oleh negara Indonesia. Kita menyadari sepenuhnya bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum adalah suatu bangunan yang belum selesai dan harus kita isi secara terus-menerus sampai menemukan bentuknya yang cocok dengan bangunan sosial budaya masyarakat Indonesia. Buku ini telah memberikan arah bagaimana bangunan negara hukum Indonesia harus ditelusuri, dibangun dan disempurnakan.

Sudah lama saya mengenal Prof. Zudan sejak masih di Badan Diklat maupun sekarang di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Depdagri. Dengan seluruh ketekunan, kerja keras dan semangat yang ingin terus maju memang layak untuk mendapatkan ini semua. Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian derajat Guru Besar dalam usia 35 tahun dan seluruh kiprahnya selama ini. Saya mengucapkan selamat atas penerbitan buku ini dan juga selamat ulang tahun yang ke-40 untuk Prof. Zudan. Semoga Allah Swt. meridhoi.

SEKRETARIS JENDERAL,

DIAH ANGGRAENI, S.H., M.M.

SEKAPUR SIRIH
UCAPAN TERIMA KASIH



Pertama-tama dan dari tempat yang paling utama dalam hati saya, rasa syukur tak henti-hentinya saya ungkapkan**.** Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan karunia dan nikmat-Nya yang tak terhingga. Sungguh tidak ada lagi nikmat dan karunia Allah Swt. yang dapat didustakan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah Saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang tetap istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya.

Pada mulanya saya sendiri tidak terlalu yakin dengan ide menerbitkan kompilasi karya tulis para Guru Besar dan Doktor untuk peringatan ulang tahun ke-40 saya dalam bentuk buku yang penuh dengan bobot pemikiran teoretik dan wawasan praktikal ini dapat terlaksana. Sambil bercanda, sahabat dan teman-teman dekat mengatakan "ada-ada saja, ulang tahun ke-40 kok dirayakan dengan menerbitkan buku, terus ya siapa yang mau menyumbangkan makalahnya, nanti saja kalau sudah ulang tahun ke-60 atau ke-70 saja...." Untung saja mereka hanya sebatas meledek, selebihnya membantu penuh untuk agenda ini yang terkendala dengan waktu yang pendek dan belum terhubunginya beliau-beliau para penulis. Akhirnya saya memberanikan diri menelepon, mengirim email, memanfaatkan *facebook* dan bersurat kepada guru, kolega dan sahabat saya untuk memberikan makalah dalam peringatan ulang tahun saya yang ke-40.

Saya menjadi yakin agenda ini akan terlaksana ketika saya menelepon Prof. Tjip, —sapaan akrab Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.—, dan beliau menyatakan kesediaan dan bahkan menanyakan kapan makalah harus sudah diserahkan. Makalah beliaulah yang pertama-tama sampai ke tangan saya dan memberikan motivasi kuat bahwa apa yang saya inginkan akan terwujud. Terima kasih Prof. Tjip atas seluruh dukungannya. Respons dan dukungan yang luar biasa saya dapatkan dari seluruh guru, kolega dan sahabat saya yang memberikan konfirmasi bersedia menulis untuk agenda ini. Pada mulanya saya hanya ingin buku ini berisi 40 tulisan –simbol ulang tahun ke-40-. Namun untung tak dapat ditolak, terkumpullah 43 makalah yang kemudian tersaji dalam bentuk buku berjudul "*MEMAHAMI HUKUM: Dari Konstruksi sampai Implementasi*" ini. Untuk itu semua, ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam saya haturkan

kepada bapak dan ibu atas kado yang terindah ini, semoga akan menjadi amal jariyah yang tidak akan terputus.

Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Bapak H. Mardiyanto Menteri Dalam Negeri dan Ibu Diah Anggraeni, S.H., M.M. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang memberikan dukungan penuh penerbitan buku ini dan telah memberikan kesempatan yang luas pada saya untuk banyak membantu tugas-tugas beliau di Departemen Dalam Negeri. Tidak lupa kepada Bapak dan Ibu para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Diklat dan Kepala Badan Litbang Departemen Dalam Negeri serta Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang telah memperkenankan saya berkiprah membantu tugas-tugas komponen di Depdagri, tiada ungkapan lain kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas semua kepercayaan yang telah diberikan.

Kepada pengelola Program Pascasarjana di Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Tanjungpura, Universitas Sebelas Maret, Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya, Universitas Jayabaya, Universitas Borobudur dan STIH IBLAM yang masih tetap memberikan kepercayaan pada saya untuk beraktualisasi akademik dengan mengajar/membimbing tesis dan disertasi, saya menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga atas semua kesempatan yang telah diberikan. Semoga kerja sama kita tidak akan lapuk oleh hujan dan tak lekang karena panas. Kepada para mahasiswa, ucapan terima kasih pantas diberikan, karena anda semualah saya termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam seluruh proses pembelajaran yang kita jalani bersama.

Mas Satya Arinanto dan Dik Ninuk Triyanti, terima kasih banyak atas semua jerih payahnya yang telah bersedia menjadi editor buku ini. Tentu saja ini adalah pekerjaan yang melelahkan, namun percayalah, Allah Swt. telah mencatat seluruh amal itu untuk menjadi bekal dalam perjalanan berikutnya. Kepada penerbit RajaGrafindo Persada yang telah berkenan menerbitkan buku ini, saya menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Ada harapan yang muncul, semoga kerja sama ini akan terus berlangsung pada masa yang akan datang. Kepada anak-anakku, Muhammad Fatah Anugerah Akbar, Zatila Aqmar Arifa dan Hazida Fahkrin Arifa, terima kasih atas semua kelucuan kalian yang telah mencairkan semua kesuntukkan papa. Tetaplah bermain gitar, menabuh drum, dan menekan tuts keyboard walaupun semua tanpa nada, tapi papa sungguh tetap menikmatinya. Namun jangan lupa shalat dan mengajinya. Kepada Istriku Ninuk Triyanti terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayangnya serta telah menjadikan aku seperti sekarang ini.

Pada kesempatan ini, saya harus meminta agar dibukakan pintu maaf kepada para sahabat, para kolega yang terpaksa harus ditinggal dan makalahnya tidak dapat dimuat dalam buku ini karena sudah harus naik cetak. Juga kepada para mahasiswa dan rekan-rekan yang budiman, saya sesungguhnya sedang memotivasi anda untuk menjadi doktor ketika mengatakan "nanti ya kalau

sudah jadi doktor boleh ikut serta dalam penulisan buku ini", saya tidak bermaksud menolak anda semua. Oleh karena itu, segera tanggalkanlah kata "kandidat" di depan tulisan doktor anda. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya.

Jakarta, 24 Agustus 2009

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

RAJAWALI PERS

RAJAWALI PERS

BIODATA
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. adalah Guru Besar Termuda dalam komunitas intelelektual Ilmu Hukum Indonesia. Menjadi Guru Besar Bidang Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum sejak tahun 2004 dalam usia 35 tahun. Lahir di Sleman 24 Agustus 1969 dari keluarga sederhana, ayah guru dan ibu penjual jamu. Menyelesaikan studi di FH UNS tahun 1992, Program Magister Ilmu Hukum di Undip tahun 1995 dan Program Doktor Ilmu Hukum di Undip tahun 2001. Seluruh perjalanan studi mendapatkan bea siswa dari yayasan, individu maupun dari Bank Dunia. Bahkan "modal hidup" berupa rumah tipe 54/120 diperoleh dari sisa beasiswa Bank Dunia saat menyelesaikan Program Doktor. Semasa mahasiswa pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum UNS, aktif pula dalam kegiatan senat, pers kampus dan mahasiswa pecinta alam. Karier akademis diawali dengan menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya sampai memperoleh jenjang Guru Besar. Selain itu mengajar/membimbing di Pascasarjana Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Tanjungpura, Universitas Jayabaya, Universitas Borobudur, STIH IBLAM dan Universitas Nusa Bangsa serta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Saat ini lebih banyak mengaktualisasikan ilmu pengetahuannya di Departemen Dalam Negeri.

Aktif mengikuti berbagai kursus singkat di dalam negeri maupun di luar negeri antara lain di Jepang, Malaysia, Singapura, dan Belanda. Tulisannya tersebar di berbagai media massa dan jurnal ilmiah. Anggota Tim Pakar dalam penyusunan UU Pemerintahan Daerah, RUU Pilkada, RUU BUMD, Paket UU Bidang Politik, RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional, RUU Antariksa dan Tim Ahli Pemerintah dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Mempunyai banyak prestasi antara lain di bidang LKTI, Cerdas Cermat Bidang Hukum dan P4 dengan puncaknya menjadi Mahasiswa Berprestasi Utama UNS tahun 1992 dan Dosen Teladan Kopertis VII tahun 1998.

RAJAWALI PERS

PRAKATA

Ada sebuah tradisi yang baik di kalangan para akademisi untuk merayakan ulang tahun koleganya dengan menyumbangkan buah pikiran dalam bentuk karya tulis yang kemudian dikompilasi menjadi sebuah buku. Buku ini merupakan kumpulan karya tulis yang berasal dari para Guru, Sahabat, dan Rekan Sejawat dalam rangka peringatan ulang tahun ke-40 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Buku ini secara sadar didesain untuk mengetengahkan gagasan dari Empat Generasi Pemikir dalam Hukum Indonesia yang kemudian kami kelompokkan sesuai dengan bagian-bagian dari buku ini. Walaupun mungkin tidak terlalu tepat benar pembagian empat generasi tersebut, dalam buku ini akan tergambarkan gagasan-gagasan tentang bagaimana cara berhukum dan memandang hukum dalam perspektif masing-masing.

Dalam buku ini terurai pemikiran dari generasi senior pemikir hukum Indonesia yang diwakili oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Prof. Masyhur Effendi, Prof. Dr. Muchsin dan Prof. Dr. Bambang Purnomo. Generasi berikutnya antara lain adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr. Paulus Hadi Suprapto, Prof. Dr. Wahyono, Prof. Dr. Ade Saptomo. Kemudian Generasi pemikir hukum yang lebih muda adalah antara lain Prof. Dr. Satya Arinanto, Prof. Dr. Joni Emirzon, Prof. Dr. IBR Supancana, Prof. Dr. Arief Amrullah, Prof. Dr. Adjie Samekto dan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji. Dalam buku ini terwakili pula generasi pemikir hukum yang paling muda, pemikir hukum yang masih muda belia (dalam usia 35-40 tahunan) diwakili oleh Dr. Cecep Effendi, Dr. Andi Irmanputra Sidin, Dr. Agus Surono dan Dr. Gusti Ayu Ketut Rachmi.

Kami menyadari bahwa pengelompokan tulisan-tulisan bukanlah merupakan persoalan yang mudah. Kami memang tidak membatasi dengan tema khusus, dan kami menyerahkan sepenuhnya tema tulisan kepada beliau-beliau penyumbang naskah. Untuk memudahkan para pembaca, akhirnya kami mengelompokkan dalam lima bagian.

Bagian pertama merupakan kumpulan tulis tentang arah pembangunan hukum Indonesia. Walaupun dengan tema yang beragam, seluruh tulisan pada bagian ini menyadarkan pada kita bahwa pembangunan hukum yang dilakukan dan yang dicerminkan dalam sub-sub sistem hukum tidak bisa dilakukan

dalam ruang hampa. Hukum akan selalu berkelindan dengan persoalan keadilan, keberagaman, kemiskinan, ideologi negara dan persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo membuka tulisan pada bagian pertama ini dengan menawarkan orientasi baru tentang bagaimana cara berhukum, dan beliau menyebutnya dengan Hukum Progresif.

Bagian kedua diwadahi dengan tema mengantisipasi kejahatan sistematik. Seluruh tulisan dalam bagian ini, sesuai dengan perspektif masing-masing menguraikan bagaimana kejahatan sistematik seperti korupsi, *money laundering*, maupun kejahatan ekonomi global. Berbagai gagasan dalam wacana teoretik maupun langkah antisipatif dikemukakan oleh para penulis secara komprehensif meliputi tataran substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukumnya. Dengan pendekatan yang melepaskan diri dari paham positivistik, Prof. HM. Ali Mansyur langsung menukik pada budaya hukum masyarakat. Beliau menawarkan sebuah terapi untuk membangun masyarakat anti korupsi. Masih dalam kaitan dengan korupsi, Prof. Indriyanto mengurai tentang polemik korupsi sistematik. Prof. Bambang, Prof. Emeliana dan Dr. Supanto mengajak kita untuk melihat persoalan hukum yang terkait dengan *Cyber Law, Money Laundering* dan Kejahatan Ekonomi Global dengan perspektif yang baru.

Pada Bagian ketiga dimaksudkan untuk mewadahi berbagai pemikiran yang terkait dengan Konstitusi. Prof. Jimly Asshiddiqie memaparkan bagaimana upaya membangun budaya sadar berkonstitusi. Pemikiran beliau selama lima tahun terakhir saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan budaya sadar berkonstitusi. UUD 1945 yang memuat *grand design* dalam berbangsa dan bernegara dikaji oleh para penulis dalam kaitannya dengan konteks ideologi negara, politik hukum, sistem pemerintahan dan perlindungan hak perempuan (lihat Isnaeni, Soetanto, Fauzan dan Andi Irman). Pengujian UU terhadap UUD selama 5 tahun terakhir merupakan salah satu indikator menguatnya peran masyarakat dalam mengontrol dominasi negara dalam pembuatan produk legislasi. Sampai dengan bulan Juli 2009 telah terjadi 212 kali pengujian UU terhadap UUD 1945. Prof. Wahyono, Prof. Agnes Widanti dan Prof. Indrati Rini menyoal tentang persoalan pengujian UU terhadap UUD 1945.

Birokrasi beserta kewenangan yang berada di tangannya merupakan titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bila ada bahasan tentang birokrasi maka persepsi orang tidak lain adalah birokrasi pemerintah. Menurut Prof. Miftah Toha, birokrasi pemerintah sering kali diartikan sebagai "*officialdom*" atau kerajaan pejabat yang raja-rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi yang digolongkan modern. Di dalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yurisdiksi yang jelas dan pasti, mereka berada dalam area ofisial yang yurisdiktif. Di dalam yurisdiksi tersebut seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi (*official duties*) yang memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaannya.

Bagian keempat buku ini ditautkan dengan kajian-kajian tentang birokrasi pemerintahan yang dibedah dari aspek pengawasan (Prof. Muchsin dan Dr. I Gusti Ayu), visi transformasi birokrasi (Dr. Sudarsono) serta hubungan pusat dan daerah (Prof. Aminudin dan Dr. Siti Nurbaya). Birokrasi menjadi motor yang penting dalam kerangka perwujudan *good governance* sekaligus pemegang monopoli dalam pelayanan publik yang dalam implementasinya ternyata masih memerlukan pengawasan baik dari lembaga eksternal maupun internal. Secara umum ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik *governance* yang baik. ***Pertama***, praktik *governance* yang baik harus memberi ruang kepada aktor lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara aktor dan lembaga pemerintah dengan non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar. ***Kedua***, dalam praktik *governance* yang baik terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. ***Ketiga***, praktik *governance* yang baik adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN dan berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

Bagian kelima buku ini merupakan kumpulan tulisan yang berisi gagasan yang amat beragam dan paling sulit untuk diklasifikasikan. Namun kami dapat temukan benang merahnya yaitu tentang pengembangan lembaga dan pranata hukum. Dalam pengembangan aspek ini, sesungguhnya setiap bangsa mempunyai pilihan sendiri-sendiri. Tidak ada lembaga dan pranata hukum yang dapat *di copy paste* dari negara lain secara utuh dengan menafikkan kondisi riil keberadaan kultur dan struktur sebuah bangsa. Pengembangan pranata dan lembaga hukum di Indonesia diyakini merupakan pekerjaan yang rumit dan tidak mudah karena adanya keragaman geografis, etnografis dengan banyaknya masyarakat yang sudah lebih dahulu "kental" dan memiliki hukum-hukum lokal. Praktik ini seharusnya memerhatikan pula struktur sosial, keanekaragaman budaya, kultur lokal dan berbagai faktor sosial lainnya yang melingkupi bekerjanya hukum. Tulisan Prof. Satya, Prof. Yuhari, Prof. Tri Pranadji, Dr. Febrian, Prof. Jamal, Dr. Agus Surono mencoba mengurai bagaimana aspek kelembagaan dalam memengaruhi bekerjanya hukum secara menyeluruh. Terkait dengan hal tersebut, Prof. Supancana, Prof. Paulus, Dr. Sholehuddin, Dr. Kamarullah, Dr. Habib Adjie dan Dr. Cecep Effendi menelaah bagaimana pentingnya pranata hukum dikembangkan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia maupun keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, perlu disegarkan kembali bagaimana sesungguhnya hukum harus dipandang sebagai bagian dari keseluruhan hidup manusia, sehingga akan lebih tepat apabila menempatkan hukum untuk kepentingan dan kebutuhan manusia bukan sebaliknya yaitu manusia untuk hukum.

Kami menyadari bahwa seluruh tulisan dalam buku ini tidak dapat menyajikan peta teori maupun penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh manusia secara menyeluruh dan tuntas. Tulisan-tulisan dalam buku ini lebih dimaksudkan untuk mengundang perhatian dalam kerangka membangun kesadaran baru dalam cara berhukum. Dalam berbagai kesempatan diskusi, seminar maupun berbagai kesempatan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa hukum itu dibuat untuk manusia sehingga hukum harus mampu mewujudkan peningkatan martabat manusia, kesejahteraan masyarakat dan melahirkan kebahagiaan bagi umat manusia. Keberadaan hukum juga terikat dengan ruang dan waktu. Dengan demikian hukum harus dibangun secara dinamis sesuai dengan perkembangan manusianya yang berada pada tempatnya dan masanya sendiri-sendiri. Di sinilah dapat dipahami bahwa mengapa cara berpikir kita dalam berhukum tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan dan masalah yang melingkupi kehidupan manusia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah menyumbangkan naskah untuk penerbitan buku ini. Kami sadar bahwa kami telah menyita waktu beliau-beliau yang amat padat dengan kesibukan masing-masing. Tak lupa kami mohon maaf karena pasti ada sahabat maupun kolega yang tak dapat terhubungi dalam rangka penulisan ini, juga kepada para sahabat yang telah mempersiapkan tulisan, namun tidak dapat kami muat karena harus segera diedit untuk naik cetak. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.

Selamat ulang tahun Prof. Zudan, *life begin at fourty*. Semoga Allah Swt. senantiasa menganugerahkan kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin.

Jakarta, 24 Agustus 2009

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.
Ninuk Triyanti, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR
Edisi Kedua



Merupakan hal yang sangat membahagiakan bagi kami ketika dari Penerbit PT RajaGrafindo Persada memberitahukan bahwa cetakan edisi pertama buku "MEMAHAMI HUKUM DARI KONSTRUKSI SAMPAI IMPLEMENTASI" sudah hampir habis dan perlu untuk dicetak ulang. Sejak buku ini diedarkan pada bulan Oktober 2009, kami banyak mendapat tanggapan dan komentar dari para pembaca, khususnya dari para mahasiswa, dosen, birokrat, praktisi hukum dan para pemerhati hukum. Para pembaca menyampaikan bahwa isi buku ini sangat bervariasi dan dapat memacu siapapun yang membacanya untuk belajar memahami hukum dalam perspektif yang utuh.

Pada cetakan edisi kedua ini belum ada perubahan materi. Dari para kontributor memberitahukan kepada kami bahwa isi tulisannya masih relevan dan Insya Allah pada cetakan edisi berikutnya akan dilakukan penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembaca yang telah memberikan perhatian dan pendapatnya terhadap buku ini, dan khususnya kepada Penerbit PT RajaGrafindo Persada yang berkenan untuk mencetak edisi kedua dan dapat menyebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air. Kami tetap menantikan komentar, kritik dan saran dari para pembaca untuk penyempurnaan buku ini. Mudah-mudahan, penerbitan edisi kedua ini akan dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi pengembangan ilmu hukum dan pembangunan hukum di Indonesia. Selamat menikmati.

Jakarta, Oktober 2010

Editor

RAJAWALI PERS

DAFTAR ISI

Tentang Editor v

Sambutan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri vii

Sekapur Sirih Ucapan Terima Kasih ix

Biodata Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. xiii

Prakata xv

Kata Pengantar Edisi Kedua xix

BAGIAN PERTAMA
Arah Pembangunan Hukum Indonesia 1

1 Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. 3

2 Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan
Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. 6

3 Pembangunan Hukum: Perspektif Paradigma Komunikatif
Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. 13

4 Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila
Prof. Dr. Prasetijo Rijadi, S.H., M.S.
Sri Priyati, S.H., M.H. 24

5 Akomodasi Keberagaman ke dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., S.U. 38

6 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rangka Pembangunan Hukum
Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. 54

7 Reformasi Hukum Nasional: Problem dan Prospeknya
Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. 61

8 Sistem Hukum Modern, *Rule Of Law* dan Kemiskinan di Indonesia
Prof. Dr. FX. Adjie Samekto, S.H., M.Hum. 69

9 Membangun Kesadaran HAM dalam Masyarakat Modern
Prof. A. Masyhur Effendi, S.H., M.S. 74

10 Penerapan Otonomi Keilmuan dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi
Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. 88

11 Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. 120

12 The Resurrection of Islamic Law in its Existence in the Indonesia Legal System
Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S. 140

BAGIAN KEDUA
Mengantisipasi Kejahatan Sistematik **151**

13 Menuju Masyarakat Anti Korupsi
Prof. Dr. HM. Ali Mansyur, S.H., M.Hum. 153

14 Polemik Korupsi Sistemik
Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. 160

15 Problematik *Cyber Law* Bagi Perkembangan Hukum Indonesia
Prof. Dr. Emeliana Krisnawati, S.H., M.Si. 178

16 *Money Laundering* Persepsi Hukum Sosial-Ekonomi Beraspek Pidana
Prof. Dr. Bambang Purnomo, S.H. 185

17 Perspektif Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan Kejahatan Ekonomi Global
Dr. Supanto, S.H., M.Hum. 195

BAGIAN KETIGA
Membangun Bangsa Sadar Konstitusi **215**

18 Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 217

19 Pancasila Sebagai *Grand Design* Pengkajian Konstitusi
Dr. Mochamad Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H. 229

20 Diperlukan Pengaturan Ketentuan Politik Hukum dalam UUD 1945
Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.H. 236

21 Presidensial, Buruk Rupa Cermin Dibelah
Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H. 244

22 Menggugat Superiorisasi Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu
Prof. Dr. Wahyono, S.H., M.S. 248

23 Pengaruh *Gender Mainstreaming* Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Perempuan di Indonesia Menurut UUD 1945
Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.
Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. 269

24 Problematika Hukum Pascayudisial Review UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., CN 291

25 Dampak Liberalisasi Ketenagalistrikan
Prof. Dr. Indrati Rini, S.H., M.S. 298

BAGIAN KEEMPAT
Pembaruan Penyelenggaraan Pemerintahan **309**

26 Ombudsman Mendorong Pelayanan Publik yang Bertanggung Jawab
Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. 311

27 Visi Besar Tanpa Transformasi Birokrasi
Dr. Ir. Sudarsono Harjosoekarto, M.A., S.H. 321

28 Hubungan Pusat-Daerah dan Konstelasi Demokrasi di Indonesia
Prof. Dr. Aminudin Ilmar, S.H., M.H. 327

29 Problematika Politik Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Desentralisasi di Indonesia
Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. 335

30 Sistem Pengawasan Eksternal VS Internal Penegak Hukum dalam Konteks Hukum Administrasi Negara
Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. 380

BAGIAN KELIMA
Pengembangan Lembaga dan Pranata Hukum **393**

31 Gagasan Pengadilan Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu 1999: Suatu Tinjauan Sejarah Hukum
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. 395

32 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Prof. Dr. Hj. Yuhari Robingu, S.H., M.S. 408

33 International Law, Rules And Principles For Disaster Management
Prof. IBR. Supancana, S.H., M.H., Ph.D. 425

34 Amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Gagasan Pembaruan Hukum Pidana Anak Indonesia)
Prof. Dr. Paulus Hadi Suprapto, S.H., M.H. 435

35 Undang-Undang Cukai Tahun 2007: "Sebuah Kegamangan yang Membelenggu"
Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.H. 446

36 Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan
Dr. Kamarullah, S.H., M.H. 456

37 Kejahatan Internasional dalam RUU KUHP
Dr. M. Sholehuddin. S.H., M.H. 470

38 Partai Politik dan Kualitas Lembaga Legislatif
Dr. Ir. Tri Pranadji, M.Si., APU 478

39 Reformasi dan Modernisasi Sistem Perpajakan Nasional dalam Kerangka Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. 496

40 Eksistensi Kelembagaan Mediasi Perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia Terhadap Sistem Aturan Hukum
Dr. Febrian, S.H., M.H. 507

41 Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Lokal
Dr. Agus Surono, S.H., M.H. 513

42 Beda Karakter Yuridis Antara Notaris dan PPAT Serta Akta Notaris–PPAT
Dr. Habib Adjie, S.H., M.H. 544

43 Membangun Paradigma Baru Hubungan Negara dengan Organisasi Masyarakat Sipil
Dr. Cecep Effendi 548

Daftar Indeks **563**

Biodata Penulis **573**

Bagian Pertama

Arah Pembangunan Hukum Indonesia

RAJAWALI PERS

1

HUKUM PROGRESIF: AKSI, BUKAN TEKS

Oleh:
*Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.**

HUKUM PROGRESIF adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum. Cara berhukum tidak hanya satu; melainkan bermacam-macam. Di antara cara berhukum yang bermacam-macam itu, hukum progresif memiliki tempatnya sendiri.

Untuk membuat deskripsi yang jelas mengenai hukum progresif, maka ia dapat dihadapkan kepada cara berhukum yang positif-legalistis. Dalam cara berhukum terakhir, maka berhukum adalah menerapkan undang-undang. Cara berhukum yang demikian ini semata-mata berdasarkan undang-undang (*alles binnen de kader van de wet*) atau "mengeja undang-undang." Di sini orang tidak berpikir jauh kecuali membaca teks dan logika penerapannya. Cara berhukum seperti ini adalah ibarat menarik garis lurus antara dua titik. Titik yang satu adalah (pasal) undang-undang dan titik yang lain adalah fakta yang terjadi. Segalanya berjalan secara linier, sehingga cara berhukum sudah seperti mesin otomatis. Paul Scholten menyebutnya sebagai *"hanteren van logische figuren"* (Scholten, 1954), sedang O.W. Holmes mengatakannya sebagai *"a book of mathematics"* (Holmes, 1963).

Dihadapkan kepada cara berhukum tersebut di atas, maka hukum progresif bekerja sangat berbeda. la tidak berhenti pada membaca teks dan menerapkannya seperti mesin, melainkan suatu aksi atau usaha (*effort*). Cara berhukum memang dimulai dari teks, tetapi tidak berhenti hanya sampai di situ melainkan mengolahnya lebih lanjut, yang disebut aksi dan usaha manusia itu. Dengan demikian, maka cara berhukum secara progresif itu lebih menguras energi, baik pikiran maupun empati dan keberanian.

Cara berhukum yang demikian itu bersifat non-linier, oleh karena adanya faktor aksi dan usaha manusia yang terlibat di dalamnya. Masuknya faktor atau

---

*Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

keterlibatan manusia itu menyebabkan bahwa berhukum itu tidak mengeja teks, melainkan penuh dengan kreativitas dan pilihan-pilihan. Scholten mengatakan, bahwa dalam pembuatan putusan-putusan hukum selalu terjadi suatu lompatan (*een sprong*) dan oleh karena itu bersifat non-linier. Dengan demikian, hukum bukan suatu proses logis semata. Homes merumuskannya dengan kata-kata. "*the life of the law has not been logic: it has been experience.*" Pengalaman tersebut memberi isi kepada teks hukum. Seorang hakim, misalnya, akan memutus berdasarkan keadaan (*the felt necessities of the time*), kendatipun bertolak dari teks hukum.

Keterlibatan manusia secara aktif juga berarti melibatkan empati, nilai-nilai, keberanian dan lain-lain. Ronald Dworkin menyebutnya "*the moral reading of the law*". Dengan demikian maka berhukum tidak dilakukan dengan mengutak-atik teks undang-undang dan menggunakan logika, melainkan dengan akal sehat dan nurani. Bukan dengan *logos* (logika), melainkan *holos* (*wholeness*) atau seluruh potensi yang ada pada manusia.

Dalam gagasan hukum progresif, maka hukum itu adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kendatipun berhukum itu dimulai dari teks, tetapi selanjutnya pekerjaan berhukum itu diambil-alih oleh manusia. Artinya, manusia itulah yang akan mencari makna lebih dalam dari teks-teks undang-undang dan kemudian membuat putusan.

Berhukum secara progresif juga dapat diartikan sebagai menguji batas kemampuan hukum. Kalau dikatakan, bahwa menjalankan hukum itu adalah menciptakan keadilan dalam masyarakat, maka berhukum itu adalah upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Berhukum dengan teks semata tidak otomatis menciptakan keadilan. Oleh karena itu, orang membedakan antara "keadilan menurut teks' (*formal/legal justice*) dan keadilan sebenarnya (*substantial justice*). Paul Scholten mengatakan, bahwa keadilan itu (memang) ada di dalam undang-undang, tetapi (masih) harus ditemukan (*het recht is in de wet, maar het moet nog gevonden warden*). Dengan demikian, maka berhukum itu tidak persis sama dengan menerapkan undang-undang, melainkan suatu usaha untuk memunculkan keadilan yang tersimpan di dalamnya. ltulah makna menguji batas kemampuan hukum.

Para hakim bukanlah legislator, karena tugasnya adalah melakukan ajudikasi (*ajudication*) atau memeriksa dan mengadili. Tugas membuat undang-undang itu ada dalam ranah legislasi. Kendatipun demikian pada akhirnya hakimlah yang menentukan apa yang dikehendaki oleh undang-undang itu. Hakim memang harus memutus berdasarkan hukum, tetapi sesungguhnya ia tidak hanya mengeja teks undang-undang, melainkan memutuskan apa yang tersimpan dalam teks tersebut. Seperti dikatakan oleh Dworkin di atas, memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*textual reading*), melainkan menggali moral di belakangnya (*moral reading*). Dengan demikian, hakim sesungguhnya juga "membuat hukum" pada tingkatan lebih tinggi.

Hukum progresif itu tidak pernah berhenti, melainkan terus mengalir mewujudkan gagasannya, yaitu hukum untuk manusia (Rahardjo, 2007). Filsafat yang melatarbelakangi hukum progresif adalah bukan "hukum untuk hukum", melainkan "hukum untuk manusia." Hukum itu tidak sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan. Hukum yang dipersepsikan sebagai sebuah institut yang otonom penuh, dengan logikanya sendiri dan sebagainya, berpotensi menghambat usahanya untuk menjadikan hukum menjadi sebuah institut yang melayani dan membahagiakan manusia (Rahardjo, 2009).

Daftar Referensi

Holmes, Oliver Wendell. *The Common Law*. Boston: Little. Brown and Company, 1963.

Rahardjo, Satjipto, Biarkan Hukum Mengalir - Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

————————. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Scholten, Paul. *Algemeen deel* dari *Asser's inleiding tot de beoefening van het Nederlandsch burgerfijk recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1954.

2

PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM BERKEADILAN

Oleh:
*Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si.**



Orientasi

Membangun sistem hukum nasional, lebih luas dari hanya sekadar memproduksi sekumpulan peraturan tertulis dan norma-norma belaka. Di luar peraturan dan norma tersebut, terdapat elemen-elemen lain yang tersusun dalam jalinan interaksi yang idealnya bermuara pada pencapaian tujuan dan kepentingan nasional.

Di samping itu, perlu pula dipahami bahwa pembangunan sistem hukum nasional adalah suatu proses berkelanjutan yang melintasi waktu, peristiwa, dan kondisi khas di setiap periode. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tiba-tiba mempunyai sistem hukum yang mapan. Konsep *"Rule of Law"* yang hadir sebagai anak kandung hukum modern, sebenarnya adalah hasil pergulatan dan jatuh bangunnya susunan masyarakat, mulai dari *Tribal Society, Aristocratic Society* sampai dengan *Liberal Society* (Unger, 1976).

Di balik setiap periode, di belakang susunan masyarakat serta di setiap sisi gelap dan terang norma-norma yang dijadikan pedoman, tersirat secara laten nilai-nilai yang menjadi dasar berlakunya norma. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai dan ide fundamental tersebut biasanya dicantumkan dalam falsafah dan konstitusi negara.

Pembukaan UUD 1945 merupakan fundamen pembangunan hukum nasional yang mengarah pada cita-cita negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machsstaat*). Prinsip dasar ini

*Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak.

dicantumkan dalam Batang Tubuh Perubahan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."

Negara hukum yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *democratische rechtsstaat* (negara hukum yang demokratis). Konsekuensi negara hukum yang demokratis adalah adanya supremasi konstitusi sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Akan tetapi, lebih dari setengah abad kemerdakaan, pembangunan sistem hukum nasional belum juga selesai. Istilah "*belum selesai*" dimaksud adalah bagaimana menjadikan negara hukum itu sebagai organisasi yang secara substansial mampu menjadi rumah yang menyenangkan, menyejahterakan, dan membahagiakan bangsa Indonesia. Hukum itu diciptakan bukanlah semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu, untuk mencapai tujuan luhur, yakni keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat (Satjipto Rahardjo, 2003).

Jika kita perhatikan hukum positif yang sekarang berlaku, ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu dicermati. Di antaranya adalah: Apakah ada jaminan bahwa hukum positif itu bersesuaian dengan hukum nasional yang hendak kita bangun? Apakah elemen sistem hukum itu mampu menjadi pilar bangunan hukum nasional sebagaimana cita-cita konstitusi? Benarkah hukum positif yang berlaku telah menggambarkan ciri hukum nasional sebagaimana dikehendaki dalam konstitusi? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan kecermatan dan upaya terus-menerus untuk meneguhkan terbentuknya sistem hukum nasional yang "*semangat*"–nya mengalir dari *rechtsidee* yang terkandung di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Memperkaya Paradigma dan Teori Pembangunan Hukum

Paradigma dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini dan menentukan cara memandang gejala yang ditelaah (Liek Wilardjo, 1990). Di bidang ilmu hukum, paradigma utama yang masih digunakan sampai dengan saat ini adalah paradigma positivistik yang memandang hukum sebagai entitas yang mampu mencukupi dirinya sendiri secara koheren dan bebas nilai.

Turunan paradigma ini dapat kita temukan dalam teori "*hukum murni*" sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, dalam bukunya "*Reine Rechtslehre*" pada 1934 yang cukup kentara dalam pemikiran hukum di Indonesia. Teori "*hukum murni*" berisi konsep-konsep yang ditarik dari isi norma hukum positif. Apa yang tidak bisa ditemukan dalam isi norma hukum positif tidak bisa memasuki konsep hukum. Arah analisisnya adalah pada struktur hukum positif, bukan pada penjelasan psikologis dan ekonomis, ataupun penilaian moral politik yang menyangkut tujuan-tujuannya.

Ditegaskan pula bahwa apa yang dikemukakan oleh ilmu hukum harus didasarkan pada tata hukum positif atau pada perbandingan isi dari sejumlah tata hukum. Dengan demikian hukum terpisah dari filsafat keadilan dan sosiologi hukum. Diharapkan melalui cara ini hukum dapat mencapai kemurnian metodenya.

Di horizon berbeda, muncul paradigma lain yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam menjelaskan entitas hukum. Salah satunya adalah paradigma konstruktivisme. Dalam paradigma ini, hukum dipandang sebagai sesuatu yang relatif terbentuk dan dipahami secara transaksional, subjektif, dan dialektik.

Paradigma konstruktivisme memandang hukum bersifat plural dan plastis. Dikatakan plural karena hukum itu diekspresikan ke dalam berbagai simbol, bahasa, dan wacana. Sifat plastis hukum diartikan sebagai sifat dan ciri hukum yang dapat direntangkan dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia.

Dari paradigma konstruktivisme ini mengalir teori-teori hukum yang lebih bersifat empiris. Roscoe Pound muncul dengan konsep "*sociological jurisprudence*", yang kemudian disusul Karl Llewellyn dan Jerome Frank dengan "*realistic jurisprudence*" (*legal realism*). Roberto Unger juga muncul dengan "*critical legal studies*"-nya. Pemikiran alternatif ini muncul sebagai reaksi atas pandangan yang memandang hukum positif bekerja secara mekanik, deterministik, dan terpisah dari hal-hal di luar hukum, sebagaimana diintrodusir oleh Dekan *Harvard Law School*, C. Langdell pada 1870. Ia menyamakan hukum dengan ilmu eksakta di mana para yuris bekerja di perpustakaan sebagai laboratoriumnya (Dragan Milovanovic, 1994).

Dalam teori hukum yang empiris, hukum dipandang sebagai bagian dari fenomena sosial. Ada hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat. Hasil akhir dari penerapan hukum dalam memengaruhi masyarakat menjadi perhatian. Oleh karena itu, perlu pertimbangan pada aspek sosial lain, baik aspek ekonomi, sosial maupun filosofis.

Keberagaman paradigma dan teori yang digunakan untuk melihat dan menjelaskan fenomena hukum ini, dapat digunakan sebagai referensi membangun sistem hukum nasional. Tinggal kita menentukan pilihan paradigma dan teori yang akan menjadi *mainstream*. Norma kritikal dalam melakukan pilihan ini tentu saja kembali pada UUD 1945 sebagai kontrak sosial tertinggi bangsa Indonesia.



Pelaku Pembangunan Hukum Nasional

Pada awalnya tidak ada keragu-raguan mengenai kemampuan negara untuk secara otonom dan mutlak mengatur serta menata kehidupan masyarakat. Hukum menjadi semacam alat di tangan kekuasaan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki. Sejak kita mengetahui kompleksitas kekuasaan dalam

masyarakat, yaitu tentang kehadiran kekuasaan lain di luar negara, maka perencanaan pembangunan hukum menjadi tidak sederhana lagi. Kita mengetahui risiko besar yang harus kita tanggung manakala perencanaan kita gagal mengantisipasi dinamika masyarakat dan apa yang dapat dilakukan masyarakat (Satjipo Rahardjo, 2008).

Sampai dengan saat ini masih dirasakan bahwa segala sesuatu masih berjalan dalam koridor *state base*. Kekuatan dan potensi masyarakat masih belum mendapatkan saluran yang rapi dan terpelihara. Dalam menentukan apa objek yang akan diatur dan bagaimana mengatur objek tersebut, partisipasi masyarakat baru sampai pada "*penyerapan aspirasi*" dan "*dengar pendapat*" yang boleh "*diterima*" dan boleh pula "*ditinggalkan.*"

Terpinggirkannya peranan masyarakat dalam proses pembangunan hukum, membawa konsekuensi yang tidak kecil. *Pertama*, hukum kemungkinan besar hanya akan menjadi teks yang tidak memiliki makna sosial yang signifikan. *Kedua*, lebih jauh lagi hukum dapat menjelma menjadi beban atau faktor pemicu benturan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengimbangi kekuatan negara, perlu dibangun tradisi pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people centered development*).



Elemen Sistem Hukum Nasional

Secara umum dapat dirumuskan bahwa sistem adalah sesuatu yang terdiri dari elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sunaryati Hartono (1991), mengemukakan bahwa paling sedikit ada dua belas unsur yang saling memengaruhi dalam sistem hukum, yaitu nilai kehidupan berbangsa, filsafat hukum, budaya hukum, norma hukum, bahasa hukum, lembaga hukum, prosedur di lembaga hukum, sumber daya manusia, pendidikan hukum, sarana dan prasarana hukum, lembaga pembangunan hukum, serta anggaran pembangunan hukum.

Elemen-elemen yang berinteraksi dalam sistem hukum ini tidaklah statis, akan tetapi bersifat kontinyu dan bergerak dari dimensi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dengan melihat dinamika dan perkembangan nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, perlu kiranya dilakukan perencanaan pembangunan hukum dalam jangka yang cukup panjang. Sebab apabila perencanaan pembangunan hukum tersebut disusun dalam jangka pendek, kemungkinan akan terbentur pada panjangnya pembahasan di tingkat penyusunan rancangan undang-undang sampai dengan pengesahannya. Ini baru pada masalah waktu dan prosedur yang teknikal. Belum lagi bila kita melihat bagaimana masalah filosofi dan substansi hukum yang akan dibangun.

Di balik semua potensi masalah yang ada, hal terpenting yang perlu diperhatikan dari bekerjanya sistem hukum adalah kemampuannya menghadirkan

keadilan bagi masyarakat. Bagaimana "warna" dan "spektrum" keadilan yang dihadirkan tentunya tidak terlepas dari format "*grand design*" politik hukum yang disusun.



Hukum dan Keadilan

Socrates menyatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan. Plato mencanangkan suatu tatanan di mana hanya kepentingan umum yang diutamakan, yakni partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Lebih tepatnya ia mencanangkan suatu negara di mana keadilan akan dicapai secara sempurna (Bertens, 1999).

Pandangan tentang keadilan dari zaman klasik juga dikemukakan oleh Aristoteles. Bagi Aristoteles, keadilan hukum sama dengan keadilan umum.

Di zaman Romawi Kuno, muncul pemikiran Cicero (300 M) yang menyatakan bahwa hukum merupakan keharusan rasio manusia. Seperti halnya pemikiran di zaman Romawi Kuno, rasio manusia yang dimaksud adalah rasio Ilahi. Jadi hukum merupakan keharusan kehendak Ilahi bagi manusia agar bisa hidup aman dan damai sebagai manusia (Carl J.Friederick, 1969).

Pada masa *Renaissance*, Thomas More hadir dengan pemikiran tentang susunan pemerintah di pulau yang tidak dikenal atau *Utopia*, yang melukiskan suatu susunan negara imaginer dengan susunan masyarakat yang sempurna. Tulisannya dimaksudkan sebagai kritik terhadap ketidakadilan yang terjadi di Inggris pada saat itu, khususnya untuk kaum bangsawan dan kaum kuat lainnya yang memerintah Inggris dengan menindas rakyat.

Pentingnya perlindungan hukum bagi kaum lemah, juga ditemukan dalam pemikiran Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, dan John Locke. Mereka adalah ahli-ahli yang muncul di era kebangkitan teori Hukum Alam abad XVII. Grotius mengatakan bahwa hukum itu ada karena adanya suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian ini terjadi semata-mata karena manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga selalu ada keinginan untuk hidup bermasyarakat. Hukum dan negara bertujuan untuk ketertiban dan keamanan.

Ide tentang hukum dan negara sebagai penjaga keamanan individu, juga datang dari Thomas Hobbes. Menurut Hobbes, tanpa hukum manusia yang satu akan menjadi serigala bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*). Dalam kondisi alamiah, manusia adalah serigala bagi yang lain. Tidak ada konsep adil atau tidak adil. Jika ingin adanya keadilan, harus ada peraturan yang mengatur. Untuk itu diperlukan adanya negara.

Selanjutnya, gagasan tentang negara dan hukum sebagai pelindung hak-hak kodrat manusia diperkenalkan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris.

Sebagaimana halnya pemikir hukum alam lainnya, Locke mendasarkan teorinya pada keadaan manusia yang *naturalis*. Berbeda dengan Hobbes yang menggambarkan keadaan *naturalis* manusia ada dalam keadaan *disorder*, Locke justru melihat manusia dalam keadaan *naturalis* adalah masyarakat yang penuh keteraturan. Keadaan ideal ini terjadi karena dalam keadaan *naturalis*, tidak ada hak-hak dasar manusia yang dilanggar. Negara dan hukum diciptakan untuk melindungi hak milik, hak hidup, dan kebebasan. Konsep dari Locke inilah yang menjadi asal mula konsep Hak Asasi Manusia yang masih dikenal sampai sekarang.

J.J. Rousseau sebagai penganut teori hukum alam abad XVIII bersama Montesquieu dan Imanuel Kant, melanjutkan pemikiran Locke. Menurut Rousseau, negara dan hukum merupakan *pribadi publik* dan *pribadi moral*, yang berasal dari kontrak sosial untuk membela dan melindungi kepentingan bersama, di samping kepentingan pribadi dan milik pribadi. Hasil kontrak sosial ini adalah terciptanya *kemauan umum*, yaitu kesatuan kemauan orang-orang yang telah melakukan kontrak sosial tersebut. Dengan adanya kontrak sosial, terjadi peralihan naluri manusia dari keadaan bebas tanpa batas ke situasi tertib dalam koridor *kemauan umum* yang berbasis keadilan dan kesusilaan.

Pandangan Locke mengenai *hak-hak alamiah* dan *asas pemisahan kekuasaan* diperkuat pula oleh Montesquieu. Pemikiran J.J. Rousseau tentang *kedaulatan rakyat* juga ikut meneguhkan ajaran Locke.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum dan negara sebagai pelindung hak-hak asasi warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Negara harus menjamin kedudukan hukum individu. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama, dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Hukum dan negara harus menjamin setiap warga untuk bebas di lingkungan hukum. Artinya kebebasan dalam batas norma-norma yang telah ditetapkan oleh undang-undang, karena undang-undang tersebut merupakan penjelmaan kemauan umum dari rakyat.

Teori-teori selanjutnya yang mengupas tentang keadilan, antara lain adalah seperti apa yang dikemukakan oleh John Rawls. Ia memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurutnya adalah *susunan dasar masyarakat*. Susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana produksi dan pasar kompetitif. Jelas bahwa Rawls memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerja sama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak dan kebebasan. Beban sosial meliputi kewajiban seperti pajak. Teori keadilan Rawls dikenal dengan *teori keadilan prosedural*, karena *keadilan dipahami sebagai hasil persetujuan melalui prosedur tertentu*.



Penutup

Bila kita bersepakat bahwa muara dari pembangunan sistem hukum nasional adalah terbangunnya sistem hukum nasional yang berkeadilan, maka kita harus segera melanjutkan upaya untuk mengoreksi setiap elemen sistem hukum baik pada aras paragdimatik maupun pada aras teknikalnya.

Bahwa konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memuat cita Negara Hukum Indonesia, memuat konsep *keadilan* yang berbeda dengan konsep *keadilan* yang berkembang di negara Eropa. Filosofi keadilan yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah *keadilan sosial* yang berakar pada *kolektivitas*. Sedangkan konsep keadilan berdasarkan "*rule of law*" di negara-negara Eropa, lebih berakar pada *perlindungan individual*.

Oleh karena itu, ada baiknya kita bersegera memusatkan perhatian dan upaya untuk membangun sistem hukum nasional yang mampu mengembalikan jati diri bangsa Indonesia. Dialog teoretik dan rekam jejak pemikiran Eropa sebagaimana digambarkan pada beberapa bagian dari tulisan ini, dapat kita jadikan pembanding untuk merasakan perbedaan "kehadiran keadilan" baik pada aras "idea" maupun "realitas."

Daftar Referensi

Bertens, K. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung, Alumni, 1991.

————————. *Paradigma Pembangunan Hukum Indonesia: Respons Terhadap Globalisasi Tanpa Mengorbankan Kepentingan Nasional dan Kesejahteraan Rakyat*.

Milovanovic, Dragan. *A Premier in the Sociology of Law*. New York: Harrow and Heston Publisher.

Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.

————————. *Merencanakan Pembangunan Hukum Dalam Era Demokrasi, Transparansi dan Perkembangan Sains*, Makalah, Seminar dan Temu Hukum Nasional, Yogyakarta, 2008.

Unger, Roberto Mangabeira. *Law in Modern Society: Toward Critism of Social Theory*. London: Collier MacMillan Publisher, 1976.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1986.

Wilardjo, Liek. *Realita dan Desiderata*. Duta Wacana University Press, 1990.

3

PEMBANGUNAN HUKUM: PERSPEKTIF PARADIGMA KOMUNIKATIF

Oleh:
*Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum.**



Kontemplasi Awal

ADA BANYAK PERISTIWA dalam tataran kehidupan dewasa ini, terutama dalam hal ini adalah kehidupan dunia hukum kita saat ini, yaitu adanya realitas, fakta bahwa sering terjadinya berbagai bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh negara melalui lembaga legislatif. Bahkan bentuk penolakan ini tidak jarang menimbulkan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan, baik oleh masyarakat sendiri ataupun kekerasan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum sendiri.

Sekilas penolakan ini diterjemahkan sebagai bentuk kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting keberadaan hukum yang diproduk oleh negara, namun jika dilakukan kontemplasi yang seksama dan mendalam maka terlihat sesungguhnya penolakan tersebut bukanlah hal yang sederhana seperti asumsi tersebut di atas.

Dengan mendasarkan pada pemahaman konsepsional penulis tentang hukum itu sendiri yang mendasarkan pada perspektif filsafat eksistensialis yang memberikan pemahaman akhir bahwa hukum sesungguhnya merupakan cara beradanya manusia, maka berbagai bentuk penolakan yang dilakukan pada esensinya adalah bentuk penolakan masyarakat karena dalam produk hukum yang dibuat tersebut tidak mampu memanifestasikan keberadaan manusia dengan pluralitas yang ada dalam hukum itu sendiri. Pembangunan hukum dewasa ini menekankan pada paradigma kekuasaan tanpa menyadari bahwa sesungguhnya pembangunan dalam bidang hukum pada galibnya adalah

---

*Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, menyelesaikan studi Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip Tahun 2007.

proses komunikasi yang dituangkan dalam bagan hukum antara negara dengan masyarakat, atau antara rakyat/masyarakat dengan sesamanya.

Masyarakat menyadari betul bahwa mereka memiliki sistem regulasi yang sejak awal ada dan tetap dipertahankan, sehingga ketika hadir sistem regulasi lain—meskipun dari negara—tetapi hukum negara tersebut dinilai dan dirasakannya tidak mampu menjadi media komunikasi nilai yang sudah terinternalisasi dengan baik, maka miskonsepsi, mispersepsi yang akan mengarah pada berbagai bentuk penolakan terhadap kehadiran hukum negara niscaya akan terjadi.



Manusia: Makhluk Komunikasi

Manusia memang unik, terhadap dirinya berbagai predikat dapat diberikan, mulai dari manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang berpikir, makhluk simbolik (homo simbolicum), homo faber dan lain sebagainya.[1] Pemberian berbagai macam predikat pada manusia ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat kompleks dan sempurna.

Demikian juga upaya mengungkapkan dan memahami keunikan manusia, berbagai aliran, paham dikembangkan guna bisa memahami manusia, namun selalu saja dirasakan pemahaman tersebut belum dan tidak pernah selesai. Salah satu paham atau aliran filsafat tersebut adalah eksistensialisme, suatu aliran yang berusaha memahami manusia tidak hanya dari sisi yang tampak saja (fenomena), tetapi juga berusaha memahami dari sisi dalam, semisal rasa cinta, kehendak, putus asa, perlunya orang lain, dan lain sebagainya. Pandangan eksistensialisme inilah sebagai pandangan atau pendekatan utama (*mainstraim*) yang digunakan dalam mencoba merekonstruksi pola dan hubungan hukum yang sifatnya positivistik, hegemonik, eksploitatif, diskriminatif menjadi pola dan hubungan hukum yang komunikatif.

Dan dalam perspektif eksistensialisme rekonstruksi relasi antara hukum negara dan hukum lokal, pada dasarnya dapat dilihat sebagai bentuk rekonstruksi hubungan antara para subjek, baik dalam posisinya sebagai individu maupun dalam kedudukan sosialnya, yang tercermin dalam masing-masing hukum (hukum negara/kapitalisme dengan hukum lokal/masyarakat), atau lebih dikenal dengan intersubjektivitas. Oleh karena itu, rekonstruksi relasi antara hukum negara dan hukum lokal dalam eksistensialisme dapat dikatakan sebagai bentuk rekonstruksi pemahaman intersubjektivitas.

---

[1]Liek. Wilardjo, *Realitas dan Desiderata*, Penerbit Duta Wacana University Press 1990, lihat juga Liek Wilardjo dalam *"Peran Paradigma Dalam Perkembangan Ilmu"*, Makalah Pada Simposium Nasional Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, 1998.

Subjek dalam eksistensialisme merupakan tema yang penting dalam pembicaraannya. Namun demikian, ada perbedaan pemahaman bagaimana intersubjektivitas tersebut harus dikonstruksi. Setidaknya ada dua pendapat sehubungan dengan keberadaan orang (subjek) lainnya terhadap eksistensi diri. *Pertama,* pendapat yang mengakui keberadaan orang lain hanya keberadaan orang lain tersebut "merupakan neraka bagiku",[2] pendapat ini dikemukakan oleh Sartre. Sampainya Sartre pada pendapat seperti ini, karena Sartre sebagai seorang eksistensialis, sangat menjunjung tinggi dan mengagungkan kebebasan individu.

Pandangan Sartre ini membawa pada konsekuensi konflik eksistensialisme yang tak terhindari, konflik ini terjadi lantaran keberadaan orang lain tidak selalu dihiraukan oleh kedirian sendiri. Sehingga apakah orang/pihak/komunitas lain tersebut tersisihkan dari ranah kehidupannya sebagai akibat dari manifestasi aktualisasi diri, tidak menjadi persoalan bagi dirinya. Dalam posisinya yang demikian penulis memang kurang menyetujui dengan pendapat Sartre tersebut. Karena mendasarkan pada asumsi atau pendapat inilah hukum negara yang mengatur masalah kehutanan, juga akan mengklaim sebagai bentuk eksistensi dari kapitalisme yang cenderung eksploitatif terhadap pihak lain.

Kedua, adalah pendapat yang mengakui pihak (subjek) lain, dan pihak lain tersebut memiliki peran yang besar terhadap perwujudan eksistensi diri, setidaknya demikian dikatakan oleh Kierkegaard, seorang eksistensialis. Bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menjadi makhluk hidup sendirian dan bereksistensi secara individual.[3] Karena hal itu tidak mudah dilakukan, maka pertanyaannya adalah mestikah dia menghentikan hubungan eksistensialnya dengan pihak lain, guna menemui kediriannya sebagai ketunggalan? Atas pertanyaan ini, Kierkegaard mengatakan bahwa jelas hal ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya memang Kierkegaard tidak secara langsung mengatakan bahwa hubungan dengan pihak lain (subjek) penting, sebab dalam melihat persoalan ini Kierkegaard melakukan loncatan yang radikal dengan mengatakan bahwa hubungan dengan Tuhan adalah bentuk pengakuan akan keberadaan orang atau subjek lainnya,[4] dan penulis menilai pemahaman ini belum mencerminkan bagaimana hubungan yang seharusnya diambil dalam kaitannya dengan subjek lainnya.

Adalah Jaspers seorang eksistensialis yang lebih tegas melihat persoalan ini, dan meletakkan pentingnya komunikasi antara para pihak (subjek) dalam kehidupan nyata. Eksistensi diri kiranya hanya bisa diaktualisasikan dalam

---

[2]Muzairi, Muzairi, M.A., *Eksistensialisme Jean Paul Sartre: Sumur Tanpa Dasar Kebebasan Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 59.

[3]M.A.W. Brower, *Sejarah Filsafat Barat Modern dan Sejaman,* (Bandung: Penerbit PT Alumni, 1980), hlm. 112.

[4]Muzairi, *op.cit.,* hlm. 58

dunia sosial hanya dengan komunikasi, dan komunikasi inilah yang merupakan substansi dasar dari intersubjektivitas. Bahkan menurut Jaspers: *"Existence is revealed and realized in communication and communications is only possible if I and my neighbour do not each make the other his tool, but meet in mutual affirmation of our respective freedoms* (Terjemahan bebasnya: Eksistensi ditampilkan dan direalisasikan dalam komunikasi, dan komunikasi itu hanya mungkin jika seandainya aku dan tetanggaku masing-masing tidak saling menjadikannya sebagai alatnya, akan bertemu dalam pengakuan timbal balik dengan menghormati kebebasan kita masing-masing). [5]

Dari apa yang dikatakan oleh Jaspers ini terlihat bahwa orang lain tidak dianggap sebagai objek, alat bagi orang atau pihak lain, tetapi orang lain tersebut ditangkap secara positif sebagai pribadi-pribadi yang berkembang dalam eksistensinya. Sehingga dalam perspektif eksistensialis keberadaan atau eksistensi diriku tampak dan riil berkat eksistensi orang lain, dan bukan sebaliknya keberadaan orang lain merupakan neraka bagi diriku, sebagaimana Sartre memahaminya.

Pentingnya komunikasi intersubjektif ini juga didasari pada realitas bahwa manusia dalam pandangan eksistensialisme hidup dalam suasana *Eigenwelt,* yaitu kesadaran diri, perhubungan diri yang secara khas hadir dalam diri manusia. *Eigenwelt* inilah yang kiranya menjadikan komunikasi begitu penting dalam kehidupan eksistensi manusia.

Bahkan komunikasi dalam eksistensialisme merupakan penyebab manusia tersebut berada dalam dunia sosialnya. Dalam aktivitas komunikasi tersebut pada hakikatnya manusia mengomunikasikan "dirinya sendiri" kepada yang lain, ia menyampaikan "aku"-nya, substansinya kepada yang lain, yang juga dinilai sebagai "aku", tetapi yang lain tersebut tetap saja menjadi yang lain.[6] artinya dalam proses komunikasi tersebut, orang lain tidak pernah berubah kedudukannya menjadi objek atau alat dari lainnya, tetapi tetap ditempatkan sebagai subjek yang memiliki kebebasan sebagaimana orang lain juga memilikinya.



Hukum: Komunikasi Antarbudaya

Seperti diketahui bahwa hukum dalam perspektif antropologis merupakan produk budaya di samping produk lainnya. Oleh karena itu, benturan antara dua sistem hukum yang berbeda dalam masyarakat sehingga menimbulkan persoalan sosial (kekerasan), bisa dimaknai sebagai benturan antara dua

[5]Lihat Noberto Bobbio, *The Philosophy of Decadentism, A Study in Existentialism,* (Oxford: Basil Blackwell, 1948), hlm. 49.

[6]Anton Bakker, *Antropologi Metafisik,* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), hlm. 149.

sistem budaya yang berbeda, yaitu benturan antara budaya hukum yang tidak tertulis dengan budaya hukum tertulis, benturan antara budaya kapitalis dan budaya subsisten dalam mengelola hutan, budaya individualis dengan budaya kolektivisme dan bentuk budaya lainnya. Benturan budaya ini seyogianya bisa dihindari, jika terjadi dialog atau komunikasi antara budaya, yaitu suatu bentuk komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan yang memiliki perbedaan budaya.[7]

Perbedaan budaya para komunikator pada satu sisi bisa menjadi penyebab disparitas di antara mereka yang bisa berakhir pada perbedaan persepsi yang muncul antara satu orang dengan orang lainnya. Dalam kondisi seperti ini, maka upaya penyamaan persepsi di antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan budaya menjadi penting, guna menghilangkan atau setidaknya mengurangi disparitas persepsi yang muncul, dan komunikasi adalah salah satu cara menghilangkan disparitas tersebut, dan hal ini bisa terjadi sepanjang dalam komunikasi tersebut bersifat efektif,[8] yaitu suatu sikap komunikasi yang setidaknya memenuhi unsur (1) saling keterbukaan, (2) empati, (3) merasa positif, (4) memberi dukungan, (5) merasa seimbang. Jika komunikasi efektif antarbudaya dapat terjalin seperti tersebut di atas, maka berbagai prasangka sosial terhadap keberadaan budaya lain bisa dihindari.[9]

Oleh karena itu, komunikasi antarbudaya hukum yang berbeda (hukum negara/lokal, hukum tertulis/tidak tertulis) dalam kondisi yang plural menjadi sangat penting perannya, karena komunikasi pada akhirnya akan menghindari berbagai macam klaim absolutisme yang ada pada masing-masing hukum, yang mengarah pada penggunaan kekuasaan yang secara intrinsik mesti ada dalam setiap hukum ditolak, dan menurut Nonet dan Selznick mengatakan bahwa penggunaan kekuasaan, paksaan dalam menerapkan hukum pada dasarnya merupakan proses dehumanisasi.[10]



Ilmu Hukum: Paradigma Komunikatif

Setelah melihat arti pentingnya komunikasi dalam tataran individu maupun budaya, pada bagian ini penulis mencoba melihat bagaimana sifat

---

[7]Istilah komunikasi antarbudaya untuk pertama kalinya dijelaskan oleh David K. Berlo dalam bukunya *The Process of Communication (an Introduction to Theory and Practice)* pada 1960, sedangkan istilah antarbudaya (interculture) untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang antropolog, yaitu Edward T. Hall pada 1959 dalam bukunya: *The Silent Language*. Lihat Alo Liliweri, Liliweri, Alo, W.S. *Gatra-gatra Komunikasi Antarbudaya*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 1.

[8]Lihat DeVito dalam Alo Liliweri, *Ibid*, hlm. 173.

[9]*Ibid*.

[10]Philippe Nonet & Philip Selznick (Rafael Eddy Bosco-Penerjemah), *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, (Jakarta: Penerbit Huma), hlm. 25.

ilmu pengetahuan sosial pada umumnya, terutama ilmu hukum seharusnya dibangun.

Belajar dari pengalamannya tentang kemunculan ilmu sosial kritis yang pada akhirnya terjebak pada tindakan praktis yang cenderung kepada kekerasan (karena menafikan yang lainnya), Jürgens Habermas berpendapat bahwa seyogianya ilmu sosial/humaniora dibangun atas pijakan komunikatif sebagai paradigma praksisnya. Artinya bahwa harus ada interaksi intensif dan terus-menerus dari para subjek dan objek dalam ilmu pengetahuan, guna menghindari sifat yang otoritatif, dan inti dari paradigma komunikasi dalam ilmu pengetahuan sosial adalah penciptaan solidaritas dan keadilan.[11]

Pandangan Jürgen Habermas terhadap sifat ilmu pengetahuan yang berpardigmakan komunikatif ini, pada dasarnya merupakan kritikan serta keprihatinan Jürgen Habermas sebagai salah satu tokoh aliran atau mazhab Frankfurt terhadap merebaknya rasionalitas instrumen seperti penerapan efisiensi dan efektivitas di berbagai bidang kehidupan yang justru membuat manusia mengalami ketidakbebasan dalam pengertian yang sebenarnya.[12]

Sesungguhnya apa yang dikritik oleh Jürgens Habermas terhadap sifat ilmu pengetahuan sosial yang positivistik, juga menjadi perhatian dari ilmuwan hukum, di antaranya Nonet & Selznick. Menurutnya hukum yang terbangun selama ini merupakan ilmu pengetahuan hukum yang berparadigmakan positivisme, di mana ruang publik didominasi oleh negara, dan hukum yang dihasilkan dari besarnya peran negara oleh Nonet dan Selznick disebut sebagai ciri hukum represif, yaitu hukum yang tidak memerhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah/diatur oleh hukum tersebut.[13]

Memang kemudian terjadi ingsutan dari hukum represif ke hukum otonom, namun demikian hukum otonom ini juga masih tetap tidak mengacu pada kepentingan orang atau individu yang riil dan konkret, tetapi masih mementingkan kelangsungan berbagai institusi yang secara spesial dibentuk oleh hukum itu sendiri.[14]

---

[11]Lihat Ibrahim Ali Fauzi, *Jürgen Habermas*, (Bandung: Penerbit Teraju, 2003), hlm. 124.

[12]Heru Nugroho, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 34.

[13] Setidaknya ada lima ciri hukum represif, yaitu *pertama*, institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik, hukum diidentifikasikan sama dengan negara dan disubordinasikan pada tujuan negara (*raison d'etat*). *Kedua*, langgengnya suatu otoritas merupakan urusan yang paling penting dalam administrasi hukum. *Ketiga*, lembaga-lembaga kontrol yang terspesialisasi, seperti polisi, menjadi pusat-pusat kekuasaan yang independen, mereka terisolasi dari konteks sosial yang berfungsi memperlunak, serta mampu menolak otoritas politik. *Keempat*, sebuah rezim "hukum berganda" (*dual law*) melembagakan keadilan berdasarkan kelas dengan cara mengonsolidasikan dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial. *Kelima*, hukum pidana merefleksikan nilai-nilai yang dominan, moralisme hukum yang akan menang. Lebih jauh lihat Philippe Nonet & Philip Selznick, *op.cit*., hlm. 3.

[14]Ada empat ciri hukum otonom, yaitu *pertama,* hukum terpisah dari politik. Secara khas, sistem hukum ini menyatakan kemandirian kekuasaan peradilan. *Kedua*, tertib hukum mendukung

Dalam perspektif kritis, tipe hukum represif maupun otonom dinilai sudah tercemar dari dalam, ikut menyebabkan ketiadaan-ketiadaan ketertiban sosial secara keseluruhan, dan bekerja terutama sebagai alat kekuasaan. Dalam tema ini, keberpihakan hukum pada golongan kaya (kapitalisme-*pen*) menjadi sangat jelas, serta merugikan dan menipu golongan miskin. Demikian juga terhadap tujuan hukum dan keadilan yang ingin dibangun, keduanya memiliki keyakinan yang tinggi terhadap sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, serta otonom.[15]

Melihat berbagai kelemahan yang ada pada dua sifat hukum sebelumnya (hukum represif dan hukum otonom), Nonet & Selznick menawarkan konsep hukum responsif, yaitu hukum yang mampu menampung berbagai ragam kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menelusuri pendapat Nonet & Selznick tentang gagasan hukum responsif ini, menurut penulis tidak lain adalah usaha yang dilakukan oleh Nonet & Selznick memahami keberadaan hukum yang sedemikian pluralnya, dengan tentunya segala implikasi yang mungkin timbul jika hukum yang plural tersebut tidak terakomodasi dalam berbagai ruang kehidupan. Hal ini bisa dilihat dari, dikutip pendapat Bickel oleh Nonet & Selznick dalam melihat keberadaan hukum itu sendiri yang menyatakan bahwa di zaman modern (saat ini) sesungguhnya bermunculan berbagai macam peraturan yang memperlihatkan taraf perbedaan yang cukup signifikan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Semua peraturan yang ada tersebut bersifat otoritatif, dan bahkan ada yang lebih otoritatif dari yang lainnya. Sehingga yang terpenting dalam hal ini, menurut Nonet & Selznick adalah bagaimana mengakomodasi atau bahkan mengelaborasi berbagai kewajiban perilaku yang muncul dari berbagai macam peraturan tersebut.[16]

Berkenaan dengan konsep pluralisme hukum, tawaran Nonet & Selznick akan hukum responsif adalah menarik secara teoretik. Dikatakan demikian, karena secara substansial apa yang terkandung dalam hukum responsif memiliki kesesuaian dengan etika yang hendak dibangun dalam pluralisme hukum itu sendiri. Sebagai contoh moralitas yang mendasari pada hukum responsif adalah moralitas sipil berupa kerja sama.

Berbagai alternatif guna menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang ada dimungkinkan oleh hukum responsif, artinya hukum (hukum negara-*pen*) bukanlah satu-satunya sarana yang bisa digunakan dalam menyelesaikan

---

"model peraturan" (*model of rules*). Fokus pada peraturan membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat, pada saat yang sama, ia membatasi kreativitas institusi-institusi hukum maupun risiko campur tangan lembaga-lembaga hukum itu dalam wilayah politik. *Ketiga*, prosedur adalah jantungnya hukum. *Keempat*, ketaatan pada hukum dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna yang berlaku, harus disalurkan melalui proses politik. Lebih jauh lihat Philippe Nonet & Philip Selznick, *Ibid*, hlm.44.

[15] *Ibid,* hlm. 3-4.

[16] *Ibid*, hlm. 71-72.

persoalan yang ada.[17] Dalam hukum responsif, integrasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat menjadi sangat penting, artinya dalam perspektif pluralisme di mana mengakui berbagai hukum yang ada dalam masyarakat memperoleh tempat dalam hukum responsif ini.

Pemikiran Nonet & Selznick ini memberikan inspirasi kepada Prof. Satjipto Rahardjo, untuk melemparkan gagasan tentang hukum progresif. Gagasan hukum progresif ini muncul dari suasana ketidakpuasan, terutama kinerja penegakan hukum[18]. Meskipun terinspirasi pemikiran Nonet & Selznick, namun ada beberapa hal yang menarik dari pemikiran, ide atau gagasan tentang hukum progresif ini, yaitu hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo bersifat membebaskan, yaitu membebaskan diri dari sekalian dominasi suatu tipe hukum liberal, terutama kapitalisme. Demikian juga hukum progresif dinilai mampu membebaskan diri dari belenggu prosedural pada sistem penegakan hukum, yang berakhir pada pengabaian tujuan-tujuan manusiawi itu sendiri, berupa kebahagiaan dan lain sebagainya.[19]

Sampainya gagasan tentang hukum progresif ini, didasari pada kenyataan bahwa ilmu hukum yang dewasa ini dijadikan pedoman bersifat khas, yaitu institusi yang euro sentris, yaitu hasil perkembangan pengorganisasian masyarakat di Eropa yang meliputi sosial, politik, ekonomi, kultur, dan lain sebagainya. Ada satu hal penting yang diingatkan oleh Satjipto Rahardjo ini yaitu bahwa warisan hukum Eropa ini memperlihatkan watak feodal dan liberal, di mana tidak semua masyarakat/negara memiliki watak atau kultur hukum yang demikian. Salah satu watak yang terlihat dari sistem hukum yang feodal dan liberal ini, menurut Satjipto Rahardjo, adalah watak mengatur dan membatasi hak yang ada pada masyarakat, watak seperti ini cenderung bersifat diskriminatif, mengingat pluralnya kondisi masyarakat yang ada.[20]



Hukum yang Komunikatif: Pengertian dan Substansi

Dari paparan di atas, terlihat bahwa komunikasi merupakan salah satu esensi kehidupan, baik pada tingkat individual yang sifatnya lebih riil dan konkret, tingkat sosial maupun pada ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan

---

[17]*Ibid*.

[18]Pemikiran tentang hukum progresif ini dilontarkan setiap saat pada setiap kesempatan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, dan terakhir pemikiran beliau bisa dilihat dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Kesinambungan, Merobohkan, dan Membangun*. Jurnal Hukum Progresif, Volume 1/Nomor 1/ April 2005 Penerbit Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 2/Nomor 1/April 2006. Penerbit Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

[19]Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang ….Ibid*, hlm. 13.

[20]*Ibid*. hlm. 29-31.

komunikasi diharapkan berbagai persoalan, pesan, kehendak, keinginan dapat diketahui oleh pihak lain. Akan tetapi, tidak hanya diketahui saja, yang terpenting dari proses komunikasi tersebut adalah upaya memahami pihak lain dengan segala persoalan yang ada padanya jauh lebih penting.

Mendasarkan pada arti pentingnya komunikasi dalam setiap lapangan kehidupan, serta persoalan yang muncul dalam disertasi ini berupa kekerasan sebagai akibat pola dan bentuk relasional antara hukum negara dan hukum lokal yang bersifat positivistik, hegemonik, eksploitatif, dan apokaliptif, penulis menawarkan perlunya rekonstruksi pola dan hubungan hukum yang lebih komunikatif.

Perlu digarisbawahi bahwa tawaran konsepsional ini bukanlah semacam dogma hukum, sebab biasanya suatu dogma akan sangat mudah terjebak pada absolutisme, yang dalam perspektif pluralisme merupakan hal yang dihindari. Sesungguhnya konsep hukum yang komunikatif ini lebih didasari pada upaya menurunkan (*derivat*) etika pluralisme, yang lebih abstrak sifatnya, ke tataran yang lebih konkret.

Rekonstruksi pola dan bentuk hubungan yang dilandasi pada etika pluralisme ini, akan menempatkan hukum negara bukanlah satu-satunya hukum yang paling benar, dan paling berkuasa dalam menentukan arah kehidupan suatu kelompok masyarakat tertentu. Sebab sesungguhnya di samping hukum negara, masih ada hukum lain, seperti hukum lokal, hukum agama, yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama seperti hukum negara. Bahkan dapat dikatakan kemunculan hukum lokal sesuai dengan keinginan dan tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut.

Dalam situasi seperti ini, maka ketegangan antara norma yang ada dalam hukum dengan nilai yang ada dalam masyarakat, seperti halnya yang sering muncul dengan pemberlakuan hukum negara, bisa dihindari. Karena hukum yang muncul ke permukaan, tidak lain dari pemberian bingkai norma hukum atas nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Itulah yang menyebabkan sehingga hukum lokal menjadi begitu lekat dalam kehidupan masyarakatnya. Kelekatan dan keeratan mana dikarenakan antara hukum yang ada tidak mengalami ketegangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut.

Demikian juga sebaliknya, hubungan yang didasari pada etika pluralisme hukum ini akan menyadarkan kepada hukum lokal, bahwa di samping keberadaan dirinya sebagai salah satu sistem regulasi yang ada, dalam konteks kehidupan bernegara ada hukum lain, yaitu hukum negara, yang kemunculannya merupakan suatu kenicayaan politik dalam suatu negara. Oleh karena itu, hukum negara dan hukum lokal tidak bisa saling menegasikan satu dengan yang lainnya, sebab sikap menegasikan itu sendiri merupakan sikap yang tidak didasari pada etika pluralisme, dan komunikasi ataupun dialog antara kedua sistem tersebut menjadi sangat penting dalam rangka menghindari obsolutisme dalam melihat keberadaan hukum masing-masing.

Secara hipotetik, jika hukum yang komunikatif ini dikembangkan menjadi paradigma dalam pembangunan hukum di Indonesia, maka pengakuan akan pluralisme hukum tidak hanya sebatas pada pengakuan simbolik dan retoris saja, sehingga benturan antara hukum negara dengan hukum lokal lainnya yang akan mengarah pada kekerasan dapat dihindari.

Mungkin pertanyaannya adalah apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum yang komunikatif, dan bagaimana substansi yang ada dari konsep hukum yang komunikatif ini? Suatu pertanyaan yang akan muncul ke permukaan sehubungan dengan banyaknya gagasan pola dan bentuk hukum yang mestinya dibangun.

Secara sederhana pengertian hukum yang komunikatif ini adalah *bentuk hukum yang mampu berfungsi sebagai sarana komunikasi, baik lisan maupun tulisan, di antara subjek hukum akan keberadaan dirinya masing-masing*. Pengertian ini tentunya beranjak dari arti pentingnya komunikasi dalam kehidupan, baik pada tataran individu (manusia sebagai makhluk komunikasi/*homo comunico*), dalam tataran budaya, di mana pertemuan antara dua sistem hukum yang berbeda dalam suatu sistem sosial kehidupan bisa dimaknai juga sebagai dialog atau komunikasi antarbudaya, serta perlunya membangun suatu ilmu yang berparadigmakan komunikatif.

Seperti diketahui, bahwa dalam hukum lokal (tidak tertulis) berbagai ketentuan yang terdapat di dalamnya bisa dimaknai sebagai bentuk sarana komunikasi antarsubjek hukum mengenai apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Bagaimana masing-masing individu harus berada dan mengaktualisasikan diri dalam dunianya, baik dalam kaitannya dengan sesama, alam semesta, maupun aktualisasi diri dengan sang pencipta, dapat dilihat dari hukum yang tidak tertulis tersebut. Demikian juga halnya dengan hukum negara, keberadaannya dapat dilihat sebagai bentuk peralihan dari wacana lisan (hukum yang tidak tertulis) menjadi wacana tulisan (hukum yang tertulis), di mana dalam perspektif komunikatif, isinya tidak lain adalah komunikasi berbagai kepentingan, keinginan, kehendak yang berbeda-beda dalam masyarakat yang serba plural.

Dari pengertian yang sederhana ini terlihat bahwa hukum yang komunikatif bukanlah mengacu pada bentuk hukum yang baru, tetapi lebih mengarah pada upaya bagaimana hukum yang tercipta (baik hukum lokal/tidak tertulis maupun hukum negara/hukum tertulis) berfungsi sebagai media komunikasi. Fungsinya yang komunikatif ini bisa dimanifestasikan jika hukum yang terbangun tersebut bisa memiliki sifat terbuka pada sistem hukum lainnya, empati, merasa positif, memberikan dukungan serta menjunjung tinggi keseimbangan, yang kesemuanya merupakan prinsip dasar dalam komunikasi.[21]

[21]Lihat DeVito dalam Alo Liliweri, *loc.cit*.

Oleh karena itu, secara substansial hukum yang komunikatif memiliki ciri pada: *pertama,* pengakuan akan keberadaan masing-masing hukum, *kedua,* dikembangkannya kerja sama sebagai dasar moralitas hukum, serta *ketiga,* peningkatan yang optimal terhadap partisipasi dari masing-masing pihak. Ketiga nilai ini pada hakikatnya adalah nilai yang ada pada pluralisme hukum.

Secara substansial memang akan terlihat bahwa konsep hukum yang komunikatif ini memiliki kemiripan dengan gagasan hukum responsifnya Nonet & Selznick,[22] serta hukum progresifnya Prof. Satjipto Rahardjo, karena memang sesungguhnya gagasan hukum responsif dari Nonet & Selznick serta hukum progresifnya Prof. Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang berlandaskan pada pandangan hukum yang plural.

Namun yang terpenting dari ciri hukum yang komunikatif ini adalah dianutnya budaya kompromis (*compromise culture*), suatu budaya yang selalu berusaha menghargai nilai-nilai perbedaan dan berusaha untuk mencari kebenaran konteks yang akan disepakati bersama, tanpa menghilangkan perbedaan itu sendiri yang merupakan kondisi alamiah.

Konsep hukum yang komunikatif ini tidak hanya bersifat teoretik semata, tetapi dalam tataran praktisnya juga bisa menjadi pedoman bagi negara dalam menyusun dan mengambil kebijakan konstitusional yang bersifat regulatif, maupun yang bersifat aplikatif. Pernyataan secara tegas akan keberadaan hukum lain dalam hukum negara merupakan salah satu ciri hukum yang komunikatif sifatnya. Jika pernyataan secara tegas akan keberadaan hukum lain dinyatakan oleh hukum negara itu sendiri, maka pengadilan dalam melaksanakan peran dan fungsinya tidak menemui kesulitan dan hambatan yuridis dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapkan padanya. Bahkan tidak hanya itu, pada tingkat yang paling bawah sekalipun (penegak hukum/polisi) hukum yang komunikatif ini bisa dijadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut sengketa yang muncul dari klaim hukum yang berbeda.

[22]Kritik dan sekaligus tawaran alternatif responsif ini, didasari pada sepuluh karakter yang melekat pada sistem hukum, yaitu tujuan hukum, legitimasi, peraturan, pertimbangan, diskresi, paksaan, moralitas, politik, harapan akan ketaatan serta partisipasi. Kesepuluh karakter ini juga yang digunakan oleh Nonet & Selznick dalam mengklasifikasi bentuk atau tipe hukum represif, otonom dan responsif. Lihat Philippe Nonet & Philip Selznick hlm. 13.

4

MEMBANGUN ILMU HUKUM MAZHAB PANCASILA

Oleh:
*Prof. Dr. Prasetijo Rijadi, S.H., M.S.**
Sri Priyati, S.H., M.H.



Pendahuluan

Perkembangan sosial dan budaya dalam penyelenggaraan negara dewasa ini tampak ada yang sangat memprihatinkan dalam konteks ideologi. Betapa manusia-manusia yang mengklaim sebagai "produk dari proses reformasi" telah dengan lantang menafikan makna terdalam Pancasila. Bahkan menyebut nama Pancasila saja mereka enggan, karena dianggapnya tidak modern, tidak ilmiah, kampungan, pro-Orde Baru, antireformasi, atau Pancasila memang dinilainya hanya tinggalan sejarah yang tidak berarti bagi kelangsungan hidup bangsa. Hal ini tentu saja amat menyayat hati dan pemikiran terdalam saya sebagai bagian dari Warga Negara Republik Indonesia.

Secara naratif saya menjadi bertanya: Apa yang tidak tepat dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang siapa pun secara sadar harusnya mengakui sebagai nilai-nilai keabadian. Nilai-nilai Pancasila dengan *Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan* bagi saya adalah agung dan menakjubkan. Banyak pakar dari belahan dunia Barat dan Timur telah mengkaji Pancasila dengan kesimpulan yang senada *"betapa beruntungnya bangsa Indonesia yang telah mampu menggali dan berdiri di atas Pancasila."*

Untuk itulah saya terus merenung secara argumentatif bahwa ada sesuatu kekuatan yang sedang mau menjejakkan dirinya yang memandang remeh Pancasila. Apa yang merupakan tindakan destruktif terhadap Pancasila yang sekarang ini marak dengan aneka ragam gerakan yang "memarjinalkan Pancasila", sejujurnya perlu dikaji ulang untuk direkonstruksi dalam bangunan keilmuan termasuk dalam bidang Ilmu Hukum. Kita semua tahu bahwa

*Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

berdasarkan UUD 1945 adalah bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Namun, kini kita menyaksikan bahwa hukum di Republik ini sedang menapaki kisahnya di era reformasi yang tidak berwibawa. Hukum disinyalir benar-benar ada dalam titik ketidakberdayaan melawan keangkuhan sosial (lihat berbagai kerusuhan sosial yang terjadi) dan dominasi politik (kekerasan yang muncul akibat konflik politik).

Perilaku publik menjadi sangat tidak merefleksikan nilai dasar Pancasila secara tepat. Pancasila pun ditafsir secara serampangan dan jauh dari kaidah awalnya untuk menata semua perikehidupan dan dimensi keilmuan untuk *berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan.* Maka perilaku komunitas publik sekarang ini yang cenderung adu kuat ala gerombolan telah mengingatkan pada kisah historis yang dilansir oleh Thomas Hobbes: *"homo homini lupus."* Siapa yang harus memangsa siapa dan siapa untuk berbagaimana dengan apa?

Semua itu (yang menistakan hidup dengan ber-Pancasila) tidak akan terjadi dalam kehidupan yang memiliki hukum atas jiwa terdalam Pancasila. Kenyataan kekerasan (fisik maupun psikologis) yang terus mengemuka sekarang ini adalah cerminan paradaban klasik (pra-sejarah) yang sepertinya belum tercerahkan. Kita semua harus menyadari bahwa Pancasila merupakan produk budaya dan pemikiran cerdas untuk melandasi semua dimensi kehidupan negara. Ilmu hukum adalah juga hasil dari proses keilmuan yang secara domestik mestinya dapat menyerap prinsip-prinsip utama Pancasila. Hukum yang bersandar terhadap Pancasila saya pastikan tetaplah ilmiah *("scientific-mind")* dan bukan kumpulan dogma semata-mata. Marilah kita memahami hal ini dengan mencermati arti penting ilmiah sebagai wujud penyatuan ilmiah dalam kerangka teoretis maupun praksis.



Apakah Ilmu Itu

Meresensi dan merefleksi ingatan atas buku pemikir "luar biasa" yang bernama Archie J. Bahm. Archie J. Bahm melalui karya pentingnya *What is Science?* tampak berupaya untuk memberikan penguasaan intelektual tentang ilmu secara substantif. Dengan mengetengahkan enam komponen dasar "sesuatu" itu dinamakan *"ilmu",* yaitu: *masalah, sikap, metode, aktivitas, kesimpulan* dan *efek*. Archie J. Bahm sesungguhnya telah melakukan pengkajian *luas* yang menjadikan "*ilmu"* memiliki karakteristik untuk dikenali sebagai ilmu dan yang bukan ilmu. Bagi Archie J. Bahm, langkah awal untuk memasuki dunia ilmu adalah *masalah*. Tanpa masalah tidak akan ada ilmu. "Jantung" ilmu adalah masalah yang dijawab secara ilmiah. Suatu masalah dianggap ilmiah apabila memiliki karakteristik: *comunicable*, dapat didekati dengan *sikap* dan *metode ilmiah*. Hanya masalah yang *comunicable* sajalah yang disebut *ilmiah*.

Bangsa Indonesia sudah menghadapi banyak masalah: bagaimana orang antri beras, antri minyak tanah, antri gas elpiji, antri sembako, dan lain sebagainya. Dalam kondisi demikian sesungguhnya kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mencibir Ilmu Hukum ataupun Pancasila. Bagaimana mungkin dalam sebuah negara yang memiliki Pancasila sedang antri penderitaan dan ilmuwan hukum asyik dengan pasal-pasalnya. Di satu sisi orang antri dan di sisi lain orang korupsi, sementara akademisi sibuk berargumentasi, sedangkan orang birokrasi sibuk dengan biaya administrasi. Maka masalah tersebut harus disikapi dengan pengembangan hukum yang mampu mengatur distribusi kebutuhan secara Pancasilais agar manusia-manusia Indonesia tidak egois seperti sekarang ini.

Maka Archie J. Bahm menjelaskan bahwa *sikap* ilmiah memiliki watak dasar: *keingintahuan, kespekulatifan, keobjektifan, keterbukaan, kesabaran,* dan *kesementaraan*. Dalam perjalanan waktu, meskipun seorang ilmuwan secara sadar dalam menyelesaikan masalah hanya menggunakan sebagian saja komponen ilmu, misalnya sikap dan metode saja, usahanya tersebut tetap ilmiah. Untuk itulah dalam melakukan tindakan penyelamatan rakyat janganlah menunggu semua sesuai dengan standar bakunya. Ada titik-titik kebijakan yang dapat ditempuh demi rakyat sebagai tujuan akhirnya. Penggunaan dana publik untuk rakyat merupakan langkah utama dalam menyelesaikan kekurangan kebutuhan publik.

Seseorang yang berhasil menggunakan satu metode tertentu dalam menyelesaikan masalah, maka itu pun sudah ilmiah. Dengan pernyataan demikian, Archie J. Bahm sesungguhnya hendak menyatakan bahwa keenam komponen ilmu tersebut adalah alternatif dan bukan kumulatif. Untuk itulah para pengambil kebijakan jangan segan mengambil langkah prakarsa untuk bertindak nyata. Satu saja sikap ilmiah diambil maka sebuah tindakan tetap dapat diukur secara ilmiah. Ini meneguhkan dan memotret sebagai seorang relativis untuk tidak segan-segan mencairkan diri dalam komunitas sosial. Pola pikir dan pola hidup ilmuwan yang jauh dari tradisi di mana dia hidup, sesungguhnya itu bukanlah ilmiah. Lebih tegasnya saya hendak katakan bahwa tidak ada dominasi keilmuan di antara penstudi ilmu, termasuk tidak ada yang dianggap paling ilmiah mengenai suatu objek kajian. Dengan demikian, seorang ilmuwan akan selalu berada dalam pendulum apa pun untuk menentukan sikap objektifnya tanpa mengabaikan realitas sosial budayanya.

Sikap mengetengahkan ukuran keilmiahan tanpa menjadikan keenam komponen secara kumulatif sebagai kriteria baku, semakin meneguhkan perspektif filsafat ilmu bahwa tidaklah ada jawaban tunggal yang tersepakati tentang apa yang menjadi karakteristik ilmu, sehingga A.F. Chalmers perlu bersuara:

> "… Ia menyangka bahwa ada suatu kategori 'ilmu' dan menganggap berbagai macam bidang pengetahuan, fisika, biologi, sejarah, sosiologi, dan

sebagainya. harus termasuk kategori-kategori itu atau tidak. Saya tidak tahu bagaimana karakterisasi umum tentang ilmu demikian dapat dikukuhkan atau dibela. Para filsuf tidak mempunyai jalan keluar yang bisa mensahkan suatu kriteria yang harus dipenuhi untuk menilai apakah suatu bidang pengetahuan dapat diterima atau dianggap 'ilmiah' …".

Dengan demikian, A.F. Chalmers telah mendeskripsikan adanya problem kolosal bagi filsafat ilmu dalam menghadapi "klaim" kondusif dalam memproyeksikan karakteristik ilmu. Ia menyatakan: "bahwa tidak ada konsepsi tentang ilmu yang abadi." Meskipun demikian, maka ilmu sepanjang yang terbaca dalam pustaka menunjuk pada tiga hal: pengetahuan, aktivitas, dan metode. Ketiga "muatan ilmu" ini merupakan sesuatu yang menjadi gambaran "sosok ilmiah" yang menamakan dirinya "ilmu."

Maka karakteristik ilmu secara akademik dapat saja tersitir sebagai *knowledge* yang reflektif, sistematis, kritis, *generality,* variabilitas, rasional, empiris, *communality*, logis, metodologis yang secara filosofis terimplifikasi ke dalam dimensi *ontologis*, *epistemologis* dan *aksiologis*. Berarti keenam komponen dasar ilmu dari Archie J. Bahm dalam optik filsafat ilmu dapat dikembalikan pada ketiga dimensi tersebut, yaitu apa yang dikaji oleh pengetahuan (*ontologi*) meliputi komponen masalah dan sikap, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan (*epistemologi*) yang mencakup metode dan aktivitas, serta untuk apa pengetahuan tersebut digunakan (*aksiologi*) yang terdiri atas simpulan dan efek. Semua ini sebenarnya ada dalam diri Pancasila, baik secara logik maupun dialektik serta taktik keilmuan.

Suatu pengetahuan terhadap hukum ataupun Pancasila tetap akan memiliki karakter keilmuan apabila memenuhi syarat-syarat ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Suguhan keenam komponen dasar ilmu dari Archi J. Bahm harus tetap dihayati rangkaian dinamika *"an adventure in idea."* Dari itulah saya senantiasa mengulang-ulang pandangan A.F. Chalmers bahwa: "setiap bidang pengetahuan dapat dianalisis sebagaimana apa adanya." Apalagi Paul Feyerabend telah menandaskan: ilmu tidak mempunyai segi-segi istimewa yang dapat menyatakan dirinya mempunyai keunggulan secara hakikat terhadap cabang-cabang pengetahuan lain seperti mitos purba atau *voodoo*.

Hal itu merupakan sisi dimensional yang dapat dikatakan bahwa ilmu hukum ataupun Pancasila tidak selalu membutuhkan kriteria-kriteria ilmiah agar dinamakan objek kajian yang ilmiah. Pancasila ataupun Ilmu Hukum akan tetap menjadi ilmiah sesuai dengan kesepakatan penstudinya. Bukankah kesepakatan merupakan hukum tertinggi bagi sebuah bangsa? Dalam tradisi kemasyarakatan perlu ada kesepakatan bahwa Ilmu Hukum di Indonesia harus dilandaskan pada Pancasila, dan Pancasila seyogianya menjadi panduan pembelajaran Ilmu Hukum. Langkah ini bukanlah salah sebab langkah ini sesuai dengan karakter perkembangan ilmu hukum dalam negara yang memang sepakat berdasarkan Pancasila.



Hukum adalah Kaidah dan Fakta

Berbagai kasus yang berserakan sekarang ini merupakan cermin tidak dihargainya hukum secara konsisten dalam sebuah kerangka sistem. Hukum cenderung difungsikan sesuai dengan selera masing-masing penggunanya termasuk Pancasila sedang mengalami nasib serupa. Kasus Pemilihan Kepala Daerah di banyak wilayah dengan sentuhan politiknya amat sangat membuktikan bahwa hukum dan Pancasila selalu dimain-mainkan sesuai seleranya. Apa yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara ataupun Sulawesi Selatan telah mengubah dunia hukum menjadi "pasar politik" yang mengakibatkan penegak hukum berlagak sebagai penentu nasib subjek hukum yang justru menimbulkan kekisruhan sosial. Inilah risiko yang dihadapi hukum sebagai ilmu yang bersentuhan dengan banyak bidang dan terangkai dalam sebuah sistem yang lepas dari pijakan dasar suatu negara. Hukum dikira sebagai sesuatu yang "berdiri di ruang hampa."

Terhadap hal ini saya ingat apa yang diungkapkan oleh A.H. de Wild bahwa "hukum bukanlah kosmos kaidah yang otonom." Lebih dari itu adalah bahwa hukum merupakan kompleks kaidah, hukum tidaklah gejala netral. Hukum berada dalam jalinan problem dan dinamika kemasyarakatan. Hukum dan fenomena sosial diletakkan pada tataran yang sama. Dalam suasana yang paling nyata adalah bahwa *"sein"* dan *"sollen"* tidak dapat dipisahkan. Hukum adalah suasana dari *"das sein"* yang di dalamnya ada *"das sollen"* untuk mendapatkan wujudnya. Pada hukum, fakta, dan kaidah selalu berjalan saling berimpitan: hukum adalah fakta dan kaidah sekaligus, kata D.H.M. Meuwissen. Bahkan Friedrich Karl von Savigny, tokoh Mazhab Sejarah berpesan: *"… that law can not be understood without an appreciation of the social milieu in which it has developed."* Untuk itulah hukum harus dipahami tanpa terlepas dari nuansa etis, sosiologis, politis, ekonomis, historis, maupun kultural. Konsekuensinya adalah bahwa ilmu hukum akan menarik perhatian publik dan penggunaan hukum nyaris mudah dimanipulasi atas nama ambisi yang mengabaikan jiwa Pancasila yang mengandung spirit: Tuhan, Manusia, Bangsa yang bersatu, Rakyat, dan Keadilan.

Hal tersebut senada dengan gagasan seorang Begawan ilmu hukum Indonesia Prof. Dr. Satjipto Rahardjo yang telah menggagas tentang *"Hukum Progresif"*, pandangan ini menyatakan:

> Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Ini menjadi modal penting bagi membangun kehidupan berhukum dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum menjadi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan tersebut. Hukum bukan raja, tetapi alat saja yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia.

> Hukum mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka hukum itu selalu berada pada status *law in the making*. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri dan tidak bersifat final. Setiap tahap dalam perjalanan hukum yang demikian itu adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik itu dibuat oleh legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Setiap putusan itu bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Dengan uraian tersebut, maka hukum progresif selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global. Karakteristiknya adalah menolak keadaan *status-quo*, ia memiliki watak pembebasan yang kuat, berparadigma "hukum untuk manusia," yang membuat kita bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan itu.

Dengan demikian, mengonstruksi perspektif yang kondusif-korelatif bagi pemahaman dan pemaknaan hukum sebagai norma yang memiliki momen sosial adalah signifikan. Masalah penggusuran warga stren kali ataupun PKL misalnya, tidaklah bisa hanya menggunakan paradigma positivistik semata dengan mengedepankan aturan-aturan tertulis yang tidak dibangun dengan mendengar suara publik. Peristiwa "antri minyak" dan "penggusuran PKL" tersebut harus disentuh dengan berbagai nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah negara. Penerapan hukum yang berbasis Pancasila yang terlihat timpang dan menimbulkan konflik sosial yang besar di Indonesia selama ini karena memang penerapan hukumnya mengabaikan watak dasar Pancasila.

Memahami hukum sebagai suatu sistem yang berwatak Pancasila adalah kebutuhan sebagaimana melihat hukum dengan mempergunakan *System Approach*. Wacana Ilmu Hukum menunjukkan rotasi historik watak hukum yang "*empiris*" maupun "*normatif*" yang dalam perkembangannya mengikuti jejak kemasyarakatan yang menurut Henry Maine bergerak secara evolusioner dari tipe tradisional ke tipe modern, dan "*the movement of the progressive societies has hitherto been a movement from Status to Contract*". Progresivitas ini bagi Max Weber niscaya membawa pula ritme hukum dari wujudnya yang menekankan *substansi* ke wujudnya yang *rasional* dan *formal*.

Kontekstualitas itu semua menandakan bahwa suatu aturan haruslah *iustum* sebagai norma yang mengandung kepastian dengan rujukan kompleksitas dimensinya. Negara menciptakan hukum bermuatan norma, memerintah sesuatu, pedoman perilaku, yang secara sosiologis acapkali didayagunakan sebagai instrumen kontrol "*law is governmental social control*" model Donald Black. Meski pemikiran ini banyak dicibir oleh pengagum aliran positivistik yang legalistik tanpa tahu kegunaannya. Maka adalah sesuatu yang sangat disayangkan apabila aliran atau mazhab demikian masuk pada wilayah hukum tanpa filter Pancasila. Hukum akan terlihat kering dan seperti ada di menara gading yang *enjoy* dengan dirinya sendiri tanpa kegunaan bagi publiknya.

Pemerintah tidak boleh kehilangan daya kontrol kepada laju mazhab yang mengabaikan Pancasila di Ilmu apa pun, apalagi ilmu Hukum. Masyarakat dan semua pihak tidak boleh kehilangan daya ketaatan kepada logika bangunan Ilmu Hukum model Pancasila. Ini benar-benar kondisi yang perlu perjuangan akademik, sehingga tidak sekadar menjadi angan utama saja.



Hukum dan Pancasila

Permasalahan hukum sangat beragam dan telah menjadi fokus sentral kajian Ilmu Hukum dengan persepsi dan visi yang berbeda. Apa yang terjadi sekarang perlu dihentikan apabila tidak ada titik keseimbangan pengajaran yang mengedepankan Pancasila. Terjadi dominasi reduksi normatif terhadap hukum yang mengakibatkan hukum lebih menonjolkan momentum positifnya ataupun empirisnya melalui influensi tradisi cabang ilmu dalam mendefinisikan hukum yang berkeadilan. Pada akhirnya hukum menjadi terisolasi dari elementasi non-yuridis lainnya yang menentukan keberadaan hukum dalam masyarakat yang abai dengan kebutuhan rakyat. Di kampus-kampus diajarkan hukum dengan "keadilannya", sementara di luar kampus terjadi pelanggaran hak-hak rakyat. Bisakah kita mengajarkan keadilan dengan nilai ketuhanannya di ruang kuliah, sementara di depan kampus akan ada tangis penggusuran bagi warganya? Di sinilah yang saya maksudkan bahwa praksis hukum dan pengajaran hukum harus ada dalam wadah tunggal Pancasila (bukan asas tunggal Pancasila).

Untuk itu tidaklah berlebihan apabila atensi itens diberikan pada Anil Divan yang menyatakan bahwa: *The law deals with the complexity of human life, and must be closely relater to the needs of life*". Kalaulah demikian, tidak cukup untuk zaman sekarang para juris hanya mampu dan mahir berpikir secara juridis. Manfres Rehbinder yang pendapatnya diterima oleh Henc van Maarseveen pun mengantisipasi kecenderungan hukum ke arah pengilmiahan hukum sesuai dengan kodrat masyarakatnya.

Penguasaan terhadap konsepsi hukum sebagai norma dan fakta, per definisi harus dilakukan secara integral, dan bukan parsial. Pengetahuan elementer dan adekuat tentang hukum positif mutlak diperlukan. Hanya dengan cara ini yang diperoleh juris lewat studi, dimungkinkan untuk dilakukan argumentasi yuridis dalam analisis relevanitas fakta yang dapat dikontrol dan diverifikasi secara ilmiah sebagaimana ditulis oleh Gr. van der Burght.

Semua itu meneguhkan suatu refleksi dari mendesaknya kebutuhan suatu telaah yang mampu membebaskan hukum dari kesan normatif semata maupun wajah praktikal. Maka penggunaan Pancasila sebagai tolok ukur ilmu hukum dalam mengkaji keberadaan hukum dapatlah ditegaskan sebagai pilihan tepat dan memiliki argumentasi jelas. Hukum di Indonesia harus *("fardhu ain")* untuk berspirit: *Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan*

Keadilan. Siapa yang akan meragukannya tentu dia termasuk golongan orang-orang yang jauh dari falsafah Pancasila. Sederhananya adalah: adakah di negeri ini yang tidak berkemanusiaan? Adakah yang tidak mau bersatu dalam sebuah bangsa? Adakah yang mengabaikan kerakyatan? Adakah yang tidak mau berbuat keadilan? Renungkanlah. Semuanya bersumber kepada Tuhan bukan? Karena Tuhan adalah sumber segalanya. Bukankah dalam Surah An-Nur dinyatakan bahwa:

Alaahu nuurus samaawaati wal-ardl
Makhalunuu rihii kamisykaatin fiihaa mishbaakh
Almishbaakhu fii zujaa-jah, az-zujaa jatu ka-annahaa
Kawkabun dur-riyy-yuy yuu qodu min-syajaroh.
Min-syajarotim mubaarokatin zaytuu natil laasyarqiy-
Yatiw walla ghorbiyyah.
Yakaadu zaytuhaa, yudlii-u walaw lamtamsas-hu naar
Nuurun alaa nuur, yahdii-laahu linuriihii may-yasyaa
Wayadl-ribul-loohul amtsaala linnaas
Wallaahu bikulli syai-in alim

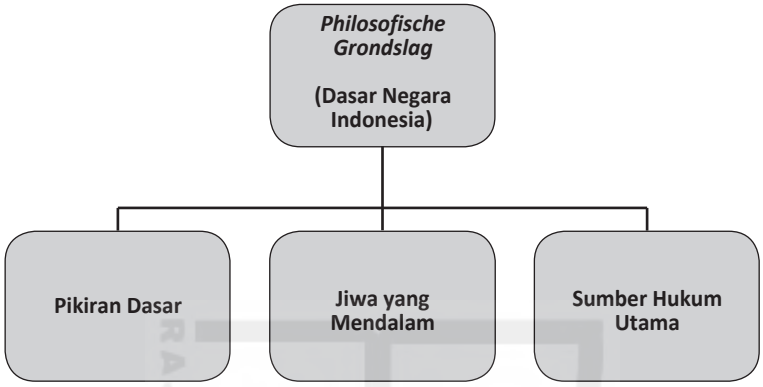
(Substansinya: *Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi dan segala yang ada pada keduanya, yang dengan Nur Ilahi itu semuanya berjalan dengan tertib dan teratur; *Untuk mendekatkan pengertian Nur Ilahi Allah memberikan contoh seperti lampu yang paling cemerlang yang berada di ruang yang sempit di dinding sehingga terjadilah cahaya yang pantul memantul, cahaya di atas cahaya; *Allah memberikan cahaya itu kepada setiap hambanya yang benar-benar beriman serta patuh dan taat kepada perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya).

Betapapun idealnya suatu produk substansi dan struktur hukum yang bermuara di Pancasila selayaknya menghayati Ayat Suci Al-Qur'an tersebut. Selebihnya tentu dibutuhkan dukungan budaya publiknya, mengingat apabila tidak didukung oleh budaya hukum (*"legal-culture"*) para warga masyarakat, watak fungsional hukum tersebut tidak lebih sekadar *"blueprint"* atau *"design"* hukum semata. Di samping itu, dengan "retorika" yang berbeda, namun sama substansinya, Cees Schuyt mengemukakan bahwa suatu sistem hukum juga memiliki elemen idiil, elemen operasional, dan elemen aktual yang mewujudkan sistem hukum. Dengan Pancasila, maka elemen idiil (*het ideele elemen*), terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Elemen operasional (*het operationele elemen*) meliputi keseluruhan organisasi dan lembaga, termasuk pada *"ambtsdrager-nya"*. Elemen actual (*het actuele elemen*) adalah sistem makna dari hukum.

Dengan memahami hukum yang demikian itu (*law as a whole system*) berikut segenap komponennya, intristik menghargai hukum yang adekuat:

hukum adalah fakta maupun kaidah dengan sumber ideologisnya: Pancasila. Pengertian hukum demikian akan menjadikan hukum memiliki sifat dialektis antara fakta dan kaidah, bentuk dan isi. Pengkajian hukum menjadi tidak akan berhenti pada anatomi sepihak: bentuk-isi, kaidah-kaidah, melainkan berusaha untuk memikirkannya dalam suatu hubungan sistematik.

Dalam lingkup ini perkenankanlah saya mendeskripsikan eksistensi fungsional Pancasila tersebut secara skematis sebagai berikut:



Apa yang hendak saya tekankan adalah bahwa apa pun statusnya, Pancasila adalah *motivasi* dan *pedoman* sekaligus *confirm and deepen the identity of their people* guna mendefinisikan aktivitas sosial-kultural maupun struktural penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Pancasilais. Oleh karena itulah Pancasila harus menjadi panduan pengembangan Ilmu Hukum. Adalah aneh apabila Ilmu Hukum di Indonesia alergi terhadap nilai dasar Pancasila. Dunia pendidikan tinggi dengan segala organ kelembagaannya harus memanifestasikan Pancasila. Akademisi secara alamiah selayaknya menjadikan Pancasila sebagai pijakan untuk menyelenggarakan urusan keilmuan. Kampus tempat di mana Ilmu Hukum diajarkan yang tidak mendasarkan diri pada Pancasila adalah suatu lembaga pendidikan yang kehilangan dasar fundamentalnya: filosofis maupun ideologis dari jiwa Indonesia. Orang kampus harus dapat memberi apresiasi pada Indonesia dengan Pancasilanya. Bukankah almarhum Gombloh telah memberikan teladan ideologis dan argumentatif yang aksiomatik mengenai hal ini dalam lagunya yang sangat menggugah: *Gebyar-gebyar.* Mengikuti lagu Gebyar-gebyar perkenankanlah saya memodifikasinya:

Biarpun Bumi Berguncang Kau Tetap Pancasilaku

Andaikan Matahari Terbit dari Barat Kau pun Pancasilaku

Tak Sebilah Pedang Yang Tajam Dapat Memalingkan Daku Dari Mu

Kusingsingkan Lengan Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung Bersamamu

Pancasila menjadi sangat aksiomatik dan ini juga ilmiah dalam ukuran kesepakatan kolektif kita sebagai bangsa Indonesia. Mengenai hal ini perlu saya takarkan kembali bahwa sebagaimana diketahui bahwa Pancasila terdiri atas lima sila yang membentuk suatu rangkaian sistem ideologis dan filosofis yang logik saintifik yang menjadi dasar hukum utama (*yang dalam bahasa populernya dinamakan "sumber dari segala sumber hukum."* Sila-sila Pancasila itu adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

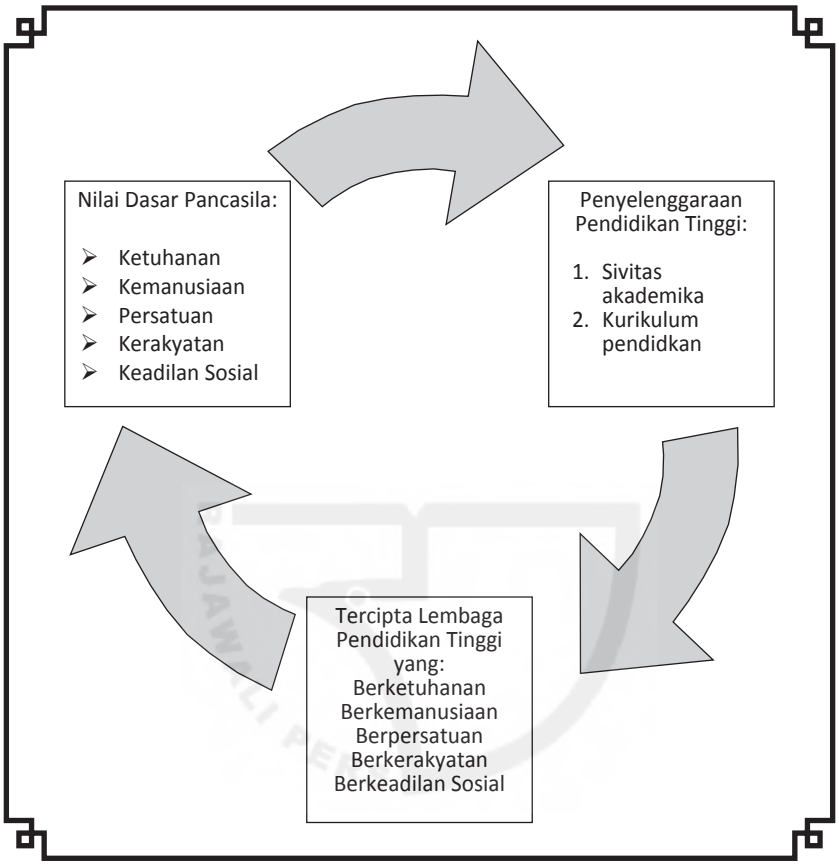
Rangkaian sila-sila Pancasila itu secara terang menginformasikan bahwa kaidah dasar yang merupakan nilai fundamental Pancasila adalah: *Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.* Nilai dasar ini memberikan arah bagi semua Warga Negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan yang berbasis *Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan*. Dengan demikian, kita wajib bertindak yang sejiwa dengan *Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan*. Dengan kata lain bahwa kita dalam pengajaran Ilmu Hukum dilarang berbuat yang tidak berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan.

Secara praktis implementasi nilai-nilai Pancasila ini harus diwujudkan pada setiap sesi perkuliahan secara total. Apabila nilai-nilai Pancasila ini diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka akan lahir pribadi-pribadi yang bertumpu pada *Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan*. Logikanya maka di pendidikan Tinggi di Indonesia akan terwujud sebagai contohnya adalah:

- Kurikulum yang bersendikan: *Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.*
- Pelayanan akademik yang berjiwa: *Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.*
- Pelaksanaan dan penegakan hukum: *Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.*

Konsepsi demikian jelas menyiratkan bahwa penyelenggaraan pengajaran Ilmu Hukum yang mengimplementasikan Pancasila jauh lebih hebat daripada sekadar mewujudkan prinsip-prinsip *dari Eropa* atau *Amerika Serikat*. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang bermuara pada Pancasila memiliki dua dimensi sekaligus: dimensi *teologis* dan dimensi *demokrasi.* Apa yang dinamakan nilai-nilai *Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan* adalah jelas universal dan bermuatan makna yang lebih *bernas*. Nilai-nilai tersebut

sangat ideal dan begitu dalam makna filosofisnya untuk direalisasi organ Pendidikan Tinggi yang siklusnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Ilmu Hukum Mazhab Pancasila

Dari sisi demikianlah maka tidaklah patut dalam suatu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang berdasarkan Pancasila diketemukan adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), atau pembunuhan karakter, karena hal itu bertentangan dengan Pancasila yang memiliki nilai-nilai universal. Semua organ kelembagaan Pendidikan Tinggi semestinya menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap geraknya.

Sebagai kekuatan moral dan intelektual, para ilmuan hukum mutlak terpanggil untuk mengonstruksi ulang pendidikan tinggi ilmu hukum di Indonesia yang masih terkesan "ragu-ragu" memasukkan nilai Pancasila dengan

segala karakteristiknya. Ilmu hukum *("legal science"/"jurisprudence"/"rechtslehre"/ "rechtsleer")* memang memiliki "kekhasan", tetapi ini bukan dalil untuk menjustifikasi agar ilmu hukum mengisolasi diri dengan ideologi negara. Justru dengan Pancasila, ilmu hukum dan penstudinya tertantang untuk memainkan perannya sebagai (aktor) *genuine sciences* (sebenar-benarnya ilmu) serta berkomunikasi dengan ilmu-ilmu lain (sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, kedokteran, fisika, kimia, planologi, ekologi, hidrologi, geodesi, radiologi, biologi, dan lain-lain). Dengan mensitir gagasan David Straker: antara penganut mazhab apa pun perlu melakukan *"the quality conspiracy"* yang tetap teguh mengamanatkan Ilmu Hukum yang Pancasilais. Persoalan yang terbentang di "lapangan" tidak dapat dituntaskan dengan satu disiplin ilmu yang egois *("building blocks")* yang mengabaikan Pancasila.

Pada kesempatan ini pula saya mengajak sejawat ilmuwan hukum dan ilmuwan lainnya untuk melakukan "gerak akademik" dengan saling bekerja sama. Membangun kembali ilmu hukum dari bersifat abai terhadap Pancasila menjadi pendukung Pancasila. Inilah *"starting point"* atau *"entry point"* kelahiran bangunan "Ilmu Hukum Mazhab Pancasila."

Ilmu Hukum Mazhab Pancasila dibangun untuk mampu "memproduksi" yuris-yuris yang tidak sekadar "tukang yang amat terampil dengan pasal-pasal" tetapi juga sebagai intelektual yang menjadi bintang pemandu hukum yang: *Berketuhanan, Berkemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan, dan Berkeadilan*. Pengemban Ilmu Hukum Mazhab Pancasila harus memiliki tanggung jawab kebangsaan untuk selalu ada dalam tegangan kreatif pada situasi ilmu hukum modern yang menurut Boaventura de Sousa Santos bergerak pada pusaran transisi paradigmatik *("the paradigmatic transition")*.

Itulah manifestasi hakiki sebagai pengemban amanat Pancasila. Maka semua disiplin Ilmu yang dikembangkan di kampus secara tematik pastilah mengejawantahkan Pancasila. Kapan paradigma "Ilmu Hukum Mazhab Pancasila" yang sarat nilai-nilai *Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan dapat dengan segera terwujud di negeri tercinta ini?*

Daftar Referensi

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Statu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.

————. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Alkostar, Artidjo dan M Sholeh Amin. *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: FH-UII, 1997.

Amos, H.F. Abraham. *Legal Opinión, Aktualisasi Teoritis & Empirisme*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

————————. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba sampai Reformasi) Telaah Sosiologis Yuridis dan Yuridis Pragmatis krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Bahm, Archi J., Bottomley, Stephen, at.all. *Law in Context*. The Federation Press, 1994.

Bruggink, J.J.H., Alih bahasa: Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Capra, Fristjof. *The Turning Point Science, Society and The Rising Culture*. New York: Simon and Achuster, 1982.

De Wild, A.H. *Pendidikan Hukum antara Ilmu dan Profesi*. Bandung: Pro-Justitia, Majalah Fakultas Hukum UNPAR, Tahun XII Nomor 1, Januari, 1994.

Ellickson, Robert C. *Order Without Law*. How Neighbors Settle Disputes, Harvard University Press, 1991.

Ewing A.C. *Persoalan-persoalan Mendasar Filsafat*, Judul Asli *"The Foundamental Questions of Philosophy*, Penerjemah: Uzair Fauzan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Fay, Brian. *Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela, 2002.

Fukuyama, Francis. *The End of History and The Last Man*. New York: The Free Press, 1992.

————————. *The Great Disruption: Human Nature and The Reconstitution of Social Order*. New York: The Free Press, 1999.

Grossmann, Henryk. *Hukum Akumulasi dan Keruntuhan Sistem Kapitalisme*. Jakarta: Hasta Mitra, 2003.

Hartono, C.F.G., Sunaryati. *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia, makna Kedudukan dan Implikasi Hukum Nazca Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Konstitusi Press, Jakarta & Citra Media, Yogyakarta, 2006.

Hudson, Barbara. *Justice in The Risk Society*. Sage, 2000.

Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Lawrence, M. Freidman & Stewart Macauly. *Law and the Behavioral Sciences*. New York: The Bobbs-Marrill Company, Ins., 1969.

Lyons, David. *Ethics and The Rule of Law*. Cambrigde University Press, 1984.

MC. Laughlin, Eugene, at.all. *Restorative Justice Critical Issues*. The Open University, 2003.

Meuwissen, D.H.M. *Pengembangan Hukum-hukum*. Bandung: Pro-Justitia, Majalah Fakultas Hukum UNPAR, Tahun XII Nomor 1, Januari, 1994.

Muhadjir, Noeng. *Filsafat Ilmu: Positivismo, Post Positivismo, dan Post Modernismo*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001.

Nonet, Philippe, Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper Row, 1982.

Parkinson, Patrick. *The Principles of Equity*. Lawbook Co, 2003.

Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Iritis Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: KOMPAS, 2007.

Sampford, Charles. *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*. Brasil Blackwell, 1989.

Santos, Boaventura De Sousa. *Toward a New Common Sense, Law, Science and Politics in The Paradigmatic Transition*. New York: Routledge, 1995.

Sawer, Goffrey. *Law in Society*. London: Oxford at The Claredon Press, 1976.

Shidarta, B. Arief. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Bandung: Utomo, 2006.

Van der Burght, Gr. *Penyelesaian Kasus*. Bandung: Pro-Justitia, Majalah Fakultas Hukum UNPAR, Tahun XII Nomor 1, Januari, 1994.

5

AKOMODASI KEBERAGAMAN KE DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh:
*Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., S.U.**



Pengantar

AKHIR-AKHIR INI, terutama sepuluh tahun sejak keambrukan era Orde Baru, sebagian produk penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkesan semakin menjauh dari roh ideologi bangsa, bahkan sebagian orang mengatakan cacat ideologis. Cacat ideologis dimaksud adalah sebagian produk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya hingga peraturan daerah di daerah-daerah terkesan tercerabut dari fakta keberagaman sosial, budaya, agama, suku bangsa, dan norma-norma lokal nusantara yang menjadi karakter masyarakat asli yang dimiliki bangsa Indonesia.

Fakta dimaksud menunjukkan bahwa beberapa undang-undang dan peraturan daerah menuai protes dari sekelompok masyarakat yang keberadaannya terasa tidak terlindungi oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Dengan kalimat lain, peraturan perundang-undangan dimaksud dipandang belum mengakomodasi keberadaan mereka, yang faktanya memang telah menjadi bagian dari masyarakat lain dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya Undang-Undang tentang Pornografi dan Peraturan Daerah tentang Syariah di berbagai provinsi dan kabupaten/kota.

Kehadiran serangkaian protes sosial di tengah masyarakat terhadap diberlakukannya sejumlah peraturan perundang-undangan karena yang disebut terakhir ini dianggap tidak mengakomodasi keberagaman tersebut, bahkan produk undang-undang dapat dikatakan bahwa ia telah meninggalkan nilai-nilai kebersamaan. Sementara kebersamaan itu sendiri merupakan *the virtual*

*Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan Usakti Jakarta.

of Pancasila. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang demikian ini dapat dikatakan cacat ideologis karena dianggap semakin menjauh dari ideologi/ falsafah bangsa Indonesia, Pancasila. Secara akademis, praktik-praktik semacam ini juga menimbulkan kesan meninggalkan lapangan ilmu ketatanegaraan pada umumnya mengingat peraturan perundang-undangan sebagai produk dari serangkaian praktik ketatanegaraan dan ketatapemerintahan harus berisi dan didasarkan sebuah nilai budaya masyarakat yang ada di seluruh penjuru nusantara Indonesia, apalagi faktanya juga masih dipraktikkan oleh warga bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, dalam kehidupan ketatanegaraan dan ketatapemerintahan akhir-akhir ini, justru hal itu mulai terangkat dan mengering karena terkesan tidak dijadikan roh perundang-undangan atau bahkan dengan sadar diabaikan begitu saja, seolah risih dan malu menyebutkan sebagai pedoman bertindak dan berpolitik hukum. Padahal jika direnungkan secara mendalam, *the virtual of Pancasila* dimaksud berakar dari dan tepat dengan kondisi riil bangsa Indonesia, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Untuk itu, tulisan ini mencoba mundur sedikit ke belakang untuk melacak dari mana titik pembiasan-pembiasan dimulai.

Hal ini amat menjadi penting mengingat dengan menguraikan dan menjelaskan Pancasila agak surut ke belakang, orang menjadikan memahami jati dirinya. Oleh sebab itu, dalam bahasan ini sedikit memasuki wilayah, *pertama*, ilmu filsafat sebagai dasar filosofis peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ke-Indonesiaan adalah Pancasila mengingat ia sebagai suatu "*Weltanschauung*", yaitu sebagai pandangan hidup termasuk alam cita-cita. *Kedua,* ilmu sosial sebagai dasar sosiologis. Dalam konteks ke-Indonesiaan, yaitu adanya keberagaman masyarakat asli Indonesia atau sebagai kebhinekaan sosial, budaya, agama, dan norma lokal nusantara, dan *ketiga*, ilmu hukum sebagai dasar yuridis mengingat hukum berupa peraturan perundang-undangan tersebut harus berakar jauh ke bawah sehingga efektif keberlakuannya.



Dasar-dasar Keberagaman

a. Dasar Filosofis

Ketika Pancasila dijadikan dasar atau basis filosofis/ideologis dari penyusunan praktik ketatanegaraan, mestinya struktur (baca: peraturan perundang-undangan) ketatanegaraan dimaksud harus berisikan nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai nusantara atau keberagaman nilai-nilai budaya nusantara harus diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, pada setiap hukum dan peraturan merupakan perwujudan ideologi yang tersembunyi di belakangnya. Sebenarnya, tata

negara itu sendiri merupakan bentuk lahir atau kulit dari suatu cita-cita yang dikandung oleh rakyat. Dengan kata lain, tiap-tiap struktur ketatanegaraan harus didukung oleh alam pikiran, keinginan, hasrat, dan sikap rakyat yang hidup dalam masyarakat. Hasrat dari cita-cita dan alam pikiran rakyat[1] itulah yang memberi isi dan jiwa pada struktur tata negara, sehingga jika tidak, tentu akan menjadi lapuk dan keropos. Dengan demikian, ilmu hukum perundang-undangan berhubungan erat dengan ilmu filsafat umumnya.

Lantas, pertanyaannya, dari manakah sumber Pantjasila itu? Menurut Soekarno dalam buku "Pantjasila" yang berisi pidato dari Presiden Soekarno, waktu beliau menjelaskan soal itu dalam sidang pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia di Jakarta pada bulan Agustus 1945, dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa Pantjasila, atau Lima Dasar itu sesungguhnya berasal dari dua alam pikiran, yang digabungkan menjadi satu pikiran yang bulat. *Pertama*, bersumber dari arus perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya menghadapi penjajahan yang didasarkan pada paham *imperialism* barat. Untuk menghadapi hal itu, disusunlah paham-paham yang bercorak anti-imperialisme, yaitu paham Sosialisme, Demokrasi, dan Nasionalisme[2].

Sehubungan dengan itu, penyusunan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, hendaknya senantiasa membawa nilai-nilai yang terkandung dalam aliran sosialisme, nasionalisme, dan demokrasi. Memang aliran demikian juga tumbuh di negeri barat, namun aliran-aliran modern kebaratan ini nyata-nyata diterima dan dapat disesuaikan pula dengan paham-paham dan alam pikiran rakyat yang hidup dalam masyarakat asli yang tersebar di seluruh nusantara semenjak ada dalam proses kelahirannya.

b. Dasar Sosiologis

Pergaulan hidup dari rakyat yang bersifat desa, itulah sumber yang primer, yang jadi pokok pangkal kelahiran Pantjasila. Menurut perkataan Bung Karno, Pancasila itu jika di "peras" hingga patisarinya, akan tinggal dasar pemulaannya, yaitu biji embrionya Pancasila, yaitu gotong-royong. Paham gotong royong

---

[1]Alam pikiran rakyat ialah dasar negara. Susunan Tata Negara Prancis didasarkan pada cita-cita luhur "Egalite Fraternite-Liberte", yaitu cita-cita persamaan, persaudaraan dan kemerdekaan, cita-cita mana telah dilahirkan dalam arus revolusi Prancis dalam abad ke-18. Susunan undang-undang dasar Tiongkok Nasional ialah berdasar pada prinsip San Min Chu I, yaitu dasar sosialisme, nasionalisme, dan demokrasi seperti yang diikrarkan oleh almarhum Sun Yat Sen. Tata Negara Soviet didasarkan atas paham ideologis marxisme dengan diktatuur proletarnya, yaitu cita-cita mengadakan masyarakat komunistis melalui jalan dan tingkatan diktatuur kaum buruh dulu. Susunan masing-masing negara itu adalah merupakan persesuaian dengan cita-cita yang dikandung oleh rakyatnya yang memberi jiwa pada tata negara itu.

[2]Lihat Soenarko, dalam *Susunan Negara Kita*. (Malang: Djambatan, 1950).

inilah yang tidak lain adalah paham Indonesia asli, yang dirasakan sungguh-sungguh sebagai pedoman hidup dari bangsa Indonesia. Di dalam pergaulan hidup masyarakat desa, serangkain praktik gotong-royong masih amat kuat, di mana sosialisme, demokrasi, dan nasionalisme masih terlihat dalam bentuk asli di desa-desa nusantara.

Desa dalam segala tingkatan di seluruh Indonesia ialah masyarakat asli Indonesia, di mana bangsa Indonesia dari bermacam-macam suku hidup bersama dalam sesuatu lingkungan kecil. Dilihat dari sudut ilmu sosiologi, yaitu ilmu masyarakat, maka desa itu menurut sarjana Ferdinand Tonnies, tergolong masyarakat yang bersifat *"gemeinschaft"* di mana para warga desa saling terkaitan oleh perasaan persatuan yang erat. Dilihat dari sudut ilmu adat, maka Profesor Ter Haar dalam bukunya *"Inleiding tot Adatrecht"* yang terkenal menamakan desa itu sebagai "Gerombolan manusia yang tetap dan teratur dengan pemerintahan dan kejayaan materiil dan imateriil sendiri," dan Profesor Boeke dalam bukunya "*De Theorie der Indonesische Economie*" yang melihat desa itu dengan kacamata ekonomi, memberikan definisi sebagai berikut:" Desa itu ialah suatu masyarakat religius yang diikat oleh tradisi bersama dari warga penanam bahan makanan yang sedikit banyak mempunyai hubungan kebangsaan." Profesor Kleintjes, ahli Tata Negara, mendefinisikan desa sebagai berikut: "Desa ialah badan hukum Indonesia asli yang berdiri sendiri dan terikat pada suatu daerah kecil."[3]

Selain ragam sebutan desa juga beragam sifatnya, misalnya dalam masyarakat Aceh dinamakan Gampong, dalam masyarakat Batak disebut Kuria, dalam masyarakat Minangkabau dinamakan Nagari, dalam masyarakat Palembang dinamakan Marga, di Ambon Negory dan sebagainya. Selain itu, karakternya juga berbeda, semua terbentuk atas dua dasar ikatan, yaitu dasar kedarahan atau keturunan para warga desa dan dasar kedaerahan atau kediaman para warga desa. Mengenai hal ini, lebih lanjut dapat disimak pada matrik berikut ini.

[3]*Ibid.*

Sebutan Masyarakat Hukum Adat Nusantara

No	Provinsi/Daerah	Nama Masyarakat
1.	Aceh	Kampung, Mukim, Gampong, Jurang, Kute
2.	Sumut	
	a. Sumatera Timur	Marga, *Kuria*
	b. Tapanuli	Kampung, (Lorong/Wek), *Huta* Negeri
3.	Sumatera Barat	Nagari
4.	Riau	Kampung, Dusun
5.	Sumatera Selatan	Marga
6.	Jambi	Marga, Kemedapaan, Dusun
7.	DKI Jakarta Raya	Kelurahan. Wijk
8.	Jawa Barat	Desa, kampung
9.	Jawa Tengah	Desa, Dukuh
10.	Yogyakarta	Desa
11.	Jawa Timur	Desa, Kampung, Dukuh
12.	Kalimantan Barat	Kampung
13.	Kalimanatan Tengah	Kampung, Kademangan
14.	Kalimanatan Selatan	Kampung, Kademangan
15.	Kalimanatan Timur	Kampung
16.	Sulawesi Utara	Desa, Kampung
	Sulawesi Tengah	Kampung, Woma
17.	Sulawesi Tenggara	Desa
18.	Sulawesi Selatan	Gabungan Kampung, Desa Gaya Baru,
19.	Bali	Bua
	Nusa Tenggara Barat	Desa, Perbekel.
	Nusa Tenggara Timur	Banjar
20.	Maluku	Desa
21.	a. Maluku Tengah dan Tenggara	Desa Gaya Baru
	b. Maluku Utara	
22.	Irian Barat.	Negeri
		Kampung, Kare

B. Surianingrat, BPHN, 1981.

Desa selalu mengandung dasar asal-usul, mungkin dasar keturunan atau ikatan darah dan juga mengandung dasar teritorial, dasar kediaman atau ikatan daerah. Dalam desa di Jawa misalnya anasir "darah" sudah tipis dan lebih dirasakan ikatan kedaerahan, tetapi dalam Gampong Gajo Aceh, lebih terasa pengaruh ikatan keturunan atau kewargaan (*stamverband*) itu. Desa di Jawa, Pasundan, Madura, dan Bali lebih didasarkan pada ikatan kediaman bersama, di mana rasa kekeluargaan sudah agak menipis, tetapi dalam Gampong, Marga, dan sebagainya itu lebih dirasakan pengaruh ikatan kekeluargaan sebagai pengikat bersama. Dalam kenyataannya, lebih dari 90% warga bangsa Indonesia hidup dalam ikatan-ikatan tradisional yang berada di wilayah seluruh Nusantara.

Sehubungan dengan itu, negara harus menghormati terhadap keberagaman itu dan sekaligus itu sebagai paham kebangsaan yang mengandung maksud persatuan seluruh warga Nusantara, tak peduli asal-usul atau keturunannya.

Segala peraturan yang bersifat memecah belah tidak boleh terjadi dan jangan terulang seperti pada zaman kolonial dahulu, di mana orang-orang di Indonesia dipisah-pisahkan menjadi golongan-golongan penduduk asing, Eropa, timur asing, Belanda, kawula raja, kawula pribumi, dan sebagainya.

Memang dalam undang-undang dasar (*grundnorm*) mengkategorikan kebangsaan berdasarkan perbedaan administratif, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing, memberi perlindungan hukum yang sama, tetapi dalam soal perkembangan dan keberagaman sukubangsa, kultur, agama, kepercayaan, dan lain-lain primordial tidak dibelakangkan, yaitu tiap-tiap golongan apa saja bebas mengembangkan bahasa, kultur mereka sendiri, asal tidak menimbulkan gerakan provinsialisme politik, yaitu gerakan kedaerahan yang membahayakan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama yang mengangkat senjata dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI (separatism).

c. Dasar Budaya

Mengapa diskusi budaya (baca: budaya hukum) dewasa ini menjadi penting. Ini merupakan pertanyaan yang amat relevan dengan gerak legislasi dewasa ini yang semakin ceroboh mengingat tidak sedikit persoalan-persoalan hukum memunculkan diskusi yang menyatakan bahwa praktik hukum sebagai tak berbudaya (*acultural)*, tak asli (*unnative*). Tentu, ini akibat isi perundang-undangan telah tercerabut dari akar budaya bangsa. Kita semakin menjadi sadar bahwa betapa pentingnya aneka ragam budaya lokal nusantara di satu pihak dan di pihak lain adanya kemunculan keinginan kuat kembali ke budaya lokal. Dua hal yang tidak mungkin dihindari sebagai paradoksiasi dari politik hukum, di mana nuansa otonomi daerah semakin bergerak merambah ke bawah, dan di bawah sana yaitu masyarakat lokal penuh dengan budaya lokal (*micro cultural*).

Kemudian pertanyaannya adalah apakah isi budaya lokal itu? Ada tiga tataran budaya untuk menjawabnya, yaitu tataran budaya individual, komunal, dan budaya bangsa. Pada tataran pertama, budaya diartikan sebagai keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai individu dalam masyarakat. Ini sering kali kontras dengan nilai-nilai multikultural seperti Indonesia sendiri. Tentu, budaya individual yang subur di negeri lain ini tidak sertamerta cocok ketika membangun peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada tataran kedua, biasa dijumpai dalam masyarakat pluralistik, multikultural yang biasanya mengakui nilai-nilai mayoritas di atas nilai-nilai minoritas dan sering kali diterima sebagai budaya ideal nasional, misalnya seperti prinsip kebersamaan, konsensus, dan musyawarah mufakat di Indonesia. Di Indonesia dengan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan aktivitas sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukumnya dirujukan pada prinsip-prinsip demikian itu yang telah diakui sebagai budaya bangsa dan merupakan kristalisasi dari

keseluruhan budaya lokal dari seluruh nusantara yang kini disebut bangsa Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut dipahami sebagai kendali budaya terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan. Artinya, keseluruhan produk hukum merupakan turunan dari prinsip-prinsip kebersamaan, konsensus, dan musyawarah mufakat. Tentu tidak saja berhenti pada konstitusi seperti Undang-Undang Dasar 1945, tetapi seperangkat peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah hingga peraturan yang paling bawah di tingkat desa. Kesemuanya merupakan norma yang menindaklanjuti pasal-pasal konstitusi dan terkontrol oleh nilai budaya bangsa sehingga undang-undang dapat kembali atau dikembalikan ke masing-masing budaya masyarakat Indonesia itu sendiri dan diterima. Dengan cara demikian, bentuk budaya hukum yang lebih disukai secara resmi adalah dalam bentuk kelembagaan dan memang selalu menunjukkan bahwa budaya bergerak antara dua tataran antara yang sedang dibentuk dan yang telah dibentuk oleh individual maupun oleh negara.



Implikasi Keberagaman

a. Interaksi Hukum

Keberagaman atau sebut saja Pluralisme memiliki pengertian sebagai sebuah paham yang menerima segala bentuk perbedaan di antara kita. Perbedaan dimaksud tidak berhenti pada satuan desa sebagaimana disebut di atas, tetapi juga dilihat dari sisi agama, bahasa, suku-bangsa, kebudayaan, dan primordialistik lainnya. Pemahaman tentang keberagaman dalam konteks Indonesia amat penting untuk dimiliki oleh tiap-tiap warga negara, khususnya pemimpin bangsa dan calon pemimpin masa depan. Pendidikan dan peningkatan pemahaman keberagaman secara terus-menerus menjadikan di antara kita saling menghargai atas perbedaan tersebut.

Hal itu dapat memunculkan sikap adil atas kebijakan-kebijakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu untuk kepentingan umum, namun dalam kepentingan umum dimaksud terdapat perbedaan tersebut, khususnya menyangkut sukubangsa dan agama tertentu. Lebih-lebih di balik keberagaman desa juga berhubungan dengan keberagaman agama, sukubangsa, dan budaya sehingga jika salah mengaturnya, maka sangat sensitif untuk terjadi benturan kepentingan di masyarakat. Artinya, uraian di atas memperlihatkan keragaman desa asli, dibalik keragaman desa asli itu juga mencerminkan keragaman suku, golongan minoritas, keagamaan, dan keragaman norma dan budaya lokal atau biasa disebut hukum adat.

Implikasi teoretik keberadaan keragaman yang hidup di dalam satu wilayah sama dan sama-sama pula dianggap sebagai fakta yang diyakini benar ada oleh masing-masing, tentu mereka berinteraksi.[4] Secara teoretik, interaksi dimaksud diduga akan melahirkan lima kemungkinan perubahan, *pertama*, integrasi (*integration*), yaitu penggabungan hukum negara, hukum lokal, dan hukum lainnya; *kedua*, inkoorporasi (*incoorporation*), yaitu mengadaptasikan sebagian hukum negara ke dalam hukum lokal atau sebaliknya; *ketiga*, konflik[5] (*conflict*), yaitu hukum negara dan hukum lokal dimaksud saling bertentangan; *keempat*, kompetisi (*competition*), yaitu hukum negara, hukum lokal, dan hukum lain berjalan sendiri dalam mengakses sumber daya alam; *kelima*, penghindaran (*avoidance*), yaitu salah satu hukum yang ada menghindari keberlakuan hukum yang lain.[6]

Pada konflik sumber daya air misalnya, ketika sumber air berasal dari daerah lain (luar kabupaten atau provinsi) di satu pihak, dan di pihak lain pemanfaatannya oleh daerah kabupaten atau provinsi yang berbeda dari daerah sumber air disebut pertama, paham pengelolaan konflik pemerintah didasarkan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sumber Daya Air, yaitu diselesaikan secara lintas pemerintah daerah (horizontal). Berangkat dari pengertian ini, tidak aneh jika kerja sama dan penyelesaian sengketa sumber daya air secara formal sehingga penyelesaian jalur polisional dan peradilan formal menjadi pilihan. Demikian pula sebagian hasil penjualan air yang telah disetor ke kas Pemkab setiap tahunnya sebagai pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang didasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 jo Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pengairan. Dengan demikian, menempatkan kasus ini ke dalam pajak pemanfaatan tidak tepat karena dalam era otonomi dewasa ini daerah (desa) di mana sumber mata air tidak memperoleh hasil

---

[4]Penulis berpandangan bahwa *living law* hendaknya selain diartikan seperti apa yang dimaksud oleh Ehrlich, E., 1936, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (translated by W.L. Moll), New York: Harvard University Press, juga diartikan sebagai seperangkat pengetahuan hukum yang diyakini benar oleh sebagian besar masyarakat dan dijadikan pedoman bertindak. Dengan demikian, ia dapat diartikan sebagai peraturan tertulis maupun tidak tertulis.

[5]Konflik merupakan bagian dari proses sengketa mengingat proses konflik mencakup tahapan potensi konflik (*conditional*), pra-konflik (*monadic*), konflik (*diadic*), dan sengketa (*triadic*) yang setiap tahap memiliki pilihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yaitu ajukasi (*ajucation*), arbitrasi (*arbitration*), mediasi (*mediation*), negosiasi (*negotiation*), atau tanpa bantuan pihak ketiga yaitu dengan paksaan (*coercion*), penaklukan (*conquest*), penghindaran (*avoidance*), dan pembiaran (*lumping it*). Selanjutnya, lihat Nader, Laura and Harry F. Todd, Jr. 1978. *The Disputing Process: Law in Ten Societies*. (New: Colombia Press, hlm. 9-11).

[6]Kemungkinan-kemungkinan hukum produk interaksi antarhukum ini dikemukakan oleh Stratford W. Moores dan Gordon R. Woodman, 1987, *Indigeneous Law and State*, Dordrecht Holland: Foris Publications.

sumber daya air secara proporsional sehingga ia menyelesaikan secara diagonal ke otoritas pemerintah yang bukan hierarkinya.

Pada titik demikian ini telah terjadi konflik diagonal antarpemerintah daerah dengan model pengelolaan formal dan desa sebagai pemilik sumber air.[7] Untuk itu, dalam perspektif Otonomi Daerah, ketika Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum menyediakan pasal yang mengakses sumber daya alam sehingga hal ini dipandang memiliki kontribusi konflik hukum dan tidak melindungi keberagaman budaya daerah mengingat ketidakjelasan perangkat hukum itu sendiri. Kini, meski telah ada perbaikan dari undang-undang dimaksud sebelumnya, misalnya dalam hal sumber daya air telah diatur dalam Pasal 2 ayat 4. Di sana dinyatakan bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya, Pasal 2 ayat (5) hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Pasal 2 ayat (6) hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Kemudian, Pasal 195 ayat (1) menyatakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, ayat (2) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antardaerah yang diatur dengan keputusan bersama.

Seperangkat pasal-pasal formal di atas ternyata tidak menyebutkan bagaimana penyelesaian konflik atau sengketa bilamana secara struktural di antara pelaku sengketa berbeda tataran otoritas strukturalnya sebagai diuraikan di atas. Hal ini menjadi kabur ketika misalnya satu pihak menuntut hak berdasarkan tatanan kultural dan di lain pihak tatanan struktural (*juridical formal*).[8] Terutama, ketika konflik yang menyangkut hubungan diagonal antara

[7]Dalam konteks hukum formal lain, dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air misalnya, ditegaskan bahwa sengketa yang menyangkut sumber daya air, diselesaikan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Di antaranya, Pasal 88 ayat 1 menyatakan "Penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan, (3) upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrase atau penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 89 menyatakan bahwa sengketa mengenai kewenangan pengelolaan sumber daya air antara pemerintah dan pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[8]Dalam kondisi pemanfataan sumber daya alam secara lintas teritorial yang melibatkan dua atau lebih satuan wilayah administrasi daerah dan pemerintahan, konflik dapat terjadi antarpemerintah daerah secara horizontal, namun dapat pula terjadi secara diagonal. Artinya, dapat terjadi konflik antara pemerintah daerah, antara pemerintah daerah di satu daerah di satu pihak dan pemerintah daerah lebih rendah di pihak lain, bahkan masyarakat setempat sebagai pemangku sumber daya alam dimaksud.

masyarakat di satu daerah, di satu pihak, dan pemerintah di daerah lain, di lain pihak, yang tidak memiliki hubungan struktural. Selain itu, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tentang pengakuan eksistensi masyarakat adat.[9] Namun, perumusan formalnya masih menimbulkan interpretasi yang tidak perlu mengingat nilai kultural masyarakat tempatan belum terakomodasi ruang geraknya, terutama dalam memainkan peran kulturalnya untuk menyelesaikan perselisihan mengingat adat dan masyarakat adat di setiap daerah berbeda.

Dalam kondisi demikian, model negosiasi diagonal sebagai model penyelesaian berhasil menyelesaikan konflik diagonal. Diagonal dimaksud adalah suatu pertentangan dan penyelesaian antara dua belah pihak yang secara struktural tidak memiliki hubungan otorisasi langsung (vertikal) dan tidak berada pada tataran kesejajaran otorisasi (horizontal). Contoh lain, dalam konteks hukum adat tentang tanah ulayat pun demikian, ini dapat dibaca pada contoh-contoh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, khususnya bab yang mengatur pendaftaran dan subjek hukum tanah ulayat, merupakan contoh konkret dan mutakhir terhadap apa yang penulis jelaskan di muka.

No.	Jenis Hak Ulayat	Status Hak	Subjek Hak
1	Tanah Ulayat Nagari	HGU, Hak Pakai, Hak Pengelolaan	Ninik, Mamak, KAN
2	Tanah Ulayat Suku	Hak Milik Kolektif Suku	Penghulu-penghulu Suku
3	Tanah Ulayat Kaum	Hak Milik Kolektif Kaum	Mamak, Kepala Waris
4	Tanah Ulayat Rajo	Hak Pakai dan Hak Kelola	Laki-laki Tertua Pewaris Rajo

Disebutkan pada Pasal 8 Bab V Perda dimaksud, di dalam pasal dimaksud diatur Pendaftaran dan Subjek Hukum Tanah Ulayat, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data/informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat didaftarkan pada kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

a. Terhadap tanah ulayat nagari dapat didaftarkan, yang bertindak sebagai subjek pemegang hak adalah ninik mamak Kerapatan Adat Negara (KAN) diketahui oleh pemerintahan nagari dengan status hak guna usaha, hak pakai atau hak pengelolaan.

[9]Pasal 2 ayat 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Terhadap tanah ulayat suku dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah penghulu-penghulu suku, dengan status hak milik.
c. Terhadap tanah ulayat kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dangan status hak milik.
d. Terhadap tanah ulayat rajo dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan pihak ketiga, diketahui oleh laki-laki tertua pewaris rajo, dengan status hak pakai dan hak kelola.



Akomodasi dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Sebelum diuraikan implikasi keberagaman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, perlu diutarakan lebih dahulu pengertian yang terkandung dalam terminologi peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang dalam bahasa Inggris disebut *legislation*, dalam bahasa Belanda disebut *Wetgeving*, dan dalam bahasa Jerman disebut *Gezetzgebung* memiliki lafal berbeda namun kesemuanya memiliki dua arti, *pertama*, diartikan sebagai proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun daerah. *Kedua*, diartikan sebagai keseluruhan peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Kedua pengertian tersebut mengingatkan penulis pada perdebatan antara Hans Kelsen dan Austin ketika yang disebut terakhir ini memandang bahwa susunan hierarkis suatu peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai yang statis di mana aplikasinya peraturan perundang-undangan yang secara hiarkhis berada di atas dianggap sebagai yang benar sehingga peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan.[10] Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, hierarkis perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) Undang-Undang/ Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Daerah, (5) Peraturan Daerah Provinsi, (6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan (7) Peraturan Desa, hendaknya tidak dipahami sebagai hierarkis yang statis tetapi juga dinamis.

Solly Lubis pernah menegaskan yang senada bahwa landasan yuridis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bagi pembuatan suatu peraturan.

[10]Lihat Hans Kelsen. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. (Bandung: Nusa Media, hlm. 331-332).

Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan undang-undang organik. Selanjutnya, undang-undang itu menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Peraturan Pemerintah, SK Presiden, Peraturan Daerah, dan lain-lain.[11] Menurutnya, landasan yuridis ini dapat dibagi lagi atas dua macam, yaitu:

1. Landasan yuridis dari segi *formil*, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan yuridis dari segi formil bagi presiden untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU).
2. Landasan yuridis dari segi *materiil*, yaitu landasan yuridis untuk segi isi (materi), yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal, misalnya: Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan yuridis dari segi materiil untuk membuat undang-undang organik mengenai pemerintahan daerah.

Pasal-pasal 5 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, dan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan-landasan yuridis untuk segi formil, bagi pembuatan suatu Undang-Undang. Banyak pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar yuridis dari segi materiil dan pasal-pasal inilah yang merupakan pasal-pasal yang fleksibel dan supel, membuka kemungkinan bagi pembuat undang-undang untuk menyesuaikan undang-undang dengan dinamika tuntutan zaman. Namun sebaliknya, jika dalam amandemen per amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di kemudian hari semakin memperlihatkan rumusan klausula yang semakin teknis dan peraturan di bawah dianggap bertentangan jika tidak sesuai dengan yang di atasnya dimaknai secara kaku, tentu hal ini mengundang bahaya konstitusional tersendiri. Ini berbahaya jika materi undang-undang dimaksud telah mengalami pembiasan atau berisikan kehendak politik pragmatis penguasa.

Jika demikian halnya, maka potensi lokal masyarakat yang amat beragam dan dinamika masyarakat tidak akan terakomodasi dengan baik. Pembiaran terus -menerus terhadap kondisi demikian, tentu dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan berikutnya menemui ketidakefektifan di tengah masyarakat. Dalam merespons kondisi demikian, penulis ingat pada Hans Kelsen dalam teori Hukum Murni yang menghendaki adanya pendekatan dinamis selain statis, di mana dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan bermateri dari apa yang ada dalam masyarakat. Penulis menyebutnya pendekatan sistemik, artinya secara simultan statis aplikatif dan dinamis tersebut bergerak saling melengkapi karena hukum itu tidak terlepas dari sosial budaya masyarakat di mana hukum itu berlaku. Dalam konteks kondisi sosial

[11]M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang Undangan*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 7).

budaya masyarakat Indonesia yang penuh keberagaman identitas primordial, menjadikan pemahaman-pemahaman tentang keberagaman tersebut di atas baik ragam secara ideologi, sukubangsa, agama, hukum adat, masyarakat asli tidak asli, budaya, sangat penting bagi legislator dalam memainkan peranannya membuat peraturan perundang-undangan.

Artinya, keberagaman berimplikasi pada Pembangunan Hukum Nasional, khususnya pengakomodasian keberagaman dimaksud dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam konteks otonomi daerah, Pasal 2 ayat 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensinya, semua praktik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat tidak boleh mengubur atribut-atribut yang melekat dalam masyarakat adat dimaksud.

Maka model kluasulanya menjadi misalnya: "Jika terjadi sengketa di kemudian hari, diselesaikan menurut budaya masyarakat setempat di mana sengketa dimaksud terjadi. Dengan rumusan seperti itu, maka dalam praktik penyelesaian sengketa diperlihatkan nilai-nilai lokal yang diyakini sebagai hal yang benar dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian yang nyata lebih efektif dan diterima oleh masyarakat dibanding penyelesaian formil polisionil.[12] Artinya, konflik dan model penyelesaian atas kasus-kasus sengketa agrarian berimplikasi hukum pada pembangunan hukum, khususnya terakomodasi kedalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengingat saluran-saluran kultural masyarakat tempatan mulai berdaya di era otonomi dewasa ini.

Intinya, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dapat dipandang melanggar asas perundang-undangan jika ada penyebutan teknis satu kelompok tertentu karena dengan penyebutan akan berakibat ketersinggungan kelompok lain. Sehubungan dengan itu, ke depan, pasal-pasal harus dapat memberi perlindungan rasa aman secara ideologi, politik, sukubangsa, agama, dan kelompok-kelompok primordial lainnya. Misalnya, dalam proses pembuatan undang-undang, materinya diangkat dari materi lapangan, bukan sebaliknya 'karangan' penguasa di atas meja. Contoh konkret ketika kehendak masyarakat Minangkabau Sumatera Barat untuk memanfaatkan tanah ulayat, kehendak dimaksud diakomodasikan ke dalam Peraturan Daerah tingkat provinsi. Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya misalnya, selain menjawab keraguan ini juga telah menggambarkan kemajuan

[12]Ade Saptomo, "Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Antarpemerintah Daerah dan Implikasi Hukumnya" dalam *Membangun Paradigma Baru Pembangunan Hukum Nasional,"* di Jakarta, Indonesia, 6-7 Desember 2004.

berarti dalam bagi Pembangunan Hukun Nasional, khususnya penyusunan Peraturan Daerah.

Tanah ulayat sebagai fakta agrarian ada di seantero Nusantara, jika daerah lain yang memiliki identitas sama dan meniru apa yang telah dilakukan masyarakat Minangkabau, maka bukan tidak mungkin dalam proses pembuatan peratuan perundang-undangan, misalnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah direvisi, mengingat dalam PP tersebut disebutkan bahwa pendaftaran tanah dilakukan oleh orang/badan hukum. Sementara dalam faktanya, tanah ulayat bukan dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum, tetapi oleh komunal sehingga rumusannya dapat dipertimbangkan untuk direvisi menjadi pendaftaran tanah dilakukan oleh orang/ yang dituakan dalam ulayat/badan hukum.

Dengan semangat otonomi yang telah memberi ruang gerak kebangkitan keberagaman dimaksud di atas, maka dewasa ini bukan keterpisahan, tetapi kebersamaan sedemikian rupa sehingga ke depan diharap semakin banyak terbit undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, hingga peraturan desa yang memuat titik singgung, titik temu secara vertikal antara tatanan lokal dan nasional, Hukum Adat dan negara, tetapi juga secara horizontal semua kelompok primordial terlindungi oleh undang-undang atau perda. Jika demikian, berarti tidak saja secara filosofis nilai-nilai kedesaan yang terangkat ke dalam falsafah Pancasila itu terpenuhi, namun juga memenuhi semangat *Bhineka Tunggal Ika*. Pada saat bersamaan, undang-undang dimaksud juga telah memenuhi 10 asas materi peraturan perundang-undangan, yaitu asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.



Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa, *pertama*, keberagaman telah munculkan fenomena interaksi (hukum lokal dan negara). Untuk itu, seyogianya penentu kebijakan hukum di negeri ini, perancang dan penyusun peraturan perundang-undangan sudah harus memahami dengan baik keberagaman masyarakat lokal (hukum lokal, agama, budaya, dan identitas primordial lainnya) untuk mendialogkan antara hukum negara dan lokal serta mengoperasikan antara kepentingan nasional dan masyarakat tempatan di bawah payung sebuah undang-undang atau pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan agar keberagaman tidak menjadi tenggelam dan terkubur di negerinya sendiri.

Kedua, peraturan perundang-undangan dimaknai selain secara statis sebagai produk yang harus diaplikasikan, tetapi juga secara dinamis sebagai proses pembentukan sehingga peraturan perundang-undangan dipahami sebagai lingkaran sistemik. Dengan demikian, maknanya akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan pembangunan hukum nasional berbasiskan keberagaman,[13] yaitu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengakomodasi keberagaman.

Daftar Referensi

Ade Saptomo. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni: Sebuah Alternatif*. Jakarta: Universitas Trisakti Press, 2009.

————————. *Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Grasindo, 2009.

————————. *Revitalisasi Hukum Adat Nusantara ke dalam Pengembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Pidato Dies Natalis ke-63 Fakulatas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 17 Maret 2009.

————————. "Menyelamatkan Hukum Dari Ambang Kematian" dalam *Revitalisasi Hak Ulayat: Tantangan Atau Peluang*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau Press, 2006.

————————. "Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Antarpemerintah Daerah dan Implikasi Hukumnya" dalam *Membangun Paradigma Baru Pembangunan Hukum Nasional"*, Komisi Hukum Nasional (KHN). Jakarta, Indonesia, 6-7 Desember 2004.

————————. "Local Potential in Land Tenure and Other Natural Re-sources" in *International Conference on Land and Resource Tenure in Changing Indonesia*, Questioning The Answer. Jakarta, Kemala Foundation, October 11-13, 2004.

Ehrlich, E. *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (translated by W.L. Moll). New York: Harvard University Press, 1936.

Franz dan Keebet von Benda-Beckmann. *Jaminan Sosial, Sumberdaya Alam dan Kompleksitas Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.

[13]Pasal 33 ayat 3 menggambarkan bahwa jika dibayangkan jauh ke belakang, tatanan kultural lokal yang mengatur keberadaan sumber daya alam telah ada sebelum lahir negara modern seperti ini terbentuk. Artinya, pengaturan keberadaan sumber daya alam dimaksud diyakini telah lahir mendahului kelahiran negara, demikian pula masyarakat telah ada sebelum negara berdiri. Dengan demikian, asumsinya, praktik pengelolaan sumber daya alam berdasarkan potensi lokal telah dilakukan oleh masyarakat sebelum negara berdiri. Hal itu diformalkan dalam undang-undang pemangku sumber daya alam, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang sebenarnya telah mengakomodasi keberadaan praktik pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat lokal mengingat keberadaan hukum adat diakui dan diakomodasi ke dalam hukum negara.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Griffiths. "What is Legal Pluralism" in *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. No. 24/1986.

Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2008.

Koesnoe, Mohammad. *Hukum Adat*. Surabaya: Ubhara Press, 1996.

Moores, Stradford W dan Gordon R. Woodman. *Indigeneous Law and State*. Dordrecht Holland: Foris Publications, 1987.

M. Solly Lubis. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Nader, Laura and Harry F. Todd, Jr. *The Disputing Process: Law in Ten Societies*. New: Colombia Press, 1978.

Prill-Brett, June. "The Interaction of National Law and Customary Law in Natural Resource Management in the Northern Philippines". dalam *Legal Pluralism and Unofficial Law in Social, Economic and Political Development*. *Papers of the XIIIth International Congress*, 7-10 April, Chiang Mai, Thailand, 2002.

Soenarko. *Susunan Negara Kita*. Malang: Djambatan, 1950.

6

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM

Oleh:
*Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.**

Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang sedang berlangsung dan perlunya suatu kesinambungan yang saat ini berjalan adalah untuk menciptakan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berkemampuan dan berkualitas untuk menyelenggarakan pembangunan. Demi cita-cita nasional untuk mencapai kesejahteraan adil dan makmur serta menciptakan masyarakat madani.

Gerakan pembangunan yang sudah lama terlaksana pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan dalam upaya mentransformasikan manusia-manusia Indonesia yang berada dalam suatu kondisi ke kondisi yang lebih maju baik secara individual maupun dalam konteks sebagai kelompok masyarakat.

Salah satu prioritas dalam pembangunan, yaitu diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, guna mencapai SDM tersebut, diperlukan pengembangan dan perubahan paradigma bahwa pembangunan akan berhasil apabila ditunjang dengan SDM yang mengerti dan patuh pada hukum. Hukum adalah sebagai suatu pijakan yang mendasar dalam menjalankan suatu kegiatan.

Betapa tidak dengan adanya kepercayaan yang hakiki bahwa hukum harus jadi panglima tertinggi, akan menjadi suatu keyakinan bagi masyarakat bahwa dalam rangka menjalankan dan meningkatkan pembangunan dalam kegiatan sehari-harinya akan merasa terlindungi apabila ada individu atau masyarakat yang ingin melakukan tindakan kejahatan. Hukumlah yang akan melindungi apabila hal itu terjadi.

---

*Dekan Fakultas Hukum dan Guru Besar Ilmu Hukum, Universitas Borobudur.

Indonesia begitu mencintai dan melindungi warga negaranya, betapa tidak dalam UUD 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Bahkan di samping itu, dikatakan bahwa setiap warga negara adalah sama kedudukannya di mata hukum. Dengan adanya hal tersebut kita harus yakin bahwa hukum bisa ditegakkan di Indonesia, syaratnya adalah Sumber Daya Manusia yang ada harus berkualitas.

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu pembangunan perlu dan terus dilaksanakan. *Pengembangan SDM adalah merupakan suatu proses jangka panjang untuk meningkatkan potensi dan efektivitas komponen bangsa, yaitu manusia Indonesia.*

Manusia Indonesia atau SDM berkualitaslah yang bisa berkiprah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Perubahan yang begitu cepat dan sangat dinamis adalah ciri yang sangat utama dalam meneruskan keberlanjutan suatu bangsa. SDM yang tidak berkualitas dan tidak berkompetensi sudah pasti tidak akan bisa dipakai atau dipergunakan dalam roda pembangunan ini. Tersingkir, sangat ironis.

Perlu kerja keras untuk dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia. Apalagi sekarang ini indeks SDM kita terpuruk di bawah Negara Malaysia, padahal pada 1975 SDM kita dikirim ke Malaysia untuk membantu pemerintah Malaysia guna mencerdaskan masyarakatnya. Hal ini harusnya menjadi pemikiran yang mendalam bagi pemerintah ke depan kenapa hal ini bisa terjadi. Agar lebih optimal dalam upaya meningkatkan SDM untuk di masa yang akan datang dapat tercapai apabila pemerintah memerhatikan pendidikan dan hukum dengan sepenuh hati. Bangsa yang besar akan terwujud apabila ditopang oleh SDM yang berkualitas, yaitu dengan cara pendidikan. Jadi dengan pendidikanlah dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia akan dapat terwujud khususnya dalam bidang hukum.

Eksistensi hukum menjadi rambu-rambu yang menggariskan tentang aturan main (*rule of game*) bagi setiap SDM tanpa kecuali, agar perilaku dan konstruksi sosial, politik, keagamaan, budaya, dan aspek-aspek kehidupan lainnya berjalan di jalur yang benar. Aturan main yang bernama "hukum" harus ditegakkan supaya masing-masing semua pihak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat menikmati kehidupan damai, aman, dan tertib tidak saling mengganggu dan merugikan di antara satu dengan lainnya.



Kondisi SDM Bangsa

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) mewujudkan suatu tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Pada hakikatnya manusia baik individual maupun kelompok masyarakat

akan berjalan dengan baik apabila mereka patuh dan taat pada hukum, hukum sebagai panglima adalah menjadi cita-cita Republik Indonesia. Namun hingga sekarang cita-cita Republik Indonesia belum begitu terwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia.

Sebagai negara hukum, hukum diberlakukan atau diberdayakan tetaplah sebagai pilihan utama. Karena hukum, seperti yang dilontarkan olen Van Apeldoorn mempunyai tujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum merupakan penjaga atau pelindung "hak damai, hak sejahtera, hak hidup, hak sehat atau hak-hak manusia" lainnya.

Berangkat dari istilah penegakan hukum tersebut di atas, maka hasrat menjadikan hukum sebagai panglima menjadi doktrin dan prinsip yang dapat dikatakan dengan istilah negara berdasarkan hukum (*rule of law*) bukan sebaliknya bahwa negara sebagai *machstaat* atau kekuasaan semata.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rule of law*) maka peraturan hukum itu dibuat dan diterapkan oleh pemerintah (*eksekutif*) besama dengan DPR (*legislatif*). Peraturan hukum yang dibuat tersebut kadang tergesa-gesa sehingga pada akhirnya lahir peraturan hukum yang kurang responsif. Bahkan banyak peraturan hukum yang dikeluarkan saling tumpang-tindih dengan peraturan hukum lainnya, sehingga menghambat penegakan hukum dan membuat masyarakat tidak dapat menerima bahkan cenderung menghambat proses pembangunan yang kita harapkan.

Dengan selesainya pemilu legislatif beberapa hari yang lalu, diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas (Anggota Legislatif DPR/DPRD/DPD), sehingga SDM yang ada tersebut dapat menjadi yang terbaik untuk keberlangsungan pembangunan yang sedang berjalan ini.

Melihat fenomena yang ada sekarang ini dengan memerhatikan kualitas para calon anggota legislatif boleh dikatakan sangat memprihatinkan, apabila kita perhatikan dengan saksama lebih banyak para calon tersebut hanya berbekal popularitas dan kekuasaan saja, tanpa memerhatikan kualitas daripada calon anggota legislatif tersebut.

Bisa dibayangkan apablia SDM tersebut tidak berkualitas, padahal mereka tugasnya sangat berat dalam menjalankan amanah dari para konstituen yang telah memilihnya untuk mewujudkan pembangunan yang diharapkan bagi terwujudnya cita-cita masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi bumerang apabila cita-cita mereka hanya pada mencari kekuasaan semata tanpa memerhatikan kepentingan masyarakat banyak. Ini yang menjadi suatu dilema yang harus diperhatikan.

Reformasi adalah hal yang pada awalnya sangat diharapkan untuk bisa mengubah tatanan dan perilaku SDM menjadi lebih baik. Tetapi hal ini juga belum bisa terlalu banyak kita harapkan. Hanya sebagian kecil saja yang merasakan kenikmatan dari reformasi tersebut (kebebasan mengeluarkan

pendapat, kebebasan berserikat, pers) itulah yang menikmati hasil dari buah reformasi, peningkatan dan pengembangan SDM belum tersentuh.



Perubahan

Reformasi atau demokratisasi merupakan suatu perubahan berbagai unsur yang terdapat dalam negara, termasuk di dalamnya adalah di bidang hukum, misalnya siapa pun manusia di Indonesia harus tunduk pada hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa:

> "setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali."

Dari pasal tersebut sudah jelas, bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perbaikan dalam rangka pengembangan SDM, tentu mendapatkan pendidikan adalah yang utama untuk menuju perubahan SDM menjadi lebih baik.

Perlu diketahui investasi pengembangan SDM sendiri tidak cukup hanya menjelaskan kemajuan sebuah negara atau perusahaan. Tetapi, diperlukan suatu bukti nyata dalam pelaksanaan pengembangan SDM jadi bukan sekadar retorika belaka. Investasi ini memang mahal dan tidak bisa instan untuk menikmatinya, masa yang akan datang hal ini baru bisa dinikmati.

Berpikir mengenai pengembangan sumber daya manusia harus didahului dengan beberapa tindakan nyata. Harus ada pengertian tentang apa yang harus dan dapat dilakukan oleh pemerintah dan hal ini merupakan tanggung jawabnya. Itu yang penting!.

Dalam melakukan perubahan guna pengembangan sumber daya manusia ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Perubahan keahlian dan kompetensi untuk memperbaiki kinerja setiap individu atau kelompok masyarakat.
2. Apa kekurangan tertentu, dan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal ini.
3. Perubahan teknologi, perlu disikapi.
4. Kesempatan, memberi kesempatan atau tidak?
5. Tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab?
6. Perubahan perilaku.

Inti dari fokus pada pengembangan adalah pengertian bahwa kita adalah individu yang utuh (sama artinya dengan kita tidak terpisahkan). Kasus dalam fokus pengembangan adalah bahwa kita berkembang cepat, menjadi kreatif, memberikan sumbangan yang besar jika kita mampu mempertimbangkan hidup

kita sebagai kesatuan dalam membuat kebijaksanaan yang seimbang tentang apa yang baik untuk kesatuan hidup kita, tidak hanya sebatas pada kepentingan kebutuhan jangka pendek saja, yaitu kekuasaan. Fokus pada pengembangan yang harus diperhatikan yaitu:

1. Memerlukan tujuan awal individu dan nilai-nilai yang dibawanya.
2. Dapat meminta belajar untuk melihat apa yang mereka lakukan terhadap keseluruhan hidup.
3. Mendorong individu meluangkan waktunya untuk mempertimbangkan pengembangan diri mereka dan apa yang ingin mereka lakukan.
4. Memungkinkan individu bekerja sebagai kelompok teman guna melakukan proses belajar.

Pendekatan ini dilakukan bukan untuk orang-orang penakut, tetapi ditujukan kepada orang yang mau berubah dan mau melakukan suatu perubahan bagi negara dan bangsanya. Melakukan suatu perubahan ada tiga tekanan yang harus diperhatikan:

1. karena adanya suatu kebosanan,
2. karena adanya suatu kecemasan,
3. karena adanya potensi.



Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang tidak mengindahkan prinsip "*equality before the law*", sehingga menghasilkan perilaku diskriminatif, hal ini akan merusak tatanan sistem, sekaligus akan mencederai serta kegagalan dalam melaksanakan sistem yang menimbulkan citra buruk pada semua kalangan masyarakat yang bermoral termasuk masyarakat internasional.

Kegagalan sistem itu mendorong pihak yang dirugikan mencoba untuk bereksperimen menggunakan cara lain, artinya cara lain dijadikan sebagai pilihan setelah cara normal tidak memihak kepadanya. Tidak memihak berarti sebagai bentuk pelanggaran, perampasan, pelecehan, dan pengebirian hak-haknya, sehingga praktik demikian tidak boleh dibiarkan terus berlanjut merugikannya.

Kalau dipahami dari sudut sistem, maka kegagalan penegakan hukum bisa berakar dan menular kepada pengembangan hukum di masa yang akan datang dan hal ini akan berdampak pada pengembangan Sumber Daya Manusia secara keseluruhan dalam rangka peningkatan pembangunan di segala bidang.

Efektivitas hukum ditentukan oleh efektivitas subsistem hukum secara sinergi, integral, dengan ditopang oleh faktor *sosio cultural* struktural lainnya. Artinya tujuan hukum untuk kesejahteraan masyarakat hanya akan tercapai

apabila struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan kondisi sosio kultural struktural, masing-masing memberikan andil yang positif dan efektif. Adapun budaya hukum atau *legal culture* adalah bagian dari budaya atau *culture* pada umumnya. Tidak berfungsinya atau tidak efektifnya salah satu subsistem hukum lainnya akan menyebabkan hukum menjadi kehilangan makna.

Ketidakefektifan dan penyalahgunaan hukum atau penodaan hukum, hal tersebut merupakan salah satu akar masalah yang digunakan oleh masyarakat sebagai bagian dari cara untuk penegakan hukum yang adil di Indonesia untuk dipergunakan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Produk-produk hukum setelah era reformasi, setidaknya merupakan refleksi hukum sebagai kehendak perlunya pembaruan hukum di Indonesia dalam perspektif menangkal, memerangi, serta melakukan tindakan perlawanan terhadap pelaku kejahatan hukum di era globalisasi, di mana berbagai kejahatan tersebut telah dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Karenanya, konsep pemikiran tentang hukum sampai kepada akar-akar filsafatnya, sehingga masalah-masalah hukum dalam hukum dan penegakan hukum sekarang di Indonesia dapat dikaitkan ke belakang guna menyongsong penegakan hukum untuk masa depan bangsa yang lebih beradab di era globalisasi yang reformis kepada kepentingan bangsa.



Penutup

Menurut Grotius, sifat manusia yang khas adalah keinginannya untuk bermasyarakat, untuk hidup tenang bersama, hal ini sesuai dengan watak intelektualnya. Prinsip-prinsip hukum alam berasal dari sifat intelektual manusia yang menginginkan suatu masyarakat yang penuh damai. Prinsip-prinsipnya yang paling fundamental adalah *pactasuntservanda,* yakni tanggung jawab atas janji-janji yang diberikan dan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani.

Kita sebagai insan yang memiliki wawasan intelektualitas yang bernaung pada suatu lembaga ilmiah, sungguh sangat berharap setiap saat mampu menyampaikan kebenaran atas persepsi guna mewujudkan keadilan sebagai suatu fitrah yang diberikan Tuhan Yang Mahakuasa.

Kita tidak berkehendak menari di atas penderitaan orang lain, dan tidak berkehendak mengabaikan kebenaran yang disampaikan orang lain. Sebagai insan yang bergelut serta menekuni ilmu hukum, maka jika terjadi penodaan terhadap fitrah tersebut, sungguh merupakan kekejian sebagaimana yang dilakukan oleh penegak hukum yang tidak mau berbuat adil terhadap sesamanya yang berkehendak meminta keadilan.

Daftar Referensi

Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Achmad, Ali. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

David Megginson, Jennifer Joy. *The Fast Track MBA Series Human Resources Development*. Jakarta: Media Komputindo, 1997.

Faisal Santiago. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Cintya Press, 2005.

————————. *Memerangi Korupsi*. Jakarta: Cintya Press, 2006

Garry Dessler. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenhalindo, 1997.

Ilham Bisri. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, 2004.

Michael Armstrong. *Performance Management*. London: Kogan Page Ltd 1994.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

William B. Werther, Keith Davis. *Personal Management and Human Resources*. Singapore, 2005.

Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

UUD 1945 Amandemen ke-IV.

7

REFORMASI HUKUM NASIONAL: PROBLEM DAN PROSPEKNYA

Oleh:
*Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.**

HUKUM TELAH MENGAMBIL bagian penting dalam debat, kebijakan, dan program-program pembangunan. Hukum dianggap sangat penting sebagai cara vital untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, hak asasi, dan demokrasi. Sejak 1990-an, negara-negara berkembang dan transisi, telah dikunjungi setidak-tidaknya ratusan, konsultan hukum (*legal advisers*), bahkan ribuan, dari Barat untuk membantu dalam proyek reformasi hukum yang sangat mahal. Padahal pengetahuan mereka mengenai hukum yang ada, institusi pembentukan hukum, dan proses-proses sosio-legal di negara-negara penerima (*host countries*) sangat terbatas, dan banyak di antara mereka cenderung salah asumsi bahwa mereka datang di suatu padang pasir legislatif. Lebih dari itu, mereka merasa membongkar di antara dua ide, yaitu transplantasi hukum disingkirkan dan pembangunan hukum selalu menjadi persoalan transplantasi hukum.[1] Transplantasi hukum memang telah menjadi kecenderungan dalam pembangunan hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Transplantasi hukum itu sendiri dilakukan dengan alasan yang berbeda-beda. Mulai dari upaya menyesuaikan pembangunan hukum nasional dengan kecenderungan global atau internasional sampai ke ikhwal fasilitas perubahan ekonomi, teknologi, sosial, dan politik.

Reformasi hukum nasional dalam pengertian perubahan (*change*) atau perbaikan (*improvement*) dalam tata hukum nasional atau sistem hukum di Indonesia merupakan keniscayaan.[2] Keniscayaan itu di antaranya karena

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

[1]J.M. Otto, W.S.R. Stoter, & J. Arnscheidt, *"Using legislative theory to improve law and development projects"*, dalam RegelMaat, 2004/4, hlm. 121.

[2]Barda Nawawi Arief mengartikan reformasi hukum tidak hanya sebatas reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi, struktur, dan budaya hukum. Bahkan, terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial (termasuk sistem ekonomi). (Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan," (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

dinamika sosial yang mengusung ideologi, nilai, atau ekspektasi yang membutuhkan "pewadahan" hukum baru disebabkan pengaturan dalam hukum positif yang ada tidak memadai. Secara politik hukum, hal ini terkait dengan arah kebijakan program pembangunan hukum, terutama program pembentukan peraturan perundang-undangan. Tulisan ini tidak membatasi pada arah kebijakan program pembangunan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang pembangunan nasional, sehingga tidak sekadar masalah penyelenggaraan fungsi legislasi sesuai UUD 1945 pascaamandemen. Pembahasan dalam tulisan ini terlepas dari telah terjadinya pergeseran fungsi legislasi dari dominasi presiden menjadi superioritas DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), baik terhadap presiden maupun DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Dalam hal ini lebih ditekankan pada ikhwal pencarian ideal-ideal dalam mengubah atau memperbaiki hukum nasional serta penggunaan teori legislasi untuk mengubah atau memperbaikinya.

Pembahasan reformasi hukum menurut J.M. Otto, W.S.R. Stoter & J. Arnscheidt terkait dengan hubungan hukum dan pembangunan (*development*). Untuk memahami bagaimana hukum dalam memberi kontribusi pada "pembangunan", dibutuhkan pemahaman dasar mengenai pembangunan itu. Dengan mengutip pendapat M.J. Esman, digambarkan bahwa pengertian inti dari pembangunan, yaitu *"steady progress toward improvement in the human condition"*. Perbaikan (*improvement*) tersebut dapat menunjuk pada pemenuhan kebutuhan dasar dari warga masyarakat seperti halnya perbaikan pemerintahan (negara), dengan bertolak dari pembedaan antara tujuan pembangunan (*goals of development*) dan tujuan pemerintahan (*goals of governance*). Salah satu kategori dari tujuan pemerintahan adalah pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal itu terkait dengan tujuan pembangunan dalam dua hal. *Pertama*, sebenarnya semua proses pembangunan, baik dalam ekonomi, kesehatan, pendidikan, peradilan atau perlindungan lingkungan, mensyaratkan pemerintahan yang baik. *Kedua,* pemerintahan yang baik menjadi tujuan pembangunan itu sendiri. Dimensi hukum dari tujuan ini telah dinyatakan dalam konsep, seperti *rule of law* dan hak asasi manusia. Pada dasarnya, kondisi ini lebih menunjuk pada "*law-in-the-books"* daripada *"law-in-social-reality."* Di negara-negara berkembang (*developing countries*), hal tersebut problematis karena terdapat kesenjangan sangat besar antara norma-norma yang preskriptif (*prescribed norms*) dan praktik nyata (*actual practice*).[3]

Kesenjangan antara norma-norma yang preskriptif dan praktik nyata tersebut di Indonesia bukan ikhwal yang luar biasa. Dalam ranah peradilan tidak jarang tersaksikan perilaku-perilaku aktor-aktor hukum yang menyimpang atau melanggar norma, seperti peninjauan kembali yang dilakukan oleh kejaksaan; hal ini seakan-akan telah menjadi benar. Terlebih lagi pemaknaan terminologi

[3]J.M. Otto, W.S.R. Stoter, & J. Arnscheidt, *op.cit.,* hlm.122.

hukum dalam ranah di luar peradilan; masyarakat memperlakukan beberapa norma sosial sebagai hukum apa pun alasannya. Beberapa waktu lalu (2008), di eks-karesidenan Surakarta masih muncul hukum "arak-keliling" orang yang berzinah kendati kemudian berakhir di pengadilan bagi "pengarak". Ini menandai konsep hukum sebagai norma yang lazim di negara-negara maju dengan masyarakat yang homogen, tidak selalu dapat dipaksakan pada masyarakat Indonesia yang heterogen. Di Indonesia, terdapat koeksistensi berbagai norma sosial dan pada situasi tertentu norma sosial itu mengalahkan norma hukum. Kasus yang digambarkan di atas—dengan menggunakan istilah Satjipto Rahardjo—hanyalah satu eksemplar saja dari sekian banyak, ratusan mungkin ribuan, komunikasi sederhana di negeri kita.[4]

Itulah yang oleh Seidman sebagaimana dikutip dan dikembangkan oleh J.M. Otto, W.S.R. Stoter, & J. Arnscheidt menuntut diciptakannya konsep sosio-legal yang disebut dengan *"real legal certainty"* (kepastian hukum yang nyata). Proyek-proyek legislasi bagi pembangunan dikaitkan dengan perbaikan hukum dalam pengertian teknis (*improving the law in a technical sense*) dan dikaitkan dengan realitas sosial yang diusahakan untuk dipengaruhi (*social reality it seeks to influence*).[5] Kepastian hukum yang nyata itu berimplikasi bahwa:

1. *a lawmaker has laid down clear, accessible and realistic rules*;
2. *the administration follows these rules and induces citizens to do the same*;
3. *the majority of people accept these rules, in principle, as just*;
4. *serious conflicts are regularly brought before independent and impartial judges who decide cases in accordance with those rules*;
5. *these decisions are actually complied with*.

Penentuan tujuan hukum dan proyek-proyek pembangunan dalam pengertian ini dapat membantu memperbaiki keefektivannya.[6]



Aturan yang Realistis

Seperti dikemukakan di atas, keefektifan aturan hukum sangat ditentukan oleh sifatnya yang realistis, dapat diakses, dan jelas. Uraian ini menjelaskan sebatas pembentukan aturan (*rules*) hukum yang realistis. Hukum yang realistis secara sederhana dapat dimaknai dengan merujuk pada pandangan instrumentalis seperti dikemukakan oleh Brian Z. Tamanaha. Pandangan kaum instrumentalis menekankan bahwa hukum dilihat sebagai suatu instrumen

[4]Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta, Kompas, 2007), hlm. 52.
[5]J.M. Otto, W.S.R. Stoter, & J. Arnscheidt, *op.cit.*, hlm. 123.
[6]*Ibid.*

kepentingan sosial tertentu (*law was seen as an instrument of a particular social interest*).[7] Pada karyanya yang lain, Tamanaha mengemukakan bahwa "Pandangan instrumentalis terhadap hukum melihat bahwa hukum – meliputi aturan hukum (*legal rules*), institusi hukum (*legal institutions*), dan proses hukum (*legal processes*) – secara sadar dilihat oleh seseorang atau kelompok sebagai "alat" (*tool*) atau "cara" (*means*) untuk mencapai tujuan. Tujuan-tujuan yang dilekatkan terbuka dan tidak terbatas, bergerak dari tujuan personal ke ideologis, sampai tujuan sosial, seperti maksimalisasi kesejahteraan sosial (*maximizing social welfare*) atau penemuan keseimbangan kepentingan yang bersaing (*finding a balance of competing interests*)."[8]

Lebih jauh dikatakan Tamanaha bahwa hukum merupakan alat efektif untuk mencapai tujuan sosial; aturan hukum secara konsisten melekat pada adresat hukum tersebut (petugas hukum ataupun masyarakat). Kaum realis mengakui bahwa kegunaan aturan hukum itu meningkat ketika penerapannya lebih dapat diprediksikan (*their applications are more predictable*), sehingga seseorang dapat merencanakan aktivitasnya dengan mengetahui konsekuensinya.[9]

Persoalan yang dihadapi dalam konteks hukum di Indonesia, yaitu bagaimana hukum dapat memenuhi tujuan sosial, sehingga menjadi efektif? Sementara itu, yang terjadi dalam reformasi hukum di antaranya:

1. Produksi peraturan perundang-undangan yang sangat tinggi karena menyesuaikan dengan dinamika atau tuntutan kecenderungan internasional; hal ini ditempuh melalui transplantasi dalam jumlah besar, sehingga potensial melahirkan resistensi, setidak-tidaknya ketidaksesuaian antara hukum dan masyarakat;
2. Pluralitas dan fragmentasi hukum, baik hukum lokal, kebiasaan, hukum agama, maupun hukum negara yang diadaptasi hukum kolonial; hal ini membutuhkan harmonisasi;
3. Secara proses, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum; dalam kondisi ini hukum lebih mencerminkan ambisi elite pembentuk hukum.



Reformasi Hukum, Kecenderungan Global, Pluralitas, dan Pragmentasi

Reformasi hukum sering kali disebabkan faktor eksternal suatu bangsa, dalam hal ini pengaruh kecenderungan global. Globalisasi dalam bentuk pola-

[7]Brian Z. Tamanaha (I), *A General Jurisprudence of Law and Society*, (Oxford, Oxford University Press, 2001), hlm. 44.
[8]Brian Z. Tamanaha (II), *Law as a Means to an End*, (Cambridge, Cambridge University Press, 2006), hlm. 6.
[9]*Ibid*., hlm. 71.

pola perdagangan, komunikasi, dan pembangunan merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan hukum suatu bangsa. Bahkan, ketika globalisasi tidak dapat ditolak, apa pun jenis nilai dan moral yang diusung sering tidak dapat ditolak. Kecuali, suatu negara melakukan isolasi, namun isolasi total adalah ikhwal yang tidak mungkin. Dampak yang ditimbulkan di antaranya, negara-negara bangsa harus berinteraksi dengan cara-cara yang tidak biasa dilakukan. Perubahan hukum suatu bangsa dengan menyesuaikan hukum yang diterima secara internasional karena globalisasi itu menuntut perubahan perilaku warga yang sebelumnya tidak mempola. Hal tersebut terjadi karena perubahan itu ditempuh melalui transplantasi hukum (*borrowing from other legal systems*). Dari perspektif antropologi hukum, hal itu digambarkan oleh Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, dan Anne Griffiths sebagai bentuk mobilitas hukum (*mobility of law*). Proses terjadinya mobilitas hukum yang memengaruhi reformasi hukum itu diakibatkan oleh mobilitas aktor, baik orang maupun organisasi yang bergerak atau berpindah dari satu negara ke negara lain (*mobility of people or organizations*).[10]

Dalam konteks tersebut, seperti diungkapkan oleh Larry Cata Backer bangsa kita dapat: 1) berinkorporasi dengan norma-norma komunitas global; 2) mengomunikasikan dengan merangkul norma-norma global untuk "melawan" (menentang atau mengubah) dasar-dasar normatif globalisasi; atau 3) menolak dan secara efektif menyerang jaringan perdagangan, gerakan orang, komunikasi, atau saling hubungan antara komunitas ekonomi atau politik.[11] Namun, dalam hal reformasi hukum, alternatif pertama menjadi fokus. Dalam kondisi itulah, kemungkinan terjadinya resistensi dari masyarakat. Resistensi tersebut muncul karena norma-norma yang mengglobal itu dibangun dalam basis sosial yang berbeda. Resistensi itu dalam studi perbandingan hukum disebut atau diakibatkan oleh ketidaksepadanan antara hukum dan masyarakat yang menjadi adresat hukum itu (*mismatch between law and society*). Bermuara pada kemungkinan munculnya ketidaksepadanan itu kemudian melahirkan konsep-konsep harmonisasi, konvergensi, divergensi, unifikasi, standardisasi, dan pencampuran (*mixing*).

Bangsa Indonesia memiliki pluralitas budaya, dan dengan demikian juga norma-norma yang melingkupi kehidupannya mengalami pluralitas, bahkan pragmentasi. Beberapa norma hukum yang berasal dari sistem hukum yang berbeda koeksis dalam kehidupan hukum di Indonesia. Perbedaan filosofi dan ideologis, doktrin-doktrin hukum dan cara-cara argumentasi yudisialnya, juga teori dan sumber hukumnya tidak serta merta dapat berintegrasi. Persoalan

[10]Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda Beckmann, dan Anne Griffiths, *Mobile People, Mobile Law, Expanding Legal Relations in a Contracting World,* (England, Ashgate, hlm. 2-3).

[11]Larry Cata Backer, *Harmonization Law in an Era of Globalization, Convergence, Divergence, and Resistance,* (Durham, North Carolina, Carolina Academic Press, 2007), hlm. 10-11.

ini membutuhkan harmonisasi. Menurut Esin Örücü, sebagai suatu metode, harmonisasi menjadi tujuan reformasi hukum.[12] Harmonisasi tidak selalu menciptakan unifikasi hukum, namun mensyaratkan dan mempertahankan diversitas. Dengan analogi musik, komponen-komponen mempertahankan individualitas, namun membentuk bunyi yang baru dan lebih kompleks. Kita dapat mencapai harmoni tidak cuma dengan mengeleminasi diversitas, namun juga dengan diversitas itu.[13] Persoalan ini tampaknya belum digarap dalam reformasi hukum di Indonesia. Pembentuk hukum justru cenderung mengeleminasi keragaman hukum di Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Hikmahanto Juwana bahwa:

> *"Indonesia's vast territory is comprised of numerous, incredibly diverse, regions. For our purposes, this diversity takes at least three main forms. First, the values that exist in a particular region may be totally different from values prevailing in other regions. Secondly, great differences exist in the law supporting infrastructure, such as the number of police personnel, buildings used by legal institution, etc. Thirdly, different regions enjoy markedly different levels of development*
>
> *The point is that diversity is much more prevalent than uniformity. If we study examples of the above three points of difference, the reality of legal pluralism in Indonesia does not come as a surprise."*[14]

Hal tersebut terkait dengan ikhwal rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Tingginya sentralisasi pembentukan hukum atau *top-down model* memiliki peran krusial upaya-upaya elite pembentuk hukum menghadapi pluralitas dengan mengeleminasi diversitas dalam suatu kesatuan hukum negara. Alasan yang acap kali dikedepankan, yaitu bersandar pada pandangan dalam sosiologi bahwa hukum diadakan untuk mengubah masyarakat (*law as an instrument of social change*), sehingga corak hukum sepenuhnya ditentukan oleh elite pembentuknya. Kebanyakan mengabaikan persyaratan seperti dikemukakan oleh William M. Evan, yaitu:

1. hukum harus keluar dari sumber yang prestis dan otoritatif;
2. hukum harus menunjukkan rasionalitasnya, dalam arti dapat dimengerti dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada;
3. dukungan perubahan membutuhkan referensi negara atau masyarakat lain yang dikenal dan hukum tersebut berhasil;
4. penegakan hukum harus ditujukan untuk mengubah dalam waktu yang relatif pendek;

---

[12]Esin Örücü, "Critical Comparative Law, Considering Paradoxes for Legal Systems in Transition", EJCL, Vol.4.1, June 2000, hlm. 14.

[13]*Ibid.*, hlm. 15.

[14]Hikmahanto Juwana, "Legal Pluralism in Indonesia", dalam *Current Issues in Indonesian Law*, University of Washington School of Law in Collaboration with University of Indonesia, Faculty of Law, 2007, hlm. 19.

5. penegakan hukum tersebut meniscayakan komitmen perubahan sebagaimana dimaksudkan oleh hukum;
6. implementasi hukum mengandung sanksi positif maupun negatif; dan
7. penegakan hukum masuk akal, tidak hanya terhadap sanksi yang dipergunakan, tetapi juga dalam perlindungan hak-hak yang hilang karena terjadinya pelanggaran hukum.[15]

Keberhasilan hukum sebagai mekanisme perubahan sosial dikondisikan oleh banyak faktor. Salah satu faktor adalah informasi mengenai legislasi dan putusan. Ketika transmisi informasi tidak mencukupi mengenai ikhwal yang diatur, hukum tidak akan memroduksi hasil yang diharapkan. Penolakan hukum tidak dapat dianggap sebagai permakluman terhadap ketidakpatuhan, tetapi penolakan tentu membatasi keefektivan hukum.[16] Penolakan menjelaskan hukum tidak sepadan dengan masyarakatnya, terutama hukum hasil transplantasi. Harmonisasi sebagai upaya mengeleminasi ketidaksepadanan pada akhirnya dapat menghasilkan pragmentasi sistem hukum karena diversitas yang tetap dijaga.

Daftar Referensi

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Backer, Larry Catá. *Harmonizing Law in an Era of Globalization, Convergence, Divergence, and Resistance*. Carolina Academic Press, Durham, Nort Carolina, 2007.

J.M. Otto, W.S.R. Stoter, & J. Arnscheidt, 2004/4, *"Using legislative theory to improve law and development projects"*, dalam *RegelMaat*.

Juwana, Hikmahanto. "Legal Pluralism in Indonesia", dalam *Current Issues in Indonesian Law*, University of Washington School of Law in Collaboration with University of Indonesia, Faculty of Law, 2007.

Örücü, Esin. "Critical Comparative Law, Considering Paradoxes for Legal Systems in Transition", EJCL. June 2000, Vol 4.1.

Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2007.

Tamanaha, Brian Z., *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford, Oxford University Press, 2001.

[15]Steven Vago, *Law and Society*, Fifth Edition, (New Jersey: Prentice Hall, 1997), hlm. 294.
[16]*Ibid.*

————————. *Law as a Means to an End*. Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

von Benda-Beckmann, Franz dan von Benda-Beckmann, Keebet, *Mobile People, Mobile Law,* Ashgate, England, 2005.

RAJAWALI PERS

8

SISTEM HUKUM MODERN, *RULE OF LAW* DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh:
*Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum.**

Pengantar

Tulisan ini didedikasikan untuk menyambut ulang tahun ke-40 dari Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh,S.H.,M.H, seorang Guru Besar yang masih muda dilihat dari sisi usia, namun semangat yang ditunjang oleh kecerdasannya telah banyak ikut mewarnai pemikiran dalam pendidikan hukum. Pemikiran-pemikirannya tidak kaku, tidak tekstual. Sebagaimana diketahui, persoalan hukum di Indonesia menjadi lebih berat lagi kalau kita melihat cara berhukum di negeri kita. Kualitas penegakan hukum hanya ditentukan oleh ketundukan kepada bunyi teks, tidak peduli apakah teks itu memuat pesan untuk kemanfaatan secara berkelanjutan atau tidak. Oleh karena itu, cara berpikir yang tidak tekstual seperti mewarnai cara pandang Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, bagi saya layak dikembangkan supaya hukum dapat memenuhi tujuan esensiilnya, yaitu keadilan.

Sistem Hukum Modern dan Kapitalisme

TERDAPAT HUBUNGAN antara sistem hukum modern, prinsip *rule of law* dan timbulnya kemiskinan di Indonesia. Hubungan tersebut merupakan hubungan sebab-akibat. Sistem hukum modern adalah sistem hukum yang didasarkan pada asas-asas dan lembaga-lembaga hukum yang berasal dari Eropa Barat yang tumbuh pada abad ke-19 bersamaan dengan tumbuhnya kapitalisme. Karakteristik sistem hukum modern dapat diidentifikasikan sebagai berikut (Satjipto Rahardjo, 2005):

*Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.H., adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

a. merupakan sistem hukum yang berasal dari tatanan sosial Eropa Barat pada abad ke-19;
b. sangat dipengaruhi oleh paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan alam;
c. rasional, lepas dari pengaruh ketuhanan;
d. meyakini bahwa hukum dapat dikonstruksi dan dikelola secara netral, tidak berpihak, impersonal, dan objektif;
e. mendukung terciptanya kepastian dan prediktabilitas;
f. melindungi hak asasi manusia dan kebebasan.

Akan tetapi, perlu dikemukakan pendapat Boaventura de Sousa Santos (1995) yang menyatakan bahwa, saintifikasi dan sistem hukum modern yang dibangun pada abad ke-19 dimaksud untuk kepentingan melayani tatanan sosial yang bercorak pasar bebas yang kompetitif melalui kebebasan yang dijamin oleh sistem demokrasi. Lebih lanjut dikatakannya, ahli hukum abad ke-19 (di Eropa Barat) telah menciptakan sistem hukum modern yang didasari ide demokrasi dan pasar bebas yang harus ada dalam sebuah republik. Jadi boleh dikatakan, sistem hukum modern dimaksud untuk melanggengkan sistem kapitalisme. Berdasarkan konsep-konsep yang dibangun dalam sistem hukum modern itulah maka dibangun ajaran hukum *rule of law.*

Rule of law menurut Gerald Turkel (1995) mengandung makna bahwa hukum merupakan sumber tertinggi untuk pengendali sosial *(the law is the ultimate source of social control)*. Di bawah prinsip *rule of law*, masyarakat meyakini bahwa hubungan-hubungan di antara mereka dibatasi oleh ketentuan hukum dan peran lembaga-lembaga hukum. Akan tetapi, tidak boleh dilupakan bahwa pertumbuhan prinsip *rule of law* tidak bisa dilepaskan dari pola-pola hubungan masyarakat dan gerakan-gerakan masyarakat yang menempatkan kemerdekaan individual sebagai landasan utama pengorganisasian masyarakat *(the liberty of individual as a basic principle of social organization)*.



Rule of Law yang Tidak Pro Kemiskinan

Ahli-ahli sosiologi hukum (Weber, 1968; Trubek, 1972; Turkel, 1995; dan Unger,1976) berpendapat bahwa *rule of law* bersumber dari pengakuan bahwa kebebasan individual dapat dicapai dalam masyarakat yang diatur berdasarkan hukum untuk membatasi kekuasaan negara dan menjamin hak-hak ekonomi. Akan tetapi, ada identifikasi tentang *rule of law* dari Gerald Turkel (1995) yang harus diperhatikan dalam konteks masalah kemiskinan di Indonesia sebagai berikut:

a. *the rule of law, is not oriented toward social goals or solving social problems by creating and implementing policies*;

b. *in rule of law, law is not an arena for solving problems of poverty*;

c. *rather, the rule of law provides a stable order for individuals and businesses to pursue their economic interests*.

Dengan demikian, jelas bahwa prinsip *rule of law* sesungguhnya tidak dimaksud untuk menjadi sarana pencapaian tujuan masyarakat atau sebagai instrumen untuk memecahkan problem-problem masyarakat seperti masalah kemiskinan. *Rule of law* lebih dimaksud untuk menciptakan tatanan yang stabil bagi individual dan dunia usaha berkaitan dengan aktivitas ekonominya.

Lebih lanjut, manakala organisasi (kelembagaan) di dalam masyarakat menjadi semakin kompleks, aktivitas ekonomi diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengarah pada pemberian ruang bagi kapitalisme dan pasar bebas, identitas individual menjadi semakin penting daripada identitas kolektif dan masyarakat menjadi semakin terkotak-kotak atas dasar agama maupun kebangsaan, maka hukum akan tumbuh menjadi sarana untuk penyelesaian sengketa dalam masyarakat dan instrumen pengawas kegiatan individual. Pola kehidupan sosial seperti ini akan semakin meningkatkan kecenderungan melemahkan rasa kebersamaan, kepedulian akan sesama di dalam masyarakat.

Hasil temuan Gerald Turkel (1995) ini selanjutnya harus kita cocokkan dengan keadaan Indonesia sekarang ini. Melihat hasil temuan Gerald Turkel dan menjadikannya sebagai alat analisis keadaan di Indonesia sekarang, maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia ajaran *rule of law* (dalam artian klasik) telah "mendapatkan tempatnya" dalam pengertian, *rule of law* cocok dalam konteks kekinian Indonesia karena hukum-hukum yang berlaku di Indonesia semakin memfasilitasi dan memberi ruang bagi berkembangnya ekonomi kapitalistik dan pasar bebas yang mewujud dalam berbagai privatisasi.

Dominannya aturan-aturan hukum yang ditujukan untuk memfasilitasi kepentingan kapitalisme dan pasar bebas mendorong diimplementasikannya program-program penyesuaian oleh pemerintah Indonesia demi mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga atau negara donor. Oleh karena itu, program-program seperti swastanisasi berbagai sektor publik, penegakan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), pengakuan hak mogok buruh, dan penyesuaian model pengelolaan ekonomi dengan dukungan IMF, World Bank, dan WTO yang dibakukan dengan aturan-aturan hukum, sulit dihindarkan, karena adanya dorongan untuk mengakomodasi kebijakan negara atau lembaga donor. Tidak dimasalahkan apakah program-program penyesuaian dan aturan hukum yang diterbitkan kemudian, mampu menjawab problem kemiskinan maupun korupsi di Indonesia. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, keberpihakan pada hak-hak masyarakat lokal, perwujudan keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan menjadi terpinggirkan.

Implikasinya, pola kehidupan sosial di Indonesia akan semakin meningkatkan kecenderungan melemahnya rasa kebersamaan, kepedulian akan sesama

di dalam masyarakat. Kegiatan perekonomian akan lebih didominasi oleh praktik-praktik bisnis dengan tingkat kompetisi yang amat tinggi, pengabaian terhadap solidaritas, pengabaian terhadap pencapaian kesejahteraan bersama dan dalam batas tertentu lenyapnya etika dalam pengelolaan bisnis maupun lingkungan hidup.



Memaknai *Rule of Law* Secara Progresif

Sistem hukum modern di dalam perkembangannya melahirkan ajaran *rule of law,* sekalipun telah dikonstruksi sebagai ketentuan yang bersifat netral, tidak berpihak, bersifat impersonal (tidak subjektif) di dalam implementasinya ternyata menunjukkan hal yang sebaliknya. Bahkan sejak ketentuan itu dibuat ternyata hukum sudah bisa bersifat tidak netral, memihak pada kepentingan tertentu yang lebih dominan. Keberpihakan hukum pada kekuatan yang lebih dominan bisa terjadi karena sesungguhnya (sebagaimana dikatakan Sampford, 1999) basis sosial hukum sesungguhnya penuh dengan hubungan yang kompleks, tidak kaku, bahkan bisa mengarah pada keadaan tidak seimbang. Apa yang di permukaan tampak teratur, tertib, jelas, dan pasti sebenarnya adalah ketidakteraturan. Sampford *(1999,)* menyebut keadaan seperti ini dengan istilah *social melee*. Dalam kaitan ini hukum akan memberikan keuntungan pada pihak yang dominan atau kuat, sekalipun secara formil disebutkan bahwa suatu ketentuan hukum tertulis adalah hasil "kesepakatan" bersama. Subjek yang mengatakan bahwa suatu ketentuan hukum telah dibuat atas kesepakatan bersama adalah subjek-subjek yang berkepentingan untuk menyatakan demikian. Kemudian muncullah ketimpangan dan kemiskinan.

Akan tetapi, menolak laju ekonomi pasar di era globalisasi ini bukanlah pekerjaan mudah. Globalisasi dengan segala implikasinya adalah keniscayaan. Namun, jika dominasi hukum di Indonesia semata-mata hanya cenderung mengabdi pada kepentingan ekonomi pasar dan meminimalkan peran negara, maka hasilnya hanya akan mengukuhkan kesenjangan sosial dan keberadaan kemiskinan. Oleh karena itu, yang diperlukan di Indonesia kini adalah aturan hukum yang masih memberi ruang pada ekonomi pasar, tetapi dikombinasikan dengan pemberlakuan hukum dan kebijakan yang memihak pada pemenuhan kebutuhan dasar, perwujudan keadilan sosial, penguatan kapasitas masyarakat lokal, dan perlindungan lingkungan.



Penutup

Menyadari hal itu maka sudah saatnya sistem hukum modern dan ajaran *rule of law* di Indonesia harus dimaknai secara lebih progresif. Hukum di Indonesia harus kembali menjadi tempat mencari keadilan, bukan sekadar tempat untuk

mengaplikasikan atau menegakkan peraturan yang mengabdi pada kepentingan pengembangan liberalisasi yang memiskinkan. Keinginan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia tidak bisa tidak harus melibatkan perubahan hukum karena hukum yang ada kini justru berpotensi memiskinkan masyarakat. Perubahan itu wajar dan harus ada karena hukum tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang final dan ia selalu dalam proses untuk terus dibangun agar dapat mewujudkan keadilan substansial bukan sekadar keadilan formal. Ajaran *rule of law* dalam konteks kekinian di Indonesia tidak boleh dimaknai sekadar untuk memfasilitasi pengembangan pasar bebas yang bersifat kompetitif, tetapi sebaliknya, harus diusahakan menjadi instrumen untuk melepaskan diri dari situasi yang semakin kapitalistik atau setidaknya menjadi landasan aturan hukum untuk mengarahkan terselenggaranya ekonomi pasar yang berkeadilan sosial.

Daftar Referensi

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006.

————————. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan" dalam Jurnal Hukum Progresif, Volume I/Nomor 1/April 2005, Diterbitkan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,2005.

Samekto, FX Adji. *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

————————. *Justice Not For All: Kritik Terhadap Hukum Modern*. Yogyakarta: Genta Press, 2007.

Turkel, Gerald. *Law and Society: Critical Approaches*. Toronto: Allyn and Bacon, 1995.

Trubek, David M. *Max Weber on Law and the Rise of Capitalism*. Yale School Studies in Law and Modernization, No.4 (tanpa tahun).

Unger, Roberto Mangaibera. *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard University Press, 1986.

9

MEMBANGUN KESADARAN HAM DALAM MASYARAKAT MODERN

Oleh:
*Prof. A. Masyhur Effendi, S.H., M.S.**

DALAM ERA GLOBALISASI sebagai akibat revolusi IPTEK yang tidak terbendung (informatika, elektronika, biotek, computer, dan nuklir) dalam masyarakat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, terutama bagi masyarakat yang sedang berkembang, sehingga dalam berbagai ilmu sosial kemasyarakatan pun menimbulkan pemikiran-pemikiran baru termasuk dalam ilmu hukum.

Dalam praktik bernegara dan bermasyarakat, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional, kita dihadapkan kepada kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang sangat memprihatinkan. Antara lain berupa penyalahgunaan wewenang, penyelewengan, korupsi, menang sendiri, hanya untuk "aku" dan berbagai bentuk/model dan modus yang menunjukkan sikap mental yang kurang kuat, "sak kepenake", kerja asal-asalan, kurang adanya rasa tanggung-jawab dan pokoknya kerja atau asal kerja.

Hal ini merupakan satu refleksi kurangnya tanggung jawab. Gejala ini banyak sekali dirasakan dalam masyarakat, baik nasional maupun internasional sehingga sangat mendambakan munculnya manusia-manusia yang mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dan benar. Kalau kita melihat perkembangan masyarakat internasional, persoalan-persoalan yang menonjol dan seakan-akan merupakan persoalan abadi antara lain seputar keadilan, kemakmuran (baca: kemiskinan/kemelaratan), kedaulatan, hak asasi, di samping berbagai persoalan lainnya akan terus-menerus kita saksikan.

Dalam rangka ikut memikirkan masalah-masalah internasional tersebut, banyak usaha yang telah ditempuh oleh berbagai organisasi internasional dan organisasi-organisasi regional lainnya, di antara sekian banyak organisasi yang ada, Richard A. Falk, Saul H. Menlovitz, dkk., pernah mengajukan satu proposal

*Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta.

yang disebut *WOMP (World Order Model Project)* dan dikembangkan tahun 1968 dengan maksud/cara:

> *"…to promote just world order by assembling scholars, intellectuals, and activies from various parts of the world to undertake research, publication, education, and other promotional activities. Perceiving the contemporary world as beset by complex and interrelated problems of war, poverty, social injustice, ecological instability and alienation, they employ an analytic-ethical scheme of inquiry, organizing around the basic theme of peace, economic well-being, social justice, ecological stability, positive, identity and meaningful participation…"* (Lungchu Chen, 1989; 445)

Kalau diperhatikan bersama, banyaknya pelanggaran terhadap kesepakatan-kesepakatan internasional yang ada terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepada negara/seorang, penyalahgunaan kekuasaan, peremehan tugas, tidak mau memerhatikan hak orang lain, yang utama "aku senang/puas" dan berbagai hal yang bernada negatif, kalau dipikirkan secara mendalam antara lain berkaitan dengan kurang dan tipisnya rasa tanggung jawab. Hal tersebut telah melanda dalam berbagai strata masyarakat, baik nasional maupun internasional untuk mengikuti "hati sendiri" enak sendiri, malah juga kaya sendiri, dan lain-lain.

Gejala tersebut dilihat/dikaitkan dengan kesadaran orang/golongan lain akan banyak terkait dengan kualitas mental/moral/etika seseorang. Lebih-lebih bila dihubungkan dengan masalah yang lebih substansial, menghormati hal asasi manusia, antara lain menjunjung keadilan, kebenaran, kejujuran, kebersamaan, kemakmuran, persamaan, kepastian, keseimbangan dapat terwujud dalam masyarakat.

Dalam masyarakat, banyak dijumpai pesan-pesan hukum yang belum dapat berjalan dalam masyarakat dengan baik, masih banyak pelaksana hukum dan anggota masyarakat yang bertindak "seenaknya". John Farrar menyatakan: *" … law (as a set of laws and morality can perhaps be justified on rational ground, but law always falls back on the nation of authority, an internal consistency in the use of authority, which called legality) …"* (1977: 9).

Dengan demikian, para pelaksana hukum dan pemerintahan harus bertindak jujur, *"justice is fairness."* Kalaulah "kejujuran" sudah merambah menjadi milik anggota masyarakat, maka "kredo" hukum untuk membahagiakan seluruh masyarakat akan tercapai, sebagaimana harapan Jeremy Bentam, pendiri aliran utilitas *(doctrine of utility): "…that of utility and be wishedhe wished to test every law to see if it led to the greatest happiness of the greatest number…"* (GW. Patton, 1951: 4)

Sehubungan dengan pendangan tersebut, pelaksanaan pada penafsiran kontekstual/sosiologik, diharapkan hukum dapat membahagiakan anggota masyarakat sebanyak-banyaknya "hanya" dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Dengan demikian, hukum pertama merupakan saluran yang paling tepat untuk menyelenggarakan/menggelar keadilan/yang dianggap adil dalam masyarakat *(law as a channel of justice)*. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum alam yang berisi konsep keadilan dan moral, demikian kata Marcus G. Singer, yang dalam "penjabaran/pengisiannya" lebih lanjut, prinsip-prinsip hukum alam akan sesuai dengan akal (rasio), tuntutan masyarakat dan kondisi hukum yang berlaku (hukum positif), malah kata O.Von Gierke "…(hukum alam) jika tidak diperkenankan masuk dalam hukum positif, ia kian terbang ke sana-ke mari seperti hantu dan mengancam akan berubah menjadi kelelawar yang menghisap darah dari tubuh hukum positif …"(A.P. d'Entreves, 1963: 130). Pandangan tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa "hubungan" antara hukum alam dan hukum positif sangat erat.

Adil dan benar yang menjadi ciri hukum haru dapat menjadi "isi dan pegangan" hukum positif suatu negara. Dengan demikian, hukum dalam masyarakat harus dapat mengantarkan anggota masyarakat menikmati keadilan atau satu kesepakatan bersama yang dianggap adil, sehingga Roscoe Pound menyatakan,

> *"…law is more than a set of abstract norms or a legal order, it is also a process of balancing conflicting interest and securing the satisfaction of the maximum of wants with the minimum* of *friction…"* (G.W. Paton, 1951: 18)

Dan seterusnya dikatakan:

> *"…the record of a continually wider recognizing and satisfying of human wants or claims or desires through social control; a more embracing and more affective securing of social interest; a continually more complete and effective elimination of waste and precluding of friction in human enjoyment of the goods of existence in short a continually more efficacious sengineering…."* (Ronny Hanitijo Soemitro 1984: 21).

Dari sisi ini, tampak hukum di dalam fungsinya dapat pula mengubah, merekayasa, mengatur, memaksa masyarakat untuk melangkah sesuai dengan irama dan cita-cita hukum, satu situasi yang adil atau dianggap adil lewat kesepakatan bersama (bukan kehendak penguasa). Dengan demikian "lengkaplah" tugas hukum, *as a channel of justice* dan *as a tool* [1]*of social engineering*. Persoalannya kemudian, bagaimana kita, anggota masyarakat. Akankah kita menyalahgunakan/memutarbalikkan "misi" hukum yang ada. Persoalan, antara *justice/gerecht/*adil, *truth/rechtig/*benar dalam hukum *(law, recht)* selalu dibicarakan terus sepanjang masa, hal ini menyangkut tidak hanya hakikat kemanusiaan dan harkat manusia sendiri dalam masyarakat, tetapi juga hubungan antarmanusia bermasyarakat. Dalam hukum alam *(natural law)*, salah satu " muatannya" adalah hak-hak pemberian dari alam *(natural rights)*, karena

[1]DINAMIKA HAM. 1 No.01, Mei-Oktober 1997.

dalam hukum alam ada sistem keadilan yang berlaku universal. Adanya hak dalam hukum alam memihak kepada kemanusiaan. Lepas dari adanya kelemah-an-kelemahan yang ada, perdebatan tentang hubungan antara hak, kewajiban dalam diri hukum itu sendiri akan terus berlangsung. Satu hal yang pasti, hak mempunyai kedudukan/derajat utama dan pertama dalam konteks hukum dan hak asasi manusia. Dalam rangka tercapainya keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat dalam praksisnya terkait dengan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Tiga elemen tersebut secara proporsional akan mewujudkan hubungan ideal antaranggota masyarakat.

Selama ini, hak asasi manusia, yang sering disebut hak kodrat, hak dasar, juga dengan *natural rights,* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *grond rechten, mensen rechten, rechten van deen mens*, menjadi bahan debat internasional yang tidak ada hentinya. Istilah-istilah tersebut menunjuk, sebagaimana disebut di muka, titik beratnya pengakuan adanya hak manusia. Dalam kehidupan manusia bermasyarakat lebih lanjut, hak asasi manusia selain "bergandengan tangan" dengan kewajiban asasi juga tanggung jawab asasi.

Hak dalam dirinya-selain merupakan suatu wewenang/tuntutan *(claim)*, karena merupakan wewenangnya-juga menjadi miliknya yang sangat berharga. Tuntutan tersebut bagian integral dari hak itu sendiri. Artinya, manakala hak-hak kemanusiaan diinjak-injak, dikesampingkan, disepelekan, dilecehkan, di-langgar sampai dihapus atau dibuang, akan timbul tuntutan pemulihannya.

Louis Henkin, dalam tulisannnya *The Rights of Man Today,* dikutip oleh Philipus Hadjon:

> *"…Human right are claims asserted recognized 'as of rights' not claims upon love or grace or brotherhood, or charity one does not have to earn or deserve then. They are not merely asoiration or moral assetions but, increasingly, legal claims under some applicable law"* (1985: 50).

Istilah *natural rights* berkembang menjadi *human rights* pada abad XVIII oleh para sarjana Prancis/Inggris (Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, JJ. Rousseau) mengandung makna persamaan di depan hukum.

Dalam sejarah perkembangan lebih lanjut, istilah hak asasi manusia dikenal pula istilah *fundamental rights,* meliputi baik *legal rights* dan *moral rights*. Hak asasi dikatakan fundamental bukan karena hak-hak tersebut konstitusional sifatnya (1985: 51).

Perkembangan konsep hak asasi manusia seirama dengan perkembangan pemikiran hukum alam karena itu penelusurannya, dilihat dari segi sejarah, terdapat kebersamaannya.

> "Abad XX menjembatani hukum kodrat dan hukum positif, menjadikan hak-hak kodrat sebagai hak-hak positif (*positive legal rights*), mengawinkan penekanan pada individu (yang sifatnya otonom dan memiliki kebebasan) dengan penekanan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk semuanya,

mengawinkan pandangan terhadap pemerintah sebagai ancaman bagi kebebasan dengan pandangan terhadap pemerintah sebagai alat yang dibutuhkan untuk memajukan kesejahteraan bersama" (1984: 53).

Sebaliknya abad-abad sebelumnya, abad XV/XVI dengan sistem pemerintah otoriter, kebanyakan segi-segi kewajiban manusia yang ditonjolkan, dalam arti seluruh anggota masyarakat harus melaksanakan kewajiban untuk negara.

Abad XVIII mulai mengedepankan kemerdekaan dan kebebasan individu sebagai "arus balik" sistem pemerintahan diktator/otoriter sebelumnya yang mengilhami revolusi Amerika/Prancis, maka abad XIX menekankan aspek persamaan di depan hukum.

Artinya individu sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat hidup sendiri-sendiri, harus hidup dalam satu masyarakat bersama karena mempunyai persamaan tujuan, persamaan kepentingan sehingga hak-hak individu mempunyai pula fungsi sosial karena itu, hak individu yang semula sifatnya mutlak seperti hak milik "bergeser" dan mengandung unsur-unsur sosial sedangkan abad XX, kedua hak tersebut merupakan satu paket yang tak terpisahkan sebagai dasar *(basic rights)* dengan jalan memasukkan ke dalam satu deklarasi internasional tentang hak asasi manusia, lewat Deklarasi Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia tidak terbatas pada hak politik/sipil tetapi hak[2] ekonomi, sosial, dan kultural dan dapat berkembang terus merupakan bagian integral dari "isi" hak asasi manusia.

Dari sisi ini, harus diakui bahwa hubungan antara hukum alam dan hak asasi bersifat integratif dalam arti antara hukum alam dan hak asasi manusia tak dapat dipisahkan. Keadilan universal merupakan keadilan potensial, berkembang dalam tafsir yang beragam manakala berhadapan dengan politik dan negara.

Namun yang pasti, penafsiran dan pelaksanaannya jauh dari ide dasar hukum alam dan kemanusiaan hanya bersifat sementara.

> *Human rights is a fairly new name for what where formerly called "the rights of man"…the rights of man at an earlier date had itself replaced the original term "natural right."*

Demikian ungkapan Ny. Eleanor Roosevelt pada 1940 dalam rangka mengembangkan PBB (Maurice Cranston, 1983: 1).

> *Golongan Stoi berpendapat bahwa antara jurist dengan filosof mempunyai ide yang sama, sebagaimana dikatakan Cicero, "there is a true law, right reason, an accordance with nature, it is unalterable and eternal"* (Maurice Cranston, 1983: 3).

[2]DINAMIKA HAM. Volume No. 01, Mei-Oktober 1997.

Dalam "perjalanan" para penganjur hak asasi memperjuangkannya memerlukan waktu yang cukup panjang. Dengan demikian, konsep HAM adalah konsep tentang diri manusia sendiri, bicara kita sendiri, karena kalau mau jujur, konsep HAM yang dimiliki manusia untuk selama hidup merupakan konsep universal yang tak dapat diingkari.

Hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi dewasa ini harus ditafsirkan secara kontekstual dengan pendekatan integral, sehingga hak asasi manusia mempunyai arti-tidak saja bagaimana kita kenal "sekadar" bebas berbicara, bebas berkumpul, bebas beragama, juga terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab asasi, sehingga tercipta harmonisasi tata kehidupan dalam masyarakat.

Masalah kemanusiaan dalam arti menjaga, manghormati haknya, merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena pemerintahan memegang amanat/ kepercayaan untuk menjaga hak-hak tersebut.

Tentu saja suara kekuatan kelompok idealis (intelektual, ilmuwan, cendekiawan, budayawan, agamawan, seniman, dan lain-lain) berperan sebagai faktor penunjang utama. Keterlibatan dua unsur tersebut menjadi sangat mutlak.

Membicarakan hak asasi manusia masih tetap relevan sepanjang masa. Dalam praktisi, masalah hak asasi manusia "muncul" selalu terkait dengan ketidakadilan, kemelaratan, kesewenang-wenangan, keakuan tindakan/ kebijaksanaan seenaknya, dan berbagai praktik yang mengandung unsur ketidakpastian, kecemasan terhadap manusia lain.

Kearifan dan keterbukaan pemegang kekuasaan untuk selalu membaca dan mendengar "tanda-tanda zaman" dan suara hati nurani semua golongan sangat diharapkan. Keterbukaan yang dilandasi dengan iktikad baik merupakan awal pembudayaan dan semangat menghormati hak asasi manusia.

Hak asasi manusia universal sifatnya, faktor budaya sejarah suatu bangsa memungkinkan adanya "perbedaan." Karena itu, kalau ada anggapan antara pandangan Barat dan Timur berbeda, derajat perbedaannya hanya ada di permukaan" bukan hakiki dan bukan absolut.

Intinya pada suatu pihak mengatakan kemandirian dan aktualisasi orang perseorangan mendapat prioritas pertama, yang lain menyatakan, hak-hak ekonomi, sosial, dan kultural, merupakan prioritas/landasan utama.

Soalnya sekarang, bagaimana memadukan pandangan-pandangan tersebut dengan harapan hak asasi manusia yang begitu mulia, justru menjadi penyebab, antara lain terkotak-kotaknya negara-negara yang ada di dunia.

Melihat beragamnya pandangan yang mengakibatkan perbedaan pelaksanaan hak asasi manusia, kiranya pendekatan integralistik merupakan pemecahan yang memadai. Lewat pendekatan tersebut, berarti tidak saling mempertanyakan perbedaan hak-hak tersebut, tapi saling melengkapi, justru

antara hak politik, sipil tidak dapat dipisahkan dengan hak ekonomi, sosial, dan kultural, dan lain-lain. Kedua kelompok hak tersebut merupakan refleksi hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik. Karena itu, negara sebagai organisasi politik yang terpenting menyadari peranannya yang menonjol.

Walaupun hak asasi manusia begitu kompleks, pendekatan kontekstual dan integral dengan menempatkan hak asasi manusia dalam "satu paket"berisi tiga elemen. Pada tatanan teori, elemen awal dan pertama dari dua elemen yang lain, berupa hak (wewenang *right)* memiliki "nilai lebih" dibanding dengan dua elemen yang lain dalam makna hak asasi itu sendiri. Namun, dalam tatanan praktis sosiologis, antara tiga elemen tersebut dalam posisi seimbang.

Dalam teori, ada dua elemen hak asasi manusia secara fungsional mempunyai nilai sama, yaitu elemen hak (wewenang) dan kewajiban ("beban"*/duty*). Selanjutnya dalam tatanan praktis "masuknya" tanggung jawab ("kesadaran", *responsibility, a committed citizen*), menjadi mutlak. Dengan demikian, seorang yang memiliki hak, juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab.

Sehubungan dengan itu, terselenggaranya sistem pemerintahan demokratik, transparan kepada warga negaranya akan "lebih mudah" memberi keyakinan kepada warga negara dan akan mendapat kepercayaan lebih besar dari rakyat, sehingga pelaksanaan hak asasi yang diiringi dengan kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi dapat dimengerti. Dari segi edukatif, terkandung unsur mendewasakan warga negara. Sebaliknya pemerintah yang tertutup, hal ini sulit terlaksana.

Ketiga elemen tersebut, sering "berhimpitan" sehingga menjadi sulit untuk dipisahkan, tetapi dalam hal-hal tertentu, ketiganya terpisah dan mempunyai makna yang berbeda-beda. Akibatnya, sering satu sisi, antara kewajiban dan tanggung jawab dianggap mempunyai arti yang sama.

Austin Fagothey menguraikan/membedakan tanggung jawab (*responsibility*), kewajiban (*duty*), dan hak (*rights*), pada garis besarnya dijelaskan sebagai berikut.

A. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan satu refleksi tingkah manusia. "Penampilan" tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya/mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain, mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah "dipimpin" oleh kesadaran intelektualnya. Persoalannya kemudian, sejauh mana orang per orang bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya.

Tidak semua tanggung jawab dapat dijelaskan dengan keinginan. Hal ini berkaitan dengan keputusan yang diambil karena tidak semua pengetahuan

dikuasai dengan benar, demikian juga keinginan tidak selalu melewati satu keputusan yang seimbang/benar. Apa yang lebih dahulu ada pada keinginan seseorang, langsung maupun tidak langsung, akan berkaitan dengan bentuk tindakan itu sendiri, dan mungkin sebanding dengan tingkat kebebasan dan kemampuannya.

Setiap perbuatan manusia, antara lain dapat dibedakan antara tidak adanya keinginan untuk berbuat/berakibat seperti itu, atau sejak awal sama sekali ingin tidak melakukan sesuatu. Pada kasus pertama yang bersangkutan tidak ada kebebasan, sedangkan pada tindakan kedua benar-benar bebas.

Modifikasi rasa tanggung jawab menurut A. Fagothey dapat dalam bentuk *ignorance* (karena ketidaktahuan), *passio*n (perasaan kesungguhan), *fear* (akibat perasaan yang takut luar biasa), *force* (adanya kekuatan/paksaan/gejolak perasaan), *habit* (kebiasaan).

Dengan demikian, tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan "gejolak jiwa" sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Dari penjelasan di atas, terbukti tanggung jawab sebagai salah satu bentuk ungkapan jiwa memang ada, juga merupakan bagian bentuk dari "tingkah laku" mental seseorang. Di sini, terbukti tanggung jawab sebagai salah satu bentuk ungkapan jiwa memang ada, juga merupakan bagian bentuk dari "tingkah laku" mental seseorang. Di sini terbukti tanggung jawab dapat berdiri sendiri dalam arti tidak selalu dan tidak harus merupakan bagian dari elemen rasa yang lain, misalnya dari kewajiban, sehingga tidak selalu berhimpitan. Manusia diberi tanggung jawab oleh hukum sehingga "posisi" tanggung jawab sejajar dengan hak dan kewajiban yang selama ini dikenal dengan baik dalam hukum.

Tingkah laku hendaknya memerhatikan:

1. *the act must be or indifferent in itself*,
2. *the good must not be obtained by mean of the evil*,
3. *the evil must not be intended for itself*,
4. *there must be a sufficient proportion (1972: 37)*

Dilihat dari sudut ini, tentunya tidak semua perbuatan manusia dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada yang bersangkutan tanpa memerhatikan, tidak saja segi-segi koneksitas dan isinya, tetapi juga aspek formalitas dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

Dengan masuknya unsur tanggung jawab dalam praktik bermasyarakat diharapkan akan mengurangi "kerja sakarepe dewe", sekehendak hatinya, apatis, sekadar kerja, asal-asalan, dan lain-lain.

Diharapkan pula "penempatan" segi tanggung jawab dalam kerangka pemikiran hukum dapat mengurangi tindakan perbuatan hukum "negative"

(*onrechmatig daad,* delik, dan lain-lain) yang ada. Di sini hukum lebih memberi "sumbangan" semakin konkret dalam upaya membangun bangsa.

B. Kewajiban

Kewajiban *(duty, onligation, oughtness)* merupakan satu aspek yang terkait secara langsung dengan hukum, sehingga ada "ikatan" antara keduanya. Tanpa adanya kewajiban tidak pernah ada hukum. Immanuel Kant yang mengembangkan teori kewajiban dalam kerangka hukum dan cita-citanya menyatakan:

> *"…the laudable one of keeping morality free from the taint of self-interest, from the lure of reward and the fear of punishment more the reduction of morality to a mere means instead of an end in itself, from the mercenary motive of living of the moral life only if it pays off in some other good than the moral good"* (1972: 128).

Tentu saja tidak setiap kewajiban mengandung unsur-unsur hukum. Banyak terkait pula dengan etika, moral, dan nilai-nilai filsafat lainnya. Namun, yang relatif pasti, dalam setiap ketentuan hukum mengandung unsur dan isi kewajiban dan beban. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan hukum tanpa diikuti kewajiban bukan dalam arti ketentuan hukum, sebagaimana dikenal selama ini, dapat masuk dalam kelompok etika. Diakui kewajiban dalam arti umum sebagai *"moral necessity,"* ia baru menjadi kewajiban hukum terkait dengan adanya sanksi.

> *"Sanction means the promise of reward for keeping the laws or the threat of punishment for breaking the law, or both, it also means the reward or punishments themselves"* (1972: 136).

Begitu eratnya antara hukum dengan kewajiban, sehingga nilai ketaatan seseorang dengan ketentuan hukum, dilihat dari aspek kewajiban, merupakan satu tindakan yang penuh disadari dengan sungguh-sungguh, termasuk pula akibatnya.

C. Hak

Hak (*rights*) merupakan satu aspek dan satu kesatuan, malah bagian integral dari hukum. Hukum tanpa adanya hak (wewenang) bukan lagi merupakan hukum, mungkin sekadar kebiasaan sehari-hari yang tidak mempunyai "ikatan."

Hak dalam arti *rights* dalam bahasa Inggris mempunyai kaitan dengan:

a. *rights as opposed to wrong*,
b. *rights as correlative to duty*.

Di sini tampak bahwa hak/wewenang/*claim* selalu diartikan dengan perbuatan/tingkah laku yang benar dan bukan sebaliknya, demikian juga hubungan antara hak dan kewajiban sangat erat. Dalam kaitannya dengan hukum, maka hak yang dimiliki/diberikan oleh hukum adalah hak untuk melaksanakan

ketentuan-ketentuan yang ada yang diberikan kepadanya, bukan hak untuk menyeleweng dan menyalahgunakan *"privillages"* yang ada.

> *"Rights is something which squares with the rule or norm, as a right line or a right angle"* (1972: 196).

Dalam istilah hukum (law) sering juga disebut *rights,* antara kedua istilah tersebut saling melengkapi:

> *"This is why itself is something called right, a usage common in other languages but infrequent in English. Since all rights come from law, rights are called natural or positive, devine or human, eclesiastical or civil, according to the kind of law that confers the rights"* (1972: 197).

Manusia, pada hakikatnya tidak mungkin lepas dari sistem hukum yang berlaku pada waktu tertentu. Kalau demikian halnya, berarti manusia, harus selalu diingatkan akan hakikat bernegara, bermasyarakat sebagai layaknya seorang subjek hukum yang dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku. Karena itu, pelaksanaan hak asasi[3] tidak pernah absolut. Ia terikat aturan-aturan formal, aturan yang menghormati keberadaan hak asasi itu sendiri.

Adalah benar, kata Thomas Jefferson, untuk merumuskan batas bagi hak adalah usaha yang penuh resiko. Ada bahaya, bahwa sesuatu yang sangat hakiki akan terlupakan; hal-hal yang betapa pun diinginkan, namun sesekali bukanlah hak akan tercakup di dalamnya (Titian nomor 27).

Menghormati HAM bukan berarti memberi keistimewaan dan memanjakan manusia, justru untuk memanusiakan manusia, sebab tanpa pengakuan HAM, nilai/martabat kemanusiaannya menjadi tidak ada. Untuk itulah manusia menjadi subjek hukum, satu posisi yang menempatkan manusia sebagai pemilik/pemegang hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum, karenanya manusia dilindungi hukum.

Universal Declaration of Human Rights 1948 sering disebut *"the first generation"* dari hak asasi manusia, sedang hak-hak sosial, ekonomi, dan kultural disebut *"the second generation"*. Dalam proses lebih lanjut *"…the rights of all people to equality without domination of people by another"*. Hak ini disebut *the third generation* (Burn H. Weston et.al., 1989: 2150 di dalamnya termasuk *the rights to develop* (hak untuk membangun). Hak-hak dasar tersebut digulirkan terus sampai nantinya dikenal generasi-generasi selanjutnya. Membangun berarti "mengubah" alam untuk menjadi lebih bermanfaat bagi kita.

Dengan demikian, kita tidak saja minta "bantuan" alam untuk hidup, tetapi seyogianya "mensejajarkan" antara manusia dengan alam. Secara analogi, terbukti ada hubungan timbal balik antara manusia dan alam, yang sering kita lihat lingkungan banyak "dirusak" oleh manusia sendiri.

---

[3]DINAMIKA HAM. 01, Mei-Oktober 1997.

Karena itu, semenjak ditandatanganinya Deklarasi PBB tentang Lingkungan Hidup pada Konferensi Strockholm 1972, masyarakat internasional semakin menyadari bahwa lingkungan hidup merupakan bagian integral dari hidup manusia itu sendiri, baik sekarang (kekinian) maupun terlebih masa depan.

Hal ini ditekankan dalam Pasal 1 Deklarasi Lingkungan Hidup 1972 tersebut:

> *"…man has fundamental rights to freedom equality condition of life,…and bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generation…".*

Lingkungan berisi tidak saja semua benda, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi lingkungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, lingkungan dan isinya "manunggal". Hal ini berarti semua "anggota" lingkungan, baik yang hidup maupun yang "mati", yang keberadaannya karena kehendak Tuhan akan saling mengisi dan membutuhkan. Karena itu, benda-benada tersebut "hidup" dan selalu dalam posisi saling bergantung.

Dengan demikian, manusia sebagai subjek hukum berarti pemilik hak. kewajiban, dan tanggung jawab hukum dari suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan. Kalau dibuat rumus menjadi: SH = H + K + TJ. SH *(Subjek Hukum) = H (Hak) + K (Kewajiban) + TJ (Tanggung Jawab)*. Bertemunya tiga elemen tersebut pada seseorang, menunjukkan kesadaran hukum seseorang cukup tinggi, sebaliknya kalau "hanya" dua elemen saja pada diri seseorang misalnya, menunjukkan kesadaran hukum yang bersangkutan masih "rendah".

Manusia sebagai subjek hukum, sering melakukan banyak perbuatan hukum. Perbuatan hukum sempurna (PHS) mengandung tiga tahap kesadaran manusia utama, yaitu ada *niat (N)*; ada *perbuatan (P)*; dan *akibat (A)*. Ketidak-lengkapan "kesadaran" terbuat, perbuatan hukum seseorang tidak kurang lengkap, kalau dicoba dirumuskan menjadi: PH = N + P + A.

Lewat analogi, Deklarasi Lingkungan Hidup 1972, selain merupakan keharusan/tuntutan zaman, sekaligus "mengimbangi" tidak saja hak asasi manusia, tetapi juga mengantisipasi lompatan-lompatan teknologi yang sulit dibayangkan. Deklarasi Lingkungan Hidup 1972 tersebut merupakan "Deklarasi Hak-hak Asasi Lingkungan". Hal ini perlu diangkat dan direnungkan, demi hidup dan kehidupan manusia sekarang dan masa depan. Kalau manusia, sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan subjek hukum sempurna, maka lingkungan hidup merupakan subjek "hukum semu" (kuasai subjek hukum). Karena lingkungan "hanya" mempunyai hak (wewenang) hidup, demi dan untuk manusia itu sendiri. Lingkungan[4] tidak mempunyai beban/tugas/kewajiban

[4]DINAMIKA HAM. Volume 01, Mei-Oktober 1997.

hukum apalagi tanggung jawab/kesadaran hukum. Lingkungan hidup sebagai subjek hukum semu dapat dirumuskan: LH = SHS = H-K-TJ. *LH (Lingkungan Hidup); SHS (Subjek Hukum Semu); H(Hak); K (Kewajiban); TJ (Tanggung Jawab)*

Pengangkatan lingkungan hidup dalam posisi sentral/penting selain bermaksud mengingatkan kita bersama bahwa lingkungan mempunyai hak hidup yang harus "dihormati" bersama, juga diharapkan semakin berkurang pelanggaran/perusakan atas lingkungan diharapkan karena kesadaran hukum manusia semakin tinggi dan sadar pula bahwa lingkungan adalah "sahabat" manusia, yang mempunyai hak hidup seperti kita dan untuk kita.

Selain itu, dalam praktik diharapkan dapat membantu para pemegang otorita untuk lebih menjaga lingkungan hidup dan memperbaikinya, sehingga lingkungan hidup dapat diwariskan kepada anak cucu dalam keadaan baik. "Pengangkatan" menjadi kuasi subjek hukum (subjek hukum semu), diilhami dengan diterimanya deklarasi tersebut, berarti adanya pengakuan atas hak-hak lingkungan hidup.

Dengan demikian, Deklarasi Stockholm 1972 merupakan "pelengkap" Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia 1948. Konferensi tersebut dianggap sebagai:

> *"a new libratic movement to free man the threat of their freedom to environment perils of their own making."* (St. Munadjat Danoeputro, 1978:70)

Kalau kita sepakat mengangkat "derajat" lingkungan hidup, sebagaimana disebut di atas, maka perhatian kepada lingkungan bukan dalam arti "kasihan" kepada lingkungan, tetapi karena kesadaran. Sadar bahwa lingkungan juga mempunyai hak. Karena itu, pikiran/tindakan menggunakan alam sekitar/ lingkungan hidup dipakai semuanya oleh manusia tidak dapat dibenarkan/ diterus-teruskan (A. Masyhur Effendi, 1986:35).

Kesadaran hukum dalam bermasyarakat dengan memerhatikan aspek hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta menempatkan lingkungan hidup, merupakan "generasi IV" (*the fourth generation*) dari proses "perjalanan" ide HAM. Dengan demikian, semakin kuatnya posisi HAM (secara teoretik), posisi HAM diharapkan semakin kuat dan kesadaran HAM anggota masyarakat termasuk pejabat/aparat semakin tinggi pula.

Daftar Referensi

Masyhur Effendi. *Tempat Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional."* Bandung: Penerbit Alumni, 1980.

————————. "Prinsip-prinsip Dasar Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup". FH Unibraw, 1986.

————————. *Pengenalan Hukum Humaniter Internasional*. Unair Press, 1986.

————————. "Hukum Diplomatik Internasional (Hubungan Politik Bebas Aktif, Asas Hukum Diplomatik dalam Era Ketergantungan Anatarbangsa)." Usaha Nasional Press Surabaya, 1993.

————————. Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional (Rintisan Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia/ *Human Rights Law)* di Indonesia". FH Unibraw, 1993.

Austin Fagithey. "Rights and Reason, Ethies in Theory and Practice", The CV Mosby Company, St. Louise, 1972. Baut S. Paul & Beny Harman K, "Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia". Yayasan LBHI, 1988.

Black's, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Miami: West Publishing Co., ST. Paul, 1968.

d'Enreves, A.P (diterjemahkan Hasan Wira Sutisna). "Hukum Alam," *Pengantar Filsafat Hukum*. Bharata, 1963.

Farrer J. Tom. *Human Rights and Human Welfare in Latin America*. USA: Dialus, Richmond, Virginia, 1983.

Hardjon, M. Philipus. "Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia", Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Unair Surabaya, 1985.

Kuntjoro Purbopranoto. *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Lung-Che Chen. *An Introduction to Contemporary International Law*. Yale University Press, 1989.

Maurice Cranston. *Are There any Human Rights*. USA: Deadlus, Richmond, Virginia, 1983.

Miriam Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 1987.

Mochtar Kusumaatmaja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta, 1976.

Mulyana W. Kusumah/Fauzi Abdullah. *Hak Asasi Manusia dan Struktur dalam Masyarakat Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.

Munadjat Danoeputro. *Hukum Lingkungan Global*. Bandung: Bina Cipta, 1982.

Paton, G.W. *A Text Book of Jurisprudance,* Oxford, 1969. Pictet, Jean, International Human Rights", I.C.R.C. Geneva, Swiss, (tanpa tahun).

Pictet Jean. *The Principles of International Humanitarian Law*. Genewa: I.C.C.R, 1966.

Robertson, A.H. *The European Count of Human Rights*. The American Journal of Comperative Law, Vol.9., Winter, 1959.

Romila Thaper. *The Problem of Human Rights in The Hindu and Buddhist Traditions"*. Human Rights Teaching, UNESCO, Vol.IV/1985.

Ronny Hanitijo Sumitro. *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1973.

Sunarjati Hartono. *Apakah The Rule of Law itu?* Bandung: 1969.

Vasak, Karel. *Diagram Showing the Implementation of The Machinery of the Conversation*. Internal Institute of Human Rights, 6, Place de Bordeaux 6700, Strasbourg France, 1977.

RAJAWALI PERS

10

PENERAPAN OTONOMI KEILMUAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

Oleh:
*Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**

Pendahuluan

DISKUSI TENTANG apa dan bagaimana pembangunan *Hukum Ekonomi Nasional Indonesia* hingga saat ini terus berlangsung bahkan menjadi perdebatan yang tidak habis-habis atau kata ektremnya suatu wacana yang tidak pernah habis. Berbagai kajian, penelitian, seminar, dan lokakarya telah dilakukan, baik regional dan nasional. Tumbuh dan berkembangnya diskusi tersebut juga disebabkan adanya aneka ragam penafsiran terhadap Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan yuridis sistem perekonomian nasional, faktor tidak jelasnya penjelasan UUD 1945, perbedaan kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu, kriteria atas produk atau barang dimaksud dalam pasal tersebut bersifat dinamis dan selalu berubah tergantung dimensi ruang dan waktu, dan faktor sosial politik lainnya.[1] Bahkan perdebatan makin ramai sejak akan berlaku dan pemberlakuan globalisasi ekonomi oleh negara-negara di dunia.[2]

Sadar atau tidak, Era Globalisasi Ekonomi telah dimulai,[3] berbagai perjanjian multilateral disepakati serta pembentukan berbagai lembaga internasio-

---

*Guru Besar Hukum Ekonomi, FH Universitas Sriwijaya.

[1]Marwah M. Diah, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau Korporatisasi,* (Jakarta: Literata Jendela Dunia Ilmu, hlm. 262).

[2]Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang meratifikasi dan menandatangani kesepakatan Putaran Uruguay 1994 dengan UU No. 14 Tahun 1994, sehingga konsekuensi hukumnya sistem hukum ekonomi negara Indonesia harus menyesuaikan dengan konvensi tersebut.

[3]Jika kita perhatikan proses memasuki globalisasi di Indonesia lebih banyak didorong oleh pemerintah bukan sektor bisnis swasta, pelaku bisnis swasta di negeri justru cenderung merasa tidak siap untuk memasuki era globalisasi. Ketidaksiapan para pelaku ekonomi Indonesia dalam memasuki pasar bebas, membuat posisi Indonesia menjadi ragu apakah kita siap memasuki AFTA apalagi APEC yang penuh tantangan dan persaingan itu. Suhanadji-Waspodo TS, *Modernisasi dan Globalisasi Studi Pembangunan dalam Perspektif Global,* (Malang: Insan Cendekia, 2004), hlm. 141-142.

nal dalam kerangka kerja sama ekonomi di berbagai wilayah, seperti NAFTA, APEC, AFTA, Uni Eropa, dan WTO. Terbentuknya tatanan ekonomi global merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia termasuk Indonesia,[4] baik yang merasa siap maupun tidak. Salah satu permasalahan penting khususnya bagi negara Indonesia di era globalisasi ekonomi adalah pembangunan hukum ekonomi nasional, yang hingga saat ini dianggap belum dapat mengakomodasi semua perkembangan aktivitas bisnis nasional maupun internasional.[5]

Lima belas tahun yang lalu Menteri Kehakiman dalam Seminar Akbar 50 Tahun Hukum sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional dalam PJP II bulan Juli 1995 telah melontarkan berbagai hal penting yang perlu diperhitungkan dalam pembangunan Hukum Nasional, yang pokok-pokoknya antara lain:[6]

1. *Globalisasi* pada hampir semua aspek ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), ekonomi, berkembangnya pluralisme dan meningkatnya tuntutan pengembangan demokrasi dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia, serta runtuhnya Marxisme Leninisme di sebagian dunia yang menggoda orang untuk berpeluk pada individualisme, liberal dan kapitalisme sebagai paham alternatif yang diunggulkan.
2. *Keikutsertaan* kita dalam kesepakatan-kesepakatan dalam GATT, GATS, TRIPs, WTO, APEC dan sebagainya merupakan perkembangan dalam kehidupan ekonomi akan berpengaruh pula pada pembangunan kehidupan hukum.
3. Di bidang hukum misalnya *kemajuan teknologi dan ekonomi* meningkatkan kecanggihan mutu serta pengorganisasian bentuk hubungan, bentuk tindak perdata, pidana maupun tata usaha negara, perkembangan dan penegakan hukum hak atas milik intelektual (*intellectual Property Rights*), pencegahan kejahatan kerah putih, percepatan pelayanan masyarakat, pendaftaran serta perubahan perusahaan dan penyusunan perjanjian dalam kehidupan ekonomi.
4. *Kemajemukan* dalam kehidupan masyarakat termasuk kemajemukan *hukum* makin memerlukan upaya keterpaduannya, apabila hendak menciptakan

---

[4]Dalam kenyataannya Negara Indonesia belum siap dihampir semua aspek untuk menghadapi era globalisasi ekonomi, hal ini terbukti pada saat krisis ekonomi melanda Negara Indonesia pada pertengahan 1997 hingga saat ini masih bergelut menghadapi krisis ekonomi, bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Korea Selatan.

[5]Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, sebagian peraturan perudang-undangan peninggalan Belanda tetap diberlakukan hingga saat ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sedang dirancang), dan lain-lain.

[6]Oetojo Oesman, *Kebijakan Pembangunan Hukum dalam PJP II*, Makalah, Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional dalam PJP II, Jakarta, Juli 1995, hlm. 111-112.

ketahanan terhadap tarikan kekuatan, dan paham-paham dunia yang makin pluralistik dan cenderung disosiatif, individualistik, dan materialistik.

5. *Perwujudan negara* hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menuntut adanya sistem hukum nasional selain menggantikan sistem hukum yang diwariskan zaman kolonial, juga dapat menjawab perkembangan dunia serta kemajuan bangsa.

Demikian juga Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H. telah mengingatkan kita tentang bagaimana pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bangsa dan Negara Indonesia dalam pembangunan Hukum Nasional, khususnya hukum ekonomi, di mana beliau menjelaskan bahwa:[7]

> *... Kita juga tidak perlu dan tidak boleh menutup diri terhadap modernisasi dan globalisasi itu, karena suka atau tidak suka akhir abad ke-20 ini di luar kehendak bangsa kita, memang sudah merupakan suatu realitas hidup yang tidak dapat dipungkiri. Karena itu, perlu kita siapkan diri untuk dapat menarik manfaat dari arus globalisasi itu dan di lain pihak dapat menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang dapat membawa bangsa kita dalam situasi yang hampir serupa dengan situasi yang dihadapi nenek moyang kita pada abad ke-17, di mana bangsa kita akan tertekan – bukan oleh bangsa atau negara lain, tetapi – oleh perusahaan-perusahaan transnasional... di sinilah diperlukan peraturan-peraturan Hukum Ekonomi Indonesia yang cukup jeli, untuk di satu pihak mengembangkan kerja sama internasional di bidang ekonomi, tetapi di lain pihak memasang rambu-rambu yang cukup ampuh untuk melindungi hajat hidup maupun kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia di dalam badai globalisasi itu. Di sini pula tampak betapa Hukum Nasional ikut menentukan ketahanan nasional.*

Bertitik tolak dari hal di atas, pada dasarnya ada dua hal pokok yang perlu dikaji dan menjadi pokok permasalahan berkaitan dengan ekonomi global, yaitu adanya nilai-nilai dasar Hukum Ekonomi Nasional dan Internasional. Kedua nilai-nilai dasar tersebut saling berbenturan dalam implimentasinya, misalnya di satu pihak pembangunan hukum ekonomi di Indonesia berdasarkan filsafat Pancasila yang berciri demokrasi dan keadilan sosial dan di pihak lain hukum ekonomi internasional lebih menekan nilai individual, neo-kapitalisme dan neo-liberalisme, materialistis yang dipelopori negara-negara maju (Negara G-7). Untuk menghindari benturan tersebut perlu dicarikan jalan keluar agar terwujud harmonisasi kedua nilai tersebut, sehingga jangan sampai negara Indonesia masuk dalam jebakan globalisasi.

Selama ini, pembahasan dan kajian tentang pembangunan hukum ekonomi lebih menonjolkan *pemikiran praktis ekonomi*, terutama di kalangan pemerintah, berupaya bagaimana perekonomian berkembang dengan menarik dan meningkatkan perkembangan investasi, pertumbuhan ekonomi tinggi, sehing-

[7]C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni 1991), hlm. 71.

ga kebijakan di bidang pengembangan ekonomi lebih berpihak pada investor tidak sebaliknya, sehingga timbul kepincangan-kepincangan dalam substansi regulasi di bidang ekonomi, terutama masa-masa memasuki era globalisasi, dan tanpa sadar sebagian besar aset bangsa telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing seperti perusahaan-perusahaan multinasional sebagaimana yang banyak diperkirakan oleh banyak kalangan yang anti globalisasi. Ini sebenarnya kesalahan manajemen hukum kita yang kurang melindungi sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga sumber daya alam terkuras habis sekaligus menciptakan ketergantungan dengan bangsa lain[8] bahkan menciptakan kemiskinan bukannya menciptakan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.[9] Pembuatan regulasi di bidang ekonomi selama ini sangat dipengaruhi faktor eksternal[10] dan kurang memerhatikan faktor-faktor internal,[11] sehingga regulasi sebagai piranti aktivitas perekonomian kurang memberikan perlindungan terhadap bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, makalah ini akan mencoba mengkaji bagaimana penerapan otonomi keilmuan dalam pembangunan hukum ekonomi di era globalisasi dalam perspektif bangsa Indonesia, hal demikian merupakan persoalan yang sangat serius, karena *pertama,* tidak terlampau banyak ahli hukum yang menaruh perhatian terhadap masalah hukum yang bersifat konseptual, *kedua,* di antara ahli-ahli hukum yang menaruh perhatian terhadap hal ini masih terdapat perbedaan pandangan tentang konsepsi dan ruang lingkup hukum sebagai suatu sistem, *ketiga,* kedua masalah yang mendahului didukung oleh berbagai masalah yang sangat berpengaruh terhadap gerak hukum dalam menyelenggarakan fungsinya, baik yang berasal dari faktor internal, maupun faktor eksternal.[12]

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas ada beberapa hal penting yang perlu dikaji secara mendalam tentang bagaimana penerapan otonomi keilmuan dalam pembentukan Hukum Ekonomi Nasional/Indonesia di era globalisasi? Dan Pendekatan apa yang dapat diterapkan dalam pembentukan Hukum

---

[8]Contoh konkret saat ini, ketergantungan negara Indonesia terhadap BBM dengan negara lain, mengakibatkan menjadi beban berat bagi perekonomian negara Indonesia, bahkan mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

[9]Prof. Dr. Sri Redjeki, S.H., mengungkapkan jika masalah investasi asing tidak diatur secara saksama dan konprehensif akan menimbulkan *dampak negatif* seperti: eksploitasi sumber daya secara besar dan melampaui batas kemampuan; Tidak/kurang memanfaatkan kekuatan lokal sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi; Penyelundupan hukum untuk berbagai kepentingan (Sri Redjeki, 2005: 8).

[10]Berbagai regulasi di bidang ekonomi diterbitkan atas desakan negara-negara maju yang mempunyai kepentingan ekonomi dengan negara Indonesia, misalnya Amerika Serikat, Jepang, dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan lain-lain.

[11]Faktor-faktor intern atau domesti adalah faktor yang tercantum dalam cita hukum Pancasila dan UUD 1945.

[12]Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*, dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 353.

Ekonomi Nasional di era globalisasi saat ini? Kedua pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang mendasar untuk menentukan arah pembangunan nasional, khususnya Hukum Ekonomi.



Globalisasi dan Nilai-nilai yang Berkembang

Globalisasi[13] sebagai sebuah determinasi sejarah yang tidak bisa dihindari bagi setiap bangsa atau negara, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, tampaknya kita harus mengikuti arusnya. Rosabeth Moss Kanter menggambarkan globalisasi sebagai dunia yang telah menjadi pusat perbelanjaan global, yang dalam gagasan dan produksinya tersedia di setiap tempat pada saat yang sama[14]. Emanuel Richter menyatakan bahwa globalisasi adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi dalam planet bumi ke dalam ketergantungan yang saling menguntungkan dan persatuan dunia.[15]

Terjadinya jaringan global sangat ditunjang oleh kemajuan teknologi dan komunikasi. Kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan aktivitas ekonomi tidak lagi terbatas oleh batas-batas negara. Fenomena-fenomena regionalisme yang terjadi di berbagai belahan dunia dewasa ini, seperti ASEAN atau Uni Eropa juga makin mengurangi batas-batas negara ini. Dengan kata lain batas-batas negara pada taraf tertentu menjadi relatif tidak terlalu signifikan. Alvin Toffler menskenariokan globalisasi sebagai gelombang ketiga dengan ditandai adanya kemajuan pesat di bidang transportasi, komunikasi, dan informatika modern.

Globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan sebagainya. Globalisasi yang ditandai dengan revolusi informasi menuntut nilai-nilai dan norma-norma baru dalam kehidupan skala nasional maupun internasional.[16] Proses globalisasi akan terus berlangsung,

---

[13]Globalisasi dan Pasar Bebas memang diimajinasikan sebagai upaya meningkatkan efisiensi ekonomi global. Saat ini imajinasi dan upaya itu ditumpukan kepada organisasi dunia WTO, pengganti GATT, yang mematok pakem-pakem ekonomi pasar bebas untuk mencapai efisiensi ekonomi global. Namun dari kenyataan empirik yang ada, membuat banyak di antara kita harus bersikap menolak dan reaksioner. Dalam praktik si lemah harus membiayai dunia demi kesejahteraan di Selatan membiayai efisiensi global demi keuntungan dan kemajuan di Utara. (Sri Edi Swasono, Ekspose ekonomi Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas, (Yogyakarta: Pusat Studi ekonomi Pancasila UGM, 2005), hlm.83.

[14]Rosabeth Moss Kanter, dalam Suhanadji & Waspodo TS, *Modernisasi dan Globalisasi Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*, (Malang: Insan Cendikia, 2004), hlm.93.

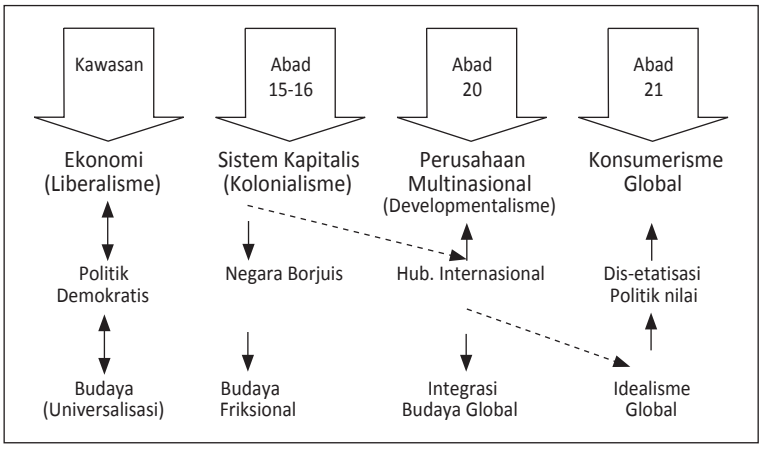
[15]*Ibid*.

[16]Muladi, *Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi*, Makalah, tt, hlm.4.

tanpa ada kendali dan siapa pun tidak ada yang mampu menghentikannya karena *globalisasi adalah sebuah ideologi yang tampaknya sudah disiapkan oleh negara-negara industri maju agar semua negara-negara di dunia terinkorporasi ke dalam masyarakat dunia yang tunggal*, masyarakat global dengan *kapitalisme dan liberalisme* sebagai panglimanya.

Jika ditelusuri sejarah terjadinya globalisasi terjadi dalam tiga fase perkembangan globalisasi yaitu:[17] *fase pertama,* dimulai sejak abad ke-15 yang ditandai dengan ekspansi bangsa-bangsa Eropa ke beberapa wilayah negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin serta pendudukan bangsa kulit putih atas tanah Amerika Utara dan Australia. Melalui fase kolonialisme, tahun 1860 dan 1870 perdagangan dunia mengalami booming, inilah masa keemasan perdagangan dunia, meskipun para penguasa Eropa sangat manis dalam menumpuk kebaikan hatinya dan kemakmuran mereka berasal dari negara-negara koloninya. *Fase kedua*, dikenal sebagai era pembangunan atau era developmentalisme. Pada fase ini ditandai dengan masa kemerdekaan negara-negara dunia ketiga secara fisik, tetapi dominasi negara-negara koloninya tetap dipertahankan melalui kontrol terhadap teori pembangunan dan perubahan sosial yang nota benenya adalah produk-produk negara kapitalis. Pada fase kedua ini terjadi penjajahan secara ideologi, konsep, dan ekonomi telah ditanamkan melalui teori-teori pembangunan, sehingga hampir semua negara-negara dunia ketiga melaksanakan pembangunan serta yang disarankan oleh Rostow, meskipun pada akhir fase pembangunan ini berakhir dengan krisis di sebagian besar negara-negara berkembang. *Fase ketiga,* yang terjadi menjelang abad ke-21 atau penghujung abab ke-20, ditandai liberalisasi di segala bidang yang dipaksakan melalui *structure adjustment* program oleh lembaga keuangan global dan disepakati oleh rezim GATT dan Perdagangan Bebas, suatu organisasi global yaitu WTO. Sejak saat itulah suatu era baru muncul menggantikan era sebelumnya, dengan begitu dunia memasuki apa yang dikenal dengan era globalisasi yaitu suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme. Mengenai hal ini Petras dan Veltmeyer secara tegas mengungkapkan bahwa globalisasi saat ini adalah *imperialisme baru* dalam bentuknya sebagai sistem baru "*global governance*" yang terstruktur dalam jaringan *new international capitalist class*. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan ragaan fase perkembangan globalisasi berikut ini.

[17]James Petras dalam Suhanadji & Waspodo TS, *Modernisasi dan Globalisasi Studi Pembangunan dalam Perspektif Global,* (Malang: Insan Cendekia, 2004), hlm. 88-89.



Sumber: HAR Tilar (1997) hal 16 dan Water's dalam Globalisasi

Gambar 10.1 Fase Perkembangan Globalisasi

Sebenarnya secara teoretis tidak ada perubahan ideologi dari ketiga fase tersebut, bahkan ada kecenderungan dari fase ke fase makin canggih baik dari pendekatannya maupun dari sistem yang: [18]

1. *secara ekonomis berwatak eksploitatif,*
2. *secara politik berwatak represif, dan*
3. *secara budaya berwatak hegemonik dan diskursif*.

Jika pada era kolonialisme (fase pertama), ilmu sosial melegitimasi kolonialisme dengan mengembangkan teori evolusi dan darwinisme sosial, tetapi pada era developmentalisme (fase kedua) teori-teori modernisasi dan pembangunan sangat dominan serta neo-liberalisme juga menjadi bagian penting pada penghujung fase kedua ini. Dalam fase ketiga, ada kecenderungan menyolok yang dapat membedakan antara fase kedua dengan fase ketiga, yaitu jika fase pembangunan lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi nasional dan mereka lebih melihat ke dalam negeri sendiri. Dalam fase ketiga (era globalisasi) mereka mendorong menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi global, yang aktornya bukan negara yang menonjol, tetapi perusahaan transnasional (TNCs) dan bentuk-bentuk transnasional (TNBs) serta lembaga-lembaga keuangan multinasional, seperti Bank Dunia, *International Monetary Fund* (IMF) serta birokrasi perdagangan regional dan global seperti *World Trade Organization* (WTO), NAFTA, APEC, dan lain-lain. Jika kita cermati secara teoretis antara kolonialisme dan globalisasi adalah suatu rangkaian yang tidak

[18]Suhanadji & Waspodo TS, *log.cit*, 2004, hlm. 90.

terputus dan merupakan satu ideologi yang berasal dari ibu kandung yang sama yaitu *kapitalisme*.

Kapitalisme adalah sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan-perusahaan swasta dengan ciri persaingan di pasar bebas.[19] Pada sistem kapitalisme nilai-nilai yang dianut adalah nilai *individual, liberal, materialis*, nilai-nilai ini tertanam sepanjang perkembangan globalisasi mulai fase satu hingga fase ketiga. Tidak semua negara di dunia yang menganut paham ini, sehingga terbentuknya tatanan ekonomi global sebagaimana dijelaskan di atas disambut *pro* dan *kontra* oleh berbagai pihak. Pihak yang pro dengan globalisasi ekonomi mengutarakan Teori Interpendensi bahwa dalam dunia nyata tidak ada negara yang benar-benar otonom dan sepenuhnya mandiri, dan tidak ada negara yang pembangunannya dapat dipahami semata-mata sebagai refleksi dari apa yang terjadi di luar batas-batas nasional mereka. *Semua negara saling tergantung satu sama lain, dan bergantung pada sistem yang di dalamnya mereka ambil bagian, ...*[20] Sedangkan pihak penentang terdiri dari dua kubu, yaitu *Kubu Nasionalistik Partikular* menganggap globalisasi adalah akar dari semua kerusakan mulai dari ekonomi, politik, sosial, hukum, kultural sampai terorisme yang dialami warga dunia, tidak ada sama sekali nilai positif yang dihasilkan dari globalisasi. Mereka menolak dengan tegas semua hal yang berkaitan dengan *globalisasi, perdagangan bebas, neo-kapitalisme dan neo-liberalisme, PMA oleh Transnational Corporations (TNCs)*, Sedangkan *Kubu Humanistik Universal* berpendapat *globalisasi penyebab terbesar kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi, kerusakan lingkungan dan kultural, pelanggaran HAM*, sehingga globalisasi harus ditolak atau minimal dihentikan.[21] Bahkan Paul Hirst dan Grahame Thompson dalam bukunya yang berjudul "*Globalisasi adalah Mitos*" berpendapat bahwa konsep globalisasi seperti yang dikemukakan oleh para penganut ektrem teori globalisasi tidak lain dan tidak bukan adalah *Mitos Belaka*.[22]

Di lain pihak, para pengamat yang kritis cenderung bersikap pesimis, globalisasi yang intinya perdagangan bebas menurut mereka akan lebih banyak menguntungkan negara-negara maju, yang ibaratnya sebagai sebuah pertandingan yang tidak seimbang. Data Bank Dunia sendiri memperkirakan bahwa di tahun 2002-2003, seluruh negara maju akan mengeruk keuntungan yang sangat besar, sementara negara Afrika dan sebagian negara-negara Asia

---

[19]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 444.

[20]Bjorn Hattne, *Development Theory and The Three World*, terj. Teori Pembangunan dan Tiga Dunia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 202.

[21]Ida Susanti & Bayu Seto, Edt., *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 42-43.

[22]Paul Hirst dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos*, terj. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 3.

justru mengalami defisit, oleh karena itu dalam pertandingan pasar bebas akan melahirkan pihak *losser* dan *winner*. Hal ini akan terjadi, karena kemampuan negara-negara yang bersaing dalam pasar bebas tidak sama, yaitu negara maju, negara berkembang dan negara terkebelakang.

Sesungguhnya, penerapan ekonomi global ini ada unsur paksaan terhadap negara-negara di dunia terutama negara-negara sedang berkembang, yang sebenarnya mereka tidak siap dan tidak memiliki kemampuan bersaing yang selama ini memang sudah diciptakan oleh negara-negara maju pelopor terbentuknya ekonomi global, yaitu adanya ketergantungan di bidang ekonomi. Untuk itu teori-teori globalisasi menunjukkan bahwa globalisasi sesungguhnya mengandung fenomena sebagai berikut:[23]

(1) *Homogenisasi*

Fenomena globalisasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi baik yang bersifat satu arah dan massal (tv, radio, film dan sebagainya) maupun yang dua arah (telepon, internet), yang paling mengkhawatirkan adalah berlanjutnya proses homogenisasi masyarakat global itu sendiri. Nilai-nilai budaya, vitalias, dan potensi yang asli ditinggalkan dan nilai-nilai yang telah dipaket dan diproduksi secara massal, diiklankan dan dijual ke pasar massal lalu diadopsi beramai-ramai. Oleh karena itu, dengan era pasar bebas akan membuat kehilangan keunikan-keunikan kultural kita masing-masing.

(2) *Ketergantungan*

Negara-negara maju sebagai pelopor globalisasi menciptakan ketergantungan negara-negara di dunia, kebanyakan negara-negara berkembang yang membuat peralatan-peralatan teknologi maju, alih teknologi tidak akan pernah terjadi secara suka rela, karena negara-negara maju amat menyadari betapa pentingnya mempertahankan keunggulan mereka dalam bidang teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi, demikian juga negara-negara maju menciptakan ketergantungan keungan *(financial)* dalam melaksanakan pembangunan negara-negara berkembang berupa pinjam uang dan investasi, sehingga negara-negara yang terjerat dengan utang tidak dapat berbuat banyak.

(3) *Keterbukaan dan Integrasi*

Kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi menjadi dunia semakin terbuka dan terintegrasi. Batas-batas wilayah geografi suatu negara

[23]Hal ini sama dengan kaidah dasar dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Internasional, yaitu mengacu pada dua prinsip kebebasan utama, yaitu kebebasan berkomunikasi dan kebebasan berdagang. Kedua prinsip kebebasan ini merupakan hasil dari perkembangan yang telah berlangsung sejak berabad-abad lamanya (Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.16, namun prinsip ini masih tetap diadopsi dalam kegiatan globalisasi ekonomi.

tidak begitu penting lagi bagi banyak orang yang terbiasa menggunakan jasa komunikasi dan transformasi. Kuatnya arus informasi yang hampir setiap hari membanjiri dunia makin sulit untuk dikontrol oleh kekuatan negara sehingga menjadi arus globalisasi ini terus menggelinding tanpa ada yang mampu menolaknya.

Jika kita amati fenomena globalisasi di atas sangat menakutkan bagi suatu bangsa, betapa kuatnya arus globalisasi menerobos dan membunuh nilai-nilai budaya, sosial dan hukum suatu negara, dengan menancapkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh negara-negara maju yang kapitalis tersebut. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung negara-negara maju memaksakan agar negara-negara di dunia sama menyepakati terbentuknya globalisasi ekonomi dengan menandatangani berbagai konvensi internasional tentang perdagangan bebas. Oleh karena itu, negara-negara berkembang, khususnya negara Indonesia haruslah mampu membendung semua serangan-serangan kaum kapitalis yang berkedok kejujuran globalisasi dengan memperbaiki semua aspek kehidupan terutama aspek hukum ekonomi yang paling depan akan dilumpuhkan oleh globalisme ekonomi.



Nilai-nilai Dasar dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia

Sentral kegiatan globalisasi adalah sektor ekonomi, oleh karena itu sektor ini haruslah diatur secara saksama, jangan sampai terjebak dalam arus globalisasi seperti yang diungkapkan Hans Peter Martin dan Harald Schumann, dalam bukunya yang berjudul "*Die Globalisierungsfalle* atau Jebakan Globalisasi, serangan terhadap Demokrasi dan Kesejahteraan". Habermas dalam bukunya yang berjudul *"Legitimations probleme im spatkapitalisme"*, ia menjelaskan bahwa krisis yang terjadi dalam ranah ekonomi akan beralih melalui tindakan (kebijakan) negara, ke ranah budaya dan pada gilirannya krisis ini akan mengancam integrasi sosial, merusak berbagai resource yang dibutuhkan negara demi berlanjutnya pengelolaan sektor ekonomi yang sedang berjalan, lebih lanjut lagi, krisis ini kemungkinan besar akan mengakibatkan hilangnya legitimasi terha-dap lembaga pemerintah.[24] Dalam kondisi terpuruk tersebut negara-negara yang berselogan membantu yang akhirnya menjerat dan membelenggu ke dalam keterpurukan ekonomi.

Secara gamblang Hukum Ekonomi dapat diartikan sebagai kumpulan norma yang mengatur semua aktivitas atau kegiatan ekonomi dalam kehidupan bernegara. Boleh dikatakan hukum ekonomi sangat dominan dalam mengatur

[24]Jurgen Habermas, *Krisis Legitimasi*, terj, (Yogyakarta: CV Qalam, 2005).

hidup bermasyarakat, karena aktivitas ekonomi akan terus terjadi dan berlangsung sepanjang manusia masih hidup, oleh sebab itu pembangunan ekonomi tidak terputus-putus sepanjang negara tersebut masih tetap eksis.

Pembangunan hukum ekonomi tidak terlepas dari kerangka pembangunan hukum nasional. Nilai dasar pembangunan hukum nasional secara jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Di dalam Pembukaan tersebut terdapat pendirian asasi yang secara singkat berhubungan dengan soal-soal kemerdekaan bangsa, penjajahan, ke-Tuhanan, kebebasan, dan pemerintahan. Pendirian asasi tersebut di dalam Penjelasan UUD 1945 diberikan uraian ringkas dengan sebutan Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan. Pokok-pokok pikiran ini merupakan nilai dasar pembentukan hukum nasional, yaitu yang berisi sebagai berikut.[25]

1. *"Negara"' begitu bunyinya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam "pembukaan" itu diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.*
2. *Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.*
3. *Pokok yang ketiga terkandung dalam "pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.*
4. *Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam 'pembukaan' ialah negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur."*

Istilah pokok-pokok pikiran yang dipergunakan dalam Penjelasan UUD 1945 menunjukkan kepada jiwa yang mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) kita. Cita hukum adalah pengertian atau konsep hukum menurut kita. Cita-cita hukum atau pengertian hukum kita kalau diikuti dengan saksama, bunyi penjelasan dari UUD kita sudah ditentukan oleh filsafat hukum kita yang dasarnya adalah Pancasila. Dengan begitu, apa yang disebut menurut hukum di Indonesia tidak dapat sama dengan pengertian hukum dari tata hukum lain. Di

[25]Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

dalam menghadapi persoalan pengertian hukum *rechtsidee* kita, artinya menurut UUD 1945, maka lima butir ide yang harus selalu mendapat perhatian yaitu:[26]

1. bahwa di dalam memahami hukum, perlu diperhatikan fungsi hukum, filsafat kita (pokok pikiran 1);
2. bahwa di dalam memahami hukum, perlu diperhatikan tujuan hukum menurut filsafat (pokok pikiran 2);
3. bahwa di dalam memahami hukum perlu diperhatikan sumber kemauan yang dinyatakan di dalam hukum, filsafat kita (pokok pikiran 3);
4. bahwa di dalam memahami hukum perlu diperhatikan sifat isi ketentuan hukum itu, dilihat dari segi moral dan susila bangsa (pokok pikiran 4);
5. bahwa di dalam memahami hukum perlu diperhatikan pelaksanaan hukum dilihat dari segi susila dan moral rakyat yang luhur. Ringkasnya, kualitas susila dan moral dari pelaksanaan hukum yang memutus atau menjalankan hukum (pokok pikiran 4).

Kelima butir di atas adalah butir-butir ide yang menjadi acuan di dalam menentukan pengertian hukum di dalam negara sebagaimana ditentukan oleh Pembukaan UUD. Kelima butir tersebut merupakan bahan-bahan idealita dari hukum yang harus tertuang dalam pengertian hukum nasional untuk selanjutnya dituankan ke dalam hukum positif. Dengan demikian, ada empat nilai dasar yang merupakan nilai-nilai dasar bagi hukum nasional yang bersumber dari Pembukaan UUD 1945, yaitu:[27]

1. *Nilai dasar pertama*, yaitu hukum itu berwatak mengayomi/melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, berdasarkan persatuan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut pokok pikiran di dalam penjelasan UUD, di dalam sifat itu terkandung di dalamnya dua ide yang menjadi acuan dasarnya, yaitu bahwa perlindungan itu mendasarkan diri pada ide persatuan; dan di dalam merealisasi persatuan tersebut terkandung suatu ide yang menjadi acuan persatuan itu ialah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial sebagaimana dinyatakan di dalam butir pertama pokok pikiran itu dan juga di dalam alinea terakhir dari kalimat Pembukaan UUD 1945, dasar pandangan yang dianut ialah dasar pandang kita, yaitu filsafat pancasila.[28]
2. *Nilai dasar kedua*, hukum harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial di sini bukanlah semata-mata tujuan, tetapi juga merupakan pegangan konkret dalam membuat peraturan hukum. Nilai dasar kedua ini menunjukkan bahwa nilai dasar ini

[26]Moch. Koesnoe dalam Artidjo Alkostar, edt. *log.cit*, 1997, hlm. 33-34.
[27]Artidjo Alkostar, edt. *Identitas Hukum Nasional*, (Yogyakarta: FH UII, 1997), hlm. 287.
[28]*Ibid*.

oleh ide hukum kita, ditempatkan secara fundamental dan diwajibkan meliputi segala peraturan hukum kita, sedangkan mengenai bagaimana isinya nilai dasar ini tidak dibenarkan mengisinya berdasarkan paham dan pandangan luar. Di dalam Pembukaan UUD 1945, ditegaskan kekhususan tersebut dengan suatu kata, yaitu "suatu". Dengan adanya ketentuan ini, maka keadilan sosial yang kita laksanakan atau kita wujudkan itu merupakan suatu keadilan sosial yang merupakan pendekatan kepada apa yang di dalam filsafat hukum dinamakan "sosial ideal" kita, yang di dalam bahasa kita juga diperinci dengan kata-kata "suatu masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Swt. Dalam Batang Tubuh UUD 1945 terdapat beberapa pasal yang merupakan termasuk paham keadilan sosial, seperti Bab X sampai dengan Bab XIV. Pasal-pasal tersebut merupakan bahan-bahan pokok dan urgen yang harus diwujudkan mengenai nilai dasar yang kedua ini.[29]

3. *Nilai dasar ketiga*, hukum berasal dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan atau dengan kata lain adanya prinsip kedaulatan rakyat. Istilah kerakyatan adalah istilah yang menunjuk kepada rakyat. Dalam prinsip ini tidak menerima paham eliterisme, yaitu suatu paham yang tidak mau mengakui adanya dominasi suatu kalangan yang dinamakan kalangan terpilih karena keistimewaan dalam suatu hal, kalangan elite. Dari sifat ini, maka hukum Indonesia tidak dapat diterima, kalau itu merupakan hukum kalangan elite saja. Hukum dalam paham kerakyatan ini menurut sifatnya hanya dapat diterima, kalau itu sesuai dengan kemauan semuanya, artinya sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh semua warga. Ini berarti bahwa hukum kita dituntut untuk dibentuk berdasarkan kepada apa yang dewasa ini dinamakan sebagai kepribadian nasional kita, dan bukan berdasarkan kepada nilai-nilai hukum dari luar budaya kita. Dalam persoalan kerakyatan ini ada pandangan teoritikus Jerman, bernama Von Savigny, yang berpandangan bahwa adanya suatu "*Volksgeist*" atau "Jiwa Rakyat", baginya jiwa rakyat ini adalah nyata, dan menjadi sumber dari segala hukum dari masyarakat yang bersangkutan.
4. *Nilai dasar keempat*, hukum berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan dasar pengaturan terhadap adanya hukum-hukum Tuhan, di samping memerhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur.

Empat butir tentang apa cita-cita, atau *rechtsidee* hukum menurut ajaran Pembukaan dan UUD 1945 tersebut merupakan *idealita* apa yang dinamakan hukum di negara kita, artinya, ukuran-ukuran yang dipakai untuk membuat aturan-aturan kehidupan masyarakat di dalam negara kita, agar aturan itu diakui sebagai aturan hukum atau tidaknya, bergantung kepada sesuai atau

[29] *Ibid*.

tidaknya aturan itu dengan nilai-nilai dasar dari idealita hukum tersebut. Apabila nilai-nilai tersebut tidak terpenuhi, maka aturan yang bersangkutan secara substansiil yuridis tidak dapat diterima sebagai hukum. Demikian halnya dengan pembangunan Hukum Ekonomi Nasional tidak terlepas dari keempat nilai-nilai dasar tersebut. Oleh karena itu, idealnya nilai-nilai dasar tersebut akan tercermin dalam setiap produk hukum ekonomi yang diterbitkan. Untuk mewujudkan hukum ekonomi Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai dasar tersebut masih tahap proses, karena tata hukum ekonomi Indonesia saat ini masih sisa dari masa sebelum perang atau kolonial Belanda. Dengan perumusan menurut UUD 1945, tata hukum ekonomi kita dewasa ini masih suatu tata hukum peralihan. Untuk itu mencari kerangka tata hukum ekonomi nasional kita dewasa sangat penting dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar pembangunan hukum nasional sebagaima yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945, dan bukan dicari kerangka tata hukum ekonomi yang asing. Kegiatan mencari dan meneliti kerangka tata hukum ekonomi yang kini ada tampaknya mengarah kepada sasaran yang kurang memadai perintah UUD 1945 dan cita hukum Pancasila, serta ditambah dengan berbagai tekanan dari berbagai negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional (yang juga dipelopori negara-negara maju).



Penerapan Otonomi Keilmuan dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan di atas ada empat nilai-nilai pembangunan hukum nasional yang sekaligus juga dasar pembentukan hukum ekonomi nasional yang dapat dikaji melalui penerapan otonomi keilmuan. Namun, Sebelum membahas pembentukan hukum ekonomi berdasarkan otonomi keilmuan, akan dibahas terlebih dahulu tentang makna otonomi keilmuan.

Makna esensi dari otonomi keilmuan di sini adalah bebas nilai atau bebas nilai dalam Ilmu Pengetahuan. Bebas nilai sesungguhnya adalah tuntutan yang ditujukan kepada ilmu pengetahuan agar ilmu pengetahuan dikembangkan tidak memerhatikan nilai-nilai di luar pengetahuan. Tuntutan dasarnya adalah agar ilmu pengetahuan dikembangkan hanya demi ilmu pengetahuan, dan karena itu ilmu pengetahuan tidak boleh dikembangkan dengan didasarkan pada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus dikembangkan hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan ilmiah murni. Maksud dasar dari tuntutan ini adalah agar ilmu pengetahuan tidak tunduk kepada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan sehingga malah mengalami distorsi.[30] Lalu timbul pertanyaan, apakah pengertian bebas nilai tersebut

[30]A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 149-150.

bersifat absolut atau tidak, apakah ilmu pengetahuan harus menjadi dirinya sendiri, harus otonom, harus tunduk kepada kaidah-kaidah ilmiah saja dan tidak boleh tunduk kepada otoritas dan nilai di luar pengetahuan. Bagaimana jadinya kalau ilmu pengetahuan dikembangkan secara otonom sehingga akhirnya tidak memperdulikan berbagai nilai di luar ilmu pengetahuan dan akhirnya merugikan manusia, kalau begitu apa sesungguhnya tujuan dari ilmu pengetahuan itu?

Jika kita amati tujuan akhir ilmu pengetahuan adalah untuk mencari dan memberikan penjelasan tentang masalah dan fenomena dalam alam semesta ini, ilmu pengetahuan bertujuan memberikan pemahaman kepada manusia tentang berbagai masalah dan fenomena dalam hidup. Kemudian timbul pertanyaan "untuk apa penjelasan itu" yang diberikan ilmu pengetahuan tersebut? Mengenai hal ini ada dua kecenderungan dasar dalam melihat tujuan ilmu pengetahuan tersebut:[31]

a. *Kecenderungan puritan-elitis*, beranggapan bahwa tujuan akhir dari ilmu pengetahuan adalah demi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bertujuan mencari dan menemukan penjelasan, yaitu penjelasan benar tentang segala sesuatu, tetapi kebenaran ilmiah dari penjelasan hanya dipertahankan demi kebenaran murni begitu saja, dengan kata lain ilmu pengetahuan dikembangkan hanya demi ilmu pengetahuan. Bagi kelompok ini yang lebih penting adalah *teori-teori yang ditemukan tanpa mempersoalkan keterkaitannya dengan kegunaan praktisnya dalam kehidupan sehari-hari manusia dengan kata lain paham ini tidak mempersoalkan aplikasi bagi kehidupan konkret*. Paham ini berpendapat bahwa ilmu pengetahuan mempunyai otonomi mutlak, ilmu pengetahuan harus dikembangkan demi ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan tidak boleh kalah dan mengalah terhadap pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan, supaya ilmu pengetahuan itu bisa sampai pada kebenaran objektif. Ilmu pengetahuan harus dibebaskan dari tu-juan kemanusiaan, kebahagiaan dan keselamatan bagi manusia karena selama ilmu pengetahuan dikembangkan demi membantu manusia, demi memecahkan berbagai persoalan hidup, kebenaran bisa dikalahkan oleh pertimbangan lain tersebut. Contohnya, selama ilmu pengetahuan dikembangkan demi meningkatkan keuntungan dan kemakmuran bagi hidup manusia, kebenaran bisa dikorbankan demi keuntungan tersebut. Misalnya, kasus Busang beberapa tahun yang lalu memperlihatkan dengan jelas kesalahan ini. Demi meningkatkan nilai saham perusahaan Bre-X, perusahaan telah mengorbankan kebenaran ilmiah dengan melaporkan kebohongan bahwa mereka telah menemukan mas dalam penelitian yang mereka lakukan. Paham ini sama dengan ideal aritotelian, yaitu tujuan ilmu adalah untuk ilmu itu sendiri, untuk mengembangkan ilmu itu sendiri. Dalam hal ini seorang ilmuan akan berada di puncak menara gading keilmuan.

[31] *Ibid*.

b. *Kecenderungan pragmatis*, paham ini beranggapan bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan demi mencari dan memperoleh penjelasan tentang berbagai persoalan dalam alam semesta ini. Ilmu pengetahuan memang bertujuan untuk menemukan kebenaran, tetapi ilmu pengetahuan tidak sampai di situ saja, yang penting bahwa ilmu pengetahuan itu pada akhirnya berguna bagi kehidupan manusia, yaitu untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidup, jadi ilmu pengetahuan bukan dikembangkan demi ilmu pengetahuan semata, melainkan demi menjawab berbagai persoalan hidup manusia. *Bagi paham ini ilmu pengetahuan menjadi menarik justru karena ia berguna membantu manusia, tanpa itu ilmu pengetahuan tidak ada artinya*. Penjelasan dan kebenaran objektif ya, tetapi kebenaran dan penjelasan itu punya arti justru ia berguna bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, *ilmu pengetahuan tidak hanya " tahu bahwa, tahu akan, tahu mengapa, melainkan tahu bagaimana."* Juga yang disebut kebenaran ilmiah tidak hanya bersifat logisrasional dan empiris,[32] melainkan juga bersifat pragmatis,[33] yaitu kebenaran itu berguna menjawab berbagai persoalan hidup manusia. Paham ini sama dengan ideal Bacon bahwa tujuan ilmu adalah untuk kesejahteraan manusia. Menurut Bacon tujuan ilmu lebih bersifat terapan. Tujuan ilmu tidak sama dengan komersialisasi ilmu, melainkan bertujuan mulia demi kemaslahatan umat.

Prof. Dr. A.G.M. van Melsen, dalam bukunya berjudul *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita* menjelaskan bahwa kebebasan yang dituntut ilmu pengetahuan itu seharusnya bebas. Namun demikian, kebebasan yang dituntut ilmu pengetahuan sekali-kali tidak sama dengan ketidakterikatan mutlak.[34] Lebih lanjut van Melsen menjelaskan bahwa setiap ilmu pengetahuan berpangkal pada *praandaian-praandaian* yang tersimpul dalam metode ilmu pengetahuan sendiri, mengesampingkan praandaian-praandaian serupa itu sama saja dengan

[32]Menurut pandangan logis-rasional bahwa hanya dengan menggunakan prosedur tertentu dari akal saja bisa sampai pada pengetahuan yang sebenarnya, yaitu pengetahuan yang tidak mungkin salah. Menurut kaum rasionalis, sumber pengetahuan, bahkan sumber satu-satunya adalah akal budi manusia. Tokoh paham ini adalah Plato, Rene Descartes. Sedangkan para filsuf empirisis mengatakan bahwa sumber satu-satunya bagi pengetahuan manusia adalah pengalaman. Untuk bisa sampai pada pengetahuan yang benar adalah data dan fakta yang ditangkap oleh pancaindera atau dengan kata lain satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan pancaindera atau semua konsep dan ide yang kita anggap benar sesungguhnya bersumber dari pengalaman dengan objek yang tangkap melalui pancaindera. Tokoh paham ini adalah John Locke, David Hume.

[33]Teori pragmatis tentang kebenaran ini dikembangkan dan dianut oleh filsuf-filsuf pragmatis dari Amerika, seperti Charles S. Peirce dan William James, bagi kaum pragmatis kebenaran sama artinya dengan kegunaan, ide, konsep, pernyataan atau hotetis yang benar adalah ide yang berguna. Ide yang benar adalah ide yang paling mampu memungkinkan seseorang-berdasarkan ide-melakukan sesuatu paling berhasil dan tepat guna, dengan kata lain adalah kriteria untuk menentukan apakah suatu ide benar atau tidak.

[34]A.G.M. van Melsen, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, terj. K. Berten, (Jakarta: PT Gramedia, 1969), hlm. 88.

melumpuhkan setiap pendekatan metodis dan dengan demikian menghilangkan ciri khas segala ilmu pengetahuan. Ketika menyelidiki praandaian-praandaian ilmu pengetahuan dapat dibedakan dua macam prinsip ilmu pengetahuan, yaitu prinsip-prinsip *konstitutif* dan prinsip-prinsip yang menyangkut *isi* (*substansi*).[35] Prinsip-prinsip konstitutif sama dengan praandaian-praandaian, tetapi prinsip-prinsip yang menyangkut isi tidak merupakan praandaian-praandaian melainkan hasil ilmu pengetahuan. Kadang kala hasil-hasil ilmu pengetahuan itu dapat berfungsi sebagai perandaian, misalnya bila ilmu satu menggunakan hasil ilmu lain. Dengan demikian, sejauh berkenaan dengan aspek-aspek yang menyangkut isi ilmu pengetahuan menjadi prerogatif eksklusif untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang tidak benar, sedangkan aspek-aspek yang menyangkut prinsip-prinsip konstitutif yang menentukan metode suatu ilmu, tidak termasuk pengontrolan langsung ilmu itu sendiri. Salah satu alasan ialah tiadanya reflesivitas yang memungkinkan metode suatu ilmu untuk menyelediki metode itu sendiri, dengan kata lain *secara metode otonomi keilmuan bersifat kebebasan mutlak* (memiliki otonomi mutlak), sedangkan *secara isi atau substantif kebebasnya relatif*, karena dipengaruhi oleh manusia, waktu dan budaya. Oleh karena itu, dari aspek substantif ilmu pengetahuan kebebasan relatif dibatasi dengan aspek etika.

Dalam kaitannya dengan otonomi keilmuan tidak berarti bahwa penelitian ilmiah tidak perlu menghiraukan nilai-nilai luar ilmiah apapun, misalnya penelitian media tertentu boleh dilakukan, tidak semata-mata bergantung pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah saja, tetapi *perlu pertimbangan etis* yang melarang dilakukannya eksperimen-eksperimen terhadap manusia, betapapun banyaknya informasi ilmiah yang dapat diperoleh dengan eksperimen-eksperimen tersebut. Dan hal yang sama juga berlaku untuk ilmu pengetahuan yang lain seperti ekonomi dan hukum. Ilmu pengetahuan yang tidak pernah bebas nilai sebab ia sendiri mengejawantakan suatu nilai etis[36], bertambah relevansi etisnya karena semakin erat kaitannya dengan praktis, tetapi apa sebab perlunya bebas nilai ilmu pengetahuan begitu sering ditekankan? Lagi pula mengapa tekanan paling besar justru pada ilmu-ilmu manusia, yang karena objeknya manusia begitu jelas berorientasinya.

---

[35]*Ibid*.

[36]Nilai etis atau etika, menurut Berten ada tiga arti etika yang dapat dirumuskan yaitu: (K. Berten dalam Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.14).

1. Etika dipakai dalam arti *nillai-nilai dan norma-norma moral* yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut sebagai sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat, misalnya etika orang Jawa, Etika Jawa, Etika Agama Budha.
2. Etika dipakai dalam arti *kumpulan asas atau nilai moral* yang dimaksud di sini kode etik, misalnya Kode Etika Advokat Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia, dan lain-lain.
3. Etika dipakai dalam arti *ilmu tentang yang baik dan yang buruk*. Arti etika di sini sama dengan filsafat moral.

Praktik ilmu manusia seperti ekonomi, hukum tidak pernah akan bisa bebas nilai sama sekali, dalam arti tidak pernah boleh mengemukakan pertimbangan-pertimbangan *nilai etis yang mengevaluasi*, karena sebagai praktis ilmu manusia harus memberikan petunjuk, baik bagi kehidupan perorangan maupun bagi kehidupan masyarakat. Struktur-struktur sosial yang telah diwarisi dari masa lampau atau yang sedang berubah karena terpengaruh perkembangan teknologi, oleh ilmu manusia tidak pernah boleh diterima sebagai data-data begitu saja. Ia harus memandang struktur-struktur itu secara kritis dan itu mengikutsertakan suatu pertimbangan nilai tentang apa yang baik atau buruk. Dan bukan saja perlu ilmu manusia mengemukakan pertimbangan itu tapi pertimbangan tersebut harus memimpin praksis, sebab kesulitan khusus bagi ilmu-ilmu manusia adalah bahwa dalam praktik tidak dapat melakukan eksperimen-eksperimen secara netral. Dalam ilmu pengetahuan kemanusiaan ada tempat untuk eksperimen, tetapi sangat terbatas karena manusia-manusia tidak boleh diperlakukan sebagai instansi-instansi yang dapat ditukar terus menerus, dengan cara seperti ilmu alam dan teknologi mempelajari sifat-sifat besi dengan menyelidiki berbagai contoh besi. Untuk itu dalam ilmu-ilmu manusia boleh dan harus memanfaatkan sistem-sistem sosial yang berbeda-beda bagi analisa teoretis mereka.[37] Hal ini penting karena berhubungan langsung dengan manusia, waktu, dan budaya, yang semua itu berhubungan dengan nilai etika. Demikian juga dengan hukum ekonomi yang memadukan dua hal pokok, yaitu ekonomi dan hukum, dalam yang pembangunannya sangat erat dengan nilai etika.

Jika kita kaji secara mendalam hal-hal pokok tentang otonomi keilmuan, pada dasarnya secara substantif, otonomi keilmuan bersifat relatif, yaitu tidak bebas nilai sepenuhnya. Hal ini dapat kita terapkan pada Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional Indonesia dalam kerangka Pembangunan Hukum Nasional. Dalam membangun Hukum Nasional harus berdasarkan *etika Pembangunan Hukum Nasional*. Pertanyaan, mengapa etika diperlukan dalam pembangunan Hukum Nasional, khususnya Hukum Ekonomi? Pembahasan etika *an sich* sudah dijadikan bahan dialog para filsuf besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles (di abad ke-4 SM), di mana nilai-nilai kebijaksanaan (*wisdom*) yang patut, bahkan wajib dianut seseorang atau masyarakat. Fundamental, karena etika juga sering disebut sebagai filsafat moral selalu berada dalam konteks kultural. Dalam arti tidak dapat dilepaskan dari pandangan hidup seseorang atau masyarakat yang bersangkutan, dan selalu aktual, karena etika mengandung nilai-nilai yang selalu dirindukan oleh siapapun dan di manapun. Lebih-lebih dalam kehidupan masa kini dalam masyarakat Indonesia, di mana implikasi pembangunan telah melahirkan perombakan yang menyeluruh sendi-sendi kehidupan yang paling dasariah, juga kehidupan kita di bidang hukum.[38] Sedangkan Pembangunan

[37]A.G.M. van Melsen, log.cit., 1969, hlm.88.

[38]Koento Wibisono, dalam Artidjo Alkostar, edt. *Identitas Hukum Nasional*, (Yogyakarta: FH UII, 1997), hlm. 3-4.

Hukum Nasional adalah membangun tata hukum Indonesia yang bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian, *Hukum Nasional Indonesia dengan sendirinya akan memiliki corak khas sebagai salah satu aspek dari budaya Indonesia*.

Tentunya setiap bangsa memiliki kebudayaanya sehingga sistem hukumnya pun akan memiliki corak sesuai dengan kebudayaan. Kaitan antara etika dengan pembangunan hukum nasional adalah bahwa etika memberikan petunjuk tentang cara membangun hukum, memilih jenis hukum apa yang akan dibangun dan juga tentang cara melaksanakan hukum yang telah dibangun. Karena etika memberikan arah dalam cara membangun hukum, memilih jenis hukum yang akan dibangun dan bagaimana pelaksanaan hukum yang telah dibangun maka dengan sendirinya berarti membangun hukum dengan cara yang benar atau sesuai dengan etika.[39] Pertanyaan lebih lanjut adalah apa yang menjadi etika pembangunan hukum nasional?

Jika kita telusuri kembali sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan identitasnya yang bersumber pada filsafat Pancasila maka perlu diingat bahwa Pancasila bukanlah sekadar konsensus politik atau konsensus konstitusional semata, melainkan lebih dari itu. Pancasila sebagai salah satu unsur *Staats-fundamental Norm* bangsa Indonesia, dengan sendirinya juga merupakan komitmen filsafati yang menjanjikan persatuan sikap dan pandangan bangsa Indonesia, kesatuan upaya bangsa Indonesia dalam menyongsong hari depan yang dicita-citakan bersama melalui pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan bidang hukum nasional. Konsekuensi dan implikasinya ialah bahwa *Pancasila merupakan asas etika,*[40] dalam arti sebagai pangkal tolak derifikasi deduktif dan parameter induktif dalam menjabarkan setiap gagasan dalam setiap bidang pembangunan, dan sekaligus juga dalam mengkaji serta menguji setiap capaian yang kita peroleh melalui pembangunan. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar alternatif, melainkan kategori imperatif bagi pembangunan nasional.

Pancasila adalah sumber dari segala sumber dalam kehidupan bernegara dalam negara Indonesia. Untuk itu, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dalam pembangunan hukum nasional diletakkan pada posisi teratas atau tertinggi sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono dalam lima belas komponen yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan dan implementasi pembangunan hukum nasional, sebagai berikut:[41]

---

[39]Baharuddin Lopa, Artidjo Alkostar, edt. *log.cit,* 1997, hlm. 17-18.

[40]*Ibid*.

[41]C.F.G. Sunaryati Hartono, dalam B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,* (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), hlm. 77.

(1) Filsafat dan asas-asas hukum nasional.
(2) Wawasan dan pendekatan pembinaan hukum nasional.
(3) Kaidah-kaidah hukum (termasuk Yurisprudensi dan Hukum Kebiasaan).
(4) Pranata-pranata hukum.
(5) Lembaga-lembaga hukum.
(6) Kesadaran hukum nasional.
(7) Sikap dan perilaku hukum.
(8) Proses dan prosedur, cara dan mekanisme hukum.
(9) Monitoring, analisis dan evaluasi, pengkajian, dan penelitian hukum.
(10) Sistem pendidikan hukum (formal, non-formal, dan informal).
(11) Ilmu Hukum Nasional.
(12) Profesi Hukum, para Penegak Hukum dan Pejabat/Petugas Pelayanan Hukum.
(13) Penyedia data, bahan, kepustakaan, dan informasi hukum.
(14) Sarana dan prasarana fisik dan non-fisik.
(15) Rencana-rencana pembangunan hukum.

Pembangunan hukum suatu bangsa merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses. Dalam perumusan hasil seminar "Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional, disebutkan bahwa cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, cita hukum itu adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: keadilan, kehasilan-gunaan dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk *perpaduan pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan* yang diproyeksikan pada proses tiga unsur tersebut tadi.

Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum itu akan memengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. Dirumuskan dan dipahaminya cita hukum atau memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku dan memudahkan terjaga konsistensi dalam penyelenggaraan hukum.[42]

[42]B. Arief Sidhareta, *Ibid,* hlm.181.

Pancasila adalah cita hukum dan sumber tertib hukum nasional Indonesia.[43] Ketentuan yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai cita hukum terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Pada 1 Juni 1945 Bung Karno sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah menyampaikan pidato atas permintaan Ketua BPUPKI tentang *Philosofische Grondslag*, dasar-dasar filsafat bagi negara Indonesia Merdeka. Isi pidato itu tidak saja mengikat, tetapi pada dasarnya disetujui oleh seluruh anggota BPUPKI. Isi pidato diterima sebagai pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat lima sila yang menjadi "dasar negara" yang disebut Pancasila.[44]

Pancasila sebagai cita hukum dan falsafah bangsa Indonesia yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 angka III menyatakan bahwa:

> "*Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya*."

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menyatakan bahwa terdapat kaitan dan saling memengaruhi antara pokok-pokok pikiran, cita hukum (*Rechtsidee)* dan hukum dasar negara. Pokok-pokok pikiran merupakan sumber dari dan akan memberi isi serta menjiwai cita hukum dan asas-asas hukum yang akan terwujud dalam hukum dasar negara dan selanjutnya akan menjadi fundamen dari aturan hukum yang berlaku.

Intisari dari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak lain adalah nilai-nilai atau perwujudan sila dari kelima sila Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur dan pandangan hidup yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diperjuangkan sejak lama dan telah menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia.

Setiap sila dari Pancasila sebagai cita hukum, asas hukum, filsafat negara dan norma dasar tertinggi, menurut Notonagoro[45] memiliki kualifikasi empat sila yang lain yang digambarkan sebagai berikut.

"1. *Bagi sila pertama*: Hakikat manusia Indonesia terhadap Tuhan, yang ditentukan oleh hakikat Tuhan, sebagai bawaan hakikat manusia makhluk Tuhan adalah untuk taklim dan taat kepada Tuhan.

---

[43]Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966.

[44]M. Dawam Rahardjo, "Pancasila dan Masalah Hak Asasi Manusia" dalam *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Problem dan Tantangannya*, Jakarta, 1995, hlm. 27.

[45]Notonagoro, *Beberapa Hal mengenai Falsafah Pancasila,* (Jakarta, Rajawali Pers 1982), hlm. 58-61.

2. *Bagi sila kedua*, Hakikat manusia Indonesia sebagai bawaan hakikat manusia Indonesia makhluk Tuhan adalah untuk:
   (a) memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwanya, individu dan sosialnya, dan kebutuhan hidup-religiusnya;
   (b) melakukan perbuatan atas dorongan-dorongan kehendak, yang tertuju kepada kebaikan, berdasar atas putusan akal, yang tertuju kepada kenyataan termasuk kebenaran, selaras dengan rasa, yang tertuju kepada keindahan kejiwaan, serta atas kesatuan rasa-kehendak berupa kepercayaan, yang tertuju kepada kenyataan mutlak (Tuhan), dan selaras pula dengan kesatuan jiwa raga, kesatuan sifat hakikat manusia pribadi berdiri sendiri-makhluk Tuhan, semuanya itu dalam keseimbangan kesatuan harmonis-dinamis.

   (Kemampuan jiwa yang demikian itu menunjukkan tabiat saleh yang perinciannya: *pertama,* berupa kebijaksanaan, yaitu selalu berbuat atas dorongan kehendak, berdasarkan keputusan akal, selaras dengan rasa, *kedua,* berupa keadilan, yaitu selalu memberikan kepada orang lain apa yang telah menjadi haknya, *ketiga,* berupa kesederhanaan, yaitu selalu membatasi diri dalam hal kenikmatan raga, *keempat,* berupa keteguhan, yaitu selalu membatasi diri dalam hal menghindarkan penderitaan. Semuanya itu untuk mencapai tujuan hidup manusia, yaitu yang menurut pendapat umum disebut kebahagiaan yang sempurna).
3. *Bagi sila ketiga*: Hakikat manusia Indonesia sebagai bawaan hakikat warga Persatuan Indonesia, penjelmaan hakikat manusia makhluk Tuhan dalam kesatuan hubungan dengan sesama umat manusia makhluk Tuhan adalah untuk kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat dan negara, yaitu:
   (a) mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan-perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak menolak ke arah perselisihan-pertikaian-perpecahan;
   (b) menghidupkan perbedaan-perbedaan yang mempunyai daya tarik ke arah kerja sama;
   (c) dengan kesediaan, kecakapan, dan usaha untuk melaksanakan kesatuan kebangsaan Indonesia yang organis tak terpisah-pisah, yang seimbang-harmonis-dinamis;
   (d) atas kesadaran akan dan dengan melaksanakan kebijaksanaan hidup dan nilai-nilai hidup kemanusiaan serta nilai-nilai religius yang sewajarnya.
4. *Bagi sila keempat*: Hakikat manusia Indonesia sebagai bawaan hakikat warga rakyat Indonesia, penjelmaan hakikat manusia makhluk Tuhan yang menjelma sebagai hak-wajib asasi manusia dalam hubungan hidup bersama perseorangan, dalam keseimbangan dengan sifat hakikatnya makhluk

sosial, adalah untuk hidup melaksanakan dan menikmati keamanan, kemerdekaan/kebebasan dan kekuasaan rakyat, keseluruhan jumlah semua warga, sebagai pendukung kekuasaan berupa hak wajib demokrasi politik dan sebagai pendukung kepentingan berupa hak wajib demokrasi kepentingan atau fungsional, dalam lapangan kenegaraan atas dasar tritunggal "negara dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat", guna tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan jasmaniah, rohaniah religius, atas dasar tritunggal: satu untuk semua, semua untuk satu, semua untuk semua."

5. *Bagi sila kelima*. Hakikat manusia Indonesia sebagai bawaan hakikat pendukung keadilan sosial, penjelmaan hakikat manusia-makhluk Tuhan yang menjelma pula sebagai hak-wajib asasi manusia, dalam hubungan hidup bersama dengan sesama warga sebangsa dan sesama umat manusia makhluk Tuhan adalah untuk hidup melaksanakan dan menikmati kesamaan kemerdekaan/kebebasan dan kekuasaan dari perseorangan dalam keseimbangan dengan sifat hakikatnya makhluk sosial guna mengusahakan dan memenuhi kepentingan kebutuhan, keperluan hidup jasmaniah-rohaniah religius, yang sesuai dengan sifat-sifat hakikat manusia makhluk Tuhan dan martabat mutlak manusia sebagai pribadi.
   (a) yang oleh karena hidup adalah berhak-berwajib hidup;
   (b) dan oleh karena itu berhak-berwajib mendapat segala sesuatu yang menjadi hak kepentingan-kebutuhan-keperluan hidup;
   (c) dalam hakikatnya tidak karena hasil usahanya, akan tetapi karena hak-kewajibannya untuk hidup, dalam arti mutlak sesuai dengan martabat manusia. …."

Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka Pancasila sebagai cita hukum akan menguasai hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis. Atau dengan kata lain akan berfungsi sebagai pengukur dan penguji dan landasan hukum dasar yang selanjutnya akan menjadi fundamen bagi peraturan perundangan Negara Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch yang dikutip dari Roeslan Saleh,[46] yaitu: "bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu menentukan bahwa tanpa cita hukum maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum."

Fungsi Pancasila sebagai cita hukum yang merupakan landasan konstitusional dan sebagai penguji dari suatu hukum positif memiliki peranan yang

[46]Roeslan Saleh. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, (Jakarta: CV Karya Dunia Fikir, 1996), hlm. 17.

sangat penting dalam kehidupan konstitusional negara Indonesia dan juga akan memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Masyarakat dan bangsa Indonesia yang heterogen berasal dari kultur dan daerah yang berbeda dan bergaul di tengah-tengah masyarakat dunia yang sedang berubah sangat memerlukan suatu falsafah dan cita hukum nasional sebagai pedoman.[47]

Dalam rangka pembangunan Hukum Ekonomi Nasional harus berpedoman dengan cita hukum Pancasila yang dijabarkan Batang Tubuh UUD 1945 dalam Pasal 33, yang menentukan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas *asas kekeluargaan*.
2. Cabang-cabang produksi *yang penting* bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya *dikuasai oleh negara* dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perkonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas *demokrasi ekonomi* dengan prinsip kebersamaan, efsiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945, ada beberapa hal pokok yang sangat prinsipil yang terkait dengan sistem perekonomian Negara Indonesia yang menjadi pokok perdebatan, yaitu mengenai:

1. *asas kekeluargaan;*
2. *cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;*
3. *dikuasai negara;*
4. *kemakmuran rakyat;*
5. *demokrasi ekonomi.*

Lebih lanjut penjelasan Pasal 33 menjelaskan bahwa:

> *"Dalam Pasal 33 tercantum dasar ekonomi demokratis, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan untuk penilikan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun yang sesuai dengan itu adalah koperasi.*

[47] Menurut Roeslan Saleh: "Walaupun disadari benar bahwa titik akhir dari cita-cita masyarakat itu tidak mungkin dicapai sepenuhnya, namun cita hukum memberi faedah positif karena ia mengandung dua sisi: dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku, dan kepada cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha mengatur tata kehidupan masyarakat dan bangsa." *Ibid*, hlm. 16

Perekonomian berdasar atas demokratis ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup banyak orang harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-perorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Semenjak lima tahun terakhir UUD 1945 telah diadakan amandemen sebanyak empat kali, khusus Pasal 33 ada penambahan dua ayat, yaitu ayat 4 dan ayat 5, ayat 1 s.d.3 masih tetap. Amandemen ini hanya mempertajam bahwa Perkonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas *demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efsiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang*. Selama ini banyak ketidakjelasan tentang undang-undang yang mengatur di bidang perkonomian, dengan adanya tambahan kedua ayat ini, maka secara tegas ada batasan dan pedoman ke mana arah kebijakan di bidang perkonomian akan ditetapkan.

Sebenarnya ide pembangunan hukum ekonomi nasional telah cukup sering diajukan oleh berbagai pakar ekonomi dan hukum, misalnya Prof. Dr. Emil Salim berpendapat bahwa dalam menghadapi perubahan ekonomi perlu dicari kerangka dasar Hukum Ekonomi Nasional dengan prinsip-prinsip:[48]

(1) Demokrasi ekonomi, dengan ciri-ciri positif dan negatifnya.

(2) Pengembangan kesempatan yang sama dan adil dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan.

(3) Pemeliharaan kekuatan penyumbang untuk mencegah kosentrasi kekuatan ekonomi pada satu-dua kelompok atau individu, sehingg dapat dicegah kekuatan monopoli dan oligopoli.

(4) Penyelenggaraan mekanisme *check* dan *recheck* untuk memelihara keseimbangan kekuatan dan bahkan dapat diarahkan untuk melindungi golongan ekonomi lemah

(5) Pengembangan pertimbangan kepentingan umum dalam pembangunan dengan memerhatikan adanya keterbatasan sumber daya.

(6) Penyempurnaan aparatur serta pengelola pembangunan (ekonomi) dengan menempuh prosedur hukum/peraturan perundang-undangan.

[48]Emil Salim dalam Sumantoro edt., *Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 43.

(7) Penertiban produk Hukum Ekonomi pembangunan perlu memerhatikan butir-butir dalam Demokrasi Ekonomi dan selanjutnya dapat mendorong ikhtiar masyarakat untuk mengembangkan usaha/kegiatan di bidang ekonomi, sehingga tercipta suhu/iklim, budaya dan kesadaran untuk menyumbang hukum ekonomi itu sendiri

Demokrasi ekonomi, dengan ciri-ciri positif dan negatifnya yang dimaksudkan oleh Emil Salim tersebut sebenarnya berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan GBHN, yang disimpulkan sebagai berikut:[49]

a. Demokrasi Ekonomi yang mempunyai ciri-ciri positif yaitu:
   (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
   (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
   (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
   (4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permupakatan lembaga-lembaga rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga Perwakilan Rakyat pula.
   (5) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
   (6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
   (7) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
   (8) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

   Sedangkan demokrasi ekonomi tersebut harus dihindari dari ciri-ciri negatif, yaitu:
   (1) Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarah di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
   (2) Sistem *etatisme* dalam negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

[49]Sumantoro edt., *Hukum Ekonomi,* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 23-24.

(3) Pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk yang merugikan masyarakat.

Dari pembahasan di atas jelas bahwa dari aspek substansi dari otonomi keilmuan, kita bangsa Indonesia memiliki cita hukum yang dapat menentukan bentuk dan sistem hukum sendiri berdasarkan akar budaya dan aspirasi bangsa Indonesia, tidak serta merta dipengaruhi oleh unsur asing yang berupa arus globalisasi yang memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa Indonesia. Selama ini menurut Prof. Dr. Muladi seberapa jauh doktrin-doktrin dasar dalam UUD 1945 dengan segala refleksi pengaturannya, dalam kehidupan global ini tidak dianggap justru sebagai kendala dan sampai seberapa jauh aspirasi global dalam berbagai kehidupan tersebut dapat dimanfaatkan tanpa harus mengorbankan jati diri bangsa, dengan kata lain bagaimana membangun hukum berstuktur sosial Indonesia dengan tetap memerhatikan trend globalisasi.[50] Kemudian Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, juga menjelaskan bahwa Pola pembangunan hukum sampai sekarang ini boleh disebut sebagai pembenahan atau penataan ke dalam untuk memenuhi cita hukum dalam UUD 1945. Dalam konteks perkembangan globalisasi dewasa ini, maka tentunya kita perlu melakukan peninjauan terhadap siasat yang lebih melihat ke dalam tersebut, sekalipun itu tidak berarti melepaskan orientasi kepada citra hukum UUD.[51] Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum, ada beberapa hal yang secara kritis terutama hukum ekonomi mendapat perhatian, yaitu:

(1) Mendesain struktur hukum ekonomi Indonesia sebagai bagian pembangunan hukum nasional.
(2) Adaptasi kecenderungan hukum ekonomi internasional ke dalam hukum ekonomi nasional.
(3) Membangun paradigma Hukum Pancasila sebagai parameter pembangunan hukum.

Dalam mendesain struktur hukum ekonomi nasional haruslah berpedoman dengan cita hukum dan nilai-nilai dasar yang terjabar dalam UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas. Nilai yang dimunculkan adalah nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut merupakan dasar bagi pembangunan Hukum Ekonomi Nasional yang dapat menimbulkan struktur ekonomi sosial masyarakat Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan perangkat hukum yang dibutuhkan adalah perangkat hukum yang

[50]Muladi dalam Zudan Arif Fakrulloh, Membangun Hukum yang Berstruktur Sosial Indonesia dalam Kanca Trends Globalisasi, dalam Wajah Hukum di Era Reformasi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 52-53.

[51]Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global* dalam Khudzaifah Minyati & Kelik Wardiono, edt., Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001, hlm.13.

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di dalam era global dan yang mampu menampung cita hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional di samping dalam kesejahteraan dengan negara-negara lain.[52] Sedangkan adaptasi terhadap kecenderungan global tersebut dilakukan dengan melalui ratifikasi konvensi internasional dengan undang-undang maupun keputusan presiden. Hal ini tidak bertentangan dengan tujuan nasional, karena dalam Pembukaan UUD 1945 kita menyatakan ikut serta menciptakan ketertiban dunia.

Dalam kaitannya dengan era globalisasi, semua aspek yang dijelaskan di atas sangat menunjang dalam pembentukan hukum ekonomi, tetapi harus terrencana dengan baik, karena dalam pembentukan dan pembaruan hukum, aspirasi yang perlu diperhatikan adalah aspirasi suprastruktur, infrastruktur, ekspertis dan aspirasi masyarakat internasional, di samping proses *legal drafting* yang berkualitas.[53] Penulis setuju dengan pendapat Prof. Dr. Muladi, bahwa dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum harus tergambar pula karakteristik hukum modern. Karakteristik hukum modern yang dimaksud adalah (a) seragam dalam aplikasi: (b) transaksional; (c) universalistik; (d) hierarkis; (e) *organized-critically*; (f) rasional; (g) profesional; (h) dapat diamandemen; (i) politik; (j) pemisahan lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.[54] Namun demikian, Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan UUD 1945 menjadi syarat utama di samping persyaratan-persyaratan lain, akan tetapi Pancasila merupakan instrumen dari *"Margin of Appreciation Doctrine."* Dalam hal ini Pancasila menjadi acuan parameter bagi penerapan *"Margin of Appreciation Doctrine,"* seperti di India dikenal Mahatma Gandhi disebut sebagai *"the seven social science, yaitu politic without morality, commerce without morality; wealth without work, education without character, science without humanity, pleasure without conscience, and worship without sarcrifice."*[55] Oleh karena itu, Paradigma Hukum Pancasila perlu kita matangkan dan hidupkan, sehingga Pancasila sebagai

---

[52]Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, dalam bukunya berjudul *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan* menjelaskan bahwa Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan apabila mungkin, membolehkan keanekaragaman bila menghendakinya, tetapi bagaimanapun juga mengutamakan kepastian (*Unity whenever posible, diversity where desireable, but above all certainty*), kalau kita beralih dari alam filsafat ke tingkat yang lebih konkret cukup banyak asas-asas atau prinsip-prinsip terkandung dalam UUD1945 dan Mukaddimah yang seharusnya dijadikan pedoman dalam melakukan pembaruan hukum nasional yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum umum yang diterima oleh bangsa-bangsa di dunia. (Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan berkerja sama dengan PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 188-189.)

[53]Muladi, Demokratisasi, *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, hlm.125).

[54]*Ibid*.

[55]Muladi, "Menggali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Progresif,* Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, Volume 1/Nomor 1/April 2005, hlm. 35.

falsafah benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan sekaligus mewujudkan masyarakat adil dan makmur.



Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari aspek substansi dari otonomi keilmuan, kita bangsa Indonesia memiliki cita hukum yang dapat menentukan bentuk dan sistem hukum sendiri berdasarkan akar budaya dan aspirasi bangsa Indonesia, tidak sertamerta dipengaruhi oleh unsur asing yang berupa arus globalisasi yang memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa Indonesia.

Selama ini doktrin-doktrin dasar dalam UUD 1945 dengan segala refleksi pengaturannya, dalam kehidupan global ini tidak dianggap justru sebagai kendala dan sampai seberapa jauh aspirasi global dalam berbagai kehidupan tersebut dapat dimanfaatkan tanpa harus mengorbankan jati diri bangsa, dengan kata lain bagaimana membangun hukum berstuktur sosial Indonesia dengan tetap memerhatikan trend globalisasi.

Dalam pembangunan hukum, ada beberapa hal yang secara kritis terutama hukum ekonomi mendapat perhatian, yaitu: Mendesain struktur hukum ekonomi Indonesia sebagai bagian pembangunan hukum nasional, Adaptasi kecenderungan hukum ekonomi internasional ke dalam hukum ekonomi nasional, dan membangun paradigma hukum Pancasila sebagai parameter pembangunan hukum ekonomi.

Dalam mendesain struktur hukum ekonomi nasional haruslah berpedoman dengan cita hukum dan nilai-nilai dasar yang terjabar dalam UUD 1945. Nilai yang dimunculkan adalah nilai-nilai budaya bangsa Indonesia atau nilai dasar yang tercantum dalam cita hukum Pancasila. Nilai-nilai tersebut merupakan dasar bagi pembangunan hukum ekonomi nasional yang dapat menimbulkan struktur ekonomi sosial masyarakat Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan perangkat hukum yang dibutuhkan adalah perangkat hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di dalam era global dan yang mampu menampung cita hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. Sedangkan adaptasi terhadap kecenderungan global tersebut dilakukan dengan melalui ratifikasi konvensi internasional dengan undang-undang maupun keputusan presiden.

Dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum harus tergambar pula karakteristik hukum modern. Namun demikian, Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan UUD 1945 menjadi syarat utama di samping persyaratan-persyaratan lain. Pancasila merupakan instrumen dari "*Margin of Appreciation doctrine,*" dalam arti Pancasila menjadi acuan parameter bagi penerapan "*Margin of Appreciation Doctrine.*"

Daftar Referensi

Artidjo Alkostar, edt. *Identitas Hukum Nasional*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997.

A. Sonny Keraf & Mikhael Dua. *Ilmu Pengetahuan sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.

B. Arief Sidharta. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2000.

C.F.G. Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.

C.F.G. Sunaryati Hartono, dalam B. Arief Sidharta. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Emil Salim dalam Sumantoro edt. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Habermas, Jurgen. *Legitimation Crisis*, terj, Yudi Santoso, *Krisis Legitimasi*. Yogyakarta: CV Qalam, 2005.

Hattne, Hattne. *Development Theory and The Three World*, terj. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Huala Adolf. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Ida Susanti & Bayu Seto, Edt. *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

K. Berten dalam Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Khudzaifah Minyati & Kelik Wardiono, edt., Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001.

Koento Wibisono, dalam Artidjo Alkostar, edt. *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: FH UII, 1997.

Lili Rasjidi. *Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*, dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia. Bandung: Eresco, 1995.

M. Dawam Rahardjo. "Pancasila dan Masalah Hak Asasi Manusia" dalam *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Problem dan Tantangannya*. Jakarta, 1995.

Moss, Rosabeth Kanter, dalam Suhanadji & Waspodo TS. *Modernisasi dan Globalisasi Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*. Malang: Insan Cendikia, 2004.

Marwah M. Diah. *Restruktrurisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau Korporatisasi*. Jakarta: Literata Jendela Dunia Ilmu.

Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerja sama dengan PT Alumni, Bandung, 2002.

Muladi. *Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi*, Makalah, tt.

———— dalam Zudan Arif Fakrulloh, *Membangun Hukum yang Berstruktur Sosial Indonesia dalam Kanca Trends Globalisasi*, dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Notonagoro. *Beberapa Hal mengenai Falsafah Pancasila*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1982.

Oetojo Oesman. *Kebijakan Pembangunan Hukum dalam PJP II*. Makalah, Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional dalam PJP II, Jakarta, Juli 1995.

Petras, James dalam Suhanadji & Waspodo TS. *Modernisasi dan Globalisasi Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*. Malang: Insan Cendikia, 2004.

Paul Hirst dan Grahame Thompson. *Globalisasi adalah Mitos*. terj. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Peter, Hans Martin dan Harald Schumann, Die Globalisierungsfalle der angriff auf demokratie und Wohhistand, terj. Warsito dkk, Hasta Mitra-Institute for Global Justice, Jakarta, 2004.

A.G.M. van Melsen. *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*. terj. K. Berten, Jakarta: PT Gramedia, 1969.

Roeslan Saleh. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*. Jakarta: CV Karya Dunia Fikir, 1996.

Satjipto Rahardjo. *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global* dalam Khudzaifah Minyati & Kelik Wardiono, edt., Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama, Universitas Muhammadyah Surakarta, 2001.

Sri Edi Swasono. Ekspose Ekonomi Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas, Pusat Studi ekonomi Pancasila_UGM, Yogyakarta, 2005.

Sri Redjeki Hartono. Pentingnya Pengaturan yang Baik di Bidang Hukum Bisnis, Khususnya Investasi, *Jurnal Spektrum Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum UNTAG, Vol.03/No.1/April 2005.

Suhanadji-Waspodo TS. *Modernisasi dan Globalisasi Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*. Malang: Insan Cendekia, 2004.

Sumantoro edt. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Undang-Undang Dasar 1945.

RAJAWALI PERS

11

POLITIK HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG*

Oleh:
*Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.***

Pendahuluan

KEJAHATAN TENGAH meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia dan menghambat kemajuan negara, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya. Mengingat kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, maka wajar jika ada suatu ungkapan: *kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita*. Artinya, sejak dulu hingga kini orang selalu membicarakan mengenai kejahatan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa) sampai kepada kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktiannya.

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan perdagangan orang tidak lepas dari perkembangan tersebut, dan sehubungan dengan konteks perdagangan orang dimaksud, pada 1995 dalam konferensi PBB mengenai *the crime prevention and the treatmen of offers* yang diselenggarakan di Cairo, telah dibicarakan tindakan-tindakan *to combat transnational crime, terrorism and violence against women*. Sehubungan dengan itu, dan terkait dengan *combat transnational crime*, pada 2000 di Palermo Itali diselenggarakan konferensi PBB mengenai *Transnational Organized Crime*, termasuk di dalamnya adalah mengenai perdagangan orang, khususnya wanita dan anak.

*Disampaikan dalam seminar Nasional dengan tema: Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Lokal, Nasional, dan Internasional, Sabtu, tanggal 27 Juni 2009.

**Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Apa yang telah dibicarakan dalam Kongres PBB tersebut, merupakan respons atas perkembangan kejahatan, baik dalam skala nasional maupun internasional, termasuk kejahatan perdagangan orang, khususnya wanita dan anak sebagai salah satu jenis kejahatan yang mendunia. Kejahatan perdagangan orang telah masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya, yaitu *the drug trafficking industry, smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*.[1]

Jenis-jenis kejahatan tersebut sangat memprihatinkan masyarakat internasional, karena apabila dikaitkan dengan ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat begitu dahsyat (*insidious*), dan dapat menembus ke berbagai segi atau bidang, baik terhadap keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional, dan merupakan ancaman utama (*frontal attack*) terhadap kekuasaan politik, dan ancaman bagi kewibawaan negara. Di samping itu, memperangkap dan bahkan memperbudak golongan-golongan masyarakat, khususnya wanita dan anak-anak dalam melakukan pekerjaan ilegal di berbagai bidang, terutama sekali dalam prostitusi.

Adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut. Dana-dana gelap ini akan digunakan oleh pelaku untuk membiayai kegiatan kejahatan selanjutnya.[2] Dan, ini tampaknya terkait dengan perubahan dalam bidang ekonomi global, yang telah memberikan keuntungan bagi penjahat tingkat dunia, yaitu dengan memanfaatkan peningkatan arus barang, uang, dan orang secara lintas batas, maka organisasi kejahatan internasional telah memperluas jangkauan wilayah mereka dan hubungan mereka dengan kekuasaan pemerintahan setempat.

Kejahatan perdagangan orang yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*,[3] *white collar crime*, *corporate crime*,

---

[1]Dokumen PBB No. E/CONF.88/2 tanggal 18 Agustus 1994 dan telah dibicarakan dalam World Ministerial Conference on Organizied Transnational Crime di Naples, 21-23 November 1994 dengan tema Problem and Dangers Posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions of the World, untuk disampaikan dalam Kongres PBB ke-9 tentang the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Kairo, 29 April – 8 Mei 1995, hlm. 17-22.

[2]Ambassador Wendy Chamberlin, Principal Deputy Assistant Secretary, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State, in Economic Perspectives, *The Fight Against Money Laundering*.

[3]Untuk memahami apa yang dimaksud dengan kejahatan terorganisasi tersebut, dalam Article 2 ayat 1 *Proposal and Contributions Received from Governments,* dinyatakan (General Assembly,

dan *transnational crime*. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk dari *cyber crime*.

Berdasarkan karakteristik yang demikian, maka dampak dan korban yang ditimbulkannya juga sangat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dan, sehubungan dengan itu, dalam United Nations Office on Drugs and Crime,[4] dinyatakan bahwa dari dusun-dusun Himalaya hingga kota-kota Eropa Timur, orang-orang, khususnya wanita dan anak-anak, tergiur dengan prospek pekerjaan dan bayaran yang tinggi, baik sebagai pembantu rumah tangga, pelayan, maupun pekerja pabrik. Para pedagang tersebut mendapatkan wanita dan anak-anak itu dengan cara menipu atau informasi bohong di antaranya melalui iklan-iklan. Wanita dan anak-anak itu dipaksa bekerja sebagai pelacur.[5]

Kondisi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan gambaran tersebut, dan sebagai salah satu contoh, yaitu sebagaimana yang diberitakan oleh Media Indonesia Online[6] bahwa polisi berhasil membongkar sindikat penjual ABG (anak baru gede) untuk dijadikan WTS (wanita tuna susila) dan menangkap tiga germo di lokalisasi Teleju Pekanbaru pada hari Jumat 28 Februari 2003. Tiga ABG yang berasal dari Cianjur Jawa Barat itu, semula dijanjikan akan bekerja di Jakarta, tetapi kenyataannya dijadikan WTS dan dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang. Polisi berhasil membongkar sindikat penjualan ABG tersebut berdasarkan informasi masyarakat dan laporan pers.

Adanya sindikat penjualan manusia (ABG) tersebut menunjukkan bahwa kejahatan terorganisasi itu (perdagangan wanita dan anak) sudah merambah ke Indonesia, dan ini merupakan tantangan bagi Indonesia untuk menanggulanginya, baik pada tataran perundang-undangan (kebijakan legislatif) maupun

---

A/AC.254/5 19 December 1998), bahwa *organized crime* berarti kegiatan-kegiatan yang bertujuan (melakukan perbuatan) dalam rangka (dalam kaitannya dengan) sebuah organisasi kejahatan. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan: Sebuah organisasi kejahatan (*a criminal organization*) berarti suatu kelompok (tiga atau lebih) orang dengan hubungan hierarki atau hubungan personal yang dapat bertahan lama untuk tujuan memperkaya diri atau pengawasan wilayah-wilayah atau pasar-pasar, baik di dalam maupun di luar negeri (*internal or foreign*) dengan cara melawan hukum seperti kekerasan, ancaman atau korupsi, dan dalam memajukan aktivitas kejahatan itu juga masuk ke dalam ekonomi yang sah.

[4]Trafficking in Human Beings, http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_human_beings.html, diakses tanggal 15 April 2003.

[5]Dalam berbagai sumber telah dikemukakan bahwa, prostitusi memang sudah lama dijadikan sebagai unsur utama dalam kegiatan organisasi kejahatan pada tingkat nasional, ataupun juga pada dimensi internasional. Organisasi kejahatan Triads dan Yakuza khususnya aktif di bidang ini dan menjadikan wanita sebagai budak dalam industri seks wisata (*tourist sex industry*) di Filipina, Korea Selatan dan Thailand. Jenis perdagangan gelap ini menjadikan suguhan wanita sebagai komuditi yang mempunyai nilai pasar. Bekerja seks merupakan bagian besar dalam dunia ekonomi di mana wanitanya dan anak-anak dipandang sebagai barang kesukaan.

[6]Media Indonesia Online, Sindikat Penjual WTS ABG Dibongkar Polisi, http://www.media-indonesia.com, diakses tanggal 02 Maret 2003.

aparat pelaksananya (kebijakan aplikasi/yudikatif dan kebijakan eksekusi/eksekutif).

Mengingat perbuatan perdagangan orang yang demikian itu, pada hakikatnya merupakan kejahatan transnasional dan merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Bahkan dalam UNODC dikemukakan bahwa perdagangan orang merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan (*human trafficking is a crime against humanity*).

Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58), tanggal 19 April 2007, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban. Bahkan saat ini, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009, tanggal 1 Januari 2009. Dengan telah diratifikasinya Konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia telah benar-benar merupakan bagian dari upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang secara global.

Mengingat pelaku tindak pidana perdagangan orang akan sangat berpotensi bagi timbulnya korban, maka yang patut dipertanyakan: apakah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 telah mengatur mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang? Karena dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 telah disebutkan bahwa ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Jika demikian halnya, maka yang perlu dipertanyakan lagi, apakah Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 telah cukup baik dalam mengatur mengenai perlindungan korban.



Perluasan Subjek Hukum Pidana

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang, terlebih dahulu perlu dikemukakan mengenai perluasan subjek hukum tindak pidana perdagangan orang. Hal itu penting, mengingat adanya korban pasti ada pelakunya.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pasal 1 angka (4) merumuskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Ini berarti subjek hukum pidana menurut undang-undang ini, selain manusia alamiah (*natural person*), juga manusia hukum (*juridical person*). Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (6) dipertegas lagi bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Namun, ketika

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) bahwa yang dimaksud dengan setiap orang itu meliputi kelompok orang. Dan, dalam Pasal 1 angka (6) RUU dipertegas lagi bahwa kelompok orang adalah sekumpulan dua orang atau lebih baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Walaupun, pengertian mengenai kelompok orang tersebut, masih belum sesuai dengan *Annex I UN Convention against Transnational Organized Crime*, yang memberi batasan dalam Article 2 tentang *Use of terms*. Karena, dalam huruf (a) dinyatakan bahwa kelompok kejahatan terorganisasi berarti sebuah kelompok yang terstruktur (*structured group*) dari tiga atau lebih orang. Sedangkan dalam RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kelompok orang dimaksud terdiri atas dua orang atau lebih.

Terlepas dari perbedaan penyebutan jumlah dalam kelompok orang tersebut, akan tetapi pembuat RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah mengetahui bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi. Karena itu, dalam Konsideran disebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Itu sebabnya, subjek hukum tindak pidana perdagangan orang diperluas, di samping orang perseorangan, korporasi, juga kelompok orang. Dan dalam Pasal 16 RUU tersebut ditentukan dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2[7] ditambah 1/3 (sepertiganya). Setelah RUU itu disahkan menjadi undang-undang, ketentuan mengenai kelompok orang (group) dihilangkan. Akhirnya, yang diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 adalah orang perorangan, dan korporasi. Akan tetapi, ketentuan Pasal 16 RUU masih tetap dipertahankan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, yaitu dalam pasal dan redaksi yang sama. Sementara itu, pengertian mengenai kelompok orang sudah dihilangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

---

[7]Pasal 2 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya, mengenai diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di samping orang perseorangan, tidak lepas dari upaya untuk mengantisipasi perkembangan ke depan. Karena dalam RUU tentang KUHP telah diatur, bahwa: "Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah *(natural person*) tetapi mencakup pula korporasi, ……." (Penjelasan Umum Buku Kesatu, angka 4).

Mengingat korporasi adalah subjek hukum yang sifatnya non-badaniah, maka perlu diketahui kapan suatu tindak pidana dikatakan telah dilakukan oleh korporasi. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, sudah diatur melalui Pasal 13 ayat (1): Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Hal ini penting, jika tidak ada penentuan mengenai kapan suatu tindak pidana perdagangan orang dapat dikatakan telah dilakukan oleh korporasi, maka akan mengaburkan dalam hal dapat dipidananya korporasi. Di samping itu, juga akan melemahkan tanggung jawab korporasi terhadap korban, jika pelakunya adalah korporasi.



Kebijakan Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 bahwa perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Jika demikian halnya, maka yang perlu ditelusuri apakah Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 telah cukup baik dalam upaya memberikan perlindungan korban.

Sebenarnya, UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan suatu langkah yang positif dalam upaya Perlindungan Saksi dan Korban, yang selama ini pengaturannya masih bersifat sektoral, maka dengan adanya upaya untuk mengaturnya secara khusus dalam satu undang-undang boleh dikatakan sebagai langkah maju dalam rangka perlindungan terhadap korban, dan itu sesuai dengan amanat yang telah diletakkan dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan, sesuai pula dengan kesepakatan masyarakat internasional sebagaimana tercermin dalam *The United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dapat dilihat dalam bagian konsideran huruf a dan b, sebagai berikut.

a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam rangka menemukan dan mencari kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
b. bahwa penegak hukum dalam menemukan dan mencari kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Berdasarkan konsideran tersebut, yang merupakan semangat dibuatnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 menunjukkan bahwa pembuat undang-undang berkehendak menempatkan korban agar dapat ambil bagian dalam sistem peradilan pidana yang selama ini telah termarginalkan, dan itu sejalan dengan yang telah dikemukakan dalam *Guide for Policy Makers* dalam rangka Implementasi Deklarasi PBB mengenai *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1999: 1), bahwa *in modern criminal justice system*, korban kejahatan dan korban penyalahgunaan wewenang, maka apa yang menjadi haknya dapat dikatakan telah dilupakan orang.

Kendati telah ada upaya nyata untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban, akan tetapi yang masih perlu dipertanyakan apakah perlindungan korban yang terimplementasikan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 sesuai dengan konsep perlindungan korban. Pertanyaan ini mengemuka, karena apabila memerhatikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tampaknya pembuat Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 masih bias dalam memahami konsep tentang perlindungan korban dan kaitannya dengan akses korban dalam sitem peradilan pidana, sehingga apa yang telah dinyatakan dalam bagian konsideran tidak diimplementasikan secara konsisten dalam pasal-pasalnya.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dinyatakan: Korban dalam pelanggaran HAM yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana diamaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

a. bantuan medis; dan
b. bantuan rehabilitasi psikososial.

Pencantuman "pelanggaran HAM yang berat" dalam Pasal 6 itu, demikian juga dengan bentuk perlakuan yang berbeda dari korban kejahatan lainnya, sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b, barangkali tanpa disadari oleh pembuat UU bahwa apa yang diatur dalam Pasal 6 telah menanamkan adanya diskriminasi dalam memberikan perlindungan terhadap korban, termasuk

korban tindak pidana perdagangan orang. Apalagi dengan mencantumkan "pelanggaran HAM yang berat," yang sebelumnya tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan "pelanggaran HAM yang berat."

Dibandingkan dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dikemukakan bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM yang berat apabila melakukan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Bahkan dalam Pasal 8 ditentukan: Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

a. membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ditentukan bahwa: Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f. penyiksaan;
g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama,

jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

i. penghilangan orang secara paksa; atau

j. kejahatan apartheid.

Sedangkan apa yang telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006 masih tidak jelas kriterianya, tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat tersebut. Selain itu, perlindungan terhadap korban seharusnya diberikan kepada semua korban tanpa terkecuali, dan dalam Deklarasi PBB mengenai *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* dikemukakan, apa yang dimaksud dengan korban diberikan pengertian yang luas, yaitu seseorang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk fisik atau mental, emosional, kerugian secara ekonomis atau pelemahan (*impairment*) substansial terhadap hak-hak mendasar lainnya, baik dengan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional atau norma-norma yang diakui secara internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia (Handbook on Justice for Victims, 1999: iv). Sedangkan pengertian korban menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006: "korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."

Terkait dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tersebut, dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dikemukakan bahwa korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berhak mengajukan ke pengadilan, berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Adanya ketentuan demikian, selain tidak diatur kriteria mengenai pelanggaran HAM yang berat sebagaimana telah diuraikan di atas, juga pemberian kompensasi kepada korban yang dibebankan kepada negara, justru akan melemahkan tanggung jawab pelaku kepada korban. Di samping itu, dalam kondisi keuangan negara yang masih serba sulit, seharusnya tidak lagi menempatkan negara pada posisi *provider*, tapi sebagai fasilitator.

Sebagai bahan bandingan, dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, pada bagian yang mengatur mengenai *Compensation*, ditegaskan dalam Pasal 12 dan 13 yang menyebutkan:

1. Pasal 12: *When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to:*
   (a) *Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes*;
   (b) *The family, in particular dependents of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization*.
2. Pasal 13: *The establishment, strengthening and expansion of national funds for compensation to victims should be encouraged. Where appropriate, other funds may*

also be established for this purpose, including in those cases where the State of which the victim is a national is not in a position to compensate the victim for the harm.

Berdasarkan ketentuan tersebut tampak, negara diposisikan sebagai fasilitator, dan terkait dengan pemberian kompensasi kepada korban, tetap menjadi tanggung jawab pelaku. Negara hanya sebagai penunjang, jadi bukan yang utama.

Selanjutnya, di samping mengatur mengenai kompensasi, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, juga mengatur mengenai restitusi dari pelaku kepada korban, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b. Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berhak mengajukan ke pengadilan, berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Adanya ketentuan itu merupakan implementasi dari konsep bahwa pelaku juga harus bertanggung jawab kepada korban sebagai wujud dari ide perlindungan yang berorientasi kepada korban nyata. Pencantuman ketentuan seperti itu, sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yang telah mengatur pemberian restitusi dari pelaku kepada korban, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 11 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 8: *Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights*.
2. Pasal 9: *Governments should review their practices, regulations and laws to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanctions*.
3. Pasal 10: *In cases of substantial harm to the environment, restitution, if ordered, should include, as far as possible, restoration of the environment, reconstruction of the infrastructure, replacement of community facilities and reimbursement of the expenses of relocation, whenever such harm results in the dislocation of a community*.
4. Pasal 11: *Where public officials or other agents acting in an official or quasi-official capacity have violated national criminal laws, the victim should receive restitution from the State whose officials or agents were responsible for the harm inflicted. In cases where the Government under whose authority the victimizing act or omission occurred is no longer in existence, the State or Government successor in title should provide restitution to the victims*.

Namun demikian, kendati Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 telah mengatur adanya tanggung jawab pelaku terhadap korban, akan tetapi suatu hal yang perlu dipertanyakan: bagaimana jika pengadilan

telah memutuskan bahwa pelaku wajib memberikan restitusi kepada korban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) ternyata kemudian tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi oleh pelaku. Dalam kaitan ini apakah ada ketentuan yang memberikan sanksi kepada pelaku tersebut. Jawabannya, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tidak mengatur mengenai hal itu. Dengan tidak adanya ketentuan dimaksud justru melemahkan apa yang sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b. Hal itu dapat ditelusuri pada ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam Bab V mulai dari Pasal 37 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, dan tidak satu pasal pun yang mencantumkan ancaman pidana kepada pelaku dimaksud. Pasal-pasal dimaksud, hanya mengatur sebagai berikut.

1. Pasal 37

   (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000,000,- (dua ratus juta rupiah).

   (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

   (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2. Pasal 38

   Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apa pun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

3. Pasal 39

   Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

4. Pasal 40

   Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikuranginya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Pasal 41

   Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

6. Pasal 42

   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

7. Pasal 43

   (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

   (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Selanjutnya, sebagai wujud dari adanya perlindungan langsung terhadap korban, dalam Deklarasi PBB mengenai *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* telah mengatur perlunya asistensi (*Assistance*) terhadap korban. Hal itu diatur dalam Pasal 14 sampai dengan 17:

1. Pasal 14: *Victims should receive the necessary material, medical, psychologycal and social assistance through governmental, voluntary, community-based and indigenous means*.

2. Pasal 15: *Victims should be informed of the availability of health and social services and other relevant assistance and be readily afforded access to them*.
3. Pasal 16: *Police, justice, health, social service and other personnel concerned should receive training to sensitize them to the needs of victims, and guidelines to ensure that they provide proper and prompt aid*.
4. Pasal 17: *In providing services and assistance to victims, attention should be given to those who have special needs because of the nature of the harm inflicted or because of factors such as those mentioned in paragraph 3 above*.

Ketentuan demikian, tidak dijumpai secara nyata dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 hanya mengatur mengenai kompensasi dan restitusi, sedangkan mengenai asistensi tidak diatur. Mengingat konsep perlindungan korban tidak hanya berorientasi pada *potensial victims*, tetapi juga pada *actual victims*, karena itu sebuah undang-undang yang mengatur perlindungan dimaksud secara komprehensif sangat diharapkan. Upaya yang dilakukan oleh pembuat UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebenarnya merupakan langkah yang positif dalam merespon lemahnya pengaturan perlindungan korban dalam perundang-undangan pidana, sehingga hak-hak korban sebagai bagian dari anggota masyarakat menjadi termarginalkan. Tetapi, apa yang sudah diatur dalam UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban itu, masih perlu ditinjau ulang, terlebih bila dikaitkan dengan *Deklarasi PBB mengenai Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang tidak hanya mengatur tentang kompensasi, tetapi juga restitusi dan asistensi kepada korban sebagai cerminan dari adanya perlindungan yang berorientasi kepada korban langsung.



Implementasi Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan korban, pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permasalahan hak asasi manusia, dan hak korban itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep hak asasi manusia. Karena itu, bila hak asasi manusia tersebut telah terancam atau diganggu, perlu adanya jaminan perlindungan hukum terhadap korban.

Dengan demikian, korban akibat kejahatan memang seharusnya dilindungi, sebab pada waktu korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, korban dapat menentukan besar-kecilnya ganti rugi itu. Namun, setelah segala bentuk *balas dendam* dan *ganti rugi* diambil alih oleh negara, maka peranan korban tidak diperhatikan lagi. Apalagi dengan adanya perkembangan pemikiran dalam hukum pidana, di mana perlunya pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Akibatnya, telah mengurangi perhatian negara

terhadap korban.[8] Dewasa ini telah terjadi perkembangan orientasi hukum pidana, jika semula hukum pidana berorientasi kepada perbuatan (*crime*) sasarannya adalah *prevention of crime*, selanjutnya kepada orang (*offender*) sasarannya adalah *treatment of offender*, kemudian berkembang kepada korban (*victims*) sasarannya adalah *treatment of victims*. Adanya perhatian terhadap korban, sesuai dengan perkembangan dewasa ini agar hukum pidana menghapuskan kesan seolah-olah hanya memanjakan pelaku ketimbang korban.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang merujuk kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 pada dasarnya merupakan upaya penyapaan antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya (harmonisasi undang-undang secara horizontal). Karena dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, telah diatur mengenai perlindungan saksi dan korban dalam satu undang-undang, yang selama ini khusus pengaturan hak korban sifatnya masih sektoral dalam beberapa undang-undang, dan itu apabila ditelusuri lebih lanjut bahwa apa yang menjadi hak ternyata bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk mendapatkannya, sehingga yang terjadi: dari imperatif menjadi fakultatif.

Di beberapa negara, kepedulian terhadap nasib korban telah tumbuh begitu meyakinkan, yaitu sehubungan dengan adanya bentuk pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana. Perhatian terhadap nasib korban sesuai dengan keinginan masyarakat internasional, yang ditandai dengan diselenggarakannya Kongres PBB di Caracas, Venezuela, tahun 1980. Komisi PBB mengenai *Crime Prevention and Treatment of Offenders* berpendapat bahwa pada Kongres PBB ke VII yang diadakan di Milan tahun 1985 harus membahas permasalahan korban kejahatan, yang meliputi baik korban kejahatan konvensional, seperti kekerasan terhadap orang maupun juga korban berbagai penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan ekonomi dan politik, kejahatan terorganisasi, diskriminasi dan eksploitasi, dan memberikan perhatian khusus terutama sekali terhadap golongan-golongan penduduk yang rentan, seperti anak-anak, wanita, dan etnik minoritas.[9] Dan, sesuai dengan hasil Kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan dikemukakan: hak-hak korban seyogianya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Dalam kaitan ini, Joanna Shapland, dan kawan-kawan[10] pernah mengingatkan bahwa korban kejahatan sudah dilupakan orang dari sistem peradilan pidana. Kurangnya perhatian yang diberikan terhadap korban, justru akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana.

---

[8]Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 75-76.

[9]Paul Zvonimir Separovic, *Victimology Studies of Victims,* Samobor-Novaki bb Pravni Fakultet, Zagreb, 1985, hlm. 43, 425-426.

[10]Joanna Shapland, Jon Willmore dan Peter Duff, *Victims in the Criminal Justice System, Gower,* England, 1985, hlm. 1.

Sehubungan dengan hal itu, J.J.M. van Dijk, dan kawan-kawan[11] menulis bahwa pada paro pertama abad ke-20 ilmu hukum pidana hampir tidak memerhatikan sama sekali kedudukan si korban. Demikian juga dengan kriminologi, selalu diarahkan kepada si pelaku. Perkembangannya, baru pada 60-an muncul sejumlah perhatian kepada pihak yang dirugikan. Dengan maksud, agar penderitaan yang menjadi beban si korban agak diperlunak. Kemudian, sekitar tahun 1980, di banyak negara terjadi kelompok-kelompok aksi yang mengadakan kampanye untuk memperlakukan korban lebih baik dalam sistem peradilan pidana, dan para kriminolog yang berorientasi pada korban, ternyata memberi dukungan bagi upaya tersebut.

Perkembangan perhatian terhadap korban tersebut menunjukkan, bahwa masalah korban sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sudah seharusnya mendapat perhatian. Merespons hasil kongres PBB tersebut (sebagai bandingan), Komisi Eropa (*European Commission*, 1999: 2) menyatakan bahwa dalam suatu era kemerdekaan, keadilan dan keamanan dalam lingkup Uni Eropa, harus ada jaminan atas warga negara Eropa untuk dapat akses dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, individu-individu harus dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Hal itu penting, sebab hak-hak korban kejahatan sudah begitu lama diabaikan, dan sekarang waktunya untuk lebih memberikan perhatian terhadap hak-hak korban dimaksud. Upaya ke arah perlindungan terhadap korban kejahatan, sebenarnya telah dilakukan sejak awal 1980-an, di mana Dewan Eropa mengadopsi beberapa instrumen internasional dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan korban kejahatan di Uni Eropa. Langkah lanjut dari upaya tersebut, dalam beberapa kesempatan telah dibicarakan di Parlemen Eropa. Pada 1998, masalah perlindungan korban kejahatan dibicarakan di Dewan Uni Eropa, dan hasilnya korban kejahatan dimasukkan dalam *Action Plan on Freedom, Security and Justice*.

Deklarasi PBB mengenai Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power itu sendiri telah diadopsi oleh Majelis Umum tanggal 29 November 1985 (*General Assembly Resolution* 40/34), dan itu mencerminkan adanya kemauan kolektif masyarakat internasional untuk memulihkan keseimbangan antara hak-hak fundamental tersangka dan pelaku, dan hak-hak dan kepentingan korban. Adanya deklarasi tersebut didasarkan atas suatu filosofis bahwa korban harus diakui dan diperlakukan secara memadai atas dasar kemanusiaan. Karena itu, korban berhak akses terhadap mekanisme pengadilan dan memberikan ganti rugi yang tepat terhadap kerugian yang dideritanya. Di samping itu, korban juga berhak untuk menerima bantuan khusus yang memadai yang berkaitan dengan trauma emosional dan masalah-masalah lain yang disebabkan oleh terjadinya penderitaan yang menimpa diri korban.

---

[11]J.J.M. van Dijk, H.I. Sagel-Grande, dan L.G. Toornvliet, *Kriminologi Aktual,* Alih Bahasa P. Soemitro, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1999), hlm. 289.

Perhatian atau kepedulian terhadap korban kejahatan, seharusnya tidak terbatas pada korban kejahatan konvensional (perampokan, perkosaan, pencurian, dan yang sejenis lainnya), tetapi juga harus mencakup korban kejahatan nonkonvensional, di antaranya korban tindak pidana perdagangan orang.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa adanya perkembangan perhatian terhadap korban kejahatan pada dasarnya sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara hak-hak fundamental tersangka dan pelaku, dan hak-hak dan kepentingan korban. Untuk itu, maka konsep mengenai perlindungan terhadap korban pun harus jelas. Dalam arti harus ditetapkan terlebih dahulu arah atau cakupan dari perlindungan dimaksud.

Untuk membangun konsep perlindungan terhadap korban yang komprehensif, maka perlu dikaitkan dengan konsep pemidanaan sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief[12] bahwa konsep pemidanaan harus bertolak dari keseimbangan antara dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu, sehingga melahirkan konsep *Daad-dader Strafrecht*. Namun, perlindungan individu tersebut menurut saya harus pula diperluas ruang lingkupnya, tidak hanya pada *offenders oriented* tetapi juga pada *victims oriented*. *Victims oriented* ini pun diperluas lagi, tidak hanya berorientasi pada *potential victims*, tetapi juga pada *actual victims* atau *direct victims*. Karena itu, konsep *Daad-dader Strafrecht* yang terimplementasi dalam Pasal 11 RUU KUHP 2008[13] sudah seharusnya ditinjau ulang dan dikembangkan dengan konsep *Daad-dader-slachtoffer Strafrecht*. Dengan demikian, pihak korban tidak lagi termarginalkan dalam hukum pidana. Karena itu, keseimbangan dan kesetaraan perlu dibangun dalam hukum pidana ke depan.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 telah mencantumkan perlindungan hukum terhadap korban nyata atau korban langsung, yaitu sebagaimana terimplementasi dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55. Khusus mengenai tanggung jawab pelaku terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50.

1. Pasal 48
   (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
   (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
      a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
      b. penderitaan;

---

[12]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 98.

[13]Penjelasan Pasal 11 antara lain menyebutkan: Hukum pidana Indonesia didasarkan pada perbuatan dan pembuat tindak pidananya (*daad-dader-strafrecht*) dan atas dasar inilah dibangun asas legalitas dan asas kesalahan.

c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

2. Pasal 49

(1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

(2) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

(3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

3. Pasal 50

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 angka (6) korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.

(3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 hari, pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.

(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun.

Ketentuan yang tercantum dalam Bab V Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban sudah cukup baik, dan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 bahwa pada prinsipnya perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang mengacu kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, karena memang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 hanya menentukan: korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Jadi, sifatnya umum. Dan, tidak ada ketentuan yang sifatnya memaksa kepada si pelaku jika ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tidak diindahkan. Hal itu justru melemahkan apa yang sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2006.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 sudah banyak menunjukkan kemajuan berarti, terlebih yang menyangkut tanggung jawab pelaku kepada korban, akan tetapi jika memerhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 timbul masalah, karena yang dapat dijatuhi pidana yang sifatnya badaniah (kurungan) hanyalah orang atau manusia, dan dalam konteks ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang dapat dijatuhi pidana adalah para pengurusnya, tetapi bagaimana dengan badan hukum atau korporasinya? Padahal sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menentukan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi. Dengan demikian, suatu kemustahilan jika korporasi akan dijatuhi pidana kurungan pengganti.

Berdasarkan temuan ini menunjukkan, bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mempunyai kelemahan dalam upaya memaksa korporasi untuk memenuhi kewajibannya atas korban akibat dari tindak pidana perdagangan orang yang telah dilakukannya. Di samping itu, juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam perumusan subjek hukum tindak pidana perdagangan orang. Tampaknya, pembentuk undang-undang sudah terpola dengan pemikiran lama (seperti dalam KUHP) bahwa subjek hukum pidana adalah orang perseorangan.

Untuk yang akan datang, pidana terhadap korporasi sudah seharusnya perlu dikembangkan dengan alternatif-alternatif sanksi lainnya yang selama ini selalu mengandalkan pidana denda. Karena itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 melalui Pasal 15 ayat (2)-nya, telah mengatur: selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha;
b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
c. pencabutan status badan hukum;

d. pemecatan pengurus; dan/atau
e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Namun demikian, di antara sanksi-sanksi tersebut yang mungkin sulit untuk dilaksanakan adalah ketentuan yang tercantum pada huruf a dan huruf b (Pencabutan izin usaha dan Pencabutan status badan hukum), karena menyangkut kemungkinan pemecatan atau PHK terhadap tenaga kerja. Hal itu perlu dipikirkan lebih lanjut. Di samping itu, ke depan perlu mempertimbangkan sanksi yang berupa publisitas dalam upaya pembaruan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, dengan begitu akan tercakup aspek general prevensi dan special prevensi.

Mengingat konsep perlindungan korban tidak hanya berorientasi pada *potensial victims*, tetapi juga pada *actual victims*, karena itu apa yang sudah diatur dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sudah lebih maju dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya (kendati sebagai cacatan masih bermasalah pada ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007). Misalnya, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30) tanggal 17 April 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108) tanggal 13 Oktober 2003. Dalam undang-undang itu, tidak ada ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap korban aktual. Ambil contoh, ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang ditujukan kepada korporasi, tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan tentang kewajiban korporasi untuk memberikan ganti kerugian kepada korban yang menderita akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Misalnya, dalam hal pencucian uang harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana penyelundupan tenaga kerja.

Menurut Schafer, bahwa ganti rugi kepada korban seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi pelaku, tanggung jawab itu pada dasarnya juga merupakan bagian dari proses pemasyarakatan. Berdasarkan sudut pandang ini, restitusi tidak semata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan itu (korban), akan tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkan kembali dan rehabilitasi si pelaku, dan itu bagian dari pemidanaan.[14]

Dengan demikian, sebagaimana ditulis oleh J.J.M. van Dijk, dan kawan-kawan.[15] bahwa untuk menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban, maka pidana merupakan bantuan bagi penyelesaian konflik tersebut, karena pidana

[14]M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan,* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 213.

[15]J.J.M. van Dijk, H.I. Sagel-Grande, dan L.G. Toornvliet, *Kriminologi Aktual,* Alih Bahasa P. Soemitro, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1999).

dapat menjadi pemuasan bagi korban. Penyelesaian konflik sepenuhnya antara pelaku dan korban dalam tindak pidana yang menimbulkan kerugian tergantung dari sejauh mana kerugian itu pada akhirnya diganti atau dipenuhi.



Penutup

Perdagangan orang penyebarannya tidak lagi terbatas pada skala lokal nasional, tetapi juga sudah mendunia, bahkan dalam perkembangannya telah dimasukkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Mengingat dampak atau korban yang ditimbulkan cukup besar, maka pelakunya atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pun diperluas.

Perluasan pengaturan mengenai subjek hukum pidana, tidak lagi terbatas pada orang perorangan, tetapi juga korporasi. Bahkan, ketika Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU), kelompok (*group*) dimasukkan sebagai subjek hukum. Pengaturan kelompok orang terorganisasi tersebut dalam RUU, mencerminkan bahwa tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dilepaskan dari kejahatan terorganisasi sebagaimana telah diatur dalam Protokol PBB mengenai *Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children*. Akan tetapi, setelah RUU disahkan menjadi undang-undang, subjek hukum: kelompok orang, dihilangkan.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah berkolaborasi dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Namun demikian, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang dirujuk oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 masih belum cukup komprehensif dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

Ide perlindungan hukum terhadap korban yang berorientasi baik pada *potential victims* maupun *actual victims*, sudah terimplementasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan itu sesuai dengan ide keseimbangan: *Daad-dader-slachtoffer-strafrecht*. Kendati ada gangguan sehubungan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (4). Karena itu, baik Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 maupun Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 sudah seharusnya ditinjau ulang untuk diperbaiki.

12

THE RESURRECTION OF ISLAMIC LAW IN ITS EXISTENCE IN THE INDONESIA LEGAL SYSTEM

Oleh:
Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.*

Introduction

The existence of Islamic Law in Indonesia often becomes discussion and debating. It relates to the contra opinion toward the concept and effort of becoming Indonesia as Islamic state. Everybody knows that Indonesia has unity in diversity in tribes and religion. That is why, the founding fathers of Indonesia wanted this country not purely based on particular religion but confess the God and Religion in the government and ruling society. This country allows the citizen to implement the law and norm of the religion. Therefore, we can find the rules which are based on the rules of religion such as marriage law and inheritance law which is Islamic law. Those rules have been implemented before the independence of Indonesia. It means that to implement the norm of Islamic law must not be in the form of Islamic state. Indonesia has been proven to be able to put the Islamic law as the part of legal system without changing the form of this country becoming Islamic law.

Statement of The Problems

Based on the explanation above, we can describe the statement of the problems as the following:

1. How is the existence of the theory and the enactment concerning the implementation of Islamic Law in Indonesia?
2. How is the implementation of Islamic Law in Indonesia as the impact of the extension authority of court?

---

*Guru Besar di Fakultas Hukum Unair Surabaya.



Discussion And Analysis

Islamic law has become the part of the Indonesia legal system. That is why, we often hear a question relates to the implementation of Islamic Law in Indonesia whether Indonesia is a country based on religion or not. First, to answer the question, let us see the article 29 item (1), 1945 Constitution of The Republic of Indonesia which is said that "*Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa*." It means that Indonesia admits the existence of religion and the rules written in the holy book. However, this country is not based on a particular religion. It protects religions and gives right to the citizen to pray as the rules of their religion. Thus, Islamic Law, as one of the religion protected by the government, can be applied and integrated into the Indonesia legal system.[1] It also can be proven by the regulation which derived from Islamic law. Marriage Act Number 1/1974 said that marriage is legitimate based on the rule of the religion obeyed by the persons themselves.[2] Thus, the marriage of persons can be legitimized if it holds based on procedure which is ruled by religion. If the persons who want to marry are Moslem, they have to hold *akad nikah* as procedure of marriage as ruled by Islamic law. That is way, the religion law included here Islamic law is entitled in the matter of marriage legalized. Then, Judicial Power Act Number 14/1970 juncto Judicial Power Act 4/2004 divide the power into four parts, one of them is Syariah Court. The legislation is broken down into Syariah Court Act Number 7/1989 *junto* Syariah Court Act umber 3/2006 about which confesses Islamic personal principle. It provides absolute competence to Syariah Court to handle the specified civil cases, which include Moslem as a subject, namely marriage, inheritance, gift, testament, *wakaf, zakat, infaq, shodaqah, syariah* economic. Thus, this legislation is as a formal law to imply material law, such as Marriage Act number 1/1974, Banking Act Number 10/1998 which rules also about syariah banking, Pilgrimage Organizer Act Number 17/1999, Zakat Act Number 36/1999 about and Wakaf Act Number 41/2004.[3] Besides, we can also find Islamic Law Compilation. Islamic Law Compilation is a guidance for judge in Syariah Court to decide the marital, inheritance and *wakaf* case. For the time being, Islamic economy law has been growing up in Indonesia. We can see the development of economic syariah institution in the field of Banking, mortgage, insurance, financing, capital market and cooperation (Baitul Maal wa Tamwil).[4] The legislative body

---

[1]Afdol. 2003. *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Airlangga University Press. Page 20.

[2]*Ibid*. Page. 20.

[3]Afdol. 2006. Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press. Page 25.

[4]Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Jakarta: Ekonisia. *Passim*.

is preparing to arrange the legislation for syariah banking and syariah obligation in order to support syariah investment in Indonesia. Thus, from the explanation above, we can conclude that Islamic law has been integrated into the Indonesia legal system.

Second, let us compare the rules contained in Burgerlijk Wetboek and Islamic Law. We will find that there are several rules seem identical to Islamic Law. For instance, the rule of *muqashah* in Islamic Law is similar to the rule of compensation in Burgerlijk Wetboek. That is why; he tries to explore the history of Burgerlijk Wetboek. Burgerlijk Wetboek is originated from *Code Civil* of Napoleon Bonaparte. The Code Civil has two sources namely Rome Law and Islamic Law. Rome Law is acknowledged as *Codex Justinian's* or *Justinian Corpus Juries Civilis*. Those rules, which derived from Islamic law, sources from Islamic Fiqh written by Abdullah As-Syargawi (1737-1812 M). When Napoleon occupied Egypt, he asked Syargawi, who was also known as Syaikhul Azhar, to help French Team namely Portalis, Trouchet, Bigot de Preameneu, and Melleville to form *Code Civil*. Therefore, we may find several items in Civil Law Book (BW) which seems identical to Islamic Law. If we find the items which may be in contrast with Islamic Law, it means that the item originated from Rome Law. Because Rome Law has different norm from Islamic Law, especially connected with the status of Women toward men, dowry, adoption, reposition of debt, obligation to pay inheritance's billabilities. The social status of Women Rome was under the men one. They did not have a right to hold transactions concerned their property without their husband permission. Adoption gave the all similar right of the adoption child to the natural child. Reposition of debt could not be allowed. The debt of the deceased must be paid by the heir. On the contrary, Islamic law gives the whole rights for women to hold any kinds of transaction; dowry is gift for women and belongs to the women. Adoption child will not obtain heritage from the parent, he may only get testimony maximally 1/3 of the heritage and not more than the right of the natural child. Reposition of debt can be done and the deft of the heir must be paid only as much as his heritage, if the debt is more than the heritage, the family should not be paid the debt more than it.[5]

Third, Let us try to discuss about the source of Islamic law and the relevance of *Al-Ahkam Al-Khamsah* in order to establish the truth and justice. The source of Islamic law is Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad. Al-Quran is the holy book of Islam. There are about 228 items in Al-Quran which contains enactment. It consists of 70 items of the family law (marriage and heritage), 70 items of agreement law, 10 items of economic law, 30 items of penal law, 10 items of government law, 25 items of international law, and 13 items of procedural law.

[5]Afdol. 2003. *op.cit.*, Page. 17

As-Sunnah or Al-Hadits is all statement, behavior, and attitude of the prophet Muhammad SAW. Al-Hadits becomes a more explanation from the prophet of Muhammad concerned the rule contained in Al-Quran. Ijtihad is the result of human being mind exploration to interpret and understand the fundamental norm of Al-Quran, general norm contained in As-Sunnah to justify specific case which is not clearly ruled in Al-Quran and As-Sunnah.

Islamic Law categorizes the basic norm contained in Al-Quran, As-Sunnah and Ijtihad into five namely *"Fardlu, Sunnah, Mubah, Makruh, Haram"* which is called *Al-Ahkam Al-Kamsah*.[6] One case can be obtained different norm. For instance, the basic law of marriage in Islamic Law is *mubah/halal* (something that is allowed to do). However, if someone has the ability of marriage connected with the maturity of mental and thinking, prospective carrier, the norm of marriage may be *sunnah* (something that we do, we have prize to the god but if we do not do we have no sin). Later, if someone has all the sufficiency to marriage and he also tends to attract his opposite sex, the norm becomes Fardlu (something that we must do it). If we do not do it, we may get sin). On the contrary, if someone has a willing to marriage but he has not been ready enough connected to the mental and the economical sufficiency so the norm changes to be *Makruh* (Something if we do it, The God does not like it). Moreover, if someone wants to marry only for sexual abuse motivation, the norm becomes *haram* (something if we do, if we get sin).

Based on the five norms which are flexible, human is expected to think before do something. Because one case may obtain different norm connected with the wish of somebody. The concept of *Al-Ahkam Al-Khamsah* in order to establish the truth and justice. In fact, several lawyers tend to defend their client by allowing all way. To defend a client basically is mubah. Everybody has a right to be defended based on the presumption of innocence. It becomes fardlu, if the client is in the position to be slandered so the lawyer must defend him although he is a poor man who can pay sufficiently. However, if the corruptor wants to be his client, it is better to avoid the case. Because, corruption is *haram* so to defend the case may be *haram* or at least *makruh* based on Islamic Law. If a Moslem lawyer is compelled to accept the case, what he must explore the real fact of the case position. He is not allowed to cover up moreover to manipulate the truth. As a lawyer, his job is only to make sure that the rights of the client as the defendant has been fulfilled. Briefly, if the concept *Al-Ahkam Al-Khamsah* is applied in all fields in the court, justice may be established. The truth will be found, there is no force, manipulation, and bribery.

In the daily life, We can give simple explanation how the implementation of al-*ahkam al-khamsah*. Mubah means permission, as students of law faculty

[6]Hasbi. Ash-Shiddieqy. 1980. *Pengantar Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang.

for instance, they can choose concentration of study whether it is civil law, criminal law, or government law. The others example, when Moslem pray together (*sholat berjamaah)*, It is suggested (*Sunnah*) to pray on time, in the first line or forward line and uses a clean, good and tidy cloth. It can be applied in the daily life when we go to work or to school, campus, we should arrive on time, sit in the first or forward line in the lecturer, and use an appropriate shirt. Smoking is categorized as Makruh in Islamic Law, thus as Moslem should avoid and/or leave the habit of smoking because Allah does not like this habit. However, there is case that is allowed (halal) to be done but Allah hates it namely divorce. Divorce is not prohibited in Islamic Law but it should be Avoid because Allah hates it. Marriage should be kept to be binding however if it causes a worst (*mudlarat*) and divorce is an alternative way to get live better outside marriage, divorce can be allowed. Fardlu is something that must to do such as praying five times. In the implementation of legal area, the judges must give an appropriate decision to the person who prohibits the law. Lawyer, police, attorney must struggle the fairness and truth, and witness must be honest in his the testimony. [7]

Fourth, Let us explore the theories connected with the existence of Islamic Law in Indonesia. There are five theories which connected with the existence of Islamic Law in Indonesia, namely *receptio in complexu, receptie, receptie exit, reception a contrario* and *recoin (Receptio Contextual Interpretatio)*. *Receptio in complexu* theory said that Islamic law conducted totally for Moslems. As the effect, the Islamic rule had to be admitted wholly because they had confessed the religion though in fact, it could not be implemented well. Later, the theory had influenced the acceptance of Islamic law as integrated system in the society and colonial law (Dutch colony). This theory was found by L.W.C. Van Den Berg. He studied about the condition and culture of Indonesian. Then, he realized that most of Indonesian confessed Islam as their religion and influenced the norm of the society. This theory was used by the colony to get attention and sympathy from Indonesian. The government of colony then conducted Islamic Family Law and Islamic Inheritance Law. He obligated the judges from Dutch to master those laws. They are assisted by Islamic *qadli*. The government in this period also built Religion Court which had a competence to solve the case included Moslem based on Islamic Law. In the other words, it established Islamic Law as the part of legal system which was being built by the colony.[8]

Unfortunately, this period was over because of the criticism from Cornelis Van Volenhoven. He was known as the who took the base of Adat Law. He criticized the effort of Dutch to change Indonesian Adat Law into Europe Law as the attempt of church missionary to expand the influence of Christian. The

[7]Afdol. 2006. *op.cit*. page. 30.
[8]Afdol. 2006. *Ibid*. page. 40-50.

other opinion was from Christian Snouck Hurgonje, a colony advisor concerned Islam and Native. He was employed by colonial government to study about customs and traditions in Islam in order to give advice for colonial rules. Its objective was to dominate the majority of Moslem population and to estrange them to Islamic teaching. Hurgronje studied Islam, Arabic and went to Mecca on a pilgrimage. Later, he conducted the study of the implementations the syariah in Aceh. He found that in general Indonesian took a religious person became the figure of life. Then, he changed his performance to be a religious person and began introducing his theory which aimed is to reduce the influence of Islamic Law. He used the method of divide and rules (*devide et impera*). Hurgonje recommended three policies to Dutch Government. They are turning Moslems into heretics, implementing *adat law by* confining that adat law was the original norm of Indonesian, and determining Islamic activity is restricted only in the mosque.[9] As the impact, Adat or tradition had been emphasized instead of Islamic law. In the legal system, Islamic Law can be conducted if the Adat law allowed it. He suggested to the Dutch government to give policy for the implementation of Islamic Law like these: In the ritual, Dutch government should give the freedom for Moslem to do the ritual pray and never prohibit them because they will fight for it. In the social side, Dutch government should socialize and support the growth of adat and reduce the Islamic culture influence. In governmental side, there must be an effort to prevent the power of *Pan Islamism* which aimed to opposite the colony. Later in legal area, Dutch government did not include *hudud* and *qishash* as a part of penal crimes. The criminal sanction derived from *Wetbook van Straftrecht* (Criminal Law Book). Dutch also avoided Moslem from the discussion of Al-Quran which contained political problem, and prohibited the teaching of book which explained governmental law in Islamic perspective. In *muamalah*, it was restricted only the implementation of marriage law and in heritage law could only be applied if adapt law allowed it. As the effect, the authority of Religion Court of Java, Madura and South Borneo was prohibited to examine the heritage case. By the receptie theory, it arose assumption that native would think that they had appreciated culture as Europe one and it would prevent the clash from the grass root.[10]

The rejection of the *receptie* theory was stated by Hazairin. He said that *receptie theory is a devil theory*. He has an opinion that after Indonesia becomes independent country, the receptie theory had been broken, must not be conducted anymore and must exit from the constitution and governmental policy of Indonesia since Indonesia declared the independency in 1945 and 1945 Republic of Indonesia Constitution become the basic law of Indonesia. As the rule stated in article 29 item (1) 1945 Republic of Indonesia Constitution,

[9]Sofia Rangkuti, Hasibuan. 1999. *English for Specific Purposes: Law*. Jakarta: Djambatan.
[10]Afdol. 2006. *op.cit*. page. 60-65.

Indonesia has obligation to form national legal system which sourced from religion norm. The norm of religion which is integrated in Indonesia national legal system is not only Islamic law but also the all religion norms which are protected by the Indonesia government and binds the confessor. The religion rules in the civil and crime area can be absorbed in to Indonesia national legal system that is really new legal system of Indonesia which based on Pancasila.

The identical theory arouse later namely Receptio a Contrario. It contradicts with receptie theory. This theory is the developing idea which derived from receptie exit theory stated by Sayuti Thalib. It said that for Moslem conducted Islamic Law. It is appropriate with the confession, legal spiritual and moral aim. Adat law can be conducted if there is no contradiction with Islamic Law.[11]

The different between receptie exit theory and receptio a contrario one is the way of getting idea. Receptie theory tends to be normative. It occurs based on the fact that Inonesia is a independent country and has 1945 Republic of Indonesia Constitution which the paragraph three of the preface admit Indonesia stand by the bless of God and religion become basic norm of the county as stated in article 29 and the spirit of article II transition rule which has to be understand comprehensively. However, the receptio a contrario one based on the thought that Indonesia is as independent country is in harmony with the legal spiritual and moral aim and legal awareness thus means that there must be a freedom to accomplish the religion law.

The last one is Recoin (Receptio Contextual Interpretario) theory.[12] It continues the previous theory which supports the conduct of Islamic Law. This theory tries to see the implementation of Islamic law especially in inheritance law, by applying textual interpretation. It is found that empirically persons who want to solve the heritage lease based on Islamic law is only 11,82%, the one, about 88,18%, goes to General Court to solve the case by Adat Law. It occurs based the assumption that if they solve based on Islamic Law, it may be an unfair, especially for women who only get a half of men. Based on the phenomenon, there must be contextual interpretation of the items of Al-Quran concerned the implementation of the inheritance law. There are three problems which needs contextual interpretation as the effect of the feeling of unfairness if they are only applied textually. The three problems are about substitute the position, adoption child, and the right of daughter compared by son. The problems concern substitution position and adoption child, actually it has been arranged in Islamic Compilation Law. Based on the fiqh, substitute position can be allowed in inheritance case, so that the child can substitute

[11]Afdol. 2006. *loc.cit*.

[12]Afdol. 2003. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil.* Surabaya: Airlangga University Press, page. 50.

the position of the parent in heritage if the heir has passed away. Adoption child can get testament maximal 1/3 of the heritage but not more then the part gotten by the natural child. The hottest issue concern heritage is the right of daughter compared by son in which daughter get a half compared by the son. By contextual interpretation, the comparison 2:1 can be interpreted as the part whish daughters get *minimal* a half of the sons. This is contextual interpretation which is called *recoin* theory. In the other word, daughter can get more than a half, if there is an agreement between sons and daughters. The judges should give advice to solve the problem by discussion in order to get fairness and the daughters may get the same right as sons. By socializing this theory it is expected to be able to increase the will of Muslim to solve the heritage case based on Islamic law in Religion Court.

Lastly, Let us discuss the authority of the religion court especially in the field of syariah economy which is regulated in Syariah Court Act Number 3/2006. It is the extension of authority which did not arrange in Syariah Court Number 7/1989. Syariah economy here refers to the agreement which hold based on syariah principle such as profit and lost sharing principle which is applied in the agreement of *Musyarakah* (project financing participation), *Mudharabah* ((trust financing), *muzara'ah* (harvest-yield profit sharing), *musaqah* (Plantation Management Fee based on Certain Portion of Yield). The principle of sale and purchase is implemented in the agreement of *Murabahah* (Deferred Payment Sale), Bai As-Salam (In-front Payment Sale), Bai Al-Istishna (Purchase by order or Manufacturer). The principle of operational and financial lease principle is applied in *Ijarah* (operational lease) and *Ijarah Muntahabia bit Tamilk* (Financial Lease awith Purchase Option). Fee-Based Service would be applied in the agreement of *Wakalah* (Deputyship) and *Kafalah* (Guaranty), *Hawalah* (Transfer Service), *Rahn* (Mortgage), *Qordh* (Soft and Benevolent Loan). Those all principles are implemented in the area of Syariah Banking, Syariah Insurance, Syariah Stock, Syariah Obligation, Syariah Financing and Syariah Mortgage.[13] By this authority, the persons who has disputes with the Institutions which implemented syariah principle or hold agreement based on syariah principle can take the case on the religion court. Therefore, there are two alternative way in resolving the disputes, on Syariah Arbitration or Religion Court. As the impact, it will be supported the building of syariah economic and the development of Islamic law in Indonesia.

[13]Muhammad Syafii Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press and Tazkia Cendikia.



Conclusion and Suggestion

Based on the explanation described above, we can conclude the discussion as the following:

1. Islamic law has become a part of Indonesia legal system. It is proven by the 1945 Indonesia Constitution which allows the citizen to implement the norm an d law of the religion and the enactment which is based on Islamic law in the field of civil affairs (marriage and inheritance) and economic affairs (banking, zakat, wakaf). Thus, we can summarize that to implement Islamic law must not be in the form of Islamic state however by the opportunity given by state to implement the rules of Islamic religion and regulated in enactments.
2. The Act No.3/2006 has given the extension of the authority for the Religion Court to resolve the dispute in economic syariah affairs (banking, insurance, mortgage, financing, cooperation which are operated based on syariah principles). It means that the syariah disputes have two alternative way to be resolved in litigation and non litigation. This law has supported the building of syariah economic and the development of Islamic law in Indonesia.

Finally, it is suggested that the Moslem must not be doubted to implement the Islamic law because it has become the part of Indonesia legal system and to resolve the civil and economic syariah disputes in litigation and non litigation. In the other hand, the government should completed the legislation toward the other syariah institution outside banking as they also need legitimacy. Finally, the building up of economic syariah needs Moslem's support. Let us provide for the growing up of economic syariah institution particularly and Islamic law generally.

References

Text books

Afdol. *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Per-masalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam.* Surabaya: Airlangga University Press. 2003.

————. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil.* Surabaya: Airlangga University Press, 2003.

————————. Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press. 2006.

Hasbi. Ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1980.

Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Jakarta: Ekonisia, 2003.

Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press and Tazkia Cendikia, 2001.

Sofia Rangkuti, Hasibuan. *English for Specific Purposes: Law*. Jakarta: Djambatan. 1999.

Enactments

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1945 Republic of Indonesia Constitution).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Marriage Act Number 1/1974).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Banking Act Number 7/1992).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Banking Act Number 10/1998).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji (Pilgrimage Act Number 17/1999).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Zakat (Zakat Act Number 36/1999).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power Act Number 4/2004).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Wakaf Act Number 41/2004).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. (Syariah Court Act Number 3/2006).

RAJAWALI PERS

Bagian Kedua

Mengantisipasi Kejahatan Sistematik

RAJAWALI PERS

13

MENUJU MASYARAKAT ANTI KORUPSI

Oleh:
*Prof. Dr. HM. Ali Mansyur, S.H., M.Hum.**



Pendahuluan

KORUPSI MERUPAKAN penyakit jiwa yang berupa keinginan untuk memiliki/menguasai harta yang tidak dibenarkan oleh norma/aturan. Dengan istilah lain, upaya meraih sesuatu dengan menghalalkan segala cara, tidak memerhatikan halal dan haram.

Perilaku korupsi bertentangan dengan norma apa pun dan di mana pun, korupsi boleh dikatakan sebagai penyakit, yang akan menjalar dan merasuki tubuh manusia apabila tidak dicegah atau diobati, membuat tubuh menjadi rusak, sakit, kurus dan akhirnya mati, karena digerogoti oleh penyakit tersebut.

Uang negara yang semestinya ditasyarufkan untuk kepentingan rakyat mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat yang merata, dengan korupsi uang negara tersebut *diselewengkan oleh orang yang punya jabatan/kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, atau kroninya/jamaahnya* sehingga porsi untuk kemakmuran dan keadilan rakyat tidak dapat diwujudkan.

Jika *perilaku korupsi* bukan lagi sebagai perbuatan dosa, tetapi sudah dianggap sebagai sesuatu *perbuatan yang lumrah, tidak berdosa, tidak dilarang agama, tidak bertentangan hukum maka korupsi akan menjadi suatu budaya "nauzubillah min dzalik."*

Jika demikian keadaannya, maka sudah terjadi degradasi nilai kemanusiaan, merosot jiwa kemanusiaannya dan kemungkaran akan merajalela serta manusia tidak mempedulikan lagi nilai ketuhanan.

---

*Guru Besar Hukum Perdata pada Fakultas Hukum UNISSULA dan Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Korupsi dapat digolongkan sebagai *perbuatan dholim*, karena mengambil hak orang lain dan perbuatan semacam itu sangat ditentang oleh Allah dan RasulNya, bahkan diancam dengan hukuman berat dihari kiamat.

Rasul bersabda:

"Barangsiapa mendzalimi (mengambil) tanah orang satu jengkal, maka pada hari kiamat Allah akan menimpakan kepadanya 7x lipat dari tanah yang diambilnya." (HR Buchori & Muslim).

Perbuatan *dholim* terjadi karena orang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya *(dislocation, disfunction)*, memunculkan ekses negatif adanya ketidakadilan, dan menyengsarakan orang lain.

Allah berfirman dalam S. Ibrahim ayat 42:

Dan janganlah kamu sekali-kali (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim, Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Korupsi menyengsarakan orang lain, memakan hak orang lain, melakukan khianat terhadap orang lain selamanya mereka tidak akan mendapatkan ketenangan dan keamanan di dunia, dan di akhirat akan mendapat azab yang berat. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas dan masing-masing kita ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan hal ini.

Ahli sejarah Inggris, Lord Acton mengatakan bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan manusia tanpa kecuali mempunyai kelemahan. Dia terkenal dengan ucapannya *"Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely."*



Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Moral, Mental, Tata Nilai, dan Pola Pikir

Rasulullah bersabda:

"Siapa saja di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, kalau tidak sanggup (dengan tangan) dengan lisan, jika tidak sanggup dengan lisan, ubahlah dengan hati. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya Iman."

Untuk mengoperasionalkan Hadis di atas, dapat ditempuh melalui dua cara yaitu: *Pendekatan Preventif, dan Pendekatan Kuratif.*

Pendekatan Preventif

1. Menyentuh Qolbu/Hati Nurani.

   Penyadaran *hati nurani* manusia, mengapa hati? Karena hati merupakan *Al-Lathaif al-rabbaniyah* (Sesuatu yang halus yang mempunyai sifat ketu-

hanan) yang mampu memberikan pertimbangan kepada akal untuk bertindak apakah perbuatan itu merugikan orang lain atau tidak, atau apakah suatu perbuatan merendahkan nilai kemanusiaan atau tidak. Hati akan selalu menunjukkan kepada jalan yang baik.

HR Imam Ahmad.

Mintalah fatwa pada dirimu, mintalah fatwa pada hatimu wahai wasibah (ibn Ma'ad al-aswadi) nabi mengulangi 3x. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa tenang dan membuat hati tenang dan dosa adalah sesuatu yang terasa tidak karuan dalam jiwa (rasa) dan bimbang dalam dada.

2. Kejujuran

Jujur adalah lawan dari bohong. Jujur yang dimaksud mencakup jujur dalam perkataan, sikap dan perbuatan. Kejujuran selain mendatangkan ketenangan dalam hati, juga mendatangkan kepercayaan orang lain kepada si pelaku kejujuran. Sebaliknya kebohongan hanya akan mendatangkan kegusaran dan ketidakpercayaan orang lain, sekali berbohong maka kita akan berbohong terus-menerus. Sebab untuk menutupi kebohongan yang telah kita lakukan, kita harus melakukan kebohongan berikutnya, begitu seterusnya sampai nanti akan dikenal sebagai pembohong.

Dalam hal ini syarat dalam pemilihan pemimpin harus jujur. Jika pemimpin jujur, Insya Allah rakyatnya juga jujur.

3. Jabatan sebagai Amanah

Hakikatnya jabatan itu adalah *ujian* (Amanah) bukan semata-mata "*Nikmat*" merupakan beban yang disampirkan di pundaknya untuk dipikul, ditunaikan dengan sebaik-baiknya.

Rasulullah bersabda: *Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancurannya. Pada saat itu salah seorang sahabat bertanya pada Rasul apa tanda-tandanya menyia-nyiakan amanat dalam memegang jabatan. Rasul menjawab: Jika suatu urusan/perkara diserahkan kepada bukan ahlinya tunggulah saat kehancurannya* (HR Imam Buchori).

Melakukan korupsi dalam kapasitas sebagai pejabat adalah mengingkari amanah dan menciderai amanah serta menyia-nyiakan amanah tidak mustahil kalau akan hancur kehidupan dan tidak barokah.

4. Keadilan

Menegakkan keadilan merupakan syarat mutlak menuju bebas korupsi, bentuk keadilan dapat diartikan penegakan hukum yang adil dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar (tegaknya hukum dan keadilan), juga menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan prinsip "*The Right man in the right place*" jika hal ini tidak dilakukan tunggulah saat kehancurannya.

"Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya."

Pendekatan Kuratif

Pemberantasan korupsi dilakukan melalui pendekatan kuratif, yaitu ditempuh melalui penegakan hukum *(law inforcement process)* dengan penerapan sanksi hukum bagi yang melakukan perbuatan korupsi (melanggar UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Dilihat dari segi pemberantasan kuratif, perlu dilakukan langkah aksi (tindakan) untuk memberantas korupsi yang telah terjadi melalui:

a. Menghentikan sikap permisif terhadap praktik korupsi mulai dari lingkungan terkecil (diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan seterusnya)
b. Melakukan kampanye (sosialisasi) bahaya korupsi terhadap kehidupan kepada masyarakat luas.
c. Melaporkan berbagai tindakan korupsi kepada pihak yang berwajib.
d. Memberi tekanan/dorongan kepada pihak berwajib untuk segera mengusut dengan cepat dan tuntas segala kasus korupsi serta memberikan hukuman yang seberat-beratnya, jika memang terbukti bersalah.

Mewujudkan negara tanpa korupsi tidaklah semudah membalik telapak tangan butuh perjuangan, proses dan semangat semua pihak terutama dimulai dari mentalitas, moral, tata nilai, dan pola pikir dari para pejabat teristimewa adalah para pemimpin, kemudian diikuti oleh anggota/rakyatnya.

Selanjutnya ingin saya kemukakan cuplikan paper Yasri Sulaiman dalam acara Koalisi Antarumat Beragama Anti Korupsi di Yogyakarta, yang mengutip pemberitaan tentang Presiden RRC Zhu Rongjie sebagai berikut:

1. Ketika dilantik sebagai Presiden RRC pada 1998, Zhu Rongjie menghadapi penyakit besar yang melanda rakyat Cina, baik dalam pemerintahan maupun di tubuh Partai Komunis Cina. Penyakit itu tidak lain adalah korupsi yang menyebar bagai virus di negara dengan penduduk terbesar di dunia. Dan Zhu bertekad memberantas korupsi dari lapis atas sampai bawah: sampai-sampai Zhu berucap: "Berikan kepada saya 100 peti mati; 99 untuk koruptor dan 1 lagi untuk saya jika melakukan hal yang sama."
2. Ucapan Zhu tidak main-main, selama 3 tahun pemerintahannya (2001), tidak kurang dari 4000 orang langsung ditembak mati di depan umum karena korupsi. Bahkan dalam kuartal pertama tahun 2003 lalu sebanyak 33.761 polisi Cina dipecat, karena beberapa alasan: menerima suap, mabuk-mabukan, berjudi, membawa senjata api di luar tugas, dan kualitas SDM di bawah Standar.
3. Sejak korupsi diberantas, Cina berhasil mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi hingga 10.7% per tahun. Angka pertumbuhan ekonomi yang spektakuler dan belum pernah dicapai oleh negara mana pun di dunia.



Menjauhkan Diri dari Kemungkaran

Mengapa kemungkaran kian hari semakin merajalela dan bagaimana usaha kita untuk menjauhinya? Kemungkaran adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt., bertentangan dengan aturan Allah dan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, jika dilakukan akan merugikan orang lain dan juga diri kita sendiri, namun sama sekali tidak akan merugikan Allah sedikit pun.

Manusia mengetahui dan memahami kalau perbuatan mungkar, *fakhsya'*, tidak terpuji merugikan diri sendiri, tetapi anehnya kebanyakan kita terkadang tidak menyadari perbuatan tersebut dilarang oleh agama, bahkan lebih ngeri lagi melakukan pembenaran perbuatan mungkar seolah-olah merupakan perbuatan baik. Untuk itu dibutuhkan kesungguhan diri untuk menumbuhkan kesadaran menjauhkan kemungkaran (korupsi) pada setiap medan kesempatan, lingkungan yang akan membuat terjerumusnya diri kita kepada kemungkaran.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imron ayat 104, yang artinya: *"Hendaknya ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah perbuatan mungkar dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."*

Dari ayat tersebut di atas, Allah menyebut ciri orang yang beruntung antara lain:

1. Orang yang mau menyeru kepada kebaikan
2. Orang yang mau menyuruh kepada yang ma'ruf
3. Orang yang mau mencegah kepada kemungkaran.

Kriteria di atas, terdapat tiga ungkapan kata yang perlu mendapat perhatian yakni: menyeru, menyuruh, dan mencegah. Untuk mewujudkan tiga ungkapan di atas, tidak akan mungkin dapat dilaksanakan jika tidak dibarengi dengan tiga hal pula yakni: kemauan, kemampuan, dan persanguan. Di samping itu, harus berani menanggung risiko, dan sebagian manusia takut risiko.

Kemauan hanya muncul jika orang tersebut mempunyai mental, moral, kemampuan berani bertindak, yang tentu harus dilandasi oleh tata nilai yang diyakini dan memiliki jangkauan berpikir yang sistematis dan rasional. Itulah sebabnya tidak heran jika kemungkaran dari waktu ke waktu semakin menjadi-jadi dan susah untuk memberantasnya. Ibarat penyakit, dokter yang memberi obat kepada pasien yang tidak didiagnosis dulu penyebab penyakitnya. Sehingga penyakit tidak kunjung sembuh. Dengan istilah lain kalau ingin mencegah kemungkaran (korupsi), terlebih dahulu harus dicari penyebab dari munculnya korupsi itu. Korupsi merupakan antitesis, untuk mencari pemberantasan korupsi (merupakan sintesis), maka terlebih dahulu harus diketahui tesisnya.

Adapun tesisnya adalah:

1. Kesempatan/Peluang/Keadaan.
   - Kesempatan merupakan biang kerok munculnya perilaku korupsi.
   - Pada awalnya orang tidak punya niat untuk korupsi, tetapi karena ada peluang dan tidak diketahui oleh orang lain, maka nafsunya tergoda. Hati tidak mampu menangkal, tidak mampu melawan, jadilah perbuatan jahat itu dilakukan.
   - Tidak ada kesempatan/peluang untuk melakukan korupsi.
2. Niat

   Niat dalam arti umum dapat diartikan rencana/program yang ada dalam hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan, dorongan untuk melakukan perbuatan. Kesempatan ada namun tidak ada niat, perbuatan tidak akan jadi terlaksana. Bagaimana membatasi niat agar tidak mengembara menuju yang tidak berguna, dalam hal ini kontrol hati manusia sendiri yang dapat menjawabnya.
3. Iman kepada Allah Swt.

   Iman yang rendah kepada Allah hampir pasti membuat manusia hilang rasa takutnya kepada Allah Swt., manusia tidak membayangkan akan adanya dosa, jika ia berbuat salah dan melanggar larangan Allah Swt. Dia lupa kalau dipundaknya terdapat dua malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat seluruh amal perbuatannya sehingga ia berani melakukan kejahatan dan penyimpangan sebab tidak ada lagi yang ditakuti dan merasa tidak ada yang mengawasi. Karena itu, di sinilah Iman/Agama menjadi *power* yang diharapkan mampu menjadi penangkal setiap godaan hawa nafsu.
4. Pengendalian diri/kontrol diri

   Pangkal tolak dari setiap kesuksesan dan kegagalan hidup adalah terletak pada pengendalian diri sendiri, setiap usaha untuk mengatasi masalah tergantung pada sejauh mana usaha yang kita lakukan untuk membedah masalah. Jika masing-masing kita tidak ada kemauan besar untuk keluar dari masalah, maka tidak ada satu ukuran pun yang dapat dipakai untuk menentukan orang itu hebat atau tidak, kecuali sejauhmana kemampuan dirinya untuk mengendalikan diri.

   Rasul bersabda:

   "Tidak disebut sebagai orang kuat, sesungguhnya orang yang kuat dan hebat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika gejolak hawa nafsu membara mengajak kepada kemungkaran."

Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat tanpa korupsi, diperlukan sikap mental dari para pemimpin, yang mempunyai moralitas serta mengemukakan nilai-nilai hati nurani, kejujuran, amanat dan adil dan berani

menghadapi risiko. Di samping itu, harus mempunyai pola pikir yang jernih, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemikiran yang berorientasi pada kenikmatan sesaat dan menghalalkan secara cara merupakan tantangan terberat dalam memberantas korupsi.



Penutup

Melalui doa dan usaha semoga menyertai kesuksesan kita dalam mewujudkan Indonesia tanpa korupsi, tercapai masyarakat Indonesia yang *baldatun thoyyibatun wa rabbul ghofur*. Amin.

RAJAWALI PERS

14

POLEMIK KORUPSI SISTEMIK*

Oleh:
*Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.***

Dalam Konteks yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Korupsi merupakan White Collar Crime dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai invisible crime yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karenanya sering kali memerlukan "pendekatan sistem" (systemic approach) terhadap pemberantasannya. Berbicara mengenai korupsi tidak sekadar pemidanaan saja, tapi bagaimana kebijakan Hukum Pidana menghadapi invisible crime tersebut.

Pendahuluan

Tema tulisan dengan judul *"Polemik Korupsi Sistemik"* tampaknya bersifat limitatif mengingat permasalahan penegakan hukum di Indonesia tidaklah sekadar diamati dari sisi substansial perundang-undangan saja, tetapi juga berkaitan dengan sistem, khususnya sistem hukum pidana, karena korupsi itu kenyataannya telah merusak sistem (*destructed to the system*).

Dalam Kongres PBB VII tentang *"Prevention of Crime and the Treatment of Offenders"* di Milan tahun 1985, telah dibicarakan suatu tema yang tidak klasik sifatnya, yaitu "Dimensi Baru Kejahatan dalam Konteks Pembangunan." Dalam salah satu hasil pembicaraan tentang "dimensi baru" ini yang memperoleh sorotan adalah tentang terjadi dan meningkatnya "penyalahgunaan kekuasaan" *(abuse of power)* oleh pejabat publik yang kemudian meluas dan dikenal sebagai *"Korupsi Sistemik"*, yang kadang kala dimaknai representasi kelembagaan negara, karenanya sering dikatakan pula *"Korupsi Kelembagaan"*. Penyalahgunaan

*Disampaikan Sebagai Sumbangsih Tulisan pada ULTAH Ke-40 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh.

**Pengajar pada Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum pada: Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Pelita Harapan, Universitas Krisnadwipayana, Anggota Senat Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan lain-lain, Tim Pakar Hukum (Pidana) Senior Menteri Kehakiman & HAM R.I., Konsultan Ahli Hukum (Pidana) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman & HAM, Tim Perumus RUU Pengadilan Tipikor, RUU Pemberantasan Tipikor, RUU Pencucian Uang, Perubahan KUHP/KUHAP dan lain-lain, serta Advokat Senior pada "Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan."

kekuasaan dalam bidang ekonomi ini melibatkan pihak-pihak *"upper economic class"* (seperti misalnya para konglomerat) maupun *"upper power class"* (seperti misalnya pejabat tinggi) yang melakukan konspirasi dan bertujuan untuk kepentingan ekonomi kelompok tertentu tersebut. Kasus yang telah tergelar adalah kasus Akbar Tandjung (saat itu Mensesneg RI), Syahril Sabirin (saat itu Gubernur BI) dan 3 mantan Direktur Bank Indonesia, maupun kasus-kasus yang melibatkan anggota DPR/DPRD dan Gubernur/Kepala Daerah, Direksi PLN, KPU, KPPU, pula kasus perbankan, khususnya Bank-Bank (saat itu) di bawah naungan BUMN, seperti kasus Direksi Bank Mandiri (Nelloe cs), Bank Bumi Daya (saat itu dengan terpidana RS Natalegawa) maupun bank-bank swasta dalam kaitan BLBI ataupun kasus Rudi Ramli Bank Bali dengan Cessie atau dahulu Bapindo, di mana perbuatannya melibatkan konglomerat (Eddy Tansil) sebagai *upper economic class* dan pejabat tinggi perbankan pemerintah Towil cs) selaku *upper power class* juga kasus-kasus lainnya di berbagai belahan daerah di bumi Indonesia dengan berbagai macam disparitas pemidanaan, di satu sisi dikenakan pemidanaan, tetapi di sisi lain dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Para profesional violator itu selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat atau sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum, bahkan perbuatannya itu sering kali tidak terjangkau oleh hukum (*"offences beyond the reach of the law"*), sehingga sering kali para pelakunya dapat dengan leluasa membobol perbankan melalui tingkat profesional yang dimilikinya. Perbuatan-perbuatan pelakunya sering kali merugikan keuangan dan perekonomian masyarakat dan negara dalam skala yang sangat besar, sehingga penggunaan aturan-aturan KUHPidana yang terkodifikasir itu pun tidak jarang masih belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.



Penegak Hukum *versus* "Korupsi Kelembagaan"

Saat awal dibentuknya *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) di Hong Kong, sikap pesimisme sangat mengental di kalangan masyarakat, bahkan pengamat terkemuka Prof. S.S. Hueh, Rektor (saat itu) *The University of East Asia* memberikan suatu pandangan kompleksitas antara keterkaitan establisitas institusi itu dan perubahan hukum dengan menyatakan bahwa *"the growth of the law on corruption can not be divorced from changes in the socio-economic and political setting"*. Beliau hendak memberikan suatu ilustrasi hukum betapa pembentukan aturan hukum dalam kerangka memberantas korupsi itu tidak dengan begitu saja dapat memisahkan persoalan ekonomi dengan permasalahan politik.

Namun, sejalan dengan perkembangan masyarakat dan sarana pembentukan hukum itu sendiri, khususnya perangkat sarana pemberantasan korupsi, Hong Kong, dengan ICAC, dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang berhasil melakukan pola minimalisasi terhadap perkembangan korupsi sebagai

penyakit akut dalam sistem ketatanegaraan. Pola minimalisasi korupsi yang dilakukan oleh ICAC itu sendiri justru dimulai di kalangan institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian Hong Kong yang saat itu sangat rentan dengan isu korupsi dihampir segala level birokrasinya, suatu bentuk baru *illegal acts* sebagai Korupsi Sistemik wujud dari Korupsi Kelembagaan.

Berlandaskan sikap idealistik yang sama dengan ICAC, pula kajian sosiologis atas menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum yang ada (POLRI dan Kejaksaan Agung), lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebuah institusi independen yang sangat diharapkan sebagai *trigger mechanism* atau sebagai lembaga pemicu dan pemberdaya atas skeptisme publik terhadap lemahnya institusi penegakan hukum yang sudah ada. Sebagai institusi penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan yang baru, KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan sangat luar biasa atau *extra ordinary power* yang tidak dimiliki oleh institusi lainnya. Karena itu, menjadi wajar apabila masyarakat memiliki harapan lebih searah dengan kewenangan yang luar biasa dari KPK tersebut. Dengan *extra ordinary power* yang dimiliki KPK, diharapkan pula, segala bentuk, cara dan aplikasi korupsi dapat dijadikan suatu bagian tatanan pemberantasan korupsi.

Tantangan kemuka bagi KPK lebih kepada persoalan kelembagaan, korupsi kelembagaan. Korupsi kelembagaan ini selalu berkaitan dengan masalah kebijakan, baik yang dimanfaatkan para aparatur negara maupun minimalisasinya pemahaman penegakan hukum antara makna penyalahgunaan wewenang dalam area Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Tentunya korupsi kelembagaan tidaklah diartikan sebagai suatu justifikasi lembaga terhadap perbuatan korupsi dari aparaturnya. Korupsi kelembagaan merupakan hasil stigmanisasi individual atau kelompok terhadap kelembagaan maupun perilaku korupsi sebagai akibat penyimpangan norma legislasi dari aparatur, yang kesemua ini menimbulkan labelisasi "korupsi kelembagaan."

Korupsi sudah menyebar dan merata di kalangan institusi pemerintahan, kenegaraan maupun swasta. Bahkan korupsi sudah dianggap sebagai bagian hidup bangsa ini. *Individual Corruption* sebagai bentuk konvensional sudah tertinggal.

Korupsi kelembagaan yang sistematis ini bukan saja monopoli di Indonesia, tetapi juga terjadi di Amerika Serikat. Memang polemik kekuasaan dan korupsi sudah menjadi pasangan langgeng dalam suatu birokrasi kekuasaan, bahkan Prof. Michael Levi dalam bukunya *Regulating Fraud, White Collar Crime and the Criminal Process* menunjukkan adanya suatu *trend* baru berupa *Crimes by Government* dalam arti ekstensif, suatu kejahatan yang melibatkan pejabat publik sebagai karakteristik *White Collar Crime* yang sulit tingkat pembuktiannya, sulit pula menentukan status pelakunya dan selalu dapat berlindung dengan justifikasi lemahnya norma legislasi, bahkan *beyond the law* dengan memanfaatkan norma dibalik asas legalitas yang relatif. Kesemua ini sekaligus mempertegas betapa korupsi telah merusak sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, baik eksekutif,

yudikatif, bahkan legislatif yang melibatkan anggota Kongres Illinois, Dan Rostenkowski, yang terbukti korupsi 640.000 dolar, dan ini membuktikan simbol mengakarnya korupsi dalam sistem ketatanegaraan.

Sebagaimana diakui oleh Prof. August Bequai dalam bukunya *White Collar Crime: A 20th–Century Crisis,* korupsi kelembagaan merupakan karakteristik dan krisis di abad ke-20 dari kejahatan kerah putih yang meliputi para birokrat publik dihampir semua sektor kelembagaan politik dan ketatanegaraan, baik yang independen maupun yang terikat birokrasi kelembagaan.

Political Corruption sebagai format Korupsi Kelembagaan sangat mengganggu stabilitas politik sebagaimana ditegaskan Prof. Stephen Rosoff dari *University of Houston Clear Lake* bahwa *corrupt activities of public official can destroy a stability of the State and the potential effectivities of all types of governmental programmes, hinder development and victimized individuals and groups*.

Sebagai modus baru, korupsi kelembagaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan korupsi individu yang sudah mulai tertinggal di era reformasi ini. Karenanya beberapa catatan dari upaya dan kendala Penegak Hukum (Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI dan KPK) menjadi catatan tersendiri dalam pemahamam praktik maupun pendekatan secara akademiknya, tentunya untuk membuka segala tabir kompleksitas korupsi kelembagaan tersebut, sehingga pesimisme menjadi tidak tersentuh dalam konsepsi *Due Process of Law*, yaitu antara lain melalui:

A. *"Systemic Approach"* dan Korupsi Kelembagaan

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa korupsi kelembagaan ini selalu berkaitan dengan masalah kebijakan, baik yang dimanfaatkan para aparatur negara maupun minimalisasinya pemahaman penegakan hukum antara makna penyalahgunaan wewenang dalam area Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana.

Secara konseptual, pada konsep Negara Berkembang, pemikiran bahwa korupsi ini bagian dari kekuasaan menjadi tidak diragukan, karena ia–korupsi–merupakan bagian dari sistem itu sendiri, karenanya ada yang berpendapat bahwa penanggulangan yang terpadu adalah dengan memperbaiki sistem yang ada. Penulis pernah mengingatkan bahwa:

> *"Bentuk kejahatan struktural inilah yang memasukan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisasi. Korupsi yang melanda hampir seluruh dunia ini merupakan kejahatan struktural yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yang baik, karenanya perjudian dan korupsi begitu menjadi sangat kuat dalam konteks perilaku politik dan sosial."*[1]

[1]Indriyanto Seno Adji. *Korupsi & Hukum Pidana.* Cetakan I. Jakarta: "Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan". 2001, hlm. 236.

Artikulasi *"Sistem"* ini memiliki makna yang luas dan komprehensif, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang signifikan. *"Korupsi"* sebagaimana dikemukakan di atas sudah sebagai bagian kejahatan terstruktural yang sangat utuh, kuat dan permanen sifatnya. "Korupsi" sudah menjadi bagian dari "sistem" yang ada, karenanya suatu usaha yang maksimal bagi penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilakukan dengan pendekatan sistem itu sendiri atau dikenal dengan istilah *"Systemic Approach"*, apalagi bila pendekatan sistem ini dikaitkan dengan peranan institusi peradilan yang sangat menentukan sebagai salah satu institusi penegakan hukum dalam proses akhir pemberantasan korupsi.

Sangat sulit untuk menentukan arah awal dimulainya antisipasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ini. Kejahatan yang sudah terukur melalui kejahatan yang terstrukturisasi maupun kejahatan yang telah tersistematisasi sangat sulit untuk menentukan makna "pemberantasan" atau "eliminasi" terhadap perbuatannya itu, mungkin yang terjangkau sebagai tindak antisipasi yang preventif hanyalah sekadar minimalisasi terjadinya perbuatan koruptif tersebut. Sungguh, manakala kita membicarakan korupsi dalam konteks pemberantasan dan eliminasi, saat itulah dapat dikatakan korupsi sebagai suatu perbuatan yang *beyond the law* karena sangat sulitlah kadar pembuktiannya. Kesulitan pembuktian ini disebabkan oleh multifaktor, antara lain, kekuasaan, kuatnya para *economic power* di mana pengaruh kekuasaan ekonomi (konglomerat) dan *bureaucratic power* sebagai kekuasaan umum (pejabat birokrat) yang dapat dikatakan telah memposisikan meraka dalam status *beyond the law*, sehingga hukum sering dikatakan sebagai suatu retorika kekuatan politik saja. Oleh karena itu, premis dan logika hukum masyarakat yang menyatakan bahwa membicarakan pemberantasan korupsi sama halnya membicarakan berbagai kompleksitas penyakit yang tidak ada penyembuhan medikalnya, dapatlah dibenarkan.

Mekanisasi arti "sistem" (hukum) mengalami suatu perubahan mendasar. Arah idealistis SPP ini dapat dipahami melalui sinonimitas pendapat Lawrence M. Friedman dalam bukunya *American Law: What is a Legal System?* Mengenai sistem (hukum). Sistem, lanjutnya, haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi dan pembaruan (reformasi) terhadap struktur *(structure)*, substansi *(substance)* hukum dan budaya hukum *(legal culture)*. Keterpaduan *(integrated)* dari sistem hukum tersebut itu selayaknya dilakukan secara simultan, integral, dan paralel.

Systemic Approach ini dapat sebagai bahan untuk memecahkan persoalan hukum (*legal issue*) atau penyelesaian hukum (*legal solution*), maupun pendapat hukum (*legal opinion*), termasuk permasalahan korupsi, yaitu:

Pertama, dari sisi *structure* (struktur) yang meliputi perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang menyelenggarakan peradilan sehingga terdapat minimalisasi terjadinya KKN. Birokrasi struktur peradilan menimbulkan mafia

peradilan yang telah menjadi polemik peralihan milenium yang selalu tidak terpecahkan. Fungsi pengawasan peradilan terhadap para advokat ataupun administrasi legalitas advokat setiap dua tahun sekali akan menjadi awal perbuatan tercela.

Persoalan hukum yang ada antara lain, berlakunya UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 11, yaitu pemisahan fungsi administratif badan peradilan dari eksekutif (Departemen Kehakiman & HAM) kepada Mahkamah Agung meski dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun, merupakan salah satu pemecahan masalah yang berkepanjangan dan membantu para hakim menjalankan fungsi yudisialnya. Kekuasaan Eksternal tidak lagi mencampuri masalah administratif yang berdampak pada penanganan teknis dan substantif judisial hakim dalam menjalankan tugas profesionalnya. Perkara yang berdimensi politik dapat dijalankan sesuai hati nurani para hakimnya, tanpa ada rasa khawatir eksekutif yang telah memisahkan diri dari fungsi administrasi yudikatif.

Dibentuknya suatu *Komisi Pemberantasan Korupsi*[2] yang bersifat independen dan komisi ini memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan[3] sebagai institusi yang memiliki sinergitas dengan institusi penegakan hukum yang sudah ada (Polisi dan Kejaksaan). Pula adanya *Komisi Ombudsman Nasional* melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 yang memberikan peran masyarakat yang cukup signifikan dalam rangka menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif terhadap pelaksanaan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Indonesia telah melakukan pendekatan komparatif atas pembentukan institusi ini dengan negara lain, seperti Hong Kong melalui *Independence Commission Anti Corruption*, Malaysia dengan *Anti Corruption Agency*, Singapura dengan *Singapore's Corruption Prevention and Investigation Bureau* dan Muangthai melalui *Thailand's National Counter Corruption Commission*.

Penyelesaian dan Pendapat Hukum adalah sebagaimana penjelasan pada unsur ketiga di bawah ini.

Kedua, substance yang menyangkut pembaruan terhadap berbagai perangkat peraturan dan ketentuan normatif *(legal reform)*, pola dan kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut. Pembahasan dalam makalah

---

[2]KPK dibentuk melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dan memiliki wewenang penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan supervisi, koordinasi dan monitoring terhadap institusi penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) ini, menurut Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., merupakan *trigger mechanism* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap institusi yang sudah ada. Lihat Indriyanto Seno Adji. *"Sekilas Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi"*, Cet.1. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, S.H.", 2003, hlm. 58.

[3]Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

inilah yang membahas sekilas problematika dalam penerapan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi.

Persoalan hukum pada era reformasi ini, pembaruan terhadap substansi hukum mengarah kepada pendekatan kemasyarakatan, bukan lagi pada sisi legalistik formal. Juga dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang akan dibahas tersendiri, khususnya eliminasi terhadap prinsip kepastian hukum dan proses beracara yang baik merupakan identifikasi bahwa hukum hanyalah sebagai roda bergulirnya kekuasaan politik.

Dahulu, putusan hakim yang tidak sesuai dengan kehendak kekuasaan akan mengakibatkan hakim tersebut menerima mutasi ke daerah yang sangat jauh dan rentan dari pusat kekuasaan. Penyelesaian dan Pendapat Hukum adalah tidak perlu dilakukan seperti contoh tersebut, namun perlu dicarikan suatu solusi yang bertujuan untuk memperbaiki citra penegakan hukum, yaitu antara lain perlu adanya semacam *Law Enforcement Officer Act*. UU semacam ini sangat diperlukan bagi penunjangan kontrol terhadap para aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Diharapkan studi komparasi yang dapat dijadikan landasan bagi pembentukan UU yang sangat urgensif ini. Sanksi tegas dan berat diperlukan UU ini, mengingat kehendak penegakan hukum di Indonesia ini sangat tergantung pada keberadaan pejabat penegak hukum ini, bukan saja para hakim, tetapi pejabat pada Sistem Peradilan Pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dengan UU ini diharapkan adanya antisipasi perilaku korupsi diketahui sedini mungkin. Kekayaan yang diperoleh dari hasil perbuatan korupsi, umumnya berupa penempatan uang pada sarana perbankan akan diketahui sedini mungkin, karena undang-undang ini nantinya memperkenankan adanya suatu investigasi terhadap asal-usul uang tersebut secara komprehensif.

Ketiga, *legal culture* (budaya hukum) merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic-minded* sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Persoalan hukum adalah budaya hukum ini berkaitan erat dengan soal etika dan moral masyarakat dan pejabat penegak hukum dalam mensikapi KKN. Masalah rendahnya moral dan budaya hukum inilah yang sangat penting dalam pembangunan hukum Indonesia, dan sangat mengganggu struktur dan substansi dari sistem hukum secara keseluruhan. Peranan pejabat penegak hukum dalam memberantas KKN sangat dipengaruhi oleh moral dan etika yang berintegritas dengan pemahaman budaya hukum atas pembersihan KKN tersebut. Menurut Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. (alm) bahwa faktor iman dan pengaruh lingkungan sangat menentukan integritas pejabat penegak hukum.

Penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara memberikan dukungan peningkatan moral dan etika penegak hukum, seperti

telah diusulkan di atas, yaitu perlu segera direncanakan pembuatan *Law Enforcement Officer Act*, selain itu adanya perbaikan sistem rekrutmen para calon Hakim (Jaksa, Polisi) yang bebas dari KKN, melalui kurikulum peningkatan kesadaran beretika (hukum). Jadi, tanpa adanya *political will* dari institusi kenegaraan, bukan dalam artian sempit Eksekutif saja, tetapi juga dari Legislatif dan yudikatif, maka pemberantasan korupsi akan sulit mecapai hasil yang maksimal.

Dari penelitian *(field research)* yang dilakukan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. ke berbagai negara, antara lain Muangthai, Malaysia, dan Australia (khususnya Negara Bagian New South Wales), melalui bukunya yang secara lengkap, jelas dan terurai yaitu *"Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara"*, penulis memberikan beberapa masukan dan pendapat sebagai berikut:

> *Aktivitas yang independen dari Independent Commission Against Corruption (ICAC) seperti di Australia, Thailand (National Counter Corruption Commission) sangat menunjang keberhasilan pemberantasan korupsi, mengingat Komisi ini tidak berada di bawah (sub-ordinasi) dari Pemerintah. Karena itu, seperti NCCC di Thailand dapat secara bebas melakukan penyidikan terhadap Perdana Menteri Thaksin (masih aktif sebagai Perdana Menteri saat itu!) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Political Will secara komprehensif terhadap pemberantasan korupsi itu tidak harus datangnya dari Eksekutif, tetapi lembaga Non-Eksekutif, seperti Legislatif maupun Judikatif, harus sangat memberikan respons yang signifikan untuk menghasilkan pemberantasan korupsi yang maksimal tersebut. Independensi ini terlihat pada sistem pertanggungjawaban komisi ini yang langsung kepada parlemen (semacam Legislatif), bukan kepada Perdana Menteri (seperti Malaysia).*

Dari semua permasalahan-permasalahan di atas, di sini sangat berarti peran *kebijakan kriminal (Criminal Policy)* melalui pendekatan non-penal, yaitu dengan meningkatkan langkah-langkah kampanye anti-korupsi misalnya. Kampanye semacam ini diperlukan dengan pendekatan antara masyarakat, pers (sebagai *social power*) dan institusi kenegaraan. Mengapa dikatakan institusi kenegaraan? Masalah korupsi di Indonesia sekarang ini sudah tidak dapat dikatakan lagi sebagai persoalan eksekutif saja, tetapi sudah terkontaminasi terhadap institusi kenegaraan lainnya, apakah itu legislatif, yudikatif, lembaga non-pemerintah, lembaga kenegaraan yang lainnya. Pendekatan sistemik ini harus diartikan sebagai sikap antisipasi terhadap sistem institusi kenegaraan secara komprehensif.

Harus disadari bahwa tanpa adanya perbaikan moral dan etika dari pejabat penegak hukum, keutuhan substansi dan struktur dari sistem hukum akan tidak memiliki nilai yang berarti. Memperbaiki kinerja Sistem Peradilan Pidana Terpadu sebaiknya tetap memerhatikan ketiga hal tersebut, jika tidak akibatnya pemberantasan tindak pidana korupsi hanya sebatas *retorika* saja!

1. *"Beleid" – "Administrativerechtelijkheid"* dengan Tindak Pidana Korupsi

Sering kali penegak hukum memahami secara menyimpang terhadap soal *"administrativerechtelijk"* dari ranah Hukum Administrasi Negara yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Perhatikan saja pemidanaan terhadap perkara-perkara antara lain Ir. Akbar Tandjung (meskipun dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh Mahkamah Agung), Dr. Syahril Sabirin (dibebaskan dari segala dakwaan oleh Mahkamah Agung), Samadikun, tiga mantan Direktur Bank Indonesia, Direksi Bank Mandiri (Nelloe cs), khususnya dalam kaitan antara Hukum Pidana dari unsur "menyalahgunakan wewenang" (Pasal 1 ayat 1 b UU No.3 Tahun 1971 jo Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999) dan Hukum Administrasi Negara yang berkaitan antara *"Staatsbeleid"* (Kebijakan Negara) dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur). Badan yudikatif telah mencampuradukan, bahkan menganggap sama antara unsur "menyalahgunakan wewenang" dan "melawan hukum", bahkan, tanpa disadari badan peradilan menerapkan asas perbuatan melawan hukum materiel dengan fungsi positif tanpa memberikan kriteria yang jelas untuk dapat menerapkan asas tersebut, yaitu melakukan pemidanaan berdasarkan asas kepatutan dengan menyatakan para pelaku telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, tanpa bisa membedakannya dengan persoalan *"beleid"* yang tunduk pada Hukum Administrasi Negara.[4]

Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif berupa kewenangan diskresioner *("discretionary power", "vrijsbestuur", "freies ermessen")* untuk melaksanakan kebijakannya ("*beleid*") dalam mengatasi segera dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidaklah sekadar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang ("kekuasaan terikat"). Menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Kekuasaan Pemerintah merupakan kekuasaan yang aktif yang meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri dan kewenangan intepretasi terhadap norma-norma tersamar *("vage normen")*. Dalam kaitannya dengan "beleidsvrijheid", kekuasaan yang aktif dari pemerintahan, menurut Prof. R.M. Girindro Pringgodigdo, S.H., berupa *"wijsheid"* dapat merupakan tindakan-tindakan seketika *("instant decision")* dengan melihat urgensi serta situasi/kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan atau keputusan tertulis atau lisan didasarkan kekuasaan/wewenang "diskresioner" *("discretionary power/authority)* yang dimiliki.

Namun demikian, suatu *"discretionary power"* maupun *"wijsheid"* itu harus tetap selaras dengan maksud ditetapkan kewenangan atau sesuai dengan tujuan akhirnya tersebut, yaitu harus sesuai dengan *"doelgerichte"* atau tujuan

---

[4]Indriyanto Seno Adji. *Prospek Hukum Pidana Indonesia pada Masyarakat Yang Mengalami Perubahan*. Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta: 19 Februari 2004. hlm. 27.

ditetapkannya dari kewenangan itu, bahkan menurut Prof. Dr. Riyaas Rasyid, M.A., juga Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. ("Discretionary Power" dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, halaman 3), dalam kondisi yang urgensif, mendesak dan darurat sifatnya, suatu *discretionary power,* juga *"wijsheid",* dapat menyimpang dari produk perundang-undangan yang ada, asalkan penyimpangan ini pada akhirnya sesuai dan dengan diarahkan pada *"doelgerichte"* ditetapkannya kewenangan tersebut.

Pengertian penyalahgunaan "menyalahgunakan wewenang" dalam Hukum Pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian tersebut dalam Hukum Pidana, maka dipergunakan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Mr. H.A. Demeersemen tentang kajian "De Autonomie van het Materiele Strafrecht" (Otonomi dari Hukum Pidana Materiel). Intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai suatu cabang hukum lainnya. Di sini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu Hukum Pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya.

Memang, pengertian *detournement de pouvoir*, dalam kaitannya dengan *Freies Ermessen* ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Prancis.

Menurut Prof. Jean Rivero. dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam tiga wujud, yaitu.

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Bentuk ketiga yang dinamakan *"Abuse of Procedure"* (atau penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana) inilah yang sering kali dipergunakan penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi bentuk-bentuk perbuatan dalam lingkup/ ranah kompetensi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perdata sebagai koruptif.

Memang ada kekeliruan mendasar yang dilakukan badan yudikatif dalam menentukan unsur *"menyalahgunakan kewenangan"* dengan persoalan *"staatsbeleid"* yang tidak menjadi kompetensi dari peradilan umum. Selain itu, parameter terbukti tidaknya unsur "menyalahgunakan kewenangan" adalah bersifat alternatif, dengan tetap memberikan eksistensi kebijakan pada Asas Kecermatan Substantif. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melepaskan tiga mantan Direktur BI dari segala tuntutan hukum *(ontslag van alle rechtsvervolging)* dan Ir. Akbar Tandjung melalui Putusan Vrijspraak dari Mahkamah Agung No. 572K/Pid/2003, kesemua ini memisahkan alasan-alasan soal Materiele Wederrechtelijk (juga penyalahgunaan wewenang) dengan Hukum Administrasi Negara.

Dalam kaitan mantan Direktur BI, pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 148/PID/2003/PT.DKI tanggal 29 Desember 2003, menyatakan:[5]

> *"Menimbang, bahwa karena terbukti Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 15 dan 20 September 1997 adalah sebagai Kebijaksanaan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai upaya untuk menyelamatkan sistem moneter dan Perbankan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tidak berhak menilai suatu kebijaksanaan (beleid) dari Pemerintah Cq. Bank Indonesia, terlepas daripada apakah kebijaksanaan tersebut berhasil atau tidak untuk menyelamatkan sistem moneter atau perbankan atau perekonomian negara."*

Selanjutnya dinyatakan pada hlm. 62:

> *"Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, tetapi karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Onstlag van alle rechtevervolging)."*

Dari pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a Quo terbukti adanya *"Materiale Feit"* berupa Rapat tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 yang menghasilkan suatu *discreation*/diskreasi atau kebijakan/kebijaksanaan Dewan Direksi Bank Indonesia bagi pemberian dispensasi kliring untuk 18 bank yang mengalami saldo debet yang tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, meskipun inkonsistensi Mahkamah Agung muncul kembali manakala lembaga yudikatif ini membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi. Proses polemik Kebijakan Negara sebagai area pada Hukum Administrasi Negara ataukah Hukum Pidana dalam kasus Bank Indonesia ini masih terus bergulir searah dengan keterbatasan pemahaman polemik ini di antara para penegak hukum.

---

[5]Kontra Memori Kasasi Terhadap Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 148/PID/2003/PT.DKI tanggal 29 Desember 2003 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2043/PID.B/2001/PN.Jak.Pst tanggal 1 April 2003. hlm. 32-33.

Dalam kaitannya dengan Ir. Akbar Tandjung, Prof. Dr. Paulus Lotulung, S.H., Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, sekaligus sebagai Guru Besar dan Ahli Hukum mengenai relasi antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana (Korupsi), memberikan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI No. 572 K/Pid/2003 tanggal 4 Feburari 2004 yang kesimpulannya menyatakan:[6]

> *"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa I, yaitu menerima dana budgeter sebesar Rp 40 miliar kemudian diserahkan kepada Terdakwa II untuk digunakan dalam pengadaan dan penyaluran sembako untuk masyarakat miskin, bukan merupakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa I baik selaku Mensesneg maupun selaku koordinator yang menangani program pengadaan dan penyaluran sembako tersebut, tetapi merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang Koordinator/Mensesneg dalam keadaan darurat sesuai dengan kewenangan diskresioner yang ada padanya untuk melaksanakan perintah presiden sebagai atasannya. Bahwa dalam keadaan darurat, tentu tidak dapat diharapkan menempuh prosedur dan cara-cara dalam keadaan normal, terlebih pula penggunaan prosedur dan cara-cara dalam keadaan normal, terlebih pula penggunaan dan pengelolaan Keuangan Negara dalam bentuk dana non budgeter hanya diatur oleh apa yang disebut "konvensi", tidak seperti halnya keuangan negara dalam bentuk APBN yang penggunaan dan pengelolaannya diatur oleh Keppres, misalnya untuk pengadaan barang oleh Pasal 21 sampai dengan 30 dalam Keppres No. 16 Tahun 1999 dan Keppres No. 18 Tahun 2000 sebagaimana telah dikemukakan di atas."*

Kebijakan pemberian kredit likuiditas dalam keadaan yang darurat ini sesuai dengan petunjuk presiden pada 3 Desember 1996 yang saat itu pada pokoknya melarang untuk melakukan tindakan likuidasi atau tindakan-tindakan lain yang dapat menimbulkan gejolak sosial sehubungan dengan adanya dua agenda nasional, yaitu Pemilihan Umum dan Sidang Umum MPR-RI, dan hal yang sama dikemukakan kembali oleh Presiden kepada Direksi Bank Indonesia pada 15 April 1997.

Sebenarnya, atas dasar petunjuk Presiden RI (saat itu) yang tidak menghendaki adanya likuidasi dan tindakan-tindakan lain yang dapat menimbulkan gejolak sosial sebagaimana bunyi pertimbangan di atas, maka pemberian fasilitas kredit likuiditas merupakan Kebijakan Negara atau *Staatsbeleid* (atau *State Policy* atau Kebijakan Negara) dalam hal ini presiden sebagai Kepala Negara (atau Kepala Pemerintahan) yang dalam tataran implementasinya dilaksanakan oleh aparatur negara atau *"Overheidsbeleid"* melalui Kebijakan Dewan Direksi Bank Indonesia, yang dituangkan sebagai parameternya adalah

[6]Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 572K/Pid/2003, Perkara Pidana Korupsi atas nama Ir. Akbar Tandjung, hlm. 207.

peraturan perundang-undangan tertulis, juga asas-asas hukum tidak tertulis sebagai kepatutan yang lazim dalam masyarakat.

Kebijakan Direksi Bank Indonesia secara kolektif institusional tentang pemberian kredit likuiditas dalam kondisi yang darurat, apakah melalui fasilitas dispensasi kliring bagi 18 (delapan belas) bank yang mengalami saldo debet ataukah (seharusnya) melalui fasilitas penyediaan kredit likuiditas dengan Diskonto II dalam rupiah merupakan persoalan "Kebebasan Kebijakan" atau *"beleidsvrijheid"* atau *"Freies Ermessen"* yang dalam tugas publiknya Negara cq Direksi Bank Indonesia memiliki semacam ruang gerak yang bebas dan luas. Sehingga landasan ataupun motivasi adanya suatu kebebasan kebijakan dari negara dalam menjalankan tugas publiknya tidak dapat dinilai oleh Hakim Perdata dan Hakim Pidana, yang kesemuanya ini, menurut Prof. Oemar Seno Adji, S.H. mendekatkan diri pada suatu *"separation of powers"*, khususnya dalam arti *"separation of functions"* ataupun *"separation of organism"*.

Sebagaimana dikatakan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. memang diakui doktrin dan yurisprudensi, segala perselisihan tentang pola kerja Tata Usaha Pemerintahan, juga yang mengenai kebijakan (kebijaksanaan) pemerintah *(Staatsbeleid)* dimasukkan kekuasaan Pengadilan, maka ini sebetulnya berarti bahwa Pengadilan menjadi pemerintah belaka (Prof. Oemar Seno Adji, S.H.: *Peradilan Bebas Negara Hukum*, halaman 235). Dapat dikatakan bahwa kebijakan tidak termasuk penilaian oleh hakim, yang memfokuskan dirinya pada soal *"rechtmatigheid"* dan bukan *"doelmatigheid"*.

Prof. Lie Oen Hock, S.H. menyatakan secara tegas bahwa Hakim biasa tidak diperkenankan mengadili mengenai kebijakan penguasa. Bukanlah Pengadilan yang dapat menilai kebijakan penguasa dengan *Freies Ermessen*-nya, sehingga kebijakan pemerintah tidak boleh dicampuri oleh Hakim Umum. Pembatasan terhadap *Beleidsvrijheid* itu adalah apabila terdapat perbuatan yang masuk dalam kategoris penyalahgunaan wewenang *("Detournement de pouvoir")* dan perbuatan sewenang-wenang *("Abus de Droit")*, dan pola penyelesaian terhadap penyimpangan ini adalah melalui Peradilan Administrasi (sekarang: Peradilan Tata Usaha Negara).

Dengan demikian Kebijakan Direksi Bank Indonesia dalam *menentukan untuk memberikan atau tidak memberikan kredit likuiditas, baik melalui fasilitas saldo debet ataupun fasilitas diskonto*, maupun *untuk menghentikan atau tidak menghentikan kliring bagi ke-18 bank yang saldo debet* merupakan Kebebasan Kebijakan, suatu Freies Ermessen atau *beleidsvrijheid* dalam rangka *Staatsbeleid* yang dalam tataran implementasinya dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia selaku *Overheidsbeleid*, dan tidak menjadi wewenang dari Hakim Umum (Perdata maupun Pidana), begitu pula tidak menjadi wewenang Peradilan Pidana terhadap Pembanding. Penilaian terhadap benar tidaknya suatu Kebijakan Negara (*in casu* Kebijakan Direksi Bank Indonesia dalam memberikan fasilitas kredit likuiditas) yang masuk dalam kategoris *beleidsvrijheid* tidak menjadi kompetensi dari Peradilan

Umum, baik Peradilan Perdata maupun Peradilan Pidana, untuk mengadili dan memutus perkaranya!

Peradilan Pidana (juga Peradilan Perdata) tidak memiliki kewenangan menilai *"Kebijakan Negara yang Substantif (Materiel)"* seperti halnya Kebijakan Direksi Bank Indonesia mengenai dispensasi kliring terhadap 18 (delapan belas) bank yang terkena saldo debet tersebut di atas.

Seharusnya peradilan pidana tidak memiliki kompetensi untuk mengadili dan memutus persoalan *"Staatsbeleid"* dalam kerangka *"beleidsvrijheid"* berupa *Kebijakan Substantif* sebagai Kebijakan Institusional dari Bank Indonesia yang merupakan wujud dari *Overheidsbeleid.* Uraian di atas ini hanya sekadar memberikan kejelasan mengenai hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana yang masih sangat terbatas pemahaman di antara penegak hukum sehingga akan memengaruhi pula kendala terhadap eksistensi korupsi sistemik dimaksud.

2. Administrative Penal Law–Asas *Systematische Specialiteit*

Selain itu, yang harus menjadi perhatian dari penegak hukum adalah relasi antara dapat tidaknya absorsi tindak pidana yang berada dalam ranah Hukum Administrasi dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai ranah Hukum Pidana, khususnya terhadap penerapan asas *Lex Specialis* berdasarkan pemaknaan Pasal 103 KUHP, selain masalah *"beleid"* yang telah dijelaskan di atas.

Ajaran *Lex Specialis* sudah semakin berkembang dalam pemahaman Hukum Pidana. Ia –asas Lex Specialis– tidaklah sekadar, membicarakan lagi mengenai pengesampingan suatu asas umum *(lex generalis),* tetapi telah memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yang demikian kompleksitasnya dan bentuknya, karena telah tersebar perundang-undangan yang bersifat khusus dan bersifat ekstra kodifikasi atau berada di luar KUHP. Seperti penjelasan di atas, yaitu eksistensi UU Perbankan (juga UU Kehutanan, Lingkungan, Pajak, Kepabeanan, Keimigrasian, Ketenagalistrikan, Kehutanan, Pertambangan, dan lain-lain).

Asas Hukum Pidana mengenai asas *Lex Specialis* yang dinamis dan limitatif sifatnya., terutama (1) untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang harus diberlakukan di antara dua atau lebih perundang-undangan yang juga bersifat khusus, dan (2) Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undang-Undang Khusus.

Untuk menentukan ketentuan (pasal) yang akan diberlakukan dalam/ pada satu perundangan khusus, maka berlaku asas *Logische Specialiteit* atau Kekhususan yang Logis, artinya *ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus, apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain, juga memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum*, misalnya Pasal 341 KUHP yang harus diterapkan daripada Pasal 338 KUHP terhadap kasus pembunuhan yang pelakunya seorang ibu terhadap anaknya atau Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 adalah yang diterapkan daripada Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, artinya *ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada*. Misalnya, subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada dalam konteks perbankan, maka UU Perbankan adalah yang diberlakukan, meskipun UU Khusus lainnya (seperti UU Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya) adalah akseptabilitas sifatnya.

Doktrin dinamis dari ajaran dan asas *Lex Specialis* ini sangat berkaitan dengan ajaran asas *Concursus* dan *Deelneming* yang apabila keliru dalam pemahaman akan menjadi indikator kemampuan penegak hukum akan pemahaman asas-asas Hukum Pidana.

Pelanggaran *Prudential Principles* Perbankan tidaklah dapat diartikan sebagai perbuatan koruptif, karena berdasarkan pendekatan akademis doktrinal melalui asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian adalah menjadi area Tindak Pidana Perbankan, bukan Tindak Pidana Korupsi, ini semua harus menjadi landasan legalitas untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap asas *Concursus*. Semua perbuatan yang menyimpangi aturan tentunya diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi tidak dapat diartikan selalu sebagai perbuatan koruptif. Asas Kekhususan yang Sistematis merupakan sarana untuk mencegah dan membatasi serta meluruskan kembali arah asas "perbuatan melawan hukum" dan "menyalahgunakan wewenang" dalam tindak pidana korupsi agar tidak bermakna *"all embracing act dan all purpose act"*.

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman asas *Systematische Specialiteit* (Kekhususan yang Sistematis) sebagai doktrin akademis yang belum tentu dipahami oleh masyarakat hukum, khususnya dalam keterkaitan antara perundangan administrasi yang bersanksi pidana *(Administrative Penal Law)* dengan Hukum Pidana (Korupsi), maka pembentuk undang-undang (khususnya Prof. Dr. Muladi, S.H., saat itu sebagai Menteri Kehakiman RI) memberikan pemahaman eksplisitas melalui Pasal 14 UU No.31 Tahun 1999.

Mengingat telah ada asas *Systematische Specialiteit* (Kekhususan yang Sistematis) sebagai pengakuan akademis tersebut, pendapat doktrin telah diformulasikan melalui norma legislasi untuk memberikan batasan-batasannya melalui Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

> *"Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini."*

Jadi makna yang terkandung dalam substansi ketentuan ini adalah bahwa undang-undang tindak pidana korupsi berlaku apabila perbuatan tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang memang secara tegas jelas dinyatakan demikian dalam perundangan ekstra Undang-Undang Korupsi. Dengan demikian, dalam hal perundangan tertentu tersebut tidak menyatakan yang demikian, maka yang berlaku bukanlah pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi, tidak semata-mata Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau semua produk legislasi sebagai perbuatan melawan hukum yang memberi kesan sebagai jaring laba-laba atau jaring. Tidak dapat dibenarkan seseorang yang melanggar UU Kepabeanan, tetapi selain didakwa melanggar UU Kepabeanan, juga dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi bahkan (dahulu) dengan UU Subversi meskipun perbuatan materiel yang didakwakan adalah satu dan sama.

Dimensi *Administrative Penal Law* agar tidak semata-mata sebagai perbuatan yang absorsi sebagai tindak pidana korupsi ditegaskan pula oleh Dr. Parman Soeparman, S.H., M.H (Ketua Muda Bidang Tindak Pidana Mahkamah Agung RI) dalam makalahnya berjudul *"Dimensi Administrative Penal Law Sebagai Tindak Pidana Korupsi"*[7] dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Makassar 2-6 September 2007.[8] Bahkan perlunya asas *lex specialis systematic* ditegaskan oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LLM dalam kaitannya dengan Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 sehingga UU Pemberantasan Korupsi tidak berlaku terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi atas suatu perbuatan yang terjadi di dalam aktivitas yang dilindungi suatu UU lain semisal UU Perbankan, Perpajakan atau Pasal Modal, juga adanya asas *Lex Specialis Systematic* dan Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 menghindari UU Pemberantasan Korupsi menyimpangi asas *Concursus Idealis* pada Pasal 63 ayat 1 KUHP.[9]

B. Kewenangan yang *Equal*–Disintegrasi Kelembagaan

Akhirnya, selain itu perlu diperhatikan wacana progresif bahwa korupsi kelembagaan ini selalu merusak sistem ketatanegaraan dan perekonomian negara, karena itu yang diperlukan perhatian adalah, *pertama*, melakukan tindakan secara terintegrasi dari lembaga penegak hukum melalui *integrated criminal justice system*, artinya di antara penegak hukum harus memiliki suatu *balanced and equal of power*, suatu kewenangan yang berimbang dan sama di antara para penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegakan hukum terhadap korupsi, selain itu

[7]Parman Soeparman. *Dimensi Administrative Penal Law Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Juli 2007.

[8]Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Makassar 2-6 September 2007.

[9]Romli Atmasasmita. *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Media Indonesia, halaman 8, Rabu, 17 Oktober 2007.

justru diskriminasi kewenangan akan menimbulkan disintegrasi penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, tingkat keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi justru harus dilandasi adanya suatu *integrated criminal justice system,* dan bukannya menciptakan sistem diskriminasi kewenangan, akhirnya terjadi penegakan hukum yang terpilah, sehingga sering timbul anekdot, lebih baik disidik Polri dan Kejaksaan Agung daripada KPK. Tujuan penegakan hukum bukanlah menimbulkan disintegrasi di antara lembaga penegakan hukum, tetapi bagaimana memaksimalkan penegakan hukum yang non diskriminatif wewenang. *Kedua*, selain itu eksistensi independensi dalam proses penegakan hukum merupakan suatu wacara yang imperatif sifatnya. Akan menjadi sulitlah bagi Polri dan Kejaksaan Agung memaksimalkan pemberantasan korupsi selama independensi dalam konteks limitatif masih dalam status sub-ordinasi kekuasaan eksekutif tertinggi sehingga terkesan adanya suatu kekuasaan otoriter yang permisif. Dari kajian sosiologis yuridis, gangguan optimal independensi penegak hukum justru dari lingkaran internal kekuasaan, sehingga selama masih ada hubungan sub-ordinasi penegak hukum dan kekuasaan tertinggi eksekutif, kegamangan kehendak penegak hukum korupsi akan selalu minimal hasilnya.

Gangguan, serangan dan intervensi terhadap institusi penegak hukum itu begitu menguatnya sehingga pola intervensi dikemas dalam bentuk *quatie* independensi yang terbatas, seperti penempatan lembaga penegak hukum yang sub-ordinasi kekuasaan, kehadiran rutin penegak hukum dalam rapat kabinet misalnya, sehingga jarang terlihat Polri dan Kejaksaan Agung memeriksa pejabat negara aktif dalam pemberantasan korupsi, kesemua ini memberikan arah seolah adanya suatu justifikasi yang berlindung di balik prinsip legalitas sub-ordinasi.

Sikap non-sinergitas, diskriminatif kewenangan di antara lembaga penegak hukum, yaitu Polri/Kejaksaan Agung dengan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, justru melemahkan penegakan hukum. *Balanced and Equal of Power* adalah kebangkitan penegak hukum, Polri, Kejaksaan Agung dan KPK sebagai *"voorportaal"* (gerbang terdepan) membuka tabir korupsi kelembagaan dalam konteks *Due Process of Law* yang prospektif.

Kesimpulan yang dapat diberikan secara garis besar tentang Korupsi Sistemik, keterkaitan antara "Beleid" dengan Tindak Pidana Korupsi dirangkumkan antara lain sebagai berikut:

- "Dimensi Baru Kejahatan Dalam Konteks Pembangunan" memperoleh sorotan tentang meningkatnya "penyalahgunaan kekuasaan" *(abuse of power)* oleh pejabat publik yang kemudian meluas dan dikenal sebagai *"Korupsi Sistemik"*, yang kadangkala dimaknai representasi kelembagaan negara, karenanya sering dikatakan pula *"Korupsi Kelembagaan"*, sebagaimana terjadi di KPU, DPR, Departemen Agama, Departemen Kelautan, dan lain-lain. Penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang ekonomi ini melibatkan pihak-pihak *"upper economic class"* (seperti misalnya para konglomerat) maupun

"upper power class" (seperti misalnya pejabat tinggi) yang melakukan konspirasi dan bertujuan untuk kepentingan ekonomi kelompok/golongan tertentu sehingga pada akhirnya menimbulkan tindak pidana di bidang ekonomi *(economic crime)* sebagai salah satu objek kriminalisasi. Pendekatan Sistemik merupakan sarana pokok untuk memperoleh minimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi.

- Korupsi Kelembagaan ini menimbulkan kerancuan dalam memberikan limitasi yang deferensi antara norma (penyalahgunaan kewenangan) dalam Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana.
- Kewenangan diskresioner (*discretionary power*) dari aparatur negara, baik perbuatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (kewenangan mengikat) maupun menyimpangi peraturan perundang-undangan (kewenangan aktif), dan dilakukan sesuai pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam kondisi yang mendesak, urgensi dan atau darurat sifatnya merupakan *"overheidsbeleid"* dalam area Hukum Administrasi Negara yang tidak menjadi yurisdiksi dan makna "menyalahgunakan kewenangan" maupun "melawan hukum" (formal dan materiil) dalam Hukum Pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Kewenangan diskresioner, berupa *"beleidvrijheid"* maupun *"wijsheid"*, yang kadangkala menyimpangi ketentuan perundang-undangan dapatlah dibenarkan asalkan selaras dengan maksud ditetapkannya kewenangan atau memang sesuai dengan tujuan akhirnya, sesuai dengan *"doelgerichte"* ditetapkan diskresioner ini, sehingga dalam hal terjadi penyimpangan dari asas *doelgerichte* tersebut, maka area Hukum Pidana menjadi pijakannya.
- Pelanggaran Perundang-undangan Administrasi yang bersanksi penal *(Administrative Penal Law)*, termasuk pelanggaran UU Perbankan, Pasar Modal, Lingkungan Hidup, Ketenagalistrikan, Pertambangan, Kehutanan, Telekomunikasi, dan lain-lain, tidaklah selalu dapat diartikan sebagai perbuatan koruptif, karena berdasarkan asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, pelanggaran terhadap *Administrative Penal Law* atau perundang-undangan administratif yang bersanksi pidana adalah menjadi area Tindak Pidana pada Perundang-undangan Administratif, bukan Tindak Pidana Korupsi, ini semua harus menjadi landasan legalitas untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap asas *Concursus*. Asas *Systematische Specialiteit* ini dipertegas melalui Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 yang bertujuan menghindari Tindak Pidana Korupsi sebagai *all embracing act* dan *all purposing act*.
- Sikap non-sinergitas, diskriminatif kewenangan di antara lembaga penegak hukum, yaitu Polri/Kejaksaan Agung dengan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, justru melemahkan penegakan hukum. *Balanced and Equal of Power* adalah kebangkitan penegak hukum, Polri, Kejaksaan Agung dan KPK sebagai *"voorportaal"* (gerbang terdepan) membuka tabir korupsi kelembagaan yang telah meluas.

15

PROBLEMATIK *CYBER LAW* BAGI PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA

Oleh:
*Prof. Dr. Emeliana Krisnawati, S.H., M.Si.**



Latar Belakang

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI yang terjadi di setiap negara merupakan ciri global, yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih baik terutama bagi negara yang sedang berkembang bahkan negara yang masuk sebagai negara miskin. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma di mana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara. Pada era globalisasi ini, penguasaan dan pemahaman teknologi informasi ini sangat diperlukan supaya tidak menyebabkan ketergantungan yang tinggi dari pihak lain. Hal tersebut akan menyebabkan hilangnya kesempatan untuk bersaing yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta pemanfaatan teknologi informasi.

Teknologi informasi dapat menyebabkan dampak positif, tetapi dapat juga berdampak negatif yaitu dapat menjadi instrumen perbuatan melawan hukum yang potensial. Dalam hal ini diperlukan pembenahan sektor hukum di bidang lain, dengan cara membuat hukum di bidang ini, dengan cara membuat hukum positif terkait dengan aktivitas *cyber* yang disebut dengan *cyber law*.

Cyber law ruang lingkupnya sangat luas, pada saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemahaman teknologi informatika atau disebabkan kemauan peradaban manusia, termasuk kesejahteraan.

*Guru Besar pada Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Hukum Teknologi Informasi *(Law of Information Technology)*, Hukum Dunia Maya *(Virtual World Law)*, Hukum Mayantara

Perkembangan teknologi informasi yang berwujud internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, seperti interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet selalu memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah.

Menurut Jhon Chamber, Presiden dan CEO di Amerika menyatakan bahwa saat ini alokasi internet memiliki dampak yang cukup besar bahkan lebih besar dari revolusi industri. Untuk merespons perkembangan ini Amerika Serikat sebagai pelopor penggunaan dan pemanfaatan internet telah mengubah parade guna ekonominya dari berbasis manufaktur menjadi ekonomi berbasis jasa. Pada saat ini perkembangan di bidang informasi merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi yang sangat maju pesat.

Di Indonesia intrastruktur di bidang teknologi belum terlalu banyak, namun bukan berarti Indonesia lepas dari ketergantungan terhadap teknologi informasi. Ada beberapa aspek kehidupan masyarakat di Indonesia yang pada saat ini dipengaruhi oleh peran teknologi informasi seperti: pelayanan informasi, transaksi perdagangan dan bisnis serta pelayanan jasa baik oleh pemerintah maupun swasta.

Berdasar uraian di atas masalah yang timbul apakah problematik *cyber law* bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Pembahasan

Pada saat ini telah hadir hukum baru yang dikenal sebagai hukum siber sebagai padanan dari *cyber law* yaitu suatu hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi atau disebut Hukum Dunia Maya serta Hukum Mayantara. Dengan adanya *cyber law* akan terjadi permasalahan atau problematik pembuktian dan penegakan hukum, karena penegak hukum akan mengasumsikan sebagai sesuatu yang tidak terlihat, semu atau maya. Kegiatan siber sekarang sudah tidak sederhana lagi, dengan kegiatan yang tidak dapat dibatasi wilayah negara, aksesnya dapat dilakukan dengan mudah dari negara mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang sama sekali tidak pernah berhubungan. Contoh yang banyak terjadi yaitu pencuruan dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Masalah pembuktian faktor yang penting karena data elektronik belum terekomendasi

dalam sistem hukum acara di Indonesia. Data masih rentan untuk diubah dipalsu dan diterima ke berbagai negara, dalam waktu yang sangat singkat sehingga dampak yang diakibatkannya dapat juga demikian cepat. Dalam perdagangan global teknologi informasi telah menjadi instrumen yang efektif. Masih banyak problematik-problematik yang lain dalam transaksi *e commerce* telah merupakan bagian perniagaan nasional maupun internasional seperti membayar zakat, memesan obat-obatan yang sangat pribadi dengan melalui internet. Perkembangan di bidang telematika sulit untuk dibendung, termasuk ditemukannya hak cipta dan hak paten baru di bidang teknologi informasi. Dalam kegiatan *e commerce* terhadap dokumen elektronik yang kedudukannya diselaraskan dengan dokumen yang dibuat oleh negara.

Cyber law dapat diklasifikasikan sebagai rezim hukum tersendiri, karena memiliki multi aspek yang dapat menguntungkan masyarakat dalam komunikasi yang mudah dengan menggunakan informasi elektronik. Di sisi lain dapat merugikan karena hukum yang terkait belum mengatur secara jelas, dan belum cukup mampu memfungsikan dirinya sebagai sarana ketertiban.

Cyber law atau dengan kata lain disebut *cyber space law* merupakan aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi pada ruang maya atau mayantara, sampai saat ini belum ada satupun regulasi di Indonesia yang menyebut atau mendefinisikan istilah cyber atau mayantara karena istilah cyber pada saat ini bukan merupakan istilah hukum.

Ada beberapa ruang lingkup *cyber law* yang perlu diperhatikan:

1. Kriminalisasi *cyber crime* atau kejahatan di dunia maya. Dampak negatif dari kejahatan di dunia maya ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Perangkat peraturan yang ada saat ini masih belum cukup kuat menjerat pelaku dengan saksi yang tegas, maka kejahatan ini makin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Menurut Lacassague bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Betapapun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.
2. Aspek pembuktian, masih banyak pendekatan antara akademisi dengan praktisi mengenai hal ini. Untuk aspek perdata, pada dasarnya hakim dapat bahkan dituntut untuk melakukan penemuan hukum *(rechtsvinding)*. Untuk aspek pidana tidak demikian asas legalitas menetapkan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Untuk itu diperlukan adanya dalil yang kuat sehingga antara akademisi dan praktisi tidak perlu terjadi perdebatan lagi.

3. Aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual disingkat HAKI dalam *Cyber law,* termasuk hak cipta, paten, merek, desain industri rahasia dagang, sirkuit terpadu, dan lain-lain.
4. Standardisasi bidang telematika, penerapannya akan membantu masyarakat untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi informatika.
5. Aturan di bidang *E – Business* termasuk di dalamnya perlindungan konsumen dan pelaku bisnis.
6. Aturan-aturan di bidang *E- Government*, bila hal ini telah terintegrasi dengan baik, maka efeknya adalah pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.
7. Aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi dalam menggunakan teknologi informasi.
8. Yurisdiksi hukum, *cyber law* tidak akan berhasil apabila aspek ini diabaikan.

Dalam ruang siber pelaku pelanggaran sering dijerat, karena pengadilan di Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional, namun akibatnya mempunyai implikasi hukum di Indonesia.

Dalam hukum internasional dikenal tiga macam/jenis yurisdiksi yaitu:

1. untuk menetapkan undang-undang *(the jurisdiction to priscribe);*
2. untuk penegakan hukum *(the jurisdiction to enforce);* dan
3. untuk menuntut *(the jurisdiction to adjudicate)*.

Ada beberapa asas yang berkaitan dengan penentuan luar hukum yang berlaku dikenal asas:

1. *Subjective teritoriality* yang menekankan pada keberlakuan hukum ditentukan berdasar tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
2. *Objective teritoriality*, bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
3. *Rationality*; yang menentukan bahwa negaranya mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
4. *Passive rationality* yang menekankan yurisdiksi berdasar kewarganegaraan korban.
5. *Protective principle*, yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan di luar wilayahnya.

6. *Universality* yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Asas ini perlu perhatian khusus terkait dengan penanganan kasus *cyber* yang disebut *universal interest jurisdiction*. Menurut asas ini setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan kejahatan terhadap kemanusiaan *(crimes against humanity)*, seperti penyiksaan, genosida, pembajakan udara, dan lain-lain. Asas ini mungkin dikembangkan untuk *internet piracy* seperti computer, *cracking, carding, harking and vouses*. Perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan yang sangat serius berdasar perkembangan internasional.

Untuk ruang *cyber* pengaturan dan penegakan hukumnya tidak dapat menggunakan cara-cara tradisional, sebaiknya kegiatan *cyber space* diatur dalam hukum tersendiri.

Sengketa pada hukum perdata internasional juga menyangkut masalah kompetensi forum yang berperan dalam menentukan kewenangan forum (pengadilan dan arbitrase) penyelesaian kasus perdata internasional. Pada makalah ini akan dibatasi pada pembahasan tentang *cyber crime* berkaitan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (UU ITE).



Kriminalitas dalam *Cyber Law*

Problem pelanggaran hukum atau kejahatan merupakan tanggung jawab setiap masyarakat. Kejahatan mayantara atau *cyber crime* pada asas ini banyak dilakukan oleh masyarakat terutama anak muda yang kadang-kadang ingin mencoba-coba kreativitasnya di bidang mayantara.

Kejahatan merupakan perbuatan yang bersifat tindak susila, melanggar norma, mengacaukan, menimbulkan ketidaksenangan dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan bukan sekadar mengandung perbuatan melanggar hukum, namun juga termasuk melanggar hak-hak orang lain baik di bidang sosial, ekonomi, dan sebagainya sehingga menimbulkan reaksi masyarakat untuk membenci, menolak atau mereaksi perbuatan tersebut. Tingkat dan ragam kejahatan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Semakin modern dan maju kehidupan masyarakat, semakin maju dan modern pula modus operandi kejahatan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Perubahan dalam suatu masyarakat, pasti akan diikuti oleh perubahan perilaku masyarakatnya. Ada yang dapat menerima, tetapi ada pula yang gagal dalam adaptasi dengan transformasi yang berorientasi dengan penegakan nilai-nilainya positif. Sebagian masyarakat yang dapat menikmati dan menyetujui adanya perubahan, tetapi ada pula yang tidak dapat atau tidak mau menerima perubahan tersebut. Mereka ini

yang biasanya berusaha menentang perubahan nilai-nilai sehingga melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang disebut dengan kriminalitas.

Dalam suatu masyarakat pasti ada peraturan atau hukum *(ubi societas, ibi ius)*. Hukum merupakan sarana untuk mencegah kejahatan hukum dibuat oleh negara yang mempunyai kekuatan memaksa melalui penegak hukum yang harus tegas dan konsisten dalam melaksanakan hukum tersebut. Aparat penegak hukum harus dapat memberdayakan fungsi hukum untuk menanggulangi kejahatan yang makin lama makin maju dan profesional.

Dalam era globalisasi ini warna dan corak perubahan banyak ditawarkan oleh pasar dunia dan bangsa mana pun sehingga masyarakat menemui perbedaan dalam perubahan yang dipenetrasikan. Pada masa sekarang ini perubahan global yang terjadi, yaitu adanya kejahatan mayantara atau *cyber crime* yang selalu berkejaran antara tarikan pengaruh global dengan keinginan. Masyarakat dituntut untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi modern atau canggih, namun ada juga yang menyebabkan dampak negatif atau deskriptif.

Kejahatan mayantara atau *cyber crime* ini terjadi dalam produk teknologi canggih yaitu melalui internet atau komputer. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan seperti *cyber crime* ini, maka sebagai negara hukum *(rechtstaat)* harus keberadaan hukum sangat diperlukan untuk mengatur dan mencegah terjadinya *cyber crime*. Demikian penegak dan penegakan hukum harus dapat menjalankan fungsi hukum dengan baik dan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum harus dibuat lebih dahulu sesuai asas *mellum selectum mella poena sine previec lege poenali,* perbuatan dapat dihukum apabila ada peraturan yang mengatur. Pada kenyataannya kejahatan terjadi dulu, kadang peraturannya belum ada sehingga ada pendapat bahwa hukum selalu ketinggalan zaman.

Upaya yang sedang dilakukan pemerintah pada saat ini dalam menyusun payung hukum ruang *cyber* melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 memang patut dihargai meskipun belum dapat memenuhi kebutuhan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Masih banyak masalah yang timbul seperti yang telah diungkapkan di depan yaitu tentang yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, asas perdagangan secara *E commerce,* asas persaingan usaha tidak sehat (melawan hukum), perlindungan konsumen, kekayaan intelektual, hukum internasional, serta asas *cyber crime* Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang sekarang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi merupakan hasil kombinasi antara hukum teknologi informasi dan Rancangan Undang-Undang Tanda Tangan digital dan transaksi elektronik.

Di tingkat Internasional PBB melalui komisi khususnya *The United Nations Commissions on International Trade Law* (UNCITRAL) telah mengeluarkan dua *guidelines* yang terkait dengan transaksi elektronik yaitu:

1. *Uncitral model law on Electronic Signature with Guide to Enactment* 2001.

2. Di Uni Eropa dalam upaya mengantisipasi masalah-masalah pidana di *cyber space*, Uni Eropa mengadakan *convension on cyber crime* yang di dalamnya membahas jenis-jenis kejahatan apa saja yang dikategorikan sebagai *cyber crime*.

Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain di bidang *cyber law* seharusnya Indonesia segera melengkapi *cyber law* dengan mencari perbandingan hukum negara lain.

RAJAWALI PERS

16

MONEY LAUNDERING PERSEPSI HUKUM SOSIAL–EKONOMI BERASPEK PIDANA

Oleh:
Prof. Dr. Bambang Purnomo, S.H.



Pengantar

DALAM BERBAGAI TULISAN ilmiah dan pertemuan ilmiah sudah tumbuh anggapan bahwa pertumbuhan kejahatan seiring dengan pertumbuhan manusia bermasyarakat, karena anggapan bahwa kejahatan sudah menjadi anak kandung masyarakat.

Konsep penalaran bahwa kriminalisasi dan viktimisasi sudah menjadi dalil umum yang muncul dari upaya penertiban masyarakat melalui pengembangan hukum akan berhasil menanggulangi kejahatan dan korban kejahatan guna menciptakan ketertiban masyarakat secara simultan. Dalam kenyataan konsep penalaran yang dimaksudkan tidak dapat terwujud secara nyata di mana pun dan kapanpun karena faktor dominan dari perubahan sosial budaya dan benturan kepentingan hidup antarmanusia itu sendiri.

Salah satu dominasi budaya masyarakat yang menonjol, yaitu budaya hukum untuk mengontrol perubahan budaya dan pencegahan benturan kepentingan antarmanusia. Sosok budaya hukum menjadi perangkat penting ketika ajaran tentang negara hukum tumbuh meluas pada abad ke-16 sebelum pertumbuhan ajaran negara kesejahteraan abad ke-20.

Ajaran negara hukum menumbuhkan kepercayaan bahwa hukum akan mampu menciptakan dunia tertib-aman bagi penduduk dunia, namun ternyata sudah menjadi kurang berhasil-guna ketika tumbuh doktrin filsafat positivisme ke arah neo-positivisme seperti di negara Jerman di masa Hitler, di negara Italia di masa Musolini dan beberapa negara lain yang mengembangkan absolutisme.

Di beberapa negara termasuk negara Republik Indonesia bahwa perwujudan negara hukum lalu ditumbuhkan pembentukan undang-undang atau hukum

dalam bentuk undang-undang menjadi dominasi hukum dengan anggapan "hukum supermasi..." untuk segala-galanya sehingga tampak seperti kebanjiran hukum undang-undang yang tumbuh tidak efektif. Dalam ilmu pengetahuan hukum terlalu banyak undang-undang dapat disebut *"over-legislation"* dan *"sweeping-legislation"* yang kurang menyadari efektivitas norma sosial dan norma moral/agama di samping norma hukum.



Perkembangan Kriminalitas dalam Masyarakat Modern

Sejak masyarakat bangsa-bangsa beradab (1939) dan setelah para ahli bertaraf dunia mengintroduksi *"blue collar crime"* berkembang menjadi *"white collar crime"* telah tumbuh gejala meluasnya hukum sosial-ekonomi yang meliputi *"development, quality of life"* yang terkandung potensi perbuatan kejahatan *"crime against development, crime against social welfare, crime against quality of I ife."*

H. Sutherland mulai menunjuk bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat negara dan atau pengusaha yang merugikan masyarakat dan negara (1955/1960). Lebih jelas lagi ketika terbit *"Handbook on White Collar Crime"* di Amerika Serikat 1974. Nama istilah tersebut dikembangkan lagi oleh UNAFEI dalam Seminar in the Prevention and Control of Social and Economic Offences (1978) sehingga lebih terkenal dengan bentuk *"social-economic offences"* yang menjadi bagian dari kejahatan dalam hukum sosial-ekonomi.

Kejahatan dalam hukum sosial-ekonomik terkait dengan upaya tatanan sosial dan tatanan ekonomi di lingkungan regional, nasional, dan internasional sehingga dapat diartikan suatu bentuk kejahatan yang sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial negara menjadi bentuk kejahatan transnasional atau internasional. Karakteristik kejahatan sosial-ekonomi bersifat (1) perbuatannya diimplementasikan secara terselubung, misalnya berupa fasilitas dan kesempatan bagi si pemberi terhadap si penerima dalam hal penyuapan, (2) keahlian si pembuat kejahatan untuk memanfaatkan si korban baru merasakan menjadi viktimisasi setelah berselang beberapa lama sesudah kejadian kejahatan (*credit card fraud*), (3) kejahatan yang dilakukan dalam rangka perdagangan, perbankan, pemerintahan, kelembagaan keuangan lainnya misalnya *"banking violations by bank officer employees"* dan *"money laundering",* (4) kejahatan sebagai usaha *business* atau sebagai aktivitas penyalahgunaan kredit bank.

Kongres ke-7 PBB di Milan, Italia 1965 telah merekomendasikan tumbuhnya jenis *"industrial crime"* dan *"economic penalties"* dengan cam kebijakan *"social-policy"* dan *"criminal policy"* menurut konsepsi hukum "bersifat represif yang menggunakan tindakan penal dalam sistem peradilan pidana", dan konsepsi hukum prevensi upaya kemasyarakatan "bersifat *prevention without punishment*", serta "usaha pendayagunaan opini masyarakat atau melalui mass

media untuk sosialisasi hukum tentang anti kejahatan sosial-ekonomi" secara multiguna dalam masyarakat modern.

Kejahatan *money laundering* sebagaimana telah disebutkan di atas termasuk berkarakter kejahatan sosial-ekonomi itu memperoleh label kriminalisasi perbankan dan sosialisasi anti money laundering dengan sarana Undang Undang No. 15 tahun 2002 dan Undang Undang No. 25 tahun 2003.



Pengertian Kejahatan *Money Laundering*

Pengertian *money laundering* dalam kepustakaan belum terdapat definisi yang jelas, terjemahan bahasa Indonesia "pencucian uang" dan hanya untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan hukum diperoleh batasan bahwa:

> "*money laundering* adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah."

Penjelasan seperti tersebut di atas apa yang dinamakan *money laundering* dapat mengandung paling sedikit lima unsur yaitu:

1) Seseorang atau organisasi yang melakukan perbuatan,
2) Uang haram berasal dari tindak pidana,
3) Dengan maksud untuk menyembunyikan uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menindak terhadap tindak pidana,
4) Dengan cara memasukkan uang ke dalam sistem keuangan suatu negara,
5) Kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan yang dimaksud menjadi uang yang sah.

Sumber sejarah *money laundering* ada hubungannya dengan nama Al Capone tokoh kejahatan bersindikat dan lalu lintas perdagangan *illegal drug trafficking,* namun kemudian berkembang *money laundering* juga berasal dari uang kejahatan lainnya *"financial crime"*. Dalam istilah *"Dirty Money"* disebutkan bahwa telah beredar 500 miliar dolar sampai 1 triliun dolar, bahkan ada pula yang menyebutkan lebih dari 2,5-5,0 triliun dolar dari berbagai jenis kejahatan *dirty money* sudah memasuki sirkulasi di Bank Amerika Serikat, dan sumber lain di Kanada setiap tahunnya sekitar 5-14 miliar dolar pencucian uang ke dalam bank sampai tahun 1996.

Informasi tentang kegiatan *money laundering* seperti tersebut di atas terdapat kesan hanya negara-negara pembangunan perbankan sudah maju saja yang dilanda kejahatan *money laundering,* sedangkan bagi negara-negara yang sedang

berkembang *(under developing)* seolah-olah tidak tersentuh kejahatan *money laundering*.

Pro dan kontra untuk menyelenggarakan anti *money laundering* masih berkembang di dunia, kurang lebih ada 20 negara tidak setuju atau ragu-ragu untuk bersikap anti *money laundering* dengan berbagai alasan kondisi nasional perekonomian maupun perbankan ataupun kondisi keuangan (APBN) yang sering kali mengalami defisit sangat membutuhkan dana untuk menutup keuangan negara dengan cara membuka penanaman modal dari segala sumber keuangan. Dalam keadaan yang demikian di Indonesia tidak perlu ketat menghadapi keuangan yang terkait dengan *money laundering*.

Sinyalemen dari sudut pandang politik yang belum dapat dibuktikan secara hukum bahwa P. Marcos beserta keluarga di Philipina diprasangkai menjadi pelaku *money laundering*. Demikian pula mantan Presiden Soeharto di Indonesia yang mendapat prasangka *money laundering* di luar negeri berhadapan dengan tim pelacakan pun tidak berhasil membuktikan secara hukum. Reaksi mantan Menteri Keuangan RI kurang setuju bahwa Widjoyo Nitisastro berpendapat Indonesia masih dapat mengikuti kelompok negara kontra *money laundering* walaupun terdapat tekanan dari kelompok pro *money laundering*.

Berbagai alasan dari kelompok negara anti *money laundering* antara lain bahwa (1) *money laundering* menungkinkan para pengedar narkoba dan para pedagang yang melakukan kegiatan penyelundupan dapat memperlancar gerakan kejahatannya, (2) *money laundering* mempunyai potensi untuk meningkatkan kejahatan korupsi karena peredaran uang berjumlah banyak merangsang para koruptor, (3) *money laundering* mengurangi pendapatan pajak negara karena peredaran uang yang tidak legal, (4) *money laundering* dapat menggerakkan tindak pidana lain menurut cara-cara tersembunyi misalnya penipuan, pemalsuan, dan lain-lainnya yang dapat membuat kesibukan berkepanjangan petugas penegak hukum, (5) dapat mengakibatkan biaya sosial yang tinggi, (6) membahayakan usaha-usaha privatisasi dari perusahaan negara, (7) merongrong sektor swasta yang sah dan integritas pasar keuangan karena kegiatan bank-bank dimasuki unsur-unsur kejahatan yang terselubung, dan (8) pada akhirnya menimbulkan ketidakstabilan ekonomi negara dan atau ekonomi masyarakat.

Amerika Serikat sebagai negara besar yang sangat berkepentingan dengan pemberantasan *money laundering* membuat undang-undang yang pertama "*Money Laundering* Control Act 1986" di dunia agar menghentikan para penjahat yang menikmati pencucian uang hasil kejahatan dengan menginvestasikan uang di bank teristimewa dari hasil perdagangan gelap narkoba dan hasil korupsi pejabat negara. Sedangkan negara-negara lainnya (negara kontra) anti *money laundering* masih mentolerir peredaran *money laundering* dalam batas-batas tertentu sepanjang tidak mengganggu bank negara lain dan bank internasional.

Perbuatan kejahatan *money laundering* telah sedemikian tertutupnya tidak mudah diketahui oleh pemerintah atau oleh masyarakat institusi keuangan

karena proses tiga tahap yaitu (1) tahap *"placement"* dari uang hasil kejahatan itu didepositokan atau masuk rekening bank, kemudian ditarik keluar lagi dari bank dari seterusnya berganti dimasukkan ke bank lain berikutnya maka uang tersebut sudah menjadi legal, (2) tahap *"layering"* dengan cara sesudah tahap *placement* uang bank tersebut dipindahkan lagi dari bank satu ke bank yang lainnya pada negara yang menyelenggarakan rahasia perbankan yang ketat atau dengan cara seolah-olah melakukan transaksi *business* terpecah-pecah supaya tidak mencurigakan petugas negara, (3) tahap *"integration"* bahwa uang yang telah dicuci itu mondar-mandir di wilayah lembaga keuangan resmi pada suatu saat yang tepat menjadi uang halal dan bahkan sudah masuk dalam dunia perpajakan, maka kembali dalam jalur sirkulasi uang yang bersih untuk dipergunakan dalam investasi kegiatan real estate atau perusahaan lainnya.

Sedemikian hebatnya gerakan *money laundering* sehingga banyak negara di dunia tertarik untuk memasuki kelompok *money laundering,* manakala negara yang bersangkutan tidak mengalami kelemahan uang negara atau uang bank. Tumbuh kritik dari negara Meksiko bahwa gerakan *money laundering* justru menguntungkan Bank Amerika Serikat dengan mengalirnya banyak jumlah uang di bank maka modal uang bank di Bank Amerika Serikat semakin besar yang terbuka masuk uang tidak sah kemudian oleh para penjahat diproses menjadi uang sah. Demikian pula banyak yang menentang terhadap gagasan "penghapusan untuk membuka rahasia bank yang sudah ratusan tahun menjadi perlindungan terhadap privat nasabah bank dan pengamanan kekayaan uang di bank.



Model dan Perundang-undangan *Money Laundering*

1. Model *Money Laundering*

Cara-cara para pembuat *money laundering* melakukan kegiatannya dari hasil kejahatan itu supaya tidak dilacak asal usul uang oleh penegak hukum melalui lima kesempatan model:

a. Menyalahgunakan bisnis yang sah, dan menyembunyikan ke dalam bisnis yang dikendalikan oleh organisasi kejahatan yang terkait untuk mencegah kebocoran informasi dan kalangan dalam maupun dari luar perusahaan agar tidak diketahui oleh penegak hukum.

b. Menembus melalui sektor perbankan atau sektor non-perbankan, karena lewat bank perusahaan mekanisme yang paling dijadikan persembunyian uang hasil kejahatan, atau transaksi melalui jalur non-perbankan di sektor *money changer* yang masih ada kebebasan sirkulasi uang.

c. Upaya investasi di bidang real estate, dan atau di bidang asuransi oleh para pencuci uang untuk menanamkan uang pro-perumahan yang sangat

dibutuhkan masyarakat atau program asuransi yang jaminan hidup lebih murah. Selanjutnya kedua proyek dan program tersebut untuk beberapa lama lalu dijual lagi dengan sisa uang sudah menjadi uang sah.

d. Penyelundupan melewati batas negara (banyak dilakukan di Asia) dengan berbagai cara terselubung sehingga *money laundering* telah dilakukan pencucian menjadi sah.

e. Menembus melalui industri sekuriti (perdagangan efek-efek saham dan obligasi) yang menjadi sasaran untuk para penjahat *money laundering* yang wilayah operasionalnya mencapai tingkat internasional.

Tujuan dan maksud dari *money laundering* menikmati manfaat yang diperoleh uang kejahatan untuk menyulitkan petugas dalam penuntutan, dan selanjutnya menginvestasikan kembali untuk kegiatan kriminal di masa yang akan datang, atau untuk kegiatan usaha yang sah dalam jumlah uang besar supaya diserap peredaran investasi di sektor perbankan atau perusahaan bisnis lainnya. Manfaat kegiatan *money laundering* itu memperoleh kesempatan dari negara seperti Swiss yang menganut pendapat bahwa penempatan *money laundering* banyak memberikan keuntungan bagi pendapatan negara Swiss. Demikian pula negara Meksiko menganut pendirian bahwa uang hasil kejahatan tersebut diperlukan untuk menutup defisit perdagangan, dan justru di Amerika Serikat penampungan kejahatan *money laundering* menjadi sumber keuntungan yang besar bank-bank besar di Amerika Serikat. Apabila mencermati informasi mengenai *money laundering* seperti tersebut di atas tampak terjadi keadaan controversial kegiatan kejahatan *money laundering* di dunia sehingga sulit diberantas tanpa kebersamaan antarnegara.

2. Perundang-undangan *Money Laundering* Bersifat *Lex Specialis*

Ciri umum dari hukum *lex specialis* dalam undang-undang *money laundering* ditentukan oleh hukum pengecualian, yaitu bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang ditentukan menurut aturan KUHAP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang bersangkutan dalam Undang-Undang *Money Laundering* 2002. Memang banyak memuat aturan pengecualian atau penyimpangan dibandingkan dengan aturan umum yang bersifat *lex generalis*.

Paling sedikit terdapat 17 prinsip penyimpangan hukum dalam aturan tentang *money laundering* guna memperlancar penegakan hukum dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003:

a. Kualifikasi delik pada pembuat disamakan dengan delik percobaan, pembantuan, permufakatan sehingga delik selesai maupun delik tidak selesai disamakan terhadap ancaman pidananya.

b. Dalam waktu 3 hari sejak ada kecurigaan *money laundering* oleh petugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) wajib melaporkan kepada petugas penyidik.

c. Penyidik, penuntut, hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk memblokir apabila diketahui atau patut diduga terdapat uang sebagai hasil kejahatan dalam jumlah tertentu.

d. Penyidik, penuntut, hakim berwenang minta keterangan kepada Penyedia Jasa Keuangan mengenai uang hasil kejahatan yang dilaporkan oleh PPATK, dengan ketentuan seperti itu, maka perbuatan tersebut tidak akan terjadi pelanggaran rahasia bank.

e. Alat bukti perkara *money laundering* tidak dibatasi seperti KUHAP melainkan yang berkaitan dengan alat elektronik atau optic yang menjadi sumber informasi dapat dipakai menjadi alat bukti.

f. Mengandung limitasi minimum pidana dan maksimum pidana (5-15 tahun) dan denda paling sedikit lima miliar dan lima belas miliar.

g. Perkara *money laundering* mengenal peradilan in absentia walaupun terdakwa tidak hadir tetap diputus pengadilan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, sepanjang sudah dipanggil secara layak, dengan tujuan perkara menyelamatkan hasil kejahatan yang menjadi *money laundering*.

h. Mengenal sistem pembuktian terbalik dengan cara "terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana". Ketentuan pembuktian terbalik di sini agak berbeda dari cara pembuktian terbalik dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena pembuktian terdakwa diperlukan apabila dapat menguntungkan terdakwa.

i. Perintah hakim untuk melakukan penyitaan harta kekayaan karena sejak tingkat penyidikan belum ada tindakan penyitaan harta kekayaan.

j. Hakim dapat membuat penetapan tentang perampasan harta kekayaan ketika terdakwa sudah meninggal sebelum sampai pada putusan hakim dijatuhkan dengan syarat pada tingkat persidangan telah terbukti yang meyakinkan sebelum putusan hukuman karena dinyatakan bersalah *(presumption of innocence)*.

k. *Money Laundering* merupakan kejahatan uang berasal dari sejumlah kejahatan (± 25 jenis kejahatan lain) dan menjadi objek pencucian uang pada Jasa Pelayanan Uang yang apabila berhasil menjadi uang sah. Alur pemikirannya harus terjadi hasil uang dari tindak pidana tertentu, lalu diproses melalui pencucian uang *(proceed of crime* beralih ke *predicate crime/ predicate offences)*.

l. Badan *public participation* dan posisi yang independent dengan tugas interogatif, tetapi lebih mendekati tugas *financial intelligence* membantu penyidik untuk tugas peradilan perkara *money laundering*. Sebagai tugas pelajar badan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan harus menjalankan tugas yang cermat demi kepentingan hukum keuangan.

m. Perbuatan asal kejahatan (± 25 kejahatan) yang tersalur ke kejahatan *money laundering* sebagai hukum Indonesia yang berlaku di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia dalam arti *"double criminal system"*.

n. Kejahatan yang dilakukan dalam teori fiksi oleh korporasi atau atas nama korporasi sebagai subjek delik untuk perluasan delik dalam kejahatan *money laundering*.

o. Suatu ketentuan yang mewajibkan petugas tertentu tidak boleh memberitahukan kepada nasabah tentang suatu laporan transaksi keuangan yang ada hubungannya dengan nasabah yang dimaksud *"tipping off"* yang memungkinkan nasabah melarikan diri atau mengubah siasat untuk mengelabui penyidik. Perbuatan pembocoran oleh petugas kepada pembuat delik *money laundering* ini dikategorikan pelanggaran hukum berat.

p. Aturan mengenai wajib laporan transaksi keuangan oleh pihak Penyedia Jasa Keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam waktu tiga hari. Hal ini pun petugas tidak melanggar kerahasiaan bank.

q. Perlindungan saksi dan pelapor mewajibkan penyidik, penuntut, hakim dilarang menyebut saksi dan pelapor supaya tidak membahayakan keselamatan dari ancaman pembuat delik. Apabila terjadi pembocoran tersebut, berakibat tuntutan ganti rugi dari saksi atau pelapor kepada petugas hukum yang terbukti membocorkan.

Praktik kegiatan kejahatan *money laundering* tidak mudah untuk diberantas disebabkan ada beberapa faktor penyebab: (1) globalisasi kejahatan internasional dan *organized crime* perdagangan narkoba yang menghasilkan uang untuk dicuci dalam jasa pelayanan keuangan melalui bank pemerintah maupun bank swasta yang membutuhkan investasi, (2) kemajuan teknologi informasi/internet yang mendorong kemajuan kejahatan lintas batas negara sebagai kejahatan yang bersifat lintas batas atau kejahatan transnasional, (3) himbauan internasional tentang ketatnya rahasia bank menimbulkan pengawasan bank menjadi sulit seperti di negara Luxemburg dan Austria yang mengikuti sistem bank Swiss, (4) perkembangan Cyberlaundering melalui kemajuan elektronik bank atau *elektronik money* mempermudah transfer uang yang mengatasi kecurigaan pencucian uang bagi para pelaku kegiatan *money laundering*, (5) kemungkinan kerja sama antara Lawyer yang memberanikan diri menggantikan nama pemilik uang sebenarnya dalam arti tugas mengacara mewakili klien sehingga terjadi transfer berlapis, dan (6) masih banyak negara yang enggan mengikuti gerakan anti *money laundering* secara diam-diam.



Tindak Pidana *Money Laundering* Belum Ada di Indonesia

Penelitian tentang *money laundering* sampai tahun 2002 belum terjadi di Indonesia. Menurut penelitian disertasi oleh Yenti Ganarsih di University of Washington, School of Law, Seattle (2000) data perkara cukup banyak di Amerika Serikat dari tahun 1978-1987 sehingga kejahatan *money laundering* seolah-olah berpusat di Amerika Serikat dan kemudian pelariannya menyusul di negara Canada.

Pada saat bersamaan di Indonesia dan beberapa negara Asia serta negara Eropa (Luxemburg dan Austria) menentang kriminalisasi *money laundering* karena negara yang dimaksud membutuhkan banyak investasi keuangan sehingga tidak perlu peraturan dari mana asal-usul uang yang ditransfer ke bank atau Jasa Pelayanan Keuangan. Atas dasar tekanan internasional untuk prevensi kejahatan *money laundering* maka Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 sebagai undang-undang yang tidak berlaku efektif karena tidak pernah diterapkan secara konkret, dalam kepustakaan hukum sering disebut *"over legislation"*.

Tekanan internasional mulai nyata di Indonesia, karena (1) Indonesia meratifikasi (1997) United Nation Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, (2) dan sekaligus (1997) menjadi anggota Asia-Pacific Group on *Money Laundering*, dan (3) karena relevan dengan pemberantasan narkotika dan korupsi yang menjadi kemungkinan untuk transfer hasil kejahatan tersebut, maka dibentuk Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang *Money Laundering*.

Kondisi kejahatan *money laundering* di Indonesia (2008) yang hampir tidak ditemukan, dan budaya hukum yang kurang menggejala anti *money laundering* seperti tersebut di atas, dapat diperoleh kesan bahwa kejahatan hasil "narkoba dan korupsi" belum berbahaya bagi hukum keuangan publik dan hukum privat maupun belum menjadi kejahatan serius dalam hukum sosial-ekonomi. Dalam hal yang demikian itu tidak perlu menjadi prinsip hukum pidana konvensional, tetapi dimungkinkan penembangan hukum pidana dalam teori alternatif dan teori utility dalam arti *"criminal law of dynamical on criminal without the punishment (non penal)"*. Dengan demikian, ajaran hukum pidana tentang "kriminalisasi dan dekriminalisasi" bisa masih berkembang luas karena karakter hukum pidana bersifat ambivalensi. Kebutuhan hukum pidana di Indonesia harus mempertimbangkan kepustakaan "Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa-Regulasi" dari L.H.C. Hulsman/Wonohito, yaitu mempertimbangkan motif baik bagi pelaku maupun korban.

Daftar Referensi

Ancel, Marc. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem*. London: Rontledge & Kegan Paul, 1965.

Garnasih, Yeni, 1(X)7, Kriminalisasi Pencucian Uang (*Money Laundering*), Universitas Indonesia, Fak. Hukum, Pascasarjana, Jakarta.

Hartjen, Clayton, A. *Crime and Cirminalization*. New York: Prayer Publicer, 1974.

Sjandeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Grafiti, 2007.

Shutherland, H, Etal. *Principle of Criminology,* 6ed, JB. New York: Lippincott. 1960.

RAJAWALI PERS

17

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MENGHADAPI PERKEMBANGAN KEJAHATAN EKONOMI GLOBAL

Oleh:
*Dr. Supanto, S.H., M.Hum.**



Pengantar

Masyarakat dan negara dunia sudah menjadi satu, perubahan terjadi sangat cepat, disertai keterbukaan hubungan antarbangsa dan negara, yang tiada batas-batas kekuasaan, pasar, pemanfaatan teknologi, aliran barang dan jasa, serta pengetahuan manusia. Perubahan di suatu wilayah dapat ikut menentukan perubahan di wilayah lain secara global. Norma-norma, tatanan, ikatan yang mendunia menelusup dan menguasai segala kompleksitas dan keanekaragaman lokal, identitas etnik–bangsa sehingga melahirkan penyeragaman, yang barang tentu berakibat ketidakseimbangan terjadi di antara negara-negara, komunitas-komunitas kekuasaan dan penguasaan aneka sumber daya.

Perkembangan globalisasi, khususnya ekonomi bermuatan ekses positif maupun negatif. Dalam hal ini perlunya peran hukum dalam kehidupan perekonomian, yang bersifat nasional maupun internasional, yang tidak dapat dibedakan lagi karena pengaturan hukum sudah menjadi global. Sehubungan dengan potensi kriminal terkait dengan pendayagunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan.

Hukum pidana dan penegakannya merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*), politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang mencakup pula penegakan hukum perdata dan penegakan hukum administrasi. Politik penegakan hukum merupakan bagian politik sosial (*social policy*) yang merupakan usaha setiap masyarakat dan

*Dosen Fakultas Hukum UNS dan Program Pascasarjana UNS.

negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.[1] Hal ini sejalan dengan *a systematic approach to crime prevention planning* sebagaimana diintroduksi Kongres PBB VIII mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (1990).

Situasi global memunculkan tipe kejahatan berdimensi baru khususnya di bidang ekonomi, yang berkembang sebagai kejahatan ekonomi global. Ini menjadi tantangan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam hal penggunaan piranti hukum pidana terdapat ganjalan yang perlu diperhatikan. KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana yang peninggalan sejak pemerintah Hindia Belanda telah tertinggal dengan kondisi sekarang ini. Demikian pula pengaturan hukum pidana ekonomi dalam UU No. 7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, sudah berusia 53 tahun, dan sudah melewati beberapa orde kekuasaan, baik orde lama, orde baru, maupun kini orde reformasi, yang barang tentu berbeda visi dan misinya mengenai pembangunan ekonomi, namun undang-undangnya tetap sama. Sementara itu, karena tuntutan perkembangan kehidupan perekonomian nasional maupun internasional dalam era global, telah banyak dikeluarkan produk perundang-undangan perekonomian, yang memuat ketentuan hukum pidana.



Situasi Global

Globalisasi yang didasarkan pada model ekonomi baru, bercorak neoliberalisme berjalan sangat lancar bagi kepentingan negara-negara besar. Doktrinnya telah mendorong negara-negara mengintegrasikan ekonominya ke dalam satu ekonomi global tunggal. Doktrin ini meliputi liberalisasi perdagangan dan arus keuangan, deregulasi produksi, modal dan pasar tenaga kerja, serta merampingkan peran negara, terutama yang berkaitan dengan progam pembangunan sosial dan ekonomi.[2] Globalisasi dirasakan sebagai suatu kekuatan "yang menggilas segala sesuatu yang ada di jalannya" *(juggernaut)*. Kekuatan ini membawa perubahan sosial besar yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan kultural dunia. Di Indonesia ketidakpastian ini sudah terasa antara lain terlihat pada keprihatinan terhadap kedaulatan ekonomi dan kebudayaan Indonesia, juga mengancam "negara kebangsaan" Indonesia dengan konsepnya ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]

---

[1]Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar 24 Februari 1990, (Semarang: Universitas Diponegoro. hlm 6).

[2]Mohammad Amien Rais, *Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!,* (Yogyakarta: PPSK Press, 2008). hlm. 25.

[3]Mardjono Reksodiputro, *Multikulturalisme dan Negara-nasion serta Kejahatan Transnasional dan Hukum Pidana Internasional (Pemikiran Awal dan Catatan untuk Direnungkan)*, Seminar Nasional dan Kongres PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI MENGHADAPI KEJAHATAN TRANSNASIONAL, diselenggarakan ASPEHUPIKI 17 Maret 2008, Bandung. hlm. 2.

Kekuatan globalisasi melalui kesepakatan dagang, deregulasi, dan privatisasi, sangat melemahkan negara-bangsa dalam bertindak menurut kebebasan politiknya. Kemudian menyusul kevakuman politik, yang kemudian dipenuhi alternatif-alternatif moderen yang sudah nyata, yaitu perusahaan multinasional/transnasional. Perusahaan tersebut lebih kaya melampaui negara-negara bangsa, akan mampu mengatasi persoalan-persoalan dunia secara lebih rasional dan efisien. Sehubungan perusahaan tersebut terbebas dari beban kewajiban yang dipikul negara bangsa (yang sudah melemah), seperti tuntutan nasionalisme, dan emosional warga negara.[4] Dalam dunia ekonomi sangat dipengaruhi oleh global *capitalism* yang dikendalikan dan dimanipulasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional atau transnasional (MNC dan TNC). Yang turut juga mendorong perubahan-perubahan sosial di negara berkembang adalah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, yang tentunya juga memengaruhi kecepatan transaksi dalam pasar uang dunia (*global finance market)*.[5]

Pengaturan hukum yang bersifat global, seperti HaKI, investasi, persaingan usaha, beroperasinya perusahaan-perusahaan MNC dengan kuatnya merambah dan harus diterima dalam kehidupan masyarakat dan negara Indonesia (termasuk yang bersangkutan dengan hukum), jika memang para pelaku usaha Indonesia ingin melakukan kegiatan ekonominya secara mendunia. Sebaliknya, pengaturan hukum yang asli, kinerja perusahaan dan para pelaku bisnis, bahkan segala sumber daya dan kultur perlu dikreasikan sesuai persyaratan global. Fenomena ini sesuai dengan sebutan *globalized localism* ataupun *localized globalism*, sebagaimana diuraikan oleh Boaventura de Sousa Santos.[6]

Program pembangunan berada dalam suatu keadaan yang tidak dapat ditawar, yakni kehidupan ekonomi yang telah mengglobal, sementara itu muncul banyak problem dalam level nasional mengenai stabilitas, keamanan, rasa memiliki, dan rasa persatuan. Terjadinya kebebasan ekonomi yang merusak masyarakat dan kehidupan sosial. Singkatnya kebebasan ekonomi yang terus-menerus kemungkinan memusnahkan masyarakat dan kehidupan sosial, serta permasalahan pengendalian ekonomi agar keselamatan masyarakat menjadi agenda kembali. Oleh karena itu, perlu meyakinkan sekali lagi pentingnya masyarakat dan membuatnya-ekonomi berdampingan-secara terpadu dengan konsep pembangunan dan kemajuan. Penegasan ini disampaikan oleh Ramesh Mishra.[7]

Gambaran tersebut menunjukkan hubungan yang kait-mengait antara pembangunan ekonomi dengan kehidupan politik. Lebih tegas lagi ditunjukkan

---

[4]John Ralston Saul, *The Collapse …, op.cit*. hlm. 146.
[5]Mardjono Reksodiputro, *Multikulturalisme …, op.cit*. hlm. 3.
[6]Boaventura de Sousa Santos, *To Ward a New....., op.cit*. hlm. 263.
[7]Ramesh Mishra, *Beyond the Nation State: Social in an Age of Globalizaion*. SOCIAL POLICY AND ADMINISTRATION Vol. 3 No. 5, December, 1998, USA: Blackwell Publisher Ltd. hlm. 485.

bahwa, pertama, upaya pemulihan ekonomi tidak dapat dilakukan dalam vakum. Proses politik telah berjalan dengan dinamika yang tinggi. Pada masa sebelumnya pertumbuhan ekonomi didukung oleh investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang luas, dan dapat meredam berbagai permasalahan sosial. Krisis ekonomi membuka berbagai jenis konflik sosial yang menghambat proses pemulihan ekonomi.[8] Kedua, ketidakmampuan para elite politik mengakhiri konflik-konflik politik yang terjadi, yang tidak hanya akan memacu instabilitas politik, tetapi juga memperparah kesulitan ekonomi yang mengakibatkan masyarakat Indonesia terpuruk dalam kemiskinan.[9]



Kejahatan dalam Perkembangan Ekonomi Global

Berdasarkan laporan Kongres PBB VI tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* (1980 di Caracas), diidentifikasikan bentuk-bentuk penyimpangan di bidang ekonomi (*economic abuse*).[10] Guiding principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order (United Nation Congres VII on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders) menentukan *protection against industrial crime, economic crime.*[11] Pada 1991 diselenggarakan Kongres PBB: *The Prevention of the Treatment of Offenders* ke VIII,[12] yang dalam rekomendasinya mengenai *Crime prevention and criminal justice in the context of development*. Dalam Kongres PBB VIII tersebut dirumuskan problem *corruption in public administration* menyebabkan kerusakan dan melemahnya ekonomi. Keprihatinan dikemukakan Kongres PBB VIII mengenai *the increase in the abuse of computers,* pengakuan secara serius terhadap kejahatan: *transnational crimes*, yang merusak *the political and economical stability of nation*, yang perkembangannya *sophisticated and dynamic*. Kongres PBB IX tahun 1995[13] menyepakati perlunya memerangi *organized crime*. Pada tahun 2000 diselenggarakan Kongres PBB[14] menentukan *International Cooperation in Combating Transnational Crime*: New Challenges in the Twenty-first Century.

---

[8]Umar Juoro, *Krisis …, op.cit*. hlm. 29.

[9]Ignatius Ismanto, *Jalan …, op.cit*. hlm. 251.

[10]Report of The United Nations Congress VI, hlm. 67. Rinciannya: *(a) tax evasion, (b) credit and custom fraud, (c) embezzlement of public funds, (d) misappropriation of public funds, (e) violations of currency regulation, (f) speculation and swindling in land transaction, (g) environmental offences, (h) over pricing, (i) over invoicing, (k) labour exploitation, (l) export and import of sub-standard and even dangerously unsafe products.*

[11]The Secretariat *Sevent United Nations Congress of the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, 26August- 6 september 1985. (New York: United Nations, 1986), hlm 9.

[12]Eighth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 27 August-7 September 1990, (New York: United Nations, 1991).

[13]Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, (Cairo 29 April – 8 May 1995).

[14]Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender (Vienna 10-17 April 2000).

Pengelompokan oleh Trasman mengenai *economic crime* terdiri dari dua kategori. Kategori pertama, meliputi *the illegal forms of economic activity, illegal gambling, concealing stolen goods, organized procuring among them*. Jadi merupakan keseluruhan kegiatan yang bersifat ilegal. Kategori kedua, mencakup tindak pidana yang dilakukan dalam perusahaan yang bersifat ekonomis (*the economic enterprise*). Tindak pidana tersebut adalah: (1) *the abuse of invested capital and acts causing damage to economic partners, shareholders, etc.*, (2) *the abuse of deposited capital and acts causing damage to creditors, guarantors, etc.*, (3) (*the abuse of labour, directed against employees and workers, the violations of consumers' rights*, (4) *acts against competitors*, (5) *the illegal exploitation of nature and acts damaging the environment*, dan (6) *offences violating the interests of the state*.[15]

Sue Titus Reid menggunakan istilah *business–related crime*, yang ketika membicarakan WCC dikaitkan dengan *corporate crime* dan kejahatan ekonomi lainnya. *Corporate crime* merupakan salah satu bentuk WCC, dan bercirikan sebagai *organizational crime*.[16] Richard Quenney menyebutkan adanya *crimes of the economy*, yang terdiri dari *crime against the worker*, *occupational and professional crime*, *corporate crime*, dan *organized crime*.[17]

Jaringan pengaturan global serta hubungan kelembagaan negara nasional dalam relasi birokrasi internasional, ternyata melibatkan pula peran dari *non-state source* yang mempunyai kekuasaan mengalokasikan nilai dan pengaruh pembagian sumber pendapatan, seperti: *outlaw business (such as drug cartel, the mafia), professional association, transnational social, political, and religious movements*.[18] Menyangkut mafia berbentuk kejahatan terorganisasi, sindikat kejahatan, berasal dari orang-orang Cina, Rusia, Jamaika, dan latar belakang etnik lainnya. Usahanya mengalahkan bisnis legal masyarakat, dengan dilakukannya siasat godaan mencari keuntungan secara cepat dan meluas dalam investasi maupun bidang lainnya yang mengancam kehidupan dana tabungan investor. Sumber pendapatan negara kecil mudah diserang dan menjadi korban. Uang hasil kejahatannya dilakukan *money laundering* yang dipergunakan untuk memasuki dan merongrong bisnis yang sah, menyuap pemerintahan, dan membiayai terorisme.[19]

Penyalahgunaan komputer untuk kejahatan bersamaan meluasnya pemakaian komputer yang hampir universal, untuk memenuhi kebutuhan kemu-

---

[15]Imre A. Wiener, *Economic …, op.cit.*, hlm. 16.

[16]Sue Titus Reid, *Crime and Criminology, (*USA: McGraw Hill Higher Education, 2000), hlm. 248-268.

[17]Richard Quenney, *Criminolgy, (*Boston: Little Brown and Company, 1979), hlm. 191.

[18]Nicola Yeates, *Social Politic and Policy in Era of Globalization: Critical Reflection,* SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION Vol. 33, No. 4, December, (USA: Blackwell Publisher Ltd, 1999), hlm. 382-383

[19]Gerhard O.W. Mueller, *The Globalization of Life and Earth, of Crime, and of Crime Prevention,* dalam Albin Eser & Otto Lagodny, Principles Procedures for a New Transnational Criminal Law, (Freiburg: Max-Plank-Instite), 1992. hlm. 353.

dahan *interconnecting computer worldwide*. Ini menimbulkan dua tipe kejahatan komputer, yakni (1) tujuan *profit*, namanya *computer fraud*, dan (2) tujuan *terrorism or mischief*, namanya *the creation of computer viruses or rub-outs (computer sabotage)*.[20]

Berkembangnya teknologi informasi ditandai maraknya aplikasi internet di dunia bisnis mendorong percepatan globalisasi perdagangan, berdampak pula terhadap perkembangan kejahatan transnasional. Bentuk dan dimensinya membuat sulit penanganannya dalam sistem peradilan pidana nasional. Kejahatan tersebut secara berurutan disebutkan: (1) *the international drug trade*, (2) *environmental criminality*, (3) *transnational economic criminality, including international organized criminality, money laundering and computer criminality*, (4) *maritime crime*, (5) *political aggression, suppression, and corruption,* dan (6) *terrorism.*[21] Perhatian khusus yang berhubungan dengan kejahatan ekonomi perlu diuraikan. *Pertama*, kejahatan ekonomi mengadopsi cara bekerja yang sulit dibedakan dengan kegiatan komersial yang normal. *Kedua*, kejahatan ekonomi melibatkan individu yang secara ekonomi sukses keberadaannya di mata masyarakat. *Ketiga*, banyak kehadiran kejahatan ekonomi merupakan tantangan khusus bagi aparat penegak hukum, sistem peradilan pidana, dan kebebasan masyarakat.[22]

Kejahatan ekonomi dilihat bentuknya *(styles of economic crime)* ada dua. *Pertama,* kejahatan yang dilakukan oleh kalangan pengusaha bersamaan kegiatan bisnis yang biasa dilakukannya. Tanggung jawab pengusaha mengandung kesempatan untuk melakukan kejahatan, misalnya: penggelapan, pelanggaran peraturan mengenai kegiatan bidang bisnis, penyimpangan kewajiban pajak. Inilah yang sering disebut *white collar crime*. *Kedua,* perbuatan perdagangan/produksi barang dan jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang *illegal*/tidak sah. Perbuatan ini dikoordinasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang biasa secara normal, namun di dalamnya digunakan cara-cara yang bersifat kejahatan. Hal ini sering dinamakan *organized crime*. Kejahatan ini memerlukan koordinasi sebagai kegiatan ekonomi di luar hukum, dengan formasi kerja sama secara organisatoris dalam praktiknya terdiri dari kelompok-kelompok penjahat, dan sudah menjadi kebiasaan.[23] Dengan demikian, dapat dideskripsikan mengenai kejahatan di bidang ekonomi global, dari segi pelakunya merupakan WCC, tidak lagi perseorangan melainkan oleh korporasi, maka dinamakan *corporate crime*, segi pengelolaannya sebagai *organized crime*, dan lingkup beroperasinya tidak hanya secara nasional melainkan melampaui batas-batas negara terkait

[20]Gerhard O.W. Mueller, *ibid*.

[21]Gerhard O.W. Mueller, *The Globalization …, op.cit*. hlm. 251.

[22]Edmund W. Kitch, *Economic Crime Theory*, dalam Leonardo Orland (ed.), Corporate and White Collar Crime: An Anthology, (USA: Anderson Publishing Co, 1995), hlm. 14.

[23]Edmunt W. Kitch, *Economic Crime Theory*, dalam Leonardo Orland (ed.), Corporate and White Collar Crime, (USA: Anderson Publishing Co, 1995), hlm. 14.

globalisasi ekonomi sebagai *transnational crime*, dan modusnya memanfaatkan kemajuan IPTEK sebagai *high-tech crime*.

Tindak pidana di bidang ekonomi yang bersifat global oleh karena itu melingkupi antarnegara/transnasional, dilakukan oleh *organized crime group*, dalam hal ini bisa ditunjukkan seperti La Cosa Nostra sebagai kelompok organisasi kejahatan yang beroperasi di Amerika Serikat, mereka mengekalkan dan terus-menerus melakukan berbagai tindak kejahatan, dan diorganisasi secara *hierarchis*. The Boryokudan merupakan organisasi kejahatan yang lahir dan berkembang di Jepang, selanjutnya meluas sampai Amerika Serikat. Triads beroperasi pusatnya di Hong Kong, Republik Rakyat Cina, dan Taiwan. Italian Organized Crime Groups beroperasi di Italia dan merambah ke seluruh Eropa. Kelompok ini bisa disebutkan the Sicilian Mafia or Sicilian Cosa Nostra, the Camorra, the Ndrangheta and the United Sacred Crown. South American Drug Cartels seperti the Cali and Medillin drug cartels, banyak pengaruhnya dengan perluasan kegiatan peredaran obat terlarang dan jaringan *money laundering*. Russian Organized Crime Groups beroperasi di Rusia dan tersebar ke luar.[24]

Sehubungan dengan *organized crime*, sebagaimana Mafia, dijelaskan Raymond P. Green[25] bahwa dalam perundang-undangan Amerika Serikat disebutkan United State of America Code (*U S Code*), ada pengaturan yang disebut *Racketeer Influenced and Corrupt Organizations* ("RICO") Act. Pengaturan ini ditujukan untuk memerangi *organized crime* dengan tindakan baik secara hukum pidana maupun hukum perdata, agar dapat memecah kekuatan organisasi kejahatan, seperti mafia, dari berbagai perusahaan yang sah maupun yang terlarang.

Peningkatan kejahatan terorganisasi menjadi dikenal berkaitan dengan korporasi, atau sebagai *"a continuing criminal enterprise"*. Yang dijelaskan bahwa "*organised crime*" merupakan pelanggaran hukum yang direncanakan untuk mencari untung atau meraih kekuasaan, yang masing-masing tindak pidananya, atau bersama-sama, atau yang paling pokok, dilaksanakan oleh lebih dari dua peserta yang bekerja sama dalam pembagian pekerjaan untuk rentang waktu

---

[24]Frank J. Marine, The Threat Posed by Transnational Crimes and Organized Crime Groups, Resource Material Series No. 54, (Tokyo: UNAFEI, September 1999), hlm 35 –37.

Di Jepang, *the Boryokudan* istilah resmi untuk menunjuk *organized crime group*. Terdapat pengaturan *"Legislation relating to Prevention of Unjust Acts by Boryokudan Members"*, dalam Pasal 2 didefinisikan *the Boryokudan as follows: a groups whose members are prone and encouraged to perpetrate violent illegal acts collectively or chronically*. Boryokudan umumnya disebut YAKUZA, yang secara tradisional mempunyai sejarah panjang. Dalam pengertian modern YAKUZA termasuk Ba-Ku- To (yang lebih pada penjahat dalam perjudian), dan Te-Ki-Ya lebih merupakan kelompok penjahat pada umumnya, beserta kelompok kejahatan lainnya, sering disebut San-Go-Ku-Jin, yakni orang-orang dari tiga bangsa (Cina, Taiwan, Korea) di Jepang. Lihat Hisao Katoh, *Prohibition of The Money Laundering as A Countermeasure against Organized Crime Groups (Yakuza or Boryokudan) in Japan*, KEIO LAW REVIEW No. 7-1994, The Association for the Study of Law and Politics, Faculty of Law, (Keio University, Japan), hlm. 26-28.

[25]Raymond P. Green, *The Application of RICO to Labor-Management and Employment Disputes*, St. THOMAS LAW REVIEW, 309, Spring 1995, http://www.stthomas.ed/law (17 Juli 2008). hlm. 1.

yang panjang dan tidak terbatas, yang menggunakan: *–commercial or commercial–like structures*, atau – *violence or other means of intimidation,* atau – *influence on politics, media, public administration, justice and the legitimate economy*.[26]

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk WCC, yang mewujud dalam berbagai jenis kejahatan ekonomi. Yang dibedakan: 1) *crime for corporation*, 2) *crime against corporations*, dan 3) *criminal corporations*. Yang pertama, sebagai kejahatan korporasi dalam arti sesungguhnya (*corporate crime*). Yang kedua sering disebut sebagai *employee crime*, dan yang ketiga merupakan korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Dilihat motivasi timbulnya kejahatan korporasi, terletak pada tujuan organisasi yang berupa pengutamaan perolehan keuntungan sebesar-besarnya dengan ciri-ciri individual sebagai *anomie success*, serta kontradiksi antara tujuan-tujuan korporasi dengan kepentingan pesaing, negara, staf, konsumen dan masyarakat.[27] Kejahatan korporasi pada hakikatnya merupakan WCC, yang mencakup tindakan ilegal yang dilakukan secara *akal-bulus*, penipuan, penyembunyian, dan tidak digantungkan pada penindakan paksaan fisik maupun ancaman kekerasan. Dalam hal ini lebih sering disebut sebagai *economic crime* sebagai perbuatan pelanggaran hukum dalam arti luas terhadap kehidupan perekonomian.

Organized crime memasuki kehidupan ekonomi-bisnis yang kelihatannya tampak legal, namun tidak meninggalkan wataknya berupa tindakan pemalsuan, pengancaman ataupun pemerasan. Yang diwujudkan dalam bentuk menjalankan, di antara kategori berikut ini. *Pertama*, secara langsung atau tidak langsung melakukan investasi dalam perusahaan yang bergerak di bidang bisnis, uangnya yang berasal dari kegiatan yang termasuk dalam formula *racketeering*, atau yang berasal dari penagihan utang yang ilegal (*unlawful debt*). *Kedua*, mendapatkan keuntungan dari suatu perusahaan melalui cara-cara yang termasuk ke dalam kegiatan dengan formula *racketeering* atau yang termasuk ke dalam penagihan utang yang ilegal. *Ketiga*, menjalankan perusahaan/berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan melalui formula *racketeering* atau penagihan terhadap utang yang ilegal. *Keempat*, ikut berkonspirasi dalam melakukan pelanggaran ketentuan tentang *racketeering*.[28]

Potensi Indonesia bagi perkembangan *organized crime*, Adrianus Meliala menjelaskan, bahwa dalam memenuhi kebutuhan dunia akan narkoba, sindikat narkoba internasional memisahkan tempat-tempat untuk kultivasi dan produksi. Untuk itu, mereka mencari tempat yang dikategorikan sebagai *soft state*,

---

[26]Michael Levi, *Combating White –Collar and Organized Crime: Some Key Dilemmas for Democratic Societies*, KOBE UNIVERSITY LAW REVIEW, International Edition, No. 32, Kobe, (Japan: Faculty of Law, 1998), hlm. 51.

[27]Muladi dan Dwidja Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana,* (Bandung: Bag. Penerbitan STIHB, 1991), hlm. 174 -175.

[28]Munir Fuady, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih, (*Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 5.

yakni negara-negara yang pemerintahannya lemah, aparat penegak hukum dan birokrasinya mudah ditembus, serta administrasi kependudukannya kacau. Indonesia dapat termasuk dalam kategori ini.[29] Kemudian paparan Ronny Nitibaskoro, bahwa di Indonesia telah hidup jaringan sindikat narkoba yang sangat sistematis, yang menyerupai organisasi kejahatan yang selama ini dikenal di berbagai negara, seperti Mafia Sisilia, Triad China, Yakuza Jepang, atau Kartel-kartel di Kolombia. Organisasi kejahatan itu juga dijalankan oleh warga negara Indonesia yang menjadi kepanjangan dan binaannya, yang bermarkas besar di negara lain. Transnasionalisasi organisasi kejahatan itu didukung juga oleh perdagangan bebas, sistem keuangan global, kemudahan transportasi, dan teknologi komunikasi.[30] Sehubungan dengan ini, Mardjono Reksodiputro mengetengahkan adanya "kejahatan terorganisasi berdimensi global" (KTO Global), yang harus diwaspadai karena merupakan kelompok yang bisa jadi menguasai kekuasaan ekonomi maupun politik pada masyarakat yang sedang dalam masa transisi demokrasi. Mereka menginfiltrasi pemerintahan dan menyuap para pejabat, hakim, dan penegak hukum lainnya, dan juga di Indonesia bisa mengobarkan konflik antargolongan, mempersenjatai kelompok yang bertikai melalui penjualan senjata ilegal, mencari dana dengan menjual narkoba, *trafficking*, korupsi (penyuapan pejabat publik), serta membantu melarikan aset korupsi ke luar negeri (*money laundering*).[31]

Sehubungan dengan perkembangan IPTEK, membawa persoalan penyimpangan dalam kegiatan siber. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kenyataan bahaya kegiatan siber sebagaimana kelakuan para *craker* dan *hacker* dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas dan fatal, contohnya: gangguan terhadap situs Komisi Pemilihan Umum atas data Pemilu, pemadaman aliran listrik di Washington, perusakan sistem kontrol penerbangan di Kansas, Amerika Serikat.[32] Ditambahkan, dalam dunia maya dikenal istilah *hacker,* yaitu orang-orang yang "keranjingan" mempelajari seluk beluk komputer, program dan jaringan komputer, mengakses sistem keamanan komputer, namun dengan tujuan baik, justru memberikan saran perbaikan, penemuan baru. Ini sering disebut sebagai *hacker topi putih*. Sebaliknya, terdapat tindakan-tindakan semacam itu (*hacking*) bertujuan jahat, merusak, melakukan *unauthorized acces,* memanfaatkan informasi *hacker* untuk

[29]Redaksi, *Mafia Pilih Negara Yang Rapuh*, KOMPAS , Senin 26 November 2007. hlm 11.

[30]*Ibid*. Ditambahkan di sini adanya mafia penggundulan hutan (*illegal logging*) seperti di Kalimantan yang melibatkan para pejabat, penegak hukum, dan para cukong luar negeri (Malaysia). Laporan Utama Tempo Edisi 14-20 April 2008, hlm. 102-111.

[31]Mardjono, Reksodiputro, *Multikulturalisme …. op.cit*. hlm. 11.

[32]Ahmad M. Ramli, et.al. (tim Penyusun), *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik,* Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2007. hlm. 2, 4.

kejahatan, pelakunya dinamakan *hacker topi hitam*. Inilah yang dinamakan *cracker*, atau *bogus hacker* (vandal komputer).[33] *Hacker* (topi putih) perlu dimanfaatkan untuk mencegah kejahatan siber. Mereka berkemampuan di bidang komputer mengenai software, hardware, arsitektur, administrasi, dan lain sebagainya, sehingga dapat membangun pengamanan dunia maya, serta dimanfaatkan untuk melawan tindakan hacker bertujuan jahat (hacker topi hitam atau *cracker*).

Kejahatan siber dibedakan dalam dua jenis *(subcategories of cyber crime)*:

(a) *cyber crime in a narrow sense ("computer crime")*: berbagai perilaku penyimpangan/ilegal yang dikendalikan langsung dengan alat yang bekerja secara elektronik dengan sasarannya keamanan sistem komputer dan proses datanya,

(b) *cyber crime in a broader sense ("computer-related crime")*: berbagai perilaku penyimpangan/ilegal yang dilakukan dengan alat atau berhubungan dengan sistem atau jaringan komputer, yang meliputi kejahatan menguasai, menawarkan, dan menyebarluaskan secara tidak sah informasi melalui alat dari suatu sistem atau jaringan komputer.[34]



Pendayagunaan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu alat kontrol sosial yang formal, meliputi aturan-aturan yang ditafsirkan dan ditegakkan oleh peradilan, dan secara umum dibuat oleh pembentuk undang-undang. Fungsinya membuat batasan-batasan perilaku warga negara, dan menjadi tuntunan aparat serta menetapkan keadaan penyimpangan atau perilaku yang tidak dapat diterima.[35]

---

[33]Penguraian lengkapnya, lihat Agus Raharjo, *Cyber Crime ……, op. cit*. hlm. 130 –200. Di Jakarta pada 12 Juni 2008 telah diselenggarakan kegiatan *"Biggest Hacker's Day Event in Indonesia"* bersamaan dengan kegiatan Festival Komputer Indonesia. Di sini para hackers berkumpul membahas berbagai hal termasuk *cyber law*, juga diadakan workshop keamanan teknologi informasi. Lihat KOMPAS, Kamis 12 Juni 2008.

[34]UNAFEI, The Global….., *op. cit*. hlm. 4. Lihat juga, Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana…., op. cit*. hlm. 8-10. Istilah khusus telah dikembangkan untuk melukiskan *"computer crime"*: 1) data *diddling*: cara yang paling umum, paling mudah, dan paling aman, meliputi tindakan mengubah data yang akan dimasukkan ke dalam komputer, atau yang ada dalam komputer, 2) *the trojan horse method:* memerintahkan komputer untuk melakukan fungsi secara tidak wenang sebaik fungsinya yang dikehendaki, 3) *the salami technique,* menunjuk pada pengambilan sejumlah kecil milik dari sumber yang lebih besar tanpa mengurangi secara berarti keseluruhannya 4) *superzapping,* dikarenakan pada suatu saat komputer berfungsi salah, membutuhkan program yang disebut *"break glass in case of emergency"*. Program ini "menghindari semua kontrol untuk mengubah atau menyingkapkan beberapa isi komputer". Di tangan yang salah, hal tersebut dapat dijadikan alat kejahatan yang sangat kuat. 5) data leakage meliputi penghilangan informasi dari sistem komputer atau fasilitas komputer. Dalam *Sue Titus Reid, Crime…, op. cit*. hlm. 266-267.

[35]Jay A. Sigler, *Understanding Criminal Law,* Boston: Little, Brown, and Company, 1981. Hlm. 3. Bandingkan Antonie A.G. Peters, *Main Currents in Criminal Law Theory*, dalam Jan van Dick,

Upaya penanggulangan kejahatan, termasuk bagian pembangunan manusia, yang terkait dengan *a new international economic order*. Dalam konteks ini, kebijakan penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan aspek struktural, yang meliputi sebab-sebab keadilan sosial-ekonomi, termasuk kejahatan, namun sering merupakan suatu gejala *(account the structural including socio-economic causes of justice, of which criminality is often but a symptom)*.[36] Kemunculan kejahatan baru perlu didefinisikan dalam perundang-undangan, seperti: *money laundering, organized fraud, computer crime,* dan masih ditambahkan pembaruan perundang-undangan keperdataan, keuangan, dan administrasi *(there is a need for reform civil, fiscal, and regulatory legislation…..)*.[37] Oleh karena itu, disebutkan oleh Jean-Germain Gros, bahwa secara kelembagaan dalam penanggulangan kejahatan tidak bisa tunggal, mengingat kompleksitas kejahatan. Jelasnya dinyatakan *no single institutions should be given the task of combating criminality, since the problem itself is multifaceted*.[38] Pembangunan harus mencakup terbebasnya manusia dalam kehidupan yang nir-kejahatan, baik individu, masyarakat, maupun negara.

Hukum pidana membutuhkan pengembangan dalam kerangka strategi global, dan menuntut peningkatan konsep hukum secara totalitas baik nasional, internasional maupun supranasional. Kalau dalam penanggulangan kejahatan hanya mengandalkan hukum pidana, dikatakan sebagai *the traditional international model*. Perkembangannya menimbulkan apa yang disebut *the cosmopolitan model*. Di sini diperlukan tidak hanya memelihara *the national public order,* tetapi juga memperkuat *a global public order.* Hal ini berhubungan dengan secara objektif kejahatan yang berkembang bersifat menyerang *values recognized as universal,* dan guna merespons perkembangan *global crime sebagai global war*.[39]

Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi yang dihadapi, kerangka hukum siber Indonesia menjadi strategis untuk menjamin rasa aman, keabsahan informasi, dan jaminan/insentif bagi para investor. Hak asasi manusia harus ditegakkan untuk menjamin hak kebebasan berkomunikasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi global tanpa dibatasi dimensi fisik, ruang, waktu, dan institusi. Revisi beberapa kerangka hukum dan kebijakan pemerintah perlu dilakukan untuk mengantisipasi hilangnya batas dimensi

---

et.al. Criminal Law in Action, Netherland: Kluwer LawPublisher, 1988, hlm. 32. Dijelaskan dalam *welfarestate*, hukum pidana tidak lagi *a moral code,* melainkan instrumen perlindungan masyarakat, sebagai salah satu kontrol sosial *(social control)*. Problem pemberantasan kejahatan adalah dengan pengendalian secara lengkap *(complete control)*.

[36]U N Secretariat, *Guiding….. 1985*, *op.cit*. hlm. 6.

[37]U N General Assembly, *Guiding* ….. 1995, *op. cit*. hlm. 113.

[38]Jean – Germain Gros, *Trouble* ……., *op. cit*. hlm. 76.

[39]Mireille Delmas-Marty, *Global Crime Calls for Global Justice*, EUROPEAN JOURNAL OF CRIME,CRIMINAL LAW, AND CRIMINAL JUSTICE,Vol. 10/4, Netherlands: Kluwer Law International, 2002. hlm. 293.

ruang, waktu dan mempercepat transaksi dunia maya.[40] Masalah dunia siber, seperti domisili pengajuan gugatan, dan prosedural lainnya berbeda dengan yang terjadi di dunia nyata. Hal ini mengharuskan para penegak hukum untuk secara aktif mempelajari dan mendalami pengetahuan berkaitan dengan media siber. Untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut perlu dilakukan penyesuaian atau undang-undang yang berlaku agar dapat menampung transaksi di media siber.[41]

Tindak pidana di bidang ekonomi sebagai perwujudan perbuatan penyimpangan dalam kehidupan ekonomi, penyalahgunaan praktik bisnis, melibatkan pelaku orang-orang bisnis maupun korporasinya itu sendiri sehingga penting pembenahan dan perbaikan aspek manajemen organisasi yang menyangkut perbaikan kinerja, peningkatan integritas para personel dari yang paling tinggi hingga yang terendah, kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Dalam hal diperlukan tindakan yang efektif untuk menanganinya, dikemukakan oleh Djokosantoso Moeljono, dengan membangun budaya korporat (*corporate culture*) yakni sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat dan dijadikan acuan perilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.[42] Selanjutnya diperoleh penjelasan, budaya korporat ini, antara lain berfungsi mempermudah timbulnya peningkatan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan individu. Dengan demikian, dapat menumbuhkan perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi, sebagai alat pengorganisasi anggota, menguatkan nilai-nilai dalam organisasi, serta menjadi mekanisme kontrol terhadap perilaku. Dengan demikian, fungsi budaya korporat sebagai perekat sosial dalam mempersatukan anggota-anggota dalam mencapai tujuan organisasi berupa ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Di samping itu, berfungsi pula sebagai kontrol perilaku para karyawan. Oleh karena itu, diharapkan dapat mencegah berbagai penyimpangan kegiatan perekonomian dan praktik-praktik ilegal dalam menjalankan bisnis.



Kebijakan Perundang-undangan Bidang Ekonomi Bersanksi Pidana

Pencarian tolok ukur sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana sebagai *the designation of certain harms as public harms,* di samping itu, *criminal*

[40]Onno W. Purbo, *Perkembangan.., loc.cit*. hlm. 50.
[41]Asril Sitompul, *Hukum Internet …, op.cit*. hlm. 24.
[42]Djokosantosa Moeljono, *Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003), hlm. 21–22.

law was limited to behavior that was clearly socially injurious.[43] Ditambahkan tolok ukur immoral dan merugikan pihak lain, dikatakan oleh Herbert L. Packer; *only conduct generally considered* immoral *should be treated as criminal*, di samping itu, *harm to others to include* risk of damage *to interest of others, and it is usually possible to make a more or less plausible argument that any given form conduct involves that risk in some way*.[44] Perbuatan immoral bukan dalam arti daya pembeda benar atau salah, adil atau tidak adil dalam diri seseorang, melainkan keseluruhan orang-orang dalam masyarakat yang selalu berkembang dan berubah. Dengan demikian, bersifat melukai masyarakat, merugikan, atau mencelakakan pihak lain. Terkait dengan tindak pidana ekonomi, perbuatan tersebut bertentangan dengan moral di bidang ekonomi, dan merugikan kehidupan ekonomi yang merusak sistem ekonomi suatu masyarakat, sudah tentu berdampak secara individual kepada anggota masyarakat menderita kerugian.

Tolok ukur penentuan tindak pidana terkait dengan ideologi atau sistem nilai yang dianut oleh kekuasaan negara, dan ini dinyatakan dalam ketentuan hukum pidana. Oleh karenanya dapat dikatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dikarenakan bertentangan dengan ideologi atau sistem nilai suatu negara. Penentunya adalah pembentuk undang-undang yang berkehendak kepentingan atau nilai-nilai yang ingin dilindungi dan ditegakkan dengan hukum pidana.[45] Dengan demikian, penentuan tindak pidana di Indonesia bertolok-ukur apabila perbuatan bertentangan dengan ideologi Pancasila, yang nilai-nilainya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam bidang ekonomi. Nilai-nilai Pancasila menyangkut sistem ekonomi yang dikehendaki, sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 pada Pasal 33, khususnya ayat (4). Terpaut dengan tindak pidana di bidang ekonomi berarti melawan atau mengganggu ideologi atau sistem nilai di bidang ekonomi yang dikehendaki kekuasaan politik negara untuk diterapkan.

Perumusan tindak pidana di bidang ekonomi yang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, dapat ditunjukkan adanya kelompok-kelompok, seperti tindak pidana mengenai keaslian produk, tindak pidana

---

[43]Charles W. Thomas dan Donna M. Bishop, *Criminal Law, (*California: Sage Publications, 1987), hlm. 39.

[44]Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction,* California: Stanford University Press, 1968, hlm. 262, 266. Dalam hal ini kaitannya dengan moral, perbuatan melanggar hukum berarti perbuatan melanggar moral sehingga tindak pidana yang dilakukan bermakna melakukan tindakan yang bertentangan dengan moral karena hukum selalu didasarkan pada moral. Roeslan Saleh menyatakan bahwa *adanya aturan-aturan hukum tertinggi yang merupakan asas–asas hukum, yaitu ukuran nilai dari sebagian terbesar aturan tingkat yang lebih rendah. Ukuran-ukuran nilai ini merupakan bagian dari moral. Asas-asas hukum adalah aturan-aturan hukum tertinggi, dan karenanya pula mempunyai sifat moral. Dalam arti demikian kita dapat menyatakan bahwa hukum selalu didasarkan pada moral*. Lihat Roeslan Saleh, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana*, Makalah Penataran Asosiasi Nasional Pengajar Hukum Pidana, 11-22 November, Fak. Hukum UNDIP, 1989, hlm. 28.

[45]Stephen Schafer, *The Political…*, *op.cit.*, hlm. 21.

finansial-keuangan, tindak pidana menyangkut kualitas barang, tindak pidana bertentangan dengan keselamatan konsumen, tindak pidana mengenai teknologi, tindak pidana pemasaran, tindak pidana mengingkari kejujuran usaha, tindak pidana terkait produksi, tindak pidana beraspek global. Pengelompokan ini diorientasikan pada kepentingan hukum yang dilindungi, yakni kepentingan hukum tersebut menyangkut karya intelektual, lalu lintas peredaran uang dan keadaan moneter, tingkat mutu barang, keselamatan/kesehatan konsumen, kemanfaatan teknologi dan nilai ekonomis, legalitas peredaran, cara berusaha yang jujur, proses manufaktur, serta tertib ekonomi antarbangsa.

Tindak pidana mengenai keaslian produk diatur dalam beberapa peraturan perundangan, diklasifikasikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi. Ini diatur dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1994, UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 22 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2000, UU No. 31 Tahun 2000, UU No. 32 Tahun 2000, UU No. 14 Tahun 2001, UU No. 15 Tahun 2001, UU No. 19 Tahun 2002, dan UU No. 29 Tahun 2000.

Perbuatan yang dinyatakan terlarang yang kemudian diberi sanksi pidana bidang kegiatan finansial-keuangan sangat penting diatur dalam hukum pidana. Berkaitan dengan stabilitas dan kelancaran untuk mendukung lajunya perekonomian. Tindak pidana pelanggaran finansial-keuangan, menampakkan tindak pidana-tindak pidana yang tersebar pada UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 15 Tahun 2002, UU No. 24 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 1995.

Sehubungan telah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana menyangkut finansial–keuangan ini termasuk dalam pengaturannya. Dalam hal ini mengenai pemanfaatan teknologi informasi/komputer dalam kegiatan perbankan. Di dalam ketentuan UU ITE diatur mengenai pemberatan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik jika dilakukan bersangkutan dengan kesusilaan dan eksploitasi seksual anak, data/dokumen milik negara, pertahanan–keamanan, termasuk mengenai perbankan. Khususnya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik terkait dengan perbankan, keuangan, bank sental sebagai pemberatan diatur dalam Pasal 52 ayat (3) UU ITE.

Tindak pidana menyangkut kualitas barang, yang dapat dilihat tingkat mutu barang sebagai kepentingan yang dilindungi. Penentuan perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana di bidang ekonomi menyangkut kualitas barang, dalam UU No. 5 Tahun 1995, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 1984, UU No. 7 Tahun 1996, UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 19 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 5 Tahun 1997. Tindak pidana menyangkut kualitas barang ini untuk menjaga kepentingan masyarakat banyak, apabila membutuhkan barang-barang yang dikonsumsi. Di sini barang-barang harus memenuhi persyaratan mengenai kualitas produk, standarisasi, sertifikasi, syarat pendaftaran, dan sebagainya.

Tindak pidana di bidang ekonomi terkait perlindungan kepentingan hukum berupa keselamatan/kesehatan konsumen terletak pada pengaturan undang-undang di luar hukum pidana, yakni: UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 1996, UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 5 Tahun 1997.

Selanjutnya, perihal tindak pidana mengenai teknologi berkaitan dengan peraturan dalam perundang-undangan di bidang ekonomi, seperti: UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 19 Tahun 2002, UU No. 14 Tahun 2001, UU No. 29 Tahun 2000, UU No. 5 Tahun 1984, UU No. 41 Tahun 1999, dan UU No. 11 Tahun 2008.

Tindak pidana yang memberikan perlindungan kepentingan hukum untuk menjamin legalitas peredaran penting sekali sebagai sarana pemasaran berbagai produk yang dihasilkan perusahaan. Dalam hal ini, pelanggaran regulasinya merupakan bidang pemasaran atau sebagai tindak pidana pemasaran, termasuk penyimpangannya sebagai tindak pidana di bidang ekonomi. Kegiatan pemasaran sangat penting dalam kegiatan ekonomi–bisnis, karena di sinilah barang dan/atau jasa dari suatu perusahaan dikeluarkan langsung dijual kepada masyarakat. Pengaturan hukum menjadi penting, sehubungan dengan perlindungan kalangan usaha itu sendiri untuk memperoleh kepastian usahanya, dan masyarakat untuk dilindungi akan kebutuhan barang dan atau/jasa tersebut.

Kejujuran usaha atau persaingan usaha tidak sehat perlu memperoleh perlindungan hukum, dengan menyatakan sebagai perbuatan terlarang bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan yang menyangkut hal tersebut. Ini ditentukan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi menyangkut kegiatan usaha. Pengaturan tindak pidana di bidang ekonomi menunjuk pada perlindungan kepentingan hukum mengenai cara berusaha yang jujur, ditentukan UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 1999, dan UU No. 41 Tahun 1999.

Perlindungan kepentingan hukum menyangkut proses pembuatan produk/proses manufaktur penting bagi aktivitas ekonomi-produksi, maka bagi pelanggar perlu dinyatakan perbuatannya sebagai tindak pidana. Pengaturan hukumnya termasuk sebagai tindak pidana di bidang ekonomi dalam UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 1996, UU No. 22 Tahun 2001, UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 29 Tahun 2000, UU No. 5 Tahun 1999, dan UU No. 22 Tahun 1997.

Pembedaan kejahatan dan pelanggaran untuk tindak pidana dalam hukum substantif tetap memiliki kemanfaatan dalam penegakan hukum. Hal itu direalisasikan bagi penegakan hukum sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan praktis tetap relevan adanya pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran.

Menyangkut kualifikasi delik aduan, pentingnya terkait dengan adanya pengaduan untuk penindakannya. Kalau ada pengaduan segera ditindaklanjuti, terkait dengan masalah teknis. Dalam tindak pidana di bidang HaKI, penyim-

pangannya secara teknis yang mengetahui, adalah si pemegang hak, atau pihak yang berkepentingan seperti ASIRI, ASPELUKI, distributor. Sehubungan dengan ini, dipahami masalah HaKI asalnya memang merupakan masalah perdata, dalam hal ini yang diberikan perlindungan adalah hak-hak individu yang berupa kekayaan (*property*) tidak berwujud sehingga penindakan hukum diserahkan kepada para pihak. Dalam hal terjadi tindak pidana, sehubungan sebagai delik aduan, pengaduan atau pencabutan kembali kalau sudah diproses tergantung kehendak pihak-pihak yang berkepentingan, bukan oleh kekuasaan publik (penegak hukum). Perkecualian setelah undang-undang yang baru mengenai hak cipta ditentukan tindak pidana hak cipta bukan delik aduan, sehingga penindakan oleh aparat penegak hukum tidak digantungkan adanya pengaduan, dan juga dalam UU Perlindungan Varietas Tanaman. Di sini menuntut kemampuan aparat penegak hukum yang memadai secara teknis mengenai hak cipta, yang terkait dengan sesuatu bidang, misalnya: hak cipta program komputer. Kenyataannya hal tersebut tidak mudah.

Dalam pengkajian beraneka ragam perundang-undangan, kesemua UU menentukan adanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun tidak semuanya dilanjutkan adanya pengaturan mengenai beban pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Penulis dalam hal ini, membedakan antara subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan alasan: 1) subjek hukum dalam tata hukum memang diakui selain manusia *(natural person)*, juga badan hukum *(legal person)* karena hukum pidana sebagai bagian dari tata hukum yang berlaku maka selayaknya demikian pula pengakuannya mengenai subjek hukum pidana, 2) di dalam beraneka UU yang dikaji terdapat istilah-istilah, seperti: perserikatan, setiap orang, setiap pihak, pelaku usaha, asosiasi, pelaku budi daya, pengelola usaha, suatu badan, penyelenggara telekomunikasi, perkumpulan, yang dalam masing-masing undang-undang dijelaskan pengertiannya termasuk badan hukum, badan usaha (korporasi). Itu semua di dalam pasal ketentuan pidana merupakan pelaku, ataupun termaktup pula di dalam pasal-pasal norma-norma administratif (regulasi larangan dan kewajiban). Di sinilah dimaksudkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun selanjutnya ada UU yang tidak mengaturnya lebih lanjut dengan pertanggungjawaban pidana. Adapun UU yang sekaligus menentukan peraturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sebagai berikut ini.

a. UU No. 7 (Drt) 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi,
b. UU No. 2 Tahun 1992 tantang Usaha Perasuransian,
c. UU No. 10 Tahun 1995 tantang Kepabeanan,
d. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (perubahan dengan UU No. 39 Tahun 2007),
e. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan,
f. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,

g. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,
h. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
i. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
j. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
k. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hukum pidana pengertian "*korporasi*" berarti sangat luas tidak hanya yang berbetuk "badan hukum" saja, melainkan juga yang bukan badan hukum. Jadi tidak hanya badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi sebagai korporasi, melainkan juga firma, perseroan komanditer, persekutuan, bahkan sekumpulan orang. Kalau pertanggungjawaban dibebankan kepada "pengurus", juga perlu dipahami mengenai bentuk korporasi tersebut dikaitkan dengan peraturan perundangan yang mengaturnya. Apabila korporasi berbentuk perseroan terbatas maka pengertian pengurus harus mengacu pada UU No. 1 Tahun 1995 (yang sudah diperbarui dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara harus mengacu UU No. 19 Tahun 2003, yang berbentuk koperasi harus berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, bahkan yang berhubungan dengan pengurusan zakat perlu mengacu pada UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Badan-badan lain untuk ditentukan pengurusnya dapat dilihat pada Anggaran Dasarnya.

Pertanggungjawaban dari kejahatan korporasi ada tiga kemungkinan: (1) orang yang bersalah dalam tindak pidana tersebut, sesuai dengan ajaran kesalahan dalam hukum pidana yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan. Yang mempertanggungjawabkan dicari orang yang bersalah, (2) korporasinya yang dipertanggungjawabkan, berdasarkan ajaran *strict liability*. Di sini tidak perlu memerhatikan bentuk kesalahannya kesengajaan atau kelalaian, (3) baik orangnya maupun perusahaannya. Orang yang bersalah dimungkinkan dipertanggungjawabkan dan dipidana sesuai dengan KUHP, sedangkan perusahaannya dikenai kewajiban pengganti kerugian.[46]

Oleh karena itu, sudah banyak perundang-undangan yang menentukan pertanggungjawaban baik oleh perorangannya/pengurus dan/atau korporasi (sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 1996, UU No. 22 Tahun 2001, UU No. 15 Tahun 2002, UU No. 2 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 11 Tahun 1995, UU No. 5 Tahun 1997). Akan tetapi, perumusannya kumulatif-alternatif, maka kemungkinan yang dipertanggungjawabkan pengurusnya saja, berdasarkan doktrin *vicarious liability*. Bila pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi saja berdasarkan doktrin *strict liability*. Sejalan dengan kehidupan ekonomi, perkembangan masalah

[46]Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian,* (Jakarta: Datacom, 2002), hlm. 35-36.

korporasi dari *good corporate governance* menjadi *good corporate culture governance* membawa pembicaraan pertanggungan jawab korporasi dilihat pada struktur organisasi, kebijakan, kultur, dan etos korporasi yang mendorong terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini Muladi menukil dari KUHP Australia yang merumuskan *corporate culture* (budaya korporasi) sebagai *an attitude, policy, rule, course or practice existing within the body corporate generally or in the part of the body corporate in which the relevant activities takes place*.[47]

Konsep *corporate culture* mengutamakan pada kesalahan tingkat organisasi dalam suasana pelaksanaan perusahaan maupun tahap-tahap yang mendorong cara-cara dilakukannya suatu tindak pidana. Dikemukakan J. Hill dan R. Harmer[48] bahwa *The concept of "corporate culture" (*konsep "budaya korporasi") memusatkan pada kesalahan yang tidak layak dalam tingkat organisasi, dirasakan pelaksanaan dan tata cara perusahaan telah menyumbang dalam beberapa cara pada tindak pidana yang dilakukan. Untuk pertanggungjawaban dilekatkan pada korporasi dengan alat-alat ini, bukan pada tingkat di bawah hierarki korporasi yang tidak mungkin pertanggungjawaban melekat pada korporasi. Cukup menjadi isu kunci bilamana struktur organisasi pada korporasi seperti perbuatan yang sesuai dengan ketidaktaatan dapat terjadi pada banyak tingkat.

Perumusan sanksi pidana, selain pidana pokok yang ditentukan Pasal 10 KUHP, terdapat ancaman hukuman berupa sanksi administrasi, seperti pencabutan izin usaha, penutupan perusahaan, dan lain-lain. Dalam hal ini, jenis pidana yang perlu ditekankan, adalah seperti pencabutan izin, pengumuman putusan hakim. Mengenai jenis pidana pokok masih tetap sama dengan sanksi pidana dalam KUHP, yaitu berupa sanksi pidana penjara, kurungan, denda, dan kurungan pengganti denda. Yang berkembang adanya aneka jenis pidana tambahan selain menunjuk pada Pasal 10 KUHP, terdapat banyak jenis-jenis lainnya, seperti: pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi, penghentian kegiatan, pembayaran ganti rugi, penarikan peredaran barang, pencabutan izin usaha industri, dan pemusnahan barang.

Jenis tindak pidana sudah dikembangkan dari ketentuan pidana umum dalam KUHP, yaitu adanya sanksi pidana pokok, dan tambahan. Pidana tambahan ini bertambah bermacam-macam, di samping adanya jenis sanksi administrasi yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, sebagian besar peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, yang bersanksi pidana tidak memanfaatkan

---

[47]Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, makalah Seminar Nasional ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DARI TINDAK PIDANA KORUPSI, 6-7 Mei 2004, kerja sama Fakultas Hukum UNDIP dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. hlm. 3-5.

[48]J. Hill and R. Harmer, *Criminal Liability of Corporaton*, dalam Hans de Doelder and Klaus Tiedemann (ed.). Criminal Liability of Corporations, XIVth International Congress of Comparative Law. (London: Kluwer Law International, 1996), hlm. 88.

adanya sanksi tindakan (*treatments*). Justru dalam UUTPE sudah mengenal adanya tindakan tata tertib (Pasal 8), dan tindakan tata tertib sementara (Pasal 27).

Penetapan sanksi pidana dan tindakan masih tidak jelas dalam membedakan jenis sanksi pidana, khususnya pidana tambahan dengan jenis sanksi tindakan sehingga bentuk-bentuk tindakan sering ditempatkan sebagai sanksi pidana tambahan dan begitu sebaliknya. Ditambah lagi, sanksi tindakan masih sering ditempatkan sebagai sanksi yang bersifat pelengkap.[49] Demikian ini tampak pada penetapan sanksi dalam perundang-undangan di bidang ekonomi, yakni terdapat sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan, sanksi tindakan tidak ada kejelasan, selain itu banyak adanya sanksi administrasi.

Tindak pidana di bidang ekonomi, khususnya seperti kejahatan bisnis merupakan kejahatan non-penal, yang beroperasi di balik legalitas kegiatan perekonomian masyarakat ataupun birokrasi pemerintah. Untuk menanganinya tidak tepat hanya dengan penal, perlu didekati dari aspek si pelaku, juga korban yang terdiri dari perorangan, masyarakat, dan negara. Apabila digunakan pendekatan penal dapat berakibat kerugian bagi negara, karena dampaknya menimpa terganggunya kegiatan perekonomian-bisnis yang legal yang dijadikan perlindungan kejahatan.[50] Selanjutnya, sanksi yang selaras dengan penyimpangan kegiatan di bidang ekonomi tidak hanya hukum pidana, diperlukan bentuk lain termasuk pemanfaatan hukum perdata, tindakan organisasi profesi, asosiasi perniagaan, keputusan manajemen, dan pernyataan melalui media.

Oleh sebab itu, penetapan sanksi pidana dan nanti penerapannya lebih didayagunakan sanksi yang bersifat mendidik, yakni tindakan daripada yang menghukum seperti sanksi pidana. Kekurangan sistem sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi mengenai jenis sanksi tindakan perlu dilengkapi dengan meminda ketentuan UU No. 7 Drt Tahun 1955. Selain itu, perlu didukung yang dikemukakan oleh M. Sholehuddin,[51] bahwa ide dasar *double-track system* menjadi dasar kebijakan penetapan dalam perundang-undangan pidana masa mendatang, karena memungkinkan pendayagunaan jenis sanksi pidana dan tindakan secara proporsional demi efektifnya penanggulangan kejahatan secara komprehensif.

Kejahatan ekonomi yang bernuansa samar-samar penyimpangan bersifat publik maupun privat memunculkan pemikiran diintroduksinya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), misalnya seperti tindak pidana perbankan. Model penyelesaian perkara di luar peradilan dapat dipergunakan sebagai

---

[49]M. Sholehuddin, Penetapan Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Kebijakan Legislatif (*Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*). DISERTASI. (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2002), hlm. 324.

[50]Soedjono Dirdjosisworo, *Kejahatan …, op.cit.,* hlm. 10-11.

[51]M. Sholehuddin, *Penetapan …, op.cit.,* hlm. 326.

alternatif, atas dasar pertimbangan kompleksitas masalah dan pada saat yang sama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha jasa keuangan dan perbankan. Namun, apabila pelaksanaannya secara selektif dapat menimbulkan diskriminasi, dan juga memberikan diskresi yang terlalu besar pada para pejabat keuangan dan perbankan untuk mengambil keputusan, oleh karena itu mengandung risiko yang tinggi. Ini kemudian hari akan sulit dikendalikan dan jauh dari tujuan pemulihan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (negara dan *stakeholder*).[52]

[52]Romli Atmasasmita, *Pengantar …, op.cit.,* hlm. 65-66.

Bagian Ketiga

Membangun Bangsa Sadar Konstitusi

RAJAWALI PERS

18

MEMBANGUN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI*

Oleh:
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**



Kedudukan Konstitusi

DALAM PENGERTIAN yang sederhana, konstitusi adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi.[1] Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah tertentu, serikat buruh, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial sampai ke organisasi tingkat dunia seperti, Perkumpulan ASEAN, European Communities (EC), World Trade Organization (WTO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan sebagainya semuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi.

Demikian pula negara, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Bahkan negara yang tidak memiliki satu naskah konstitusi seperti Inggris, tetap memiliki aturan-aturan yang tumbuh[2] menjadi konstitusi dalam pengalaman praktik ketatanegaraan dan para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris, sebagaimana dikemukakan oleh Phillips Hood and Jackson sebagai berikut: *"a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the State and that regulate the relations of the various State organs to one another and to the private citizen."*[3] Dengan demikian, ke dalam

---

*Makalah ini pernah disampaikan pada acara Seminar "Membangun Masyarakat Sadar Konstitusi", yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar, Jakarta, 8 Juli 2008.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2003-2008.

[1]Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, (London: Blackstone Press Ltd., 1997), hlm. 3.

[2]Bandingkan dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh Brian Thompson tentang Konstitusi Inggris, *"In other words the British constitution was not made, rather it has grown". Ibid.*, hlm. 5.

[3]O. Hood Phillips, *Constitutional and Administrative Law*, 7th ed., (London: Sweet and Maxwell, 1987), hlm. 5.

konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis berupa kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antarorgan-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power*[4] yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Hal itu dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat, misalnya melalui referendum, seperti yang dilakukan di Irlandia pada 1937, atau dengan cara tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Dalam hubungannya dengan kewenangan mengubah UUD, cara tidak langsung ini misalnya dilakukan di Amerika Serikat dengan menambahkan naskah perubahan Undang-Undang Dasar secara terpisah dari naskah aslinya. Meskipun, dalam pembukaan Konstitusi Amerika Serikat *(preambule*) terdapat perkataan *"We the people",* tetapi yang diterapkan sesungguhnya adalah sistem perwakilan, yang pertama kali diadopsi dalam konvensi khusus (*special convention*) dan kemudian disetujui oleh wakil-wakil rakyat terpilih dalam forum perwakilan negara yang didirikan bersama.

Dalam hubungan dengan pengertian *constituent power* tersebut di atas, muncul pula pengertian *constituent act*. Dalam hubungan ini, konstitusi dianggap sebagai *constituent act*, bukan produk peraturan legislatif yang biasa (*ordinary legislative act*). *Constituent power* mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Seperti dikatakan oleh Bryce, konstitusi tertulis merupakan:[5]

> *"The instrument in which a constitution is embodied proceeds from a source different from that whence spring other laws, is regulated in a different way, and exerts a sovereign force. It is enacted not by the ordinary legislative authority but by some higher and specially empowered body. When any of its provisions conflict with the provisions of the ordinary law, it prevails and the ordinary law must give way."*

Karena itu, dikembangkannya pengertian *constituent power* berkaitan pula dengan pengertian hierarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental

---

[4]Lihat misalnya Brian Thompson, *op. cit*., hlm. 5.

[5]J. Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol.1, (Oxford: Clarendon Press, 1901), hlm. 151.

sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Atas dasar logika demikian itulah maka Mahkamah Agung Amerika Serikat menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menguji materi peraturan produk legislatif (*judicial review*) terhadap materi konstitusi, meskipun Konstitusi Amerika tidak secara eksplisit memberikan kewenangan demikian kepada Mahkamah Agung.[6]

Basis pokok berlakunya konstitusi adalah adanya kesepakatan umum atau persetujuan *(consensus)* di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.[7] Kata kuncinya adalah konsensus atau *general agreement*. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (*civil war*) atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Prancis tahun 1789, di Amerika pada 1776, dan di Rusia pada 1917, ataupun di Indonesia pada 1945, 1965, dan 1998.



Perubahan UUD 1945

Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional (*constitutional reform*). Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya *good governance*, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.

Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang MPR dari 1999 hingga 2002.[8] Perubahan pertama dilakukan

---

[6]Lihat kasus Marbury versus Madison (1803) 5-US, 1 Cranch, 137, dalam Brian Thompson, *op. cit*., hlm. 5.

[7]William G. Andrews, misalnya, dalam bukunya *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd edition, menyatakan: *"The members of a political community have, bu definition, common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of the compulsory political mechanisms we call the State"*, (New Jersey: Van Nostrand Company, 1968), hlm. 9.

[8]Sidang Tahunan MPR dikenal pada masa reformasi berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.[9]

Perubahan kedua dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM.[10]

Perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum.[11] Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan Keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.[12]

Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan.[13] Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 (12%) butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, sebanyak 174 (88%) butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan.

Dari sisi kualitatif, perubahan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam UUD 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan presiden yang sangat besar *(concentration of power and responsibility upon the president)* menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi *(checks and balances)*. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis.

Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan UUD 1945 yang telah diubah

---

[9]Ditetapkan pada 19 Oktober 1999.

[10]Ditetapkan pada 18 Agustus 2000.

[11]Ditetapkan pada 9 November 2001.

[12]Ditetapkan pada 10 Agustus 2002.

[13]Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah Disampaikan dalam Simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003, hlm. 1.

tersebut. Pelaksanaan UUD 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara *(the living constitution)*.



Negara Hukum yang Demokratis

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945[14] yang menyatakan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum.' Bahkan secara historis negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum *(rechtsstaat)*, tidak berdasarkan kekuasaan belaka *(machtsstaat)*.[15]

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, dalam bukunya *"the Statesman"* dan *"the Law"* menyatakan bahwa negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (*the second best*) guna mencegah kemerosotan kekuasaan. Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *"rechtsstaat"* antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *"The Rule of Law"* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi *(nomocratie)* yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.[16]

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu supremasi konstitusi *(supremacy of law)*, persamaan dalam hukum *(equality before the law)*, asas legalitas *(due process of law)*, pembatasan kekuasaan *(limitation of power)*, organ

[14]Hasil perubahan ketiga UUD 1945.

[15]Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.

[16]Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 152.

pemerintahan yang independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*), peradilan tata usaha negara *(administrative court)*, peradilan tata negara *(constitutional court)*, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis *(democratische-rehtsstaats)*, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara *(welfare rechtsstaat)*, serta transparansi dan kontrol sosial.[17]

Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum.

Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*.

Namun demikian, prinsip supremasi hukum selalu diiringi dengan dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian, negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *democratische rechtsstaat*.

Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perubahan UUD 1945 yang bersifat mendasar tentu saja berpengaruh terhadap sistem

[17]Asshiddiqie, *op.cit*., hlm. 154-162.

dan materi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap jenis peraturan perundang-undangan serta materi muatannya. Adanya perubahan UUD 1945 tentu menghendaki adanya perubahan sistem peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian materi muatan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku.

Sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi,[18] konstitusi memuat cita-cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar pencapaian cita-cita tersebut. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional.[19] Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.[20] Pembukaan dan pasal-pasal adalah satu kesatuan norma-norma konstitusi yang *supreme* dalam tata hukum nasional (*national legal order*).

Cita-cita pembentukan negara kita kenal dengan istilah tujuan nasional yang tertuang dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut akan dilaksanakan dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdiri di atas lima dasar yaitu Pancasila sebagaimana juga dicantumkan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945.

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan melaksanakan penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila, UUD 1945 telah memberikan kerangka susunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma-norma dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Hal ini karena para pendiri bangsa menghendaki bahwa rakyat Indonesia berdaulat secara penuh, bukan hanya kedaulatan politik. Maka UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik oleh negara (*state*), masyarakat (*civil society*), ataupun pasar (*market*).

Sebagai konstitusi politik, UUD 1945 mengatur masalah susunan kenegaraan, hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan hubungannya dengan warga negara. Hal ini misalnya diatur dalam Bab I tentang Bentuk Kedaulatan,

---

[18]Otoritas konstitusi berasal dari kekuasaan konstituen, yaitu otoritas yang berada di luar dan atas sistem yang dibentuk. Dalam negara demokratis, pemegang kekuasaan konstituen adalah rakyat. Brian Thompson, *op.cit*.

[19]Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 2-7.

[20]Hasil perubahan keempat UUD 1945. Sebelum dilakukan perubahan, diterima oleh umum bahwa UUD 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan.

Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab V tentang Kementerian Negara, Bab VI tentang Pemerintah Daerah, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah, Bab VIIB tentang Pemilu, Bab VIII tentang Hal Keuangan, Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab IX tentang Wilayah Negara, Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk khususnya Pasal 26, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 28I ayat (5), Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.

Sebagai konstitusi ekonomi, UUD 1945 juga mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Ketentuan utama UUD 1945 tentang sistem perekonomian nasional dimuat dalam Bab XIV Pasal 33. Ketentuan tentang sistem perekonomian nasional memang hanya dalam satu pasal yang terdiri dari lima ayat. Namun ketentuan ini harus dielaborasi secara konsisten dengan cita-cita dan dasar negara berdasarkan konsep-konsep dasar yang dikehendaki oleh pendiri bangsa. Selain itu, sistem perekonomian nasional juga harus dikembangkan terkait dengan hak-hak asasi manusia yang juga mencakup hak-hak ekonomi, serta dengan ketentuan kesejahteraan rakyat.

Sebagai konstitusi sosial, UUD 1945 mengatur tata kehidupan bermasyarakat terutama dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Bab XIII tentang Pendidikan Dan Kebudayaan, dan Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat khususnya Pasal 34.



Budaya Sadar Berkonstitusi

Kita tentunya menghendaki agar UUD 1945 merupakan konstitusi yang benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara demi tercapainya cita-cita bersama. Konstitusi mengikat segenap lembaga negara dan seluruh warga negara. Oleh karena itu, yang menjadi pelaksana konstitusi adalah semua lembaga negara dan segenap warga negara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam perspektif hukum, kata "pelaksanaan" (*implementation*) terdiri dari dua konsep fungsional, yaitu: *pertama, identifying constitutional norms and specifying their meaning*; dan *kedua, crafting doctrine or developing standards of review*.[21]

[21]Richard H. Fallon, Jr., *Implementing the Constitution,* (Cambridge, Massachusetts, and London; Harvard University Press, 2001), hlm. 37 – 38.

Agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945, diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi. Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jika masyarakat telah memahami norma-norma dasar dalam konstitusi dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pasti mengetahui dan dapat mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh terhadap pelaksanaan UUD 1945 baik melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta dapat pula melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan jalannya pemerintahan. Kondisi tersebut dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan konstitusi.

Salah satu bentuk nyata pentingnya budaya sadar berkonstitusi bagi pelaksanaan konstitusi adalah terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian tersebut dilakukan untuk menentukan apakah suatu ketentuan dalam suatu undang-undang, bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Namun Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak dapat bertindak secara aktif. Mahkamah Konstitusi hanya dapat menjalankan wewenang tersebut jika ada permohonan pengujian suatu undang-undang yang diajukan oleh masyarakat.

Dalam pengajuan permohonan inilah diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi berupa kesadaran akan hak konstitusionalnya sebagai warga negara baik sebagai perorangan maupun kelompok bahwa hak-hak konstitusional telah dilanggar oleh suatu ketentuan undang-undang. Di sisi lain, juga diperlukan adanya kesadaran untuk mendapatkan perlindungan atas hak konstitusional yang dilanggar dengan cara mengajukan permohonan pengujian konstitusional atas ketentuan undang-undang yang merugikannya. Jika tidak ada budaya sadar berkonstitusi, masyarakat tidak akan mengetahui apakah haknya terlanggar atau tidak dan tidak melakukan upaya konstitusional untuk mendapatkan perlindungan. Akibatnya, UUD 1945 akan banyak dilanggar oleh ketentuan undang-undang sehingga pada akhirnya konstitusi hanya akan menjadi dokumen di atas kertas tanpa dilaksanakan dalam praktik.

Di sisi lain, dalam budaya berkonstitusi juga terkandung maksud ketaatan kepada aturan hukum sebagai aturan main *(rule of the game)* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segenap komponen bangsa harus bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, serta apabila timbul permasalahan atau sengketa, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Budaya mematuhi

aturan hukum merupakan salah satu ciri utama masyarakat beradab. Hal ini sangat diperlukan terutama dalam konteks politik, misalnya dalam pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, maupun pemilukada.

Tanpa adanya kesadaran berkonstitusi, yaitu kesadaran mematuhi rambu-rambu permainan dan mekanisme penyelesaian sengketa, momentum politik yang sejatinya adalah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dapat tergelincir ke dalam konflik yang justru merugikan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran baik bagi untuk peserta pemilu, penyelenggara pemilu, maupun pihak dan lembaga lain yang memiliki peran dalam pelaksanaan pemilu. Semua permasalahan yang muncul harus dipercayakan dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan. Sebaliknya, lembaga yang memiliki kewenangan terkait dengan pelaksanaan pemilu juga harus menjalankan wewenangnya dengan baik.

Oleh karena itu, harus ada upaya secara terus-menerus untuk membangun budaya sadar berkonstitusi. Budaya sadar berkonstitusi tercipta tidak hanya sekadar mengetahui norma dasar dalam konstitusi. Lebih dari itu, juga dibutuhkan pengalaman nyata untuk melihat dan menerapkan konstitusi dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi adalah suatu proses panjang dan berkelanjutan.

Setiap warga negara dan penyelenggara negara harus mempelajari dan memahami UUD 1945 melalui berbagai cara dan berbagai media. Untuk itu informasi tentang konstitusi harus tersedia agar mudah diakses dengan cepat dan mudah pula dipahami. Oleh karena itu, peningkatan budaya sadar berkonstitusi tidak hanya dilakukan melalui forum tatap muka, tetapi melalui berbagai bentuk kemasan dan media yang berbeda-beda.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya mendekatkan UUD 1945 sebagai konstitusi kita kepada masyarakat umum serta menumbuhkan *the living constitution* adalah karena pembahasan masalah konstitusi dan materi muatan yang terkandung di dalamnya selalu menggunakan kerangka pikir, rujukan teori, dan rujukan praktik yang berasal dari luar negeri.

Untuk itu, diperlukan upaya domestikasi UUD 1945, yaitu menjadikan UUD 1945 dan pengkajiannya dilakukan dengan merujuk pada pengalaman bangsa Indonesia dan problem nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Pengkajian sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia selama ini masih terbatas mulai penjajahan Belanda. Padahal, sebelumnya terdapat kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara yang memiliki sistem dan struktur ketatanegaraan tersendiri yang dapat dibandingkan dengan sistem ketatanegaraan modern. Sebagai contoh, pembagian fungsi kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif sudah terbentuk walaupun kekuasaan raja cukup dominan karena menjadi ketua dari semua lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan tersebut. Bahkan

prinsip demokrasi juga mulai terlihat karena pengambilan keputusan diambil secara musyawarah oleh wakil-wakil masyarakat, meskipun keputusan terakhir tetap ada pada pimpinan tertinggi. Kenyataan-kenyataan sejarah tersebut dapat dijumpai di kerajaan dan satuan pemerintahan lain di berbagai wilayah nusantara.

Dengan elaborasi pengalaman bangsa Indonesia sendiri dan dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi dalam UUD 1945, maka masyarakat akan merasakan bahwa sistem dan pemikiran yang menjadi materi muatan UUD 1945 bukan lagi sebagai hal yang asing, tetapi tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Jika hal ini diiringi dengan upaya mendekatkan UUD 1945 dengan masyarakat, misalnya melalui penulisannya dalam bahasa dan huruf daerah, masyarakat dapat menjadikan UUD 1945 benar-benar sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat akan dapat mensikapi masalah yang dihadapi berdasarkan norma-norma konstitusional. Hal ini menjadi awal dari berkembangnya kehidupan dan pemikiran konstitusional sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat *(the living constitution)*.

Daftar Referensi

Alrasid, Harun. *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*. Revisi Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2003.

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.

————————. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Makalah Disampaikan dalam Simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.

————————. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

————————. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Barendt, Eric. *An Introduction to Constitutional Law*. New York: Oxford University Press, 1998.

Fallon, Richard H. Jr. *Implementing the Constitution*. Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press, 2001.

Field, G. Lowell. *Government In Modern Society*. New York–Toronto–London: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1951.

Jelić, Zoran. A Note On Adolf Merkl's Theory Of Administrative Law. *Journal Facta Universitatis, Law and Politics*. Vol. 1 No. 2, 1998.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. translated by: Anders Wedberg. New York; Russell & Russell, 1961.

Mahfud MD., Moh. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Montesquieu. *The Spirit of the Laws*. Translated by Thomas Nugent. London: G. Bell & Sons, Ltd, 1914.

Phillips, O. Hood and Paul Jackson. *Constitutional And Administrative Law*. Eighth Edition. London: Sweet & Maxwell, 2001.

Simanjuntak, Marsillam. *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Grafiti, 1993.

Stewart, Ian. The Critical Legal Science of Hans Kelsen. *Journal of Law and Society, 17 (3)*, 1990.

Thompson, Brian. *Textbook on Constitutional Law & Administrative Law*. Third Edition. London: Blackstone Press Limited, 1997.

Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, *Pokok-pokok Usulan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, dipresentasikan di hadapan Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI pada tanggal 15 Juni 1999 di Jakarta.

Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid Pertama. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

19

PANCASILA SEBAGAI *GRAND DESIGN* PENGKAJIAN KONSTITUSI

Oleh:
*Dr. Mochamad Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H.**



Pengantar

Konstitusi merupakan akta kelahiran bagi suatu bangsa, sehingga kaitan konstitusi bagi suatu negara amat erat. Tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki konstitusi. Dalam konstitusi juga terdapat berbagai dokumen hukum, politik, dan ekonomi yang diharapkan mampu menjadi pedoman bagi suatu negara menata dirinya. Konstitusi juga berisi tentang aturan main antarberbagai pusat kekuasaan sehingga terdapat kepastian bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Secara etimologi istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis *Constituér* yang berarti membentuk,[1] sedangkan menurut bahasa Inggris *Constitution* berawal dari kata dasar *constitute* yang berasal dari bahasa Latin *"constituo; constitutum --- con, and statuo, to set, STATUE; STATUTE]. To settle, fix, or enact; to establish, to form or compose, to make up; to make a thing what it is; to appoint, depute, or elect to an office or employment; to make and empower"* (menetapkan, memastikan, mengundangkan, mendirikan, membentuk, membenahi, membuat sesuatu, menunjukkan, mewakilkan, atau memilih seorang pejabat atau mempekerjakan, memberikan kekuasaan), sedangkan yang dimaksud dengan "*Constitution* adalah *The system of fundamental principles according to which a nation, state, corporation, etc. is governed; the document embodying these principles"*[2] (sistem prinsip-prinsip mendasar yang mengatur suatu bangsa, negara, dan perkumpulan; sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip mendasar).

Constitution juga dapat berarti *"The fundamental law of the state, containing the principles upon which government is founded, regulating the division of the sovereign*

---

*Dosen Universitas Pancasila Jakarta.

[1]Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Cet. 5. Jakarta: Dian Rakyat, 1983), hlm. 10.

[2]*New Webster Dictionary 2002* CDROM.

powers and directing to what persons each of these powers is to be exercised" [3] (Hukum dasar dari suatu negara yang berisi prinsip-prinsip sebuah pemerintahan dibentuk, pengaturan pembagian kekuasaan dan pedoman pengujian terhadap kekuasaan-kekuasaan tersebut).

Dikaitkan dengan berbagai definisi tersebut, dapat dipahami jika sebuah konstitusi ada sebelum sebuah negara terbentuk, serta memiliki fungsi menetapkan aturan-aturan dasar yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan warga negara pada suatu negara. Konstitusi sebagai norma dasar pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai "mercu suar" yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk pembentukan hukum yang lebih rendah derajatnya dari konstitusi. Dengan demikian, peran konstitusi bagi suatu negara sangat penting bagi terselengaranya kehidupan ketatanegaraan yang demokratis dan efektif.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan konstitusi yang pertama dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

Pada perkembangan selanjutnya Negara Indonesia telah mengalami beberapa pergantian konstitusi, sejak 1949-1950 dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan 1950-1959 dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, serta Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali pada 5 Juli 1959 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959.

Dan sejak 1999 sampai dengan 2002 dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara periodik melalui Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001), dan Perubahan Keempat (2002). Selanjutnya dengan mengamati dinamika konstitusi tersebut, meskipun pergantian konstitusi telah dilakukan empat kali penggantian konstitusi, namun satu hal yang permanen dalam keempat konstitusi, bahwa nilai-nilai Pancasila tetap diterapkan sebagai Pembukaan, sehingga dapat dipahami bahwa nilai-nilai tersebut merupakan kesepakatan nasional bangsa Indonesia menata kehidupan ketatanegaraannya.

Dengan demikian, Pancasila masih tetap diajukan sebagai nilai-nilai yang mutlak dijadikan pedoman bagi pengaturan lebih lanjut dalam pasal-pasal konstitusi. Hal ini pula yang harus menjadi perhatian bagi segenap komponen bangsa menata kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, Pancasila masih diakui sebagai sumber pembentuk (*rechtsidee*) hukum positif di Indonesia, sehingga konkretisasi nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam substansi peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Bahkan pengaturan materi

[3]Renato R. Pasimio, *The Philippine Constitution (Its Evolution and Development) And Political Science* (Metro Manila: National Book Store Inc., 1991), hlm. 41.

konstitusi juga harus mengacu secara konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila yang termaktub pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam batang tubuh konstitusi merupakan tuntutan konsistensi penerapan norma secara sistemik, sehingga terdapat relasi fungsional antara nilai-nilai Pembukaan dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pada saat ini bangsa Indonesia mulai mempersoalkan adanya perbaikan terhadap kehidupan ketatanegaraan, sehingga diperlukan kajian secara komprehensif berdasarkan perspektif Pancasila. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk sumbangsih dan pertanggungjawaban moral kepada bangsa Indonesia, berikut diajukan tulisan sederhana ini disajikan bagi penyusunan *grand design* pengkajian konstitusi dibahas beberapa hal antara lain: Definisi dan pengertian *Grand Design*; *Grand Design* Pengkajian Konstitusi; Relasi Pembukaan dan Batang Tubuh dalam Konstitusi, serta Konsistensi Paradigmatik.

Tema tersebut acapkali menjadi bahan diskusi yang saya ajukan bersama-sama teman sejawat yang lain, termasuk Prof. Zudan yang akan merayakan ulang tahunnya.

Untuk itu, saya berpendapat tulisan ini tepat sebagai bahan awal kajian lebih lanjut, seraya mengucapkan *selamat ulang tahun Prof. Zudan*, semoga langkah dan kontribusi kita semua dapat membuat Hukum Tata Negara Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi, semoga.



Definisi dan Pengertian *Grand Design*

Setahun yang lalu, dalam rangka memperingati 50 Tahun Badan Pembinaan Hukum Nasional, diselenggarakan Konvensi Hukum Nasional yang bertemakan *Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional,* namun pencantuman frase *Grand Design* pada tema tersebut kurang tepat sehingga pada akhir konvensi diselenggarakan terdapat perbedaan tafsir antarpara peserta, pembicara, maupun panitia mengenai *grand design* dalam tema yang diajukan.

Secara fungsi, pengertian *grand design* dapat dianalogikan dengan *grand theory* dalam penyusunan suatu karya ilmiah sehingga *grand design* seharusnya berada di atas konstitusi atau Undang-Undang Dasar. *Grand Design* dimaksud merupakan sekumpulan nilai yang membentuk norma dalam konstitusi, sedangkan konstitusi merupakan norma yang harus dilaksanakan dalam bentuk undng-undang. Hal tersebut, sejalan dengan aksioma dalam ilmu hukum bahwa *lex superiori derogat legi inferiori*.

Istilah *grand theory* secara *mutatis mutandis* sama dengan paradigma yang dalam beberapa literatur berbahasa Jerman juga disebut dengan *Weltanschauung* sehingga dapat dipahami jika yang dimaksud dengan *grand design* adalah kerangka berpikir dalam menentukan model pembentukan suatu konsep, nilai, atau norma. Kerangka berpikir tersebut diajukan secara konsisten guna merefleksikan perumusan model, konsep, nilai, atau secara sistemik.



Grand Design Pengkajian Konstitusi

Sekurangnya terdapat tiga *grand design* atau paradigma yang dapat diajukan bagi pengkajian konstitusi yakni:

1. *Paradigma Yuridis-Filosofis*

   Paradigma *yuridis-filosofis* terumuskan berdasarkan suatu keyakinan bahwa: hakikat konstitusi merupakan hasil kesepakatan luhur segenap komponen bangsa demi melaksanakan kehidupan ketatanegaraan. Kesepakatan luhur tersebut diwujudkan dalam Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, selanjutnya berdasarkan paradigma ini diyakini, bahwa: *"Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya"* sehingga tiap pasal dalam UUD 1945 niscaya merupakan hasil transformasian sila-sila Pancasila yang tertuang sebagai Pokok-pokok Pikiran dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sekaligus merupakan embanan terselenggaranya fungsi-fungsi negara.

2. Paradigma Yuridis-Konstitusional

   Paradigma kedua merupakan paradigma yang berpendapat bahwa UUD 1945 merupakan: "hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, berisi pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, mengandung atau berisi suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin."[4]

   Berdasarkan paradigma ini, konstitusi pada dasarnya memuat minimal tiga materi muatan antara lain: "jaminan perlindungan hak asasi manusia dan warga negara, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental."[5]

---

[4]Sri Soemantri dan Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, Persepsi Terhadap Prosedur Dan Sistem-sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Sebelum dan Seduah Perubahan UUD 1945.* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 7.

[5]*Ibid.*

3. Paradigma Yuridis-Politis

   Paradigma terakhir yang beranggapan bahwa konstitusi merupakan sarana pembatasan kekuasaan bagi para penguasa, sehingga berdasarkan paradigma ini substansi konstitusi seharusnya memuat: jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia secara konkret dan terperinci, terdapatnya pengaturan tentang "sistem saling mengawasi yang seimbang" (*check and balances system*), dianutnya "asas pemisahan kekuasaan" (*separation of powers principle*) serta terlaksananya demokrasi secara langsung.

Mengacu pada Kerangka Acuan Kerja yang menghendaki keterkaitan antara nilai-nilai dalam Pembukaan dan Batang Tubuh dalam Konstitusi sebagai *grand design* pengkajian penyempurnaan konstitusi Indonesia, maka *grand design* yang mengacu pada paradigma filosofis-yuridislah yang dapat disepakati untuk diajukan sebagai model pengkajian.

Hal tersebut sesuai dengan paparan terdahulu bahwa *grand design* berada di atas konstitusi, sedangkan paradigma yuridis-filosofis menyatakan adanya keterkaitan antara pembukaan dengan batang tubuh. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber pembentukan norma dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.



Relasi Pembukaan dan Batang Tubuh dalam Konstitusi

Beberapa contoh relasional antara nilai-nilai yang terdapat dalam Pembukaan dan penormaan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

   Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini dinormakan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang hak memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan tiap warga negara.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

   Nilai ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang jaminan hak-hak asasi manusia dan hak warga negara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Persatuan Indonesia

   Nilai ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang menjamin adanya kesamaan (non diskriminasi) baik antarmanusia maupun penanganan pembangunan wilayah baik pusat maupun daerah, serta pasal-pasal yang menjamin bhineka tunggal ika, secara fisik, budaya, maupun lingkungan.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

   Nilai ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang demokrasi perwakilan (bukan demokrasi langsung), baik substansial (material) maupun secara prosedural (formal).

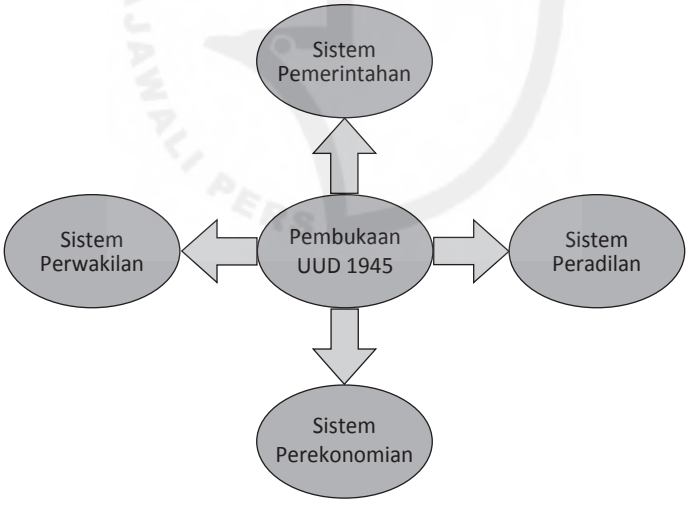
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

   Nilai ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang menjamin adanya pemerataan keadilan sosial dari, oleh, dan bagi seluruh rakyat. Sehingga nilai dimaksud dirumuskan dalam kepedulian seluruh rakyat Indonesia demi terselenggaranya tujuan nasional.



Konsistensi Paradigmatik

Segenap nilai tersebut secara sistemik diajukan sebagai kerangka dasar penyusunan berbagai sistem, yaitu sistem pemerintahan, sistem peradilan, sistem perwakilan, dan sistem perekonomian yang terumuskan dalam Batang Tubuh Konstitusi Indonesia, sebagaimana tampak pada gambar berikut.



Gambar 19.1. Konsistensi Paradigmatik Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh dalam Konstitusi Republik Indonesia

Dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hendaknya terdapat nilai persatuan Indonesia, demokrasi perwakilan yang didasarkan pula pada kebijaksanaan, keadilan sosial serta didasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian juga dengan sistem perwakilan dan sistem peradilan serta sistem perekonomian harus senantiasa berasal dari derivasi nilai-nilai dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terwujud tujuan nasional sebagaimana dicantumkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:

> Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Daftar Referensi

New Webster Dictionary 2002 CDROM

Pasimio, Renato R. *The Philippine Constitution (Its Evolution and Development) And Political Science*. Metro Manila: National Book Store Inc., 1991.

Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Cet.5. Jakarta: Dian Rakyat, 1983.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, 2003.

Soemantri, Sri dan Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem-sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945*. Bandung: Alumni, 2006.

20

DIPERLUKAN PENGATURAN KETENTUAN POLITIK HUKUM DALAM UUD 1945

Oleh:
*Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.H.**

Pendahuluan

Ketua Komisi Konstitusi, Sri Soemantri Martosoewignjo, telah menyampaikan Hasil Kajian terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diselesaikan oleh Komisi Konstitusi, lebih kurang lima tahun yang lalu. Hasil kajian—sebagai tugas sesuai dengan amanat yang diberikan oleh MPR—tersebut diserahkan secara resmi kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 6 Mei 2004, dalam Rapat Pleno Badan Pekerja MPR.

Pengkajian terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di atas, berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi; dan Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2003 tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi.

Tugas Komisi Konstitusi, yakni melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Menurut Keputusan MPR di atas, dalam melakukan tugas, Komisi Konstitusi harus berpedoman pada Pembukaan UUD 1945. Komisi Konstitusi bekerja dengan tetap berpegang kepada dasar dan arah Pembukaan UUD 1945, tanpa bermaksud mengkeramatkannya, dan menjadi kesepakatan untuk tidak diubah.

Menurut Sri Soemantri, sebagai bagian dari proses penuntasan reformasi konstitusi, Komisi Konstitusi menyadari sepenuhnya, bahwa perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR tidak terlepas dari pelaksanaan amanat

*Ketua Pusat Kajian Konstitusi Untag Surabaya.

The Founding Fathers and Mothers yang menyusun Undang-Undang Dasar. Pada waktu itu, para pendiri negara kita antara lain menyatakan, bahwa apabila suasana telah tenteran akan dibuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.

Hal di atas dapat dibuktikan, bahwa sejarah pembentukan UUD 1945 memang didesain oleh para pendiri negara (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI) sebagai UUD yang "bersifat sementara", karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana ketergesa-gesaan. Soekarno selaku Ketua PPKI pada 18 Agustus 1945 menegaskan sifat kesementaraan UUD 1945 sebagai berikut:

> ... bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekadar Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah *revolutiegrondwet*. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998:186).

Sejalan dengan itu, mempelajari materi muatan dalam "Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Perubahan dan Usul Komisi Konstitusi", tercantum penambahan pasal dalam usulan Komisi Konstitusi, yakni ketentuan Pasal 24D, 24E, 24F, dan 24G. Hal ini menunjukkan, bahwa Undang-Undang Dasar harus dibuat lebih lengkap dan sempurna. Khususnya ketentuan Pasal 24F merupakan pasal tentang Politik Hukum yang menjelaskan, bahwa negara menata dan mengembangkan sistem hukum nasional dengan memelihara dan menghormati keberagaman nilai-nilai hukum dan sumber-sumber hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, apakah diperlukan pengaturan ketentuan politik hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan? Apakah visi-misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mengarah pada materi mutan yang mengarah pada sistem hukum nasional?



Ketentuan Pasal 24F Sebagai Politik Hukum

Politik hukum (*rechtspolitiek*) menurut Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, adalah: 1) kebijakan dasar; 2) arah hukum, bentuk hukum, isi hukum; dan 3) yang akan dibentuk. (Padmo Wahjono, 1986: 160).

Dari definisi "kebijakan dasar" di atas, dapat dijabarkan, bahwa politik hukum selain ditemukan dalam UUD 1945, juga terdapat pula dalam Ketetapan MPR, khususnya Ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dalam ketentuan Pasal 3 UUD 1945 hasil Perubahan menentukan, bahwa kewenangan MPR meliputi mengubah dan menetapkan UUD (ayat 1); melantik presiden dan/atau wakil presiden (ayat 2); dan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (ayat 3).

Dari ketentuan Pasal 3 di atas, MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan produk hukum berupa ketetapan MPR maupun Keputusan MPR. Karena MPR sudah tidak mengeluarkan Ketetapan MPR, maka MPR tidak berwenang menetapkan GBHN.

Sementara itu, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004, ketentuan berlakunya, pada saat itu, sudah menginjak batas akhir tahun. Artinya, bahwa sejak tidak diberlakukannya GBHN tersebut, nantinya politik hukum hanya terdapat di dalam UUD 1945. Secara substansial, benarkah ketentuan Pasal 24A, 24B, dan 24C mengatur politik hukum?

Sebelum menjawabnya, maka perlu diuraikan terlebih dahulu definisi tentang "arah hukum". Kemungkinan yang terjadi pada arah hukum adalah unifikasi hukum, pluralisme hukum, dan kodifikasi hukum. Karena unifikasi hukum tidak mungkin dilakukan, maka pluralisme hukum menjadi sasaran, yakni terdiri atas Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Barat, dan Hukum Nasional. Sementara itu, kodifikasi hukum, yaitu pembukuan bahan-bahan hukum secara tuntas dalam kitab-kitab hukum, masih belum dimungkinkan.

Selanjutnya, "bentuk hukum" sejak 1966 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, terdiri atas:
    1) Undang-Undang Dasar 1945;
    2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
    4) Peraturan Pemerintah;
    5) Keputusan Presiden;
    6) Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti:
        – Peraturan Menteri;
        – Instruksi Menteri;
        – dan lain-lainnya.

b. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, dalam ketentuan Pasal 2, terdiri atas:
   1) Undang-Undang Dasar 1945;
   2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   3) Undang-Undang;
   4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
   5) Peraturan Pemerintah;
   6) Keputusan Presiden;
   7) Peraturan Daerah.
c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
   1) Undang-Undang Dasar 1945;
   2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
   3) Peraturan Pemerintah
   4) Peraturan Presiden;
   5) Peraturan Daerah.

Sementara itu, yang dimaksud "isi hukum" merupakan substansi atau materi muatan yang terkandung di dalamnya. Misalnya, Undang-Undang tentang Pencucian Uang; *Convention on International Court*, yang menentukan jikalau 60 negara telah meratifikasi, maka negara lain yang tidak tunduk, harus mengikutinya.

Yang terakhir, dari definisi tentang "yang akan dibentuk" mempunyai arti, bahwa politik hukum hanya yang berkaitan dengan *ius constituendum* sehingga politik hukum hanya terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Konsekuensinya, dapat muncul kemungkinan kita tidak mempunyai politik hukum. Hal itu terjadi, karena UUD 1945 tidak mengatur secara tegas politik hukum. Dengan demikian, patutlah dihargai apabila Komisi Konstitusi mengusulkan ketentuan Pasal 24F, sebagaimana diuraikan di atas. Munculnya ketentuan Pasal 24F tersebut, karena adanya kekosongan politik hukum yang terdapat dalam UUD 1945.

Selain itu, kalau kita membandingkan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), mengatur rumusan politik hukum di dalamnya. Ketentuan Pasal 102 menjelaskan, bahwa hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab hukum, kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri. Hal ini berarti, ketentuan Pasal 102 tersebut menghendaki kodifikasi hukum.

Dari uraian definisi di atas, maka politik hukum menurut Padmo Wahjono, terdiri atas:

a) Materi muatan atau substansinya meliputi bentuk hukum, arah hukum, dan isi hukum;
b) Bentuk hukumnya adalah Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c) Lembaga yang menetapkan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat; serta
d) Jangkauannya adalah *ius constituendum*.



Visi-Misi Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Sistem Hukum Nasional

C.F.G. Sunaryati Hartono dalam bukunya *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* menjelaskan, bahwa suatu sistem itu selalu terdiri atas sejumlah unsur atau komponen yang saling berkaitan dan pengaruh-memengaruhi, lagi pula terikat oleh satu atau beberapa asas tertentu. Maka Sistem Hukum Nasional terdiri atas sejumlah unsur atau komponen, yang sebagian pada saat ini sudah ada dan sudah berfungsi, tetapi sebagian besar lagi masih harus diciptakan. (C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991:37).

Dari uraian di atas, Sunaryati Hartono, selain menitik beratkan pada hukum positif atau *ius constitutum*, juga melihat pada dimensi hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau *ius constituendum*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu kiranya mencermati visi-misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Terdapat tiga pasangan calon yang akan berlaga dalam Pemilihan Umum Presiden pada 8 Juli 2009. Tanggal tersebut merupakan tonggak penting bagi bangsa Indonesia untuk melakukan konsolidasi demokrasi, dan menjadikan demokrasi prosedural dapat lebih mewujud secara nyata dalam kehidupan keseharian rakyat.

Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Bandung, mengemukakan visi-misinya sebagai berikut:

a) Membentuk kabinet presidensial yang amanah, efektif, dan kredibel;
b) Bekerja keras untuk rakyat, bukan untuk berpolitik sendiri-sendiri;
c) Tidak menyerahkan perekonomian kepada pasar bebas. Intervensi negara dengan aturan main yang tegas dan adil. Namun tidak boleh terlalu jauh campur tangan, karena akan mematikan sektor swasta;
d) Membangun pemerintahan yang bersih, tidak dikotori suap, memperdagangkan kekuasaan, dan mencampuradukkan urusan negara dan bisnis keluarga. (*Kompas,* 19 Mei 2009)

Dari visi-misi di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pasangan tersebut memang telah menitikberatkan pada sistem hukum nasional, baik *ius constitutum* maupun *ius constituendum*. Akan tetapi, terhadap masalah ketentuan yang mengatur politik hukum tidak terjabarkan.

Selanjutnya, pasangan Jusuf Kalla-Wiranto yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Tugu Proklamasi Jakarta, mengemukakan visi-misinya sebagai berikut:

a) Komitmen untuk bersama-sama menjaga serta membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, membangun ekonomi kerakyatan, dan berbagi kewenangan di pemerintahan;
b) Berjanji akan melindungi ekonomi rakyat. Menyejahterakan rakyat dengan adil dan makmur;
c) Menyelenggarakan pelayanan pemerintahan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya;
d) Membangun pemerintahan yang kuat dan tegas, serta lebih cepat dan lebih baik. (*Kompas,* 19 Mei 2009).

Menilik visi-misi di atas, visi-misi pasangan Jusuf Kalla-Wiranto hampir sama dengan visi-misi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, yakni sama-sama menitikberatkan pada sistem hukum nasional, baik *ius constitutum* maupun *ius constituendum*. Akan tetapi terhadap masalah ketentuan yang mengatur politik hukum tidak terjabarkan.

Sementara itu, pasangan Megawati-Prabowo yang akan mendeklarasikan di Bantar Gebang, Bekasi, juga telah mengemukakan visi-misinya sebagai berikut:

a) Sepakat untuk membangun ekonomi kerakyatan Indonesia, serta berkomitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan keutuhan bangsa;
b) Keberpihakan terhadap *wong cilik*, seperti petani, nelayan, buruh, guru, dan pedagang kecil;
c) Menjalankan kemandirian di bidang ekonomi;
d) Prabowo ditugaskan menangani masalah perekonomian untuk fokus membangun ekonomi kerakyatan dan kebangkitan ekonomi rakyat. (*Kompas,* 19 Mei 2009).

Setelah mencermati visi-misi ketiga pasangan calon, yakni Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, Jusuf Kalla-Wiranto, dan Megawati-Prabowo, semuanya juga sama-sama menitikberatkan pada sistem hukum nasional, baik *ius constitutum* maupun *ius constituendum*. Akan tetapi, khususnya arah kebijakan di bidang hukum, dalam hal ini politik hukum; sama sekali tidak tersentuh.

Rekomendasi

Setelah dilakukan pembahasan seperti diuraikan di atas, maka sampailah pada kesimpulan, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan (Pertama 1999, Kedua 2000, Ketiga 2001, dan Keempat 2002) tidak mengatur tentang politik hukum. Karenanya, diperlukan pengaturan ketentuan politik hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
b. Visi-misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mengarah pada materi mutan yang mengarah pada sistem hukum nasional. Akan tetapi, khususnya arah kebijakan di bidang hukum, dalam hal ini politik hukum; sama sekali tidak tersentuh.

Setelah diuraikan kesimpulan di atas, maka diperlukan saran, sebagai berikut:

a. Seharusnya ketentuan Pasal 24F dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 saat perubahan konstitusi mendatang. Sebab usulan Komisi Konstitusi, yakni untuk memasukkan ketentuan Pasal 24F ke dalam konstitusi, karena adanya kekosongan politik hukum yang ada di dalam UUD 1945.
b. Seharusnya substansi dalam visi-misi ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tidak hanya sebatas retorika saja.

Daftar Referensi

Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.

Kompas, 19 Mei 2009.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Buku I, Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 2004.

————————. *Buku II, Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Perubahan dan Usul Komisi Konstitusi*. Jakarta, 2004.

Martosoewignjo, Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.

————————. *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*. Bandung: Unpad Press, 2002.

Muqoddas, Moh. Busyro, et. al. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: UII Press, 1992.

Padmo Wahjono. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)–Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945–22 Agustus 1945*. Jakarta, 1998.

Soepiadhy, Soetanto. *Undang-Undang Dasar 1945: Kekosongan Politik Hukum*. Yogyakarta: Kepel Press, 2004.

————————, *Meredesain Konstitusi*, Yogyakarta: Kepel Press, 2004.

Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 setelah empat kali perubahan (1999, 2000, 2001, dan 2002).

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2003 tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-004.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

21

PRESIDENSIAL, BURUK RUPA CERMIN DIBELAH

Oleh:
Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H.*

Sepanjang periode 2004-2009 hampir sebagian besar pengamat politik serta pakar hukum tata negara berpendapat bahwa sistem presidensial kita sangat lemah akibat multipartai. Saya bisa memahami jikalau ahli politik berartikulasi seperti itu, namun jikalau para ahli tata negara maka saya mulai curiga bahwa mereka sudah mulai "murtad". Saya pun pernah mengalami masa awal yang hampir murtad, namun ketika tiap hari bergelut dengan huruf, kata dalam konstitusi menyangkut sistem presidensial kita, saya langsung tersadar bahwa semua pikiran itu adalah 'dosa'.

Pada prinsipnya paska perubahan konstitusi, presiden dan wakil presiden menjadi sangat kuat kedudukannya seiring dengan konsekuensi pemilihan presiden langsung oleh rakyat. kalau dahulu, presiden dituduh melanggar GBHN saja, yang tidak jelas apa definisi GBHN membuat presiden bisa jatuh ditengah jalan dengan dinamika konfigurasi politik di MPR melalui Memorandum I, II dan Sidang Istimewa seperti yang dialami Gus Dur.

Namun kini, se"diktator" apa pun presiden menjalankan kekuasaan pemerintahannya, presiden hanya bisa jatuh ketika dia diduga melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, ataupun perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden. (Pasal 7A UUD 1945). Prosesnya pun menjadi sangat bertele-tele, DPR mendakwa, diperiksa oleh MK, jikalau MK menyatakan dakwaan terbukti sah dan meyakinkan (ruang konstitusi), maka proses ini pun belum selesai. Putusan MK tersebut akan kembali lagi dalam ruang politik yaitu DPR untuk diparipurnakan lagi untuk mengusulkan ke MPR (bisa jadi tidak korum atau gagal disetujui), dan di MPR (ada anggota DPD) tidak secara otomatis putusan MK distempel untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden.

---

*Doktor Hukum Tata Negara, Mantan Koordinator Staf Ahli MK RI.



Koalisi Partai Pendukung

Bahwa koalisi partai pengusung calon presiden terpilih yang kemudian di tengah jalan pecah kongsi, memang bisa menjadi simalamakama. Tetapi sekali lagi, simalakama itu adalah problem politik, problem aura politik bukan problem konstitusi!. Koalisi partai, haram hukumnya dalam perjalanan rezim kekuasaan pemerintahan untuk *flat* mendukung presiden dalam segala putusan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya. Jikalau begitu, buang jauh-jauh konsep *checks and balance,* yang terjemahan mudahnya hadir guna "mementung" kekuasaan lainnya.

Harus disadari bahwa demokrasi dengan kemunculan ikon wakil rakyat adalah antitesa monarki yang cenderung absolut. Legislatif, eksekutif bahkan yudikatif semua berada dalam satu tangan. Oleh karenanya jangan sampai kita ingin kembali ke zaman purba, dengan bercita-cita menguatkan sistem presidensial, dengan membuat DPR menjadi "blur" dengan lembaga presiden. Jikalau ini terjadi berarti kita membenarkan perilaku politik orde baru, ketika wakil rakyat adalah cecunguk presiden yang berhasil karena "aura" politik pemangku jabatan presiden.

Konstitusi hanya menghalalkan koalisi partai hanya dalam rezim pemilihan presiden bukan dalam rezim pemerintahan presiden. Koalisi dalam rezim pemilihan presiden yang dimaksud bahwa mulai saat pemilu ketika diusulkan oleh koalisi patpol (Pasal 6A ayat (2) UUD 1945) untuk kembali lagi berkoalisi dalam pemilihan di MPR jikalau di tengah jalan keduanya mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan. MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau 'gabungan parpol' yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945). Jadi, siapa bilang Partai Bulan Bintang pecah kongsi dengan Partai Demokrat, PBB akan bersanding lagi dengan Demokrat jikalau hal yang tidak diinginkan terjadi yaitu presiden dan wakil presiden secara bersaman mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebelum 2009.

Konstitusi membatasi koalisi parpol yang permanen hanya pada saat pemilihan presiden saja karena ketika presiden setelah dilantik akan berada dalam rezim kekuasaan pemerintahan yang harus dikontrol oleh DPR. Parpol-parpol tersebut mempunyai orang-orang di DPR yang menjalankan fungsi pengawasan. Setiap anggota DPR mempunya hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas, hingga mengkristal dalam hak institusi DPR berupa interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.

Jikalau partai dipaksa mendukung permanen presiden dalam kekuasaan pemerintahannya ini sama dengan mengebiri hak konstitusional DPR baik sebagai institusi maupun individual anggota DPR. Ini pelanggaran prinsip konstitusionalisme!. Bukankah kita menginginkan DPR mengawasi presiden, tidak menjadi cecunguk presiden?. Buanglah pemikiran bahwa presiden dan DPR harus dibekap dalam dialektika parpol!. Sebab, kedua lembaga itu bukan hanya milik parpol semata sehingga yang lain, perkumpulan artis, jurnalis, pengusaha,supir hingga tukang ojek hanya menjadi penonton!



Kekuasaan Pemerintahan

Sistem presidensial kita, dalam kekuasaan pemerintahannya, presiden hanya membutuhkan persetujuan langsung DPR dalam hal kebijakan luar negeri berupa menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR (Pasal 11 UUD 1945).

Beberapa kelebihan sistem presidensial kita, di antaranya bahwa dalam sebuah proses pembentukan undang undang jikalau presiden tidak setuju, maka meski DPR adalah pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang maka rancangan undang undang tersebut tetap tidak dapat terbentuk menjadi undang undang untuk diundangkan keberlakuannya. Berbeda dengan di beberapa negara yang kita anggap penganut sistem Presidensial murni, sesungguhnya posisi presidennya lebih lemah dalam proses legislasi dibanding Indonesia, meski presidennya memveto RUU, namun jikalau veto tersebut kemudian "teranulir" oleh senat, maka RUU tersebut tetap bisa lanjut pembentukannya menjadi undang undang. Disisi lain kekuasaan presiden di Indonesia dalam memilih orang-orang yang akan duduk di kabinet (kementerian negara) adalah hak prerogatif dari presiden, tanpa perlu persetujuan parlemen, di negara yang kita anggap sistem presidensial murni tersebut, maka tetap calon anggota kabinet tersebut baru dapat dipilih oleh presiden jikalau sudah mendapatkan konfirmasi atau persetujuan senat.

Hampir semua kebijakan dalam negeri menjadi domain libido penuh presiden. Jadi, siapapun menjadi presiden tidak perlu ragu untuk bersikap tegas, bisa untuk tidak perlu berlama-lama berdiskusi dan tetap dapat memutuskan dan menghitung cepat langkah keputusannya (Donny Gahral Adian, Presidensial Bukan Etika Politik, 27/11). Presiden bahkan dengan hak subjektifnya masih bisa mengeluarkan Perpu sebagai pemadam kebakaran dalam hal kegentingan memaksa, bahkan bisa "memveto" (baca: tidak menyetujui) RUU DPR.

Oleh karenanya ruang "kediktatoran" tersebut tetap tersedia, selama "kediktatoran" tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, tentunya jikalau kita masih sepakat Indonesia negara hukum dengan supremasi konstitusi adalah ruhnya sebagai wujud kehendak seluruh rakyat (*constitusional democracy*). Jadi, harus dibedakan sistem presidensial yang kuat atau presiden yang tidak kuat, jangan sampai tampilan politik personal mengkambinghitamkan sistem, bak pepatah buruk rupa cermin dibelah, tak pandai menari lantai terjungkit? Cilakalah daulat konstitusi!

RAJAWALI PERS

22

MENGGUGAT SUPERIORISASI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILU

Oleh:
*Prof. Dr. Wahyono, S.H., M.S.**



Pendahuluan

BAGAIMANAPUN SEMPURNANYA suatu konstitusi, pada suatu saat akan tertinggal oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan situasi yang terjadi pada negara tersebut. Oleh karena itu, suatu konstitusi pada suatu saat akan memerlukan perubahan sesuai dengan perkembangan negara tersebut. Pertama-tama gagasan

Proses perubahan UUD 1945, dilakukan melalui amandemen yang lazim disebut *to change or modify for the better to alter by modification or addition*. Oleh karena itu, hasil dari amandemen UUD 1945, adalah bentuk UUD modifikasi, menghilangkan atau menambah ketentuan yang lama dalam UUD 1945, yang berarti konstitusi yang lama masih tetap berlaku. Perubahan UUD 1945 merupakan amandemen dari UUD 45 asli. Yang artinya amandemen tersebut merupakan bagian dari konstitusinya.

Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali, dengan menghasilkan perubahan-perubahan yang signifikan khususnya dalam perkembangan lembaga-lembaga tinggi negara.

Amandemen UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia melalui perubahan UUD 1945, baik perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam kekuasaan dan pelembagaan legislatif, eksekutif maupun yudisial. Dalam kekuasaan pelembagaan yudisial memunculkan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) dan Komisi Yudisial, di samping

*Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) beserta badan-badan peradilan yang berwenang di bawahnya.

UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD Pasal 1 (ayat) 2 dan ditugaskan pula Negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan tersebut di atas maka salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan MK sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara-perkara tertentu sidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi *(the guardian of constitution)* agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai kehendak dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda konstitusi.

Sesuai dengan amanat dalam Pasal III aturan peralihan UUD 1945, MK telah dibentuk pada 17 Agustus 2003 dan keberadaannya dijamin oleh Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 UUD 1945 dan kemudian diatur dalam UU No. 1 Tahun 2003.

MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, di samping MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Hal ini berarti MK terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri, dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. MA dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya yang murah.

Kewenangan konstitusional MK melaksanakan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan MK merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.

Pascaamandemen konstitusi juga terjadi perubahan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Masih segar dalam ingatan kita bahwa baru saja melaksanakan pemilihan umum presiden tahun 2004 sebagai sarana perwujudan kedaulatan dan keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan negara yang disalurkan melalui partai politik peserta pemilihan umum. Pemilihan Umum Presiden kali ini berbeda dengan pemilihan umum pemilihan karena dilaksanakan secara langsung untuk kali pertama dalam sejarah ketatanegaraan modern dan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan umum 2004 ini memberi kesempatan yang lebih besar kepada pemilih untuk menentukan *secara langsung* siapa saja wakilnya yang akan duduk di DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya. Begitu pula dengan pasangan presiden dan wakil presiden juga

dipilih secara langsung. Di samping itu, untuk memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional, diperkenalkan sebuah lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggotanya juga dipilih secara langsung.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh masyarakat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik lebih demokratis dan bertanggung jawab.

UUD 1945 yang mengalami empat kali amandemen dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam pasangan secara langsung oleh rakyat dan "pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."[1] Selanjutnya dalam 1945 Pasal 7 yang ditindaklanjuti dengan UU No. 12 tahun 2003 Pasal 15 pemilihan umum presiden dan wakil presiden dipilih setiap lima tahun sekali melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.[2] Tentu saja hal ini merupakan perubahan positif dalam demokratisasi Indonesia dan memberikan pengalaman dan pembelajaran politik berharga bagi rakyat terutama dari segi pelaksanaan *(electoral process)*. Karena masyarakat berangapan bahwasanya di dalam tatanan demokrasi sebuah negara yang merupakan standar untuk penentuan sebuah *hukum yang baik* adalah bersumber dari aspirasi rakyat, yang selanjutnya aspirasi ini diamanatkan melalui wakil rakyat yang benar-benar responsif dan tanggap terhadap segala tuntutan nurani masyarakat sehingga dapat sinergis dengan perkembangan zaman global sekarang ini.

Setelah proses Pemilihan Umum Legislatif berlangsung, dan sebentar lagi dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, tentunya akan terjadi masalah pelanggaran pelaksanaan pemilu tersebut sehingga MK sebagai lembaga yang mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa pemilu perlu mendapat perhatian, agar proses penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat.

Gugatan atas perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2009 merupakan suatu hal yang menunjukkan adanya perkembangan positif dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Kondisi ini tentunya harus dapat diperhatikan serius oleh lembaga MK yang relatif masih baru susunan personelnya, yang kebanyakan merupakan orang-orang dari partai politik, harus bersikap adil jangan melihat dari partai politik mana yang bersengketa. Di sini rakyat seharusnya diberi hak kontrol langsung terhadap setiap keputusan dari MK., agar jangan terjadi paradigma supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat beralih

---

[1]UUD 1945 Amandemen ke-3, Pasal 6A ayat (1), (2) dan Pasal 7, (Surabaya: Bina Pustaka, Cetakan I, 2002).

[2]UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 15, (Bandung: Focusmedia, Cetakan I, 2003).

menjadi supremasi Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, perlu penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana proses, prosedur, sampai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.



Pemilihan Umum dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi

1. Perkembangan Pengaturan Pemilu dalam Konstitusi Indonesia

Perkembangan pelaksanaan Pemilu Indonesia dapat dikaji melalui perkembangan Konstitusi (UUD 1945) yang dipakai, yaitu:

a. UUD 1945 periode pertama (18 Agustus 1945-27 Desember 1949);
b. Konstitusi RIS 1949 (27 Desember–17 Agustus 1959);
c. UUDS 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959);
d. UUD 1945 periode kedua (5 Juli 1959–19 Oktober 1999);
e. UUD 1945 periode ketiga setelah mengalami amandemen pertama (19 Oktober 1999), amandemen kedua (18 Agustus 2000),[3] amandemen ketiga (9 November 2001), dan amandemen keempat (10 Agustus 2002).

Dari konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku tersebut, ternyata ketentuan normatif yang secara eksplisit memuat tentang perlunya diselenggarakan pemilihan umum hanya terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUDS 1950, sedangkan UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah mengalami perubahan pertama dan kedua, secara eksplisit baik memuat tentang keharusan adanya pemilihan umum. Tetapi dalam praktik kehidupan ketatanegaraan, pemilihan umum di Indonesia pernah berlangsung sekali pada masa UUDS 1950 (September 1955 untuk memilih DPR dan Desember 1955 untuk memilih Badan Konstitusi dan delapan kali pada masa UUD 1945 periode kedua (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004).

Dari uraian tersebut dapat diperoleh pemahaman, bahwa ternyata perkembangan kehidupan ketatanegaraan tidak hanya dipengaruhi oleh materi normatif dari sebuah konstitusi suatu negara, namun juga dipengaruhi oleh sistem situasi dan kondisi sistem ketatanegaraan yang bermuara pada politik hukum dari negara yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah di negara kita Indonesia. Sistem situasi di negara kita pada waktu itu belum menentu, ditambah lagi dengan sistem ketatanegaraan yang memberikan kekuasaan yang

[3]Mukhtie Fadjar, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, In-trans, 2003, hlm. 95.

besar kepada presiden. Akibatnya kekuasaan presiden sangat mendominasi semua perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Pada masa ini tujuan negara tidak lagi sesuai dengan yang tercantum dalam konstitusi (UUD 1945), tetapi untuk mencapai kekuasaan politik. Di sini negara identik dengan penguasa. Oleh karena itu, tujuan negara adalah untuk membangun kekuasaan secara efektif. Pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan kehendaknya. Oleh karena itu, pada waktu itu ada anggapan bahwa seolah-olah PEMILU itu hanya untuk memilih presiden. Dikarenakan pada waktu itu presiden sudah dipilih untuk seumur hidup, maka tidak perlu lagi pemilu.

2. Mengkaji Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Sembilan kali pemilihan umum yang telah berlangsung di Indonesia kiranya dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Pemilihan umum tahun 1955;
b. Pemilihan umum orde baru (1971-1997);
c. Pemilihan umum reformasi (1999, 2004, dan 2009).

Untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap tiga kelompok atau corak, pemilihan umum yang lalu tersebut digunakan tiga kriteria, yaitu prinsip kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur.

a. Pemilihan Umum Tahun 1955

Pemilihan umum 1955 yang dilaksanakan pada 29 September 1955 (untuk memilih DPR) dan 15 Desember 1955 (untuk memilih Badan Konstituante) dan badan dasar hukum UU No. 7 Tahun 1953 adalah dalam rangka realisasi ketentuan yang termuat dalam UUDS 1950 (mukadimah) Pasal 1 (ayat) l, Pasal 35, Pasal 56-60, Pasal 134 dan Pasal 135 (UUDS 1950). Pemilihan umum tersebut berada dalam konteks ketatanegaraan dengan sistem parlementer dan multipartai. Ada dua alasan penting diadakannya pemilihan umum 1955, yaitu *pertama,* dengan melak-sanakan prinsip pemilihan umum tersebut akan dapat mengakhiri krisis kabinet yang silih berganti dan akan dapat menciptakan suatu parlemen yang representatif serta mempunyai kekuatan moril dan sekaligus melakukan penyaringan partai-partai yang banyak jumlahnya. *Kedua,* pemilihan umum 1955 juga diharapkan melalui konstituante hasil pemilihan umum bisa menghasilkan UUD baru pengganti UUDS 1950 pemilihan umum 1955 sering dinilai oleh banyak pakar sebagai pemilihan umum yang paling demokratis, termasuk bila dinilai dari ketiga kriteria tersebut di atas. Akan tetapi, pemilihan umum 1955 ternyata gagal mempertahankan sistem parlementer dengan pemerintahan yang stabil karena tidak ada partai yang mencapai suara mayoritas (lebih dari separo). Bahkan seperti dikemukakan oleh Herbert Feith, terjadinya separatisme dan koalisi Presiden Soekarno

dengan tentara yang tidak puas dengan sistem parlementer yang didominasi oleh peran partai politik menyebabkan terjadinya krisis dalam ketatanegaraan dan politik sehingga lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diberlakukan kembali UUD 1945 yang mengakibatkan terjadinya pergeseran sistem pemerintahan dari sistem parlementer ke sistem presidensial. Barangkali, sistem proporsional yang diterapkan dalam pemilihan umum 1955 tidak mampu melakukan seleksi dan penyederhanaan terhadap sistem multi partai, sehingga sukar terbentuk pemerintahan yang kuat.[4]

b. Pemilihan Umum pada Masa Orde Baru

Menelaah pemilihan umum orde baru tidak bisa lepas dari format politik yang ingin dibangun oleh orde baru, yaitu sebuah sistem politik demokrasi Pancasila dengan komitmen untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Format politik orde baru ingin mengeliminasi pengalaman traumatik sistem politik demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin.

Ciri-ciri format politik orde baru adalah sebagai berikut:

1) Sangat dominannya posisi Presiden (Soeharto) sebagai figur sentral kehidupan politik Indonesia selama 30 tahun;
2) Penataan lembaga-lembaga negara menurut format UUD 1945, tetapi tidak diberi peranan yang maksimal karena dominasi eksekutif;
3) Penataan terhadap infra-struktur politik rakyat UU No. 3 Tahun 1975 jo UU No. 3 Tahun 1985 (UU Partai Politik dan Golkar) dan UU No. 8 Tahun 1985 (UU keormasan) yang melahirkan sistem kepartaian hegemonik;
4) Sangat dominannya peran politik ABRI (kini berubah menjadi TNI dan POLRI) sehingga lewat konsep dwifungsinya mereka mendominasi kehidupan politik pemerintahan maupun kehidupan politik masyarakat;
5) Penjinakan radikalisme politik melalui proses depolitisasi massa, misalnya konsep masa mengambang *(floating mass)*.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa format politik orde baru menempatkan dominasi atau hegemoni negara yang begitu besar atas masyarakat.

Dalam konteks format politik orde baru seperti tersebut di atas, maka telah diselenggarakan pemilihan umum secara periodik selama enam kali (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) dengan menggunakan sistem pemilihan umum proporsional meskipun bukan proporsional murni. Sehingga melalui serangkaian pemilihan umum yang diadakan dipandang dari ketiga kriteria kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur, pemilihan umum orde baru nyaris hanya mempertahankan status

[4] *Ibid,* hlm. 97.

quo. Hasilnya memang tercipta pemerintahan yang stabil selama 30 tahun dan pembangunan ekonomi (dengan titik berat pertumbuhan ekonomi) yang signifikan, namun ternyata rapuh dalam fundamennya sehingga kembali terjadi krisis ketatanegaraan pada 1998. Pemilihan umum pada era orde baru sebenarnya hampir sama tujuanya dengan pemilu era sebelumnya, yakni mempertahankan kekuasaan presiden. Walaupun tidak ada ketentuan langsung bahwa "presiden Indonesia adalah seumur hidup", tetapi kenyataannya seorang presiden dapat dipilih secara terus-menerus. Di sini terlihat jelas bahwa pelaksanaan pemilu dibuat sedmikian rupa agar konstituen tertentu selalu menang. Di samping itu, partai-partai dibatasi hanya tiga saja. Selanjutnya yang memilih presiden adalah rakyat melalui lembaga MPR. Karena konstituen tertentu dalam hal ini Golkar selalu menang, maka mendapat kursi dominan di MPR. Yang tentu saja akan selalu memilih presiden yang bersangkutan (Soeharto), yang berkuasa hingga 32 tahun.

c. Pemilihan Umum pada Era Reformasi (1999)

Pemilihan umum pertama pasca orde baru (era reformasi) pada 1999 ditandai dengan semangat demokratisasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), tetapi juga diwarnai euforia kebebasan dan semangat resistensi terhadap semua hal yang berbau orde baru, sehingga terkesan irrasional dan emosional. Di bawah tiga Undang-Undang politik baru (UU Nomor 2, 3, dan 4 tahun 1999) pemilihan umum berlangsung dalam format sistem UUD 1945, namun menganut sistem multi partai (48 kontestan pemilihan umum). Sistem pemilihan umum yang digunakan tetap sistem proporsional dengan sedikit diberi warna distrik.

Pemilihan umum 1999 dengan format sistem ketatanegaraan UUD 1915 ternyata tidak menghasilkan partai pemenang dengan suara mayoritas mutlak seperti pada pemilihan umum orde baru sehingga partai pemenang pemilihan umum (PDIP dengan suara 30%) tidak otomatis sebagai yang memerintah. Bahkan akhirnya presiden yang terpilih bukan dari partai pemenang pemilihan umum dan pemerintahan yang dibentuk merupakan pemerintahan koalisi partai-partai.

Implikasi dari kondisi tersebut ialah munculnya gagasan dilakukannya pemilihan presiden secara langsung, pemilihan kepala daerah secara langsung, dan pemilihan umum dengan sistem distrik.

Terlepas dari kekurangan-kekurangannya, pemilihan umum 1999 telah mengalami perbaikan-perbaikan, baik dalam *electoral laws,* maupun dalam *electoral process,* dan merupakan pemilihan umum terbaik di bawah UUD 1945 selama ini. Sehingga ditinjau dari ketiga kriteria kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur sudah terpenuhi.[5]

[5]*Ibid,* hlm. 100

Dalam Pemilu Era Reformasi, ada juga kekurangan-kekurangannya, antara lain adanya dominasi Lembaga DPR, yang merupakan penjelmaan atau wakil dari partai-partai yang ikut pemilu. Partai-partai di sini merasa mempunyai andil besar untuk memilih presiden oleh karena itu melalui DPR meminta jatah jabatan menteri untuk duduk di kabinet presiden terpilih. Hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah tatkala menteri yang bersangkutan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan bidang jabatannya. Celakanya kebanyakan menteri tidak mempunyai kemampuan sesuai dengan jabatan yang didudukinya, akibatnya dalam periode presiden terpilih para menterinya selalu berganti-ganti. Dan penggantinya pun tetap dari utusan partai-partai yang cenderung kurang mempunyai kemampuan pada bidangnya. Apalagi sistem pemilu secara langsung yang memungkinkan presiden terpilih bukan calon dari partai pemenang pemilu. Akibatnya presiden tidak begitu bebas dalam menjalankan roda pemerintahan, karena selalu mendapat sorotan dari DPR, yang nota bene terdiri dari anggota-anggota partai pemenang pemilu yang tentu saja memperoleh kursi yang besar.

3. Pembaruan Sistem Pemilihan Umum

Sebenarnya gagasan untuk menerapkan sistem pemilihan umum selain sistem proporsional di Indonesia pernah direkomendasikan oleh seminar Angkatan Darat (AD) III pada 1966. Kemudian pada 21 Februari 1995 Presiden Soeharto juga telah meminta LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) untuk melakukan penelitian tentang perbaikan sistem pemilihan umum.

Kalau kita simak rekomendasi hasil penelitian LIPI, ada tiga tahap perbaikan dari/atau perubahan sistem pemilihan umum yang ditawarkan yaitu:

Tahap I : Pemilihan umum 1997 dipakai sistem proporsional yang disempurnakan;

Tahap II : Pemilihan umum 2002 merupakan transisi dari sistem proporsional yang disempurnakan ke sistem distrik;

Tahap III : Pemilihan umum 2007 dengan sistem distrik yang disempurnakan.

Dari rekomendasi LIPI tersebut menunjukkan bahwa menurut LIPI sebaiknya tidak diterapkan sistem proporsional umum maupun sistem distrik ini, tetapi kombinasi dari kedua sistem tersebut dengan memanfaatkan kebaikan, masing-masing sistem dan mengeliminasi kelemahan masing-masing. Rekomendasi LIPI tersebut ternyata belum dilaksanakan pada pemilihan umum 1997 yang masih memakai sistem dan cara lama orde baru. Setelah orde baru runtuh pada 1997, baru pemilihan umum 1999 boleh dikatakan agak sesuai dengan sistem yang direkomendasikan LIPI kalau misalnya kita setuju terhadap rekomendasi LIPI, maka tahap pelaksanaannya berubah menjadi sebagai berikut:

a. Tahap I : dilaksanakan pada pemilihan umum 1999 yang lalu;
b. Tahap II : dilaksanakan pada pemilihan umum 2004;
c. Tahap III : dilaksanakan pada pemilihan umum 2009.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia selama ini mempunyai pengaruh timbal balik dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, meskipun dari sudut sistemnya (*electoral laws*) tidak pernah berubah, namun dari sudut pelaksanaannya *(electoral process)* dan hasilnya hubungan timbal balik tersebut menampak.

Pembaruan sistem pemilihan umum yang diterapkan perlu pemikiran matang dan dijadikan wacana publik, karena sistem manapun yang dipilih pasti mengandung kelemahan-kelemahan, di samping kelebihan-kelebihan barangkali perbaikan dalam *electoral process* lebih signifikan ketimbang perbaikan dalam sistemnya *(electoral laws)*.[6]

4. Mahkamah Konstitusi dan Batas-batas Kewenangannya

Menurut F. Julius Stahl dari kelompok ahli hukum Eropa Continental memberikan ciri-ciri negara hukum *(rechstaat)* adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan kekuasaan negara;
3. Pemerintahan berdasar undang-undang; dan
4. Adanya peradilan administrasi.

Sedangkan A. V. Dicey dari kelompok Anglo Saxon, memberikan ciri-ciri negara hukum *(the rule of law)* di antaranya:

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama di depan hukum *(equality before the law)* baik bagi rakyat biasa atau pejabat;
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.[7]

Perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh F. Julius Stahl dan A.V. Dicey tersebut kemudian ditinjau ulang oleh *"International Commition of Jurist"* pada konferensinya di Bangkok pada 1965,[8] yang menegaskan ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;

---

[6]*Ibid,* hlm. 101-102.
[7]Fatkhurrahman, Dian A, dkk; *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 6.
[8]*Ibid,* hlm. 6.

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Sri Soemantri lebih memperjelas lagi mengenai unsur-unsur yang terpenting dalam negara hukum yang dirinci dalam empat unsur yaitu:

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia warga negara;
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan *(Rechtlerlijke Controle)*.[9]

Jadi, dalam negara hukum yang pokok adalah adanya *"pembatasan oleh hukum"*, dalam arti bahwasanya segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif sehingga terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara.

Untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan di dalam negara haruslah dipisah dan dibagi ke dalam kekuasaan yang mengenai bidang-bidang tertentu.

Pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) dan haruslah dibatasi dengan aturan-aturan hukum yang ada tingkatan tertinggi disebut *konstitusi*. Karena salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara hukum dan demokrasi adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.[10]

Dari uraian di atas apabila dihubungkan dengan dasar hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat ditemukan unsur-unsur negara hukum, yaitu:

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

[9]Srie Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara,* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 10.
[10]Fatkhurrahman, Dian A., dkk. *op.cit.,* hlm. 7.

4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah lainnya.

Dan hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 (ayat) 3 UUD 1945 teramandemen, ini menandakan bahwa setiap pemegang kekuasaan dalam negara, pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila UUD 1945 telah mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga negara. Ketidakseimbangan ini terlihat dari corak kekuasaan presiden yang absolut. Hal ini diperparah dengan tidak berfungsinya lembaga-lembaga negara lain sebagaimana mestinya, misalnya lembaga legislatif terkesan hanya sebagai lembaga legalisator kesewenang-wenangan presiden, di samping itu juga lembaga peradilan tidak mendapatkan kemerdekaan dan kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini pada akhirnya melahirkan budaya NKK (Nepotisme, Kolusi, Korupsi) sehingga terjadi krisis multidimensional pada hampir seluruh aspek kehidupan. Ketidakpekaan penyelenggara negara (presiden) yang diperparah oleh ketidakberdayaan lembaga negara lain terhadap situasi mengakibatkan gerakan reformasi di seluruh tanah air yang pada akhirnya berhasil menumbangkan rezim otoriter (orde baru).

Pada awal bergulirnya gerakan reformasi, tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai dengan tuntutan reformasi seperti NKK dan penyalahgunaan kekuasaan, ternyata belum diikuti dengan langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum. Terbukti masih adanya intervensi kekuasaan dalam proses peradilan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kondisi hukum demikian, mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) serta gerakan demokratisasi di Indonesia mengalami stagnasi.[11]

Pada akhirnya sebagai reaksi dari tuntutan reformasi yang semakin kencang disuarakan oleh masyarakat, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004, yang memuat beberapa hal penting dalam hal arah kebijakan di bidang hukum di antaranya:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum;
2. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran, dan supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia;

[11] *Ibid,* hlm. 2.

3. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun.[12]

Reformasi pada akhirnya membawa perubahan mendasar dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, tidak terkecuali dalam bidang hukum dan politik. Perubahan tersebut seakan telah membawa Indonesia ke alam yang lebih demokratis dan konstitusional.

Demokratisasi dan konstitusionalisme kini telah disepakati menjadi semangat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Telah disadari pula bahwa untuk mewujudkan dua hal tersebut, haruslah diawali dengan perubahan terhadap konstitusi yang merupakan dasar pijakan bagi negara demokrasi konstitusional.

Reformasi konstitusi yang terjadi pada kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia pada era sekarang ini, merupakan saat terpenting yang harus terus dijaga dan dipelihara, agar tetap berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan. Keberlanjutan demokrasi *(a sustainable democracy)* dan konsistensi diperlukan uutuk mengeluarkan bangsa Indonesia dari segala krisis pemerintahan, kepemimpinan dan demokrasi. Dan salah satu cara yang baik adalah memahami konstitusi dengan benar dan tepat.

Konstitusi sebagaimana selalu dipahamkan merupakan seperangkat ketentuan hukum yang disusun secara sistematis yang mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan pemerintahan, termasuk kewenangan dan batas-batas kewenangannya. Dengan demikian, konstitusi atau hukum dasar merupakan kebutuhan yang mendasar bagi tatanan sebuah bangunan negara (bentuk, sistem, tujuan dari negara, dan sistem pemerintahannya).

Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 mengandung banyak kelemahan, salah satunya adalah tidak tersedianya mekanisme *check and balances* (saling mengontrol dan mengimbangi) sehingga melumpuhkan kontrol yudisial terhadap pelaksanaan kekuasaan, yang berakibat pada pelaksanaan kekuasaan yang sentralistik dan otoriter. Pada akhirnya disadari bahwa untuk menciptakan pemerintahan demokratis dan konstitusional, dibutuhkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan *kontrol yudisial* terhadap penyelenggaraan negara, dan pilihannya jatuh pada Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian sistem ketatanegaraan kita saat ini telah menapaki babak baru.

Fenomena keberadaan lembaga MK *(Constitutional Court)* itu sendiri dalam dunia ketatanegaraan dewasa ini, secara umum memang dapat dikatakan merupakan sesuatu hal yang baru. Di seluruh negara di dunia, MK dikenal di 78 negara dan MKRI merupakan lembaga peradilan tata negara yang ke 78 di dunia. MK menjadi *trend,* terutama di negara-negara yang baru menga-

[12]TAP MPR No. IV/MPR/1999, tentang *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, tahun 1999-2004.

lami perubahan rezim dari otoritarian ke rezim demokratis.[13] MK akhirnya disepakati dibentuk di Indonesia. Pembentukan tersebut dilakukan melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 10 Agustus 2002. Sejak itu, Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan ketatanegaraannya yang diyakini akan lebih demokratis dan konstitusional.

Pembentukan MK di Indonesia, tidak dapat diingkari terinspirasi oleh MK di negara lain. Namun begitu, tentu saja konsep MK, yang telah ada tersebut tidak lantas diadopsi secara keseluruhan *(Recentio in Complexu)* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena bagaimanapun setiap negara memiliki karakteristik sistem ketatanegaraan yang berbeda dalam Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 dinyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi."

Ini berarti berdasarkan rumusan tersebut di atas, kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (*bifurcations system*), di mana kekuasaan kehakiman terbagi dalam dua cabang, yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada MA dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan *constantional review* atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh MK.[14] Secara konseptual, memang dimungkinkan satu fungsi dilakukan dua lembaga yang berbeda. Namun begitu, potensial menimbulkan konflik jika tidak dirumuskan secara tegas mengenai kedudukan dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut. Tidak hanya itu, oleh karena MK juga melakukan *judicialization of politics* (suatu proses untuk bagaimana tindakan-tindakan badan legislatif dan eksekutif sesuai dengan konstitusi) maka sudah barang tentu kedudukan MK terhadap lembaga negara lainnya juga harus ditegaskan.

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, MK mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*judicial review*);
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;

---

[13]KHRN, *"Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi"* Suatu Analisis Kritis, Makalah pada Semiloka "Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi" yang diselenggarakan oleh PP-Otoda FH Unibraw bekerja sama dengan KHRN, Batu 18-19 Desember 2002 mengutip Jimly Asshidiqie, *Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad ke-20*, (Makalah, Diskusi terbatas KHRN, 18 Juni 2002), hlm. 1-2

[14]*Ibid,* hlm. 4.

3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

(hal inilah yang menjadi batasan kajian dalam tulisan ini)

Di samping itu, berdasarkan Pasal 7 B ayat (4) jo Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945, MK memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945.

Berikut ini disampaikan kajian singkat terhadap wewenang dan kewajiban MK sebagaimana tersebut di atas:

Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji UU terhadap UUD
(Judicial Review)

Kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD *(judicial review)* secara teoritik maupun dalam praktik dikenal ada dua macam, yaitu pengujian formal *(formele toetsingrect)* dan pengujian secara materiil *(materiil toetsingrecht)*. Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur ataukah tidak, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk menyelidiki atau menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini rumusan Pasal 24 C (ayat) I UUD 1945 tidak membatasi hak pengujian tersebut, tetapi yang dibatasi hanyalah *subjek yang akan diuji,* yaitu UU.

Menurut Jimly Asshiddiqi, dalam pengertian *judicial review* itu terdapat pula pengertian mengenai pengujian kembali, tidak saja terhadap produk legislatif dan eksekutif, tetapi juga terhadap produk putusan hakim sendiri. Alasan diakuinya *judicial review* di Indonesia, merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif; eksekutif, maupun yudikatif.[15]

Pemberian kewenangan tersebut terhadap hakim merupakan penerapan prinsip *"check and balances"* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara yang dipercaya dapat lebih menjalin perwujudan gagasan demokrasi dan cita-cita negara hukum *(rechtstaat atau rule of law)*. Sesuai dengan prinsip *"check and balances"* yang telah menjadi salah satu pokok pikiran dalam UUD pasca amandemen pengujian konstitusional materi UU telah ditegaskan menjadi kewenangan hakim, yaitu MK.

---

[15]Jimly Asshidiqie, *"Judicial Review: Kajian atas Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah"*, Makalah, Tahun 2002, hlm. 37.

Dengan diakuinya *judicial review* dalam UUD 1945 menimbulkan dampak positif, salah satunya adalah adanya asas keseimhangan *(check and balances)* antara aparatur-aparatur demokrasi, juga merupakan cerminan supremasi hukum atas kekuasaan politik.

Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Berdasarkan Pasal 24 C (ayat) 1, salah satu kewenangan dari MK adalah memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD mengandung interpretasi yang beragam.

Hal ini disebabkan pascaamandemen, konstitusi tidak memberikan penjelasan konsepsi tentang lembaga negara. Demikian pula dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang ternyata juga tidak memberikan kejelasan konsepsi tentang lembaga negara yang menjadi kompetensi MK memang dapat menampilkan penafsiran yang beragam.

Pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, banyak terjadi pergeseran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah pergeseran paradigma kelembagaan negara. Pergeseran ini ditandai dengan direduksinya status Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kini tidak lagi sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan demikian, tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, yang ada hanyalah *lembaga negara*. Paradigma ini telah dipraktikkan dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.

Mukhtie Fajar menyampaikan konsepsi tentang lembaga negara, bahwasanya lembaga negara yang tercantum dalam UUD 1945, antara lain:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Presiden (dan Wakil Presiden);
3. Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Dewan Perwakilan Daerah;
5. Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Mahkamah Agung;
7. Mahkamah Konstitusi;
8. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota;
9. Komisi Pemilihan Umum;
10. Komisi Yudisial;
11. TNI dan POLRI[16]

[16]A. Mukhtie Fadjar; *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, In Trans, Malang, 2003, hlm. 134.

Di samping itu, ada beberapa lembaga yang sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, namun setelah amandemen UUD 1945 lembaga-lembaga tersebut independensinya dijamin oleh UUD 1945, Misalnya Komisi Pemilihan Umum dan Bank Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, lembaga negara kerap kali melakukan kerja sama atau hubungan. Dan hubungan antara lembaga negara tersebut memungkinkan terjadinya konflik, yaitu manakala suatu lembaga negara merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang dengan fungsinya, konflik-konflik tersebut harus diselesaikan, dan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk itu adalah *lembaga peradilan*.

Di sinilah peran MK sangat diperlukan, sebagai lembaga negara yang mempunyai wewenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD dalam kerangka mekanisme *check and balances* dalam menjalankan kekuasaan negara.

Dalam Pasal 24 C (ayat) 1 UUD 1945, telah disebutkan bahwa:

> *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk....., memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD....."*

Ditegaskan pula dalam Pasal 61 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, bahwasanya:

> *"Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan."*

Namun, terdapat pengecualian dalam Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa:

> "Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945."

Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Pembubaran Partai Politik

Dalam Pasal 24 C (ayat) 1 UUD 1945, salah satu wewenang MK adalah:

> *"Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk .....memutus pembubaran partai politik,....."*

Persoalannya adalah apakah pembubaran partai politik tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, oleh karena UUD 1945 dalam Pasal 28 E (ayat) 3 secara tegas menyatakan:

> *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*

Cerminan dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat salah satunya adalah melalui partai politik. Secara umum dapat

dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik (yang biasanya) dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.[17]

Menurut Pasal I UU No. 31/2002:

> *"Partai Polilik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum."*

Pembubaran partai politik pada dasarnya dan apa pun alasannya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), namun dalam praktiknya pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan alasan ideologi dan pelanggaran hukum.[18]

Alasan ideologi, karena partai yang dibubarkan memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan negara menyatakan ideologi tersebut tidak boleh dikembangkain. Hal seperti ini walaupun tampak tidak demokratis dan terkesan melanggar Hak Asasi Manusia. Tetapi lumrah terjadi di beberapa negara yang notabene adalah negara demokratis, dengan alasan setiap negara sebenarnya memiliki hak untuk menentukan ideologi dan cita-cita sendiri dan menolak suatu ideologi karena dianggap bertentangan dengan kehendak mayoritas *(volunte general)* warga negara ataupun karena alasan sejarah, di mana ideologi tersebut pernah melakukan pengkhianatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[19]

Alasan pelanggaran hukum maksudnya adalah partai politik tersebut melakukan pelanggaran hukum yang mengancam pelanggarnya dengan sanksi pembubaran partai politik tersebut.

Di Indonesia pembubaran partai politik juga pernah terjadi, sebut saja Masyumi yang dibubarkan rezim orde lama dan Partai Komunis Indonesia yang dibubarkan pada awal masa orde baru. Pembubaran keduanya nyaris sama, yakni *tanpa melalui proses persidangan*.

Dewasa ini, mekanisme pembubaran partai politik tersebut tidak akan terulang lagi oleh karena pascaamandemen dalam UUD 1945 telah ditentukan mekanisme pembubaran partai politik berdasarkan pemaparan singkat sebagaimana telah diuraikan maka dapat diinterpretasikan bahwa suatu partai politik *dapat dibubarkan* jika ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik bersangkutan dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

---

[17]Fatkhurrahman, Dian A., dkk; *op.cit,* hlm. 44.
[18]*Ibid,* hlm. 44.
[19]*Ibid.*

Secara ideologis, paham komunis jelas bertentangan dengan Pancasila merupakan ideologi dan *staatidee* bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena Pancasila menghendaki negara Indonesia adalah negara yang berperikemanusiaan dan berdemokrasi. Dengan demikian, setiap partai yang bertentangan dengan Pancasila dapat dilarang atau dibubarkan.

Mengenai alasan asas, dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2003 disebutkkan bahwa:

> *"Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD RI tahun1945."*

Ketentuan partai politik dapat dibubarkan berdasarkan alasan di atas dirasa sangat tepat. Dengan demikian, peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang dari penguasa dalam membubarkan partai politik dapat dieliminir.

Namun, dari rumusan pasal di atas tampak sistem Hukum Indonesia tidak memiliki parameter yang jelas tentang pembubaran suatu partai politik. Yang ada hanyalah ketentuan yang kabur atau *observur* dan mengandung multiinterpretasi. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah penting mengingat MK memutus perkara berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945, alat bukti, dan keyakinan hakim (Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003). Dengan demikian, pasal dalam UU tersebut di atas dapat dikesampingkan. Tampak peran MK sebagai penafsir konstitusi sangat urgen dalam hal ini.

Di sinilah fungsi MK dalam mengawal demokrasi dan menegakkan perlindungan hak asasi manusia sangat diperlukan, agarjangan sampai suatu politik dibubarkan dengan alasan yang tidak konstitusional, apalagi hanya menuruti kemauan penguasa. Mengingat pada dasarnya apa pun alasan pembubaran partai politik bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme "kesehatan" demokrasi akan terinfeksi.

Dalam prosedur pengajuan permohonan pembubaran partai politik dalam UUMK disebutkan, pihak yang berhak mengajukan permohonan pembubaran partai politik adalah pemerintah (Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003).

Mengenai putusannya, jika MK memutus pembubaran suatu partai politik, pelaksanaan putusan pembubaran partai politik dilakukan dengan membatalkan pendaftarannya pada pemerintah. Di sisi lain dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2002 disebutkan bahwa:

> *"Pengesahan partai politik sebagai badan hukum dilakukan oleh Menteri Kehakiman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan pendaftaran...."*

Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum

Kemungkinan terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum sangat terbuka dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum di suatu negara, terlebih lagi bagi bangsa Indonesia yang baru menapaki babak baru dalam kehidupan

berdemokrasi. Oleh karenanya, pada setiap negara demokratis terdapat lembaga pengawas dan pemantau pemilihan umum guna memperkecil terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum. Di samping itu, lembaga peradilan yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum, juga sangat penting keberadaannya.

Sebagai mekanisme pelaksanaan demokrasi yang sekaligus sebagai instrumen penting dalam pembangunan tertib politik dalam suatu negara demokratis, pemilihan umum laksana "medan pertempuran" dari para kontestan (partai politik peserta pemilihan umum) dalam memperebutkan simpati dan dukungan dari rakyat (para pemilih). Akibatnya, ada kecenderungan para kontestan memantapkan peluang sekecil apa pun untuk melakukan kecurangan atau pelanggaran demi mendapatkan dukungan yang besar dari para pemilih. Di sisi lain kesalahan penghitungan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU juga rentan terjadi. Maka dari itu, ketertiban lembaga peradilan untuk menangani sengketa tentang perselisihan hasil pemilihan umum mutlak diperlukan demi menjaga tingginya "kadar" demokrasi dari sebuah pemilihan umum yang diselenggarakan.

Berdasarkan perkembangan yang terjadi dewasa ini dapat diprediksi betapa kompleks permasalahan yang mungkin terjadi dalam pemilihan umum tahun 2004 ini. Oleh karena dalam pemilihan umum tahun 2004 rakyat bukan hanya memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota saja, melainkan.juga memilih anggota DPD bahkan juga memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Suatu hal yang sama sekali baru, bukan saja bagi rakyat (pemilih), melainkan juga bagi para kontestan dan KPU.[20]



Penutup

Dari uraian tersebut di atas dapat kita pahami bahwa Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya cukup strategis. Hal ini memang cukup menggembirakan, sebab kita dapat melihat bagaimana perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Di sini dapat kita katakan bahwa Hukum Tata Negara dapat berkembang secara cepat mengikuti perkembangan masyarakatnya, dibandingkan dengan aspek-aspek hukum lainnya.

Tetapi apabila dilihat dari para personelnya, yang notabene kebanyakan berasal dari kalangan partai politik, yang tentu saja akan membawa aspirasi dari partainya baik langsung maupun tidak langsung. Apabila kondisi ini tidak dikontrol, minimal dengan cara memberikan pengertian kepada masyarakat tentang lembaga Mahkamah Konstitusi, dikhawatirkan secara mikro akan

[20] *Ibid,* hlm. 49.

timbul ketidakadilan dalam menyelesaikan sengketa Pemilu. Kemudian secara makro tujuan menghilangkan supremasi lembaga MPR masa lalu tidak tercapai, karena hanya akan pindah posisi supremasi dari MPR kepada Mahkamah Konstitusi.

Daftar Referensi

Buku-buku:

Fadjar, A. Muktie. *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*. Malang: INTRANS, Cetakan pertama, 2003.

Fatkhurrahman, Dian A., dkk. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 2004.

Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni, Cetakan 1992.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Penjelasannya, Bina Pustaka Tama. Surabaya, Cetakan Pertama, 2002.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi,* Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Pertama, 2004.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang *Partai Politik,* Focusmedia, Bandung, Cetakan Pertama, 2003.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR. DPD, dan DPRD, Focusmedia, Bandung, Cetakan Pertama, 2003.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,* Citra Umbara, Bandung, Cetakan Pertama, 2003.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 05/PMK/2004 tentang *Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penelapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden* Tahun 2004.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 06/PHBU-8-II/2004 tentang Gugatan Wiranto-Salahuddin Wahid atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.

Makalah:

Asshiddiqie, Jimly, *Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad Ke-20*, 2002.

KRHN, *Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, dalam Semiloka RUU MK, diselenggarakan oleh PP-Otoda FH UNIBRAW dan KRHN, Batu, 18-19 Desember 2002.

Dossy Iskandar P. *Ide Perubahan UUD 1945*, Makalah HTN, Surabaya, 2004.

Sholehuddin, M. *Penguatan Supremasi Hukum Melalui Pemilihan Umum Presiden*, dalam Dialog Interaktif FH UBHARA, Surabaya, 12 Juli 2004.

RAJAWALI PERS

23

PENGARUH *GENDER MAINSTREAMING* TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK PEREMPUAN DI INDONESIA MENURUT UUD 1945

Oleh:
*Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.**
*Riris Ardhanariswari. S.H., M.H.***



Latar Belakang

Keberadaan perempuan (wanita) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bukan lagi berfungsi reproduksi saja, tetapi juga sangat berperan penting dalam resosialisasi, redukasi, dan berkonstitusi. Untuk itu, perempuan Indonesia juga perlu mempelajari dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Meskipun kontribusi yang telah mereka berikan dapat kita rasakan hampir di seluruh lingkup kehidupan sehari-hari, namun mereka seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang sering kali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Walaupun perempuan telah memperoleh status sosial yang cukup mulia, namun mereka masih harus tetap diberikan kemampuan yang lebih di bidang hukum, sosial, politik, dan ekonomi.

Melalui pembangunan nasional, bangsa Indonesia melakukan proses yang berkesinambungan untuk mencapai kemajuan dan mendatangkan perbaikan, demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan

*Dosen Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana UNSOED Purwokerto.
**Dosen Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto dan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD, Bandung.

spiritual berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memerhatikan tantangan global.

Meski tujuan penyelenggaraan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun penyelenggaraan pembangunan tersebut juga memberikan dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Salah satu upaya untuk menghilangkan kesenjangan gender, meski telah dilaksanakan berbagai program yang dimaksudkan memberikan fasilitas-fasilitas dasar dan praktis bagi perempuan, adalah melalui pengembangan paradigma baru pembangunan yang lebih integratif yang sekarang dikenal dengan *'gender mainstreaming'* atau pengarusutamaan gender. Guna mendukung implementasi pengarusutamaan gender tersebut, ditetapkanlah Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan gender merupakan strategi utama untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses kepada, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Untuk itu, sesuai dengan amanat Inpres No. 9 Tahun 2000 tersebut, seluruh departemen maupun lembaga pemerintah melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

Pengarusutamaan gender atau *gender mainstreaming* adalah salah satu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Pengarusutamaan gender merupakan pematangan dari strategi *Gender and Development* (GAD) yang tujuan dasarnya menjadikan gender sebagai arus utama (*mainstream*) pembangunan. Sasarannya adalah kebijakan (negara), aksi (masyarakat), serta institusi (negara dan masyarakat). Artinya, melalui penerapan strategi ini diupayakan agar setiap kebijakan (yang dibuat oleh institusi negara) atau setiap aksi (yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk LSM, organisasi bisnis, komunitas, dan sebagainya) menjadi sensitif gender atau menjadikan gender sebagai arus utamanya.

Dengan demikian, pengarusutamaan gender merupakan strategi utama untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses kepada, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Jadi pengarusutamaan gender tidak sekadar mengintegrasikan permasalahan gender dalam seluruh aspek pembangunan, tetapi juga mencakup upaya mengubah arus utama pembangunan agar lebih sensitif dan responsif terhadap keberagaman yang ada di masyarakat, termasuk adanya perbedaan gender sebagai realitas.

Sebagai sebuah strategi, agar pengarusutamaan gender dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, dibutuhkan kondisi awal dan komponen kunci. Adapun kondisi awal dan komponen kunci yang dimaksud adalah:[1]

---

[1]Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Pengarusutamaan Gender Suatu Strategi dalam Pembangunan*, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan *Women Support Project II/CIDA*, Jakarta, 2001, hlm. 6.

a. Komitmen politik (*political will*), keteladanan, dan kepemimpinan (*leadership*) dari lembaga-lembaga serta pemimpin eksekutif, yudikatif, maupun legislatif
b. Adanya kerangka kebijakan yang secara eksplisit menyatakan komitmen-komitmen pemerintah, provinsi, kabupaten/kota terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender
c. Struktur dan mekanisme pemerintah, provinsi, kabupaten/kota yang memastikan diselenggarakannya pengintegrasian perspektif gender.
d. Sumber-sumber daya yang memadai
e. Sistem informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin
f. Alat analisis
g. Dorongan dan kontrol dari masyarakat madani kepada pemerintah.

Dalam pelaksanaan pembangunan sering kali perempuan diabaikan hak asasinya. Pembangunan tidak berpihak pada perempuan.



Perempuan dalam Pembangunan

Berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka kesejahteraan perempuan telah dilakukan oleh pemerintah. Paling tidak, ada dua pendekatan yang sangat populer yaitu W*omen in Development* (WID) dan *Gender and Development* (GAD). Pembahasan mengenai pengarusutamaan gender tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan dua pendekatan tersebut. Untuk itu, masing-masing pendekatan akan dibahas pada uraian berikut:

Tahun 1975 telah ditetapkan sebagai Tahun Perempuan Internasional. Hal ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang diperjuangkan oleh Komisi PBB untuk Status Perempuan (*United Nations Commissions for the Status of Women*) melalui Majelis Umum PBB sejak sebelum tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada 1972. Para anggota Komisi Perempuan segera menyusun *World Plan of Action* (Rencana Aksi Dunia) yang diajukan di Konferensi Dunia tentang Perempuan di Meksiko tahun 1975. Salah satu hasil konferensi yang paling penting adalah diterima dan diakuinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination Discrimination Against Women* CEDAW) oleh sebagian besar negara anggota Majelis Umum PBB sejak 1979.

Konferensi dunia tentang Perempuan di Meksiko tahun 1975 memberikan dampak yang penting bagi perempuan di negara-negara peserta konferensi. Konferensi tersebut menyepakati bahwa negara-negara di dunia harus memberikan perhatian pada kaum perempuan dan mengikutsertakan mereka dalam setiap program pembangunan. Kemudian banyak negara mulai menyusun rencana aksi untuk meningkatkan peranserta atau mengintegrasikan perempuan

dalam pembangunan, yang sering disebut sebagai *Women in Development* (WID).

Indonesia menjadi salah satu peserta konferensi tersebut. Sejak 1979, Pemerintah Indonesia meluncurkan program untuk peningkatan peran perempuan antara lain dengan membentuk Kementerian Muda Urusan Peranan Wanita dengan berbagai program di antaranya, Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pendidikan. Bahkan pada 1984, Indonesia meratifikasi CEDAW dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.

Pandangan dasar WID adalah bahwa proses pembangunan dan perubahan sosial yang pesat telah menyingkirkan perempuan dari pusat-pusat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dipikirkan bagaimana mengintegrasikan perempuan ke dalam proses pembangunan. Pendekatan WID berasumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan itu problemnya terletak pada perempuan itu sendiri. Oleh karenanya diperlukan usaha untuk menggarap kaum perempuan. Salah satu caranya, adalah dengan menciptakan proyek-proyek khusus bagi perempuan yang dapat membantu mereka memperoleh penghasilan sendiri. Pendekatan WID juga mementingkan strategi penempatan perempuan dalam posisi-posisi kunci di lembaga-lembaga pemerintahan. Pendekatan ini tidak mempermasalahkan mengapa perempuan selalu berada pada posisi subordinasi laki-laki.

Setelah konferensi di Meksiko, Konferensi Dunia tentang Perempuan dilaksanakan kembali setiap lima tahun sekali. Selain konferensi itu, sebuah forum alternatif juga diadakan perempuan. Di sinilah perdebatan tentang penyebab nyata penindasan terhadap perempuan didiskusikan. Laporan yang masuk ke komisi perempuan menunjukkan, bahwa meskipun Program WID telah dirasakan manfaatnya, tidak di satu tempat pun posisi perempuan benar-benar telah meningkat secara umum dan struktural. Di banyak negara, perempuan termiskin telah menjadi miskin lagi, dan birokrasi negara sangat sedikit melaksanakan undang-undang antidiskriminasi.

Gagasan mengintegrasikan perempuan ke dalam pembangunan, yang sebelumnya dianggap sebagai harapan kaum perempuan, ternyata mengabaikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara bersama-sama, bahkan tidak dapat meningkatkan status dan posisi perempuan di dalam masyarakat. Adanya posisi kunci yang diduduki perempuan tidak menjamin adanya kebijakan yang memihak perempuan yang tertindas. Mereka sering kali justru mempunyai "bias laki-laki", karena pendekatan WID hanya menekankan pada pemenuhan kebutuhan praktis perempuan. Tidak jarang, pendekatan WID justru cenderung mengisolasi perempuan dari pelaku pembangunan lainnya, yaitu laki-laki. Pendekatan WID secara khusus belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap laki-laki dan perempuan. Akibatnya, pendekatan ini sering kali berkontribusi pada timbulnya ketidaksetaraan dan

ketidakadilan gender, seperti ditunjukkan oleh beberapa indikator dalam HDI dan GDI.[2]

Pada pertengahan tahun 1980-an, sesudah Konferensi Perempuan di Nairobi, disadari bahwa persoalan ketidakadilan gender yang dihadapi perempuan tidak hanya dapat diselesaikan dengan pemenuhan kebutuhan praktis, tetapi juga kebutuhan strategis. Strategi yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan strategis itulah yang kemudian dikenal dengan pendekatan "Gender dan Pembangunan" *(Gender and Development/GAD)*.

Gender dan Pembangunan merupakan suatu pendekatan pembangunan yang didasari pada pemikiran bahwa semua kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan merupakan cerminan aspirasi, peran, pengalaman, permasalahan, dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pendekatan tersebut merupakan satu-satunya pendekatan pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan laki-laki dalam seluruh kehidupannya, baik dalam menjalankan peran reproduktif, produktif, maupun kemasyarakatan. Pendekatan ini juga menolak upaya apa pun yang menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Pendekatan Gender dan Pembangunan (GAD) ini dikenal sebagai pendekatan "pemberdayaan."

GAD merupakan suatu pendekatan yang dilandasi pada pemikiran bahwa semua kebijakan, program, dan proyek seharusnya mencerminkan pemahaman bahwa ada perbedaan kebutuhan, prioritas yang disebabkan adanya permasalahan, aspirasi, pengalaman, kebutuhan, dan peran gender yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan, baik di lingkungan domestik maupun publik. Jika di dalam proses penyusunan kebijakan, program, dan proyek tidak memerhatikan hal di atas, maka kebijakan menjadi netral gender dan dampaknya akan sangat berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pendekatan GAD harus selalu didahului dengan analisis yang membandingkan situasi laki-laki dan perempuan, serta memerhatikan dampak hubungan gender yang tidak setara. Pendekatan pembangunan ini erat kaitannya dengan pendekatan dari bawah ke atas *(bottom-up approach)* daripada pendekatan dari atas ke bawah *(top-down approach)*. Pendekatan ini juga melacak akar subordinasi terhadap perempuan. Selain itu, pendekatan ini juga memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal, dan sedikit- banyak lebih menekankan pada *judicial review* terhadap undang-undang yang berkaitan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, seperti: UU Perburuhan, kontrol laki-laki atas tubuh dan hak reproduksi perempuan, dan lain-lain.

Menurut Barlett sebagaimana dikutip oleh Otje Salman dan Anton F. Susanto, bahwa feminist yang berhubungan hukum paling tidak memfokuskan

---

[2]*Modul Penyadaran Gender bagi Pendidik*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2004.

pada tiga faktor.[3] *Pertama, "bertanya pada perempuan"*. Yaitu, apa yang perlu ditanyakan sering kali adalah suara bisu (*silence)*, suara yang diasingkan. Hal ini menyebabkan *"dengan melihat permukaan hukum untuk mengidentifikasikan implikasi aturan gender dan asumsi yang tidak mengekalkan subordinasi wanita." Kedua,* metode ini mengistimewakan suatu *"pemahaman praktis feminist"* yang dapat mencakup semua aspek logika deduktif, tetapi mempertimbangkan logika pengalaman-pengalaman konkret dan unik dari yang tertekan. *Ketiga* adalah munculnya kesadaran. Tujuannya adalah untuk individual dan pemberdayaan kolektif, bukan untuk dendam pribadi.



Pembahasan

Dalam PUG tidak bisa lepas dari salah satu komponen penting yang menjadi landasan, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1984. Dalam undang-undang tersebut terdapat tiga prinsip. *Pertama*, prinsip menuju persamaan substantif. Model ini mengakui bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang lebih disebabkan perlakuan diskriminatif oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, pendekatan ini menggunakan model koreksi terhadap perlakukan diskriminatif tersebut. *Kedua*, prinsip non-diskriminatif. Prinsip ini didasarkan pada definisi diskriminasi yang secara tegas disebutkan di dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984, yaitu pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya terhadap perempuan, terlepas dari status perkawinan, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Definisi inilah yang digunakan untuk mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan dalam berbagai peraturan yang dibuat pemerintah, apakah sebuah perundang-undangan yang dibuat pemerintah telah melakukan diskriminasi berbasis gender atau tidak. *Ketiga*, prinsip kewajiban negara. Setiap negara yang meratifikasi konvensi tersebut wajib menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta hasilnya, merealisasikan hak-hak perempuan, mengatur tindakan-tindakan di sektor publik, keluarga, swasta, dan perorangan. Negara juga harus mengambil langkah-langkah proaktif di bidang politik, ekonomi, budaya, dan menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan, serta wajib melakukan perlakuan khusus (*affirmative action*) untuk mempercepat persamaan *de facto*. Bahkan pada Konferensi Dunia tentang Kependudukan dan Pembangunan

[3]Otje Salman dan Anton F. Susanto, *op.cit*, hlm. 135.

yang dilaksanakan di Kairo, tahun 1994, para kepala negara peserta konferensi menyepakati perlunya memerhatikan persoalan ketidakadilan gender dalam pembangunan.

Masih banyak landasan hukum lain yang dapat menjadi kekuatan hukum bagi penegakan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan karena Indonesia juga telah meratifikasi konvensi tentang hak-hak sipil dan politik, konvensi tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, Konvensi *Internasional Labour Organization* (ILO) Nomor 100 tentang Kesamaan Upah, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang secara eksplisit menyebutkan bahwa "Perencanaan pembangunan berperspektif gender pada dasarnya adalah upaya untuk mentransformasikan pengarusutamaan gender ke dalam kegiatan nyata institusi sektoral dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tersebut diperkuat dengan UU Nomor 25 tahun tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004, yang telah memadukan perspektif gender dalam beberapa kebijakan, program, dan kegiatan. Kemudian Inpres tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Selanjutnya Inpres tersebut juga dijabarkan dengan Surat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor B-51A/Dep.II/2001 tentang Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Di dalam panduan tersebut disebutkan bahwa strategi perencanaan pembangunan yang peka gender harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki yang berbeda ke dalam keseluruhan proses perencanaan kebijakan dan program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Perencanaan pembangunan yang peka gender harus dilakukan untuk menjamin laki-laki dan perempuan:

1. Mempunyai akses yang sama kepada sumber daya pembangunan;
2. Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan;
3. Memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan; dan
4. Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan

Melihat makna dan prinsip yang ada dalam pemberdayaan, terlihat bahwa pemberdayaan mempunyai prinsip kesetaraan dan keadilan. Di dalam proses pemberdayaan tidak ada yang lebih pintar dan dalam prosesnya terdapat proses saling belajar dari pengalaman masing-masing. Dalam pendekatan Gender dan Pembangunan atau Pendekatan "Pemberdayaan," perspektif gender dapat

dilihat dari lima tingkatan pemberdayaan yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama, yaitu tahap kesejahteraan. Tahap ini didefinisikan sebagai tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, seperti gizi, persediaan makanan, dan pendapatan.
2. Tahap kedua, yaitu akses, digunakan untuk melihat apakah terdapat kesenjangan gender yang muncul akibat ketidaksetaraan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya dan pelayanan.
3. Tahap ketiga, yaitu tahap kesadaran kritis, harus ditumbuhkan di kalangan laki-laki dan perempuan untuk melihat bahwa ada praktik-praktik diskriminasi gender di antara mereka.
4. Tahap keempat, yaitu partisipasi, harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
5. Tahap kelima, yaitu kontrol, untuk melihat apakah terdapat ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

Istilah *gender mainstreaming* sebenarnya sudah muncul pada saat diskusi-diskusi dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan di Nairobi tahun 1985, tetapi penggunaannya belum meluas. Sepuluh tahun kemudian, wacana *gender mainstreaming* muncul kembali pada Rencana Aksi Jakarta untuk Pemajuan Perempuan, yang kemudian diadopsi oleh Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik Kedua mengenai Perempuan dalam Pembangunan dan Program Aksi. Sejak saat itu istilah *gender mainstreaming* mulai digunakan oleh beberapa donor.

Penyelenggaraan PUG mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan yang sifatnya untuk memperbaiki kondisi mereka agar dapat menjalani kehidupan serta peran-peran sosial mereka secara layak dan bermartabat. Karena yang hendak dicapai adalah perubahan kondisi, maka pendekatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan praktis gender umumnya bersifat merespons kebutuhan jangka pendek seperti pemberian modal usaha, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, pemberantasan buta aksara, dan lain-lain.

Pembangunan kebutuhan strategis gender ditujukan untuk memperbaiki posisi perempuan sehingga secara politis dapat meningkatkan posisi tawar mereka baik di tingkat rumah tangga, masyarakat, negara maupun pasar di mana perempuan terlibat sebagai tenaga kerja. Secara teoretik, program pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan strategis gender adalah program yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan untuk mengubah posisi subordinasi mereka dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, apa pun bentuk kegiatan yang diusahakan dan siapa pun sasaran yang akan dilibatkan, kegiatan

itu diarahkan pada terjadinya perubahan di dalam pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan, dan kontrol terhadap sumber daya. Kegiatan yang umumnya dikategorikan sebagai memenuhi kebutuhan strategis gender antara lain: perubahan peraturan hukum, penafsiran ulang atas ajaran agama yang dianggap mensubordinasikan perempuan, penghapusan kekerasan dan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kesetaraan upah untuk jenis pekerjaan yang sama dengan mempertimbangkan dan menghormati fungsi-fungsi reproduksi perempuan.

Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 dapat dikatakan tidak mencantumkan secara tegas mengenai jaminan hak asasi manusia. Kalaupun dapat dianggap bahwa UUD 1945 juga mengandung beberapa aspek ide tentang HAM, maka yang dirumuskan dalam UUD 1945 sangatlah sumir sifatnya. Setelah Perubahan UUD 1945, terutama perubahan kedua pada 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar.

Materi yang semula hanya berisi tujuh butir ketentuan yang juga tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan hak asasi manusia, saat ini telah bertambah secara signifikan sehingga perumusannya menjadi lengkap dan menjadikan UUD 1945 merupakan salah satu Undang-Undang Dasar yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 pada 2000, materi baru ketentuan dasar tentang hak asasi manusia itu dalam UUD 1945 dimuat dalam Pasal 28A ayat (1) sampai dengan Pasal 28J ayat (2). Kalau dicermati apa yang diatur dalam UUD 1945 setelah perubahan berkaitan dengan hak asasi manusia tidak dibedakan antara hak laki-laki dan hak perempuan, karena dalam UUD 1945 mencantumkan kata-kata "setiap orang".

Dalam rangka menegakkan butir-butir ketentuan hak asasi seperti yang diatur dalam UUD 1945, diatur pula mengenai kewajiban orang lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggung jawab negara atas tegaknya hak asasi manusia itu, yaitu:

1) Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;[4]
2) Bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;[5]
3) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;[6]

[4]Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
[5]Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
[6]Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;[7]
5) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;[8]
6) Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;[9]

Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa "setiap orang", "segala warga negara", "tiap-tiap warga negara", atau "setiap warga negara", yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan.

Bahkan UUD 1945 juga menegaskan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Dengan demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap perempuan Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan Warga Negara Indonesia yang laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya. Semua hak konstitusional yang telah diuraikan sebelumnya merupakan hak konstitusional setiap perempuan Warga Negara Indonesia.

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri kelompok tertentu, tetapi karena struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya.

---

[7]Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.
[8]Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
[9]Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memerhatikan adanya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut. Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, UUD 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Pasal 28H ayat (2) menyatakan "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*"

Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus adalah perempuan. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan.

Pentingnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah diakui secara internasional. Bahkan hal itu diwujudkan dalam konvensi tersendiri, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women* (CEDAW). Penghapusan diskriminasi melalui pemajuan perempuan menuju kesetaraan gender bahkan dirumuskan sebagai kebutuhan dasar pemajuan hak asasi manusia dalam *Millenium Development Goals (MDGs*). Hal itu diwujudkan dalam delapan area upaya pencapaian MDGs yang di antaranya adalah; mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan, dan meningkatkan kesehatan ibu. Rumusan tersebut didasari oleh kenyataan bahwa perempuan mewakili setengah dari jumlah penduduk dunia serta sekitar 70% penduduk miskin dunia adalah perempuan.

Pada tingkat nasional upaya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan mencapai kesetaraan gender telah dilakukan walaupun pada tingkat pelaksanaan masih membutuhkan kerja keras dan perhatian serius. CEDAW telah diratifikasi sejak 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.[10] Kemudian untuk lebih meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pemerintah mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang

[10]Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.

Pengarusutamaan Gender. Upaya memberikan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan gender juga telah dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, baik berupa prinsip-prinsip umum, maupun dengan menentukan kuota tertentu. Bahkan, untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang sering menjadi korban kekerasan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[11]

Tantangan penegakan hak konstitusional warga negara dengan sendirinya juga merupakan tantangan bagi penegakan hak konstitusional perempuan. Di sisi lain, karena perbedaan yang ada dalam masyarakat, tantangan penegakan hak konstitusional bagi perempuan tentunya lebih berat dan memerlukan perlakuan-perlakuan khusus. Penegakan hak konstitusional perempuan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 tentu harus melibatkan semua komponen bangsa, baik lembaga dan pejabat negara maupun warga negara, baik perempuan maupun laki-laki. Ketentuan konstitusional tersebut diwujudkan melalui seperangkat aturan hukum dan kebijakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh karena itu, upaya penegakan hak konstitusional harus dilakukan baik dari sisi aturan, struktur, maupun dari sisi budaya.

Di samping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan, atau paling tidak telah disusun dengan perspektif kesetaraan gender, tentu masih terdapat peraturan perundang-undangan yang dirasakan bersifat diskriminatif terhadap perempuan, atau paling tidak belum sensitif gender. Apalagi hingga saat ini masih banyak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Untuk itu upaya identifikasi dan inventarisasi harus dilakukan yang diikuti dengan penataan dan penyesuaian berdasarkan UUD 1945 pasca perubahan. Hal itu dapat dilakukan dengan mendorong dilakukannya legislatif review kepada pembentuk undang-undang atau melalui mekanisme *judicial review*. Terkait dengan wewenang Mahkamah Konstitusi, setiap perempuan Warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang, atau tidak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, tentu dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi.

Selain dari sisi substansi aturan hukum, tantangan yang dihadapi adalah dari struktur penegakan hukum dan konstitusi. Untuk mencapai perimbangan keanggotaan DPR dan DPRD misalnya, tidak cukup dengan menentukan kuota calon perempuan sebanyak 30% yang diajukan oleh setiap partai politik. Ketentuan tentang kuota itu tentu harus menjamin bahwa tingkat keterwakilan

[11]Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

perempuan di parlemen akan semakin besar. Padahal, saat ini jumlah anggota DPR perempuan baru 11%, di DPD 21%. Bahkan jumlah pegawai negeri sipil eselon I yang perempuan hanya 12,8%. Untuk itu, perlu dirumuskan mekanisme yang dapat menjamin keterwakilan perempuan di sektor publik semakin meningkat di masa mendatang.[12]

Tantangan di bidang struktur penegak hukum juga diperlukan misalnya terkait dengan proses hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagai korban atau saksi, perempuan memerlukan kondisi tertentu untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan. Untuk itu proses perkara, mulai dari penyelidikan hingga persidangan perlu memerhatikan kondisi tertentu yang dialami perempuan. Misalnya saat dilakukan penyidikan, perempuan korban kekerasan tentu membutuhkan ruang tersendiri, apalagi jika kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual yang tidak semua perempuan mampu menyampaikannya secara terbuka. Demikian pula terkait dengan persidangan yang membutuhkan jaminan keamanan baik fisik maupun psikis.

Yang tidak kalah pentingnya dalam upaya menegakan hak konstitusional perempuan, adalah menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi terutama yang terkait dengan hak konstitusional perempuan. Hal ini semakin penting karena kendala yang dihadapi selama ini memiliki akar budaya dalam masyarakat Indonesia. Akar budaya tersebut melahirkan dua hambatan, *pertama,* adalah dari sisi perempuan itu sendiri; dan *kedua,* dari masyarakat secara umum. Walaupun telah terdapat ketentuan yang mengharuskan mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender dalam pimpinan partai politik misalnya, namun hal itu sulit dipenuhi salah satunya karena sedikitnya perempuan yang aktif di dunia politik. Demikian pula dengan pemenuhan kuota 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD oleh partai politik. Sebaliknya, sering pula terjadi, seorang perempuan yang layak dipilih atau diangkat untuk jabatan tertentu, namun tidak dipilih atau diangkat karena dinilai perempuan mempunyai kelemahan tertentu dibanding laki-laki.

Hal itu menunjukkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional tersebut. Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegakan hukum yang sensitif gender serta yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan budaya yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Untuk mengubah nilai budaya tertentu bukanlah hal yang mudah, bahkan tidak dapat dilakukan dengan paksaan hukum. Cara yang lebih tepat adalah dengan merevitalisasi nilai budaya setempat merefleksikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

[12]Untuk keanggotaan tahun 2004–2009.

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Pelaksanaan PUG diinstruksikan kepada seluruh departemen maupun lembaga pemerintah dan non-departemen di pemerintah nasional, provinsi maupun di kabupaten/kota, untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan, aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program/proyek dan kegiatan. Disadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan. Oleh karena itu, program pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda bangsa dan memerlukan dukungan semua pihak.

Kenyataannya dalam beberapa aspek pembangunan, perempuan kurang dapat berperan aktif. Hal ini disebabkan karena kondisi dan posisi yang kurang

menguntungkan dibanding laki-laki. Seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pembangunan, sistem upah yang merugikan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, sehingga manfaat pembangunan kurang diterima kaum perempuan. Berbagai upaya pembangunan nasional yang selama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki, ternyata belum dapat memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Bahkan belum cukup efektif memperkecil kesenjangan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan memperoleh manfaat secara optimal belum terpenuhi sehingga pembangunan nasional belum mencapai hasil yang optimal, karena masih belum memanfaatkan kapasitas sumber daya manusia secara penuh. Faktor penyebab kesenjangan gender yaitu tata nilai sosial budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (ideologi patriarki); Peraturan perundang-undangan masih berpihak pada salah satu jenis kelamin dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender; Penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau cenderung tekstual kurang kontekstual, cenderung dipahami parsial kurang holistik; Kemampuan, kemauan dan kesiapan perempuan sendiri untuk mengubah keadaan secara konsisten dan konsekuen; Rendahnya pemahaman para pengambil keputusan di eksekutif, yudikatif, legislatif terhadap arti, tujuan, dan arah pembangunan yang responsif gender. Adanya kesenjangan pada kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan belum dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Selain itu rendahnya kualitas perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerusnya, mengingat mereka mempunyai peran reproduksi yang sangat berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia masa depan.

Di bidang pendidikan, kaum perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini antara lain disebabkan adanya pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan daripada perempuan. Di bidang ekonomi, secara umum partisipasi perempuan masih rendah, kemampuan perempuan memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah, demikian juga dengan akses terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Faktor penyebab kesenjangan kondisi dan posisi perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang bias gender karena dalam bidang hukum masih banyak dijumpai substansi, struktur, dan budaya hukum yang diskriminatif gender.

Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI sebenarnya merupakan bentuk pembaruan pembangunan pemberdayaan perempuan yang selama tiga dasawarsa telah memberikan manfaat yang cukup besar. Berbagai peningkatan pemberdayaan

perempuan bisa dilihat dengan meningkatnya kualitas hidup perempuan dari berbagai aspek, meskipun masih belum optimal.

Untuk meningkatkan status dan kualitas perempuan juga telah diupayakan, namun hasilnya masih belum memadai, ini terlihat dari kesempatan kerja perempuan belum membaik, beban kerja masih berat, kedudukan masih rendah. Di lain pihak, pada saat ini masih banyak kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang belum peka gender, yang mana belum mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi dan kepentingan antara perempuan dan laki-laki serta belum menetapkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai sasaran akhir pembangunan.

Penyebabnya antara lain belum adanya kesadaran gender terutama di kalangan para perencana dan pembuat keputusan; ketidaklengkapan data dan informasi gender yang dipisahkan menurut jenis kelamin (terpilah); juga masih belum mapannya hubungan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat maupun lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan yaitu dalam tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan.

Bergesernya proporsi pekerjaan utama perempuan dari pertanian ke ranah industri, meningkatnya mobilitas perempuan baik migrasi domestik maupun internasional serta semakin membaiknya peran perempuan di lingkup keluarga, masyarakat dan berbangsa serta bernegara merupakan indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan khususnya upaya kesetaraan dan keadilan gender mulai dapat dirasakan. Meskipun kemajuan perempuan ini hanya bisa dinikmati pada tataran masyarakat yang sosial ekonominya mapan (menengah ke atas).

Sebaliknya pada tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah, masih sering dijumpai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan baik dalam memperoleh peluang, kesempatan dan akses serta kontrol dalam pembangunan, serta perolehan manfaat atas hasil pembangunan. Hal ini tidak lain karena masalah struktural utamanya. Selain nilai-nilai budaya patriarkhi yang dilegitimasi dengan (atas nama) agama dan sistem sosial yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kedudukan dan peran yang berbeda dan dibeda-bedakan. Dengan demikian pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan KKG merupakan komitmen bangsa Indonesia yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh-tokoh agama dan masyarakat secara keseluruhan. Sesuai dengan dua arahan kebijakan itu, pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional maupun daerah, yang pelaksanaannya dapat memberikan hasil terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang kehidupan dan pembangunan.

Upaya mengaktualisasikan dan memanifestasikan dan mengakselerasikan PUG di sektor strategis, provinsi dan kabupaten/kota, Kementerian Pem-

berdayaan Perempuan juga telah melaksanakan program dan langkah konkret antara lain:

1. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan perempuan, serta serangkaian koordinasi telah dilakukan dalam upaya perbaikan undang-undang yang masih bias gender seperti UU Kewarganegaraan.
2. Program Peningkatan Peranserta masyarakat dan penguatan kelembagaan PUG dilakukan dengan melalui: sosialisasi, advokasi, dan pelatihan analisis gender baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
3. Pengembangan modul sosialisasi/advokasi gender.
4. Pengembangan alat untuk analisis gender yang digunakan dalam perencanaan program dan dikenal dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP); dan *Problem Base Analysis* (PROBA).
5. Pengembangan *Homepage* untuk penyediaan data dan informasi program pembangunan pemberdayaan perempuan, konsep kesetaraan dan keadilan gender dan jaringan informasi dengan website.
6. Penyusunan Profil Gender untuk 33 provinsi.
7. Fasilitasi bantuan teknis kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
8. Tersedianya data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin secara berkala dan berkesinambungan dari provinsi dan kabupaten/kota mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Akibat diskriminasi gender yang telah berlaku sejak lama, kondisi perempuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, politik, hankam dan HAM berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Kondisi yang tidak menguntungkan ini apabila tidak diatasi, maka ketimpangan atau kesenjangan pada kondisi dan posisi perempuan tetap saja akan terjadi.

Bahwa status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal masih mengalami diskriminasi haruslah diakui. Kondisi ini terkait erat dengan masih kuatnya nilai-nilai tradisional terutama di pedesaan, di mana perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, dan aspek lainnya. Keadaan ini menciptakan permasalahan tersendiri dalam upaya pemberdayaan perempuan, di mana diharapkan perempuan memiliki peranan yang lebih kuat dalam proses pembangunan. Kurangnya keikutsertaan perempuan dalam memberikan kontribusi terhadap program pembangunan menyebabkan kesenjangan yang ada terus saja terjadi.

Dukungan untuk melaksanakan PUG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tampak dari adanya berbagai komitmen internasional maupun nasional untuk mewujudkan keadilan gender. Komitmen internasional terhadap permasalahan tersebut antara lain tertuang dalam:

1. Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993, yang menyatakan hak asasi perempuan dan anak merupakan bagian yang melekat, menyatu, dan tidak

terpisahkan dari hak asasi manusia yang universal. Partisipasi perempuan yang sepenuhnya dan sama dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin, merupakan tujuan prioritas bagi masyarakat internasional;

2. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita/*Convention of Elimination Discrimintaion Against Women* (CEDAW) Tahun 1979;
3. Hasil Konferensi Dunia tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo Tahun 1994, yang menyepakati perlunya memerhatikan persoalan ketidakadilan gender dalam pembangunan;
4. Hasil Konferensi Beijing Tahun 1995, yang menyatakan ada 12 isu kritis perempuan yang berbasis gender yang perlu segera ditangani;
5. *United Nation Millenium Declaration* Tahun 2000, yang membuat satu rekomendasi penting untuk diterapkan di semua negara, yaitu: *to promote gender equality and empowerment of women as effective ways to combat poverty, hunger, and disease, and to stimulate development that is sustainable*.

Adapun berbagai komitmen nasional untuk mendukung implementasi PUG antara lain tertuang dalam:

1. UU No. 7 Tahun 1984, yang merupakan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
2. Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa, "Perencanaan pembangunan berperspektif gender pada dasarnya adalah upaya untuk mentransformasikan pengarusutamaan gender ke dalam kegiatan nyata institusi sektoral dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah";
3. Surat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. B-51A/Meneg PP/Dep.II/2001 tentang Panduan Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa strategi perencanaan pembangunan yang peka gender harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki yang berbeda ke dalam keseluruhan proses perencanaan kebijakan dan program pembangunan baik di pusat maupun di daerah;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Derahyang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam peraturan tersebut, Menteri Dalam Negeri meminta kepada gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia untuk merumuskan strategi pengarusutamaan gender dan menuangkannya ke

dalam dokumen Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

Hal lain yang turut mendukung pelaksanaan PUG adalah semakin berkembangnya kelompok-kelompok peduli perempuan, seperti Pusat Studi Gender/Pusat Studi Wanita (PSG/PSW) di berbagai perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Keberadaan berbagai lembaga tersebut menjadi kekuatan yang sangat potensial bagi pelaksanaan PUG.

Meskipun sudah ada komitmen politik (*political will*) dan keteladanan serta kepemimpinan (*leadership*), namun karena masih banyak pengelola pembangunan yang belum memahami pengarusutamaan gender (PUG) sebagai sebuah strategi pembangunan, komitmen tersebut belum merata di semua level. Untuk itu, perlu ada sosialisasi tentang pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi pembangunan bagi para pengelola pembangunan di semua lini.

Kebijakan PUG belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh dinas/instansi. Rendahnya proporsi kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan atau kepentingan perempuan pada kegiatan-kegiatan SKPD menunjukkan relatif rendahnya sensitivitas dan kesadaran gender di kalangan staf dan pengambil kebijakan. Untuk itu, perlu ada sosialisasi dan pelatihan gender untuk meningkatkan kesadaran dan sensitivitas gender di kalangan pengelola pembangunan.

Meskipun struktur dan mekanisme yang memungkinkan terselenggaranya pengarusutamaan gender sudah terbentuk, namun belum berfungsi secara optimal. Optimalisasi peran perlu dilakukan, antara lain dengan meningkatkan koordinasi dan intensitas pertemuan intra dan antarlembaga, sehingga terjadi sinergi dalam implementasi PUG.

Sumber-sumber daya yang mendukung program pengarusutamaan gender masih sangat terbatas, baik sumber daya manusia maupun finansial. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, perlu dilakukan pelatihan gender agar jumlah personel yang memahami strategi PUG dan implementasinya di setiap bidang pembangunan, serta yang memiliki kemampuan advokasi, fasilitasi, dan mediasi memadai. Pergantian personel yang menangani PUG juga sedapat mungkin dihindari agar kesinambungannya tetap terjaga. Alokasi anggaran untuk program PUG juga perlu ditingkatkan, agar implementasinya optimal. Untuk mengetahui ada-tidaknya kesenjangan gender, implementasi PUG juga perlu didukung sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Setiap dinas atau instansi perlu menyediakan data pilah gender yang lengkap, akurat, dan diperbarui secara berkala sehingga analisis gender untuk perencanaan, penganggaran, pemantauan, serta evaluasi pembangunan dapat dilakukan. Peran masyarakat dalam implementasi PUG sangat penting, untuk itu peran mereka perlu terus

ditingkatkan. Antara lain, meningkatkan keterlibatan mereka dalam forum musrenbang.

Pada akhirnya pelaksanaan pengarusutamaan gender ini akan berpengaruh terhadap perlindungan dan penegakan hak perempuan di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Kesimpulan

Pengaruh *gender mainstreaming* terhadap perlindungan dan penegakan hak perempuan di Indonesia setelah perubahan UUD 1945 adalah bahwa setiap perempuan Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan Warga Negara Indonesia yang laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya. Melalui pengarusutamaan gender ini berupaya untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh akses kepada, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Jadi pengarusutamaan gender tidak sekadar mengintegrasikan permasalahan gender dalam seluruh aspek pembangunan, tetapi juga mencakup upaya mengubah arus utama pembangunan agar lebih sensitif dan responsif terhadap keberagamanan yang ada di masyarakat, termasuk adanya perbedaan gender sebagai realitas. Pada akhirnya pelaksanaan pengarusutamaan gender ini akan berpengaruh terhadap perlindungan dan penegakan hak perempuan di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Saran

Masih diperlukan adanya sosialisasi tentang pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi pembangunan bagi para pengelola pembangunan di semua sektor, dan perlu dilakukan pelatihan gender untuk meningkatkan kesadaran dan sensitivitas gender di kalangan pengelola pembangunan sekaligus juga meningkatkan koordinasi dan intensitas pertemuan intra dan antarlembaga, sehingga terjadi sinergi dalam implementasi PUG. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender juga masih perlu ditingkatkan.

Daftar Referensi

Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Allan R. Brewer-Carias. *Judicial Review in Comparative Law*. Cambrigde University Press, 1989.

Baehr, Peter and Pieter van Dijk dkk. (eds). *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Bagir Manan. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Darwin, Muhadjir M. *Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana, 2005.

Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2003.

E.Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.

Isna, Alizar, dkk. *Penanggulangan PMS & HIV/AIDS Pada Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan dengan Ford Foundation, 2005.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

————————. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

————————. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: BIP Gramedia, 2006.

Joeniarto. *Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

KC Wheare. *Modern Constitution*. London: Oxford University Press, 1975.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. *Pengarusutamaan Gender Suatu Strategi Dalam Pembangunan*, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan *Women Support Project II/CIDA*, Jakarta, 2001.

Mauro Capelletti. *Judicial Review in the Contemporary World*. New York: The Balbs Merril Company Inc., 1971.

Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.

Modul Penyadaran Gender bagi Pendidik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2004.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN UI, 1983.

Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Anggaran Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Mohammad Yamin. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

O. Notomihardjo. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.

Otje Salman dan Anton F. Susanto. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama, 2004.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

R. Crience Le Roy. *De Vierde Macht,* Alih Bahasa oleh Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1976.

Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Solly Lubis. *Asas-asas Hukum Tata Negara.* cet-2. Bandung: Alumni, 1978.

Sri Soemantri M. *Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*. Bandung: Remaja Karya, 1988.

————————. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali, 1984.

————————. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1987.

Sunaryati Hartono. *Apakah the Rule of Law*. Bandung: Alumni, 1976.

————————. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1982.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Dian Rakyat, 1977.

24

PROBLEMATIKA HUKUM PASCAYUDISIAL REVIEW

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Oleh:
*Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., CN**



Pendahuluan

KONTROVERSI TENTANG PEMBERLAKUAN UU No. 29/2004 tentang praktik kedokteran (selanjutnya disebut UUPK) yang dimulai sejak diundangkan 6 Oktober 2004 dan tidak pernah surut (terutama tentang ketentuan Pemidanaan dan pembatasan praktik dokter), dan baru berakhir setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 4/PUU-V/2007 yang dibacakan Selasa, 19 Juni 2007. Kontroversi tersebut timbul karena adanya perubahan drastis tentang profesi kedokteran yang selama ini menjadi wewenang organisasi profesi, tiba-tiba diatur oleh hukum praktik kedokteran.

Alasan pengaturan oleh hukum adalah bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan oleh dokter yang memiliki moral yang tinggi harus tetap memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan dan dokter sehingga diperlukan pengaturan secara hukum. Inilah yang menjadi inti perdebatan antara dua profesi tertua di dunia, yaitu profesi kedokteran dan profesi hukum.

Adanya kontroversi dapat dipahami karena profesi kedokteran dianggap sulit atau bisa dikatakan tidak dapat dijangkau oleh hukum kalau terjadi ketidakpuasan pasien terhadap dokter yang merawatnya atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan dokter di Puskesmas/rumah sakit dan lain-

*Ketua Program Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang.

lain. Selama ini dokter mempunyai kultur medis bahwa kelalaian (*error*) adalah manusiawi (*To err is human. IOM 1999*). Dokter menganggap dirinya seperti juga manusia lain yang sering membuat kelalaian. Oleh karena itu, kelalaian dokter tidak dapat diukur dengan hukum, tetapi lebih kepada tanggung jawab moral dan etis serta pembelajaran supaya tidak terulang lagi dalam praktik selanjutnya. Karena kalau dilihat dari sudut moral rasa bersalah (melakukan kelalaian) sudah merupakan hukuman yang adequat, terutama bagi dokter muda yang sedang mengembangkan karier. Dari kaca mata hukum setiap kesalahan tidak dapat dimaafkan harus diusut secara hukum. Pada titik inilah dokter merasa sangat keberatan dengan campur tangan hukum dalam praktik kedokteran sedang masyarakat yang juga dipicu para ahli hukum merasa adil kalau masalah kelalaian dokter diselesaikan dengan hukum.



Sistem Litigasi dalam UU No. 29 Tahun 2004

Dengan berlakunya UUPA dokter harus terbuka pada tindakan-tindakan medik yang dilakukan terutama untuk keamanan dan keselamatan pasien, dengan mengubah budaya bahwa dokter adalah "dewa" yang perlu menyembunyikan kelalaian-kelalaian supaya tetap tidak mengurangi kepercayaan masyarakat pada dokter.

UUPK memakai sistem litigasi yang dalam praktik justru menyebabkan banyak pelayanan kesehatan yang tidak mencegah terjadinya kelalaian karena lebih merangsang untuk terjadinya rahasia dan diam. Maka perlu peninjauan kembali terhadap sistem litigasi dalam UU No. 29/2004. Unsur kelalaian (yang dirumuskan dalam UUPK dengan kata 'dengan sengaja melakukan' yang dilakukan oleh dokter dalam praktik kedokteran baik secara administratif maupun medik langsung diancam hukuman pidana seperti ketentuan yang termuat di dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 huruf a, dan Pasal 79 huruf c UUPK. Hal inilah yang memicu diajukannya permohonan *judicial review* oleh dr. Anny dkk.



Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) pada dasarnya Mahkamah Ketatanegaraan yang sesungguhnya adalah Mahkamah Politik. Seperti PTUN yang tidak ada upaya paksa dalam pelaksanaan putusannya kecuali diserahkan kepada kepatuhan terhadap hukum dari lembaga atau pejabat negara yang dikenai putusan itu. Sebagai contoh Keputusan MK tentang UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Anggaran Belanja Negara. MK membatalkan Penjelasan UU Sistem Pendidikan Nasional, karena dalam penjelasan memberikan kemungkinan kepada pemerintah dan DPR untuk menetapkan anggaran Pendidikan

Nasional dalam anggaran negara kurang dari 20% mengingat kemampuan negara yang belum cukup (UUD 45 mengatakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran negara atau daerah). Namun, pada sisi lain MK tidak membatalkan UU APBN yang menetapkan anggaran pendidikan kurang dari 29%, dengan pertimbangan kemanfaatan. Menurut MK jika UU APBN dibatalkan, maka berlaku UU APBN sebelumnya yang justru menetapkan lebih sedikit.

Dalam melaksanakan putusan tersebut MK tidak mungkin mengeksekusi sendiri. Presiden dan DPR berkewajiban secara konstitusional untuk melaksanakan keputusan MK. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas politik, MK dapat menyuarakan kepada publik mengenai isi putusan dan akibat konstitusional yang ditimbulkannya. Pada akhirnya publiklah yang harus memberikan *judgement* apakah memihak MK dan melakukan tekanan politik kepada DPR dan presiden, atau memihak DPR dan presiden dengan mengabaikan teriakan MK.[1] Menurut Shidarta[2] tuntutan masyarakat akan kualitas putusan MK adalah wajar dan mempunyai dasar filosofi yang kuat. Mahkamah ini hanya terdiri dari 9 hakim, namun apa yang ditetapkan mayoritas hakim konstitusi pada kenyataannya mampu menganulir keputusan ratusan wakil rakyat di lembaga legislatif yang notabene dipilih langsung melalui forum pemilihan umum. Oleh karena itu, keputusan MK harus menjadi putusan yang menjulang *(landmark decision)* karena membuat penemuan-penemuan hukum baru tentang bagaimana undang-undang yang diuji harus dimaknai dan teks konstitusi harus ditafsirkan.

Keputusan MK terhadap UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran adalah berkaitan dengan pembatasan tempat praktik dokter (Pasal 37 ayat (2)) dan berkaitan dengan hukuman pidana bagi dokter yang melakukan 'kesalahan' medik maupun administratif (Pasal 76, Pasal 79 huruf a, Pasal 79 huruf c) Tentang Pembatasan tempat Praktik dan hukuman pidana bagi dokter yang melakukan 'kesalahan medik' maupun administratif (Pasal 76, Pasal 79 ayat a dan ayat c).

Pembahasan akan berdasarkan:

a. Alasan Pemohon
b. Keterangan Tertulis Dewan Perwakilan Rakyat
c. Keterangan Pemerintah
d. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi
e. Putusan Mahkamah Konstitusi

---

[1]Hamdan Zoelva. *Hubungan MK dengan Lembaga-lembaga Negara*. Jentera. Jurnal Hukum. Edisi 11 Jan-Mart 2006.

[2]Shidarta. *Filosofi Penalaran Hakim Konstitusi dalam masa Transisi Konstitualitas*. Jentera. Jurnal Hukum. *Ibid*.

Alasan Pemohon: *Legal Standing*

1. Hak konstitusional para pemohon (I sampai VII) seperti yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H (ayat 1), dan (Ayat 2), serta Pasal 34 (ayat 3) UUD 45 sungguh-sungguh telah dirugikan dengan berlakunya UUPK, khususnya berkenaan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 37 (ayat 2), Pasal 75 (ayat 10, Pasal 78, Pasal 79 huruf a, Pasal 79 huruf c UUPK.
2. UUPK telah memasung hak-hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa ketakutan dalam menjalankan praktik kedokteran karena adanya sanksi berat yang tercantum pada pasal-pasal 75 ayat 1, Pasal 79 huruf a, dan Pasal 79 huruf e UUPK. Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal-pasal tersebut adalah hanya pelanggaran administrasif dan etika jadi tidak diancam dengan sanksi pidana melainkan cukup dengan sanksi administratif dan sanksi profesi.
3. Pembatasan tempat praktik menimbulkan beban moral pada diri para pemohon karena bertentangan dengan sumpah dokter (sumpah Hipokrates) yang menegaskan adnya *noblesse oblige* profesi dokter'.
4. Kriminalisasi terhadap dokter yang melakukan praktik kedokteran yang secara sengaja tidak memasang papan nama (Pasal 79 huruf c) tidak dapat diterima akal sehat.
5. Pemohon VII mendalilkan dirinya secara objektif mengalami kerugian finansial sebagai akibat diberlakukannya Pasal 37 ayat (2) UUPK.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

1. Pemohon I samapai VI telah nyata memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK maupun kerugian hak konstitusional. Oleh karena itu, pemohon I sampai VI mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan *a quo*.
2. Bagi Pemohon VII, MK berpendapat: meskipun mungkin benar yang bersangkutan telah mengalamai kerugian finansial dengan adanya pembatasan 3 tempat praktik (Pasal 37 ayat 2 UUPK, UU *a quo* tidak menghilangkan hak yang bersangkutan untuk mendapat pelayanan kesehatan. Jadi kerugian yang didalilkan oleh pemohon VII bukanlah kerugian hak konstitusional seperti yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK. Oleh karena itu, pemohon VII tidak diterima sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku pemohon.

Keterangan tertulis DPR

Pembatasan izin praktik dokter dan pengaturan sanksi pidana

- Menjamin tersedianya waktu pelayanan yang tepat
- Tersedia waktu bagi dokter untuk penelitian, istirahat

- Menghindari monopoli pelayanan medis oleh dokter-dokter senior dan memberi kesempatan dokter untuk bersaing secara positif
- Menyebarluaskan tenaga dokter ke seluruh pelosok Indonesia

Pengaturan sanksi pidana sebagai sarana penegakan pelaksanaan aturan hukum dan salah satu perwujudan perlindungan pasien serta kepastian hukum kepada masyarakat.

Keterangan Pemerintah

- Pembatasan praktik kedokteran tidak bertentangan dengan sumpah dokter yang mengutamakan kepentingan kemanusiaan dan masyarakat. Tidak bertentangan juga dengan UUD 45 dan tidak merugikan hak/kewenangan konstitusional para pemohon.
- Pengaturan sanksi pidana untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melindungi masyarakat maupun dokter. Tindak pidana yang dilakukan dianggap kejahatan *(misdrijven)* dan bukan pelanggaran. Jadi tidak bertentangan dengan UUD 45.

Pertimbangan MK

- Ancaman Pidana pada Pasal 75 ayat (1) UUPK, Pasal 76 UUPK dan Pasal 79 UUPK huruf a dan c dapat dibenarkan dari sudut teori hukum pidana.
- Tetapi ancaman pasal-pasal tersebut menurut MK tidak proporsional, tidak mempertimbangkan perspektif hukum pidana yang humanistis dan terkait erat dengan kode etik. Hal demikian tidak sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang berbunyi: *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, yang di bawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
- Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga dirugikan. Pelayanan kesehatan menupakan hak asasi manusia, oleh karena itu ancaman pidana Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 UUPK tidak sesuai dengan filsafat hukum pidana.
- Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 C (ayat1) UUD 45 menyatakan bahwa memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan adalah hak. Dengan demikian, ketentuan pidana dalam Pasal 79 huruf c UUPK harus dibaca tidak mencakup kata-kata "atau huruf e". Oleh karena itu, permohonan sepanjang menyangkut kata-kata "atau huruf e" dalam Pasal 79 UUPK adalah beralasan.

Keputusan MK

Permohonana para pemohon dikabulkan untuk sebagian:

- Menyatakan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata "penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau" dan Pasal 79 sepanjang mengenai

kata-kata " "kurungan paling lama satu (1) tahun atau" serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata"atau huruf e" UUPK bertentangan dengan UUD 45.

- Menyatakan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata "penjara paling lama (3) tahun atau" dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata "kurungan paling lama satu (1) tahun atau" serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata "atau huruf e" UUPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Menolak permohonan pemohon selebihnya.



Pembahasan

Ada dua kepentingan hukum yang berhadapan satu sama lain yang harus dilindungi secara seimbang. Dua kepentingan hukum tersebut adalah. *Pertama,* pemerintah harus mengupayakan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis, *kedua,* pemerintah juga harus mengupayakan kepentingan provider (dokter) untuk memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dan kepastian hukum dijamin oleh UUD 45.

Permohonan pemohon yang tidak dikabulkan adalah berkaitan dengan permohonan pemohon VII yaitu tentang pembatasan tempat praktik dokter (Pasal 37 ayat (2)). Dalam hal ini asumsi MK dokter di Indonesia telah merata sehingga MK mengambil tolok ukur dokter di perkotaan. Asumsi yang keliru ini harus diikuti dengan ketentuan "pengecualian" di daerah-daerah tertentu (kondisi wilayah yang berbeda) supaya tujuan untuk melindungi pengguna jasa dokter dan dokter tidak dirugikan. Ketentuan pengecualian tidak dapat diatur dengan UU yang lebih rendah dari UU *a quo*. Pasal 37 ayat 2 tentang pelanggaran terhadap izin praktik sebetulnya bukan pelanggaran hukum pidana karena masuk dalam bidang administrasi negara. Surat izin praktik merupakan keputusan tata usaha negara (*beschikking*). Pasal 37 ayat (1) UUPK menetapkan, surat izin praktik dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten /kota tempat praktik dokter dilaksanakan. Memang ada juga keputusan tata usaha negara yang diancam hukuman pidana pada pelakunya karena perbuatannya *bersifat melawan hukum*[3] (misal pengendara mobil yang tidak mempunyai SIM, wajib pajak yang tidak mematuhi pembayaran pajak. Sedang Pasal 37 ayat 2, tidak ada unsur melawan hukum karena tidak bertentangan dengan hak subjektif para pasien. Demikian juga Surat Tanda Registrasi (STR) dan pemasangan papan nama dokter masuk dalam bidang administrasi negara.

[3]Moeljatno mengatakan bahwa: perbuatan pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 2002).

Kalau dokter tidak menggunakan STR (Pasal 75 ayat 1) tidak dapat dipandang melanggar hukum pidana karena bertindak sesuai dengan wewenang sehingga tidak dapat dipandang bertentangan dengan hak subjektif para pasien (untuk memperoleh pelayanan kesehatan menurut konstitusi), yang dilanggar adalah ketentuan konsil kedokteran atau ketentuan administratif. SIP, STR, pemasangan papan nama bagi dokter seharusnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, incasu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Sistem double license yang dianut UUPK (STR diberikan konsil kedokteran dan SIP yang sebagai *licensy* yang diberikan pemerintah} wajib dimiliki seorang dokter (yang sudah memiliki kompetensi karena sudah lulus pendidikan kedokteran) untuk menjalankan praktik dokter yang sah.



Kesimpulan

MK seharusnya memberikan perlindungan hukum yang seimbang pada dua kepentingan hukum yang berhadap-hadapan. *Pertama,* mengupayakan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis. *Kedua,* juga harus mengupayakan kepentingan provider untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum.

25

DAMPAK LIBERALISASI KETENAGALISTRIKAN

Oleh:
Prof. Dr. Indrati Rini, S.H., M.S.*



Fakta Hukum

TAK PERCAYA tetapi fakta membuktikan, UU No. 2/2002, yang selanjutnya disebut UU Kontroversial, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 14 Desember 2004. Seakan kita tersentak dari lamunan bahwa Indonesia berkiprah dalam pasar ketenagalistrikan liberal, yang bernuansa nasional, regional, bahkan global, seolah sirna *ditelan hukum*.

Bukan main fakta hukum pembatalan itu, kalau boleh saya sebut sebagai fakta spektakuler, sebab ada *undang-undang balik kucing*. Betapa tidak, UU Kontro itu berlaku sejak disahkan oleh Presiden RI 23 September 2002, dalam ketentuan penutupnya mencabut UU No. 15/1985.[1] Sekarang, kita balik lagi pada *UU tua* tersebut, karena berlaku lagi sebagai hukum positif (*positive law*). Untuk memperoleh gambaran muatan apa yang ada pada kedua UU tersebut, ada baiknya kita coba membandingkannya, walaupun hanya sekilas berikut ini. UU Kontro yang telah *almarhum* tersebut, merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan nasional. Tujuan utamanya, agar pengelolaan sektor usaha ketenagalistrikan dapat lebih efisien, transparan dan kompetitif, dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *Kompetisi usaha penyediaan tenaga listrik* diterapkan secara awal pada sisi pembangkitan, kemudian jika sudah ada kesiapan perangkat keras dan lunaknya akan diterapkan pada sisi penjualan. Dalam hal ini konsumen listrik mempunyai *the right to choose,*

---

*Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

[1]Pada saat UU Kontro ini berlaku, yaitu pada saat diundangkan, maka UU No. 15/1985 dinyatakan tidak berlaku, berarti tidak berdampak hukum lagi, namun UU No. 5/1985 sekarang diberlakukan kembali.

yaitu ada hak menentukan pilihan atas pasokan tenaga listrik yang ditawarkan 'paling bersaing dengan mutu dan pelayanan yang paling baik'. Intinya, *tak ada monopoli* di sektor ketenagalistrikan. Penerapan kompetisi di sisi penjualan tersebut, dimulai dari konsumen besar yang tersambung pada tegangan tinggi, selanjutnya pada tegangan menengah. Dalam menunjang terlaksananya kompetisi ini, maka dibentuklah "*Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik*, yang bertugas mengatur dan mengawasi penyediaan tenaga listrik di daerah yang telah menerapkan kompetisi."[2] *Peran pemerintah terkurangi* dengan adanya badan tersebut, yaitu dalam hal penetapan regulasi bisnis ketenagalistrikan, walaupun tidak mengurangi kewenangannya dalam membuat kebijakan. Pendek kata, UU "*in memoriam*" tersebut bermuatan seluk-beluk kompetisi ketenagalistrikan, yang diberikan kepada BUMN/D, Koperasi, dan Swasta secara terstruktur dimulai dari pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik, rencana umum ketenagalistrikan, usaha ketenagalistrikan, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen listrik, penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha, harga-jual listrik, penerimaan negara, lingkungan hidup dan keselamatan ketenagalistrikan, pemanfaatan jaringan listrik untuk kepentingan orang lain, pembinaan dan pengawasan, badan pengawas tenaga listrik, serta penyidikan dan ketentuan pidana di sektor ketenagalistrikan.

Sekarang mari kita kaji bersama UU tua "yang disahkan untuk pertama kali pada 30 Desember 1985."[3] Dalam UU ini digariskan bahwa *tenaga istrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak*, maka perlu digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merata materiil dan spiritual berdasar Pancasila dan UUD 1945. Dalam pembangunan nasional, tenaga listrik memiliki arti penting, yaitu sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara, "yang pelaksanaannya dilakukan oleh BUMN."[4] Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah PT PLN (Persero) sebagai pemegang atau penerima kuasa usaha. Dengan kata lain, ada perjanjian kuasa (*lastgeving*),[5]

---

[2]Badan ini mempunyai *kekuasan legislasi*, yaitu berwenang mengeluarkan peraturan-peraturan, seperti *Grid Code, Tariff Code, Procurement Tendering Code* termasuk *law enforcement*., berupa penegakan hukum ketenagalistrikan.

[3]UU No. 15/1985 menggantikan Ordonansi 13 September 1890, *Bepalingen Omrent den aanleg en het gebruik van geleiden voor electrische verlichting en het Overbrengen van kracht door middle van electriciteit in Nederlansch Indie,* yaitu Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran Untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga Listrik di Indonesia dalam Stb. 1890 No. 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Ordonansi 1934 Stb. 1934 No. 63.

[4]PT PLN sebagai Perusahaan Perseroan, yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, *yang tujuan utamanya mengejar keuntungan*, demikian UU No. 19/2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 ayat 2.

[5]Pemberian kuasa, sebagai suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *boleh jadi antara negara dan PLN di sini di samping tunduk pada Hukum Privat, juga Hukum Publik*.

antara pemerintah, yaitu menteri energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pemberi kuasa (*lastgever)* dengan PT PLN (Persero) selaku penerima kuasa (*lasthebber*), yang berobjekkan pada pengelolaan sektor usaha ketenagalistrikan, agar dapat tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik.

Selanjutnya sepanjang pengelolaan usaha ketenagalistrikan tidak merugikan negara dan dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang lebih merata, serta demi meningkatkan kemampuan negara, maka dapat diberikan kesempatan pada *koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik* berdasar pada izin usaha ketenagalistrikan. Di sini pemerintah yang mengatur harga-jual listrik. Syarat-syarat tentang penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan, instalasi dan standardisasi ketenagalistrikan diatur oleh pemerintah. Demikian juga mengenai hak dan kewajiban masyarakat ketenagalistrikan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Pemerintah juga melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. Intinya UU tua ini, negara menguasai sektor ketenagalistrikan untuk kesejahteraan rakyat, boleh jadi bersifat monopolistik dan tersentralisasi.

Hasil komparisi antara UU tua dan UU kontroversial, yaitu UU tua berisi 27 pasal, sedangkan UU Kontroversial berisi 71 pasal, di mana dalam UU tua negara/pemerintah dominan dalam menguasai ketenagalistrikan yang didelegasikan pada PT PLN (Persero), namun dalam UU "*in memorian*" terbuka kompetisi secara bertahap, dari pembangkitan sampai ke penjualan listrik pada konsumen.

Problem utamanya, dengan berlakunya kembali "UU Balik Kucing", yaitu UU No. 5/1985, sejauhmana dampaknya bagi konsumen listrik, dan sejauhmana sikap atau tindakan pemerintah dan pelaku usaha, utamanya PT PLN (Persero) dalam mengelola tenaga listrik untuk kepentingan konsumen listrik?



Problematika Konsumen

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Berarti pemerintah dan rakyat, harus taat pada hukum, termasuk hukum ketenagalistrikan, demikianlah filosofinya.

Menurut pengamatan saya, negara kita menganut sistem campuran (*mixed law system)*. Tradisi sejarah penjajahan membawa Indonesia ke dalam *civil law system*, yang lebih mengutamakan hukum tertulis daripada hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Singkatnya per-UU-an adalah landasan hukum utama daripada hukum yang tidak tertulis, namun sekarang tampaknya telah berbaur antara keduanya, tak terkecuali hukum ketenagalistrikan.

Aliran yang bernuansa yuridis-formal telah menuntun kita dalam melakukan pembuatan hukum (*rechtsvorming)* dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Hal ini tampak jelas dari ketentuan "peraturan per-UU-an adalah peraturan tertulis, yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat secara umum."

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sebagai *grund norm*. Praktiknya, pejabat sektor ketenagalistrikan tunduk dalam membuat dan menegakkan hukum, yaitu berdasar pada per-UU-an yang disusun berjenjang sesuai dengan tata urutannya (*hirarchie*), mulai dari UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, *Peraturan Presiden*, dan Perda (provinsi, kabupaten/kota, dan desa/setingkat).

Kekuatan per-UU-an ketenagalistrikan adalah mengikat, sepanjang dibuat berdasar peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini jika dilanggar, maka dampaknya batal demi hukum (*nietig, null and void*). Di samping itu, ada pula "*Governmental policies are generally regarded as legal obligations, which command the loyalty of citizens*". Dampaknya segala per-UU-an dan kebijakan pemerintah, rakyat mau tidak mau harus tunduk, termasuk UU tua tentang ketenagalistrikan.

Sekarang problem aktual-faktual yang timbul sebagai dampak berlakunya kembali UU tua, antara lain:

- Sejauhmana daya berlaku dari produk (barang dan jasa), kontrak, lembaga dan berbagai aktivitas lain, yang berlandaskan pada 'UU *in memoriam*'?
- Adakah perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan listrik yang bermutu dengan harga yang terjangkau?
- Hak-hak konsumen listrik setarakah dengan PT PLN (Persero)?
- Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan konsumen, jika haknya dilanggar?
- Bagaimana aspek legalitas 'KONSUIL', Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik?
- Bagaimana PPJ yang pembayarannya dikaitkan dengan rekening listrik?
- Sejauhmana tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah di sektor ketenagalistrikan?
- Apa yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam menangani keluhan atau sengketa konsumen listrik dengan PT PLN (Persero)?
- Benarkah tanggung jawab pemerintah lebih besar berdasar UU tua daripada UU kontroversial?

Tiada salahnya kita mengkritisi laporan pengaduan konsumen listrik ke PLN sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 25.1. Jumlah Pengaduan Berdasar Jenis Masalah

No.	Masalah	Jumlah	Persentase
1.	Pasang Baru	2	1,9%
2.	Baca Meter	12	11,7%
3.	Kehandalan	11	10,7%
4.	Pembayaran	8	7,8%
5.	Tagihan	10	9,8%
6.	Tambah/Turun Daya	7	6,8%
7.	Pemadaman Sepihak	23	20,4%
8.	Pelayanan *Call Center*	24	23,4%
9.	Jaringan	6	5,9%
Jumlah		103	100%

Sumber: Biodata Bulan Pengaduan, LPKS, 2008, diolah.

Berdasar tabel di atas, tampak bahwa pengaduan jenis pelayanan *call center* menduduki jumlah terbanyak, sedangkan terkecil adalah pasang baru. Pengaduan tersebut disampaikan konsumen, baik *secara lisan/telepon* maupun *tulisan/surat*. Dari jenis-jenis pengaduan tersebut, mencerminkan fakta bahwa problem atau masalah konsumen ternyata telah ada yang dapat diselesaikan dengan pihak PT PLN, tetapi ada pula yang tidak selesai, dan ada pula yang belum selesai atau mengambang, sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 25.2. Jumlah Pengaduan Konsumen Atas Pelayanan Publik

No.	Nama Perusahaan	Jumlah	Persentase
1.	PT PLN	74	47,36%
2.	PT TELKOM	44	24,32%
3.	PDAM	38	28,32%

Sumber: Biodata Pengaduan Konsumen, LPKS, 2008, diolah.

Dari paparan tabel di atas, tampak bahwa pengaduan konsumen ke PLN, lebih banyak dibandingkan TELKOM dan PDAM, *jika dilihat secara kuantitatif*. boleh jadi, sektor listrik dengan jumlah pelanggan yang lebih besar, maka jumlah pengaduannya lebih besar pula. Untuk itu, sebagai perusahaan BUMN/D tidak saja mengejar keuntungan, namun *juga harus mengejar kepuasan publik konsumen atau pelanggan listrik*, baik dari sektor industri, bisnis, sosial, publik, dan rumah tangga.

Hak-hak konsumen dalam UU tua tidak tertulis dalam pasal-pasalnya, namun dalam UU Kontro secara eksplisit ada lima pasal, dan lima pasal kewajiban, serta satu pasal yang berisi tanggung jawab konsumen listrik. Dari dua UU tersebut, maka UU Kontro lebih mengakomodir hak-hak konsumen

listrik daripada UU Tua. Oleh karena itu, konsumen harus lebih pro-aktif memberdayakan diri sendiri, "dengan mendasarkan hak-haknya pada UU Perlindungan Konsumen." Di samping itu, konsumen listrik dapat juga memperjuangkan hak-haknya melalui LPKSM atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota/Kabupaten.



Sikap Pelaku Usaha

Pembatalan UU Kontro mengundang reaksi dari berbagai kalangan, baik dari pelaku usaha, PLN dan rekanannya, konsumen, bahkan juga pemerintah. UU tersebut memang sejak awal "ditengarai bertentangan dengan UUD 1945", bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini terlihat perekonomian berdasar demokrasi ekonomi demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Kondisi penguasaan sektor ketenagalistrikan yang berdasar kompetisi bebas *yang bernuansa liberal*, dapat menyengsarakan rakyat, maka muncul permohonan uji materiil (*judicial review*) UU Kontro ke Mahkamah Konstitusi oleh "sejumlah elemen masyarakat", di antaranya Serikat Pekerja PLN, BHI, Ikatan Keluarga Pensiunan PLN. Hasilnya sangat menakjubkan, UU Kontro dibatalkan.

Sekarang, kondisinya kembali pada filosofi semula, bahwa *negara menguasai* (bukan memiliki) sektor ketenagalistrikan, sebab jika tidak, dikhawatirkan tampuk produksi akan jatuh ke tangan investor swasta, terutama asing (*foreign investor*), dikhawatirkan rakyat sebagai konsumen berada dalam posisi yang tertindas.

PT PLN (Persero) berharap dapat bekerja sama dengan berbagai investor, baik luar negeri maupun dalam negeri. Boleh jadi PLN melakukan langkah yang mengarah pada kompetisi internal, seperti antara dua anak perusahaannya di bidang pembangkitan, yaitu PT Pembangkitan Jawa-Bali dan PT Indonesia Power tetap dilanjutkan, mampukah keduanya memasok seluruh kebutuhan nasional?

Jajaran Direksi PLN mengungkapkan bahwa keputusan pembatalan UU Kontro sama sekali di luar harapan, sebab mereka ikut menyusun, mensosialisasi dan melaksanakannya. Namun, PLN tetap bersikap arif menerima pembatalan tersebut, dan berupaya agar tidak berdampak negatif pada masyarakat.

"Peran PLN sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK) sangat berat dan akan menunggu arahan pemerintah",[6] dalam upaya mengajak pihak swasta untuk bekerja sama dengan PLN secara sehat dan saling menguntungkan.

---

[6]Direktur Utama PT PLN (Persero), *Jawa Pos*, Surabaya, Tanggal 18 Maret 2009.

PLN dan para rekanannya dituntut memberikan pelayanan terbaiknya, sesuai dengan standar pelayanan publik dan pelaksanaan dari *Public Service Obligation*. Salah satu perwujudan peran tersebut, yaitu dengan dibentuknya Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (*National Committee For Safety of Electrical Instalation*), yang berunsurkan PT PLN (Persero), Kontraktor Listrik, Produsen Peralatan Litrik dan Pemanfaat Listrik dan Konsumen. Badan ini tugas utamanya adalah "melaksanakan pemeriksaan dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi Instalasi, *atas pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah*."[7]

Dengan dibatalkannya UU Kontro, ternyata PLN tetap menjaga kemurnian kontrak-2 dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani dan berlaku sampai habis masa berlakunya. Di samping itu, PLN melakukan restrukturisasi sesuai asas desentralisasi secara hati-hati sejalan dengan otonomi daerah. Kita lihat, apakah konsumen mempunyai posisi tawar di hadapan PLN, fakta yang membuktikan.



Tindakan Pemerintah

Di sejumlah negara maju dan berkembang seperti AS, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Korea, Filipina serta Singapura, sektor ketenagalistrikan telah dikompetisikan. Berbicara kompetisi/persaingan harus diingat *sifat listrik*, yaitu begitu dibangkitkan langsung digunakan, maka jumlahnya harus sesuai.UU Kontro almarhum *menghendaki monopoli vertikal dipecah*, dari sektor pembangkit, transmisi, distribusi, penjualan dan usaha pengelolaan pasar. Singkat kata dengan kompetisi akan tercapai efisiensi, bisa terlihat pada *harga listrik yang lebih murah dibanding monopoli*. Di sini, timbul pertimbangan pemerintah mana yang lebih utama, yaitu monopoli versus kompetisi, dilematis memang.

"Indonesia memang unik, monopoli dilarang", tetapi ada perkecualian bagi BUMN yang mengelola produksi atau pemasaran produk yang menguasai hajat hidup orang banyak. Idealnya ingin meraih kepastian hukum, *namun mengapa ada perkecualian*.

Seharusnya fokus perhatian kita terarah pada kata-kata "menguasai" dan "cabang produksi yang penting". *Siapa yang berwenang menentukannya*, legislatif (DPR), Pemerintah (eksekutif) atau lembaga lain, seperti Mahkamah Konstitusi. Menteri ESDM menengarai pembatalan UU Kontro dapat menghambat investasi. Saat ini penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan kembali bersifat *top down*, dan tidak ada lagi Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.

---

[7]Direktur KONSUIL bertanggung jawab pada Menteri ESDM c/q Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, SK. Menteri ESDM No. 1109 K/30/MEM/2005.

Pemerintah telah melakukan langkah-langkah memasukkan muatan regulasi melalui berbagai kebijakan atas listrik, di antaranya berupa PP No. 3 Tahun 2005. Dalam PP revisi ini ditentukan bahwa "harga jual tenaga listrik untuk konsumen diatur dan ditetapkan dengan memerhatikan kepentingan dan kemampuan dari masyarakat". Harga jual tenaga listrik dibedakan dalam dua kategori yaitu:

a. Harga jual tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ditetapkan oleh presiden atas usul menteri.
b. Harga jual tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota.

Perlu kita cermati bahwa antara PLN dan konsumen ada *kontrak/perjanjian jual beli* tenaga listrik. Dalam hal ini seharusnya *kedudukan mereka sejajar* dalam menentukan barang dan harga. Namun, adakah hak untuk memilih dan hak untuk menawar dari konsumen listrik dijamin hukum. Hal inilah dapat menjadi sumber *conflict of interest,* yang sering muncul terjadinya demonstrasi di masyarakat sebagai dampak dari kenaikan tarif dasar listrik.

PP revisi tersebut ternyata mendapat kritik dari masyarakat, di antaranya dari Ketua Serikat Pekerja PLN, bahwa "tarif listrik dalam negeri menjadi lebih mahal dan dapat menciptakan kartel, padahal PP ini bertujuan menarik investor listrik."

Dengan adanya kenaikan harga BBM, dapat berdampak TDL akan berubah. Faktanya, tahun 2009 ini pemerintah bersama PLN berjanji tidak akan menaikkan tarif dasar listrik. Penyesuaian tarif listrik dapat dilakukan oleh PLN ataupun pemerintah dapat memberikan kompensasi dana *atas public service obligation*. Yang pasti pemerintah diharapkan mampu melihat kondisi riil kemampuan masyarakat dalam mengelola sektor listrik sehingga dampak sosial-ekonomi pada masyarakat yang bersifat merugikan dapat dihindari, minimal dikurangi.

Secepatnya pemerintah dapat mengusulkan kembali Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan Baru, dengan memasukkan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik yang luas. Sekarang pemerintah, dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab penuh atas usaha penyediaan tenaga listrik, yang secara riil dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) didorong dan dituntut dapat mengendalikan manajemen ketenagalistrikan yang transparan efisien, mandiri dan profesional demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, semoga.

Kesimpulan

1. Dampak pembatalan UU No.20/ 2002 bagi konsumen listrik, yaitu *hak-haknya kurang terlindungi*, karena tidak tertulis dalam ketentuan UU No.15/ 1985, maka Konsumen harus pro-aktif dalam memperjuangkan hak-haknya secara mandiri kepada pelaku usaha, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota/Kabupaten, atau ke Pengadilan Negeri.
2. PT PLN (Persero) sebagai *pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dituntut bersikap profesional*, yaitu bertanggung jawab secara terbuka dan transparan kepada publik dalam melaksanakan kuasa usaha mengelola ketenagalistrikan nasional dengan memberikan produk dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tanpa menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.
3. Pemerintah, yang secara riil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral harus *bertindak arif dalam menguasai ketenagalistrikan*, yaitu mampu memberikan kekuasaan dan meminta pertanggungjawabannya pada pemegang kuasa usaha dan pemegang izin usaha, sehingga penyediaan dan pengelolaan tenaga listrik mampu disediakan secara cukup memadai secara nasional.

Rekomendasi

1. Konsumen listrik hendaknya beriktikad baik dalam mengonsumsi listrik, yaitu berperilaku lebih mengedepankan kepatuhan sebagai pembeli-pengguna tanpa mengurangi hak-haknya yang dilanggar untuk diperjuangkan, baik secara kekeluargaan dengan pelaku usaha atau pemerintah, maupun secara hukum, jika perlu melakukan gugatan *class action* atau *legal standing*.
2. PT PLN (Persero) hendaknya secara terus-menerus berbenah diri dalam berbisnis, yaitu baik dari sisi kualitas manajemen dan teknologi listrik maupun dari sisi kuantitas listrik, dengan tetap mengejar keuntungan perusahaan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat-konsumen.
3. Pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM hendaknya lebih menggerakkan dan menggeliatkan usaha ketenagalistrikan nasional, yaitu menarik investor baik domestik maupun asing*, berdasar asas pemerintahan yang baik,* tanpa segan *menegakkan hukum ketenagalistrikan secara benar dan konsisten* terlepas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, demi mewujudkan dunia impian negara Indonesia yang adil dan makmur.

Daftar Referensi

Davis G. Epstein and Steve H. Nickles. *Consumers Law*. West Publishing Co., Minnesota, 1981.

Husni Syawali dan Neni Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Indrati Rini. *Penerangan Jalan Umum Antara Hak dan Kewajiban*. Surabaya: PT PLN Jawa Timur-LPKS, 2008.

————————. *Posisi Tawar Konsumen Atas Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik*. Surabaya: PT PLN (Persero) Divre V-Konsuil, 2008.

Joni Emirzon. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama 2001.

Thomas R. Dye. *Understanding Public Policy*. New York: Prentice Hall Inc., Engelwood Cliffs. 1978.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. *Warta Konsumen*. Edisi April, Jakarta, 2009.

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Keempat, 2002.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1109 K/30/MEM/2005 tentang Penetapan KONSUIL Sebagai Lembaga Pemeriksa Untuk Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah.

RAJAWALI PERS

Bagian Keempat

Pembaruan Penyelenggaraan Pemerintahan

RAJAWALI PERS

26

OMBUDSMAN MENDORONG PELAYANAN PUBLIK YANG BERTANGGUNG JAWAB*

Oleh:
Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.**

Pendahuluan

Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman menyebutkan bahwa reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, yaitu kehidupan yang didasarkan pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pada awal-awal masa reformasi, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara menetapkan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara, yaitu: 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Asas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas, dan 7) Asas Akuntabilitas.

Sebelum reformasi, penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktik maladministrasi antara lain terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (selanjutnya disebut KKN). Hal tersebut mendorong dilakukannya reformasi birokrasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan agar efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka, serta bebas dari KKN.

Upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien bertujuan meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum

---

*Tulisan ini merupakan kado penulis untuk Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dalam rangka hari ulang tahun ke-40 dari kelahirannya. Sebagian isi tulisan ini telah dimuat dalam majalah Varia Peradilan Tahun XXIV No. 282 Mei 2009, dengan beberapa perubahan seperlunya.

**Hakim Agung MA-RI.

yang dilakukan tidak terpisahkan dari upaya tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan dalam UU No. 37 Tahun 2008.

Selain itu, ada unsur penting lainnya yang menjadi pertimbangan pula, yaitu pengawasan terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, yang bertujuan "mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan."

Pasal 1 ayat (2) UU di atas menyebutkan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut penulis, penyelenggara negara yang dimaksud dalam pertimbangan UU No. 37 Tahun 2008 adalah penyelenggara negara yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara menyebutkan bahwa penyelenggara negara adalah: 1) pejabat negara pada lembaga tertinggi negara,[1] 2) pejabat negara pada lembaga tinggi negara, 3) menteri, 4) gubernur, 5) hakim, 6) pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 7) pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (6) undang-undang di atas disebutkan "*Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme"* serta *"melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan"*....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka memerhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang baik dan efisien, jujur, bersih, terbuka, dan bebas dari KKN, lembaga *Ombudsman* dibentuk.

Penjelasan Umum undang-undang ini menyebutkan secara eksplisit bahwa lembaga yang akan dibentuk (dan selanjutnya bernama *Ombudsman*) adalah lembaga pengawas eksternal, yang salah satu alasan pembentukannya adalah karena pengawasan internal pemerintah sendiri tidak memenuhi harapan masyarakat baik dari sisi objektivitas maupun akuntabilitasnya.

[1]Pada saat ini sebutan lembaga tertinggi negara tidak ada, karena MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara.



Pembahasan

'AS Hornby menyebutkan bahwa *Ombudsman* adalah *experienced person having authority to inquire into and pronounce upon grievances of citizens against public authorities*.[2]

Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008 menyebutkan bahwa *Ombudsman* RI selanjutnya disebut *Ombudsman*. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN, serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Sedangkan dalam Pasal 2 undang-undang yang sama disebutkan bahwa "*Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara atau instansi lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.*

Menurut penulis, ada hubungan antara Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 di atas, yaitu hubungan kelaziman. Artinya, sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, *Ombudsman* haruslah tidak mempunyai hubungan apa pun dengan *lembaga negara atau instansi lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya,* sehingga kedudukannya sebagai lembaga yang mandiri benar-benar tercermin, dan dapat bekerja secara maksimal dan optimal dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Dengan kata lain, *Ombudsman* adalah lembaga pengawas eksternal bagi penyelenggara negara pada berbagai lembaga tinggi negara. Oleh karena itu pula, Pasal 20 UU No. 37 Tahun 2008 menyebutkan *"Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dilarang merangkap menjadi: (a) pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan, (b) pengusaha, (c) pengurus atau karyawan BUMN atau BUMD, (d) pegawai negeri, (e) pengurus parpol; atau (f) profesi lainnya.*

Dalam Pasal 6 undang-undang ini disebutkan bahwa fungsi *Ombudsman* adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat dan daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN, serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa fungsi antara lain berarti:

---

[2]AS Hornby, et. al., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English [Revised and Updated]*, (Walton Street: Oxford University Press, 1987), hlm. 585.

1) jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, 2) *faal* (kerja suatu bagian tubuh, 3) kegunaan suatu hal.[3]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa *Ombudsman* merupakan salah satu bagian tubuh (baca: organisasi), yang pekerjaannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di pusat dan daerah, dengan kegunaannya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4, yang merupakan tujuan pembentukan *Ombudsman,* yaitu: (a) mewujudkan negara hukum yang demokratis, (b) mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, (c) meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik, (d) membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, KKN, dan (e) meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Fungsi *Ombudsman* tersebut di atas dapat dijalankan melalui pelaksanaan tugas-tugasnya. Pasal 7 UU *Ombudsman* menyebutkan tugas *Ombudsman* yaitu: (a) menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, (b) melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, (c) menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan *Ombudsman*, (d) melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, (e) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, (f) membangun jaringan kerja, (g) melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan (h) melakukan tugas lain yang diberikan undang-undang.

Dalam Black Law Dictionary, maladministrasi diartikan dengan *poor management or regulation*. Dalam Kamus Ilmiah Populer, arti maladministrasi adalah administrasi yang buruk atau pemerintahan yang buruk. Soenaryati Hartono mengartikan maladministrasi dengan perilaku yang tidak wajar (termasuk penundaan pemberian pelayanan), kurang sopan dan tidak peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang disebabkan penggunaan kekuasaan secara semena-mena atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskriminatif, dan tidak patut didasarkan seluruhnya atau sebagian atas ketentuan undang-undang atau fakta tidak masuk akal, atau berdasarkan tindakan *unreasonable, unjust, oppresive*, dan diskriminatif.[4]

---

[3]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ketiga, hlm. 322.

[4]Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi,* (Yogyakarta; Laksbang Pressindo, 2008), cet. I, hlm. 112, mengutip (Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary,* Seventh Edition, West

Berdasarkan arti-pengertian Ombudsman di atas, menurut Sadjijono, maladministrasi adalah suatu tindakan atau perilaku administrasi oleh penyelenggara administrasi negara (pejabat pemerintahan) dalam proses pemberian pelayanan umum yang menyimpang dan bertentangan dengan kaidah atau norma hukum yang berlaku atau melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang atas tindakan tersebut menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat (atau berarti melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan administrasi).[5]

Selanjutnya Sadjijono mengatakan bahwa secara teoretis, maladministrasi dapat terjadi akibat adanya tindakan hukum pemerintah atau administrasi negara, yang dalam negara hukum setiap tindakan hukum pemerintah tersebut harus selalu didasarkan pada asas legalitas (*legaliteit beginsel)* atau perundang-undangan yang berlaku.[6]

Kategori maladministrasi, bahwa tindakan hukum dimaksud bertentangan dengan kaidah atau norma dalam menjalankan pemerintahan termasuk norma hukum sehingga menurut Soenaryati Hartono, tindakan atau perilaku maladministrasi bukan sekadar merupakan penyimpangan dari prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas pejabat atau aparat negara atau aparat penegak hukum, tetapi juga dapat merupakan perbuatan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad)*, *detournement de pouvoir* atau *detournement de procedure* yang sudah lama (sejak 1924) dikenal oleh hukum Indonesia.[7]

Menurut klasifikasi Crossman sebagaimana dikutip oleh Anton Sujata, tindakan-tindakan maladministrasi antara lain mencakup: a) berprasangka, b) kelalaian, c) kurang peduli, d) keterlambatan, e) bukan wewenangnya, f) tindakan tidak layak, g) jahat, h) kejam, dan i) semena-mena.[8]

Berdasarkan laporan *Public Commissioner for Administration (PCA)* pada 1993, tindakan-tindakan maladministrasi yang lain seperti: a) sikap kasar, b) keengganan memperlakukan pengadu sebagai insan yang memiliki hak, c) menolak memberi jawaban atas pertanyaan yang beralasan, d) melalaikan keharusan memberitahu pengadu akan hak-haknya, e) dengan sengaja memberi nasihat yang menyesatkan atau tidak lengkap, f) mengabaikan nasihat yang sah atau pertimbangan yang membatalkan yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak pada pihak yang memberikan nasihat atau pertimbangan tadi, g) menawarkan tidak ada pemulihan atau pemulihan yang tidak proporsional, h)

Group, ST Paul, 1999, p. 967), (Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 451), dan (Soenaryati Hartono, *Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia,* (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2003, hlm. 6).

[5]*Ibid*., hlm. 113.

[6]*Ibid.*

[7]*Ibid*., hlm. 114, (mengutip Soenaryati Hartono, *op. cit)*.

[8]*Ibid*, mengutip *Cabinet Office, "The Ombudsman in Your File rev 1987* dalam Anton Sujata, *Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang,* (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002, hlm. 20).

menunjukkan sikap prasangka atas alasan warna kulit, seks atau alasan lain, i) cacat prosedur, j) kegagalan manajemen dalam memantau kepatuhan melalui prosedur yang memadai, dan k) sikap memihak.[9]

Komisi Ombudsman Nasional juga memberi indikator bentuk-bentuk maladministrasi, antara lain: melakukan tindakan yang janggal, menyimpang, sewenang-wenang, melanggar ketentuan, penyalahgunaan wewenang, atau keterlambatan yang tidak perlu, dan pelanggaran kepatutan.[10]

Anton Sujata dan timnya—sebagaimana dikutip oleh Sadjijono—mengemukakan pula beberapa jenis maladministrasi dalam bukunya *Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang,* atas kutipan Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, antara lain: 1) pemalsuan/persekongkolan, 2) intervensi, 3) penanganan berlarut/tidak menangani, 4) inkompetensi, 5) penyalahgunaan wewenang/berlebihan, 6) nyata-nyata berpihak, 7) menerima imbalan (uang, hadiah, fasilitas/praktik KKN, 8) penggelapan barang bukti/penguasaan tanpa hak, 9) bertindak tidak layak, 10) melalaikan kewajiban, 11) dan lain-lain.[11]

Sadjijono mengatakan bahwa tindakan maladministrasi memiliki kaitan erat dengan sikap dan perilaku penyelenggara adminisrasi negara (pemerintahan) sebagai subjek hukum, yang secara teori pemerintah memiliki kedudukan khusus sebagai satu-satunya pihak yang diserahi kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan, menggunakan paksaan pemerintah, atau menerapkan sanksi-sanksi hukum, sehingga penyelenggaraan pemerintahan memiliki pengaruh yang sangat dominan.[12]

Apabila wewenang tersebut melekat suatu tanggung jawab, atau akuntabilitas kepada masyarakat, sehingga tindakan maladministrasi sebagai tindakan (yang) bertentangan dengan kehendak rakyat, maka tindakan maladministrasi sebagai tolok ukur moralitas suatu pemerintahan, yang mendapatkan penilaian baik apabila tidak terjadi maladministrasi, dan sebaliknya. Selain itu, tindakan maladministrasi bertentangan dengan konsep *good governance*, yang esensinya sebagai kaedah etika atau moral dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.[13]

Fungsi dan tugas *Ombudsman* tidak dapat dijalankan apabila lembaga tersebut tidak diberikan kewenangan. Oleh karena itu, undang-undang ini

---

[9]*Ibid.*, hlm. 115., mengutip Anton Sujata, *op. cit*.

[10]*Ibid,* mengutip Komisi Ombudsman Nasional dalam rangka Sosialisasi Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, dan lihat Anton Sujata, et. al., *Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang,* (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002), hlm. 35-36.

[11]*Ibid.*, dan hlm. 116, mengutip Anton Sujata, *Ibid.*

[12]*Ibid.*

[13]*Ibid.*, hlm. 117-118.

menyebutkan pula wewenang *Ombudsman* sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, yang berbunyi antara lain: (a) meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampailan kepada *Ombudsman,* (b) memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan, (c) meminta klarifikasi dan/atau saliman atau foto-kopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor, (d) melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan, (e) menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsultasi atas permintaan para pihak, (f) membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan, dan (g) demi kepentingan umum, mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, *Ombudsman* harus memerhatikan asas-asas: keadilan, kepatutan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan.

Asas-asas tersebut sejalan dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara, yaitu: 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Asas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas, dan 7) Asas Akuntabilitas.

Dalam konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau pejabat administrasi negara selalu disertai dengan tujuan dan maksud pemberian wewenang itu sehingga penerapannya harus sesuai dengan tujuan dan maksudnya. Apabila penggunaan wewenang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian wewenang, berarti telah terjadi penyalahgunaan wewenang.[14] Tujuan dan maksud pemberian wewenang merupakan parameter dalam menilai penerapan kewenangan penyelenggara negara yang tergolong penyalahgunaan wewenang. Parameter dengan tujuan dan maksud tersebut dikenal dengan asas spesialitas.[15] Tatiek Sri Djatmati menerjemahkan asas spesialitas dengan asas tujuan.[16] Dan asas ini telah diadopsi dalam Penjelasan Umum UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi "UU tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD tersebut ke dalam asas-asas, telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas.[17]

---

[14]Nur Basuki Minarno*, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,* (Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2009), cet. Ke-2, hlm. 80.

[15]Asas ini dikembangkan oleh Mariette Kobussen dalam bukunya *De Vrijheid Van De Overheid. (Ibid.)*

[16]*Ibid.*, hlm. 81.

[17]*Ibid.*, hlm. 80.

Untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan yang dilakukannya diperlukan dasar perundang-undangan yang memberikan wewenang kepadanya. Dasar tersebut dikenal dengan asas legalitas.[18] Dalam asas legalitas, kekhususan tujuan terhadap wewenang tertentu dalam penerbitan keputusan. Kekhususan pemberian dan tujuan pemberian wewenang dapat dilihat pada masing-masing peraturan perundang-undangan.[19]

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penulis berpendapat bahwa ruang gerak para penyelenggara negara pada berbagai lembaga tinggi negara semakin mendapatkan pengawasan dari berbagai lembaga atau komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang lahir sesudah reformasi.

Nur Basuki Minarno menyebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan tidaklah semata sebagai kekuasaan yang terikat, tetapi juga merupakan suatu kekuasaan bebas.[20] Indroharto menambahkan wewenang fakultatif, yaitu wewenang yang tidak mewajibkan badan atau pejabat tata usaha negara menerapkan wewenangnya, tetapi memberikan pilihan sekalipun hanya dalam hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.[21] Philipus M. Hadjon—sebagaimana dikutip oleh Nur Basuki Minarno—mengatakan bahwa kekuasaan bebas/kekuasaan diskresi meliputi: 1) kewenangan untuk memutus sendiri, 2) kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vagenormen)*.[22]

Menurut Ten Berge seperti dikutip Philipus M. Hadjon, kekuasaan bebas itu meliputi: 1) kebebasan kebijakan (dalam arti sempit) dan 2) kebebasan penilaian (dalam arti yang tidak sesungguhnya). *Yang pertama,* bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintah sedangkan organ tersebut bebas untuk tidak menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Sedangkan *yang kedua,* sebagai hak yang diberikan organ pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah terpenuhi.[23] Lalu, bagaimana mengukur tindakan yang menyalahi wewenang?

Indriyanto Seno Adji mengutip pendapat W. Konijnenbelt yang menyatakan bahwa pengukuran dimaksud dilakukan dengan parameter:

1. Unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan negara ini.

---

[18]*Ibid.*, hlm. 83.
[19]*Ibid.*, hlm. 84.
[20]*Ibid.*, hlm. 95.
[21]*Ibid.*, (mengutip Indroharto, *Usaha Memahami UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hlm. 99-101.
[22]*Ibid.*
[23]*Ibid.*

2. Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan ini diterapkan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun asas kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mencegah sifatnya.[24]

Dalam lapangan hukum administrasi, disebutkan pula oleh Indriyanto dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline, sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan berupa penyimpangan dari tujuan umum.
3. Penyalahgunaan kewenangan untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan prosedur lain.[25]

Sehubungan dengan uraian di atas dan untuk mencapai *good governance* di seluruh wilayah Indonesia, Ombudsman perlu dan harus segera mendirikan perwakilan Ombudsman di wilayah provinsi dan/atau kabupaten-kota di Indonesia, sebagaimana Pasal 43 UU Nomor 37 Tahun 2008 yang berbunyi "Apabila dipandang perlu, Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah provinsi atau kabupaten/kota (ayat 1), yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman, dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan (ayat 2), dengan dibantu oleh asisten Ombudsman (ayat 3), yang fungsi, tugas, dan wewenangnya secara *mutatis mutandis* berlaku pula bagi perwakilan Ombudsman (ayat 4).



Penutup

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari tulisan di atas adalah:

1. Seluruh Rakyat Indonesia – melalui anggotanya di MPR – telah bermusyawarah dan menetapkan TAP MPR Nomor: VIII/MPR/2001 tentang "Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN:", yang salah satunya adalah pembentukan UU Ombudsman.
2. *Ombudsman* adalah salah satu lembaga pengawasan eksternal, yang bertujuan menciptakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, adil, terbuka, dan bebas dari KKN.
3. Perwakilan Ombudsman dapat didirikan di setiap provinsi, dan/atau kabupaten/kota, dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya sama dengan Ombudsman.

---

[24] *Ibid*., hlm. 96.

[25] *Ibid*., hlm. 97. Poin ketiga di atas – menurut Nur Basuki Minarno – merupakan pencampuradukan antara penyalahgunaan wewenang dan cacat prosedur.

4. Tujuan akhir pembentukan *Ombudsman* merupakan bagian dari tujuan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, seluruh lembaga tinggi negara harus bersama-sama dengan *Ombudsman* mencapai tujuan akhir negara Republik Indonesia.

Daftar Referensi

AS Hornby, et. al. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English [Revised and Updated]*. Walton Street: Oxford University Press, 1987.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet. Ketiga.

Nur Basuki Minarno. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2009, cet. ke-2.

Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008.

TAP MPR Nomor: VIII/MPR/2001.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000.

27

VISI BESAR TANPA TRANSFORMASI BIROKRASI

Oleh:
Dr. Ir. Sudarsono Harjosoekarto, M.A., S.H.[*]

DI TENGAH SEMARAK kampanye pasangan capres-cawapres 2009, tidak banyak kalangan yang mengupas perihal transformasi birokrasi secara komprehensif. Sejauhmanakah visi, misi dan program di antara para kandidat? Apakah transformasi birokrasi tidak mendesak, dan kalaupun mendesak, tetapi tidak prioritas? Apakah para kandidat percaya bahwa visi dan misi besar yang dikampanyekan sebagai pasangan capres-cawapres ini, kelak akan sukses diimplemetasi tanpa birokrasi yang sehat? Dengan kata lain, apakah kita semua beranggapan bahwa tanpa penyempurnaan, pembenahan dan transformasi birokrasi, visi dan misi besar para kanditat dapat diwujudkan dengan optimal? Apakah dukungan jajaran birokrat dan birokrasi sudah ditempatkan sebagai *taken for granted,* siapapun pasangan terpilih, tanpa ada antisipasi atas kendala resistensi birokratik?



What Vision Does bukan *What Vision Is*

Pasal 59 ayat (5) huruf k UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa: "Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis." Ini adalah kewajiban konstitusional para pasangan calon, sekaligus juga kewajiban konstitusional kepala daerah dan wakilnya bila kelak terpilih dalam pilkada.

Khazanah penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini tentu sudah memiliki cukup banyak dokumen visi, misi dan program kepala daerah dan wakilnya, yakni sebanyak pelaksanaan pilkada berdasarkan UU No. 32 Tahun

[*]Dosen FISIP UI, pernah menjadi Dirjen PUMDA Depdagri, Dirjen Otda Depdagri, Kepala Badan Diklat Depdagri dan Dirjen Kesbangpol Depdagri.

2004 sejak pertengahan tahun 2005. Pertanyaannya adalah apakah visi misi dan program tersebut telah menjadi pedoman dan diikuti dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di setiap daerah? Apakah visi, misi, dan program ini telah menjadi norma yang berfungsi sebagai alat koordinasi organisasional (*organizational coordination through standardization of norms*) segenap jajaran pemerintahan daerah. Apakah kepala daerah dan wakilnya, DPRD, jajaran satuan kerja perangkat daerah, partai politik, dunia usaha, ormas, dan LSM serta segenap lapisan masyarakat setempat telah memahami, mengikuti, dan menjadikan visi, misi, dan program sebagai daya hidup dalam berpemerintahan daerah.

Dokumen terkait dengan Pasal 59 ayat (5) huruf k UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut bukan hanya sekadar dokumen yang bernilai administratif saja. Bahwa benar tanpa dokumen ini, pencalon bakal pasangan kepala daerah tidak dapat diproses. Tetapi jauh lebih ideal dari sekadar dokumen administratif, visi, misi, dan program adalah norma panduan gerak langkah seluruh warga pemerintahan daerah. Yang penting justru adalah *what vision does*, bukan sekadar *what vision is*.

Bagi kepala daerah dan wakilnya, implementasi visi, misi dan program adalah kewajiban pemenuhan janji konstitusional. Tujuan akhir pemenuhan janji konstitusional ini adalah terwujudnya Pasal 2 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Kewajiban kepala daerah adalah menjadikan visi dan misi tersebut sebagai *norms* yang menjadi tenaga penggerak seluruh aksi dan kreasi warganya. Termasuk komponen yang sangat penting yang harus digerakkan dan bergerak efektif tidak lain adalah jajaran birokrasi daerah.



Visi Besar 2009: Dengan atau Tanpa Transformasi Birokrasi?

Sama halnya calon kepala daerah dan wakilnya, capres dan cawapres juga punya kewajiban konstitusional serupa. Pasal 15 huruf e UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menegaskan bahwa: "Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon ke KPU wajib menyerahkan naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon", sama juga dengan kepala daerah, pasangan capres dan cawapres akan berpotensi menghadapi jebakan konstitusional, yakni terpaku pada *what vision is* bukan berkonsentrasi pada suksesnya *what vision does*. Sama halnya kepala daerah, presiden dan wakil presiden terpilih kelak harus menggerakkan seluruh warga bangsa untuk menjadikan visi dan misi sebagai *norms* yang menjadi daya hidup dari aksi dan kreasi segenap warga negara.

Pertanyaannya adalah sejauhmana relevansi visi, misi dan strategi transformasi birokrasi menjadi bagian penting dari visi besar pasangan capres dan cawapres? *Pertama*, birokrasi dan birokrat telah lama tumbuh dalam kultur, struktur dan prosedur sendiri sepanjang pasca kemerdekaan bahkan jauh sebelum kemerdekaan 1945. Kultur, struktur dan prosedur ini pada bagian tertentu sudah dapat ditransformasi secara bertahap dalam kurun waktu reformasi nasional. Tetapi harus diakui bahwa sebagian besar dari kultur. struktur dan prosedur ini belum banyak disentuh secara maksimal oleh proses reformasi yang sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun.

Kedua, bila visi besar pasangan capres dan cawapres tidak secara cerdas menyusun strategi transformasi birokrasi, tidak mustahil jebakan konstitusional *what vision is* akan menjadi gejala umum di tingkat nasional dan daerah. Kalaupun tidak akan menghadapi resistensi birokratik secara terang-terangan, jebakan konstitusional ini dapat berupa mewabahnya ketidakberdayaan belajar (*learning disability*) di jajaran birokrasi. Peter Senge (2006) mengingatkan gejala nyata *learning disability* yang dihadapi oleh organisasi apa pun termasuk organisasi publik.

Dengan demikian, masuknya strategi transformasi birokrasi secara nasional ke dalam visi dan misi pasangan capres dan cawapres menjadi sangat penting dan bahkan suatu keharusan. Di satu sisi, ini adalah pekerjaan rumah dari reformasi yang belum selesai. Di sisi lain melalui transformasi birokrasi akan dapat dibangun birokrasi yang layak dan patut (*fit and proper*) dengan kebutuhan implementasi visi besar pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.



Pegawai Negeri Profesional dan Bertanggung Jawab

Secara ideal sosok birokrasi publik telah ditetapkan dalam konsideran menimbang UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. "Bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa untuk maksud tersebut diperlukan pegawai negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab yang dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme."

Pasal 12 ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999 menegaskan bahwa: "Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan diperlukan

pegawai negeri sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Sementara itu, norma pembinaan karier pegawai negeri dalam lingkup pemerintahan daerah ditegaskan dalam Pasal 133 UU No. 32 Tahun 2004: "Pengembangan karier pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antardaerah dan kompetensi."

Pegawai negeri yang profesional dan bertanggung jawab sesungguhnya ialah pegawai negeri yang bekerja secara akuntabel dalam koridor ruang *vision and mission driven* dengan *rule driven*. Bila terjadi distorsi di antara kedua koridor ini seharusnya dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian kedua koridor tersebut secara cepat, tepat, dan transparan.

Sayang sekali yang terjadi saat ini adalah kekakuan yang luar biasa dalam segenap sendi kehidupan birokrasi. Operasionalisasi pasal-pasal ideal dalam UU No. 43 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 terkendala bukan hanya oleh kultur birokrasi saja, tetapi justru oleh norma-norma yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sistem prestasi kerja yang nyata-nyata dititikberatkan dalam pembinaan pegawai negeri sipil dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999 sama sekali tidak berdaya menghadapi kekakuan sistem karier yang juga diatur dalam undang-undang yang sama.



Birokrat Ganjil: Prof. Dr. I Gede Winasa dan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Kontradiksi konstruksi normatif dalam peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian tersebut, selain menimbulkan kekakuan birokrasi juga memunculkan kekalutan masyarakat termasuk di kalangan birokrasi sendiri. Yang menarik adalah di tengah situasi seperti ini, kita dihadapkan pada keberadaan dua orang birokrat ganjil, yang fenomal. Pertama Prof. Dr. I Gede Winasa, birokrat fungsional dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Surabaya yang menjadi Bupati Jembrana, Provinsi Bali, dan kedua, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. seorang birokrat fungsional yang menduduki jabatan struktural di Departemen Dalam Negeri.

Penelitian Rozan Anwar (2009) dalam rangka disertasi program doktor administrasi publik Universitas Indonesia menjelaskan sangat lengkap kepemimpinan Prof. Dr. I Gede Winasa dalam menjadikan visi "Terwujudnya masyarakat Jembrana yang sejahtera, berkeadilan dan berbudaya" bukan sekadar *what vision is* tetapi *what vision does*. Secara khusus Rozan Anwar mencatat bahwa *dynamic capabilities* dalam kebijakan pelayanan pendidikan di kabupaten Jembrana disumbang oleh antara lain kepemimpinan Winasa yang menegaskan

secara konsisten "menjamin masyarakat berpeluang sama dalam menempati jabatan publik". Hal ini tentu merupakan praktik birokrasi dan kepala daerah yang cerdas (*thinking again*), yang tidak mudah dijumpai di daerah lain.

Sementara ini Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., awalnya adalah birokrat fungsional pada Badan Diklat Departemen Dalam Negeri. Sejalan dengan semangat pengembangan kompetensi fungsional inilah, maka staf muda Zudan Arif Fakrulloh mengembangkan diri secara luar biasa cepat dan cerdas. Hasilnya jenjang jabatan fungsional guru besar diperoleh pada saat golongan kepangkatannya baru mencapai Penata golongan IIIC.

Persoalan teknis dan yuridis kemudian muncul manakala lembaga memerlukan tenaga yang berkompeten untuk ditempatkan pada jabatan struktural. Pasal 17 ayat (2) UU No. 43 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menegaskan bahwa: "Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan". Sebagai atasan langsung pada 2002 sampai dengan 2005, penulis sangat memahami kondisi objektif profesionalisme Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh S.H., M.H., dikaitkan dengan pengertian profesionalisme Pasal 17 UU 43 tersebut. Tetapi kontradiksi konstruksi normatif yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian dan terlebih lagi semangat implementasinya yang kaku yang secara meluas terjadi di banyak tempat, maka ternyata tidak mudah memobilisasi profesionalisme Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., secara tepat dan proporsional.



Pilar NKRI dan Negara-Bangsa Indonesia *Incorporated*

Mengingat bahwa kendala transformasi birokrasi justru antara lain terdapat dalam UU, maka transformasi birokrasi harus dimulai dari visi dan misi besar pasangan capres dan cawapres. Melalui visi dan misi ini kelak strategi transformasi birokrasi dapat dilandasi dengan UU Kepegawaian yang disempurnakan.

Penyempurnaan UU Kepegawaian harus diarahkan untuk menjadikan landasan yang kokoh bagi pegawai negeri yang visioner, sejalan dengan terpilihnya pemimpin visioner di berbagai lapisan susunan pemerintahan. Yakni, pegawai negeri yang senantiasa mau dan mampu belajar, berubah, berdialog dan memperlakukan kompleksitas masyarakat yang serba sistem dalam koridor *vison-driven* dan *rule-driven* secara transparan dan akuntabel.

Sistem besar yang harus dibangun adalah bahwa pegawai negeri di manapun berada harus menjadi pilar tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, mutasi antardaerah harus disusun dan dilembagakan sebagai

insentif utama dalam pengembangan karier pegawai negeri sipil di pusat dan daerah.

Sejalan dengan kebutuhan ini, maka pengayaan sistem mutasi sebagai bagian dari sistem pengembangan karier dan prestasi kerja harus dirancang secara komprehensif antara lain meliputi mutasi antardaerah, mutasi antardepartemen dan lembaga pemerintah, mutasi antara departemen dengan pemerintah daerah, mutasi antara lembaga pemerintah dan lembaga eksekutif independen, mutasi antarjenis jabatan, dan bahkan mutasi terbatas untuk jabatan-jabatan tertentu antara lembaga pemerintah, pemerintah daerah, lembaga eksekutif independen dengan dunia usaha. Dengan demikian, selain sebagai pilar tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pegawai negeri sipil akan dapat menjadi salah satu pilar kokohnya negara bangsa Indonesia *incorporated*, yang akan berkiprah dalam persaingan global yang sangat turbulen. Tentu saja masih banyak tema lain yang harus dirumuskan dalam rangka penyempurnaan UU Kepegawaian sebagai landasan utama transformasi birokrasi masa kini dan masa depan Indonesia.

Daftar Referensi

Anwar Rozan. "Pengembangan Model tentang Pengaruh Able People dan Agile Process terhadap Dynamic Capabilities dalam Proses Kebijakan Publik (Studi Kasus Pelayanan Bidang Pendidikan di Kabupaten Jembrana), Provinsi Bali", disertasi program doktor Administrasi Publik, Universitas Indonesia, 2009.

Senge, Peter M. *The Fifth Discipline.. The Art and Practice of The Learning Organization*. New York: Currency Doubledays, 2006.

28

HUBUNGAN PUSAT–DAERAH DAN KONSTELASI DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh:
Prof. Dr. Aminudin Ilmar, S.H., M.H.

Pendahuluan

GELOMBANG REFORMASI tahun 1998 telah menuntun terjadinya eskalasi perubahan pada tataran penyelenggaraan pemerintahan yakni, berubahnya pola pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya terjadi pada aras pemerintahan pusat saja melalui penerapan mekanisme *"chek and balances",* akan tetapi juga pada aras pemerintahan daerah melalui penerapan otonomi daerah. Perubahan tersebut menyangkut cara pandang dan paradigma yang dipergunakan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance and good government)*.

Perubahan yang berlangsung secara dramatis tanpa disertai agenda yang jelas dan runtut memberikan ruang yang kosong pada pengisian format penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan arah yang hendak dituju yakni, menuju pada tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis berdasar pada tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN, desentralisasi kekuasaan, dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Dalam kenyataan meskipun hal itu dilakukan, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan, malahan menimbulkan efek samping seperti masih menguatnya sentimen kedaerahan, ketidakpuasan terhadap berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah, masih merebaknya KKN, masih menguatnya sentralisasi kekuasaan dan penegakan hukum yang masih ambigu.

Selama pemerintahan reformasi berlangsung tampaknya arah penyelenggaraan pemerintahan mengalami demosi bukan hanya pada tataran kebijakan saja, akan tetapi juga pada tataran implementasi hubungan antara pusat dan daerah. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa kita sudah bersepakat untuk melakukan perubahan tatanan penyelenggaraan pemerintahan untuk tingkat pusat dengan patokan pada perimbangan kekuasaan negara, di mana

antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif tercipta hubungan yang saling mengawasi dan mengendalikan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Namun, dalam praktiknya tidaklah demikian. Meskipun menggunakan konsep pemisahan kekuasaan yang bertumpu kepada mekanisme *"chek and balances"*, namun sangatlah sukar untuk melakukan perubahan secara mendasar pada tataran implementasi. Barangkali dari sudut pandang teori bisa dilakukan dengan mencoba menempatkan kedaulatan ada pada rakyat melalui konsep pemilihan langsung baik legislatif maupun eksekutif sehingga menjadikan kedua lembaga tersebut lebih aspiratif dan akuntabel.

Dengan menempatkan kedudukan kedua lembaga pada posisi yang seperti itu, tentu saja membutuhkan peran yang lebih penting dan didasarkan pada fungsi-fungsi yang harus diemban yakni, bukan hanya pada pemenuhan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeter semata, tetapi juga pada sinergitas kewenangan masing-masing lembaga negara. Idealisasi dari fungsi-fungsi tersebut adalah terciptanya proses penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, partisipatif dan transparan jauh dari bias penyelenggaraan yang berbau kolutif, menguntungkan sekelompok orang dan bahkan mengabaikan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks yang lebih khusus terjadi ketidakserasian dalam penjabaran hubungan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga diperlukan sinergitas hubungan kewenangan antartingkat pemerintahan masing-masing lembaga sehingga dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat. Upaya untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai kehendak dan aspirasi masyarakat dengan dibarengi tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance* dan *good government)* dapat diwujudkan jikalau sinergitas hubungan kewenangan dapat dilakukan dengan baik melalui perimbangan kekuasaan secara memadai. Dalam arti, bahwa dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing tingkat pemerintahan sehingga akan menciptakan akuntabilitas pada masing-masing ranah tingkat pemerintahan dan memberi legitimasi pada pemerintah untuk melakukan yang terbaik pada masyarakatnya. Bukan masing-masing tingkat pemerintahan saling mengedepankan kewenangan yang dimiliki dan menafikan keserasian tatanan hubungan di antara mereka.

Hubungan yang harmonis antara masing-masing tingkat pemerintahan atau antara pusat dan daerah akan mengarahkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan secara lebih baik. Selama ini mekanisme hubungan yang terbangun melalui pengaturan yang dilakukan masih menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan sehingga membawa akibat pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Hubungan kewenangan yang sinergis antara pusat daerah akan memberi daya dorong pada masing-masing tingkatan pemerintahan untuk melakukan yang terbaik bagi kepentingan rakyat. Dengan kata lain,

pelaksanaan kewenangan masing-masing ranah tingkatan pemerintahan akan sangat menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan benar. Tidak lagi tercipta dominasi kekuasaan yang tanpa kontrol seperti pada masa rezim yang lalu. Akuntabilitas pemerintahan dapat terjaga sesuai dengan pola hubungan yang setara (sejajar), berimbang dan saling melengkapi.



Kedudukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Paradigma baru dalam berpemerintahan telah ditetapkan dalam aturan normatif baik dalam perubahan UUD 1945 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedudukan pemerintah dan pemerintah daerah sangatlah penting dalam mewujudkan mekanisme *"chek and balances"* seperti, fungsi pelayanan publik, pengawasan dan penegakan hukum. Masing-masing fungsi tersebut mempunyai implikasi dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah. Berkaitan dengan kedudukan pemerintah telah diatur bahwa pemerintah mempunyai kewenangan mutlak dan kewenangan yang bisa dibagi bersama antara pemerintah dengan pemerintahan daerah. Sedangkan kedudukan pemerintahan daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah kepada pemerintahan daerah atau urusan pemerintahan yang bersifat asli.

Pelaksanaan atau penyelenggaraan wewenang masing-masing tingkatan pemerintahan seharusnya tidak menjadi hambatan atau kendala bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dan pemerintahan daerah. Namun, dalam praktiknya hal tersebut tidaklah mudah untuk diselenggarakan atau diimplementasikan sehingga dibutuhkan adanya penataan hubungan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan dalam bentuk pengaturan hubungan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah. Dengan penataan hubungan kewenangan baik hubungan kewenangan secara kelembagaan (institusional) tidak lain dimaksudkan untuk mempertegas kedudukan masing-masing lembaga atau instansi baik vertikal maupun daerah otonom. Dengan kewenangan pada masing-masing lembaga tentu saja diharapkan dapat bersinergi dengan kewenangan lembaga atau instansi lain sehingga pelaksanaan pengambilan kebijakan publik khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik melalui peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan gubernur/bupati/walikota, penyusunan APBD, pelaksanaan kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat dilakukan secara baik dan memadai.

Penataan hubungan kewenangan secara kelembagaan (institusional) selama ini lebih banyak mengandalkan pada peran aktif masing-masing kelembagaan baik untuk tingkat pemerintah maupun pemerintahan daerah. Dalam arti, bahwa masing-masing lembaga atau instansi baik vertikal maupun daerah otonom dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dilakukan secara melembaga

melalui mekanisme koordinasi dan supervisi berdasar pada kewenangan yang dimiliki. Masing-masing instansi baik vertikal maupun daerah otonom tidak hanya dapat bertumpu pada wewenang yang dimilikinya, akan tetapi juga harus dapat bertindak atau berbuat sesuai dengan beban tugas dan fungsi yang diemban. Dari segi pelaksanaan akan lebih mudah dilaksanakan dibandingkan kalau hanya dengan mengandalkan pada kewenangan mandiri.

Selain itu, penataan kewenangan secara kelembagaan akan memberi ruang yang lebih bebas dalam pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing lembaga atau instansi. Dalam arti, akan terdapat kejelasan wewenang atau tugas dan fungsi masing-masing lembaga sehingga tidak saling tumpang tindih atau bahkan saling mengeliminasi fungsi dan tugas masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergitas kewenangan dalam arti bahwa kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga atau instansi tidak lain dimaksudkan untuk menciptakan sebuah tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Melalui sinergitas kewenangan masing-masing lembaga atau instansi baik vertikal maupun daerah otonom tentunya akan berimplikasi pada tatanan penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan di daerah. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai koridor hukum saja, akan tetapi dapat dilakukan secara lebih leluasa tanpa adanya ketakutan akan pelanggaran hukum sehingga dapat mengganggu kinerja pemerintah daerah. Proses penegakan hukum yang dilakukan baik oleh kepolisian maupun kejaksaan dalam hal terjadi indikasi korupsi tidak perlu dijadikan sebagai momok atau ketakutan bagi pemerintah daerah sehingga kreativitas dan inovasi menjadi hilang. Justru proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian maupun oleh kejaksaan semata-mata untuk mengarahkan agar tatanan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan arah yang ingin dicapai yakni, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, tanpa meninggalkan substansi yang ingin dicapai dalam penegakan hukum semestinya juga pihak kepolisian dan kejaksaan tidak lantas mencari-cari kesalahan dan menjadikannya sebagai sarana pemerasan baru.



Penyalahgunaan Wewenang

Dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga atau instansi baik vertikal maupun daerah otonom tentu saja diharapkan mampu memainkan tugas dan fungsinya secara optimal sebagai institusi pengemban amanat dan atau aspirasi kepentingan rakyat, sehingga dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak tujuan yang hendak dicapai, terwujudnya pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, dan akuntabel serta transparan jauh dari praktik KKN. Tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau instansi baik

vertikal maupun daerah otonom sebagai penyelenggara pemerintahan, haruslah dibedakan secara jelas. Dalam arti, tugas dan fungsi yang dilakukannya berada dalam tataran penyelenggara layanan publik dan pengawasan serta penegakan hukum. Dari segi koordinasi, tugas dan fungsi yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan daerah lainnya berada dalam tatanan dimensi administratif. Hal ini berarti bahwa, tugas dan fungsi lembaga atau instansi baik vertikal maupun daerah otonom lebih menekankan pada segi hubungan antara penyelenggara layanan publik di satu sisi dengan pengawasan dan penegakan hukum pada sisi yang lainnya. Dengan kata lain, terdapat kewajiban bagi lembaga atau instansi untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan dasar wewenang yang dimilikinya.

Selain itu, tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau instansi vertikal maupun daerah otonom adalah bagaimana menyerasikan masing-masing kewenangan yang dimiliki sehingga dapat saling bersinergi dalam artian positif. Dalam hal ini saling memberi daya dorong dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyalahgunaan kewenangan terjadi pada lembaga atau instansi vertikal maupun daerah otonom manakala tidak berkesesuaian dengan pemberian wewenang pada instansi tersebut. Dengan kata lain, penggunaan wewenang tidak sesuai dengan tujuan dasar diberikannya wewenang tersebut pada instansi atau lembaga baik vertikal maupun daerah otonom.

Untuk mengukur sejauhmana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh masing-masing lembaga atau instansi baik vertikal maupun daerah otonom dapat dilihat dalam peraturan dasar wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga atau instansi vertikal atau daerah otonom. Selain itu, mestinya diatur pula dalam sebuah peraturan yang mengatur tentang tata cara atau prosedur pemerintahan sehingga akuntabilitas masing-masing lembaga atau instansi baik vertikal maupun daerah otonom dapat terjaga sesuai dengan standardisasi prosedur pemerintahan yang ditetapkan untuk itu. Standar penyelenggaraan pemerintahan yang dibuat harus menjadi tolok ukur penilaian efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dalam proses penegakan hukumnya bilamana terjadi penyimpangan akan dapat dibedakan secara jelas dan tegas, apakah masuk dalam kriteria pelanggaran administrasi atau tindak pidana korupsi. Beberapa persoalan dasar yang dapat diajukan dan patut mendapat perhatian serius dari semua elemen perangkat pemerintahan yakni, sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan apakah benar-benar telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Apakah penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan kepentingan masyarakat? Apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak merugikan kepentingan masyarakat? Apakah dengan melakukan utang kepada negara donor lebih banyak memberikan manfaat ataukah sebaliknya?

Sebaliknya, dapat pula dipertanyakan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan penegakan hukum telah dilakukan sesuai dengan pro-

sedur dan mekanisme yang telah ditetapkan untuk itu? Apakah tindakan atau perbuatan pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan tidak justru menghambat dan bahkan kontra produktif serta mematikan kreativitas dan inovasi pemerintah daerah? Jika ternyata dari hasil penelaahan yang dilakukan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang oleh lembaga atau instansi baik vertikal maupun daerah otonom, maka tentunya diperlukan adanya mekanisme kontrol yang dapat mengarahkan lembaga atau instansi tersebut berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal pemerintah dan/atau pemerintah daerah melampaui atau telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan dan benar-benar telah merugikan kepentingan masyarakat banyak. Dengan kata lain, jika hal itu berkategori pelanggaran terhadap hukum, tentunya sesuai dengan prosedur pihak penegak hukum dapat menindaklanjutinya dengan meminta pertanggungjawaban pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Demikian pula, jika lembaga pengawasan dan penegak hukum melakukan penyalahgunaan wewenang atau berbuat sewenang-wenang dengan bertindak di luar dari wewenang yang dimilikinya atau tindakannya mengada-ada, maka sesuai dengan mekanisme prosedur yang ada dapat pula diminta pertanggung-jawabannya melalui komisi kepolisian untuk polisi dan komisi kejaksaan untuk jaksa penuntut. Sehingga tidak perlu menjadi beban dan persoalan dalam pelaksanaan wewenang masing-masing lembaga atau instansi baik vertikal maupun daerah otonom. Mekanisme perimbangan kekuasaan dapat pula diciptakan di tingkat pemerintahan daerah asalkan masing-masing lembaga atau instansi dapat bertindak secara profesional sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Satu hal barangkali yang perlu diperhatikan dan dicermati bahwa tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau instansi baik vertikal maupun daerah otonom adalah, tidak boleh melakukan dan atau menyelenggarakan kewenangan di luar dari bidang tugas dan fungsinya sehingga dapat selalu terjaga dan terkontrol. Penyelenggaraan wewenang yang melampaui batas akan menimbulkan akibat penyimpangan sehingga berimplikasi kepada tata penyelenggaraan pemerintahan yang tidak akuntabel, transparan, partisipatif, dan berdasar hukum.

Adanya penegasan tugas dan fungsi pada masing-masing lembaga atau instansi sebagaimana dikemukakan di atas, sangatlah diperlukan untuk mengantisipasi banyaknya kekeliruan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga atau instansi dalam melakukan tugas dan fungsinya. Terjadinya kekeliruan dan atau kesengajaan dalam melakukan tugas dan fungsinya sering kali menimbulkan ketegangan hubungan antara masing-masing lembaga atau instansi. Kelemahan memetakan kewenangan pada masing-masing lembaga atau instansi dapat menimbulkan distorsi dalam penyelenggaraan kewenangan.

Selain itu, lemahnya komitmen dan rendahnya integritas moral sumber daya pelaksana barangkali dapat membantu menjelaskan mengapa tatanan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik belum mewujud secara memadai. Dalam arti, pelayanan publik akan menjadi lebih baik dan meningkat, pengawasan dapat menekan tingkat pelanggaran yang terjadi serta penegakan hukum dapat melakukan penindakan secara tidak diskriminatif dan membuka peluang untuk terjadinya pemerasan. Oleh karena itu, tidak hanya dibutuhkan pemahaman yang lebih baik dan memadai dalam penyelenggaraan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga atau instansi baik vertikal maupun daerah otonom, akan tetapi juga memerlukan komitmen dan integritas sumber daya manusia untuk menjalankannya secara konsisten, jujur, dan terbuka.



Penutup

Apa yang dapat dikemukakan dan tersimpul dari uraian singkat tersebut di atas, hanyalah memberikan gambaran pokok tentang perlunya sinergitas kewenangan antarlembaga atau instansi vertikal maupun daerah otonom guna mendorong terciptanya tatanan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance and good government)*. Dengan kata lain, bagaimana menempatkan wewenang masing-masing lembaga atau instansi sebagai salah satu parameter dalam membangun akuntabilitas pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai perangkat pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda.

Konsekuensi dari sinergitas kewenangan tersebut akan berimplikasi pada hubungan yang harmonis dan koordinatif tanpa menafikan penegakan hukum di dalamnya. Adanya kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga atau instansi baik vertikal maupun daerah otonom tersebut melahirkan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk dapat saling memberi daya dorong pada penciptaan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selain itu, dibutuhkan pula standardisasi prosedur pemerintahan sebagai tolok ukur penyelenggaraan kewenangan masing-masing lembaga atau instansi agar dalam pelaksanaannya lebih efisien dan efektif baik dari sisi penyelenggaraan maupun dari pencapaian hasil. Mencermati kinerja penyelenggaraan tatanan pemerintahan tentunya memerlukan evaluasi hasil melalui mekanisme pelaporan baku bukan hanya dalam bentuk LAKIP masing-masing instansi baik vertikal maupun daerah otonom, akan tetapi yang terpenting melalui penataan kewenangan secara kelembagaan. Dengan kata lain, tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang baik dari segenap sumber daya pelaksana, tetapi juga pada integritas dan komitmen yang tegas dan jelas.

Daftar Referensi

Abdul Gaffar Karim, et al. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Bambang Yudoyono. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan, 2003.

Dennis Rondinelli, et al. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. California: Sage Publication, 1988.

P. de Haan, et al. *Bestuursecht in de Sociale Rechsstaat*. Kluwer-Deventer, 1986 P.P Craig, *Administrative Law*. London & Maxwell: 1994.

Rust Booney. *The Pattern of Government*. London: Pitman Paper books, 1989.

Ryaas Rasyid, et al. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

RAJAWALI PERS

29

PROBLEMATIKA POLITIK HUBUNGAN PUSAT–DAERAH DALAM SISTEM DESENTRALISASI DI INDONESIA*

Oleh:
*Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.***

Pendahuluan

PASCAPERANG DINGIN telah mendorong proses demokrasi hampir di seluruh bagian di dunia. Pemahaman demokrasi berkembang menurut berbagai sudut pandang di antaranya: 1) demokrasi adalah kebebasan dan otonomi (menurut Rosseau dan Immanuel Kant); demokrasi adalah kesetaraan (menurut Jhon Locke, Rosseau dan Bernard William); 3) demokrasi adalah prinsip keterwakilan (Edmund Burk, Robert Dhala dan Giovanni Sartyori); dan 4) demokrasi adalah partisipasi masyarakat atau *citizenship* (menurut Aristotles dan Robert Dhal). (BLAUG dan Schwarzmantel, 1998). Demokratisasi berkembang di berbagai negara dan agenda reformasi berlangsung di banyak negara seperti Eropa Timur (Hungaria, Polandia, dan lain-lain) juga negara-negara Amerika Latin (Brazilia, dan lain-lain). Demikian pula di Indonesia.

Demokratisasi di Indonesia sejak reformasi 1998 dicirikan oleh kebebasan berserikat dan berpendapat dan agenda otonomi daerah. Dalam perkembangannya otonomi daerah di Indonesia berlangsung secara dahsyat dan dunia internasional menyebutnya sebagai *big bang-decentralization*. (World Bank,2003). Agenda desentralisasi yang dilaksanakan dalam bentuk otonomi daerah tersebut mendapatkan dukungan penuh secara politis dan berkembang dengan berbagai ekses, antara lain dicirikan dengan berkembangnya daerah-daerah secara beragam, indikasi etnonasionalisme dan gejala pemilahan sosial sampai indikasi separatisme. Ekses dari implementasi otonomi daerah

*Makalah disusun sebagai kado ulang tahun Prof. Zudan Arif Fakrulloh: Selamat Ulang Tahun Yang ke-40 untuk mas Zudan "LIFE BEGIN AT FOURTY" WITH BEST WISHES.

**Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

dimaksud di antaranya telah sampai pada kondisi yang mengkhawatirkan, tidak saja mengkhawatirkan atas gejala separatisme dan pemilahan sosial, tetapi secara sistemik akan menyulitkan keberadaan NKRI. Fenomena yang harus diwaspadai atas berbagai persoalan dan ekses tersebut dapat dirangkum dalam satu perspektif persoalan yaitu ketimpangan dalam hubungan pusat daerah.

Pengertian tentang hubungan pusat daerah dirangkum dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu wujud penyelenggaraan kewenangan atau urusan (Pasal 10), pemberian sumber-sumber dan alokasi dana (Pasal 15), penyelenggaraan pelayanan umum dan kerja sama daerah untuk pelayanan umum (Pasal 16) serta pemanfaatan sumber daya alam dan penyerasian lingkungan dan tata ruang (Pasal 17). Untuk itu menjadi sangat penting untuk menjaga interaksi hubungan pusat daerah yang harus berlangsung secara sinergis. Sinergisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), adalah kegiatan yang tergabung, biasanya pengaruhnya lebih besar daripada jumlah total pengaruh masing-masing atau satu per satu.

Arus globalisasi yang secara deras masuk ke Indonesia dan telah diidentifikasi sejak awal 1990-an telah memperlihatkan pengaruhnya, dengan lahirnya reformasi 1998. Keterbukaan dan arus informasi telah memberikan ruang yang luas kepada seluruh wilayah daerah di Indonesia untuk saling berinteraksi dengan luar negeri secara langsung yang tidak dapat dihindari. Proses desentralisasi dan otonomi daerah yaang berlangsung, telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip desentralisasi dengan otonomi yang luas.

Dalam implementasinya sejak 1 Januari 2001, telah terjadi berbagai ekses di daerah-daerah dan gejala yang paling nyata ialah gejala ethnonasionalisme, mengemukanya isue lokal yang diangkat secara internasional dan indikasi melemahkan nasionalisme. Gejala yang muncul juga ialah ego daerah, gejala pemilahan sosial, tidak memerlukan pemerintah pusat atau indikasi pembangkangan sampai pada gejala separatisme. Otonomi daerah secara nyata telah memberikan indikasi kedaerahan yang sangat kuat dan berbagai gejala primordialisme yang sangat kentara terutama dalam agenda-agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Konsensus politik bangsa untuk pelaksanaan desentralisasi seharusnya didasari pada ciri dasar ketika negara ini didirikan, yaitu bahwa politik kekuasaan Indonesia merupakan kombinasi antara ketokohan elit dan kedaerahan. Perdebatan itu cukup panjang sebagaimana terungkap dalam dialog Muhamad Yamin dan Hatta saat sidang-sidang BPUPKI. Di sisi lain pengalaman dan perjalanan kebangsaan Indonesia hingga mencapai proklamasi merupakan perjalanan panjang sejak 1908 bahkan sebelumnya sehingga bangsa Indonesia sangat jelas terbentuk dari akumulasi perjuangan panjang dan Indonesia terbentuk berdasarkan pengalaman dan jiwa, bukan berdasarkan etnis, agama, bahasa

dan ras. (Otto Buer dan Renan). Adalah penting untuk penyelenggaraan negara tetap berpegang pada prinsip ketika negara ini dibentuk, semangat dan jiwanya yang merefleksikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Menjadi sangat penting untuk senantiasa menjaga prinsip-prinsip dasar saat pembentukan Indonesia sebagai negara sebagaimana disiapkan oleh BPUPKI. Hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah itu harus senantiasa diwaspadai, karena baik pelaksanaan maupun eksesnya telah memberikan indikasi ancaman dan hambatan bagi pembangunan dan mengganggu Ketahanan Nasional. Prinsip Wawasan Nusantara paling terasa sangat terganggu dan harus senantiasa diwaspadai. Salah satu instrumen menjaga Kewaspadaan Nasional tersebut ialah dengan senantiasa memelihara hubungan pusat-daerah secara konsisten.

Implementasi hubungan pusat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah selama ini tidak efektif dan menyimpan banyak persoalan seperti api dalam sekam yang pada satu saat akan meledak berupa pembangkangan nyata atau bahkan pemberontakan dari daerah yang harus diwaspadai secara serius. Tidak efektifnya politik dan sistem dana transfer daerah atau penganggaran daerah merupakan indikasi tidak efektifnya hubungan pusat daerah. Masalah ini terkait pada awalnya dengan persoalan pembagian kewenangan atau urusan. Demikian pula sistem penataan wilayah daerah menjadi tidak efektif dengan berkembangnya secara dahsyat pemekaran wilayah daerah berlangsung secara tidak efektif dengan lahirnya daerah-daerah otonom baru secara tidak terkendali. Juga dalam kaitan dengan penataan ruang wilayah yang masih menjadi friksi antara kepentingan nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat dengan kepentingan daerah, dan di antaranya membawa dampak lanjut permasalahan lingkungan hidup. Pembangunan sarana prasarana ekonomi dan sosial menurut konsep pembangunan wilayah juga sulit diharmoniskan antardaerah. Masalah lain yang sangat menonjol juga terkait dengan koherensi dukungan politik pembangunan nasional yang belum berlangsung dalam satu derap. Masih terjadi program-program nasional yang belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari daerah, demikian pula daerah mengembangkan sendiri konsep-kosnep pembangunan yang tidak selalu mengacu pada kebijakan pembangunan nasional.

Agenda desentralisasi secara internasional mendapatkan dukungan karena telah menjadi salah satu aspek penting untuk aktualisasi demokrasi yang sedang berkembang di dunia internasional. Secara regional, agenda desentralisasi telah memberi kesempatan pada daerah untuk menjalin interaksi dan kerja sama antardaerah termasuk kerja sama luar negeri secara bersama-sama dalam satu kawasan ataupun dalam interaksi daerah dengan dunia luar dalam rambu-rambu aturan. Secara nasional agenda desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi konsensus politik dan telah dilaksanakan. Memang dirasakan banyak masalah dan di antaranya menghentakkan nasional untuk lebih waspada karena berindikasi gangguan pada Ketahanan Nasional. Peluang yang berkembang dalam agenda desentralisasi ialah dukungan *capacity building* dari dunia internasional bagi daerah, dukungan politis dari para politisi sehingga ekse-

kutif dapat memberikan dukungan, demikian pula peluang untuk mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang dapat direkognisi dan dapat dimantapkan sebagai nilai-nilai bangsa secara nasional serta peluang posisi Gubernur sebagai *interface* antara pusat dan daerah. Di sisi lain terdapat pula kendala, di mana regulasi belum sepenuhnya mendukung implementasi otonomi daerah, demikian pula sikap sektoral dari beberapa departemen yang masih ditunjukkan dalam bentuk pengelolaan anggaran seperti dekonsentrasi, demikian pula kendala lemahnya SDM daerah yang kurang berkembang dalam kreativitas dan inovasi. Kendala lain ialah sistem politik praktis atau pilkada yang kurang menunjang keselarasan atau keterpaduan derap dalam kepemimpinan dalam mengelola daerah.

Agenda politik desentralisasi dan otonomi daerah akan dapat berlangsung dengan baik dengan adanya sinkronisasi upaya-upaya pemerintah pusat dan upaya-upaya pemerintah daerah. Pelaksanaan hubungan pusat daerah yang didukung dengan harmonisasi kepentingan dan upaya dalam penganggaran daerah, dalam pelaksanaan kewenangan, dalam penataan daerah dan dalam kepemimpinan daerah akan dapat mendorong implementasi hubungan pusat daerah yang baik dan mendukung Ketahanan Nasional melalui praktik-praktik *good governance*. Konsepsi dalam mewujudkan hubungan pusat dan daerah yang sinergis dapat dilakukan dengan perumusan kebijakan politik anggaran dana transfer daerah berdasarkan prinsip *money follow function,* penataan kewilayahan/ daerah dan aktualisasi kepemimpinan daerah dengan strategi dan upaya yang berorientasi keterbukaan (transparansi), akuntabilitas dan kemanfaatan yang besar bagi rakyat di daerah dan bagi tercapainya tujuan nasional.



Beberapa Pendekatan dalam Hubungan Pusat Daerah

a. Koridor Nasional dalam Kebijakan Desentralisasi

Beberapa uraian tentang situasi problematik penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai refleksi dari hubungan pusat daerah menggambarkan dua permasalahan besar. Pada satu sisi, perubahan konstruksi hubungan pusat daerah berdasarkan UUD dan UU Nomor 32 Tahun 2004 ternyata belum mampu secara optimal meredam kekuatan-kekuatan yang mengarah pada gerakan sosial yang mengandung potensi separatisme. Akankah setiap gerakan separatisme yang terjadi di daerah harus direspons oleh pusat dengan memberikan kekhususan melalui UU otonomi khusus, padahal esensi otonomi daerah itu sendiri telah mengandung makna kekhususan bagi daerah. Pada sisi yang lain praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah diwarnai dengan problem implementasi (secara teknis), misalnya terkait dengan aspek efektivitas pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, hubungan Pemda dan DPRD, dan hubungan Pemda dan masyarakat dan yang paling menonjol terkait dengan dana transfer daerah, tumpang tindih kewenangan

atau sebaliknya, kevakuman urusan, pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru dan masalah-masalah Pemilihan Kepala Daerah.

Implementasi otonomi daerah yang beranjak dari hubungan pusat daerah juga berkaitan dengan keterkaitan antarstrata kewenangan yang masih berciri *ambigous* (tidak menentu). Di satu sisi dalam hal urusan pemerintahan yang bersifat *profit gain*, maka yang terjadi ialah tumpang tindih antara kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota; namun sebaliknya untuk urusan pemerintahan yang bersifat *cost-centre*, sering kali yang muncul ialah kevakuman dalam pelaksanaan urusan, dengan kata lain tidak satu pun tingkatan pemerintah yang menanganinya. Contoh seperti ini cukup dapat ditemui terutama berkaitan dengan pemeliharaan prasarana dan sarana serta kegiatan-kegiatan yang berupa investasi jangka panjang seperti misalnya urusan arsip dan perpustakaan. Apabila hal ini secara permanen terjadi, maka akan berakibat pada friksi permanen dalam hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah yang dapat berakibat lanjut pada menurunnya ketahanan nasional karena secara perlahan, tetapi pasti akan terus berlangsung pelaksanaan otonomi daerah yang tidak efisien dan tidak efektif sehingga akan terus terpelihara gejala pemilahan sosial daerah dari kesatuan sistem nasional.

Dalam pembukaan UUD 1945 dicantumkan empat tujuan nasional sebagai tujuan negara yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber, cita-cita hukum dan moral; yang ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia. UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia (TAP MPR No. III/MPR/2000). Artinya setiap peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Penyelenggaraan negara dengan pengelolaan sistem pemerintahan yang desentralistik sepenuhnya harus berada dalam koridor UUD 1945 sebagai sumber segala sumber hukum dan pijakan dalam nilai-nilai konstitusional, di mana secara universal konstitusi negara merupakan koridor pengembangan demokrasi.

Wawasan Nusantara dirumuskan sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, tentang diri dan lingkungannya serta tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupannya yang beragam dan dinamis, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia, yang tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita nasional. Dengan demikian, pada hakikatnya Wawasan Nusantara adalah suatu keterpaduan pemikiran yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi kedaerahan/kewilayahan dan dimensi nasional. Dimensi kehi-

dupan bermasyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia dalam rangka merealisasikan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Wawasan Nusantara dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan daerah-daerah seluruh Indonesia merupakan pegangan sangat mendasar, karena disitulah jaminan bahwa prinsip negara kesatuan, prinsip rasa persatuan dan kesadaran akan keanekaragaman dan kebhinekaan dalam setiap langkah mewujudkan kepentingan dalam rangka mencapai tujuan nasional itu dilaksanakan.

Sebagai landasan visional bangsa, Wawasan Nusantara yang mencakup Astagatra (geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara senantiasa harus menjadi latar belakang pemikiran dan pertimbangan utama, serta menjiwai setiap proses perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan strategis penyelenggara negara, terlebih lagi dalam operasionalisasi otonomi daerah. Wawasan Nusantara pun hendaknya tercermin dan teraktualisasikan dalam setiap peraturan dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara selama ini juga berkembang sebagai forum dan standar pijak lintas etnis.

b. Teori Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Konsep Hubungan Pusat Daerah

Menurut dasar-dasar ilmu pemerintahan, dalam suatu negara dengan paham negara-negara kesatuan, untuk mencapai tujuan berbangsa, setidaknya terdapat 12 jenis strategi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi: diferensiasi, integrasi, sentralisasi, desentralisasi, konsentrasi, dekonsentrasi, delegasi, perwakilan, pembantuan, kooperasi, koordinasi dan partisipasi. Dari strategi-strategi itu tampak tiga strategi yang sangat populer dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara yaitu startegi desentralisasi, yaitu cara penyerahan wewenang pusat kepada daerah, strategi dekonsentrasi yaitu pendelegasian tugas pusat atau pemerintah tingkat atas kepada pemerintah level bawah serta pembantuan, yaitu penugasan kepada pemerintahan di bawahnya. (NDRAHA, Talidziduhu, 1988).

Pelaksanaan desentralisasi yang mengikutsertakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam strategi pemerintahan negara bangsa *(nation state)* seperti Indonesia dimaksudkan untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengandalkan penerapan corak pemerintahan umum *(Algemene Bestuur)*. (Maskun, S., 2001). Secara teoretis dikembangkan beberapa konsep desentralisasi, yaitu: 1) sebagai alternatif untuk pelayanan publik yang lebih efisien (konsep ini berkembang di negara-negara barat); 2) untuk menjawab masalah-masalah ketidakefisienan ekonomi, ketidakstabilan ekonomi makro dan tidak efektifnya pelaksanaan *good governance* (konsep ini berkembang

pada *developing counties*); 3) sebagai langkah alamiah menuju proses demokrasi (konsep ini berkembang terutama di negara-negara komunis); 4) karena tekanan politik (konsep ini berkembang dan terjadi di negara-negara Amerika Latin); dan 5) sebagai jalan menuju negara kesatuan (konsep di negara-negara Afrika). (Navarro, Z, 2002; Yilmaz, S., 2004; Trisman, D, 2000).

Sementara itu, PBB memberikan batasan tentang desentralisasi sebagai proses penyerahan kewenangan yang dilakukan dengan cara delegasi kepada pejabat-pejabatnya di daerah *(deconcentration)* atau dengan *devolution* kepada badan-badan otonom daerah. Lebih lanjut Bryant (1987) menyatakan bahwa ada dua bentuk desentralisasi, yaitu yang bersifat administratif dan yang bersifat politik. Desentralisasi administratif adalah delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal dalam batasan sumber biaya dan rencana yang sudah ditentukan, namun juga memiliki kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam mengembangkan kebijakan pemberian jasa dan pelayanan di tingkat lokal. Desentralisasi politik ialah wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah lokal. (Balitbang Depdagri, 2004).

Kebijakan desentralisasi diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan kewenangan antarstrata pemerintahan, dan refleksi yang muncul kemudian ialah format hubungan pusat daerah. Secara umum konsep hubungan pusat dan daerah didasari oleh prinsip rasionalitas dan proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dan kuatnya peran pemerintah daerah untuk orientasi efisiensi, akuntabilitas, kemampuan mengelola dan otonomi. Menurut Anwar SHAH, World Bank (2006) terdapat tiga pola hubungan pusat dan daerah yaitu:

1) Pola Stigler (*Stigler's Menu*, 1957) dengan dua prinsip yurisdiksi yaitu: prinsip bahwa makin dekat unit pemerintahan kepada masyarakat maka sistem akan semakin baik dan rakyat seharusnya memiliki hak atas jenis dan jumlah serta kualitas pelayanan dari pemerintah.
2) Pola Prinsip Kesetaraan Fiskal *(The Principle of Fiscal Equivalency, 1969)*, Pola ini ingin mendekatkan yuridis politik dengan wilayah pemetik manfaat dalam hal ini rakyat, sehingga tidak akan ada pihak lain yang akan mengambil kesempatan, sehingga pelayanan publik akan optimal.
3) Pola Prinsip Korespondensi *(The Correspondence Principle, 1972)*, yaitu hubungan yuridis para penyedia jasa publik yang mengarahkan secara tepat konsumen jasa publik. Konsep ini kemudian berkembang tahun 1995-1999 yang menyertakan pula konsep fungsional dan tumpang tindih yurisdiksi pelayanan.
4) Pendekatan Desentralisasi *(The Decentralization Theorem)*, di mana diharapkan bahwa penyedia jasa publik seharusnya unit yang terdekat dengan publik, atas alasan: unit pemerintah daerah lebih memahami masalah

daerah/domestik, pengambilan keputusan tingkat lokal bertanggung jawab pada masyarakat lokal yang dilayani dan sekaligus hal ini akan mendorong tanggung jawab fiskal dan efisiensi, mengurangi lapisan-lapisan yang tidak perlu dan akan terjadi interaksi antaryurisdiksi yang akan membangun inovasi.

5) Prinsip subsidi *(The subsidiary Principle)*, dalam pengelolaan pajak, pengeluaran, dan fungsi regulasi yang seharusnya dilakukan pada unit terdekat masyarakat kecuali dalam hal-hal tertentu yang harus dibawa pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pilihan-pilihan pada prinsip-prinsip tersebut dan menurut perjalanan sejarah masing-masing, konsep hubungan pusat dan daerah berkembang di berbagai negara dalam implikasi pembagian kekuasaan antarpemerintah nasional (pusat) dan daerah. Secara umum unsur penting dalam hubungan pusat dan daerah tersebut meliputi: pengaturan kewenangan dan derajat otonomi daerah, alokasi dana bagi daerah dan pengeluaraan anggaran negara, serta fungsi-fungsi pelayanan menurut sektor.

Teori dekonsentrasi perlu diangkat dalam tulisan ini karena perjalanan agenda desentralisasi selama sewindu ini memberikan indikasi pola *interface* dan komplementer antara desentralisasi dan dekonsentrasi yang perlu diikuti terus perkembanganya sampai bisa didapatkan format otonomi daerah dan hubungan pusat daerah yang paling seimbang untuk Indonesia. Konsep dekonsentrasi lahir dari konsep desentralisasi; Litvak dan Saddon (1999) menyatakan bahwa dekonsentrasi merupakan bagian integrasi dari asas desentralisasi, yakni desentralisasi administratif. Isi dekonsentrasi adalah tugas-tugas pemerintahan umum yang meliputi kelompok bidang pokok yaitu: pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, pembinaan politik dalam negeri, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, koordinasi kegiatan pemerintahan, pengawasan penegakan undang-undang dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh presiden. (SAFRUDIN Ateng, 2002). Secara politis, tujuan dekonsentrasi ialah untuk memperkuat pemerintah daerah, meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintahan dan masyarakat, serta untuk mempertahankan integrasi nasional. Sedangkan secara ekonomi asas desentralisasi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan *public goods and services*, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah (Rondinelli, 1883).

c. Wawasan Kebangsaan Sebagai Pijakan dalam Penyelenggaraan Hubungan Pusat Daerah

Sebagai bangsa majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan manusia pada aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah.

Untuk itu pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan tujuan nasional serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran tentang kemajemukan dan kebhinekaannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dikenal dengan Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia. (SUMARSONO, dkk, 2001). Menurut Lemhannas Wawasan Nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Apa yang bisa kita rangkum dalam konsep wawasan kebangsaan menurut perspektif sejarah kebangsaan Indonesia, yang paling pokok di antaranya ialah (BARRET, 2000):

1) Negara Indonesia lahir dari kesepakatan anak-anak bangsa melalui proses antara lain Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan (di sini ada *knowledge of the existence of the national group)*.
2) Daerah-daerah menjadi bagian dari kelompok orang atau bangsa Indonesia dengan masing-masing perannya seperti peran Aceh bagi kemerdekaan Indonesia, peran Yogya sebagai ibukota negara setelah Jakarta dan peran Bukittinggi sebagai pusat pemerintahan darurat dan sebagainya *(categories the self as a member of the national group)*.
3) Indonesia memiliki wilayah teritori, yaitu dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai ke Rote atau kerap pula disebut sebagai wilayah Nusantara *(knowledge of the national geographical territory)*.
4) Negara Indonesia memiliki dasar Pancasila dan lambang negara Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika *(knowledge of national emblem)*.
5) Indonesia terbangun dari kumpulan kekerabatan daerah-daerah dengan hubungan inter-relasinya *(belief about the common descent and common kinship of the members of the national group)* karena memiliki kesamaan dasar yaitu *forefathers of the nation.*
6) Bangsa Indonesia memiliki stereotipe tertentu, seperti ramah-tamah, suka bergotong royong, memiliki kekerabatan yang tinggi, penolong, dan sebagainya. Setiap elemen bangsa dan daerah di Indonesia memiliki posisi dan peran yang berarti bagi nasional *(belief about the self to the national group)*
7) Sebagai bangsa, Indonesia juga cukup sensitif dengan penghormatan orang lain yang tidak termasuk dalam *national group* terhadap *national group (beliefs about how other people, who are not members of our own national group, regard our national group)*.

Gambaran itu memberikan catatan bahwa sebagai bangsa, Indonesia memiliki dasar-dasar dan pijakan nasionalisme secara cukup ideal, karena seluruh unsur nasionalisme bisa direkognisi dengan apa yang berkembang dalam nasionalisme Indonesia. Era reformasi yang diawali pada Mei 1998 dengan di antaranya konsensus politik desentralisasi, sesungguhnya merupakan langkah korektif bangsa Indonesia terhadap kegagalan dalam mengelola negara. Reformasi yang melahirkan konsensus politik desentralisasi itu timbul atas alasan ketidakadilan di segala bidang. Kegagalan dalam mengelola negara itu diindikasikan dengan tuntutan untuk mengubah sistem politik menjadi sistem politik demokrasi dan mengubah sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini memberikan gambaran bahwa ada persoalan yang muncul dalam proses membawa nasionalisme Indonesia sepanjang perjalanan bernegara yaitu melemahnya implementasi dalam penerapan nilai-nilai dasar kebersamaan sehingga yang muncul adalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Suasana tersebut berkembang dari waktu ke waktu, dan dari satu rezim pemerintahan kepada rezim lainnya, yang kini sudah saatnya perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak tumbuh secara permanen dan berkembang pada reaksi daerah yang drastis. Pencermatan ini menjadikan kewaspadaan secara nasional terhadap perkembangan hubungan pusat daerah tersebut.

d. Referensi Hubungan Pusat Daerah di Beberapa Negara

Desentralisasi pada dasarnya merupakan proses yang fleksibel dan seharusnya memberikan ruang kepada pusat maupun daerah untuk terus mempertimbangkan segala potensi *instability*. Kalau sangat tergantung pada pusat dan konsensus masyarakat, maka upaya pengembangan akan tersendat, sementara pada beberapa hal sudah harus ada inisiatif langsung dari pemerintah daerah, tanpa harus menunggu konsensus. Untuk itu perlu ada desain yang jelas dan peran setiap elemen dan keterkaitannya. Dengan demikian, sangat besar peluang untuk proses yang melibatkan berbagai instrumen termasuk pelatihan serta pilot program. Untuk itu pula perlu partisipasi segala pihak untuk memberdayakan dan mendorong kreativitas lokal dalam mencari solusi. Agenda desentralisasi berkembang di berbagai negara dengan berbagai tipe. Di Polandia, desentralisasi berkembang dalam format *public-private partnerships,* di Hongaria lebih berkembang dalam hal pertumbuhan asosiasi-asosiasi dan lembaga independen yang mendampingi lembaga pemerintahan secara profesional, dan di Mesir lebih berkembang dalam bentuk *local partisipation*.

Agenda desentralisasi juga tidak harus menghendaki proses yang sekaligus, seperti terjadi di Indonesia atau disebut *big-bang*. Desentralisasi juga dapat berlangsung secara bertahap, di mana tidak seluruh fungsi harus didesentralisasikan tergantung sifat kritis fungsi. Contoh kasus di Uganda menunjukkan bahwa proses desentralisasi bidang kesehatan ternyata akhirnya menyulitkan bangsa Uganda, karena kegagalan program imunisasi akibat desentralisasi di mana tidak semua provinsi melakukan imunisasi secara serentak sehingga

penyakit menjadi kebal dan menambah kematian rakyat. Contoh lain ialah di Thailand, di mana desentralisasi dilakukan secara bertahap. Pengalihan kewenangan dilakukan dalam tiga kategori, yaitu: 1) misi yang dapat dijalankan oleh pemda sendiri atau bersama dengan pemda lainnya; 2) misi yang dijalankan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat; dan 3) misi yang masih tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tapi yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah. Pentahapan itu berlangsung dalam kerangka waktu berikut: 1) Tahap I, selama 1 sampai 4 tahun untuk pemda yang sudah siap maka pengalihan dapat selesai dalam 4 tahun; 2) Tahap II, 1 sampai dengan 10 tahun untuk misi yang memerlukan penyusunan dan persiapan. Demikian pula di Marokko, agenda desentralisasi diprogram dalam tahapan di mana satu tahap memakan waktu 10 sampai dengan 20 tahun untuk beberapa urusan dapat betul-betul diserahkan kepada daerah.

Desentralisasi juga cenderung merupakan proses politik sehingga dekonsentrasi juga perlu dipersiapkan dengan baik. Harus ada desain simultan dalam hal politik, fiskal dan perubahan kelembagaan, seperti halnya di negara Afrika Selatan. Untuk Indonesia, memang hampir tidak disebutkan dalam dokumen formal kaitan desentralisasi dengan dekonsentrasi, akan tetapi secara praktik justeru yang muncul dan sangat mendasar adalah posisi *interface* antara desentralisasi dan dekonsentrasi yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran dekonsentrasi yang masih terus tampak menonjol.

e. Pentingnya Kepemimpinan dalam Mengelola Hubungan Pusat Daerah

Sama derajatnya dengan antisipasi terhadap globalisasi, maka penanganan pengelolaan hubungan pusat daerah merupakan hal penting dan harus didasari pada pijakan moral Pancasila pada setiap jiwa penyelenggaranya. Oleh karena itu, pengelolaan hubungan pusat daerah dalam tampuk pimpinan yang tepat merupakan langkah strategis. Moral kepemimpinan nasional yang bersumber pada Pancasila tercermin secara terpadu dalam kelima sila Pancasila (Lemhannas RI, 2009) yaitu: moral ketakwaan, moral kemanusiaan, moral kebersamaan dan kebangsaan, moral kerakyatan dan moral keadilan. Kepekaan pemimpin untuk selalu waspada atas berbagai kondisi nasional telah diindikasikan oleh Lemhannas yang menegaskan pandangan bahwa pemimpin tingkat nasional akan berhadapan dengan masalah-masalah kompleks nasional dan masalah antarbangsa *(common security threats)*, seperti: penuntasan agenda reformasi, angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, penyakit infeksi menular, degradasi lingkungan, potensi konflik internal dan eksternal antarnegara, senjata pemusnah massal, terorisme internasional dan kejahatan trans-nasional yang terorganisasi, ketahanan pangan dan ketahanan energi serta krisis global finansial.

Menjadi cukup relevan untuk kita melihat kepemimpinan kepemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. MARK, Tucci (2008) menyebutkan beberapa ciri penting dalam kepemimpinan dalam sektor publik atau kepemerintahan, yaitu:

1) Membangun kesatuan tujuan *(building unity of purpose)*. Diperlukan berbagai visi *(shared vision)* dengan cara melibatkan sekaligus mendidik aparatur. Dalam posisi ini jelas visi bersama untuk tujuan berbangsa dan bernegara.
2) Klarifikasi Arahan (*Clarifying Direction),* perlunya langkah-langkah strategi untuk aparat memahami sasaran ideal sekaligus rencana kerja detail yang menjadi bagian tugasnya. Dalam hal ini penjabaran sekaligus dalam ukuran dan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
3) Bergeser dari transaksi menjadi transformasi, penting untuk menghindari fokus yang sempit dan hanya dalam orientasi transaksi individual; serta lebih mendorong kontribusi individual kepada sasaran tujuan yang lebih tinggi dan luas.
4) Membangun pusat peningkatan kemampuan untuk jenjang karier, untuk layanan yang lebih baik bagi masyarakat dan peningkatan jasa pelayanan di antara aparat sendiri seperti kenyamanan bekerja dan pelatihan.

Untuk itulah penting dilakukan pembahasan tentang kepemimpinan daerah dalam memimpin pelaksanaan dan menjaga rambu-rambu serta penerapan nilai-nilai bangsa dan prinsip-prinsip *good governance* untuk mencapai perwujudan tujuan negara dan agenda mengelola hubungan pusat dan daerah.



Kondisi Hubungan Pusat Daerah Serta Permasalahannya

a. Sejarah Perjalanan Fluktuatif Hubungan Pusat dan Daerah

Indonesia menjadi negara proklamasi pada 1945 dan dibangun atas penyatuan-penyatuan semangat anak-anak bangsa yang telah dirintis setidaknya sejak 1908. Tertoreh dalam sejarah pada 1928, para tokoh muda Nusantara dengan penuh kesadaran dan sikap kritis telah membangun semangat kebangsaan dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda (satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa). Mereka merupakan elemen-elemen putra bangsa berbasis lokal (daerah), yang dikenal sebagai Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Sumatra, dan sebagainya. Momentum sejarah 1928 itu secara pasti dan sistematis telah membangun kesadaran kebangsaan yang satu dalam keragaman sosio-kultural. Konstruksi ke-Indonesia-an pada dasarnya terbangun dari ruh dan elemen-elemen daerah yang heterogen baik secara etnik, budaya, maupun alamnya.

Para pendiri negara *(founding fathers)* sangat menyadari bahwa olah kuasa dan politik *(power and political exercise)* dalam bernegara harus selalu didasarkan pada prinsip dan eksistensi kebhinekaan berbasis daerah. Arah kebijakan negara haruslah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan dan permusyawaratan dari elemen-elemen bangsa itu, yang dalam terminologi generiknya dikenal dengan kata-kata demokrasi dan musyawarah. Para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam menyusun konstitusi mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 secara jelas menyadari kebhinekaan itu. Prof. Muhammad Yamin, dalam sidang BPUPKI menyampaikan pandangan di mana permusyawaratan rakyat adalah wujud tertinggi kedaulatan rakyat, dan kedaulatan rakyat syaratnya adalah adanya wakil langsung "rakyat dan daerah". Makna dari gambaran itu ialah bahwa Indonesia lahir sebagai bangsa dan negara dengan unsur yang sangat beragam dalam wilayah, etnis, maupun budaya.

Fakta sejarah mencatat banyak peristiwa terjadi yang menggoyahkan semangat kebersamaan unsur-unsur kedaerahan sebagai elemen pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Sejumlah kondisi itu antara lain: penyelenggaraan negara yang sentralistik yang berlangsung sejak era Orde Lama hingga Orde Baru telah secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat sehingga di awal reformasi semangat itu kemudian diwujudkan dalam konsensus reformasi bidang politik dan pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Konsensus politik desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah didalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai persoalan yang menggoyahkan konsensus politik dasar saat negara ini berdiri. Melemahnya rasa kebersamaan dan solidaritas masyarakat serta sinergi dan kerja sama serta solidaritas daerah, termasuk friksi dan gesekan dalam hubungan pemerintahan pusat dan daerah merupakan indikasi bahwa kita mengalami gangguan dalam aktualisasi wawasan nasional yang sesungguhnya telah menjadi konsensus politik bangsa.

Format hubungan pusat dan daerah di Indonesia berkembang dari fase ke fase dan berlangsung dalam catatan sejarah. Hadirnya UUD RIS dan UUDS menunjukkan perdebatan yang serius tentang hubungan pusat dan daerah yang akhirnya dikaitkan dengan format negara kesatuan dan ditarik kembali ke belakang pada semangat dan ikrar bangsa, yaitu Sumpah Pemuda (meskipun dalam catatan sejarah pula tercatat ketika itu keterlibatan Pemerintah Hindia Belanda). Dalam perjalanan sejarah kemudian secara tegas disikapi bahwa Indonesia kembali kepada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden. (BAHAROEDIN, Z, 1957).

Dalam konstruksi Indonesia, hubungan pusat dan daerah digambarkan dalam sejarah pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah yang dipilih ke dalam tiga kategori pokok perlimpahan kekuasaan, yaitu: 1) desentralisasi yang mencakup transfer sejumlah kekuasaan pusat kepada daerah, di mana

daerah memiliki otoritas penuh dalam pengambilan keputusan di wilayahnya; 2) dekonsentrasi atau perlimpahan pembuatan keputusan dalam beberapa bidang oleh pusat kepada daerah; dan 3) tugas pembantuan (*medebewind*) di mana tugas-tugas pusat diselenggarakan oleh unit pusat yang mempunyai wilayah kerja di berbagai provinsi (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Konsensus politik reformasi 1998, di antaranya telah mengoreksi pola hubungan pusat daerah di mana selama ini daerah merasakan bahwa seluruh sumber daya diambil oleh pusat, daerah merasa tidak berkembang karena kontrol dan eksploitasi pusat, serta lemahnya kesempatan daerah dalam pengambilan keputusan pada tataran kebijakan nasional. Sebagai konsekuensi maka dilahirkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mengatur hubungan pusat dan daerah secara sangat longgar dan luas yang dalam praktik dapat dikategorikan sebagai ciri federalistik. Ciri hubungan pusat dan daerah yang dimunculkan ialah bahwa otonomi daerah yang dilaksanakan adalah otonomi seluas-luasnya (Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004) dan daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kepentingan masyarakat daerah. Dikecualikan dari otonomi tersebut adalah urusan-urusan yang mutlak menjadi kewenangan pusat seperti: Urusan Politik Luar Negeri, Urusan Pertahanan Keamanan, Urusan Moneter dan Fiskal Nasional, Urusan Yustisi dan Urusan Agama.

Subjek hubungan pusat-daerah mengalami perjalanan fluktuasi yang cukup tajam dan tanpa disadari dapat menyentuh kembali pijakan dasar dan konsensus *building* saat persiapan proklamasi kemerdekaan. Pada konteks negara dan kewaspadaan nasional berarti subjek ini sangat rawan karena akan kembali pada pembahasan tentang ciri dasar kekuasaan Indonesia antara rakyat dan daerah seperti diutarakan Mohammad Yamin pada sidang BPUPKI. Contoh paling mutakhir gugatan atas hubungan pusat daerah ialah saat *judicial review* DPD RI atas UU Nomor 10 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 pada Maret 2008. (Setjen DPD RI, 2008).

Pada tataran operasional, nilai-nilai hubungan pusat daerah direfleksikan dalam kebijakan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang mengalami perjalanan diawali dengan UU Nomor 1 Tahun 1945 dengan bobot desentralisasi (dengan istilah otonomi berdasarkan kedaulatan rakyat); kemudian dengan UU Nomor 22 Tahun 1948 bergeser menjadi sentralistik bobot dekonsentrasi (dengan istilah otonomi sebanyak-banyaknya). Lalu berlanjut UU Nomor 1 Tahun 1957 kembali ke desentralistik (dengan istilah otonomi riel dan seluas-luasnya) dan UU Nomor 6 Tahun 1959 yang menegaskan kembali ciri desentralistik (dengan istilah riel dan luas). Kemudian bergeser menjadi sentralistik dengan bobot dekonsentrasi berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1965 (dengan istilah otonomi riel dan terbatas), berubah lagi dengan UU Nomor 5 Tahun 1974 yang bersifat sentralistik dan berorientasi dekonsentrasi (dengan istilah otonomi riel dan bertanggung jawab). Akhirnya di era reformasi lahir

UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mempertegas sistem desentralisasi (dengan istilah otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab), yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang juga bersifat desentralistik (dengan istilah otonomi seluas-luasnya).

Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan dan dirasakan cukup banyak masalah, seperti dalam hal pengaturan kewenangan, kelembagaan, keuangan, kepegawaian, pelayanan umum, keterwakilan dan pengawasan. Dalam bahasan ini ciri hubungan pusat-daerah akan didekati secara lebih makro dan mendasar yaitu pada aspek dana transfer daerah dengan prinsip *money follow function,* dan aspek penataan wilayah terkait dengan pemekaran daerah dan tata ruang serta persoalan dukungan kepemimpinan politik dalam program pembangunan nasional di daerah. Secara umum gambaran yang muncul ialah masih cukup berat dan kompleks masalah-masalah tersebut yang direfleksikan dalam bentuk sulitnya interaksi pusat dan daerah dengan timbulnya anggapan daerah bahwa pemerintah pusat kurang terbuka dalam perhitungan dana perimbangan, juga anggapan kejanggalan formulasi DAU, anggapan bahwa pusat kurang percaya pada daerah dengan dekonsentrasi yang berkembang saat ini, dan kurang intensifnya mekanisme koordinasi dan supervisi melalui pembahasan-pembahasan perencanaan pembangunan, konsultasi rancangan peraturan daerah *(judicial preview)* untuk RAPBD, demikian pula masih sangat lemahnya penanganan tata ruang terpadu antara pusat dan daerah, serta derasnya tekanan politik dalam pembentukan daerah otonom baru.

b. Implikasi dan Permasalahan Hubungan Pusat dan Daerah

Sinergisme dalam hubungan pusat daerah menjadi kebutuhan untuk efektifnya penyelenggaraan negara dalam sistem desentralisasi sesuai tuntutan reformasi. Tidak efektifnya hubungan pusat daerah mengandung implikasi nyata di mana telah muncul gejala separatis di Papua dan Aceh serta indikasi potensial di Poso, Maluku, Riau dan Kalimantan Timur, akibat rasa ketidak-adilan yang dirasakan oleh daerah. Demikian pula gejala etno-nasionalisme akibat disparitas ekonomi dan sosial serta kesenjangan antardaerah, Jawa-luar Jawa dan dalam bentuk isu putra daerah, serta pemekaran daerah. Demikian pula gejala ketidakpuasan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pengaturan dan pengelolaan penerimaan dari hasil sumber daya alam daerah. Gejala ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga masyarakat mencari jalan sendiri seperti di wilayah-wilayah perbatasan antarnegara. Implikasi lain ialah melemahnya nasionalisme akibat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang muncul dari perbandingan-perbandingan dengan kemajuan negara lain. Persaingan internasional juga telah membawa daerah-daerah di Indonesia terseret pada situasi di mana dengan kewenangan dalam hal perizinan, bupati sudah dapat memberikan izin untuk materiil dasar seperti tanah dan pasir dari daerah dikelola swasta (pemodal asing dengan partner lokal), diekspor keluar negeri seperti terjadi di Kalimantan, untuk

industri tambang zirkonia dengan tidak adanya nilai tambah yang diserap oleh daerah, karena nilai tambah itu dinikmati oleh para pemodal asing.

Implikasi lanjut dari kondisi tersebut sangat rawan bagi upaya mencapai tujuan nasional, sebab proses pembangunan akan terhambat oleh berbagai langkah-langkah kontraproduktif daerah terhadap potensi kemajuan nasional, juga karena distorsi hubungan pusat daerah. Implikasi yang lain ialah semakin lemahnya kepercayaan masyarakat daerah kepada pemerintah dan kepada negara sehingga akan melemahkan rasa kebangsaan di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain melemahnya kepercayaan daerah kepada pusat akan mendorong daerah untuk mengambil langkah sendiri yang semakin jauh dari sifat produktif bagi upaya-upaya pembangunan nasional. Implikasi lanjut juga akan terjadi pada gejala pemilahan sosial dan gejala memisahkan diri yang akan semakin menggoyahkan ketahanan nasional dan ancaman persatuan dan kesatuan serta kedaulatan negara.

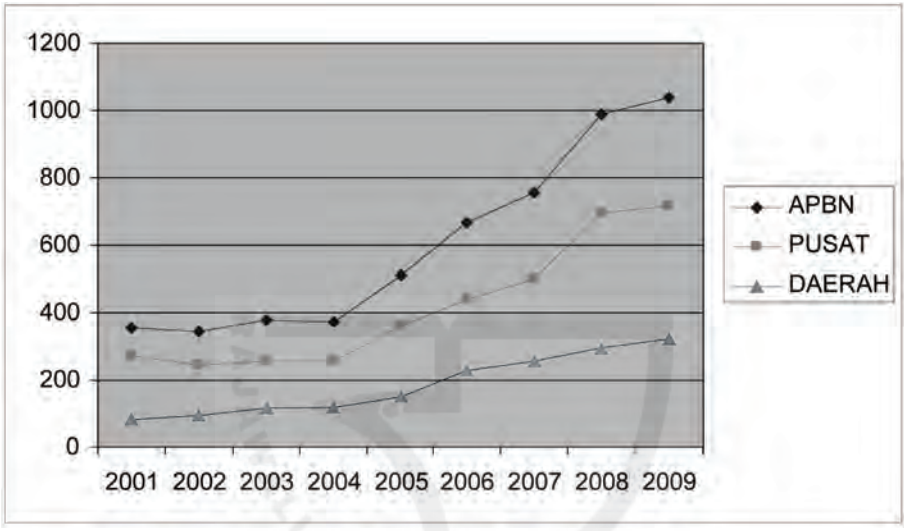
Berbagai fakta lapangan yang terjadi dalam implementasi otonomi daerah atau yang direfleksikan dalam hubungan pusat daerah secara mendasar terbagi atas tiga persoalan pokok, yaitu: *pertama,* persoalan dana perimbangan atau dana transfer daerah yang berkaitan pula dengan kewenangan karena prinsip *money follows function*; *kedua,* persoalan penataan wilayah, yaitu menyangkut pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru dan persoalan tata ruang wilayah dan *ketiga,* berkaitan dengan keselarasan dukungan kepemimpinan daerah (dalam hal ini kepala daerah).

1) Dana Perimbangan Pusat-Daerah atau Dana Transfer Daerah

Kebijakan desentralisasi secara mendasar direfleksikan dalam desentralisasi fiskal, atas pertimbangan bahwa harus ada jaminan bahwa berbagai urusan yang diserahkan pada daerah akan dapat dilaksanakan secara optimal oleh daerah. Untuk itu penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Pengaturan tentang hal ini dilakukan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dana Perimbangan (DP) adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari penerimaan pajak dan SDA. Pada dasarnya, alokasi DP ditetapkan dalam pembahasan RAPBN antara pemerintah dan DPR. Sejak 2001 hingga 2009

tercatat pertumbuhan alokasi anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seperti terlihat pada Gambar 29.1 yang menunjukkan peningkatan dari nilai APBN sebesar 364 triliun rupiah, alokasi pusat 272 triliun dan alokasi daerah 82 triliun (22,52 %) pada Tahun Anggaran 2001 menjadi sebesar 1037 triliun, alokasi pusat 716 triliun dan alokasi daerah 321 triliun (30.95 %) pada Tahun Anggaran 2009. Dana alokasi daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Aloaksi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).



Sumber data: UU tentang APBN

Gambar 29.1. Pertumbuhan APBN, dana alokasi pusat dan daerah, 2001-2009

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Kehutanan dan Perikanan). Alokasi DAU untuk daerah dihitung dengan menggunakan formula: DAU = CF + AD, di mana DAU = Dana Alokasi Umum, CF = Celah Fiskal (yaitu kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal) dan AD = Alokasi Dasar (Belanja PNS Daerah). Formulasi ini tercantum di dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan terus-menerus menuai kritik dari pemerintah daerah.

Beberapa masalah terungkap baik dari kompilasi hasil konsultasi Dewan Perwakilan Daerah RI (DPDRI) dengan para pejabat Pemda Provinsi se Indonesia pada Juli 2008, juga berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Maret 2008. Secara umum masalah-masalah tersebut meliputi:

1) Pada prinsipnya penggunaan DAU lebih banyak untuk belanja pegawai, lebih dari 80% DAU pada dasarnya merupakan belanja pegawai, oleh karena itu prinsip bahwa DAU akan dipakai sebagai *block grant* belanja publik pemerintah daerah menurut kewenangan yang diberikan hampir tidak dapat dilakukan.
2) Kriteria dan formulasi DAU menuai kritik banyak daerah mengingat bahwa luas wilayah di dalam formulasi tersebut masih hanya didasarkan pada basis wilayah daratan dan dianggap mengabaikan luas wilayah laut yang menjadi bagian dari wilayah administrasi dan tanggung jawab pengurusannya, dengan kata lain mengabaikan provinsi dengan ciri kepulauan. Namun demikian, dalam perhitungan alokasi DAU tahun 2007 telah dilakukan koreksi kebijakan, yaitu dengan kriteria luas wilayah yang digunakan adalah luas wilayah daratan ditambah dengan 25% luas wilayah laut. Hal ini berdasarkan hasil rapat kerja Pemda dan Panja DPR. Data untuk penghitungan luas daratan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2005 dan atau yang ditetapkan sendiri oleh DJPK sedangkan luas wilayah laut mengacu pada data dari Bakosurtanal yang memberikan data luas wilayah darat dan laut di tiap daerah. Kriteria lain yang dikritik juga menyangkut pertimbangan beban nasional bagi daerah seperti daerah-daerah pusat prasarana vital dan strategis, pusat investasi dan menanggung beban lingkungan hidup seperti kawasan hutan lindung atau wilayah perbatasan.
3) Mekanisme penganggaran dan informasi DAU oleh daerah masih dianggap kurang transparan dan masih ada ketidakharmonisan dalam program, demikian pula dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang tidak sejalan dengan kebutuhan daerah sehingga dirasakan menyulitkan daerah terutama berkaitan dengan aspek hukum. Penetapan alokasi DAU 2007 yang mengacu pada Perpres No. 104 Tahun 2006 untuk daerah nilainya lebih kecil dari DAU tahun 2006 sehingga daerah mengalami kesulitan dalam pembayaran gaji PNS, yang kemudian daerah memperoleh dana penyesuaian. Gambaran ini jelas menunjukkan bahwa tidak ada desain DAU untuk tujuan politik nasional, karena masih berindikasi tambal-sulam.
4) Hasil pemeriksaan terhadap penghitungan dan penetapan alokasi DAU pada 243 pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen PKPD menunjukkan bahwa data penghitungan DAU disampaikan BPS. Beberapa data yang digunakan dalam penghitungan DAU berbeda dengan

data *hardcopy* dan hasil konfirmasi data pada daerah-daerah yang diperiksa. Dengan demikian penetapan alokasi DAU tidak didasarkan pada data yang jelas. Data luas wilayah untuk penghitungan alokasi DAU tahun 2006 dan 2007 pada dasarnya mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2005. Berdasarkan kertas kerja penghitungan alokasi DAU tahun 2006, diketahui bahwa terdapat 68 daerah yang luas wilayahnya tidak sesuai dengan luas wilayah dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2005. Apabila mengacu pada ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2005, maka luas wilayah yang digunakan dalam penghitungan DAU seharusnya adalah luas daratan dan sumber data yang digunakan berasal dari lembaga pemerintah seperti BPS dan/atau Bakosurtanal yang lebih kompeten dalam pengukuran luas wilayah. (BPK RI, 2008). Dalam hal ini terdapat masalah mendasar yaitu menyangkut data luas wilayah dengan data yang berbeda.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan alokasinya kepada daerah-daerah kabupaten dan kota dilakukan dengan kriteria, yaitu: 1) kriteria umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD (PAD, DAU, dan DBH) dikurangi belanja PNS Daerah. Daerah yang memiliki kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK dan 2) kriteria khusus, ditetapkan dengan memerhatikan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan otonomi khusus NAD dan Papua dan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perbatasan negara lain, rawan banjir/longsor, kategori ketahanan pangan, pariwisata; serta 3) kriteria teknis, ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis, yang dicerminkan dengan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi sarana/prasarana pada masing-masing bidang/kegiatan yang akan didanai oleh DAK. DAK diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan urusan daerah. Secara bertahap sesungguhnya DAK merupakan pengalihan mengalihkan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah menjadi urusan daerah menjadi DAK. Jenis-jenis DAK juga berkembang dari tahun ke tahun misalnya pada 2006 meliputi DAK untuk: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Prasarana Pemerintahan Daerah dan Lingkungan Hidup, maka pada 2007 ditingkatkan jenisnya dengan

tambahan sektor kependudukan dan kehutanan serta tahun 2008 ditingkatkan jenisnya dengan air minum dan lingkungan, irigasi dan perhubungan dan tahun 2009 ditambah lagi dengan perumahan dan perdagangan. Beberapa permasalahan dalam DAK yang cukup menonjol di antaranya meliputi:

1) Daerah merasakan bahwa perencanaan DAK masih bersifat *top-down* dan daerah kurang dilibatkan oleh pusat (departemen teknis). Hal ini juga dikonfirmasi oleh temuan BPK pada DAK tahun 2006 dan 2007. Penetapan alokasi DAK tahun 2006 pada beberapa tahap dan beberapa bidang dengan total nilai sebesar 1,41 triliun rupiah dan pada penetapan Alokasi DAK tahun 2007 untuk bidang prasarana pemerintah prioritas I, II, dan III dengan total nilai sebesar 539,06 miliar rupiah serta tahap II untuk seluruh bidang dengan nilai total 530 miliar rupiah tidak dilakukan sesuai dengan proses penetapan alokasi DAK yaitu menggunakan kriteria umum, khusus dan teknis sebagaimana diatur dalam PP 55 Tahun 2005. Hal ini mengakibatkan pengalokasian DAK tahun 2006 dan 2007 sebesar 2,48 triliun rupiah diterima oleh daerah yang tidak berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat atau departemen juga dinilai oleh daerah tidak konsisten, dan kerap terjadi perubahan program dan daerah tidak mengetahui. Program DAK dan mekanisme alur DAK langsung berinteraksi antardepartemen dengan Kantor Dinas Daerah sehingga tidak dapat direkam pada tingkat provinsi (Kantor Gubernur/ Setpemda), akibatnya pelaporan kerja relatif sulit, dan sulit direkam dalam RAPBD, serta efektivitas pencapaian hasil tidak dapat dijamin.
2) Pemerintah Pusat menyalurkan DAK masing-masing sebesar 11,57 triliun rupiah pada 2006 dan 17.09 triliun rupiah pada tahun 2007. Hasil pengujian penetapan DAK yang dilakukan oleh BPK menunjukkan adanya kesalahan di mana terdapat 4 daerah Kota Pontianak, Kota Ambon, Kabupaten Kepulauan Aru yang memenuhi kriteria yang ditentukan, namun tidak mendapat DAK tahun 2006 karena formula penghitungannya terhapus. Selain itu juga terdapat perbedaan hasil penghitungan DAK tahun 2007 bidang lingkungan hidup yang disebabkan kesalahan input bobot daerah oleh DJPK. Selain itu, terdapat kesalahan pada bidang prasarana pemerintahan yang disebabkan oleh kesalahan input indeks kemahalan konstruksi oleh DJPK. Perbedaan hasil penghitungan tersebut baik selisih lebih maupun selisih kurang, terjadi pada 32 unit pemerintah daerah. Indikasi ini kembali menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki desain atau perspektif dalam alokasi DAK dalam kaitan dengan tujuan negara.
3) Dirasakan juga ada masalah dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang tidak sesuai antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah sehingga dirasakan membuat kesulitan bagi daerah dan berpotensi kerawanan secara hukum. Selain substansi, juga dalam hal ketepatan waktu masih ada masalah, karena petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis tidak tepat waktu penerbitannya.

4) Daerah juga merasakan ada masalah dalam hal pencairan dana. Hal ini juga dikonfirmasikan dengan temuan BPK berdasarkan laporan Maret 2008. DAK Dana Reboisasi yang tidak/belum disalurkan pada TA berjalan, pada akhir tahun dikeluarkan dari kas negara dan disimpan dalam rekening penampungan sementara sub account dana reboisasi (SADR). Saldo rekening tersebut per 30 September 2007 adalah sebesar 998, 71 miliar rupiah yang merupakan sisa DAK DR TA 2002, 2004, dan 2005 yang belum disalurkan kepada Pemda dan saat ini masih disimpan pada rekening BI dan Bank BNI KCU Keramat, Jakarta.

   Dana tersebut belum pernah disalurkan kepada Pemda yang berhak. (BPK RI, 2008).

5) Selanjutnya temuan BPK juga mempersoalkan adanya perintah Departemen Keuangan untuk segera mencairkan DAK pada 2006 yang memberikan perintah kepada Pemda untuk segera mencairkan DAK pada akhir tahun tanpa melihat kesiapan Pemda untuk merealisasikannya dan hal seperti ini cukup rawan korupsi.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (ketimpangan vertikal). Pengaturan DBH dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diselaraskan dengan undang-undang sektoral, pajak dan sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi ,dan panas bumi). Selain terdapat penambahan objek dari DBH SDA panas bumi, untuk dana reboisasi semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH (Depkeu, 2006). Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas DBH yang bersumber dari penerimaan pajak (pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bagunan dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, serta perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi). Formulasi DBH dicantumkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 (termasuk untuk dana otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD dan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua), dan secara ringkas seperti terlihat pada Tabel 29.1.

Tabel 29.1. Persentase Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA

No	Jenis Penerimaan	UU 33/2004			
		Pusat	Prop	Kab/ Kota	Pemerataan Kab/ Kota lainnya
1.	Minyak Bumi	84,5	3,1	6,2	6,2
2.	Gas Bumi	69,5	6,1	12,2	12,2
3.	Landrent	20	16	64	–
4.	Royalti	20	16	32	32
5.	Perikanan	20	–	–	80
6.	IHH	20	16	64	–
7.	PSDH	20	16	32	32
8.	Panas Bumi	20	16	32	32
9.	Dana Reboisasi	60	–	40	–

Sumber: UU No. 33 Tahun 2004

Permasalahan yang paling mengemuka dari komplain daerah dalam pelaksanaan DBH ialah terkait dengan keterbukaan informasi dan data dari pusat kepada daerah serta berkenaan dengan pencairan dana DBH. Hal ini juga diutarakan oleh BPK berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan. Sebelum penyaluran DBH SDA, pemerintah pusat dan daerah penghasil diharuskan melakukan rekonsiliasi guna mencocokkan jumlah PNBP masing-masing daerah penghasil, kecuali untuk DBH perikanan yang pembagian alokasinya dihitung sama besar untuk seluruh kabupaten/kota. Besarnya penyaluran DBH SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan SDA tahun berjalan dan penyalurannya dilakukan secara triwulanan. Dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan penyaluran DBH SDA antara 2 hari sampai dengan 8 bulan. Sebagai contoh dalam tahun 2006 terdapat sisa DBH SDA Triwulan I s/d III dan Triwulan IV yang belum disalurkan dialihkan kepada rekening Direktorat Jenderal Perbendaharaan Depkeu dan sampai dengan September 2007 tercatat dana DBH yang belum disalurkan ke daerah sebesar 1,15 triliun rupiah. Masalah lain yang menjadi komplain daerah ialah dalam hal keterbukaan informasi penghitungan nilai produksi sehingga daerah tidak mempunyai kejelasan dalam proyeksi penerimaan. Hal ini juga dikonfirmasikan dengan hasil pemeriksaan BPK yang memperlihatkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat mempergunakan penerimaan senilai 71,99 miliar rupiah karena belum diperhitungkan realisasi produksi minyak bumi yang belum dihitung sebesar 479,94 miliar rupiah (di mana di situ terdapat hak pemerintah pusat sebesar 85% dan Pemda 15%). Direkam pula oleh BPK bahwa belum ada prosedur yang memadai untuk memberikan keyakinan kepada Pemda mengenai jumlah DP yang menjadi alokasinya, serta waktu penyalurannya terutama untuk DBH SDA.

Beriringan dengan penanganan dana transfer daerah sebagai dana desentralisasi, perlu juga dilihat dana dekonsentrasi/tugas pembantuan yang masih cukup besar dikelola oleh pemerintah pusat. Perkembangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam APBN dari tahun ke tahun relatif stabil yaitu 38,45 triliun rupiah pada 2003 dan sebesar 36 triliun rupiah pada 2008. (Tabel 29.2).

Tabel 29.2. Nilai Dana Dekonsentrasi/Pembantuan dan Desentralisasi Tahun 2003-2008 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Dana Dekonsentrasi/Pembantuan	Dana Desentralisasi
2003	38.5	79.2
2004	39.7	86.1
2005	30.1	120.7
2006	30.6	205.7
2007	34	242.3
2008	36	264.7

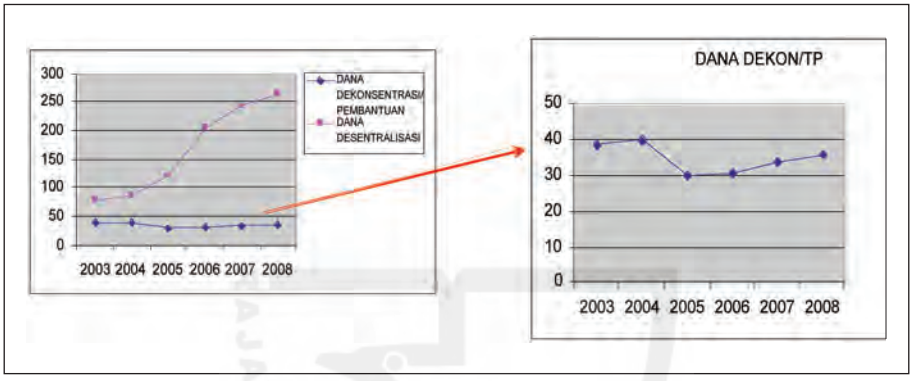
Sumber data: Nota Keuangan RAPBN, Hapsem BPK, UU APBN (diolah)

Yang dapat diidentifikasi dari data ini ialah *trend* pertumbuhan dana dekonsentrasi/TP dan dana desentralisasi dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa belum tampak pengalihan urusan secara nyata dan terpola oleh pemerintah pusat (departemen) kepada daerah kecuali dari tahun 2004 ke tahun 2005; dan pada 2007 kembali pemerintah pusat tampak mengurus urusan-urusan daerah atau konkruen. Kecenderungan tersebut dapat dibaca pada data Tabel 29.3 dan grafik pada Gambar 29.2.

Sebagai contoh tercatat dana dekonsentrasi kesehatan Provinsi Jawa Barat pada 2002 sebesar 81,61 miliar rupiah, dibandingkan dengan dana desentralisasi sebesar 32,49 miliar rupiah (28,4%), demikian pula di Provinsi NTB, dana dekonsentrasi kesehatan senilai 9,09 miliar rupiah dan dana desentralisasi sebesar 2,01 miliar rupiah (18,1%) atau secara keseluruhan provinsi di Indonesia selain DKI, jumlah dana dekonsentrasi sebesar 327,13 miliar rupiah dan dana desentralisasi senilai 388,6 miliar rupiah (50,4%), untuk sektor kesehatan. Pada 2007 tercatat dana dekonsentrasi kesehatan sebesar 448,09 miliar, yang meningkat dari tahun 2002. Daerah juga menyampaikan komplain masalah terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi yang meliputi masalah perencanaan dan pemrograman di mana dana dekonsentrasi lebih banyak direncanakan dan diprogram oleh pemerintah pusat (departemen teknis) secara *top down* dan banyak tidak diketahui oleh Kepala Daerah.

Tabel 29.3. Nilai Dana Dekonsentrasi/TP dan Desentralisasi (dalam triliun rupiah)

Tahun	Dana Dekonsentrasi/Pembantuan	Dana Desentralisasi
2003	38.5	79.2
2004	39.7	86.1
2005	30.1	120.7
2006	30.6	205.7
2007	34	242.3
2008	36	264.7



Gambar 29.2. Trend grafik perkembangan dana dekonsentrasi/TP dan desentralisasi

Hal ini juga dikonfirmasikan dengan temuan BPK tahun 2007 di mana laporan dana dekonsentrasi hanya berupa arsip data elektronik dan bukan berupa laporan resmi yang diketahui secara resmi oleh kepala daerah. Daerah juga merasakan masalah ketika untuk pelaksanaan dana dekonsentrasi, ternyata pemerintah pusat membentuk sendiri organisasi pusat di daerah dalam bentuk unit pelaksana teknis (UPT) dan di antaranya tidak diketahui oleh Kepala Daerah secara resmi. Secara umum pendanaan dekonsentrasi tidak dipahami oleh daerah, program dan pedomannya juga tidak dipahami oleh daerah.

2) Penataan Wilayah: Pemekaran Daerah dan Penataan Ruang

Subjek penataan wilayah yang diutarakan dalam identifikasi masalah ini didekati melalui dua permasalahan yang sangat menonjol di daerah, yaitu berkait dengan masalah pemekaran wilayah (daerah) dan permasalahan tata ruang.

Masalah Pemekaran Wilayah/Daerah

Pemekaran daerah telah menjadi bahan pembahasan yang cukup serius. Subjek ini juga menjadi salah satu ukuran dalam persoalan hubungan pusat dan daerah. Pada 1950 jumlah kabupaten/kota sebanyak 99 unit dan pada 1998 menjadi 300 unit kabupaten/kota. Perkembangan pemekaran wilayah sangat

pesat di era reformasi diawali dengan pemekaran sebanyak 34 kabupaten/ kota pada 1999. Pada 2008 tercatat jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 33 unit dan jumlah kabupaten dan kota sebanyak 483 unit kabupaten/kota yang terdiri dari 386 kabupaten, 91 kota dan 5 kota administratif dan 1 kabupaten administratif di DKI Jakarta. (Tabel 29.4).

Tabel 29.4. Data pertumbuhan provinsi, kabupaten dan kota periode 1950-2008

Periode	Tambahan Provinsi	Tambahan Kab/Ko	Jumlah Provinsi	Jumlah Kab/ Kota
1950-1955	6	99	6	99
1956-1960	16	145	22	244
1961-1965	3	16	25	250
1966-1970	1	11	26	161
1971-1998	1	39	27	300
1998-2008	7	183	33	483

Sumber: Hamdi, M (2008) dan Depdagri (2008), diolah.

Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 telah terbentuk daerah otonom baru sebanyak 203 daerah yaitu tujuh provinsi dan 196 kabupaten kota. Berbagai motif melatarbelakangi upaya daerah untuk melakukan pemekaran wilayah yaitu membentuk daerah otonom baru. Beberapa faktor yang mendorong pembentukan daerah otonom baru ialah faktor sosial ekonomi seperti perbedaan agama, budaya dan perbedaan tingkat pembangunan dan kemakmuran antardaerah. Faktor pemicu lainnya ialah luas wilayah yang menyulitkan jangkauan pelayanan pada masyarakat. Sementara itu menurut hasil penelitian USAID (2007) disebutkan beberapa faktor pendorong pemekaran wilayah ialah karena ketidakadilan dalam distribusi pelayanan publik, adanya ingatan kolektif yang menguatkan gejala etnosentrisme dan keinginan untuk memperoleh limpahan fiskal dari pusat. Hasil pemeriksaan BPK (Maret 2009) menyatakan bahwa proses administrasi pemekaran daerah pada Departemen Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) belum berjalan efektif karena adanya beberapa permasalahan berikut:

1) Pemerintah belum memiliki *grand design* yang mengatur arah kebijakan dan strategi pemekaran daerah, serta prediksi mengenai jumlah daerah otonom ideal di wilayah NKRI. *Grand design* tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan DPR RI dalam menyikapi aspirasi masyarakat mengenai pembentukan daerah otonom baru.
2) Penilaian BPK atas hasil observasi Departemen Dalam Negeri terhadap usulan daerah otonom baru belum didukung oleh tenaga ahli yang berkompeten dan independen, karena konsultan yang menyusun tidak melalui proses yang kompetitif, tidak ditetapkan secara resmi dan tidak diikat dengan perjanjian kerja yang sah, pelaksanaan observasi lapangan ke daerah

dibiayai oleh calon daerah otonom baru, Depdagri dan Pemda menggunakan konsultan yang sama dalam melakukan penilaian dan belum ada pedoman yang mengatur metode observasi yang dapat dijadikan sebagai acuan.

3) Dalam praktik, gagasan pemekaran daerah pada umumnya datang dari DPR, dan sering kali mengabaikan ketentuan mengenai proses pembentukan daerah otonom baru sebagaimana diatur dalam PP Nomor 129 Tahun 2000, yang sudah diganti dengan PP Nomor 78 Tahun 2007, misalnya RUU sudah diajukan oleh DPR kepada presiden sebelum dilakukan pengujian persyaratan teknis oleh tim teknis DPOD, proses pembahasan RUU mendahului sidang-sidang DPOD dan penyampaian RUU oeh DPR mendahului sidang DPOD.
4) Setiap sidang DPOD yang diadakan untuk membahas usulan pemekaran daerah tidak dihadiri oleh sebagian besar menteri-menteri anggota DPOD, tetapi diwakilkan oleh staf menteri yang ditunjuk. Ini mengandung risiko pengambilan keputusan yang cukup rawan.
5) Berdasarkan penelitian terhadap risalah sidang-sidang DPOD oleh BPK, terdapat usulan daerah otonom baru yang telah diterbitkan UU pembentukannya, belum diputuskan dalam pembahasan di DPOD, yaitu pada sebanyak 97 daerah otonom baru.
6) Belum ada sistem dan prosedur pencatatan atau tata kelola dokumentasi ataupun tim kerja administrasi yang cukup memadai untuk dokumentasi proses dan informasi wilayah-wilayah tersebut.
7) Demikian pula, belum dilakukan evaluasi terhadap 203 daerah otonom baru tersebut, termasuk kinerja daerah baru tersebut sehingga tidak diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja pembentukan daerah otonom baru atau DPOD tidak bisa mendapatkan *feed back* dalam rangka menyikapi usulan pemekaran daerah. Namun demikian, sesungguhnya sudah ada upaya Departemen Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja Pemda berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 yaitu pada sebanyak 227 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Depdagri bekerja sama dengan BPKP pada April 2008. Informasi laporan tersebut tidak dikomunikasikan kepada BPK pada saat pemeriksaan. Indikasi ini menunjukkan bahwa secara internal dalam departemen masih ada persoalan komunikasi antarunit kerja.

Dalam konteks pengelolaan hubungan pusat dan daerah, indikasi pemekaran wilayah yang paling menonjol ialah karena daerah mengharapkan untuk memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar di mana akses anggaran dari pusat ke daerah hanya dimungkinkan melalui institusi formal yaitu unit pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota melalui saluran dana perimbangan. Pada konteks kewaspadaan nasional dan *good governance*, masalah ini

menjadi tantangan besar. Pengelolaan unit pemerintahan daerah yang berwawasan nasional dengan ciri solidaritas, rasa kebersamaan dan persatuan untuk kepentingan nasional dan bangsa, disertai dengan proses dan mekanisme yang akuntabel, transparan dan partisipatif, termasuk persoalan pemekaran wilayah akan dapat dikelola dengan baik.

Masalah Tata Ruang

Permasalahan tata ruang di daerah-daerah muncul dalam bentuk indikasi masalah seperti detereoriasi fungsi lindung kawasan hutan, persoalan zonasi pengembangan wilayah yang mengakibatkan bencana alam serius seperti banjir, longsor, dan sebagainya yang sejak era reformasi 1998 menjadi tidak terkontrol. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota merupakan instrumen pengendalian dalam pemanfaatan ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan peraturan tata ruang wilayah karena menyangkut seluruh aspek kehidupan di daerah, harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah sebagai produk pemerintah (Pemda) dan wakil rakyat (DPRD). Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 78 ayat (4) disebutkan bahwa dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota tentang RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota harus disusun atau disesuaikan paling lama dua tahun (untuk tingkat provinsi) dan tiga tahun untuk kabupaten/kota sejak undang-undang tersebut diberlakukan. Sampai dengan akhir 2007 tercatat 18 provinsi dan 138 kabupaten/kota yang telah menuangkan RTRW nya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). (Tabel 29.5).

Dari data tersebut indikasi yang muncul ialah lemahnya perhatian pada persoalan tata ruang wilayah di mana hanya kurang dari sepertiga wilayah kabupaten/kota yang menetapkan Perda tentang RTRK. Demikian pula masih sekitar separuh dari provinsi yang belum memantapkan rencana tata ruang wilayahnya dalam Perda. Di sisi lain persoalan di lapangan terus-menerus muncul dalam bentuk bencana. Ketidakhadiran Perda melemahkan penegakan hukum atas pemanfaatan ruang wilayah yang tidak tepat guna. Indikasi lapangan yang muncul juga ialah belum selarasnya antara RTRK dengan RTRW, seperti contoh kasus wilayah Danau Toba di Sumatera Utara.

Perda Kabupaten Karo menetapkan wilayah sekitar Danau Toba sebagai wilayah budidaya Taman Simalem Resort, sedangkan menurut RTRW, maka kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005. (Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2007). Persoalan kepastian hukum menjadi prasyarat dalam perspektif *good governance*. Permasalahan tata ruang wilayah lainnya meliputi alih fungsi lahan yang sangat dinamis. Tercatat sampai dengan tahun 2007 telah terjadi perubahan peruntukan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 4.741.194 hektar dan pemukiman transmigrasi seluas 956.672 hektar. Perubahan untuk

Tabel 29.5. Status RTRW dan RTRKab/Ko (2007)

No	Provinsi	Perda Rtrwwp	Jml Kab/Ko	Perda Rtrrwk
1	NAD	0	23	0
2	SUMUT	1	26	6
3	SUMBAR	0	19	4
4	RIAU	0	11	4
5	KEPRI	0	6	3
6	JAMBI	0	10	2
7	BENGKULU	1	9	0
8	SUMSEL	1	15	4
9	KEP BABEL	0	7	3
10	LAMPUNG	1	11	7
11	BANTEN	1	6	3
12	DKI JAKARTA	1	6	6
13	JABAR	1	25	17
14	JATENG	1	35	8
15	DIY	1	5	3
16	JATIM	1	38	20
17	BALI	1	9	6
18	KALBAR	1	12	7
19	KALTENG	0	14	2
20	KALSEL	1	13	0
21	KALTIM	0	13	6
22	NTB	0	9	2
23	NTT	1	16	2
24	SULUT	0	9	3
25	GORONTALO	1	5	2
26	SULTENG	1	10	3
27	SULBAR	0	5	0
28	SULTRA	0	10	4
29	SULSEL	1	23	4
30	MALUT	1	9	3
31	MALUKU	0	12	4
32	PAPUA	0	19	0
33	PAPUA BARAT	0	9	0

Sumber: Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI), 2007

perkebunan yang paling luas terjadi di Provinsi Riau (1.611.860 hektar) dan di Kalimantan Tengah (619.868 hektar), sedangkan untuk pemukiman trasmigrasi paling luas terjadi di Lampung (134.147 hektar), Sumatera Selatan (120.593 hektar) dan Papua (117.194 hektar).

Perencanaan tata ruang wilayah daerah dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah menurut UU Nomor 32 Pasal 189 harus dikonsultasikan kepada pemerintah pusat sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Berdasarkan pemantauan langsung kepada Biro Hukum Departemen Dalam Negeri pada awal Maret 2009, sejak dikeluarkannya UU Nomor 26 Tahun 2007 belum ada satu pun pemerintah daerah melakukan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Departemen Dalam Negeri. Hal ini semakin memperkuat indikasi bahwa perhatian akan masalah tata ruang masih lemah. Di sisi lain, ada benturan kepentingan dalam hal penggunaan ruang wilayah antara kebutuhan daerah dan rencana pusat, demikian pula benturan kepentingan antara sektor pertambangan dengan kawasan hutan lindung, misalnya. Ego kedaerahan juga muncul berkaitan dengan pembangunan wilayah di mana prasarana dan sarana dibangun tanpa perhitungan harmonisasi wilayah pelayanan misalnya dalam membangun pelabuhan, rumah sakit, dan sebagainya. Dalam kaitan dimensi *good governance* maka hal-hal yang berkaitan dengan tidak adanya dasar hukum Perda untuk tata ruang, termasuk tumpang tindih dan tidak efisiennya pembangunan prasarana dan sarana, maka jelas bahwa ada permasalahan yang cukup serius.

3) Kepemimpinan Daerah

Pengelolaan hubungan pusat dan daerah merupakan agenda penting dalam menjaga keberlangsungan negara di samping untuk terus memupuk kekuatan negara dalam semangat Wawasan Nusantara. Sebagai bagian dari program kerja pemerintah dalam membangun daerah dan pengelolaan hubungan pusat dan daerah, sangat jelas pentingnya tampuk pimpinan dalam mengelola subjek hubungan pusat daerah yang memiliki pijakan dasar empat nilai dasar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan kata lain, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dapat disandarkan pada konsep berpikir *good governance* seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan daya responsif, akan tetapi sangat penting untuk menjaga semua hal tersebut dengan mantel atau koridor nilai-nilai Pancasila, Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan sebagaimana telah diuraikan, maka Kewaspadaan Nasional terhadap hubungan pusat dan daerah perlu diorientasikan pada semua tingkatan kebijakan dan tingkatan organisasi atau kelembagaan serta tingkatan atau *magnitude* pengambilan keputusan pada segmen Tata Kehidupan Masyarakat (TKM), Tatanan Politik Nasional (TPN), Tatanan Administrasi Negara (TAN) dan Tata Laksana Pemerintahan (TLP). Dalam urusan publik, untuk perubahan dan pengembangan inovasi dengan perubahan sistem pemerintahan, maka kepemimpinan dalam pemerintahan menjadi sangat

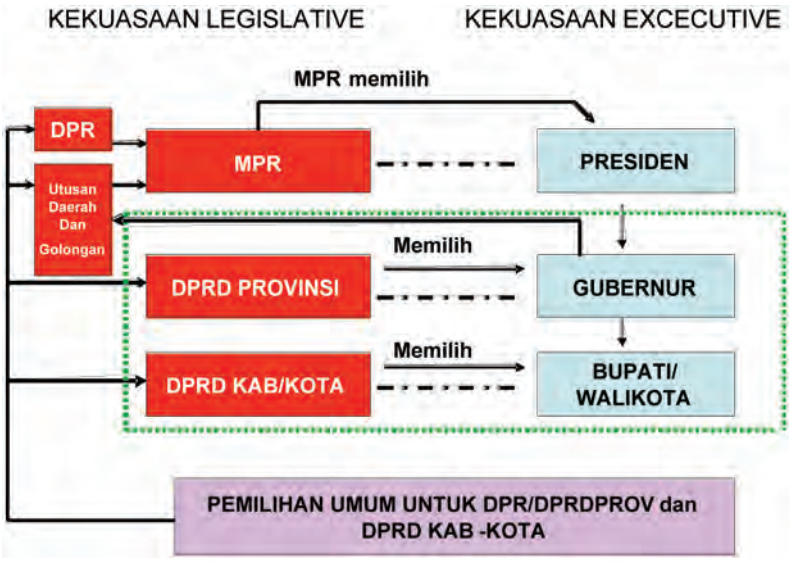
penting, dan semua rangkaian kegiatan *managerial* tidak dapat dipilah-pilah atau dilihat dan dikelola secara segmented atau parsial, namun harus senantiasa menjaga siklus manajemen dengan dimensi pertimbangan kegiatan hari-hari, kelembagaan organisasi, aparatur dan masyarakat yang dilayani.

Dengan demikian, menjaga kesatuan pembangunan dari pusat sampai daerah dan pelosok desa, merupakan hal penting sebagai satu kesatuan dan untuk itulah perlunya satu kesatuan visi kepemimpinan dan semangat membangun daerah pada seluruh jenjang strata pemerintahan. Arah pembangunan nasional yang dirumuskan dalam RPJPN berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2008 serta program-program pembangunan jangka menengah sebagaimana digariskan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN harus dilaksanakan dalam satu derap dan dalam satu kesatuan orientasi. Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan perkembangan pembangunan di daerah dan di antaranya faktor dukungan politik sebagai satu kesatuan menjadi salah satu faktor. Perkembangan politik nasional telah menempatkan pola rekrutmen kepemimpinan politik yang baru dengan sistem pemilihan presiden secara langsung serta Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sesuai pesan UUD 1945 Pasal 6A untuk Pilpres langsung dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pilkada langsung. Hal ini sangat berbeda dari sistem sebelumnya dan telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam aktualisasi pembangunan nasional. Secara skematik perbandingan pola rekrutmen sistem yang lama dana sistem yang baru seperti terlihat pada Gambar 29.3.

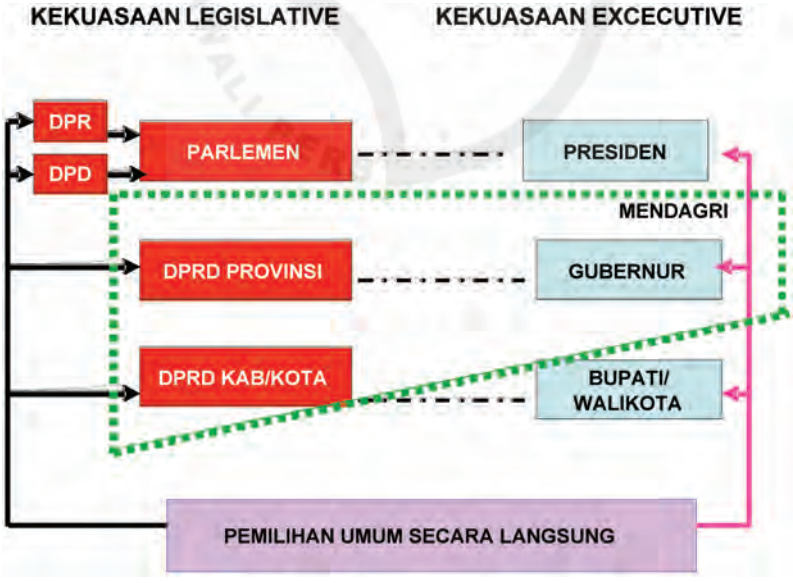
Fakta di lapangan menunjukkan kondisi tidak mudahnya kesatuan kepemimpinan dalam pembangunan nasional di mana data memperlihatkan bahwa presiden dan gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat, memiliki latar belakang dan dukungan partai politik yang berbeda. Fakta lain yang muncul ialah bahwa dengan konfigurasi format rekrutmen cabang kekuasaan legislatif yang telah betul-betul terpisah *(format separation of power)*, telah mendorong DPRD provinsi dan kabupaten/kota mengutarakan perlunya pengaturan bagi DPRD yang terpisah dari pengaturan oleh eksekutif pusat (dalam hal ini Menteri Dalam Negeri). Hal seperti ini merupakan tantangan tersendiri bagi kepemimpinan nasional atas daerah-daerah di Indonesia. Tercatat bahwa dari sebanyak 33 gubernur terdapat 15 gubernur memiliki dukungan partai politik yang sama (Partai Demokrat dan Partai Golkar) dan 11 gubernur berasal dari dukungan partai politik yang berbeda (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan); dan sisanya sebanyak 7 gubernur berasal dari dukungan parpol lainnya.

Selanjutnya untuk konteks hubungan pusat daerah dan guna menjaga dalam rangka Kewaspadaan Nasional serta mengantisipasi perspektif sistem manajemen nasional, dapat dirinci menurut wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah barat, wilayah tengah dan wilayah timur. Hubungan pusat daerah pada hakikatnya juga berdimensi posisi wilayah geografis masing-masing dari ke -33 provinsi tersebut. Apalagi dalam periode pembangunan sepanjang kurun waktu lebih dari 30 tahun yang lalu, bergulir terus perspektif lemahnya pembangunan

a) Skema pemilihan legislatif dan eksekutif pada sistem lama

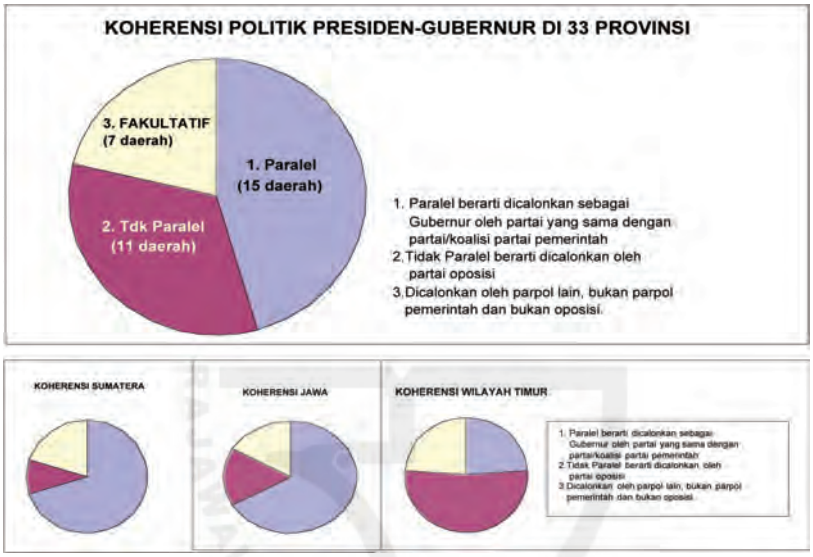


b) Skema pemilihan legislatif dan eksekutif pada sistem baru



Gambar 29.3. Skema perbandingan pemilihan legislatif dan eksekutif oleh rakyat

wilayah timur, kurang infrastruktur, dan sarana ekonomi lainnya. Gambaran dukungan politik pada wilayah barat, tengah dan timur dapat dilihat pada Gambar 29.4. yang menjelaskan bahwa di wilayah barat sebanyak 7 dari 10 gubernur memiliki latar belakang dukungan politik yang paralel; di wilayah tengah sebanyak 5 dari 11 dan di wilayah timur 3 dari 12 gubernur memiliki dukungan politik yang sama dengan dukungan untuk presiden/wakil presiden RI.



Sumber: Depdagri (data diolah, 2009).

Gambar 29.4. Koherensi dukungan politik pada kepemimpinan dalam

Pembinaan Hubungan Pusat Daerah

Dalam konteks pembinaan hubungan pusat daerah, hal ini cukup memberikan arti sehingga perlu diidentifikasi sebagai persoalan yang perlu didalami. Sehubungan dengan perkembangan terakhir dengan Pemilu Presiden Juli 2009 yang akan diikuti oleh tiga pasang calon presiden dan wakil presiden, tentu saja telah mengubah pola koherensi politik pembangunan daerah yang masih perlu terus diikuti perkembangan polanya.

Proyeksi Ideal Hubungan Pusat Daerah yang Diharapkan

Di Indonesia kebijakan desentralisasi dilatarbelakangi oleh tekanan politik akibat proses berkepanjangan tarik-menarik kekuasaan negara antara pusat

dan daerah dan sekaligus alasan untuk keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Otonomi daerah juga diharapkan sebagai pengawal NKRI, hal ini seperti dicirikan pada lahirnya kebijakan otonomi khusus Provinsi NAD dan Provinsi Papua. Masuknya pandangan-pandangan tentang *good governance* yang dinilai cukup positif juga memberi pengaruh pada perkembangan pelaksanaan otonomi daerah yang berevolusi juga untuk mengembangkan efisiensi. Contoh konkret tentang hal ini sangat nyata dengan keluarnya PP Nomor 8 Tahun 2003, sebagai koreksi terhadap PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang organisasi daerah atas anggapan bahwa telah terjadi in-efisiensi karena besarnya uang negara untuk pembayaran tunjangan jabatan, sehingga harus dikoreksi. Dengan gambaran tesebut tampak bahwa sangat besar harapan diletakkan pada agenda otonomi daerah untuk demokratisasi politik, untuk efektivitas dan efisiensi pemerintahan serta untuk memperkuat NKRI.

Pada konteks Indonesia telah disepakati bahwa seluruh elemen bangsa sadar bahwa bangsa Indonesia tidak semata-mata terbentuk dari komunitas sesama etnis, agama, bahasa dan ras, tetapi bangsa yang terbentuk berdasarkan pengalaman dan jiwa seperti telah diutarakan. Dalam kaitan memelihara hubungan suatu daerah dan menjaga luka hati daerah kepada pemerintah pusat, maka menjadi penting untuk pelaksanaan kepemerintahan yang baik dan didasari nilai-nilai luhur dan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan dapat menjamin hubungan pusat dan daerah secara baik karena dilandasi oleh semangat kebersamaan sebagai bangsa, rasa persatuan dan kesatuan dan tujuan bersama yang harus terus-menerus dipupuk, dipelihara dan dijaga dari berbagai ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan. Dalam masa membangun pemerintahan yang demokratik-desentralistik itu, maka pemantapan sistem tersebut harus dilakukan dan perkembangan ke arah itu harus dapat dikelola dengan baik dan dengan kewaspadaan nasional yang cukup tinggi. Agenda politik desentralisasi dan otonomi daerah akan dapat berlangsung dengan baik dengan adanya sinkronisasi upaya-upaya pemerintah pusat dan upaya-upaya pemerintah daerah. Pelaksanaan hubungan daerah yang didukung dengan harmonisasi kepentingan dan upaya dalam penganggaran daerah, dalam penataan daerah dan dalam kepemimpinan daerah akan dapat mendorong implementasi hubungan pusat daerah yang baik dan mendukung ketahanan nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional dan melanggengkannya.

Desentralisasi pada dasarnya merupakan proses yang fleksibel dan seharusnya memberikan ruang kepada pusat maupun daerah untuk terus mempertimbangkan segala potensi. Kalau sangat tergantung pada pusat dan konsensus masyarakat, maka upaya pembangunan akan tersendat. Atau sebaliknya, kalau daerah melaksanakan tanpa mengindahkan atau konsultasi atau mempertimbangkan kepentingan nasional, maka pembangunan juga akan jadi masalah. Untuk itu harus ada desain yang jelas dan peran setiap elemen dan keterkaitannya. Implementasi otonomi daerah juga harus melibatkan berbagai instrumen dan pelatihan serta bila perlu adanya program-progam uji coba dan

unggulan. Dengan kata lain, harus mendorong terjadinya efisiensi. Penyelenggaraan pemerintahan dalam semangat desentralisasi, memerlukan partisipasi segala pihak secara konkret untuk keberhasilan dan untuk memberdayakan dan mendorong kreativitas lokal dalam mencari solusi. Desentralisasi cenderung merupakan proses politik, sehingga dekonsentrasi juga perlu dipersiapkan dengan baik. Harus ada desain simultan dalam hal politik, fiskal dan perubahan kelembagaan. Seperti diutarakan Kausar (2009) memang menjadi sangat penting untuk pelaksanaan agenda desentralisasi dilakukan dengan prinsip seimbangnya kewenangan desentralisasi dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Yang untuk itu dapat dilakukan pentahapan dalam pelaksanaan kewenangan baik kewenangan wajib maupun kewenangan pilihan dan kewenangan konkuren sehingga akan tampak konfigurasi anggaran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sangat mungkin akan berbeda-beda untuk setiap provinsi atau kabupaten.

Oleh karena itu, menjadi penting pula untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan kewenangan wajib maupun pilihan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Depdagri dan BPKP (April 2009), dari sebanyak 227 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dievaluasi, ternyata sebanyak hanya 5 provinsi yang menyatakan lengkap pelaksanaannya sebanyak 26 kewenangan wajib, sebanyak dan 28 kabupaten/kota. Tercatat pula bahwa sebanyak 2 kabupaten/kota tidak melaporkan ataupun pelaksanaan kewenangan wajibnya. Kondisi ini tentu harus diperbaiki dan seharusnyalah seluruh daerah melaksanakan kewenangan wajib. Sementara itu, tercatat sebanyak 16 provinsi melaporkan pelaksanaan urusan pilihan dan 80 kabupaten/kota melaporkan pelaksanaannya 8 urusan pilihan tersebut. Tercatat pula 2 daerah kabupaten yang tidak melaksanakan urusan pilihan. Dari gambaran ini sangat jelas bahwa ada ketimpangan pelaksanaan otonomi daerah tingkat provinsi karena provinsi lebih memilih pelaksanaan urusan pilihan daripada urusan wajib. Gambaran ini juga memberikan indikasi bahwa sangat besar kemungkinan urusan wajib itu dilaksanakan sebagai urusan konkuren oleh pemerintah pusat sehingga tidak ditangani pemerintah provinsi. Gambaran ini sesuai dengan gambaran dana dekonsentrasi di mana dana dekonsentrasi masih dapat dikatakan cukup tinggi yang seharusnya sudah bisa dialokasikan kepada daerah. Gambaran ini juga menunjukkan bahwa belanja dana transfer daerah hampir tidak dialokasikan dalam APBD untuk belanja publik, karena terpakai untuk belanja pegawai. Konfigurasi seperti ini harus diperbaiki dan harus ditingkatkan. Secara bertahap harus ada transformasi dari dana dekosentrasi/tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus dan selanjutnya menjadi Dana Alokasi Umum. Dengan demikian, harapan bahwa otonomi daerah akan terlaksana dengan keseimbangan dalam kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi serta tugas perbantuan.

Secara umum, implementasi otonomi daerah yang diharapkan meliputi kondisi sebagai berikut: a) Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan aspek demokrasi, serta

potensi dan keanekaragaman daerah; b) Penyelenggaraan otonomi didasarkan atas prinsip otonomi luas, nyata, bulat dan bertanggung jawab; c) Pelaksanaan otonomi harus sesuai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tetap terpelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan e) Pelaksanaan otonomi harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. (Kausar, 2000). Sejalan dengan itu, hubungan pusat dan daerah harus dapat berlangsung dengan baik guna terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diharapkan. Hubungan pusat dan daerah yang diharapkan ialah yang terjalin secara sinergis. Artinya, kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah secara nasional ataupun kebijakan operasional yang dilakukan oleh daerah bagi daerahnya harus menghasilkan keluaran dan dampak yang positif dalam wujud terlaksananya otonomi daerah dengan karakteristik seperti yang telah diutarakan. Secara lebih konkret dapat diidentifikasi bentuk hubungan pusat daerah yang sinergis sebagaimana diharapkan sebagai berikut.

a. Hubungan Pusat Daerah dalam Format *"Money Follow Function"*

Prinsip *money follow function* artinya bahwa besarnya distribusi keuangan didasarkan oleh distribusi kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 didasarkan atas empat prinsip, yaitu:

1. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.
2. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD.
3. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka Tugas Pembantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.
4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah bantuan.

Dalam kajian ini fokus lebih diarahkan pada DAU, DAK dan DBH sehingga aspek pajak dan pinjaman daerah tidak dimasukkan dalam pembahasan. Dalam hal DAU maka kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan DAU agar memenuhi kriteria yang mengakomodasi berbagai kondisi yang beragam di Indonesia baik menurut kondisi wilayah geografis,

dinamika penduduk dan investasi serta beban khusus nasional seperti wilayah perbatasan dan kawasan hutan lindung. Perlunya pengaturan tersebut tidak dalam bentuk DAK atau *specific grant,* karena daerah membutuhkan *block grant* agar dapat mengatur sendiri kebutuhan tersebut.

2. Penetapan DAU harus direncanakan secara matang bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah dengan tata cara penghitungan yang transparan. Daerah berhak mendapat data/informasi yang relevan dengan hal itu, terutama dalam menilai celah fiskal.
3. Dalam kaitan dengan penetapan DAU juga diharapkan kebijakan untuk mengisi kekurangan dukungan dana kepada daerah dalam bentuk *mathcing grant* harus didasarkan pada kriteria yang lengkap, bukan hanya kriteria politik menurut pemerintah pusat dan DPR, dan dilakukan dengan penghitungan yang transparan.

Selanjutnya dalam hal DAK, kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. DAK diharapkan dapat menjadi bentuk antara dari proses bertahap pengalihan dana-dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pusat kepada daerah. Jadi konsep DAK harus memiliki kerangka waktu bagi seluruh daerah atau bagi masing-masing daerah menurut kapasitas daerah.
2. DAK agar direncanakan secara cermat bersama daerah, dan secara administratif diproses melalui tanggung jawab kepala daerah.
3. DAK agar terekam secara jelas dalam RAPBD, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam perencanaan APBD dan dalam kesatuan kerangka waktu penyusunan RAPBD.
4. DAK harus jelas sasaran fungsionalnya dan harus tetrib penggunaan dan peloporannya di bawah kepemimpinan kepala daerah.

DAK agar betul-betul secara efektif mendukung kepentingan nasional, tetapi sekaligus memberikan arti bagi daerah, sehingga dalam hal ini sangat diperlukan konsultasi dan keterbukaan dalam perencanaannya.

Sejalan dengan itu dana dekonsentrasi yang menjadi kewenangan pusat dan pengaturannya bersama daerah diharapkan sebagai berikut:

1. Dana dekonsentrasi agar direncanakan bersama antara pemerintah pusat (departemen teknis) dan daerah.
2. Dana dekonsentrasi harus menjawab secara seimbang kepentingan nasional dan sekaligus memiliki arti bagi daerah.
3. Dana dekonsentrasi secara bertahap bertransformasi menjadi DAU baik dengan atau tanpa melalui format DAK.

Dana Bagi Hasil adalah dana yeng bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Pengaturan tentang ini sudah ada dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Dalam hal Dana Bagi Hasil (DBH) dapat diidentifikasi kondisi yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan asumsi dasar berupa prognosa dan lain-lain sesuai dengan aturan agar dapat dilajukan bersama-sama dengan daerah, sehingga daerah memahami dengan jelas posisi dan memiliki peluang untuk melakukaan proyeksi penerimaannya untuk keperluan RAPBD.
2. Penetapan daerah penghasil agar jelas dan tegas karena menyangkut batas dan pemetaan wilayah, untuk itu harus ada ketegasan tentang batas-batas secara geografis.
3. Tata cara dan proses penghitungan yang menurut aturan dilakukan berdasarkan realisasi, juga harus dengan keterbukaan kepada daerah tentang nilai sesungguhnya realisasi, sehingga daerah memahami kondisi tersebut.
4. Penyaluran DBH agar sesuai dengan rencana yang dibahas bersama tidak terlambat

Secara keseluruhan dalam kaitan dengan penganggaran APBN, Dana dekonsentrasi/TP, dana perimbangan dan RAPBD, maka sesungguhnya kondisi yang diharapkan ialah sebagai berikut:

1. Posisi keuangan daerah sebagai instrumen penyelenggaraan negara, sehingga dapat pula berfungsi sebagai perekat nasional, bukan sebaliknya semakin memperlebar jurang kesenjangan antardaerah.
2. Proses RAPBD dan RAPBN agar berada dalam satu kesatuan jiwa sesuai dengan makna politik hubungan pusat daerah, yaitu untuk secara utuh membangun daerah guna menjadi kuat untuk memperoleh NKRI yang kuat.
3. Oleh karena itu, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, maka konsultasi RAPBD dari daerah kepada Departemen Dalam Negeri harus ditangani secara serius dan dianalisis menurut pisau analisis pencapaian tujuan negara, karena baik RAPBN maupun RAPBD adalah refleksi kebijakan politik untuk mencapai tujuan negara.

b. Hubungan Pusat Daerah dalam Wujud Penataan Wilayah

Hubungan dalam hal penataan wilayah difokuskan pada aspek pemekaran wilayah dan penataan ruang wilayah. Dalam hal pemekaran wilayah, kondisi yang diharapkan ialah:

1. Pemerintah perlu memilki *grand design* penataan wilayah yang disusun berdasarkan rentang kendali kepentingan nasional serta daya dukung wilayah. Perlu diproyeksikan jumlah kabupaten/kota berdasarkan kriteria menurut PP 78 Tahun 2007 dalam bentuk *master plan* provinsi. Harus dipersepsikan bahwa proyeksi pemekaran daerah atau jumlah otonom

baru sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan.

2. Pemerintah harus memiliki satu kesatuan sikap atas usulan daerah otonom baru dalam bentuk keputusan politik eksekutif yang dihasilkan dari Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang diadministrasikan secara tertib dan diputuskan secara serius pada tingkat pengambilan keputusan yang tepat (bukan pada tingkat staf yang mewakili menteri).
3. Karena sifatnya sebagai keputusan politik eksekutif yang harus dihadapkan pada politik legislatif yaitu di DPD dan DPR mungkin perlu dipertimbangkan bahwa Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dipimpin langsung oleh wakil presiden.
4. Usulan daerah otonom baru adalah usulan yang ideal dan telah mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif DPD berdasarkan pertimbangan kebutuhan daerah yang diharmoniskan dengan kepentingan nasional yang berproses di lembaga DPDRI.
5. Diharapkan menjelang penataan ke depan untuk manajemen unit pemerintahan daerah tersebut, maka perlu dipertimbangkan moratorium secara serius oleh pemerintah dengan instrumen pemerintah, karena tidak dimungkinkan menggunakan instrumen DPR, mengingat bahwa usulan daerah otonom baru terbanyak justru datang dari DPR.

Selanjutnya dalam kaitan dengan tata ruang wilayah dapat diidentifikasi kondisi yang diharapkan sebagai berikut:

1. Penataan ruang wilayah harus mencakup struktur ruang (zonasi, alokasi) yang jelas, metodis dan didasarkan pada prinsip *sustainability*, produktif, dan menjawab permasalahan kunci secara nasional dan daerah yang disatukan dalam dokumen legal dan memiliki kekuatan hukum serta dikenai sanksi atas pelanggarannya.
2. Penataan ruang wilayah harus menjadi perekat nasional dengan kelengkapan isi atau muatan: tata guna lahan, sistem transportasi nasional dan zona-zona rawan bencana. Karena ciri sebagai negara kepulauan, maka sistem tata guna lahan harus dibuat menurut pulau-pulau sedangkan sistem transportasi nasional harus diiringi dengan satu rangkaian intra moda transportasi.
3. Perlu penegakan hukum atas implementasi tata ruang dan pengawasan serta monitoring yang terpola.
4. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan ruang atau lahan.

c. Hubungan Pusat Daerah dalam Wujud Kepemimpinan Politik Mengelola Daerah

Dalam hal hubungan pusat daerah dalam kepemimpinan politik mengelola

daerah maka dapat diidentifikasi kondisi yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

1. Sikap integritas kepala daerah terhadap kepentingan nasional, yaitu memperkokoh NKRI dan mencapai tujuan nasional, yang direfleksikan melalui agenda politik presiden.
2. Keselarasan derap dalam pembangunan daerah untuk kesejahteraan rakyat melalui program-program nasional yang didukung oleh agenda-agenda pembangunan daerah.
3. Hubungan yang harmonis antara elemen-elemen kepemimpian di daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD.
4. Kemampuan daerah dalam menyikapi kondisi nasional seperti dinamika politik, lemahnya supervisi pusat ataupun dalam menyelaraskan peraturan, pedoman dan lain-lain dengan kondisi daerah, dengan terus mengembangkan daya kritis kepada pemerintah pusat.

Indikator yang dapat dipergunakan dalam melihat hubungan pusat dan daerah yang sinergis sebagaimana diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Dari Aspek Filosofis

   Secara filosofis hubungan pusat dan daerah merupakan satu kesatuan dalam wadah NKRI. Oleh karena itu, indikator yang muncul dari hubungan pusat dan daerah yang sinergis ialah kondisi damai, tertib, aman dan tenteram dalam tatanan masyarakat maupun dalam tata laku pemerintahan. Daerah akan menunjang pusat dan seluruh daerah mempunyai peran masing-masing secara nyaman, tidak ada unjuk rasa, tidak ada perlawanan kepada pemerintah (pusat) dan semua ketatalaksanaan berlangsung dalam keteraturan. Di sisi lain, daerah dapat menyelesaikan masalahnya sendiri menurut tingkatan permasalahan, berarti kapasitas daerah meningkat, juga ciri munculnya keunggulan-keunggulan lokal. Hal ini tentu saja dapat terlaksana dengan dukungan kepemimpinan daerah yang baik dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemerintahan menurut mandat rakyat (yang diperoleh dalam Pemilihan Kepala Daerah langsung) dan dalam memenuhi kaidah-kaidah *good governance*.

b. Dari Aspek Normatif

   Dari aspek normatif, indikator yang harus muncul ialah:

   1. keselarasan peraturan perundangan, tidak tumpang tindih;
   2. bertemunya nilai-nilai antara nilai-nilai universal nasional dan nilai-nilai daerah;
   3. tidak ada *judicial review* ke MK/MA atas UU dan peraturan perundang-undangan lainnya;
   4. ada SPM yang menjadi pegangan kerja;
   5. selarasnya RPJP dan RPJPD serta RPJM dan RPJMD;

6. kuatnya (*firm*) sistem pengambilan keputusan pada tingkat pimpinan daerah.

c. Dari Aspek Praktis

Dari aspek praktis, indikator yang harus muncul ialah:

1. Terjadinya transfer tanggung jawab perencanaan, manajemen dan penggalian sumber daya serta alokasinya
2. Dengan dana perimbangan untuk *co-responsibility* dalam menjalankan *social order* antarstrata pemerintahan
3. Berlangsungnya reformasi birokrasi lokal
4. Pelayanan umum yang baik
5. Konsultasi pusat daerah berlangsung dengan baik
6. Peran efektif gubernur sebagai *interface* hubungan pusat daerah
7. Kapasitas Pemda semakin baik didukung jajaran staf yang baik
8. Pelayanan umum yang baik
9. Birokrasi berjalan baik
10. Kerusakan lingkungan hidup minimal
11. Kepemimpinan daerah yang kuat dan menonjol dalam menjaga misi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hubungan pusat daerah yang berhasil akan memberikan kontribusi yang positif bagi pencapaian tujuan nasional. Adanya pembagian urusan secara jelas dan tegas dapat memberikan arahan yang jelas pula bagi pemerintah pusat dan daerah untuk dapat lebih berkonsentrasi pada tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien. Peraturan yang memberikan ruang dan jaminan kerja sama yang serasi, saling mendukung dan melengkapi antara strata pemerintahan terutama antara pemerintah pusat dan daerah, yang secara konkret adalah bentuk-bentuk kewenangan yang konkuren dapat dilakukan oleh masing-masing strata pemerintahan atas dasar pertimbangan eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Terjadinya jaminan stabilitas politik dan menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan UU yang telah menggabungkan semangat kebangsaan dengan mempertimbangkan semangat kedaerahan sehingga harus dapat dicegah adanya sentralisasi. Semua itu dapat mendukung dan mensukseskan pembangunan daerah yang berada dalam koridor sistem NKRI secara efektif dan efisien.



Catatan Penutup: Arah Penyelesaian

Hubungan pusat daerah merupakan pola hubungan desentralistis yang memberikan jaminan terhadap peran pemerintahan daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan. Hubungan

pusat daerah menetapkan domain kewenangan, wilayah pekerjaan masing-masing baik untuk pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah dengan tetap terbukanya pola kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan pusat dan daerah memberikan ruang dan jaminan kerja sama yang serasi, selain mendukung dan melengkapi antarstrata pemerintahan. Pola hubungan pusat dan daerah yang berpijak dari semangat kebangsaan telah mendorong kesertaan daerah dalam pengambilan keputusan tingkat nasional menyangkut berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang direfleksikan dalam berbagai langkah pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara.

Berdasarkan berbagai pertimbangan atas kondisi sekarang dalam hubungan pusat daerah dan permasalahannya, maka dalam mewujudkan hubungan pusat dan daerah yang sinergis dapat dilakukan dengan berorientasi keterbukaan (transparansi), akuntabilitas dan kemanfaatan yang besar bagi rakyat di daerah dan bagi kesatuan nasional. Untuk itu sinergisme dalam hubungan pusat dan daerah dapat dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut: "Terciptanya sinergisme hubungan pusat daerah melalui aktualisasi sistem anggaran daerah dengan prinsip *money folows function* dan penataan unit manajemen pemerintahan daerah dan tata ruang wilayah di bawah kepemimpinan daerah yang kuat dan dengan dukungan aparatur daerah yang baik guna terwujudnya *good governance* dalam rangka pencapaian tujuan nasional". Yang untuk itu diperlukan strategi lanjut.

Strategi adalah suatu langkah atau cara menggunakan daya, dana, sarana dan prasarana "kekuatan" dalam mencapai sasaran dengan pengaturan skala prioritas pada setiap sasaran yang ingin dicapai. Untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka disusun strategi sebagai arah dalam pencapaian strategi tersebut. Untuk itu beberapa prinsip penting yang perlu dikemukakan dalam menjalankan strategi itu yakni bahwa seluruh daya dan upaya dilakukan untuk kepentingan nasional yang dicirikan dengan sistem pengambilan keputusan di antara lembaga-lembaga pemerintahan bersifat inklusif, tidak mengedepankan kepentingan kelompok; di samping itu format partisipasi masyarakat berlangsung pada setiap lapisan pengambilan keputusan di daerah dengan prinsip kemitraan dibedakan antara kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat yang tidak di-dikotomikan.

Strategi peningkatan hubungan pusat daerah dapat diidentifikasi yang meliputi:

Pertama, Sinergi hubungan pusat daerah melalui aktualisasi sistem penganggaran daerah (dana transfer daerah dan APBD) dengan memantapkan format politik sistem anggaran daerah yang meliputi dana transfer daerah dan APBD guna menunjang kinerja daerah dan untuk tercapainya sistem penganggaran daerah yang harmonis antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan nasional dengan mekanisme politik anggaran yang melibatkan legislatif, eksekutif dan masyarakat.

Kedua, Sinergi hubungan pusat daerah melalui aktualisasi tata kewenangan antarstrata pemerintahan sebagai pijakan dasar penetapan kinerja dan alokasi anggaran dengan penerapan prinsip *money follows function* dengan sasaran terwujudnya tata kewenangan antarstrata pemerintahan untuk kinerja pelayanan masyarakat secara bertanggung jawab.

Ketiga, Sinergi hubungan pusat daerah dengan memantapkan penataan unit manajemen pemerintahan daerah (daerah otonom) atau pemekaran daerah yang dilakukan melalui pengendalian pemekaran daerah berdasarkan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah dengan konfigurasi unit-unit pemerintahan daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dalam format rentang kendali yang ideal dan realistik.

Keempat, Sinergi hubungan pusat daerah melalui pemantapan penataan ruang wilayah dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah guna terwujudnya penataan ruang wilayah secara nasional yang bersifat harmonis antara kepentingan nasional, kebutuhan daerah dan keserasian antardaerah.

Kelima, Sinergi hubungan pusat daerah dengan meningkatkan aktualisasi kepemimpinan daerah yang kuat yang berpegang pada prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah

Keenam, Sinergi hubungan pusat daerah dengan meningkatkan hubungan kelembagaan eksekutif legislatif tingkat daerah untuk keserasian kepentingan anisonal dan daerah.

Ketujuh, Sinergi hubungan pusat daerah melalui penguatan aparatur daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan daerah serta antardaerah.

Daftar Referensi

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri. *Laporan Akhir Penelitian Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Daerah,* 2004.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. *Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2008*. Jakarta, 2009.

————————. *Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2008*. Jakarta, 2009.

————————. *Pokok-pokok Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II Tahun 2007*. Jakarta, 2008.

————————. *Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi*. Jakarta, 2009.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Dana Dekonsentrasi*. Jakarta, 2005.

Baharoeddin, Z. *Menjongsong Lahirnya Undang-Undang Dasar Baru dengan Konstitusi Tudjuh Negara Sebagai Bahan Perbandingan*. Djakarta: Tintamas, 1957.

Barret, Martyn. *Inaugural Lecture*, University of Surrey, UK, 2000.

BAPPENAS, Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007, bekerja sama dengan UNDP. Jakarta, 2008.

Bellina S'everine et al, La gouvernance de'mocratique, Un nouveau paradigme pour le developpement? Editions Karthala, Ministere Des Affaires Etrangeres Et Europeennes, Paris, 2008.

Bennet, Robert, J. Local Government and Market Decentralization: Experiences In Industrialized, Developing and Former Eastern Bloc Countries, United Nations University Press, Tokyo-New York-Paris, 1994.

Blaug, Ricardo dan John Scwarzmantel. *Democracy: A Reader*. Edinburg University, 1988.

Branch, M.C. *Regional Planning, Introduction And Explanation*. Praeger, New York, Westport, Connecticut, London, 1980.

Commission of The European Comunities. European Governance, A White Paper, Brussels, 2001.

Departemen Keuangan RI. Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, Tahun 2008. Jakarta, 2008.

————————, Reformasi Sistem Anggaran. Konsep dan Implementasi 2005-2007, Jakarta, 2007.

————————, 2008, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah dalam Mendukung Pertanggungjawaban Keuangan, Prosiding Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Jakarta, 16-17 Juli 2009.

————————, Djojosoekarto Agung. *Grand Strategy Penataan Daerah Tahun 2025*, Jakarta: Penerbit Kemitraan lagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2008.

Dwiyanto, Agus dkk. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, 2003.

Effendi, Taufiq, Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance di dalam: Masalah-masalah Kebangsaan dan Kenegaraan, Himpunan Jurnal Negarawan Terpilih Edisi 01-06, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2008.

Kausar. Pemberdayaan Perangkat Daerah dan Kewenangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kertas Karya Perorangan, KSA-VIII, Lemhannas. Jakarta, 2000.

Kementerian Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Indonesia 2007, Jakarta, 2008.

Lemhannas RI Pokja Ideologi Bidang Studi/Materi Pokok Ideologi Modul 1 Sub BS Pancasila dan Perkembangannya, Lemhannas PPSA XVI, Jakarta.

Lemhannas RI Pokja Kewaspadaan Nasional BS Kewaspadaan Nasional, Lemhannas PPSA XVI-2009, Jakarta.

Lemhannas RI Pokja Sistem Manajemen Nasional BS Sistem Manajemen Nasional, Lemhannas PPSA XVI- 2009, Jakarta

Lemhannas RI Pokja Ketahanan Nasional BS Ketahanan Nasional, Lemhannas PPSA XVI- 2009, Jakarta.

Koesdiyo, R. Poerwanto. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

March, James G. and Johan P, OLSEN. *Democratic Governance*. New York: The Free Press, 1995.

Maskun, Sumitro. Azas-azas Penyelenggaraan Pemerintahan (Makalah pada Diskusi Terbatas Ditjen PUM Depdagri), Jakarta, tanggal 16 Juni 2001.

Navarro, Zander. Decentralization, Participation and Social Control of Public Resources: "Participatory Budgetting" in Porto Alegre (Brazil)". Workshop, Tokyo and Kobe, Japan, September, 2 to 6, 2002.

Ndraha, Talidziduhu. Prospek Pemerintahan Desa Pada Millenium Ketiga disampaikan pada Seminar Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Memasuki Era Globalisasi tanggal 3-4 Juli 1997 di Bandar Lampung.

Peele, Gilian. *Governing The UK*. Fourth Edition, Blackwell Publishing, Oxford UK, 2004.

Rietveld, P. Regional Planning, NHPC. New York: Oxford, North Holland Amsterdam, 1980.

RONDINELLI, Dennis and Cheema G Shabbir, Implementing Decentralization Policies: An Introduction, Di dalam: Decentralization And Development, Policy Implementation In Developing Countries. California SAGE Publications Inc Beverly Hills, 1988.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Menggugat, Laporan Pelaksanaan Uji Material UU Nomor 10 Tahun 2008 Terhadap UUD 1945, Jakarta, 2008.

Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 2005.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Menggugat, Laporan Pelaksanaan Uji Material UU Nomor 10 Tahun 2008 Terhadap UUD 1945, Jakarta, 2008.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, PT Widya Komputer Indonesia, Jakarta, 1998.

————————. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, 2004.

————————. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta, 2004.

————————. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Jakarta, 2007.

Shah, Anwar. Local Governance In Developing Countries. Public Sector Accountability Series, World Bank, 2006.

Subiyantoro, H dan S. Riphat. *Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

Sumarsono dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Syafrudin, Ateng. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: Bina Cipta, 2002.

The Independent Commission on Good Governance in Public Services, The Good Governance Standard For Public Services. London: Hackney Press Ltd, 2004.

Treisman, Daniel. Decentralization, Tax Evasion, and The Underground Economy: A Model With Evidence From Russia. Los Angeles, 2000.

Trianto dan T Triwulan. *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

Tucci, Mark. Effective Leadership In Government, Journal for Quality and Participaton. http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3616/is_200804/ai_n255000461/download 4 Februari 2008.

Usaid, Pemerakan Daerah: Temuan Penelitian Aras Lokal dan Nasional, Presentasi kepada PAH I DPD-RI Jakarta, 2007.

Wingarta, IP Sastra. Kewaspadaan Ansional dan Implementasinya dalam Good Governance, PPSA-XVI, Lemhannas RI, Jakarta, 2009.

Wreksosuhardjo, S. *Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

World Bank, Decentralizing Indonesia, East Asia Poverty Reduction and Economic Management Unit, 2003.

Yamin, Muhammad. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 memuat segala naskah resmi Undang-Undang Dasar '45 yang berlaku kembali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1960.

Yilmaz, Serdar. Concept Of Fiscal Decentralization and Worldwide Overview, 2001.

30

SISTEM PENGAWASAN EKSTERNAL VS INTERNAL PENEGAK HUKUM DALAM KONTEKS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*

Oleh:
*Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.***

Pendahuluan

PRAKTIK PENYALAHGUNAAN WEWENANG di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan, oleh karena itu mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan badan peradilan terhadap masyarakat dan dunia internasional. Keadaan badan peradilan yang demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, perlu dilakukan upaya-upaya yang luar biasa yang berorientasi kepada terciptanya badan peradilan dan hakim yang sungguh-sungguh dapat menjamin masyarakat dan pencari keadilan memperoleh keadilan, dan diperlakukan secara adil dalam proses pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan disebabkan oleh banyak faktor antara lain adalah tidak efektifnya pengawasan internal yang ada di badan peradilan. George R. Terry dalam Muchsan (Muchsan, 1992, hlm. 37) menyebutkan *Control is determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan yang* artinya pengawasan adalah apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana. Pengawasan (*controle*) terhadap pemerintah menurut Paulus Effendie Lotulung adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif (Paulus Effendie Lotulung, 1993, hlm. 15).

---

*Tulisan ini pernah dimuat oleh penulis dalam jurnal Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Pantarei tahun 2008/2009 (diolah kembali).

**Staff Pengajar pada Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum serta Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan dapat dibedakan menjadi kontrol intern (*internal control*) dan kontrol ekstern (*external control*). Kontrol internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural adalah masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Bentuk kontrol semacam itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis-administratif atau *built-in control*. Kontrol eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ secara struktur organisasi berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan BPK, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui LSM termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada bidang tertentu misalnya pemantau peradilan, kontrol politis yang dilakukan MPR dan DPR (D) terhadap pemerintah (eksekutif). Kontrol yang dilakukan badan lain seperti Komisi Ombudsman dan Komisi Yudisial.

Dalam ilmu hukum dan praktik administrasi negara, maka pengawasan atau *controlle* terhadap tindakan administrasi/pemerintah tersebut ada bermacam-macam bentuknya, yang dapat ditinjau dari saat kapan dilakukan pengawasan/*controlle* dan lembaga mana yang melakukan pengawasan/*controlle*. Ditinjau dari saat kapan dilakukannya pengawasan/*controlle,* dibedakan pula antara (Benjamin Mangkoedilaga, 1982: hlm. 70):

a. *controlle a priorie atau controlle preable,* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum administrasi/pemerintah melakukan pelanggaran administratif dengan maksud agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran;

b. *controlle a posteorie,* yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan sesudah administratif/pemerintah melakukan pelanggaran-pelanggaran administratif, tindakan mana dimaksudkan untuk memulihkan atau memperbaiki apa yang telah dilanggar oleh pemerintah/administrasi.

Ditinjau dari lembaga mana yang melakukan pengawasan atau *controlle* tersebut, maka dapat dibagi atas:

a. Pengawasan atau *controlle intern,* yang maksudnya, pengawasan tersebut dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan yang terletak dalam tubuh administrasi itu sendiri.

b. Pengawasan atau *controlle extern,* yang maksudnya pengawasan atau *controlle* tersebut dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan yang terletak di luar tubuh administrasi yang bersifat independen terhadap administrasi, yang biasanya dilakukan oleh:

    1) Kekuatan-kekuatan sosial politik, seperti lembaga-lembaga perwakilan rakyat/parlemen, partai-partai atau media pers.

    2) Badan-badan khusus yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan/*controlle,* tetapi tidak termasuk dalam tubuh administrasi dan tidak

bersifat yuridis atau politis, seperti lembaga *"Counsel of Tribunals"* yang terdapat di Inggris.

c. Badan peradilan, tegasnya oleh para hakim administrasi/tata usaha negara.

Menurut P. Nicolai dkk (Ridwan HR, 2006: 311), *"De bertuurechtelijke handhavings middelen omvatten (1) het toezich dat bertuurorganen kunnen uitoenfenen op de naleving van de bij of krachtens de wewt gestelde voorschriten en van de bij besluit individueel opgeledge verplichtingen; en (2) de toepassing van bestuursrechtelijk cancie bevoedheden"* (sarana penegakan hukum administrasi berisi: (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu; dan, (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Hans Kelsen berpendapat pengawasan hukum terhadap pemerintah oleh pengadilan tapi tidak perlu menjadi kewenangan pengadilan biasa, pengawasan hukum tata usaha ini harus diserahkan kepada pengadilan khusus, fakta bahwa pengawasan administratif oleh pengadilan dianggap penting memberi keterangan yang jelas tentang kekurangan-kekurangan dari teori pemisahan kekuasaan, prinsip pemisahan kekuasaan ini akan tampak menghendaki bahwa tidak satu pun dari tiga kekuasaan itu harus diawasi masing-masing dari kedua kekuasaan lainnya. Prinsip pemisahan kekuasaan yang dituntut untuk membenarkan pengawasan yang sangat ketat atas pemerintah oleh pengadilan, suatu keadaan yang dicapai di mana organ-organ administratif harus merujuk kepada pengadilan hukum-hukum administratif (Hans Kelsen, 2007, terjemahan).

Paulus Effendie Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara, yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol dapatlah dibedakan kontrol ekstern dan intern. Kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri, sedangkan kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya pengawasan atau kontrol dibedakan dalam dua jenis, yaitu kontrol *a-priori* dan kontrol *a-posteriori*. Kontrol *a-priori* terjadi bila pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah sedangkan kontrol *a-posteriori* terjadi bila pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah, selain itu kontrol dapat pula ditinjau dari segi objek yang diawasi, yang terdiri dari kontrol dari segi hukum (*rechtmatigheid*) dan kontrol dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*).

Kontrol dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukum saja (segi legalitas) yaitu, segi *rechtmatigheid* dari

perbuatan pemerintah, sedangkan kontrol dari segi kemanfaatan dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatan. Sesudah mengadakan pembagian pengawasan tersebut, lebih lanjut Paulus Effendie Lotulung mengatakan bahwa kontrol yang dilakukan oleh peradilan dalam hukum administrasi negara mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Ekstern, karena dilakukan oleh suatu badan/lembaga di luar pemerintahan
b. Aposteriori, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol
c. Legalitas atau kontrol segi hukum karena hanya menilai dari segi hukum saja.

Kontrol Yudisial terhadap tindakan pemerintah merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan, jika dikaitkan dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dinilai secara yuridis adalah keputusan Tata Usaha Negara, dalam lembaga peradilan yang berwenang melakukan pemeriksaan, sampai memberikan putusan adalah hakim peradilan. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang menilai dari segi hukumnya dari kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan, dengan kata lain Hakim Peradilan Tata Usaha Negara mengadakan kontrol/pengawasan terbatas terhadap perbuatan pemerintah mengenai aspek-aspek hukumnya, artinya mengadakan pengawasan apakah pada penentuan tentang kepentingan umum oleh pemerintah itu tidak mengurangi hak-hak individu yang adil secara tidak seimbang. Dapat disampaikan bahwa hakim hanya memberikan penilaian/pengawasan apakah tindakan administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan itu termasuk sebagai perbuatan yang disebut *onrechtmatige overheidsdaad* (Diana Halim Koentjoro, 273-274).

Penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan yang ada. Bahkan sering terjadi penyelenggaraan pemerintahan ini menimbulkan kerugian bagi rakyat baik akibat penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) maupun tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang terjadi apabila terpenuhi unsur-unsur; *pertama*, penguasa yang berbuat secara yuridis memiliki kewenangan untuk berbuat (ada peraturan dasarnya); *kedua*, dalam mempertimbangkan yang terkait dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah, unsur kepentingan umum kurang diperhatikan; *ketiga*, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian konkret bagi pihak tertentu. Dampak lain dari penyelenggaraan pemerintahan seperti ini adalah tidak terselenggaranya pembangunan dengan baik dan tidak terlaksananya pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana mestinya. Keadaan ini menunjukan penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan adalah antara

lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga peradilan, pengawasan dari masyarakat, maupun pengawasan melalui lembaga ombusdman. Di samping itu juga dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara adalah dengan membuat penormaan kekuasaan, mendasarkan pada asas legalitas dan persyaratan, sehingga memberikan jaminan perlindungan baik bagi administrasi negara maupun warga masyarakat. Upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan antara lain dengan pengawasan lembaga peradilan, pengawasan masyarakat, dan pengawasan melalui lembaga ombusdman. Di samping itu juga dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, maka sebaiknya pengawasan lembaga peradilan, masyarakat, dan lembaga ombusdman dilakukan dengan efektif. Di samping itu, pemerintah sebaiknya memerhatikan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van be-horlijk bestuur*).



Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak/Baik

Konsep negara hukum Indonesia sedikit banyak tidak lepas dari pengaruh perkembangan konsep negara hukum di dunia, terutama *rechsstaat* dan *the rule of law*. Intinya menurut Sri Soemantri (Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29):

1. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. adanya jaminan terhadap HAM (warga negara);
3. adanya pembagian kekuasaan negara;
4. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechttelijke control*).

Friederich Julius Stahl tahun 1878 dalam bukunya *Philosophie des rechts*, HD van Wijk yang ditulis tahun 1984 dalam *Hoodstukken van administratief recht* dan masih dipertahankan oleh Ten Berge tahun 1996 dalam *Bestuuren door de overheid* (ten Berge, J.B.J.M, 1996, hlm. 34-35), juga menjelaskan hal yang sama dengan pendapat Sri Soemantri di atas. Oleh karena itu, walaupun dikemukakan pertama kali tahun 1878, tetapi masih relevan sampai saat ini. Sehingga unsur-unsur tersebut merupakan inti dari negara hukum.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Asas ini berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi negara dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan

atau *beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Sebagian besar dari asas-asas umum pemerintahan yang baik masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum (Jazim Hamidi, 1999, hlm. 24).

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak/Baik menurut Koentjoro Purbopranoto (Koentjoro Purbopranoto, 1975) adalah:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas keseimbangan
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan
4. Asas bertindak cermat
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan
6. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan
7. Asas permainan yang layak
8. Asas keadilan dan kewajaran
9. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar
10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal
11. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi
12. Asas kebijaksanaan
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik muncul dan dimuat dalam suatu Undang-Undang yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN). Dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsionalitas
6. Asas Profesionalitas
7. Asas Akuntabilitas

Asas-asas yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 tersebut ditujukan untuk para penyelenggara negara secara keseluruhan, sementara asas-asas dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak/Baik pada dasarnya hanya ditujukan pada pemerintah dalam arti sempit, sesuai dengan istilah *"bestuur"*

pada *algemeen beginselen van behoorlijk bestuur*, bukan *regering atau overheid*, yang mengandung arti pemerintah dalam arti luas. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan proses peradilan, asas-asas yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tidak memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan AAUPL, yang secara aktual telah dijadikan sebagai salah satu dasar penilaian oleh para hakim. Dengan kata lain, asas-asas yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1999 lebih merupakan etika dalam penyelenggaraan kenegaraan, bukan sebagai kaidah hukum.



Teori Konsekuensi Pengawasan dan Prinsip-prinsip Umum Peradilan yang Baik

Akses publik terhadap putusan pengadilan merupakan bagian dari pengawasan eksternal (*external control*) yang dilakukan oleh masyarakat. Agar pengawasan masyarakat berjalan efektif, maka hal tersebut tidak terlepas dari prinsip-prinsip umum peradilan yang baik, yaitu prinsip: (1) Independensi dan Tidak Memihak (*Imparsial*); (2) Kompeten; (3) Akuntabilitas; (4) Partisipatif; (5) Transparansi; (6) Mudah Diakses dan Cepat; (7) Hak untuk Banding; (8) Kepastian Hukum; (9) Waktu yang Memadai untuk Pembelaan; dan (10) Jaminan dari Upaya Paksa yang Bertentangan dengan Hukum. Dalam kerangka prinsip-prinsip umum peradilan yang baik tersebut, yang menjadi acuan dalam hal akses publik terhadap putusan pengadilan adalah *pertama*, prinsip akuntabilitas, yang menghendaki setiap pelaksana kekuasaan, apakah itu penentuan kebijakan, pengambilan keputusan dan sebagainya, harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power)*.

Kedua, prinsip partisipasi masyarakat merupakan hal yang esensial dalam negara demokratis. Partisipasi ini paling tidak dapat dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi dalam membentuk keputusan (agar keputusannya lebih berkualitas dan partisipatif) dan dalam melakukan kontrol (untuk meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan).

Ketiga, prinsip transparansi atau keterbukaan menjadi penting untuk meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk KKN. Selain itu, agar prinsip akuntabilitas dan partisipatif dapat berjalan efektif, diperlukan adanya transparansi dalam keseluruhan proses peradilan, selama tidak mengganggu (merugikan) upaya penegakan hukum.

Keempat, akses terhadap putusan pengadilan harus dapat diperoleh setiap orang dengan cepat, murah, dan sederhana. Untuk putusan yang persidangan perkaranya tertutup, maka identitas para pihak bisa ditutup (Leip, 2002).

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah baik yang bersifat internal maupun eksternal dapat ditentukan oleh beberapa teori

konsekuensi pengawasan yang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pengawasan, yaitu:

1. Teori kekuatan yuridis
2. Teori tipe Pengawasan. Dikenal dua tipe pengawasan yang paling menonjol, (a) pengawasan represif, oleh A. Dunsire (Dunsire A, 1978, page. 35) diartikan sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya dan (b) pengawasan normatif, oleh A. Etzioni (Etzioni A., 1968 page. 96) dimaksudkan sebagai pengawasan yang menggunakan cara sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan.
3. Teori otoritas pengawasan mencakup: keabsahan (*legitimiteit*) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan yang diakui berwenang, pengawasan dengan menggunakan suatu keahlian (*deskundigheid*) (Niemeijer, E., & J.S., Timmer, June 1993, page. 301) dan kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*).
4. Teori komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau lambang-lambang yang mengandung arti tertentu.
5. Teori publisitas yaitu mempublikasikan masalah kepada masyarakat yang dapat memberi pengaruh kepada tekanan publik akibat dari opini publik (*public opinion*) (Ten Berge, J.B.J.M., 1991, hlm. 19).



Pengawasan Yudisial oleh Peradilan Administrasi

Salah satu bentuk pengawasan adalah pengawasan yudisial oleh peradilan administrasi yang melalui mekanisme suatu gugatan oleh orang atau badan hukum perdata. Pada hakikatnya tidak berbeda tugas peradilan pada umumnya yaitu mempertahankan hukum materiil dalam hal ini hukum administrasi materiil. Penjelasan Undang-Undang Peradilan administrasi menyebutnya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara administrasi negara dengan rakyat. Dari aspek lain disebut juga sebagai sarana pemeliharaan agar penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat pemerintahan selalu berdasar dan menurut hukum.

Pengawasan yudisial oleh peradilan administrasi terbatas pada menilai tindakan pada waktu pemerintah mengeluarkan keputusan administrasi (*beschikking*). Pengertian tentang keputusan administrasi (*beschikking*) telah dikemukakan oleh pakar hukum administrasi negara, antara lain Prins mengemukakan *"de eenzijdige rechtshandeling op bestuursgebied door een overheidsorgaan verricht uit kracht van zijn bijzondere bevoegdheden"* (Prins, dalam Koentjoro Purbopranoto, 1985). Suatu tindakan hukum sepihak dari pemerintah, dilakukan sebagai penguasa berdasarkan kewenangan khusus).

Pengawasan hukum melalui peradilan administrasi dilakukan menurut proses acara peradilan administrasi, bermula dari gugatan dan berakhir dengan putusan. Putusan adalah instrumen badan peradilan dan pelaksanaannya adalah

muara dari proses peradilan. Pada putusan konsep penyelesaian sengketa dirumuskan, sehingga fungsi korektif, remedial dan sanksi dari hukum administrasi menjadi nyata.



Independensi dan Akuntabilitas Peradilan

Pada 16 April 2004 telah diselenggarakan *Law Summit* III, yaitu Pertemuan puncak pejabat tinggi negara di bidang hukum dan peradilan serta pimpinan profesi hukum di gedung Mahkamah Agung RI. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolri, Ketua Profesi Hukum Advokat (KKAI), Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN), dan Komisi Ombudsman Nasional (KON).

Pertemuan puncak tersebut menghasilkan Naskah Kesepakatan Bersama (NKB) yang ditandatangani Ketua M.A., Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, dan Koordinator KKAI. Selain itu NKB tersebut ditandatangani oleh para saksi yaitu, Menko Polkam, Kepala BAPPENAS, Ketua KHN serta Ketua KON. Dalam naskah itu terdapat Rencana Aksi atau Rancang Tindak (*Plan of Action*) di bidang Pembaruan Hukum dan Peradilan. Secara ringkas, substansi rencana aksi antara lain meliputi:

1. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang bertujuan agar proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik (*accessable*).
2. Pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan masyarakat, serta perintisan sistem pengawasan eksternal yang melembaga, misalnya seperti eksaminasi publik.
3. Penyederhanaan prosedur penegakan hukum yang diujicobakan pada kasus yang menyangkut orang banyak seperti, penyederhanaan prosedur tilang (perkara lalu lintas).
4. Pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) yang transparan yang mendukung penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Dari *plan of action* tersebut ada tiga pilar yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga penegak hukum di negeri ini, yaitu: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Ketiga hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam prinsip-prinsip umum peradilan yang baik yang telah dibahas di atas. Sayangnya, kesepakatan-kesepakatan dalam *Law Summit* III yang telah ditandatangani juga oleh Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Bagir Manan pada waktu itu, pada tataran realitas, belum dapat diimplementasikan oleh Mahkamah Agung atau pengadilan di bawahnya. Terutama informasi mengenai putusan pengadilan yang mudah diakses oleh publik (*accessable*). Hal ini tidak sesuai dengan prinsip

good governance, di mana seharusnya putusan yang dikeluarkan pengadilan dapat diakses publik.

Dalam suatu kesempatan Ketua MA Bagir Manan (ketika masih menjabat) dalam pemaparan cetak biru (*blue print*) agenda pembaruan peradilan Indonesia di Gedung MA, Jakarta, menyatakan bahwa putusan itu sekali diucapkan, maka ia menjadi milik publik. Karena diucapkan dalam sidang yang terbuka, maka itu menjadi milik publik, tidak lagi milik dari mereka yang berperkara saja. Karena itu setiap mereka yang berkepentingan berhak untuk mengetahui putusan itu. Dalam beberapa kesempatan Ketua Mahkamah Agung juga memerintahkan kepada seluruh jajaran peradilan, mulai dari MA hingga pengadilan tingkat pertama dan tingkat lanjut, untuk bersikap transparan, terutama mengenai hasil-hasil putusan. Justifikasi di atas tidak hanya cukup dengan pernyataan Ketua MA ataupun "belas kasih" Ketua Pengadilan semata, tetapi juga diperlukan justifikasi hukum dalam bentuk peraturan/Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk keterbukaan akses publik terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat ke dalam lembaga pengadilan.

Kurangnya independensi kelembagaan hukum, terutama lembaga-lembaga penegak hukum juga membawa akibat besar dalam sistem hukum. Intervensi terhadap kekuasaan yudikatif misalnya, telah mengakibatkan terjadinya partialitas dalam berbagai putusan, walaupun hal seperti ini menyalahi prinsip-prinsip impartialitas dalam sistem peradilan. Akumulasi terjadinya putusan-putusan yang meninggalkan prinsip impartialitas dalam jangka panjang telah berperan terhadap terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat kepada sistem hukum maupun hilangnya kepastian hukum.

Independensi dan akuntabilitas merupakan dua sisi uang logam. Oleh karena itu, independensi lembaga hukum harus disertai dengan akuntabilitas. Namun demikian dalam praktik, pengaturan tentang akuntabilitas lembaga hukum tidak dilakukan dengan jelas, baik kepada siapa atau lembaga mana ia harus bertanggung jawab maupun tata cara bagaimana yang harus dilakukan untuk memberikan pertanggungjawabannya. Hal yang demikian telah memberikan kesan tiadanya transparansi di dalam semua proses hukum.

Secara umum, kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, dari mulai para peneliti hukum, perancang peraturan perundang-undangan sampai tingkat pelaksana dan penegak hukum masih perlu peningkatan, termasuk dalam hal memahami dan berperilaku responsif gender. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang hukum juga tidak terlepas dari belum mantapnya sistem pendidikan hukum yang ada. Apalagi sistem, proses seleksi serta kebijakan pengembangan SDM di bidang hukum yang diterapkan ternyata tidak menghasilkan SDM yang berkualitas. Di samping itu, sinyalemen tentang kurangnya integritas dari para pelaku hukum juga sangat memprihatinkan. Bahkan ada sementara pihak yang justru mengambil keuntungan dari situasi yang ada. Ini semua berpengaruh besar terhadap memudarnya supremasi hukum

serta semakin menambah derajat ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Persoalan sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka mengakibatkan hukum belum sepenuhnya memihak pada kebenaran dan keadilan karena tiadanya akses masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. Kondisi tersebut juga diperlemah dengan profesionalisme dan kualitas sistem peradilan yang masih belum memadai sehingga membuka kesempatan terjadinya penyimpangan kolektif di dalam proses peradilan sebagaimana dikenal dengan istilah mafia peradilan.

Pembinaan Satu Atap oleh Mahkamah Agung merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak memihak (*impartial*). Cetak biru (*blueprint*) yang dibuat dalam rangka mendukung Mahkamah Agung untuk melaksanakan pembinaan satu atap lembaga peradilan telah dibuat secara komprehensif. Ini dimaksudkan untuk menetapkan langkah-langkah prioritas dalam pembenahan lembaga peradilan sebagai implementasi *internal control*, di samping *external control* yang urgensinya sangat tinggi.



Penutup

Pelaksanaan pengawasan tidak selalu berjalan dengan baik dan dapat dihambat oleh berbagai halangan baik berupa hukum maupun non hukum. Seperti yang dikemukakan Antony Allot dalam buku *The limits of law "...like any system, is subject to various inbuilt source of weakness which can not be entirely eliminated, whatever we do. Our first step is therefore, like a system engineer, to examine the system for"bugs" and to "debug" it so far as possible. One must detect points of weakness in the system, fault part, bad connection, teeth missing from gears. We turn therefore to norms, their making, communication and execution, to see the possible point of weakness."*

Mengingat hal tersebut maka kebutuhan akan lembaga pengawasan untuk menciptakan peradilan yang baik adalah hal yang mutlak.

Daftar Referensi

Dunsire A. *Control in Bureaucracy*. New York, 1978, hlm. 35.

Etzioni A. *The Active Society: a Theory of Societal and Political Process*. London, 1968 hlm. 96.

Jazim Hamidi. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 24.

Koentjoro Purbopranoto. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1975.

Leip. *Pengadilan Khusus Korupsi*. cetakan pertama 2002.

Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1992, hlm. 37.

Niemeijer, E., & J.S. *Timmer, Het ABC van de Nationale Ombudsman: Arbiter, Bewaker en Consulent*. Bestuurkunde, Nr. 8, 1993, hlm. 378.

Paulus Effendie Lotulung. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 15.

Phillip Giddings, et.al. *Controling Administrative Action in The United Kingdom: The Role of Ombudsman System and The Court Compare*, Rev. of Administrative Sciences, Kol. 59 Nr. 2 June 1993, Page. 301

Prins. *Inleiding in het administratief recht van Indonesie*, dalam Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi*. Bandung: Alumni, 1985, hlm. 46

Ten Berge, JB.J.M. *De Beketenis van de nationale Ombudsman voor het bestuursrecht, in: De Nationale Ombudsman*, VAR-reeks 106, Alphen aan den Rijn, 1991, hlm. 19.

Ten Berge, J.B.J.M, *Bestuuren door de overheid, Nederlands, algemeenbestuursrecht 1*, W.E.J. Tjeenk Willink Deventer, 1996, hlm. 34-35.

RAJAWALI PERS

Bagian Kelima

Pengembangan Lembaga dan Pranata Hukum

RAJAWALI PERS

31

GAGASAN PENGADILAN PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 1999: SUATU TINJAUAN SEJARAH HUKUM

Oleh:
*Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.**

Pengantar

DARI MASA KE MASA, penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tidak pernah terbebas dari berbagai bentuk kejahatan dan atau pelanggaran. Walaupun sudah "dipagari" oleh berbagai macam ketentuan pidana, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang (UU) Pemilu, namun kejahatan dan atau pelanggaran tetap saja terjadi.[1]

Dalam KUHP, ketentuan tentang hal ini diatur dalam Bab IV Buku Kedua mengenai tindak pidana "Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan" yang berkaitan dengan suatu pemilu yang diadakan berdasarkan UU. Tak kurang dari lima pasal yang mengatur mengenai masalah ini, yakni Pasal 148-152.[2]

Di samping KUHP, rambu-rambu mengenai hal ini juga terdapat di dalam UU Pemilu yang berlaku pada saat ini.[3] Dalam Bab XIII, Pasal 72-75 UU tersebut secara khusus diatur mengenai "Ketentuan Pidana". Jika dihitung-hitung, dalam UU Pemilu tersebut dirumuskan tidak kurang dari 9 macam kejahatan dan 2 macam pelanggaran. Ancaman hukumannya pun bervariasi, mulai dari

---

*Guru Besar Hukum Tata Negara dan dan Mantan Wakil Dekan Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan mantan Sekretaris Umum Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 1999 Tingkat Pusat (Panwaspus).

[1]Satya Arinanto, "Pelanggaran Pemilu, Perlu Majelis Khusus," *Berita Keadilan*, Edisi No. 26, 21-27 April 1999, hlm. 18.

[2]*Ibid.*

[3]Pada saat penulisan artikel ini, UU Pemilu yang sedang berlaku adalah UU No. 3 Tahun 1999. Pada saat itu Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sedang mempersiapkan perancangan UU Pemilu yang baru.

kurungan maksimal selama 3 bulan, denda maksimal sebesar Rp10 juta, hingga penjara maksimal selama 5 tahun.[4]

Berbeda dengan UU Pemilu, dalam KUHP yang diterjemahkan dari *Wetboek van Strafrecht*, ancaman hukuman dalam bentuk kurungan dalam kasus pemilu tak dikenal. Yang ada adalah ancaman hukuman penjara dari yang teringan 9 (sembilan) bulan hingga yang tertinggi 2 (dua) tahun. Di samping itu, juga ada ancaman denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.[5]

Hal yang unik ialah, berbagai UU Pemilu yang berlaku selama ini tidak pernah menegaskan kaitan Bab tentang Ketentuan Pidana yang tercantum di dalamnya dengan ketentuan yang serupa di dalam KUHP. Namun demikian, berdasarkan asas *lex posteriore derogat lex priori*—UU yang bersifat khusus menyampingkan UU yang bersifat umum, jika pembuatnya sama/sejajar maka ketentuan-ketentuan pidana dalam UU Pemilulah yang berlaku. Dengan demikian, ancaman pidana dalam KUHP tersebut dapat digolongkan ke dalam "ketentuan yang mati" atau tidak berlaku lagi.[6]

Dalam pelaksanaan Pemilu 1999 yang lalu, misalnya, walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 1999 tentang "Jadwal Waktu Tahapan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu", namun pelanggaran-pelanggaran tetap saja terjadi. Simak saja misalnya kecenderungan partai-partai politik (parpol) untuk mencuri *start* kampanye. Dengan dalih mengadakan acara "temu kader", "silaturahmi", ataupun "apel akbar", para parpol dengan leluasa melanggar aturan KPU dan UU Pemilu tentang jadwal waktu kampanye.[7] Karena itulah, tak mengherankan bila kalangan hukum kemudian ramai meneriakkan perlunya dibentuk pengadilan khusus pemilu, agar persidangan terhadap kasus-kasus pelanggaran pemilu dapat segera digelar.



Pengadilan Pemilu Versi SEMA No. 1 Tahun 1999

Pendapat yang muncul berkaitan dengan hal ini antara lain mengusulkan perlunya dibentuk pengadilan khusus pemilu di tingkat kecamatan, agar pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah yang merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pemilu tersebut dapat diselesaikan. Berkaitan dengan usul pembentukan pengadilan tersebut, disadari bahwa sumber daya manusia merupakan kendala utama. Namun, usulan tersebut memberi jalan

---

[4]Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, UU No. 3 Tahun 1999, LN No. 23 Tahun 1999, TLN No. 3810, Pasal 72-75.

[5]Arinanto, *loc. cit*.

[6]*Ibid*.

[7]Satya Arinanto, "Pelanggaran *Start* Kampanye," *Berita Keadilan*, Edisi No. 25, 14-20 April 1999, hlm. 18.

tengah agar pengadilan itu tidak perlu dibentuk di tiap-tiap kecamatan, melainkan hanya di kecamatan-kecamatan yang memiliki cabang parpol yang paling banyak, atau di mana terjadi konsentrasi massa yang cukup besar.

Namun demikian, ketika usulan tersebut pertama kali dikemukakan pada tahun 1999 (sekitar 1,5 bulan sebelum waktu pelaksanaan pemilu saat itu), terasa bahwa usulan tersebut sangat berat untuk dilaksanakan. Berdasarkan data KPU pada saat itu, tercatat tak kurang dari 306 kabupaten/kotamadya, 4.029 kecamatan, 61.668 kelurahan/desa, dan sekitar 200.000 tempat pemungutan suara (TPS). Untuk pemilu yang akan datang, data itu akan bertambah mengingat adanya beberapa daerah yang mengalami "pemekaran wilayah".

Di samping itu, wacana tentang pengadilan khusus pemilu yang muncul pada 1999 yang lalu juga memunculkan permasalahan tentang hubungan antara pengadilan tersebut dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas)–dalam arti apakah pembentukannya tidak bertentangan atau bersifat tumpang tindih dengan Panitia Pengawas Pemilu? Menurut sosiolog hukum Prof. Satjipto Rahardjo, pembentukan pengadilan semacam itu tidak akan bertentangan dengan Panwas, tetapi justru harus berjalan bersama. Menurut Rahardjo, penyelesaian Panwas lebih mengarah ke masalah sosial politik, sedangkan pengadilan pemilu lebih berupa penyelesaian masalah secara yuridis.[8]

Berkaitan dengan Ketentuan Pidana yang terdapat dalam UU Pemilu, dalam kaitan dengan pelaksanaan Pemilu 1999 yang lalu MA telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1999 tentang "Tugas Khusus Pengadilan Negeri (PN) untuk Pemilu". SEMA bernomor: MA/Kumdil/44/III/K/1999 tertanggal 19 Maret 1999 tersebut ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.[9]

Pada intinya, SEMA tersebut menegaskan tiga hal sebagai berikut: *pertama*, agar pengadilan memberikan prioritas dengan memberikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan atas pemeriksaan dan penyelesaian perkara-perkara yang khusus menyangkut ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu beserta peraturan pelaksanaannya. *Kedua*, agar pengadilan membentuk majelis khusus dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan pemilu, dan anggotanya bukan hakim yang telah ditunjuk sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum. *Ketiga*, menangguhkan pelaksanaan pelaksanaan eksekusi putusan khususnya yang berkaitan dengan pengosongan selama pelaksanaan pemilu, mulai dari tahap kampanye hingga tahap penetapan hasil pemilu. SEMA ini juga meminta agar pengadilan memberikan informasi dan penjelasan tentang ketiga hal tersebut, serta menyebarluaskan SEMA tersebut kepada para hakim di wilayah kerja masing-masing.[10]

---

[8] *Kompas*, 15 April 1999, hlm. 6.
[9] Arinanto, "Pengadilan Pemilu, Perlu Majelis Khusus", *loc. cit*.
[10] *Ibid*.

Dengan penerbitan SEMA tersebut khususnya butir kedua yang memerintahkan pembentukan suatu "majelis khusus" secara teknis sebenarnya telah cukup memadai sebagai sarana untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran pemilu. Namun demikian, ada persyaratan lain agar para hakim yang menyidangkan perkara-perkara pemilu yang harus berbeda dengan para hakim yang bertugas sebagai Panitia Pengawas Pemilu benar-benar bersifat independen dalam memutuskan perkara-perkara pemilu.

Dengan demikian, akar permasalahan sebenarnya kembali ke masalah klasik tentang independensi para hakim. Walaupun para hakim tersebut tidak duduk sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilu, namun jika mereka tidak independen dalam memutuskan perkara, maka tak akan ada gunanyalah rencana pembentukan majelis khusus tersebut. Berbeda dengan pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, berdasarkan UU No. 3 Tahun 1999 tersebut para hakim memang duduk dalam keanggotaan Panitia Pengawas Pemilu. Di tingkat pusat misalnya, dari 30 anggota Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Pusat, terdapat dua orang hakim agung. Sedangkan di tingkat Provinsi DKI Jakarta, dari 19 orang anggota Panitia Pengawas Tingkat Provinsi,[11] terdapat 1 orang hakim tinggi.

Demikian pula dengan Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten/Kota,[12] juga terdapat wakil-wakil dari para hakim yang berasal dari Pengadilan Negeri (PN) setempat. Keberadaan para hakim ini tidak tercatat dalam Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan, karena tidak ada pengadilan tingkat kecamatan. Sebagaimana ditegaskan di muka, para hakim yang telah duduk dalam keanggotaan Panitia Pengawas Pemilu tidak boleh duduk dalam majelis khusus yang akan mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu. Ketentuan ini memang sempat menimbulkan permasalahan di beberapa daerah yang jumlah hakimnya kurang, seperti misalnya yang ditemui di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, hingga pelaksanaan pemilu berlangsung, ternyata permasalahan ini pada akhirnya dapat terselesaikan.

Wacana tentang Pengadilan Pemilu Menurut RUU Versi Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Versi *Centre for Electoral Reform* (CETRO)

Berkaitan dengan pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) Bidang Politik untuk pemilu yang akan datang yang banyak dilakukan pada saat

[11]Sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, lembaga ini disebut sebagai Panitia Pengawas Pemilu Tingkat I.

[12]Sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, lembaga ini disebut Panitia Pengawas Pemilu Tingkat II.

ini, ditemui adanya berbagai usulan tentang konsep pengadilan pemilu di masa depan. Salah satu konsep yang mengemuka ialah perlunya suatu Pengadilan Pemilu *Ad Hoc*. Berkaitan dengan konsep tersebut, RUU Pemilu yang diajukan oleh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada saat itu misalnya, telah membuka kemungkinan adanya pengadilan pemilu yang bersifat *ad hoc*.

Dalam salah satu *draft* RUU, tercantum bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Pemilihan Umum adalah: (a) menerima Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaan pemilu dan KPU; dan (b) memeriksa dan memutus pelanggaran peraturan pelaksanaan pemilu. Terhadap putusan Pengadilan Pemilu hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi.[13]

Center for Electoral Reform (CETRO), suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang banyak meneliti masalah pemilu di Jakarta, juga telah menyusun suatu rancangan tentang Pengadilan Pemilu *Ad Hoc* dan Hukum Acara Pengadilan Pemilu *Ad Hoc*. Jika dibandingkan dengan rancangan versi Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, konsepsi CETRO memiliki beberapa perbedaan, antara lain adanya penegasan bahwa pengadilan pemilu *ad hoc* dibentuk oleh Mahkamah Agung (MA).[14]

Jika disimak lebih jauh, selain melalui Pengadilan *Ad Hoc,* konsepsi yang diajukan oleh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah juga masih memberikan kewenangan kepada KPU untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilihan Umum, antara calon yang berasal dari Parpol yang berbeda, dan antara organisasi/kelompok masyarakat dan Parpol Peserta Pemilihan Umum, dan antara Parpol Peserta Pemilihan Umum. Pasal selanjutnya yang mengatur mengenai masalah ini tampaknya memiliki kecenderungan untuk memberikan kewenangan KPU sebagai semacam lembaga arbitrase, yang berwenang memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat untuk menyelesaikan perselisihan.[15]

Jika ditinjau lebih lanjut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang mungkin timbul berkaitan dengan pembentukan pengadilan pemilu *ad hoc* tersebut. Masalah-masalah tersebut terbentang dari masalah sanksi-sanksi untuk pelanggaran UU Parpol hingga beberapa permasalahan yang bersifat spesifik, misalnya tentang urgensi pembentukannya, struktur pengadilannya, hukum acaranya, aparat hukumnya, dan kesiapan pemerintah untuk membentuk pengadilan tersebut.

Berkaitan dengan urgensi pemisahan pengadilan pemilu *ad hoc* dengan pengadilan lainnya, dapat dikemukakan bahwa hal ini memang perlu dilakukan

---

[13]Lihat Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Umum (Konsep III, Draft II) versi Tim Asistensi Perubahan Undang-Undang Bidang Politik, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI, 2001.

[14]Lihat konsepsi CETRO tentang Pengadilan Pemilu *Ad Hoc* dan Hukum Acara Pengadilan Pemilu *Ad Hoc*, 2001.

[15]Lihat Pasal 39 RUU Pemilu versi Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

mengingat adanya kekhususan-kehususan permasalahan yang dihadapi dalam pemilu, baik yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran. Namun demikian, dalam kerangka sistem hukum nasional pada umumnya, memang harus dipikirkan kembali kecenderungan-kecenderungan untuk membentuk berbagai pengadilan *ad hoc*, termasuk untuk masalah pemilu. Karena akan menimbulkan permasalahan pula jika terlalu banyak dibentuk pengadilan *ad hoc* dalam kerangka sistem hukum nasional kita.

Jika pun kemudian pengadilan *ad hoc* dipandang tepat untuk menjadi solusi sementara untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka struktur pengadilan pemilu *ad hoc* yang akan didirikan tetap tidak bisa dilepaskan dari struktur pengadilan-pengadilan yang sudah ada. Paling tidak, ia harus dikaitkan dengan salah satu tingkat pengadilan yang sudah ada. Jika dilihat dari kemungkinan tersebarnya pelanggaran-pelanggaran terhadap UU Pemilu, maka paling tepat jika pengadilan pemilu *ad hoc* dapat diletakkan di tingkat pengadilan negeri, yang wilayah hukumnya mencapai hampir seluruh kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Permasalahan selanjutnya yang agak kompleks ialah yang berkaitan dengan perumusan hukum acaranya. Paling tidak, hukum acara tersebut harus mencakup seluruh jenis pelanggaran maupun kejahatan pemilu, baik yang telah dirumuskan dalam KUHP, UU Pemilu, maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, maupun yang belum dirumuskan di dalam berbagai peraturan tersebut.

Perumusan hukum acara tersebut juga harus diselaraskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku di Indonesia. Misalnya, UU No. 28 Tahun 1997[16] tentang Kepolisian Negara RI (Polri) memberikan kewenangan kepada Polri untuk menyidik semua jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana pemilu. Kewenangan semacam ini harus ditinjau kembali karena berdasarkan salah satu konsepsi yang diajukan oleh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, (jika disetujui) akan ada suatu institusi khusus yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemilu.

Pembicaraan tentang prospek hukum acara pemilu ini juga mencakup pembahasan tentang mekanisme banding dan upaya hukum lainnya. Di samping itu, secara makro ia juga akan berkaitan dengan permasalahan aparat hukum dan kesiapan pemerintah untuk menyelenggarakannya. Misalnya, pada saat UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara diberlakukan, dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengadilan ini baru akan dilaksanakan selambat-lambatnya lima tahun setelah UU tersebut disahkan. Hal ini berkaitan dengan perlunya persiapan sarana dan prasarana hukum serta unsur-unsur lainnya.

[16]Saat ini sudah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2002.

Berkaitan dengan hal itu, jika UU Pemilu tersebut jadi disahkan, paling tidak diperlukan waktu sekitar 2-3 tahun untuk mempersiapkan pendiriannya di seluruh Indonesia. Karena itu mau tidak mau RUU Pemilu tersebut harus disahkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun ini, agar jika pemilu akan dilaksanakan sesuai jadwal, masih terdapat cukup waktu untuk sosialisasi dan persiapan pendiriannya.



Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu

Dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, kita memiliki suatu lembaga baru yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 24C UUD 1945 ayat (1), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.[17]

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.[18] Mekanisme penggunaan kewenangan yang disebutkan terakhir ini terdapat dalam Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Perubahan Ketiga UUD 1945.[19]

Jika kita meninjau rumusan tersebut, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga yang harus segera terbentuk sebelum pelaksanaan Pemilu 2004, karena ia memiliki beberapa wewenang yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rapatnya pada tanggal 6 April 2002, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR antara lain telah menghasilkan kesepakatan untuk mencantumkan rumusan Ayat (2) Aturan Tambahan dengan rumusan sebagai berikut:[20]

Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden harus telah membentuk undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ini disahkan.

---

[17]Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001), hlm. 13.

[18]*Ibid.*, lihat Pasal 24C ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945.

[19]*Ibid.*, hlm. 8–9.

[20]Lihat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, "Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc* I pada Rapat ke-3 Badan Pekerja MPR di Jakarta, 4 Juni 2002.

Dalam menanggapi rumusan ini, penulis berpendapat bahwa seyogianya tidak hanya UU tentang Mahkamah Konstitusi saja yang harus diprioritaskan pembentukannya, melainkan seluruh UU yang telah diperintahkan oleh Perubahan Pertama hingga Perubahan Keempat UUD 1945 yang akan datang. Jika berbagai UU yang telah diperintahkan pembentukannya oleh Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan—rancangan yang akan disetujui sebagai—Perubahan Keempat UUD 1945 tersebut tidak segera terbentuk, maka berbagai perubahan yang dimaksud tidak dapat segera diimplementasikan.



Pengadilan Pemilu Versi RUU Departemen Dalam Negeri

Sebagaimana diketahui, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) baru-baru ini menyampaikan RUU Pemilu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Begitu rancangan tersebut beredar di masyarakat, segera timbul perdebatan yang mengarah ke pro dan kontra terhadap beberapa rancangan materi yang terdapat di dalam RUU tersebut. Pro dan kontra yang sedang berlangsung hangat di masyarakat hingga saat ini ialah mengenai akan diberikannya hak memilih dan hak dipilih bagi para anggota TNI dan Polri.

Berkaitan dengan UU Pemilu, dalam RUU ini antara lain dinyatakan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran terhadap UU ini akan dilakukan oleh Pengadilan Pemilu bersifat *Ad Hoc* yang dibentuk dengan undang-undang.[21] Namun demikian, RUU ini tidak memberikan gambaran lebih lanjut tentang Pengadilan Pemilu *Ad Hoc* seperti apa yang akan dibentuk. Hal ini dikarenakan rancangan penjelasan dari pasal tersebut hanya mengatakan: "Cukup jelas".



Pengalaman Beberapa Negara[22]

Dalam Subbab ini akan dikemukakan gambaran singkat mengenai Pengadilan Pemilu (*Electoral Court*) di beberapa negara. Pertama-tama akan kita tinjau Negara Brazil. Dalam Pasal 118 Konstitusi Brazil ditetapkan bahwa Pengadilan Pemilu memiliki beberapa badan sebagai berikut: (1) *the Superior Electoral Court*, (2) *the Regional Electoral Courts*, dan (3) *the Electoral Boards*.

---

[21]Lihat rancangan Pasal 127 dari RUU tersebut.

[22]Untuk penyusunan subbab ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada Sdr. Moh. Adhy S. Aman, S.H. dari *International Foundation for Election Systems* (IFES) Indonesia di Jakarta, yang telah memberikan berbagai bahan dan *website address* yang berkaitan dengan judul subbab ini. Mengingat luasnya bahan-bahan yang telah diberikan, maka dalam subbab ini hanya akan disinggung beberapa hal saja yang berkaitan dengan hal itu. Namun demikian, diskusi yang lebih mendalam mengenai hal ini dapat dilakukan dalam sesi tanya-jawab.

Dalam Pasal 121nya yang mengatur mengenai Kewenangan, Fungsi, dan Organisasi antara lain ditegaskan bahwa organisasi dan yurisdiksi dari Pengadilan Pemilu, para Hakim, dan para Anggota Dewan diatur dalam UU tersendiri. Pada saat sedang bertugas, para pihak yang disebut di muka dijamin kewenangannya dan mereka tidak dapat dipindah-pindahkan. Mereka menjabat sekurang-kurangnya selama dua tahun dan tidak boleh melebihi dua periode masa jabatan. Putusan dari Pengadilan Pemilu tidak dapat dibanding ke pengadilan lain, kecuali putusan-putusan yang bertentangan dengan Konstitusi, *Habeas Corpus*, dan sebagainya.

Di samping di Brazil, lembaga peradilan yang berfungsi seperti Pengadilan Pemilu juga terdapat di berbagai negara lainnya seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Mexico, dan Papua Nugini. Hampir di berbagai negara, pengadilan-pengadilannya memiliki peranan yang sangat terbatas atau dapat dikatakan tidak memiliki peranan sama sekali dalam proses pembatasan atau redistrikisasi (*delimitation* atau *redistricting process*). Namun, ada pengecualian terhadap hal itu, yakni sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat, di mana pengadilan-pengadilan telah memutuskan ratusan kasus yang berkaitan dengan rencana-rencana yang berkaitan dengan Kongres atau distrik legislatif.[23]

Sedangkan di Kanada, pengadilannya beberapa waktu yang lalu juga telah berspekulasi dalam arena redistrikisasi (*redistricting*), meskipun mereka telah mengeluarkan opini yang hanya berkaitan dengan konstitusionalitas dari batas-batas legislasi dan peta pemilihan provinsi. Hal ini mungkin dapat berubah dalam waktu dekat. Tantangan pertama terhadap rencana distrik pemilihan federal diajukan di Kanada pada 1997. Inggris merupakan negara lainnya di mana pengadilannya telah diminta untuk mempertimbangkan legalitas dari rencana redistrikisasi. Tetapi tantangan satu-satunya tersebut hingga saat ini belum berjalan dengan sukses, dan hal ini mungkin tidak mendorong proses litigasi yang terkait dengan permasalahan keadilan dari suatu rencana redistrikisasi atau proses redistrikisasi di Inggris.[24]

Di Mexico, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu antara lain diatur dalam *Federal Criminal Code*, antara lain dalam Pasal 403–408, dan Pasal 411–412. Pasal 403 misalnya, memberikan rincian tentang perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang mungkin dilakukan oleh individu selama masa pemilu, kampanye, dan bahkan dalam proses pemilu sebagai berikut:[25]

---

[23]Handley, Lisa, Arden, dan Wayne, "Boundary Delimitation: Role of the Courts in Electoral District Delimitation". http://www.aceproject.org/main/english/bd/bdb06/default.htm, 19 Juni 2002.

[24]*Ibid*.

[25]Office of the Prosecuting Attorney Specialized in Electoral Crimes, "Juridical Nature of FEPADE and the Electoral Crimes", (Mexico: 11 Oktober 2001).

a. *To illegally vote;*
b. *To carry out proselytism or to pressure the voters that are present at the voting booths;*
c. *To buy or force the votes by any forbidden means;*
d. *To obstruct, interfere or prevent the correct exercise of the duties of the electoral functionaries;*
e. *To restrict or pretend to restrict, in any way, the freedom of suffrage;*
f. *To violate the secrecy of suffrage;*
g. *To introduce or remove the voting slips or ballot boxes, that is, documents or electoral material, of the place that they legally correspond;*
h. *To publish the results of the opinion survey within the 8 days prior to election day;*
i. *To exchange the vote of the individual by means of a promise, coercion or gift*.

Sedangkan di Papua Nugini, dijumpai adanya kenyataan bahwa petisi-petisi pemilu (*election petitions*) telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Setiap orang mengetahui jumlah petisi pemilu yang tercatat disampaikan setelah pelaksanaan Pemilu 1997–88 petisi secara keseluruhannya. Diharapkan, jumlah petisi akan semakin meningkat setelah pelaksanaan Pemilu 2002 yang rencananya diselenggarakan dalam bulan Juni ini. Ada dua badan yang berkaitan dengan naik atau turunnya jumlah petisi pemilu. Pertama, Komisi Pemilu (*the Electoral Commission*) dan agen-agennya di provinsi-provinsi dapat meminimalkan petisi dengan penyelenggaraan pemilu yang bersih. Kedua, para kandidat dan pendukungnya harus mengontrol tingkah lakunya agar selalu sesuai dengan hukum, agar petisi pemilu atau problema pemilu lainnya tidak timbul.[26]



Penutup

Demikian beberapa wacana di sekitar pembentukan pengadilan *ad hoc* pemilu. Di luar wacana tentang masalah pengadilan pemilu yang bersifat *ad hoc* tersebut, sebenarnya ada lagi institusi peradilan lain yang sangat diperlukan di Indonesia, yang salah satu tugas dan kewenangannya juga dapat mencakup masalah pemilu. Peradilan yang dimaksud ialah suatu Mahkamah Konstitusi, semacam *Federal Constitutional Court* di Jerman. Di Jerman, lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk membubarkan parpol, dengan alasan telah melanggar prinsip-prinsip "*free democratic basic order*".

Dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, institusi ini juga telah dicantumkan. Namun demikian, untuk pelaksanaannya masih harus menunggu sejauh mana

[26]John Nonggorr, "Preparations for 2002 Elections of PNG: The Courts," http://www.thenational.com.pg, 1 April 2002.

RUU tentang Mahkamah Konstitusi akan menjabarkan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Perubahan Ketiga tersebut. Di sisi lain, secara teknis sebenarnya ketiga RUU Bidang Poilitik yang telah dipersiapkan pihak Departemen Dalam Negeri, khususnya RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, juga tidak bisa langsung diberlakukan, karena masih harus menunggu hasil-hasil Perubahan Keempat UUD 1945.

Dengan demikian, wacana tentang pengadilan pemilu yang bersifat *ad hoc* tersebut juga masih menjadi sebatas wacana, dan harus disesuaikan dengan kemungkinan Perubahan Ketiga dan Perubahan Keempat UUD 1945, di mana yang disebut terakhir ini masih dalam taraf pembahasan di Badan Pekerja MPR RI. Semoga rancangan Perubahan Keempat ini dapat segera ditetapkan dalam Sidang Tahunan ketiga MPR pada bulan Agustus 2002 yang akan datang, agar proses reformasi yang sedang berjalan tidak menjadi terhenti.

Daftar Referensi

Arinanto, Satya. "Sistem Pemilihan Umum Proporsional: Beberapa Catatan". Makalah disampaikan dalam forum Ceramah Ilmiah bagi para pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI di Jakarta, 7 Februari 2000.

————. "Beberapa Catatan tentang Pemilu Lokal". Makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Terbatas Mengenai Pemilu Lokal yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI di Jakarta, 26 Januari 2000.

————. "Di Balik Kontroversi Penetapan Hasil Pemilu". *Berita Keadilan*, Edisi No. 41, 4-10 Agustus 1999.

————. "Kontroversi PP No. 33 Tahun 1999". *Berita Keadilan*, Edisi No. 38, 14-20 Juli 1999.

————. "Campur Tangan Birokrasi dalam Pemilu 1999". *Berita Keadilan*, Edisi No. 37, 7-13 Juli 1999.

————. "Panwaslu Kurang Mandiri". *Pilar*, No. 11 Tahun II, 9-22 Juni 1999.

————. "Ditunggu, Peran MA sebagai "*Constitutional Court*". *Kompas*, 21 Juni 1999.

————. "Aspek Hukum Pemilu Ulangan dan Susulan". *Berita Keadilan*, Edisi No. 34, 16-22 Juni 1999.

————. "Mengawasi Pemilu di Singapura dan Johor Baru". *Berita Keadilan*, Edisi No. 33, 9-15 Juni 1999.

————. "Stembus Accord". *Berita Keadilan*, Edisi No. 32, 2-8 Juni 1999.

————————. "Dilema Pengawasan Pemilu". *Panji Masyarakat*, 26 Mei 1999.

————————. "Pelanggaran Pra Kampanye Pemilu". *Berita Keadilan*, Edisi No. 30, 19-25 Mei 1999.

————————. "Empat Permasalahan Hukum Pemekaran Irian Jaya dan Maluku". *Berita Keadilan*, Edisi No. 27, 27 April – 4 Mei 1999.

————————. "Pemilu, KPU, dan Konsep 'Jalan Tengah'". Buletin *Jaring*, 14 April 1999.

————————. "Pengadilan Pemilu, Perlu Majelis Khusus". *Berita Keadilan*, Edisi No. 26, 21-27 April 1999.

————————. "Pelanggaran *Start* Kampanye". *Berita Keadilan*, Edisi No. 25, 14-20 April 1999.

————————. "Anatomi Pertimbangan Hukum MA". *Berita Keadilan*, Edisi No. 24, 7-13 April 1999.

————————. "KPU, MA, dan Pertimbangan Hukum". *Berita Keadilan*, Edisi No. 23, 31 Maret–6 April 1999.

————————. "Pengawasan dan Pemantauan Pemilu". *Berita Keadilan*, Edisi No. 22, 24-30 Maret 1999.

————————. "PNS-ABRI: Satu UU, Dua Hukum". *Kompas*, 1 Februari 1999.

Bjornlund, Eric. "*The Promise of Democratization in Hong Kong: The New Election Framework*". Washington, D.C.: National Democratic Institute for International Affairs, 1997.

Diamond, Larry. "*Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation*". *Journal of Democracy*, 5 (Juli, 1994), 4-17.

Garber, Larry. "Establishing a Legal Framework for Elections." Washington, D.C.: National Democratic Institute for International Affairs, 1992.

Handley, Lisa, Arden, dan Wayne. "*Boundary Delimitation: Role of the Courts in Electoral District Delimitation*". <http://www.aceproject.org/main/english/bd/bdb06/default.htm>. 19 Juni 2002.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.

Meadowcroft, Michael. *The Politics of Electoral Reform*. London: The Electoral Reform Society, 1991.

Merloe, Patrick. "*Electoral Operations, Human Rights, and Public Confidence in a Democratic System*". Paper presented in African Election Administrators' Colloqium in Zimbabwe, 15-18 November 1994.

Nonggorr, John. "Preparations for 2002 Elections of PNG: The Courts". <http://www.thenational.com.pg>. 1 April 2002.

Office of the Prosecuting Attorney Specialized in Electoral Crimes. "Juridical Nature of FEPADE and the Electoral Crimes". Mexico: 11 Oktober 2001.

Panitia *Ad Hoc I* Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. "Laporan Perkembangan Pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc I* pada Rapat ke-3 Badan Pekerja MPR". Jakarta: 4 Juni 2002.

United Nations. *Human Rights and Elections: A Handbook on the Legal, Technical, and Human Rights Aspects of Elections*. New Geneva: Centre for Human Rights, 1994.

RAJAWALI PERS

32

MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Oleh:
*Prof. Dr. Hj. Yuhari Robingu, S.H., M.S.**

Pendahuluan

DALAM SUATU NEGARA yang sedang membangun, keberadaan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dari berbagai komponen pembangunan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Namun, dalam kenyataannya mau tidak mau harus diakui bahwa komponen tenaga kerja merupakan hal yang paling menonjol.

Dalam kenyataannya, sektor industri di negara-negara sedang berkembang mempunyai daya serap tenaga kerja yang tidak memadai dalam arti bahwa dari penambahan angkatan kerja yang ada hanya merupakan suatu presentasi kecil saja yang memperoleh pekerjaan di sektor industri. Tentang masalah ketenagakerjaan di Indonesia, seperti negara sedang berkembang lainnya, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi dan memerlukan pemikiran. penelitian, penelaahan dan pemecahan masalahnya. Di antara masalah ketenagakerjaan yang menonjol adalah kesenjangan antara melimpahnya angkatan kerja yang akan memasuki dan memerlukan pekerjaan, di lain pihak terbatasnya kemampuan untuk menyerap angkatan kerja tersebut. Atas kenyataan tersebut, terjadilah suatu kontradiksi bahwa di satu pihak sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan. Akan tetapi, di lain pihak kondisi demikian dapat menimbulkan masalah-masalah yang rumit.

Memerhatikan kondisi ketenagakerjaan demikian, kiranya perlu ada suatu perangkat hukum bagi sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kerja, terutama bagi mereka yang akan dan sedang mencari pekerjaan atau akan dan sedang melaksanakan hubungan kerja.

---

*Dosen Fakultas Hukum UNTAG Surabaya & Ketua Program Studi S-3 Doktor Ilmu Hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa semua Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajihan yang sama dan seimbang dalam melakukan hubungan hukum, begitu juga dalam hal melakukan hubungan hukum yang dilaksanakan antara pengusaha dan pekerja.

Walaupun semua warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum, namun dalam kenyataannya pengusaha sebagai pihak pemberi kerja dan upah jelas mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang lebih tinggi sehingga dalam melakukan hubungan hukum dengan pekerja sebagai pihak yang mempunyai kondisi sosial ekonomi yang lemah, jelas kebebasan dalam melakukan hubungan hukum khususnya dalam pembuatan perjanjian kerja ada di tangan pengusaha. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada pengusaha, maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum menurut Philipus:

> Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam huhungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Menurut Zainal Asikin, perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Dikatakan:

> Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.[1]

Bruggink membagi keberlakuan hukum menjadi tiga, yaitu keberlakuan faktual, keberlakuan normatif dan keberlakuan evaluatif/materiil.

Keberlakuan faktual, yaitu kaidah dipatuhi oleh para warga masyarakat/ efektif kaidah diterapkan dan ditegakkan oleh pejabat hukum; keberlakuan normatif, yaitu kaidah cocok dalam sistem hukum hierarkis; keberlakuan evaluatif, yaitu secara empiris kaidah tampak diterima; secara filosofis kaidah memenuhi sifat mewajibkan karena isinya.[2]

---

[1]Zainal Asikin, et.al, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 5.

[2]J.J. Bruggink, alih bahasa Arief Sidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 157.

Adanya peraturan-peratuan hukum adalah untuk dipatuhi. Penguasa yang membuat peraturan tidak bermaksud untuk menyusun peraturan-peraturan agar dilanggar. Peraturan hukum dibuat dengan tujuan untuk memecahkan problema-problema yang terjadi dan bukan untuk menambah problema yang sudah ada dalam masyarakat.

Dalam rangka mempelajari bekerjanya hukum di dalam masyarakat, perlu dipahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan terhadap hukum dari masyarakat. Masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu segi dari persoalan yang lebih luas, yaitu kesadaran hukum. Untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan terhadap hukum perlu diketahui apakah sebab-sebabnya anggota masyarakat itu mau patuh pada hukum.

Menurut Leopold Popisil, masalah kepatuhan hukum dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. *Compliance: an overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment not by any conviction in the desirability of the enforced rule: Power of influencing agent is based on "means control" and as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance.*
2. *Identification: an acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because a person's desire to maintain membership in a group or relationship with the agent the source of power is the attractiveness of the relations which the persons enjoy with the group or agent and his conformity with the rule will he dependent upon the salience of those relationship.*
3. *Internalisation: the acceptance by an individual of a rule of behavior because the finds its content intrinsically rewarding. The content is congruent with a person's value either because his value changed and adapted to the inevitable.*[3]

Faktor-faktor di atas dapat berdiri sendiri atau dapat pula merupakan gabungan dari bermacam-macam faktor tersebut.

Hubungan pekerja dengan pengusaha pada dasarnya bersifat "unik". Di satu pihak, hubungan hukum yang tidak seimbang[4] antara pekerja dengan pengusaha sangat rentan terhadap terjadinya konflik. Di lain pihak, hubungan saling membutuhkan (*mutual symbiosis*) antara pekerja dengan pengusaha merupakan embrio bagi terciptanya hubungan kerja sama antara pekerja dengan pengusaha itu sendiri.

Hubungan industrial yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha berpotensi menimbulkan perbedaan dan dapat terjadi setiap saat. Apabila perbedaan pendapat tidak segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya akan berubah menjadi perselisihan yang pada akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak, yakni timbulnya gangguan terhadap ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.

---

[3]Leopold Popisil, *Antropology of Law, A Comparative Theory,* (New York: Harper & Row Publisher, 1971), hlm. 196.

[4]W. Friedman, *Legal Theory, (*New York: Columbia University Press, 1967), hlm. 218.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dengan terjadinya perselisihan, maka wajarlah apabila semua pihak yang terlibat dalam hubungan industrial berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah timbulnya perselisihan. Namun demikian, apabila upaya dapat dihindarkan, maka para pihak dapat menyelesaikan secara efektif dan objektif.

Pada dasarnya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih atau secara bipartit sehingga dapat memperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian bipartit ini dilakukan melalui musyawarah dan mufakat oleh para pihak tanpa dicampuri oleh pihak manapun. Sebagai upaya pemerintah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat pekerja dan sejalan adanya era demokratisasi di segala bidang, maka perlu diakomodasikan keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Untuk mempertahankan atau memelihara huhungan kemitraan antara pekerja dengan pengusaha, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan memiliki posisi penting.

Dari uraian di atas, yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial?



Hubungan Industrial di Indonesia

Sebelum lebih jauh diuraikan mengenai konsepsi hubungan industrial di Indonesia, pada awal pembahasan ini akan dipaparkan beberapa bentuk hubungan industrial, yakni:

1. Hubungan Industrial berdasarkan Demokrasi Liberal

   Hubungan industrial ini berlandaskan pada falsafah individualisme dan liberalisme, yang dianut negara-negara industri barat pada umumnya. Ciri-ciri hubungan industrial atas dasar demokrasi liberal adalah:

   a. pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan yang berbeda, yakni kepentingan pekerja untuk mendapatkan upah yang sebesar-besarnya sedangkan pengusaha untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya;
   b. perbedaan pendapat diselesaikan dengan adu kekuatan, pekerja dengan senjata mogoknya sedangkan pengusaha menutup perusahaannya *(flock out)*.

2. Hubungan Industrial atas Dasar Perjuangan Klas (*Class Struggle*)

   Hubungan industrial ini berdasarkan pada falsafah *marxisme*/komunisme. Adapun ciri-cirinya adalah:

   a. berdasarkan pada teori nilai lebih dari Marx, yakni pengusaha selalu berusaha agar ada nilai lebih dengan merampas sebagian upah pekerja;

b. pekerja dan pengusaha adalah dua pihak yang bertentangan kepentingan karenanya perbedaan pendapat diselesaikan dengan saling menjatuhkan.

3. Hubungan industrial atas dasar komitmen seumur hidup *(life long employment)* di Jepang yakni berdasarkan falsafah dan budaya Jepang.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa ketiga pola hubungan industrial tersebut ternyata mempunyai corak atau sistem hubungan industrial yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dari bangsa yang bersangkutan.[5] Konsep hubungan industrial yang diterapkan di suatu negara dengan baik belum tentu dapat diterapkan dengan baik di negara lain. Sistem hubungan industrial yang paling tepat adalah sistem yang sesuai dengan nilai sosial budaya negara yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap masyarakat atau bangsa mempunyai corak atau sistem hubungan industrialnya sendiri, yang akan berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan nilai sosial budayanya. Selain itu, juga dipengaruhi faktor ideologi, politik, dan ekonomi dari masyarakat tersebut.

Hubungan industrial di Indonesia sebelum tahun 1965 menganut sistem hubungan industrial yang bermacam-macam, yaitu berdasarkan demokrasi liberal dan perjuangan kelas. Sistem hubungan industrial yang demikian ini dirasakan sangat mengganggu stabilitas nasional dan kelancaran pembangunan yang sedang dilaksanakan.[6] Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen di segala bidang kehidupan. Pemerintah ingin mengembangkan hubungan industrial yang didasarkan kepada falsafah Pancasila, sehingga pada akhir 1974 lahirlah Hubungan Industrial Pancasila.

Hubungan Industrial Pancasila, yaitu suatu hubungan industrial yang mendasarkan pada nilai-nilai kelima sila Pancasila. Sejak masa reformasi, istilah itu tampaknya kurang dipakai di masyarakat, mengingat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang menjadi salah satu pilar dari Hubungan Industrial Pancasila telah dicabut. Dengan dicabutnya salah satu pilar Hubungan Industrial Pancasila, maka Hubungan Industrial Pancasila kemudian disebut sebagai hubungan industrial saja tanpa disertai Pancasila.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

[5]Zaeni Asyhadie, Perselisihan Perburuhan, dalam *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 192-193.

[6]Sendjun H Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta 1995), hlm. 153.

Pada dasarnya, semua pihak pengusaha, pekerja, pemerintah maupun masyarakat secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan atas jalannya perusahaan. Sering terdapat pandangan yang keliru atas perusahaan, yaitu pandangan yang menganggap bahwa yang mempunyai kepentingan atas suatu perusahaan hanyalah pengusaha atau pemilik modal yang bersangkutan. Kekeliruan pandangan ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan.

Kemungkinan pertama dapat timbul sebagai akibat sikap pengusaha sendiri, yaitu sikap yang terlalu menonjolkan kekuasaan dan haknya atas modal dan mengutamakan keuntungannya sehingga kurang memerhatikan pekerja atau masyarakat. Kemungkinan kedua dapat timbul sebagai akibat prasangka dari pekerja yang sering menganggap bahwa pengusaha selalu mengambil keuntungan terlalu banyak dan memberi bagian pekerja terlalu sedikit.

Pengusaha mempunyai kepentingan atas kelangsungan dan keberhasilan perusahaan adalah jelas dan wajar, karena tanggung jawab morilnya sebagai pimpinan, sebagai sumber kehidupan dan untuk mendapatkan konsekuensi yang sesuai dengan modal yang ditanamkannya. Namun, pekerja juga mempunyai kepentingan yang sama atas perusahaan, yaitu sebagai sumber penghasilan dan penghidupan. Kalau misalnya suatu perusahaan terpaksa harus ditutup, maka bukan raja pengusaha yang kehilangan modalnya, tetapi juga seluruh pekerja akan kehilangan pekerjaannya dan sumber penghidupannya.

Didorong oleh adanya kepentingan yang sama antara pengusaha dan pekerja atas jalannya perusahaan dan dengan adanya keterlibatan pengusaha dan pekerja dalam proses produksi, maka timbullah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Hubungan tersebut dinamakan hubungan industrial atau *industrial relation*. Dengan perkataan lain, hubungan industrial adalah keseluruhan hubungan kerja sama antara semua pihak yang tersebut dalam proses produksi di suatu perusahaan.[7] Untuk itu, pemerintah melalui peraturan perundang-undangan ikut mengendalikan perusahaan, mengawasi, melindungi serta menciptakan kondisi yang mendorong bagi pertumbuhan perusahaan serta menciptakan ketenangan kerja dalam perusahaan. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan hubungan industrial yang serasi dalam setiap perusahaan. Dengan demikian, ketiga pihak tersebut, yaitu pengusaha, pekerja dan pemerintah sama-sama mempunyai kepentingan atas jalannya dan keberhasilan perusahaan.

Dalam hubungan industrial, pengusaha sebagai pemberi kerja dan pekerja sebagai penerima kerja dan upah, merupakan *partner* dalam pembangunan. Oleh karena itu, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus selalu bekerja sama secara kekeluargaan dan gotong royong berdasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, khususnya sila kerakyatan yang

[7]Sendjun H. Manulang, *Ibid*, hlm. 140.

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan adanya kerja sama antara pengusaha dan pekerja yang bersifat kekeluargaan dan segala sesuatu diselesaikan dengan permusyawaratan dan kesepakatan, maka di dalam hubungan industrial akan tercipta suatu hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang. Pekerja di samping *partner* di dalam menciptakan produksi (*partner in production*) juga sebagai teman seperjuangan dalam pemerataan menikmati hasil keuntungan perusahaan menurut bagian yang layak sesuai dengan prestasi kerja para pekerja dan sebagai *partner* dalam bertanggung jawab (*partner in responsibility*).

Asas kemitraan dalam hubungan industrial mengandung dua sisi pokok dalam pelaksanaan hubungan industrial. Di satu sisi adalah mitra dalam produksi (*partner in production*). Dari sisi ini timbul kewajiban bagi pekerja agar mampu meningkatkan produksi barang atau jasa bagi perusahaan. Di sisi lain adalah mitra dalam keuntungan perusahaan (*partner in profit*). Sisi ini menunjukkan bagi pengusaha untuk membagi keuntungan perusahaan dengan pekerja, baik dalam bentuk kenaikan upah, perbaikan syarat-syarat kerja maupun peningkatan kesejahteraan dan pemberian jaminan sosial.

Asas ikut bertanggung jawab (*partner in responsibility*), juga menyangkut dua sisi pertanggungjawaban. Pertama, pekerja ikut bertanggung jawab atas perkembangan perusahaan. Asas ini berkaitan erat dengan asas kemitraan karena pekerja merasa turut memiliki dan merupakan bagian dari perusahaan. Kedua, pengusaha merasa ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja.

Kepentingan bersama di antara pihak-pihak dalam perusahaan yang dijadikan landasan untuk membangun kerja sama yang sinergis itu memang bukan merupakan kepentingan yang sama, tetapi lebih tepat bila dianggap sebagai kepentingan yang komplomenter, karena secara sepintas kepentingan pekerja dan pengusaha dirasakan bertentangan secara diametral. Bukankah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal perlu mengurangi pengeluaran? Dan bukankah suatu pembayaran yang diberikan kepada pekerja tersebut merupakan suatu pengeluaran?

Untuk memasyarakatkan hubungan industrial sehingga betul-betul menjadi sikap dan pola perilaku dalam tata pergaulan di perusahaan, perlu dibarengi dengan penciptaan sarana-sarana dalam hubungan industrial yang menunjang di dalam perusahaan. Adapun sarana-sarana yang menunjang pelaksanaan hubungan industrial adalah lembaga kerja sama bipartit. Bila lembaga ini dapat berfungsi dengan baik maka akan dapat menciptakan suasana kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah di dalam perusahaan. Selain itu, bisa juga dengan lembaga kerja sama tripartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi serta mempunyai tugas utama untuk menyatukan konsepsi, sikap, dan rencana dalam menghadapi masalah-masalah ketenagakerjaan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya Kesepakatan Kerja Bersama. Kesepakatan

Kerja Bersama adalah suatu kesepakatan atau perjanjian tertulis yang dibuat antara serikat pekerja yang telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dengan pengusaha atau organisasi pengusaha yang berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja. Dengan demikian, Kesepakatan Kerja Bersama merupakan suatu peraturan induk atau peraturan dasar bagi perjanjian kerja, baik terhadap perjanjian kerja yang sudah dibuat, maupun yang akan dibuat. Sesuai dengan asas hukum perjanjian, maka kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan Kesepakatan Kerja Bersama diberikan kebebasan untuk menetapkan persetujuan/perjanjian mengenai apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam hubungan industrial, Kesepakatan Kerja Bersama sangat penting karena merupakan kelembagaan partisipasi yang berorientasi pada usaha-usaha untuk mengembangkan, melestarikan keserasian hubungan kerja dan kesejahteraan bersama. Di samping itu, Kesepakatan Kerja Bersama pada dasarnya dibentuk atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sehingga apa yang disepakati akan mengikat kedua belah pihak. Di dalam Kesepakatan Kerja Bersama dimuat berbagai hal antara lain syarat kerja, upah, jam kerja, jaminan sosial dan lain-lain. Sehubungan dengan itu maka dengan adanya Kesepakatan Kerja Bersama akan dapat menciptakan ketenangan kerja dan ketenangan berusaha.

Perlindungan yang seimbang ini diharapkan dapat menarik penanam modal untuk mengembangkan usahanya di Indonesia, tetapi adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan rencana jangka pendek maupun jangka panjang pada lingkungan perusahaan mengalami perubahan yang cukup mendasar, bahkan menyusul adanya sikap melakukan pemutusan hubungan kerja melalui model pilihan "rasionalisasi". Hubungan industrial sebagai sistem perekat dalam mekanisme para pelaku industrial, seperti serikat pekerja, pengusaha atau perusahaan, dan pemerintah selaku lembaga pengawasan ketenagakerjaan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja (Depnaker). Depnaker sebagai salah satu aparat hukum diharapkan tetap menjaga kemungkinan maraknya konflik-konflik industrial, unjuk rasa, pemogokan, serta gangguan yang mengarah pada ketidakstabilan nasional.

Di sisi lain, Depnaker juga perlu memerhatikan pengusaha atau pemilik modal yang merupakan mitra pemerintah dalam berperan membantu pembangunan. Pengusaha perlu juga mendapat perlindungan demi kelangsungan serta kepentingan investasi perusahaannya. Namun, tampaknya pada akhir-akhir ini perselisihan perburuhan semakin meningkat, hal ini dimungkinkan karena penerapan hubungan industrial yang diharapkan dapat meredam perselisihan perburuhan, ternyata masih memerlukan pengembangan dan penjabaran secara lebih konkret dalam bentuk norma yang dioperasionalkan.



Perselisihan Hubungan Industrial

Dalam praktik sehari-hari, adakalanya terjadi diskriminasi pengupahan atas dasar suka atau tidak suka. Di samping itu, banyak pengusaha yang melanggar ketentuan standar upah minimum. Masalah upah dewasa ini ternyata menjadi sangat serius, karena menjadi salah satu sebab terjadinya unjuk rasa dan mogok kerja. Di samping itu, alasan-alasan lain seperti hak cuti, uang lembur, kesehatan kerja, dan lain-lain yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hal-hal semacam inilah yang sering mengakibatkan terjadinya suatu konflik antara pekerja dengan pengusaha, meskipun para pihak tersebut sudah diikat dengan perjanjian kerja, namun konflik tetap tidak dapat dihindari.

Dalam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan disebutkan bahwa perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh karena tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.

Dari pengertian tersebut, ada dua jenis perselisihan perburuhan, yakni:

1. Perselisihan hak, yakni perselisihan perseorangan antara pengusaha atau serikat/gabungan pengusaha dengan serikat pekerja atau pekerja perorangan akibat pelaksanaan perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan atau KKB.
2. Perselisihan kepentingan, yakni perselisihan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha karena tidak adanya persesuaian paham mengenai syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.[8]

Adapun menurut Iman Soepomo yang dimaksud dengan perselisihan hak adalah sebagai berikut.

> Perselisihan hak adalah perselisihan karena salah satu pihak pada perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi perjanjian itu atau peraturan majikan atau menyalahi ketentuan hukum. Sedang yang dimaksud perselisihan kepentingan adalah mengenai usaha mengadakan perubahan dalam syarat-syarat perburuhan yang oleh organisasi buruh dituntutkan kepada pihak majikan atau menurut perumusan di atas "pertentangan berhubung tidak adanya persesuaian paham mengenai syarat-syarat dan/atau keadaan perburuhan."[9]

---

[8]Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cetakan pertama, (Jakarta: PT Raja-Grafindo Persada, 2000), hlm. 84-85.

[9]Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 96.

Adapun menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap perselisihan industrial yang terjadi harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh para pihak. Untuk melakukan upaya ini, pihak pengusaha atau gabungan pengusaha, demikian juga dari pekerja atau serikat pekerja, harus memainkan peranannya sehingga ketenangan kerja di perusahaan tetap terjaga. Jika upaya perundingan tidak membawa hasil, maka para pihak dapat menempuh upaya sebagai berikut:

a. penyelesaian melalui jalur letigasi;
b. penyelesaian melalui jalur nonletigasi.

Dalam dunia peradilan di Indonesia, diakui adanya penyelesaian sengketa keperdataan yang dilakukan di luar pengadilan secara damai oleh para pihak atau menggunakan jasa pihak ketiga sebagai arbitrase. Oleh karena itu, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Hubungan industrial yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan, baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan.

Perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai PHK atau pemutusan hubungan kerja yang selama ini diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, ternyata tidak efektif lagi untuk mencegah serta menanggulangi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja. Hal ini disebabkan karena hubungan antara pekerja dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian sehingga pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 akan dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak.

Sejalan dengan era keterbukaan dan demokratisasi dalam dunia industri yang diwujudkan dengan adanya kebebasan untuk berserikat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, maka jumlah serikat pekerja di satu perusahaan tidak dapat dibatasi. Persaingan di antara serikat pekerja di satu perusahaan ini dapat mengakibatkan perselisihan di antara serikat pekerja yang pada umumnya berkaitan dengan masalah keanggotaan dan keterwakilan di dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama ini ternyata belum mewujudkan penyelesaian perselisihan secara tepat, adil, dan murah.[10]

Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial dirasa tidak dapat lagi mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang terjadi, karena hak-hak pekerja perseorangan belum terakomodasi untuk menjadi pihak dalam perselisihan hubungan industrial.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial hanya mengatur penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan kepentingan secara kolektif, sedangkan pekerja secara perseorangan belum terakomodasi.

Hal lainnya yang sangat mendasar adalah dengan ditetapkannya putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) sebagai objek sengketa tata usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya ketentuan ini, maka jalan yang harus ditempuh baik oleh pihak pekerja maupun oleh pengusaha untuk mencari keadilan menjadi semakin panjang.

Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah oleh para pihak yang berselisih sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian bipartit ini dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh para pihak tanpa dicampuri oleh pihak mana pun. Namun demikian, pemerintah dalam upayanya untuk memberikan pelayanan masyarakat khususnya kepada masyarakat pekerja dan pengusaha, berkewajiban memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut. Upaya fasilitasi dilakukan dengan menyediakan tenaga mediator yang bertugas untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih.

Dengan adanya era demokratisasi di segala bidang, maka perlu diakomodasi keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan

[10]Penjelasan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

industrial melalui konsiliasi atau arbitrase. Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase pada umumnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di bidang sengketa perdagangan. Oleh karena itu, arbitrase hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan pengaturan khusus bagi penyelesaian sengketa di bidang huhungan industrial. Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, jenis perselisihan industrial meliputi:

a. perselisihan hak;
b. perselisihan kepentingan;
c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
d. perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.



Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Sejalan dengan era demokratisasi, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pada dasarnya menurut undang-undang tersebut perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui letigasi dan nonletigasi.

Penyelesaian melalui letigasi dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri yang penyelesaiannya dilakukan oleh Hakim Karier dan Hakim *Ad-Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang terdiri atas paling sedikit lima orang dari unsur serikat pekerja dan lima orang dari unsur organisasi pengusaha.

Untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan Peradilan Umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengadakan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dapat menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya, penyelesaian perselisihan secara nonletigasi dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Sesuai ketentuan Pasal 2 butir 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial disebutkan mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antarserikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Seorang mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antarserikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sedangkan Koalisi menurut ketentuan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antarserikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator menurut ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.

Dan yang disebut arbitrase menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antarserikat pekerja dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan dari pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

Perselisihan hubungan industrial pada dasarnya memiliki potensi yang besar dalam merusak sistem hubungan kerja sama antara pekerja dan pengusaha, jika para pihak yang ingin menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut salah dalam memilih mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Untuk mempertahankan atau memelihara hubungan kemitraan antara pekerja dengan pengusaha, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan memiliki posisi penting. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:[11]

1. penyelesaian perselisihan perburuhan di luar pengadilan dilakukan secara informal dan menekankan pada penyelesaian *win-win solution*;
2. penyelesaian perselisihan perburuhan di luar pengadilan yang dilaksanakan secara mediasi, konsiliasi atau arbitrase ini pada dasarnya merupakan proses lanjutan dari negosiasi (*contractual process*). Dengan kata lain, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase pada dasarnya berfungsi sebagai alat bantu para pihak dalam suatu proses perundingan;
3. masing-masing pihak yang berselisih diberi kesempatan secara penuh baik dalam memberikan pandangan maupun dalam menggunakan kesempatan bertanya kepada pihak lainnya selama acara dengar pendapat; dan
4. memberikan kesempatan kepada para pihak yang berselisih untuk berkomunikasi secara intens, sehingga suasana komunikatif yang tercipta selama acara dengar pendapat akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memecahkan perselisihannya secara realistis karena di lihat dari berbagai sudut pandang.

Dalam proses mediasi, pihak ketiga yang dipercaya sebagai mediator mempunyai wewenang memfasilitasi para pihak yang berselisih untuk mencapai suatu kesepakatan penyelesaian. Untuk itu mediator wajib mengupayakan agar tercipta situasi yang kondusif bagi para pihak yang sedang dalam proses perundingan penyelesaian akar permasalahan, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial. Dengan kata lain, mediator membantu agar para pihak yang berselisih dapat membuat kesepakatan-kesepakatan antar mereka sendiri.[12] Misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi tentang kesanggupan, keberatan, atau harapan para pihak. Pemahaman terhadap kesanggupan, keberatan atau keinginan/harapan antarpihak yang satu dengan pihak lainnya, yang disertai oleh kemauan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang mereka hadapi, akan mempercepat proses tercapainya kesepakatan antara para pihak yang berselisih untuk mengakhiri perselisihan yang mereka hadapi. Dengan demikian, proses mediasi ini akan diakhiri oleh kesepakatan para pihak yang berselisih.

Selanjutnya dalam proses konsiliasi, pihak ketiga yang dipercaya sebagai konsiliator diberi kewenangan untuk memberikan putusan yang bersifat anjuran.

---

[11]Aloysius Uwiyono, *Peranan Hukum Perburuhan Dalam Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh*. Orasi Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Perburuhan, FH UI, 11 Juni 2003.

[12]Evan J. Spelfogel, *Alternative Dispute Resolution and Deffered to Arbitration,* The Labor Lawyer 6 (Winter 1990, no.1) hlm. 138.

Berbeda dengan proses mediasi, konsiliator di sini aktif menggali kesanggupan, keinginan atau harapan, atau keberatan-keberatan para pihak yang berselisih. Dalam proses berikutnya, data atau fakta yang diajukan oleh para pihak, untuk selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan putusannya. Dengan demikian, konsiliator berusaha agar yang ia anjurkan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses konsiliasi ini berakhir jika para pihak yang berselisih sepakat untuk melaksanakan putusan anjuran dari konsiliator.

Di samping itu, para pihak yang berselisih dapat menggunakan jasa arbitrase. Penggunaan jasa arbitrase biasanya dilakukan jika perselisihan hubungan industrial yang dihadapi para pihak yang berselisih sangat kompleks. Dalam proses arbitrase pihak ketiga yang dipercaya sebagai arbiter diberi kewenangan oleh para pihak untuk menetapkan putusan yang bersifat mengikat (*final and binding*).

Kewenangan arbiter untuk menetapkan putusan yang bersifat *final and binding* ini didasarkan pada rangkaian kesepakatan demi kesepakatan para pihak yang berselisih.[13]

Adapun esensialia dari arbitrase ada lima hal, yaitu:[14]

Pertama, penggunaan mekanisme arbitrase atas dasar kesepakatan demi kesepakatan para pihak yang berselisih;

Kedua, tampilnya pihak ketiga (arbiter) atas kesepakatan/pilihan para pihak yang berselisih;

Ketiga, penyelenggaraan sidang dengar pendapat (*hearing*) atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih;

Keempat, adanya kesepakatan para pihak dengan arbiter terpilih tentang kapan dan di mana dengar pendapat diadakan, serta berapa lama arbiter harus menetapkan putusannya setelah sidang dengar pendapat berakhir;

Kelima, adanya kesepakatan para pihak untuk mematuhi putusan arbiter.

Dari kelima esensialia arbitrase tersebut, proses arbitrase pada dasarnya merupakan *contractual process*, karena proses arbitrase tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesepakatan para pihak yang berselisih. Pada hakikatnya arbitrase merupakan kepanjangan negosiasi dengan bantuan pihak ketiga. Oleh karena itu, arbitrase merupakan *contractual process* maka penggunaan mekanisme arbitrase ini didasarkan pada kepercayaan (*trust*) serta iktikad baik (*good faith*) para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah, dan bukan untuk memenangkan perkara.

---

[13]Arnold M. Zack, *Can Alternative Dispute Resolution Help to Resolve Employment Dispute?* International Labor Review, 1992, hlm. 107-108.

[14]Aloysius Uwiyono, *op.cit*, hlm. 16-17.

Jika prinsip-prinsip dasar arbitrase ini dilaksanakan secara benar, maka mekanisme arbitrase ini sebenarnya telah berakhir pada saat para pihak sepakat untuk menggunakan mekanisme arbitrase dan sepakat untuk mematuhi apa pun putusan arbiter. Dengan demikian, mekanisme arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang paling cepat di antara mekanisme lainnya.



Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terbaik dan dapat memuaskan kedua belah pihak yang berselisih adalah penyelesaian secara bipartit.
2. Sejalan dengan era demokratisasi mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, memberikan kebebasan kepada para pihak yang berselisih untuk menempuh penyelesaian melalui mekanisme lain. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya pemerintah menghendaki agar para pihak memprioritaskan mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan undang-undang.
3. Untuk lebih memberdayakan masyarakat, khususnya pekerja dan pengusaha timbul kebutuhan untuk mengembangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah dengan mendorong adanya mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.



Saran

Mengingat keputusan arbiter mengikat para pihak dan bersifat final dan tetap seyogyanya arbiter haruslah yang benar-henar berkompeten di bidangnya, sehingga kepercayaan para pihak tidak sia-sia.

Daftar Referensi

Appeldoorn, (Terjemahan oleh: Oetarid Sadino). *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan XIX. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Asikin, Zainal. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

Asyhadie, Zaeni. *Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

Bruggink, J.H.H. *Relleksi Tentang Hukum* (Terjemahan Arief Sidarta). Bandung: Aditya Bakti, 1999.

Djamin, Awaludin. *Hubungan Perburuhan Dalam Memasuki Era Industrialisasi, Hak Mogok dan Lock out di Perusahaan*. Perhimpunan Studi Ilmu Hubungan Industrial. Cetakan II. Jakarta, 1992.

Djumadi. *Kedudukan Kesepakatan Kerja Bersama Dalam Hubungan Industrial Pancasila*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1995.

Friedman, W. *Legal Theory*. New York: Columbia University Press, 1967.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila*. Makalah disampaikan pada symposium tentang politik, hak asasi dan pembangunan hukum Dalam rangka Dies Natalis XL / Lustrum VIII Universitas Airlangga, 3 November 1994.

Manulang, Sendjun H. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Popisil, Leopold. *Anthropology of Law,A Comparative Theory*. New York: Harper & Row Publisher, 1973.

Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1992.

Spelfogel, Evan J. *Alternative Dispute Resolutionand Deffered to Arbitration*. The Labor Lawyer, 6 (Winter 1990) No. 1.

Uwiyono, Aloysius, *Peranan Hukum Perburuhan Dalam Pemulihan Ekonomi Dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh*. Orasi Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 11 Juni 2003.

Zack, Arnold M. *Can Alternative Dispute Resolution Help to Resolve Employment Dispute?* International Labor Review, 1992. No. I.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

33

INTERNATIONAL LAW, RULES AND PRINCIPLES FOR DISASTER MANAGEMENT

Oleh:
*Prof. IBR. Supancana, S.H., M.H., Ph.D.**



Introduction

A. The Facts on Disaster and Its Responses

We can witness that every year millions of people are affected by natural and man-made disaster, and every year the international community is faced with the challenge of responding to crisis that exceeds the capacities of national infrastructure. Currently no well recognized and comprehensive legal instruments which identify internationally agreed rules, principles and standards for the protection and assistance of people affected by natural disaster[1]. Consequently many international disaster response operations are subject to ad hoc rules and systems, which vary dramatically from country to country and impede the provision of fast and effective assistance putting lives and dignity at risk[2].

B. Ideal Conditions for Disaster Preparedness

By considering the above facts on disaster and its response, there is a need to create ideal conditions for disaster preparedness which would: ensure preparedness both at local, national and international level; anticipate to the likely needs of the affected communities; the ability to identify potential legal and administrative challenges for the entry and coordination as a way to overcome it; and prevent unnecessary obstacles both legal, policy and institutional.[3]

---

*Chairman/Founder of Centre for Regulatory Research, Indonesia.

[1]Compare to David P Fidler, "The Indian Ocean Tsunami and International Law", ASIL Insight, 2005, page 1-2. He, among other stated "No definite, broadly accepted sources of International Law which spells out legal standards, procedures, rights and duties pertaining to disaster management".

[2]See International Disaster Response Law (IDRL) Appeal No. 01.100/2004, page 1.

[3]Compare to the definition of "Disaster Preparedness" as formulated in Glossary of Strategy

C. Problems in International Disaster Response

It is important to have understanding on the problems in international disaster response in the efforts to achieve the above-mentioned ideals. The problems that commonly faced are among others:

1. Delayed or even prevented from providing initial relief and operations. One examples of it can be observed during the Tsunami in the end of 2004 where they were lacks of early warning, alert and preparedness among the affected countries.[4]
2. Ill equipped national legal and regulatory system to deal with the needs of international relief provider.[5]
3. Lacks of awareness among countries/governments about the importance of international cooperation that should override/overcome political/ ideological differences and even legal/administrative obstacles in case of disaster (both natural and technological disaster).



The Idea and Establishment of IDRL Programme

A. Background

The idea of establishing IDRL programme was to response the growing concern within the international community as to the adequacy of existing legal and other mechanism to facilitate humanitarian activities in response to both natural and technological disaster. Based on a study, there were some findings concerning identified key deficiencies on existing international legal instruments relevant to disaster relief, such as:[6]

1. Regional disparities in the existence of treaties relevant to disaster relief;
2. Diversity in the content of treaties relating to disaster relief;
3. Disparate and inconclusive legal principles on disaster relief; and
4. Significant aspects of disaster relief not properly addressed.

IDRL was initiated by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (International Federation) in 2001.

2010, of which disaster preparedness is defines as: "Activities that contribute to the pre-planned, timely and effective response of individuals and communities to withstand, reduce the impact and deal with the consequences of a (future) disaster".

[4]See David P. Fidler, *loc.cit*.

[5]For example Indonesia, the most affected State stricken by Tsunami in 2004, only have a comprehensive law on disaster management that could accommodate the interest of international relief provider in 2007.

[6]See International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IDRL Legal Research: research into Existing IDRL Treaties, IDRL Fact Sheet No 6, March 2003.

B. The Overall Goal

The overall goals of IDRL Programme are:[7]

1. Save losses of live caused by disaster;
2. Reduce the suffering and vulnerability of disaster victims; and
3. Reduce losses of assets and negative impact on living conditions and livelihood.

C. The Objectives

There are some key objectives of the IDRL Programme, covering:[8] to raise awareness about the existing norms and standards governing international disaster response and to strengthen the international, regional and national frameworks of laws, rules, and principles that pertain to facilitation, coordination and regulation of international response to disaster; to facilitate access to legal and policy instruments form humanitarian response actors, disaster managers and policy makers; to promote the implementation of existing IDRL instruments and make their content tangible for humanitarian response actors; assist red cross/red crescent national societies in providing to their government with regard to strengthening the disaster management legal and policy framework in their country; identify problems which remain unaddressed in existing IDRL instruments and facilitate a dialogue about finding solutions.

D. The Focus

The focuses of the IDRL Programme will be on the legal issues arising from international response to different types of non-conflict related disasters, as well as technological, chemical and biological disasters. In that respect IDRL Programme seeks to: raise awareness of applicable normative standards and promote their effective implementation; identify gaps and weaknesses in current regulatory structures at the national, regional and international levels; and promote dialogue in finding solutions.



Relevant International Legal Instruments Related To Disaster Management

There are some existing relevant international legal instruments related to disaster management, among others:

a. Convention Establishing An International Relief Union of 1927;

---

[7]See IDRL Appeal No. MAA00004, 2006-2007, page 2.
[8]See *Ibid*, page 5.

b. Convention on Assistance in the Case of Nuclear Accident or Radiological Emergency of 1986;

c. Convention on Early Notification of a Nuclear Accident of 1986;

d. Council's of Europe Agreement on the Prevention of, Protection against, and Organization of Relief in Major Natural and Technological Disaster of 1987;

e. Convention on Temporary Admission of 1990 (in particular annex B.9 concerning goods imported for humanitarian purposes);

f. Inter-American Convention to Facilitate Disaster Assistance of 1991;

g. The Tampere Convention on the Provisions of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and Relief Operations of 1998;[9]

h. The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures as amended in 1999;

i. Framework Convention on Civil Defence Assistance of 2000;

j. The "Seville Agreement" on the Organization of International Activities of the Components of the International Red Cross and Red Crescent Movement of 1997.

Other relevant legal documents, including but not limited to:

a. Charter on Cooperation to Achieve the Coordinated Use of Space Facilities in the Event of Natural or Technological Disaster of 2000;[10]

b. The Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement as amended in 1995;

c. The Principles and Rules of Red Cross and Red Crescent in Disaster Relief as amended in 1995;

d. The Supplementary Measures to Enhance the Implementation of the Seville Agreement of 2005;

e. The Hyogo Framework for Action of 2005;

---

[9]The Tampere Convention entered into force on 8 January 2005 following the ratification by 30th country. The Tampere Convention is a legally binding international instrument aimed at helping relief workers brings telecommunication equipment across borders during and after an emergency, with a minimum difficulty.

[10]The Charter, known as International Charter "Space and Major Disaster" was initiated by the European Space Agency (ESA) and the France Space Agency (CNES) which was declared formally operational on November 1 of 2000. Some major space agencies from space faring nations such as: USA (NOAA), Canadian Space Agency (CSA), India (ISRO), Japan (JAXA) have also become members. Fur further information about "the Charter on Space and Major Disaster", read Joanne Gabrynowicz, "Comments on the Discussion Paper: Space Contribution for Disaster Management, Legal Framework", with Specific Emphasis on the Disasters Charter", presented at The Space Law Conference 2006, Asian Cooperation in Space Activities: A Common Approach to Legal Matters, Bangkok 2006.

f. The Masures to Expedite International Relief of 1977;
g. UNGA Resolution 46/182 of 1991;
h. UNGA Resolution 57/150 of 2002;
i. Etc.

The above-mentioned international legal documents, both in the form "hard laws" and "soft laws", not only complementary one another but also form a harmonious and comprehensive system laws, rules and principles that eventually contribute to humanity, in particular protect and accommodate the needs and interests of victims of disasters.



Some Challenges In Implementing IDRL

There are some challenges in implementing IDRL Programme, particularly the problems that frequently faced in the past experiences regarding international disaster relief and initial recovery assistance. Some of the problems are related to the following issues:[11]

A. Personnel

In practical situation personnel movement and qualification are often faced by the following situation:

1. Delayed or refused entry permission/visas for relief workers
2. Legal difficulties in hiring local staffs and volunteers
3. Lacks of legal protection, privileges, and immunities for relief workers
4. Lack of recognition of professional qualifications of relief workers.

B. Legal Status of Foreign Organization

For foreign organizations who conducting disaster relief and initial recovery assistance some difficulties shall be lifted such as:

1. Lengthy procedures for gaining legal status to operate in foreign country
2. Difficulties in transferring/exchanging money and opening bank accounts
3. Vulnerability to false legal claims, arrest, detention and seizure of property
4. Restriction in carrying out mandates.

C. Goods and Equipments

Facilitation of goods and equipment in disaster relief and initial recovery

[11]See IDRL Fact Sheet as quoted from www.ifrc.org.

assistance is absolutely required, this is very important to overcome the following situation:

1. Delays in the import, export, and transit of relief goods, medicine and equipments;
2. Imposition of taxes, fees and tolls on relief activities;
3. Restricted use of communication equipments;
4. Difficulties with use of vehicles, aircraft and shipping.

D. Coordination, Quality and Accountability

Coordination, quality and accountability are key success factors in the whole process of disaster relief and initial recovery operation therefore certain situations shall be prevented or minimized, such as:

1. Inadequate information-sharing about disaster and the humanitarian needs;
2. Sending unnecessary or inappropriate relief items and assistance;
3. Undervaluing local knowledge and response capacities;
4. Use of untrained or unqualified personnel;
5. Lack of adherence to quality/accountability standard.

Apart from the above challenges, some other major challenges may be faced in disaster relief and initial recovery operation, particularly in implementing IDRL, these challenges would include:[12]

1. Inconsistent access to disaster affected people;
2. Delays and inefficiency in facilitating disaster response;
3. Gaps in the use of quality and accountability standards;
4. Lack of national and international coordination.

The above challenges should be seriously taken into considerations in the efforts to implement IDRL. Narrowing the gaps between national law and international law would be of importance to lift identified obstacles. In addition, continues dialogue will bring more mutual understanding among members of the international community. Developing a culture of caring to each others' sorrow would also help the international community to find satisfactory solutions to existing and future legal, policy and institutional constraints in providing international disaster relief and initial recovery assistance to the affected victims and areas.

[12]For further detail, read Nick Carter, "Legal Protection for Disaster Affected People", unpublished, page 1-2.



Draft Guidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance[13]

The purpose of the guidelines is to contribute to national legal preparedness by providing guidance to States interested in improving their domestic legal, policy and institutional framework concerning international disaster relief and initial recovery assistance.[14] In terms of scope, the guidelines are not intended to apply to situations of arms conflict or disasters that occur during arms conflict, or to imply changes in any rules governing relief in those contexts.[15] Some definitional issues are clarified by the draft guidelines, especially on some terminologies, such as: disaster; disaster relief; initial recovery assistance; goods; services; equipment; personnel; affected state; assisting state; originating state; transit state; assisting humanitarian organization; eligible assisting humanitarian organization; assisting actor; etc.[16]

The legal status of the proposed Guidelines would be: non-binding, complementary to the existing international law; and to fill the gap of the existing laws, rules and principles.

The draft Guidelines contain important provisions, such as:

A. Core Responsibilities

The responsibilities of affected States are to ensure disaster risk reduction, relief and recovery assistance in their territory.[17] In case a disaster situation exceeds national coping capacities, it should seek international and/or regional assistance to address the needs of affected persons.[18]

Meanwhile assisting actors should abide by the laws of affected States and applicable international law, coordinate with domestic authorities, and respect the human dignity of disaster affected persons at all times. Assisting actors should also conduct their activities in accordance with the principle of humanity, neutrality and impartiality.[19]

---

[13]Version of 26 October 2007. The draft Guidelines was expected to be adopted as one of the resolution of the 30th International Conference of the Red Cross and Red Crescent.

[14]See point 3.3 of the Guidelines.

[15]*Ibid,* point 3.4. The provisions of these Guidelines are also not intended to recommend any changes to, or affect the meaning or implementation of, any existing international law or agreements.

[16]For further details of the above definitions, see Draft Guidelines point 2.1- 2.14.

[17]See Draft Guidelines, *ibid*, point 3.1.

[18]*Ibid,* point 3.2.

[19]*Ibid,* point 4.1 and 4.2.

All States have additional responsibility to actively encourage members of the public interested in contributing to international disaster relief or initial recovery to make financial donations.[20] All States (parties) should cooperate to prevent unlawful diversion, misappropriations, or fraud concerning disaster relief or initial recovery of goods, equipment or resources and initiate proceedings as appropriate.[21]

B. Early Warning and Preparedness

On early warning system, States should have procedures in place to facilitate the expeditious sharing of information about disasters.[22] Concerning legal, policy and institutional frameworks, States should adopt a comprehensive legal, policy and institutional frameworks and planning for disaster prevention, mitigation, preparedness, relief and recovery which took full account of the auxiliary role of their national red cross and red crescent societies.[23] In order to promote early warning and preparedness system, there is a need for regional and international support for domestic capacities. In that respect the international community, including donors, regional and other relevant actors, should support developing States, domestic civil society actors and national red cross and red crescent societies to build their capacities to prevent, mitigate, prepare for and responds to disaster domestically.[24]

C. Initiation and Termination of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance

Disaster relief or initial recovery assistance should be initiated only with the consent of affected States and in principle, on the basis of an appeal.[25] Request and offers for assistance should be as specific as possible as to the types and amounts of goods as well as the services and expertise available or required, respectively.[26] Affected should make available to assisting actors adequate information about domestic laws and regulations of particular relevance to the entry and operation of disaster relief or initial recovery assistance.[27]

In the event of initiation of military relief, military assets should be deployed for disaster relief or initial recovery assistance only at the request or with the express consent of affected States.[28] When the affected States or an assisting

[20] *Ibid*, point 5.2.
[21] *Ibid*, point 6.1.
[22] For further detail see *ibid*, point 7.
[23] See *Ibid*, point 8.1.
[24] See *Ibid*, point 9.1 and 9.2.
[25] *Ibid*, point 10.1.
[26] *Ibid*, point 10.2.
[27] *Ibid*, point 10.3.
[28] *Ibid*, point 11.

actor intends to terminate disaster relief or initial recovery operation, it should provide appropriate notification.[29]

D. Eligibility for Legal Facilities

Transit and affected States are recommended to grant legal facilities to assisting States with respect to disaster relief and initial recovery assistance.[30] It is the prerogative of originating, transit and affected States to determine which assisting humanitarian organizations will be eligible to receive the legal facilities with respect to their disaster relief or initial recovery assistance.[31] Affected States may also wish to extend, upon request, some of the legal facilities to other assisting actors, for example to private companies providing charitable relief operations of assisting humanitarian organizations or assisting States.[32]

E. Legal Facilities for Entry and Operations

For the purpose of conducting disaster relief and initial recovery assistance affected States should grant, to relevant personnel, visas and any necessary working permit, temporary licences, certificates that are necessary for the performance of disaster relief or initial recovery assistance, and also freedom of access.[33]

Goods and equipment shall be exempted from all customs duties, taxes, tariff or governmental fees; exempted from all export, transit and import restrictions; simplify and minimize document requirements. There must be also waived or reduced from inspections requirements. For special goods and equipments, affected States should grant temporary recognition to foreign registration and plates with regard to vehicles imported by them, they also have to grant any applicable licenses and reduce any barriers.[34]

In order to facilitate transportation of goods and equipments for disaster relief or initial recovery assistance, originating, transit and effected States should grant without undue delay, permission for the speedy passage of land, marine and air vehicles operated by an assisting State or eligible assisting humanitarian organization or on its behalf, ideally waive applicable fees.[35] Temporary domestic legal status should be granted by affected States to relevant entities of assisting States and eligible assisting humanitarian organizations,

[29]*Ibid*, point 12.
[30]*Ibid*, point 13.
[31]*Ibid*, point 14.1.
[32]*Ibid*, point 15.
[33]*Ibid*, point 16.1. a, b, and c.
[34]For further detail, see Ibid, point 17 and 18.
[35]See *Ibid* point 19.

upon entry or as soon as possible thereafter, to open bank accounts, enter into contract and leases, acquire and dispose of property and instigate legal proceedings for the purpose of providing disaster relief and initial recovery assistance.[36] On the taxation issues, affected States should provide exemptions to assisting States and eligible assisting humanitarian organizations from value-added and other taxes or duties directly associated with disaster relief and initial recovery assistance.[37]

Appropriate measures should be taken by affected States to address the safety and security of disaster relief and initial recovery personnel of assisting States and eligible assisting humanitarian organizations and of the premises, facilities, means or transport, equipments and goods used in connection with their activities.[38] Affected States should endeavour to ensure, when necessary, that State-operated offices and services essential to the timely delivery of international disaster relief function outside of normal business hours.[39] The cost of providing international disaster relief or initial recovery assistance should normally be borne by the assisting States or assisting humanitarian organizations, but upon agreement with affected States certain cost can be reimbursed.[40]



The Way Forward

a. There is a need for the same level of perceptions and awareness among international communities (covering both governments, international organizations and community at large) concerning the importance of international cooperation in case of disaster.
b. There is a need for socialization to achieve the above objectives.
c. There is a need for harmonization between national law and international law to deal with the issue of implementing IDRL.
d. There is a need to develop IDRL as an integrated approach in dealing with disaster related issues.
e. Strong commitment from international communities lead by governments is the key factor to achieve the above goals.

[36] *Ibid,* point 20.
[37] *Ibid,* point 21.
[38] *Ibid,* point 22.
[39] *Ibid,* point 23.
[40] *Ibid,* point 24.

34

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
(Gagasan Pembaruan Hukum Pidana Anak Indonesia)

Oleh:
*Prof. Dr. Paulus Hadi Suprapto, S.H., M.H.**

Pendahuluan

Gagasan ini muncul pertama kali, ketika semua pemerhati masalah anak di negeri ini dikejutkan dengan berbagai informasi yang menyangkut penanganan anak-anak pelaku kenakalan, yang secara substantif mengandung unsur pelanggaran hak-hak anak seperti diamanatkan dalam sistem hukum anak di negeri ini.

Dari sekian banyak berita menyangkut penanganan anak pelaku kenakalan di negeri ini, adalah kasus Raju. Dunia hukum anak negeri ini dikejutkan oleh adanya Sidang Pengadilan Negeri Statbat, Cabang Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat Sumatera Utara yang mengadili Muhammad Azwar alias Raju, seorang anak baru berumur kurang dari delapan (8) tahun, kelas III SD harus menjalani tahanan 19 hari dan menjalani persidangan berhari-hari dalam kasus perkelahiannya dengan Arman Syah.[1]

Berbagai tanggapan pun bermunculan dari para pemerhati anak di negeri ini. Para aparat penegak hukum yang menangani kasus Raju sudah melakukan tugasnya dengan baik, akan tetapi justru menimbulkan masalah lain. Di sini tentu ada yang salah. Apa yang salah?[2] "Cerita tentang Raju bergulir semakin jauh. Perkelahian yang semula murni kenakalan anak telah membawa isu yang lebih besar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengemukakan, "sidang yang berlarut-larut dan penahanan sedikit banyak berpengaruh pada

---

*Guru Besar Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
[1]*Kompas*, 22 Februari 2006.
[2]*Kompas*, 3 Maret 2006.

perkembangan mental Raju. Padahal, pertumbuhan dan perkembangan anak tidak boleh terhambat apa pun termasuk proses pengadilan". Ketua Komnas Perlindungan Anak dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta meminta kasus Raju dijadikan pintu masuk untuk mengamandemen UU Pengadilan Anak".[3]

Kasus monumental (*celebration cases*) Raju, tampaknya bukan satu-satunya kasus yang menyangkut ketidakproporsional penanganan anak pelaku kenakalan. Hasil pengamatan tampaknya masih banyak kasus-kasus kenakalan anak, pelakunya cenderung dijatuhi pidana, bukannya tindakan.

Paparan di atas tampaknya "trep" dengan konstatasi Barda Nawawi Arief, Guru Besar Hukum Pidana UNDIP, yang menyatakan bahwa permasalahan menonjol kehidupan hukum di negeri ini adalah masalah (a) penegakan hukum (*legal enforce ment*), dan (b) pembangunan atau pembaruan hukum (*legal reform*).

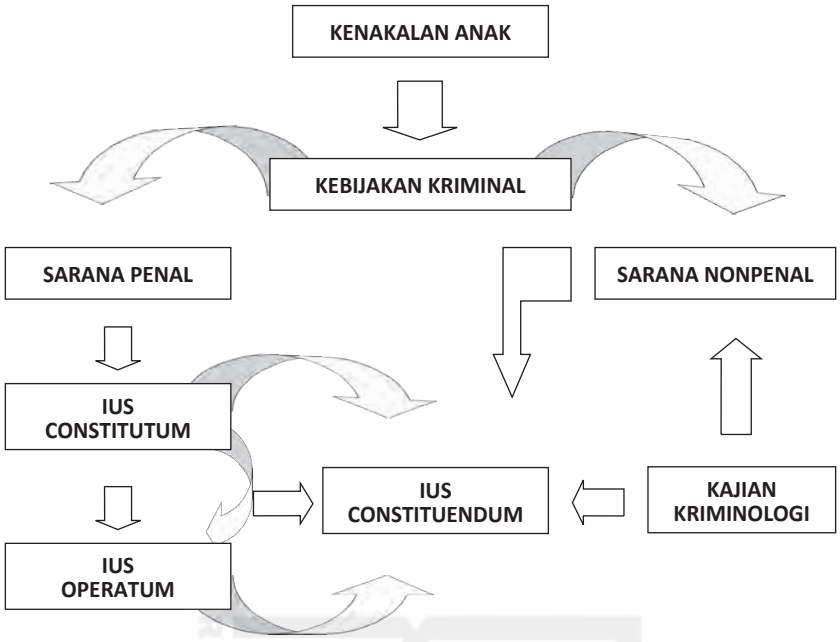
Berangkat dari ungkapan "Di sini tentu ada yang salah, apa yang salah?" dan "Lindungi anak dan amandemen UU Pengadilan Anak", sajian segenggam (*in a nut shell*) ingin mengetengahkan permasalahan sekitar "kesalahan" UU Pengadilan Anak dan "pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan amandemen UU Pengadilan Anak" (baca, pembaruan hukum pidana anak).



Lingkup Kajian Penanggulangan Kenakalan Anak

Sebelum pembicaraan terarah pada pokok masalah, ada baiknya bila sebelumnya dikemukakan lingkup kajian penanggulangan kenakalan anak di masyarakat. Lingkup kajian ini perlu dikemukakan untuk memahami peta permasalahan yang relevan dengan upaya penanggulangan kenakalan anak di masyarakat. Upaya penanggulangan kenakalan anak tentu berangkat dari satu fenomena bahwa dalam masyarakat telah terjadi anak yang berperilaku bertentangan dengan norma-norma masyarakat pada umumnya dan norma-norma hukum anak pada khususnya. Untuk jelasnya di bawah ini dikemukakan secara skematis lingkup kajian penanggulangan kenakalan anak dalam masyarakat.

[3]*Kompas*, 7 Maret 2006.



Gambar 34.1 Lingkup Kajian Penanggulangan Kenakalan Anak

Apabila di masyarakat terjadi kenakalan anak, maka akan muncul reaksi masyarakat terhadap fenomena tersebut. Reaksi itu sudah barang tentu akan terarah pada upaya pemahaman terhadap fenomena tersebut dan kemudian daripada itu melahirkan pemikiran ke arah upaya penanggulangan terhadap fenomena yang berupa kenakalan anak itu. Reaksi masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak pada khususnya dan kejahatan pada umumnya dalam pembicaraan hukum pidana dan kriminologi disebut Kebijakan Kriminal.

Kebijakan kriminal sebagai *the rational organization of the control of crime*, demikian Marc Ancel, atau *the rational organization of the social reactions to crime; the science of responses, the science of crime prevention; a policy of designating human behavior as crime; a rational total of the responses to crime,* demikian G.P. Hoefna gels, atau "suatu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang meliputi seluruh asas dan metode yang mendasari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana, keseluruhan fungsi aparat penegak hukum (cara kerja) dan kebijakan UU dan badan-badan resmi untuk menegakkan norma masyarakat,[4] secara operasional dapat dilakukan dengan sarana penal dan nonpenal.

[4]Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 16.

Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat "represif" (penumpasan/pemberantasan/penindasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat "preventif" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan pembedaan secara kasar, karena pada hakikatnya, tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.[5]

Kajian terhadap kebijakan penal sesuai dengan skema tersebut difokuskan perhatiannya pada "*ius constitutum*" dan "*ius operatum*". Berbicara tentang *ius constitutum* dalam konteks kenakalan anak, berarti mengadakan telaah terhadap hukum positif yang menyangkut anak nakal yang berlaku saat ini, yaitu KUHP, KUHAP dan berbagai UU lain yang menyangkut anak. KUHP dalam hal ini berkaitan dengan masalah tindak pidana. KUHAP dalam hal ini menyangkut Pasal 50 s/d 68 KUHAP (kecuali Pasal 64), UU lain yang menyangkut anak nakal utamanya adalah UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam konteks yang disebut terakhir, tak dapat diabaikan pula UU No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Penetapan Berlakunya Konvensi Hak Anak di Indonesia (khususnya kaidah 39, 40 CRC/KHA dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 16, 17, 59, dan 64).

Dengan kata lain, berbicara tentang penanggulangan kenakalan anak jalur penal, yang lazimnya terwujud lewat sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*, fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan pidana, pertimbangan-pertimbangan hukumnya pun tidak terbatas hanya pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, akan tetapi harus pula memerhatikan ketentuan UU lain yang mengatur tentang perlunya diperhatikan dan diutamakan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Berdasarkan pengamatan di beberapa pengadilan negeri tampaknya landasan hukum utama yang selalu menjadi pegangan hakim dalam menangani anak-anak pelaku kenakalan adalah UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Walaupun toh harus diakui bahwa kecenderungan itu sebetulnya kurang tepat mengingat adanya ketentuan UU lain yang secara struktural dapat dikategorikan sebagai sistem hukum anak Indonesia.

Atas dasar pertimbangan tersebut di bawah ini akan dikemukakan telaah terhadap ketentuan substantif UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, apakah ketentuan substanfif UU tersebut cukup memadai sebagai dasar penanganan anak di Indonesia atau mungkin perlu diamandemen agar *trep*

[5]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 49.

dengan asas-asas perlindungan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)?



Telaah UU No. 3 Tahun 1997: Pengadilan Anak

Pertimbangan Lahirnya UU No. 3 Tahun 1997

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak) disahkan berlaku pada 3 Januari 1997 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1977 No. 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 3688. Pertimbangan utama diundangkannya UU ini antara lain ialah kehendak pemerintah untuk mewujudkan suatu penanganan perkara anak yang terlibat tindak pidana secara lebih baik daripada yang terdahulu dan penanganannya memerhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik dan mentalnya. Dengan lahirnya UU tersebut diharapkan petugas hukum yang menangani perkara anak, mulai dari tingkat penyidikan hingga ke tingkat persidangan, semuanya mendalami masalah anak, agar anak setelah perkaranya diputus, secara fisik dan mentalnya siap menghadapi masa depannya secara lebih baik.

UU No. 3 Tahun 1997 menggunakan istilah "Pengadilan Anak" bukan "Peradilan Anak" merupakan hasil proses panjang perbincangan di DPR RI. Rancangan UU tersebut semula memakai istilah UU tentang Peradilan Anak, Karena UU ini nantinya diharapkan dapat menjadi landasan hukum penanganan semua perkara yang menyangkut anak. Pemikiran yang muncul dalam perdebatan di DPR waktu itu (mengubah judul dari Peradilan Anak menjadi Pengadilan Anak) didasarkan pertimbangan istilah "Peradilan" menunjukkan lingkungan badan peradilan. Di Indonesia dikenal hanya adanya empat (4) lingkungan peradilan, yaitu (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) Sementara istilah "pengadilan" lebih mengacu pada fungsi badan peradilan. Pengadilan Anak merupakan pengkhususan dari sebutan badan peradilan, yaitu peradilan umum yang menyelenggarakan pengadilan anak. Pada akhirnya RUU yang semula berjudul Peradilan Anak pun menjadi UU Pengadilan Anak, suatu badan peradilan umum yang mengadili perkara anak pidana.[6]

UU Pengadilan Anak bila dicermati dari parameter hukum pidana anak sebagai suatu sistem hukum pidana anak yang di dalamnya terkandung adanya hukum pidana anak materiil, formal, dan penitensier, secara substantif belum

[6]DPR RI, Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak, (Jakarta: DPR RI 1996), hlm. 5.

sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hukum pidana anak. Substansinya masih banyak yang harus mengacu pada ketentuan KUHP dan KUHAP.

Ketentuan Substantif UU No. 3 Tahun 1997

UU Pengadilan Anak, secara garis besar di dalamnya terkandung ketentuan-ketentuan pokok yang terdiri atas (a) pembatasan umur orang yang dapat disidangkan dalam acara persidangan anak adalah 8 – 18 tahun (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat 1); Ruang lingkup masalah dibatasi hanya menyangkut masalah perkara anak nakal (Pasal 1 ayat 2); (c) Ditangani oleh Petugas Khusus, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan, yaitu penyidik khusus anak, penuntut umum khusus anak, hakim khusus anak. (Pasal 1 ayat 5, 6, dan 7); (d) Pembimbingan Kemasyarakatan ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Pekerja Sosial Sukarela berperan penting dalam pengadilan anak (Pasal 1 ayat 11); (e) Suasana Pemeriksaan Kekeluargaan (Pasal 42 ayat 1); (f) Keharusan *splitsing*, bila ternyata anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa, penanganannya dipisahkan (Pasal 7); (g) Acara Pemeriksaan Tertutup (Pasal 8 ayat 1); (h) Diperiksa Hakim Tunggal (Pasal 11, 14, dan 18); (i) Masa Penahanan lebih singkat (Pasal 44 s/d 49), dan (j) Hukuman lebih ringan, maksimum hukuman 10 tahun bila tindak pidana yang diperbuat anak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. (Pasal 22 s/d 32).

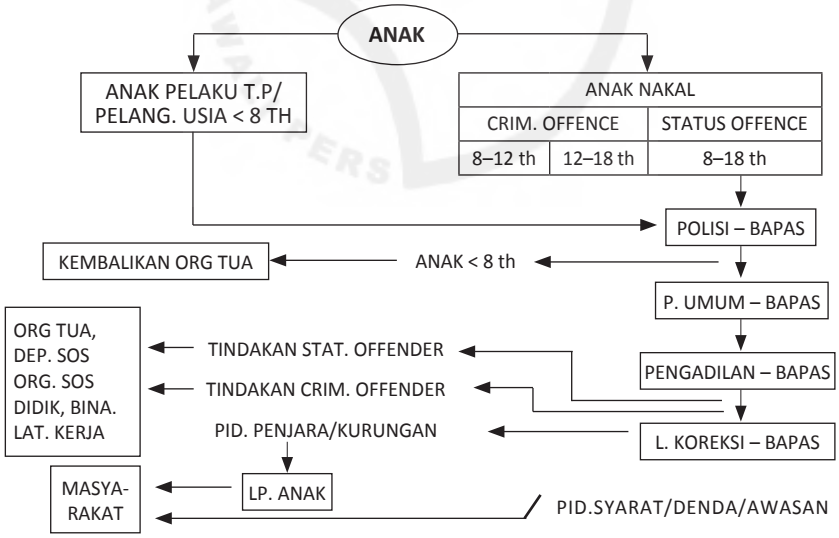
Kewenangan Sidang Anak hanya memeriksa dan menyelesaikan perkara anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak (Pasal 21). Bagi anak nakal dapat dijatuhkan sanksi pidana dan/atau tindakan. Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan. Pidana Tambahan terdiri atas pidana perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti kerugian (Pasal 23, 28, 29, 30, dan 32). Tindakan terdiri dari pengembalian anak pada orang tua, penyerahan anak pada negara atau penyerahan anak kepada Departemen Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan, di samping itu ditambahkan juga teguran dan syarat tambahan lain (Pasal 24).

Petugas Kemasyarakatan terdiri dari (a) Pembimbing Kemasyarakatan; (b) Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan (c) Pekerja Sosial dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Pasal 33). Pembimbing Kemasyarakatan, adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) bertugas melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan (Pasal 1 angka 11). Petugas Kemasyarakatan bertugas (a) membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; (b) membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan pada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak

yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 34 ayat 1). Petugas Sosial bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Di dalam pelaksanaannya Petugas Kemasyarakatan berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 34 ayat 3). Pekerja Sosial Sukarela (seperti LSM) yang memiliki pengetahuan, dan kemudian dan minat membantu anak nakal ditugaskan membantu dan berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Petugas Sosial dari Departemen Sosial (Pasal 39 ayat 1).[7]

Ini berarti bahwa peranan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS dalam perkara sidang anak, mengalami perubahan peran yang cukup signifikan, karena kini kedudukan BAPAS tidak sepenuhnya berada di "lini belakang" dalam mata rantai proses pemidanaan anak, melainkan sudah sejak awal di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan sudah dituntut peranannya untuk memberikan laporan kemasyarakatan anak pelaku delinkuen. Perubahan peran ini sudah barang tentu akan menuntut pembenahan personalia (*staffing*) dan peningkatan SDM petugas BAPAS di masa datang.

Secara skematis alur penanganan anak nakal menurut UU Pengadilan Anak, dapat dikemukakan dalam ragaan berikut ini.



Gambar 34.2 Model Peradilan pidana anak – UU No. 3/1997

[7]Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 3, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, (Jakarta: Sekretariat Kabinet, 1997).

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tanpa Diversi

Telaah terhadap Ketentuan Substantif dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana (KUHAP) mengisyaratkan bahwa bila anak karena perilaku penyimpangannya (*criminal atau status offences*) sudah masuk "mesin peradilan pidana anak" model UU Pengadilan Anak dan KUHAP, maka penanganan perkara anak itu tidak dapat dihentikan di tengah-tengah proses pemidanaan, proses harus tetap jalan sampai ada putusan pengadilan. Kasus Raju paling tidak dapat menjadi contoh konstatasi tersebut, di tengah proses pemidanaan, walaupun Raju telah menunjukkan trauma selama pemeriksaan kasusnya, proses pemidanaan harus tetap jalan hingga putusan pengadilan.

Konstatasi tersebut memberikan kesan bahwa ketentuan UU Pengadilan Anak pada dasarnya mengandung kelemahan, karena kekhususan penanganan anak yang menjadi konsiderans lahirnya UU tersebut, ternyata dalam praktiknya, justru menjadikan proses pemidanaan anak melahirkan penderitaan psikis bagi anak pelaku. Hal ini terjadi karena UU Pengadilan Anak tidak mengakomodasi apa yang dinamakan Diversi. Diversi adalah satu bentuk pembelokan penanganan anak pelaku kenakalan di luar jalur justisial konvensional. Secara substantif ketentuan Diversi pada hakikatnya dapat menjadi klep pengaman bagi penanganan kasus-kasus anak bila ternyata anak mengalami hal-hal yang menderita dalam proses penanganan anak secara konvensional, dan pada gilirannya akan mampu pula berperan sebagai klep pengaman agar anak tidak terstigmatisasikan oleh proses pemidanaan yang lazimnya sering terjadi dalam sistem peradilan pidana (anak).

Instrumen internasional yang terkandung di dalam Resolusi PBB 40/33 *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice,* utamanya dalam Rule 11 beserta Commentary-nya yang secara lengkap dapat dikemukakan berikut ini.[8]

> Rule 11
>
> *Diversion, involving removal from criminal justice processing and, fre quently, redirection to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal systems. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention could be the best response. Thus diversion at the outset and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school or other informal social control institutions have already reached, or are likely to react, in a appropriate and constructive manner."*

[8]*United Nations Standard Minimum rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules), Adopted by General Assembly resolution of 40/33 of 29 November 1993. Compilation of International Instruments, volume I, (First Part), Universal Instruments, (*New York: United Nations, 1993), p. 362.

Diversi, sangat penting untuk diperhatikan dalam penanganan anak pelaku kenakalan ini. Diversi dapat menghindarkan anak dari proses stigmatisasi yang lazimnya terjadi dalam proses pemidanaan anak lewat sistem peradilan pidana anak. Bila diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam resolusi PBB 40/33 dan kecenderungan pengaturan proses pemidanaan anak di berbagai negara (Amerika Serikat, Inggris, Negeri Belanda, Australia, Selandia Baru, dan Jepang), semuanya mengatur tentang diversi dalam penanganan anak pelaku kenakalan. Dari sisi pemberian perlindungan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child protection*), seperti diamanatkan oleh resolusi PBB 44/25 *Convention of the Rights of the Child (CRC)* yang sudah dinyatakan berlaku di Indonesia lewat Keppres No. 36 Tahun 1990 yang menegaskan perlunya negara-negara anggota PBB untuk memerhatikan dan memberikan perlindungan "*the best interests the child.*" Sejalan dengan amanat instrumen internasional tersebut di atas, maka pengakomodasian terhadap ketentuan tentang diversi menjadi sangat penting dalam penanganan anak pelaku kenakalan. Dengan diversi sangat dimungkinkan penuntutan pidana gugur dan *criminal tract-record* anak pun tidak ada, dan dengan sendirinya stigmatisasi anak dapat dicegah.[9]

Ketentuan diversi ini bila kemudian dikaji dari aspek filsafati dan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan segala aspeknya dan kondisi sosiokultural masyarakat negeri ini, rasanya akomodasi ketentuan tentang diversi pun dalam penanganan anak-anak nakal cukup relevan pula untuk dipertimbangkan dalam pembangunan sistem hukum (pidana) anak masa datang. Ini berarti secara substantif perlu adanya langkah-langkah reformasi hukum dan sistem hukum (pidana) anak di Indonesia, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan amandemen UU Pengadilan Anak yang kini menjadi dasar hukum penanganan anak-anak pelaku kenakalan, dengan cara memasukkan ketentuan tentang diversi tersebut.

Amandemen terhadap UU Pengadilan Anak ini relevan untuk dilakukan di samping alasan-alasan filsafati normatif di atas, juga dipertimbangkan dari implementasi UU Pengadilan Anak itu dalam praktik penanganan anak-anak pelaku kenakalan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa hampir semua kasus-kasus kenakalan anak ini berbuah pada penjatuhan pidana pada anak-anak pelaku. Bahkan penjatuhan pidana ini pun tidak secara memadai diikuti dengan langkah-langkah pembinaan seperti yang diamanatkan oleh berbagai seruan instrumen-instrumen internasional, dan jiwa yang terkandung di dalam UU Pengadilan Anak itu sendiri, yaitu Model Pembinaan Individual *(Individual Treatment* Model). Praktik pembinaan anak sering tidak dilakukan di tempat-tempat pembinaan yang dikhususkan bagi anak-anak pelaku kenakalan, tetapi

[9]Margo. F. Andriesen, *Buitenjustitiele aanpak van Jeudige delinkwenten,* (Arnhem: Gouda Quint, bv, 1995), hlm. 24.

dilakukan di tempat lain (tempat pembinaan napi dewasa). Apakah praktik pembinaan anak nakal yang demikian ini tidak semakin membekaskan stigma pada diri anak pelaku kenakalan, dan pada gilirannya akan sangat mengganggu perkembangan jiwa anak di masa datang.

Secara kriminologi, stigmatisasi atau pemberian label pada pelaku kejahatan pada umumnya dan kenakalan anak pada khususnya merupakan faktor kriminogen. Pelaku setelah memasuki gerbang perilaku penyimpangannya (*the first deviance*) akan tumbuh kembang menuju kariernya pada pengulangan perilaku kenakalannya di masyarakat sebagai dampak dari stigma yang ia sandang itu (*the secondary deviance*)

Dari paparan di atas, menjadi jelas kiranya bahwa baik secara filsafati normatif dan sosiologis, amandemen terhadap UU Pengadilan Anak dengan memasukkan ketentuan tentang Substantif menjadi penting untuk segera dilaksanakan, dalam rangka pencegahan anak dari proses stigmatisasi yang dialami lewat "mesin peradilan pidana anak."



Penutup

Sebagai akhir dari sajian ini ingin dikemukakan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam sajian segenggam (*in a nutshell*) ini. Adapun pokok-pokok pikiran itu adalah sebagai berikut.

1. Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu memperoleh hak-haknya untuk tumbuh kembang secara kejiwaan dalam masyarakat negeri ini.
2. Anak dalam kehidupannya karena faktor-faktor di sekelilingnya tak jarang berperilaku menyimpang dalam masyarakat.
3. Anak yang berperilaku menyimpang disebut juga sebagai anak yang bermasalah atau anak yang berhadapan dengan hukum
4. Penanganan anak-anak bermasalah atau berhadapan dengan hukum di negeri ini ditangani berlandaskan pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan beberapa UU yang relevan dengan itu (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Ketentuan Substantif yang terdapat di dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak bila dikaji dari asas-asas hukum yang terkandung di dalam instrumen-instrumen internasional, sistem hukum (pidana) anak di berbagai negara dan Nilai-nilai Pancasila dan kondisi sosiokultural secara substantif mengandung kekurangan
6. Kekurangan atau cacatnya UU No. 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak melahirkan praktik penanganan anak yang cenderung berbuah pada stigmatisasi anak.

7. Klep pengaman bagi pencegahan proses stigmatisasi penanganan anak-anak nakal (menurut istilah UU Pengadilan Anak) adalah ketentuan tentang Diversi.
8. Diversi yang diamanatkan oleh resolusi PBB ternyata sudah diakomodasi oleh sistem hukum (pidana) anak di berbagai negara belahan dunia ini.
9. Diversi perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam peraturan perundangan yang menyangkut anak pidana di negeri ini.
10. Amandemen UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak perlu dilakukan dengan memasukkan ketentuan tentang Diversi di dalam norma-normanya.

Daftar Referensi

Becker S. Howard. Outsiders. *Study in Sociology*. New York: The Free Press of Glencoe, 1963.

Braithwaite, John. *Crime, Shame and Integration*. Cambrigde: University Press, 1989.

————————. "Shame and Criminal Justice", in Canadian Journal of Crimino logy, July, 2000.

Hadi Suprapto, Paulus. *Perilaku Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayu Media, 2008.

DPR-RI. Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak. Jakarta: DPR RI, 1996.

Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 3. *Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*. Jakarta: Sekretaris Kabinet, 1997.

Margo F. Andriesen. *Buitenjustitiele aanpak van Jeudige delinkwenten*. Arnhem: Gouda Quint, bv, 1995.

Nawawi Arief Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1977.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (the Beijing Rules), a Compilation of International Instruments, Volume 1 (First Part), Universal Instruments New York: United Nations, 1993.

Zehr, H. *Changing Lenses: a New Focus for Crime and Justice*. Scotdale: PA Harold Press, 1990.

35

UNDANG-UNDANG CUKAI TAHUN 2007:
"Sebuah Kegamangan yang Membelenggu"

Oleh:
*Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.H.**

Presiden pada tanggal 15 Agustus 2007 mengesahkan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan, (selanjutnya disebut politik hukum cukai) antara lain adalah (1) Untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan; (2) bahwa cukai sebagai pungutan negara merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa; dan (3) sebagai upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai. Kesejahteraan, keadilan, dan kepastian hukum di sini harus dipandang sebagai prasarat dan *conditio sine qua non* demi terciptanya negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Materi yang menjadi substansi perubahan dari UU No. 11 Tahun 1995 ke UU No. 39 Tahun 2007 adalah (a) perluasan cara pelunasan cukai yang lebih akomodatif untuk menyesuaikan dengan praktik bisnis tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak Negara; (b) penyempurnaan sistem penagihan utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dengan menambah skema pembayaran secara angsuran tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara; (c) menghapus ketentuan yang mengatur lembaga banding untuk mkenyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; (d) penyelenggaraan pembukuan yang diselaraskan dengan perkembangan jaminan dan ketentuan audit cukai; (e) penegasan penggunaan dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai dalam bentuk data elektronik dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pihak yang mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai

*Yusriyadi, Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang.

secara tidak sah; (f) pengaturan tentang pembinaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kode etik dan penyelesaian pelanggarannya (*punishment*) melalui komisi kode etik serta pemberian insentif kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan kinerja; (g) pengaturan pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berjasa; dan (h) pengaturan tentang bagi hasil cukai hasil tembakau kepada pemerintah daerah (Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 2007 Angka 4).

Tulisan berikut, tidak dimaksudkan untuk mengkaji seluruh materi yang menjadi substansi perubahan dari UU No. 11 Tahun 1995 ke UU No. 39 Tahun 2007 tersebut, melainkan dibatasi pada materi perubahan yang berkaitan dengan pengaturan tentang bagi hasil cukai hasil tembakau kepada pemerintah daerah.



Pasal 66 A- Pasal 66 D UU No. 39 Tahun 2007 dan Problematiknya

Pasal 66A – 66D UU No. 39 Tahun 2007 pada dasarnya mengatur substansi tentang hal-hal sebagai berikut:

a) Besarnya bagian daerah dari hasil cukai tembakau adalah 2% (dua persen).
b) Penggunaan dana bagi hasil cukai tersebut adalah untuk: *mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai illegal*.
c) Gubernur diberikan kewenangan untuk mengelola dan mempergunakan dana bagi hasil cukai tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai tembakau kepada kabupaten/kota.
d) Komposisi pembagian provinsi dan kabupaten/kota adalah 30% untuk Provinsi Penghasil, 40% untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% untuk kabupaten/kota lainnya.
e) Penyaluran dana dilakukan dengan pemindahbukuan.
f) Menteri Keuangan bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana bagi hasil tersebut.
g) Dalam hal terjadi dugaan penyimpangan penggunaan dana akan diberikan sanksi administratif berupa penangguhan sampai dengan pemberhentian penyaluran dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 66 A- Pasal 66 D UU No. 39 Tahun 2007, telah diterbitkan produk hukum berupa dua Peraturan Menteri Keuangan yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK. 07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Menteri

Keuangan No. 84/PMK. 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Mendahului lahirnya dua Peraturan Menteri Keuangan, di Jawa Tengah untuk menyelenggarakan pengaturan atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dikeluarkan produk hukum berupa Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Peraturan Gubernur tersebut, yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Bagi Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008. Lahirnya dua Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang mendahului dua Peraturan Menteri, boleh dipandang sebagai tindakan yang responsif, bahkan progresif dari aparat eksekutif di Jawa Tengah. Sayangnya, dua Peraturan Gubernur tersebut seakan-akan hanya mengulang-ulang rumusan normatifnya semata, sehingga sekadar lebih menguatkan kemauan pemerintah pusat, bukan memerinci bagaimana penggunaan dana alokasi cukai hasil tembakau untuk kebutuhan daerah.



Fungsi UU Cukai Tahun 2007, Sebuah Kegamangan

Secara teoretik, dapat disebutkan dua fungsi hukum sekaligus, yakni fungsi *social control* dan fungsi *social engineering*. Fungsi yang pertama, bertujuan menciptakan ketertiban dengan mengendalikan perilaku warga, sedang fungsi kedua, hukum hendaknya juga digunakan sebagai alat, yakni alat untuk "rekayasa sosial". Dalam UU Cukai 2007, fungsi *social control* ini tampak dari fungsinya untuk mengatur/mengendalikan perilaku warga, membatasi dan mengawasi barang-barang yang karena "sifat dan karakternya" dikenakan cukai agar pemakaiannya terkendali. Fungsi ini dapat disejajarkan sebagai fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur. Dalam konteks cukai, fungsi ini boleh dibilang sebagai fungsi yang letaknya di luar bidang keuangan negara atau non-fiskal. Sementara dalam fungsinya sebagai *social engineering*, UU cukai idealnya difungsikan sebagai alat (*tool*) untuk melakukan perubahan-perubahan sosial menuju masyarakat Indonesia baru yang dikehendaki. Ironisnya, terkesan bahwa UU Cukai, lebih mencerminkan fungsi budgeter ketimbang fungsi regulerend. UU Cukai lebih sekadar sebagai alat (*tool*) untuk memasukkan uang ke kas negara untuk pembiayaan pengeluaran negara baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Negara bagaikan fiscus, atau keranjang uang. Di sini UU Cukai justru digunakan secara sadar, sengaja, dan terencana sebagai alat untuk menggali dan meningkatkan penerimaan keuangan negara, fungsi ini analog sebagai fungsi pendapatan (budgeter atau fiskal).

Pasal 1 angka 1 UU Cukai 2007 menyebutkan cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian Pasal 2 UU Cukai Tahun 2007, menyebut bahwa sifat dan karakteristik tersebut adalah (a) konsumsinya perlu dikendalikan; (b) peredarannya perlu diawasi; (c) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungannya atau; (d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Cukai Tahun 2007. Pasal 4 UU No. 11 Tahun 1995, menyebutkan bahwa barang kena cukai meliputi (a) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang dipergunakan dan proses pembuatannya; (b) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun dengan tidak mengindahkan bahan yang dipergunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; (c) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Jika dijumbuhkan dengan karakteristik khusus yang telah ditetapkan oleh UU, ketiga barang kena cukai tersebut pada dasarnya pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, oleh karena itu konsumsinya perlu dibatasi dan peredarannya perlu diawasi. Beberapa data angka berikut ini memperkuat pendapat betapa besarnya bahaya merokok, sehingga rokok perlu dikendalikan dan diawasi peredarannya: (a) Rp 130 triliun biaya konsumsi tembakau di Indonesia tiap tahun. Penerimaan cukai tembakau tiap tahun sekitar Rp 16,5 triliun; (b) 5,4 juta orang meninggal dalam setahun karena penyakit yang berkaitan dengan rokok, seperti kanker paru dan penyakit jantung; (c) 100 juta orang di dunia terbunuh oleh tembakau pada abad ke-20; (d) 37,3% pelajar Indonesia pernah merokok, dan 31 persen pertama kali merokok di bawah usia 10 tahun; (e) 8 juta orang per tahun diperkirakan mengalami kematian akibat tembakau pada 2030. Dan selama abad ke-21 diperkirakan tembakau membunuh satu miliar orang; (f) 427.948 perokok meninggal di Indonesia, dalam setahun. Angka ini setara dengan 22,5 persen total kematian di Indonesia; (g) 20% dari pendapatan rata-rata (Rp 20 ribu per hari) penduduk Indonesia digunakan untuk membeli rokok; (h) 82% perokok di dunia ingin berhenti merokok dan hanya 2% yang berhasil tanpa bantuan (Tri Budiyono, 2008: 5).

Sering disebut bahwa cukai rokok dikategorikan sebagai *tax of sin* (pajak dosa), sebab barang yang dikenai cukai adalah barang "berdosa". Itulah dasar filosofis yang mendasari pengenaan cukai terhadap ketiga barang kena cukai tersebut. Dalam rangka mengendalikan dan mengawasi peredaran rokok, langkah pertama biasanya dilakukan dengan cara menaikkan pajak dan harga rokok. "Menaikkan pajak adalah cara terbaik untuk menurunkan konsumsi," demikian kata Dr. Douglas Bettcher, Direktur Inisiatif Bebas Tembakau di Badan Kesehatan Dunia (*Tempo* Majalah Berita Mingguan, 15/XXXVII 02 Juni 2008).

Berangkat dari konstatasi tersebut, politik hukum UU cukai idealnya harus lebih berada pada ranah fungsi *regulerend* ketimbang pada ranah fungsi budgeter. Artinya, UU cukai harus menjadi istrumen untuk mengendalikan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi rokok dan alkohol, karena potensi dampak negatif yang diakibatkannya. Dengan meminjam istilah Roscoe Pound: *law* (baca UU tentang Cukai) *is a tool of social engineering,* maka menaikkan cukai rokok, yang pada gilirannya akan menaikkan harga jual rokok, dapat men-*drive* (mentransformasi) perilaku mengonsumsi rokok. Keberhasilan dari UU Cukai, khususnya terhadap konsumsi tembakau adalah apabila mampu ditekan, dikendalikan dan diawasi, sekalipun akibatnya jumlah uang yang dihasilkan negara dari cukai semakin mengecil. Logikanya, semakin kecil konsumi masyarakat terhadap minuman beralkohol dan rokok, misi UU tentang Cukai semakin berhasil. Namun, keberhasilan mengendalikan konsumsi minuman beralkohol dan (utamanya) rokok, harus dibarengi kesediaan negara untuk mengorbankan penerimaan negara dari sektor cukai ini (Tri Budiyono, 2008: 6).

Dalam UU Cukai, terkesan bahwa sikap pemerintah masih gamang bahkan disorientatif. Kegamangan ini tampak dari politik hukum dari pemberlakuan UU tentang Cukai. Dapat dibaca secara jelas bahwa pembentuk UU Cukai justru meletakkan fungsi *budgeter*, bukan fungsi *regulerend*. Pada tataran praksis, pemerintah enggan melepaskan potensi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang mencapai kurang lebih 50 triliun rupiah pada 2008 (Tri Budiyono, 2008:7). Di sinilah tampak kegamangan sikap pemerintah, sehingga boleh dibilang bahwa UU Cukai 2007 lahir karena sikap kegamangan pemerintah atau pembuat undang-undang. Tidak mengherankan jika pabrik rokok telah merasa menjadi sapi perah karena partisipasi yang telah diberikan pada saat memberikan masukan ke kas negara. (*Tempo* Majalah Berita Mingguan, 31/ XXXVII 22 September 2008).



Tiga Nilai Dasar UU Cukai

Secara teoretik harus disadari bahwa setiap undang-undang baik dalam proses pembuatan maupun penegakannya harus bertumpu pada tiga nilai dasar, yakni (1) kepastian, (2) kemanfaatan, dan (3) keadilan. Demikian juga terhadap UU Cukai 2007. Berhasil tidaknya UU Cukai tersebut bertumpu pada tiga nilai dasar pada saat didaratkan pada tataran praksis, tergantung pada aparat pelaksana penegak hukum (*law enforcement officer*).

Pada umumnya, paradigma yang mendasari penegakan hukum adalah paradigma positivistik. Paradigma positivistik, menganggap hukum (baca UU, *lege, atau lex*) sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Bukankah ada pepatah Latin kuno yang mengatakan "*Serva ordinem et ordo servabit te*" yang artinya layanilah peraturan maka peraturan itu akan melayanimu. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: v). Analog dengan pepatah ini misalnya, adagium "se-

kalipun langit akan runtuh hukum harus ditegakkan." Paul Scholten misalnya, pernah mengingatkan pada kita, bahwa hukum itu dibuat untuk ditegakkan dan apabila hukum itu tidak pernah dapat ditegakkan, maka berhentilah sebagai hukum (Satjipto Rahardjo, 1996: 1-2). Paradigma positivistik ini lebih mengutamakan nilai kepastian hukum, bukan nilai kemanfaatan dan/atau keadilan. Konsekuensinya, jika paradigma positivistik tetap dikukuhi sebagai satu-satunya kebenaran, tak menutup kemungkinan justru menempatkan aparat pelaksana penegak hukum (*law enforcement officer*) sekadar sebagai "mulut undang-undang" (*subsumptie automat*, *la boche de la loi*) atau sekadar membunyikan undang-undang saja. Aparat penegak hukum di sini tidak mempunyai sedikit pun kebebasan/keleluasaan bertindak untuk menilai apakah pelaksanaannya tersebut bermanfaat dan adil bagi masyarakatnya. Ironisnya, paradigma positivistik inilah yang justru terlanjur "mapan" sebagai satu-satunya paradigma yang harus diikuti dan dikukuhi dalam menegakkan hukum.



Makna Sosiologis UU Cukai

Tanpa bermaksud menafikan paradigma positivistik, tulisan dibuat dengan lebih mengacu pada paradigma sosiologis. Dengan paradigma ini, UU Cukai 2007 diposisikan bukan sekadar sebagai institusi peraturan (yang sarat dengan prosedur dan mekanisme formal) semata melainkan juga berposisi sebagai institusi sosial mengedepankan juga pada nilai kemanfaatan.

Melalui UU Cukai 2007, suatu perubahan telah terjadi, yakni semula dana cukai masuk kas pusat (hak sepenuhnya pemerintah pusat) telah dialokasikan sebagian ke pemerintah daerah. Namun sayangnya, penggunaan dana yang dialokasikan tersebut terkesan harus begitu mengikuti kemauan pemerintah pusat, tidak mendasarkan pada kebutuhan daerah. Hal ini tampak dari ketentuan dalam UU Cukai yang secara normatif (bahkan limitatif) pemerintah pusat "mendikte". Konsekuensinya, akan lebih banyak ditafsir harus digunakan sesuai kehendak pemerintah pusat, bukan pada kebutuhan daerah sehingga menggunakan dana alokasi cukai di luar apa yang secara normatif disebut oleh UU Cukai, adalah "risiko". Risiko ini misalnya, dapat dikenai sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian menerima jatah (Pasal 66 D ayat (1) UU Cukai). Bahkan kekhawatiran tidak berhenti pada sanksi administratif, sebab tidak menutup kemungkinan adanya sanksi pidana bagi penanggung jawab pelaksana kegiatan, yakni dijerat sebagai penyalahgunaan keuangan negara. Harus disadari sejak awal bahwa UU Cukai 2007 "besar potensiil mengandung pertelingkahan/ketegangan" pada saat didaratkan pada tataran praksis. Dalam posisi ketegangan itu, dapatkah nilai kemanfaatan lebih dikedepankan daripada sekadar menuruti nilai kepastian? Terkesan dari daftar kegiatan yang normatif limitatif disebut dalam UU Cukai, tak tampak kegiatan yang berorientasi pada kepentingan daerah, misalnya kepentingan

daerah untuk melindungi korban dari bahaya merokok dan akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari penggunaan rokok, kebutuhan daerah untuk lebih mengefisienkan pemberdayaan petani tembakau dan sebagainya.



Dana Alokasi Cukai, Ibarat Uang ”Dadakan/Tiban”

Terbitnya UU No. 39 Tahun 2007, di lima provinsi dengan sejumlah kabupaten/kota di masing masing Provinsi bisa diibaratkan telah muncul “uang dadakan/tiban.” Dari data 2007, kelima provinsi itu adalah (1) Provinsi Sumatera Utara, (2) Provinsi Jawa Barat, (3) Provinsi Jawa Tengah, (4) Provinsi DI Yogyakarta, dan (5) Provinsi Jawa Timur. Besaran dana alokasi cukai tidak sama, terbesar Provinsi Jawa Timur (Rp200.000.000.000), kemudian menyusul Jawa Tengah (Rp52.195.765.000;), Jawa Barat (Rp9.477.790.000), Sumatera Utara (Rp1.426.990.000) kemudian Provinsi DI Yogyakarta (Rp1.049.600.000). Untuk kabupaten/kota, terbesar adalah Kabupaten Kudus. Diibaratkan sebagai uang dadakan/tiban, terlebih penggunaannya secara limitatif diatur dalam UU dengan segala konsekuensinya, tak menutup kemungkinan penggunaan dana tersebut justru ”membingungkan”. Menuruti aspek kepastian hukum (*rechtmatigheid*), penggunaannya akan jauh dari prioritas kebutuhan daerah. Hal lain yang menarik untuk dikritisi adalah besaran alokasi dana cukai berdasar pada besarnya kontribusi penghasil cukai. Ini artinya UU Cukai 2007 menempatkan besar kecilnya penghasil cukai sebagai dasar pembagian dana alokasi. Pasal 66 A UU No. 39 Tahun 2007, Pemerintah Pusat mengalokasikan sebesar 2% kepada daerah penghasil cukai. Ini menarik, sebab dasar argumentatif atau dasar filosofis dibalik angka 2% tersebut tidak ditemukan. Mengapa 2% dan tidak 10% atau 50%? Apakah pembagian 2% untuk daerah dinilai sebagai sesuatu yang adil, bagaimana formulasi pembagian itu jika dikaitkan dengan pembiayaan otonomi daerah? Apakah alokasi 2% tersebut sekadar untuk membangun citra (*image*) bahwa pemerintah pusat telah berbaik hati? Terlepas dari persoalan itu, Undang-Undang Cukai 2007 memberikan alokasi 2% adalah sebagai kepastian. Masalahnya, apakah ketentuan 2% ini tinggal diterima dan dilaksanakan (*taken for granted*) begitu saja demi kepastian hukum (kepastian UU?), sehingga ke depan tak perlu dipersoalkan. Kemudian bagaimana tentang daerah yang oleh undang-undang tidak dianggap sebagai daerah penghasil cukai meskipun daerah-daerah tersebut juga mengonsumsi rokok. Daftar permasalahan tersebut dapat diperpanjang, namun intinya adalah bahwa dalam tataran praksis, UU Cukai 2007 perlu ditegakkan secara progresif.



Perlunya Penegakan Secara Progresif

Secara normatif, dana bagi hasil cukai hasil tembakau penggunaannya telah diatur secara limitatif, yakni untuk mendanai peningkatan kualitas bahan

baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan /atau pemberantasan barang kena cukai illegal. Dalam penegakan UU Cukai manakala paradigma positivistik dikukuhi sebagai satu-satunya kebenaran akan menimbulkan berbagai persoalan. Persoalannya, yakni pada waktu UU Cukai 2007 tersebut didaratkan pada tataran praksis kehidupan yang kian demokratis dan *people centered* bersamaan dengan era otonomi daerah. Dapatkah nilai kepastian hukum semata mampu menopang ide dasar otonomi daerah. Atau, dapatkah UU Cukai 2007 disimpangi?

Secara teoretik dalam setiap penegakan (baca penerapan) undang-undang, akan selalu terjadi ketegangan antara nilai dasar kepastian (*rechtmatigheid*) dan nilai dasar kemanfaatan/kegunaan (*doelmatigheid*). Nilai kepastian lebih mendasarkan pada bentuk-formal rumusan yang rigid pada teks undang-undang, sementara nilai kemanfaatan lebih melihat pada substansi kepentingan riil adresat yang dituju oleh undang-undang. Dalam UU Cukai 2007, besaran pembagian daerah dan jenis penggunaan dana alokasi cukai secara normatif (dan limitatif/rigid) telah diatur, dan itulah yang secara normatif harus diterima dan ditegakkan. Dalam konteks otonomi daerah, segera muncul persoalan, misalnya apakah jenis-jenis kegiatan dimaksud merupakan urusan rumah tangga pemerintah daerah?"

Secara teoretik, urusan rumah tangga dapat dibedakan menjadi urusan rumah tangga pemerintah pusat yang sifatnya absolut, urusan rumah tangga pusat yang diserahkan ke daerah dalam bentuk tugas pembantuan (*medebewind*) dan urusan pemerintah daerah. Berangkat dari pembagian urusan rumah tangga tersebut pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah (a) peningkatan kualitas bahan baku rokok; (b) pembinaan industri rokok; (c) pembinaan lingkungan sosial; (d) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan (e) pemberantasan barang kena cukai ilegal, merupakan urusan rumah tangga pemerintah pusat atau urusan rumah tangga pemerintah provinsi atau urusan rumah tangga pemerintah kabupaten/kota? Atau kalau sulit untuk melakukan pemilahan terhadap kegiatan yang secara normatif tersebut menjadi urusan siapa, indikasinya dapat ditelusur balik dari praksis penanganan urusan rumah tangga yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: apakah sebelum ada dana bagi hasil cukai hasil tembakau kegiatan yang ditetapkan secara normatif tersebut telah dijalankan (diprogramkan) menjadi kegiatan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota? Jika jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah bahwa selama ini kegiatan normatif tersebut memang menjadi urusan rumah tangga pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, atau kegiatan normatif tersebut sebelum ada pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau telah dijalankan (diprogramkan) maka dapat disimpulkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak memperkuat otonomi daerah, demikian juga sebaliknya (Tri Budiyono, 2008: 8).

Secara teoretik, dalam setiap penerapan UU akan selalu menimbulkan ketegangan antara aspek kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*). Kepastian hukum dipumpunkan pada rumusan yang rigid pada UU, sedang kemanfaatan dipumpunkan pada kepentingan (riil) atau kebutuhan adresat (pihak yang menjadi target pemberlakuan) hukum. Dalam kasus penggunaan bagi hasil cukai hasi tembakau, muncul pertanyaan: apakah item item penggunaan yang dirumuskan dalam UU tersebut secara empiris menjadi prioritas program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota ? Kalau tidak, apakah Pemerintah Daerah memiliki keberanian untuk mengalihkan penggunaan dana tersebut untuk kepentingan lain? Jangan-jangan ketika dana tersebut digunakan untuk kepentingan lain, sekalipun diorientasikan betul-betul pada kepentingan masyarakat yang lebih tinggi, pengguna anggarannya dibidik melakukan tindak pidana penyalahgunaan anggaran dengan ancaman pidana korupsi.. Ada berbagai macam modus operandi tindak pidana korupsi (TPK) yang potensial menjerat pelaku tindak pidana, yaitu (1) TPK dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/D; (2) TPK dalam penyalahgunaan anggaran; (3) TPK dalam perizinan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan; (4) TPK penggelapan dalam jabatan; (5) TPK pemerasan dalam jabatan; (6) TPK penerimaan suap; (7) TPK gratifikasi; dan (8) TPK penerimaan uang dan barang yang berhubungan dengan jabatan (Tri Budiyono, 2008: 16).

Munculnya berbagai permasalahan yang melingkupi penggunaan dana bagi hasi cukai hasil tembakau, maka cara yang terbaik adalah diperlukan langkah-langkah progresif. Sekalipun untuk melakukan langkah-langkah progresif ini telah begitu terpasung oleh ancaman tindak pidana korupsi, namun sudah saatnya baik penegak hukum maupun aparat pengguna anggaran untuk duduk bersama memikirkan daya guna dan hasil guna dari penggunaan dana alokasi cukai tersebut. Di sinilah perlunya paradigma cara pandang yang sama antara pengguna anggaran dan pengawas pengguna anggaran (termasuk di dalamnya penegak hukum). Tak boleh lagi di antara mereka, untuk lebih cenderung menekankan aspek kepastian (*rechmatigheid*) semata, melainkan sudah saatnya untuk lebih berorientasi pada tujuan (*doelmatigheid*). Dengan duduk bersama, kelanjutannya adalah lebih bersifat positif, misalnya dapat dibentuk semacam kesepakatan parameter dalam menentukan ada tidaknya penyalahgunaan anggaran menjadi lebih objektif, tidak semata hanya ditafsir oleh pengawas pengguna anggaran. Langkah-langkah progresif inilah yang dipandang tepat untuk membuka jalan keluar mengatasi permasalahan pelik dalam setiap usaha penegakan hukum, yakni pada saat dihadapkan pada persoalan pelik adanya pertelingkahan/ketegangan antara kepastian hukum dan kegunaan hukum. Sekalipun demikian, sangat disadari betapa sulitnya menuju langkah-langkah progresif tersebut, namun sudah saatnya untuk dimulai.

Daftar Referensi

Budiyono, Tri. Quo vadis UU tentang Cukai: Dapatkah Bagi Hasil Cukai Tembakau Menopang Otda? Makalah Seminar Peraturan Perundang-undangan Bidang Cukai dengan Tema: "Problematika Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Untuk Menunjang Otonomi Daerah. Purwokerto, 10 s.d. 11 Desember 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. 1980.

Tempo, Majalah Berita Mingguan, 31/XXXVII 22 September 2008).

Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA). Jakarta, 2002.

Yusriyadi. Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Problematika Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Dalam Ranah Empiris), Makalah Seminar Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai dengan Tema: "Problematika Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Untuk Menunjang Otonomi Daerah. Purwokerto, 10 s.d. 11 Desember 2008.

36

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Oleh:
Dr. Kamarullah, S.H., M.H.

Pendahuluan

Rancangan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan yang diajukan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*), juga sebagai upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam undang-undang tersebut memuat asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) yang menjadi dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehingga menjadi sumber hukum materiil bagi Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi sumber hukum acara dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara. Sehubungan dengan eratnya hubungan antara hukum materiil yang memuat dan mengatur substansi pokok dan mendasar sebagai hukum untuk jalannya administrasi pemerintahan yang berlaku secara umum dengan hukum acara yang memuat prosedur formal pelaksanaan kaidah-kaidah hukum materiil tersebut oleh Peradilan Tata Usaha Negara, maka diperlukan adanya kesesuaian antara substansi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan melihat beberapa substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, maka kiranya perlu dikaji perubahan apa saja yang harus dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ke depan, agar Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dapat diterapkan secara efektif.



Permasalahan

Dengan adanya beberapa substansi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan membawa konsekuensi kepada perubahan terhadap Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, permasalahannya adalah Ketentuan–ketentuan pokok apa saja yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar bagi perubahan terhadap Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



Pembahasan

Beberapa ketentuan pokok yang diatur di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

1. Perluasan Kompetensi PTUN

Dalam Pasal 1 angka 1 RUU Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam mengambil tindakan hukum dan/atau tindakan faktual oleh badan atau pejabat. Ketentuan ini memberi makna perluasan terhadap kewenangan yuridiksi Peradilan Tata Usaha Negara yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ketentuan ini membatasi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara hanya sebatas tindakan hukum yang berupa Keputusan TUN, sedangkan tindakan pemerintahan (*bestuurhandelingen*) meliputi juga "tindakan materiil" (*feitelijke handelingen*). Tindakan hukum adalah perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Ini berarti adanya "kehendak" dari badan atau pejabat tata usaha negara tersebut untuk melakukan suatu perbuatan yang akan menimbulkan suatu akibat hukum tertentu, seperti misalnya: pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha, Pengangkatan seseorang menjadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Sebaliknya jika suatu perbuatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan materiil/faktual, misalnya perintah pembongkaran, pelebaran jalan raya, dan lain sebagainya.

Suatu tindakan pemerintahan tidaklah cukup hanya dilihat dari "kehendak" badan atau pejabat tata usaha negara saja, akan tetapi juga harus dilihat "kondisi objektif" dari akibat adanya tindak pemerintahan. Dalam hal ini tindakan pemerintahan yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (tindakan materiil), ternyata secara objektif menimbulkan akibat merugikan masyarakat, seperti tindakan PDAM menggali lobang untuk memperbaiki pipa saluran air yang ternyata menimbulkan kecelakaan bagi seseorang. Dalam hal ini, orang yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ganti rugi, meskipun pihak PDAM tidak berkehendak untuk mencelakakan orang tersebut. Selama ini tindakan materiil/*factual* termasuk dalam perbuatan "melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overhead daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan masuk dalam kompetensi dari Peradilan Umum (*vide* Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). Sedangkan siapa yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Pemahaman terhadap konsep badan atau pejabat tata usaha negara terkait erat dengan rumusan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 9 Tahun 2004 yang rumusannya adalah: "badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya penjelasan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" ialah kegiatan yang bersifat eksekutif. Pertanyaan, apakah "urusan pemerintahan (eksekutif)" sama dengan "wewenang pemerintahan"? Terhadap hal demikian tampaknya istilah eksekutif begitu populer kita gunakan tanpa menyadari kontradiksi yang terdapat dalam pengertian itu sendiri. Pada dasarnya pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang, tetapi atas dasar *"ermessen"* dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun belum diatur secara tegas oleh undang-undang.

Kepustakaan Belanda lebih populer menggunakan istilah *"bestuur"* daripada istilah *"uitvoerende macht"*. Dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara, di samping keputusan pelaksanaan (*executive decision* atau *gebonden beschikking*) juga ada keputusan bebas (*discretionary decision* atau *vrije beschikking*). Kepustakaan Belanda menggambarkan kegiatan/lapangan "*besturen"* adalah seluruh lapangan kegiatan negara setelah dikurangi "*regelgeving*" dan "*rechtspraak*". Dengan demikian, kalau pengertian tata usaha negara diartikan sebagai urusan pemerintahan (Pasal 1 angka 1), maka urusan pemerintahan itu tidak hanya meliputi kegiatan yang bersifat eksekutif saja. Mungkin konsep Belanda tersebut dapat kita gunakan untuk merumuskan pengertian urusan pemerintahan itu secara tepat. Hal ini menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan "*toetsingsgronden"* (Philipus M. Hadjon, 2004; 138).

Demikian pula, Hamid S. Atamimi mengemukakan pengertian pemerintah menurut UUD 1945 tidak dapat disamakan dengan *executive power*, tetapi dengan mengintrodusir pendapat Logemann diartikan sebagai fungsi

pemerintah dalam organisasi negara, yaitu memberikan pimpinan bagaimana caranya organisasi negara itu memenuhi tugas kenegaraannya dalam mencapai tujuan negara tersebut (1990; 115) N.E. Alga, mengatakan "urusan pemerintahan" adalah mengandung makna *"bestuur"* yang meliputi bagian urusan pemerintahan yang tidak termasuk urusan pembuatan undang-undang (legislatif) dan tugas peradilan (yudikatif) (1983; 50). Dalam pengertian ini pemerintah merupakan bagian dari badan perlengkapan dan fungsi pemerintahan, yang bukan merupakan badan perlengkapan atau fungsi pembuat undang-undang dan badan perlengkapan atau fungsi peradilan.

Bertitik tolak dari pendapat tentang urusan eksekutif (pemerintahan) di atas, dapat dicatat beberapa sifat dari urusan pemerintahan: *pertama*; pemerintah adalah sebagai organ penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara atau mengurus kepentingan-kepentingan umum; *kedua*; pemerintah sebagai badan penyelenggara seluruh kegiatan atau urusan pemerintahan kecuali urusan membuat perundang-undangan (legislatif), dan urusan peradilan (yudikatif). Berdasarkan pendapat di atas terutama pendapat Philipus M. Hadjon, dalam kaitan pertanyaan apakah "urusan pemerintah" sama dengan "wewenang pemerintahan, jika urusan pemerintahan (eksekutif) hanya melaksanakan undang-undang, maka urusan pemerintahan tidaklah sama dengan "wewenang pemerintahan", sebab wewenang pemerintahan tersebut tidak hanya melaksanakan undang-undang (wewenang yang terikat), namun pemerintah juga memiliki wewenang diskresi. Sebaliknya, apabila urusan "eksekutif" adalah sebagai "urusan pemerintahan "atau *"bestuur"*, sedangkan *bestuur* mengandung wewenang pemerintahan yang terikat dan wewenang diskresi di luar wewenang legislasi dan peradilan, maka urusan pemerintahan (eksekutif) sama dengan wewenang pemerintahan. Untuk pengertian terakhir ini lebih sesuai dengan pengertian *"bestuur"* atau "administrasi". Hal ini penting dalam kaitannya dengan dasar penilaian (*toetsingsgronden*).

Dalam RUU Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan wewenang pemerintahan (Pasal 1 angka 2). Pasal 1 angka 3 wewenang pemerintahan adalah wewenang di luar kekuasaan legislatif dan yudisial yang diperoleh melalui atribusi atau delegasi. Ini berarti badan atau pejabat pemerintahan adalah pejabat yang menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan di lingkungan pejabat negara/pejabat pemerintahan meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara, Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Komisi/Dewan, Gubernur, Bupati, Walikota, Pejabat Struktural/Fungsional, Camat, Kepala Desa, dan Lurah. Badan adalah organisasi yang diberikan wewenang pemerintahan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan termasuk badan hukum lainnya yang menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan penugasan, pelimpahan kewenangan atau penyerahan kewenangan dari pemerintah dan peraturan perundang-undangan, antara lain otorita, lembaga pendidikan, pengelola kawasan, notaris, BUMN, dan BUMD.

Dengan adanya RUU tentang Administrasi Pemerintahan, maka tindakan pemerintahan tidak hanya terbatas pada tindakan hukum publik yang sepihak yang sifatnya konkret, individual dan final, akan tetapi juga meliputi tindakan materiil (*factual*). Ini berarti tindakan materiil atau *factual* yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara juga masuk dalam kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini secara eksplisit ditentukan dalam Ketentuan Peralihan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) RUU Administrasi Pemerintahan

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum administrasi pemerintahan oleh pejabat pemerintahan yang sudah didaftar, tetapi belum diperiksa oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dialihkan dan diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

(2) Perkara perbuatan melanggar hukum adeministrasi pemerintahan oleh pejabat pemerintahan yang sudah diperiksa tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Dengan demikian, perubahan Perundang-undangan Peradilan Tata Usaha Negara yang perlu dilakukan dalam kaitannya dengan tindak pemerintahan adalah Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian, rumusan Pasal 1 angka 3 yang memuat kalimat "berisi tindakan hukum tata usaha negara" harus dihilangkan. Sedangkan Pasal 2 huruf a yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata" bukan termasuk kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara harus dihapus, karena semua tindakan pemerintahan menurut RUU Administrasi Pemerintahan adalah termasuk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian pula perubahan terhadap rumusan badan atau pejabat TUN meliputi baik instansi pemerintahan, administrasi pemerintahan atau badan, dan badan hukum dapat dikatakan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, asal diberikan kewenangan atau berdasarkan penugasan, pelimpahan kewenangan, penyerahan kewenangan pemerintahan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan.

Bertitik tolak dari pemikiran dan uraian di atas tanggung-gugat hukum publik tidak terlepas dari wewenang yang melekat pada jabatan, ini berarti secara fungsional suatu tindakan hukum publik harus berdasarkan kewenangan yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Dengan demikian, pengertian badan atau pejabat TUN cakupannya sangat luas, maka luas pula pihak-pihak yang dapat diberikan kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan keputusan. Oleh karenanya setiap orang, organisasi, badan swasta pun dapat digolongkan sebagai badan atau pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan, jika mendapatkan pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan "urusan pemerintahan" tersebut, dan karenanya dapat digugat di PTUN atas keputusan yang dikeluarkannya.

2. Keputusan Notaris

Pasal 4 dan Penjelasan RUU Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa Notaris termasuk pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan semua fungsi atau tugas pemerintahan. Dengan demikian, berdasarkan rancangan undang-undang ini, Keputusan Notaris dapat dijadikan objek gugatan tata usaha negara. Pertanyaannya, apakah notaris ketika menerbitkan akte-akte notariil yang bersifat bilateral, misalnya dalam menerbitkan atau menolak menerbitkan akte jual beli dapat dikategorikan sebagai Keputusan TUN sehingga dapat digugat di Peradilan TUN. Selama ini, yurisprudensi menyatakan bahwa atas akta notariil tidak dapat diajukan gugatan TUN, karena notaris dalam membuat akta tidak berkedudukan sebagai pajabat yang memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, namun hanya menuangkan kehendak para pihak. Dalam kaitan dengan RUU ini, maka notaris dapat disebut sebagai pejabat apabila ia melakukan tindakan pemerintahan tersebut atas kehendak dan inisiatifnya sendiri, misalnya dalam memberikan atau menolak untuk melakukan legalisasi dokumen. Atas keputusannya tersebut dapatlah diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara

Dalam RUU ini ditentukan bahwa Keputusan Pemerintahan dapat berbentuk keputusan tertulis dan/atau lisan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi pemerintahan atau badan dalam lapangan hukum administrasi negara (Pasal 1 angka 4). Keputusan pemerintahan yang bersifat tertulis dikirim melalui pos atau kurir berlaku selambat-lambatnya empatbelas hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan yang disertai dengan tanda bukti penerimaan. Sedangkan keputusan yang dikirim melalui media elektronik berlaku selambat-lambatnya tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4). Ketentuan ini memberikan makna perluasan terhadap kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 3, yang hanya membatasi Keputusan TUN yang bersifat penetapan tertulis. Dalam fakta sering ditemukan Keputusan TUN yang bersifat lisan yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan seseorang atau badan hukum. Keputusan TUN yang bersifat lisan biasanya diikuti dengan tindakan nyata pemerintahan yang tanpa dapat dilakukan upaya pencegahan timbulnya kerugian sebagaimana yang diatur terhadap Keputusan TUN yang tertulis berupa permohonan penundaan pelaksanaan atas keputusan tersebut (*schorsing*). Terhadap keputusan TUN lisan yang merugikan tersebut tidak dapat ditempuh dengan prosedur beracara pada Peradilan Tata Usaha Negara, namun hanya dapat diajukan gugatan meminta ganti kerugian atas "perbuatan melanggar hukum" oleh penguasa *(OOD)* di pengadilan negeri. Dengan dimasukkannya substansi Keputusan TUN yang bersifat lisan dan elektronis dalam kompetensi Peradilan TUN, maka diharapkan perlindungan

hukum kepada masyarakat akan semakin lebih baik. Dengan demikian, perubahan substansi dalam UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No. 9 Tahun 2004, dalam Pasal 1 angka 3 perlu ditambahkan kata-kata lisan atau tidak tertulis.

4. Dasar Gugatan dan Alat Pengujian

Dasar atau gugatan dalam hukum publik dari segi keabsahan keputusan tata usaha negara ditemukan dalam UU No 5 Tahun 1986 juncto UU No. 9 Tahun 2004 adalah dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) yang menentukan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi." Ketentuan ini menunjukkan bahwa petitum gugatan terhadap suatu keputusan tata usaha negara adalah menyangkut keabsahan keputusan tata usaha negara. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, pada prinsipnya menyangkut "ketidakabsahan" keputusan tata usaha negara. Alasan menggugat keputusan tata usaha negara yang menyangkut keabsahan, karena adanya cacat segi yuridis dalam membuat keputusan tata usaha negara.

Dalam hukum Belanda kita temukan istilah "*rechtmatig, rechtmatigheid, onrechtmatig, onrechtmatige daad, onrechtmatige overheids daad*". Istilah-istilah tersebut dalam hukum kita hendaknya dibedakan penggunaannya dalam hukum perdata dan penggunaannya dalam lapangan hukum pemerintahan. Dalam lapangan hukum pemerintahan, istilah *rechmatigheid* dalam bahasa teknis hukum kita adalah keabsahan sedangkan istilah *onrechtmatig* dalam bahasa hukum kita hendaknya dibedakan dalam lapangan hukum perdata dengan lapangan hukum pemerintahan, dalam lapangan hukum perdata sudah lazim menggunakan istilah teknis melanggar hukum. Dalam lapangan hukum pemerintahan istilah *onrechtmatig* dalam bahasa hukum kita lebih tepat cacat yuridis (Philipus M. Hadjon, 2000; 12). Dengan demikian, keputusan tata usaha negara yang *onrechtmatig* janganlah dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara yang melanggar hukum, tetapi keputusan tata usaha negara yang cacat yuridis. Cacat yuridis keputusan tata usaha negara menyangkut aspek wewenang, prosedur, dan substansi. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan keputusan tata usaha negara, maka dapat dirumuskan bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dikatakan sebagai keputusan yang sah, apabila memenuhi unsur kewenangan, prosedural dan substansi. Dalam arti unsur-unsur tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Masuknya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 merupakan hasil praktik penyelenggaraan pemerintahan sebagai perkembangan dari hukum administrasi. Pada waktu membahas Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Fraksi ABRI telah mengusulkan agar AUPB dimasukkan sebagai salah satu alasan atau dasar gugatan dan sebagai alat penilaian oleh hakim. Namun, oleh pemerintah ditolak dengan alasan kita saat ini belum memiliki kriteria yang jelas tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), di samping belum kuatnya tradisi administrasi kita. Meskipun AUPB tidak diatur secara eksplisit di dalam UU No. 5 Tahun 1986, namun dengan adanya rumusan Pasal 53 ayat (2) huruf c "larangan berbuat sewenang-wenang" secara tersirat dapat ditafsirkan AUPB secara tersirat dapat diterapkan kepada larangan berbuat sewenang-wenang tersebut. Perkembangan AUPB dilakukan hakim melalui yurisprudensi. Penggunaan AUPB sebagai alat penilaian oleh hakim sangatlah penting, bila dikaitkan dengan wewenang yang dimilki oleh Badan atau Pejabat TUN dalam melahirkan suatu keputusan. Dalam hukum administrasi dikenal adanya Keputusan TUN yang terikat dan Keputusan TUN yang bebas (diskresi). Terhadap Keputusan TUN yang terikat dapat dinilai dengan menggunakan "Peraturan Perundang-undangan" (pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 tahun 2004), sedangkan terhadap Keputusan TUN yang bersifat bebas dengan menggunakan alat ukur penilaian "asas-asas umum pemerintahan yang baik". Tanpa diperlakukannya AUPB di satu sisi sebagai norma pemerintahan, dan pada sisi lain sebagai alat penilaian keabsahan oleh hakim, dimungkinkan suatu keputusan yang dikeluarkan tersebut bersifat "sewenang-wenang". Perkembangan AUPB, di samping enam asas yang terdapat dalam ketentuan UU No. 9 Tahun 2004, melalui RUU Administrasi Pemerintahan ditambah dengan beberapa AUPB lainnya sebagai norma pemerintahan, yaitu asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau mencampuradukkan kewenangan, dan asas kepentingan umum.

Asas hukum dalam ilmu hukum merupakan prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum, pengertian-pengertian atau nilai-nilai. Asas dijadikan titik tolak berpikir tentang hukum, pembentukan undang-undang, penafsiran undang-undang. Asas merupakan dasar pemikiran yang bersifat umum dan abstrak yang merupakan ide atau konsep yang tidak mempunyai saksi, berbeda dengan norma yang merupakan aturan konkret serta penjabaran ide yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan. Asas hukum berperan sebagai meta-kaidah berkenaan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku (Bruggik, 2002; 120). Asas hukum akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan pemahaman masyarakat. Demikian pula halnya dengan AUPB akan senantiasa selalu berkembang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan maupun melalui yurisprudensi. Alasan menggugat yang diuraikan di atas ber-

sifat alternatif, artinya penggugat dapat memilih salah satu dari alasan tersebut, dapat pula menggunakan keseluruhan alasan itu sepanjang memenuhi unsur-unsurnya.

Alasan menggugat menyangkut keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Soal keabsahan adalah soal "*rechtmatigheid van bestuur*". Sedangkan "*rechtmatigheid van bestuur"* merupakan asas keabsahan dalam pemerintahan". Asas keabsahan memiliki tiga fungsi, yaitu (a) bagi afarat pemerintahan asas keabsahan berfungsi sebagai norma pemerintahan (*bestuurnormen)*; (b) bagi masyarakat, asas keabsahan berfungsi sebagai alasan mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintahan *(beroepsgronden*); (c) bagi hakim, asas keabsahan berfungsi sebagai dasar pengujian suatu tindak pemerintahan (*toetsingsgronden*) (Philipus M Hadjon, 1994; 7).

Dengan demikian, perlu adanya perluasan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut sebagai norma pemerintahan, dasar gugatan dan penilaian oleh hakim ke dalam perubahan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004.

5. Prosedur Administratif

Prosedur administratif adalah suatu upaya yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila yang bersangkutan merasa tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dapat dibagi dalam dua bentuk, *Pertama,* Prosedur keberatan yang diajukan kepada badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut, atau dengan kata lain diselesaikan oleh yang mengeluarkan keputusan TUN tersebut. *Kedua,* Banding administratif, dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan. Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 ditentukan "bahwa atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tersedia prosedur administratif, maka upaya administratif tersebut harus dijalankan terlebih dahulu. Bila hasil dari upaya administratif dirasakan kurang memuaskan barulah diajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama, tanpa melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan RUU Administrasi Pemerintahan ditentukan "bahwa semua keputusan TUN memiliki prosedur upaya administratif (Pasal 37), dan keputusan upaya administratif dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 38). Ketentuan tentang prosedur administratif ini akan mengubah proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan dimaksud, *pertama* karena semua Keputusan TUN memiliki prosedur administratif, maka ketentuan dalam Pasal 48 UU. No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No. 9 Tahun 2004 harus dihapus, karena ketentuan tersebut mengatur keputusan yang ada upaya administratif dan ada pula keputusan yang tidak memiliki upaya administratif dapat langsung diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Perubahan *kedua*, berkaitan dengan ketentuan Pasal 38 RUU Administrasi Pemerintahan yang menentukan: "Keputusan upaya administratif dapat digugat ke Pengadilan TUN. Ini berarti akan menghapus Pasal 51 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan: "Pengadilan Tinggi TUN berwenang mengadili sengketa TUN yang telah terlebih dahulu dilakukan dengan upaya administratif". Jika ketentuan ini tidak dihapus maka tidak ada perkara yang akan masuk ke Pengadilan TUN, karena semua Keputusan TUN memiliki upaya administratif. Sebaliknya Pengadilan Tinggi TUN akan kebanjiran perkara, sedangkan jumlah Pengadilan Tinggi TUN tidak dimiliki oleh setiap daerah provinsi. Hal ini tentu tidak akan efektif dan bertentangan serta tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

6. Kedudukan Jurusita

Pasal 43 ayat (8) RUU Administrasi Pemerintahan menegaskan salah satu tugas dari jurusita adalah sebagai pelaksana upaya paksa atau perintah Ketua Pengadilan. Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN berbeda dengan pelaksanaan putusan perkara perdata pada Pengadilan Umum. Dalam pengadilan umum dikenal adanya eksekusi riil, yaitu dengan meminta bantuan pihak di luar dari para pihak itu sendiri, misalnya pihak keamanan. Sedangkan eksekusi riil dengan cara meminta bantuan kepada pihak di luar para pihak tidak mungkin dilakukan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, tidak mungkin pula upaya paksa dilakukan terhadap pemerintah agar secara pribadi melakukan suatu prestasi yang telah diputuskan dalam suatu putusan peradilan. Oleh karena itu, dalam eksekusi Putusan Peradilan TUN lebih bergantung pada kesadaran pihak tergugat untuk melaksanakan diktum putusan.

Namun dengan RUU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan jurusita sebagai pelaksana upaya paksa, maka tugas jurusita tidak hanya menyampaikan panggilan-panggilan dan pemberitahuan putusan saja, tetapi meliputi pula tugas eksekutorial putusan pengadilan berupa upaya paksa. Pembebanan upaya paksa tersebut dapat berupa uang paksa, sebagai sarana tidak langsung dan bukan merupakan eksekusi riil. Hal ini bisa diefektifkan dalam pelaksanaan Putusan Peradilan TUN. Meskipun harta benda yang digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum itu tidak dapat diletakkan dalam suatu sita eksekusi dan tidaklah mungkin merampas kebebasan pejabat yang memangku jabatan pemerintahan sebagai sarana paksaan, namun pemerintah selalu dianggap dapat dan mampu membayar *(solvable)*. Dengan demikian, perubahan substansi dari UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No. 9 Tahun 2004 yang berkaitan dengan tugas jurusita adalah tidak hanya menyampaikan panggilan-panggilan, penyampaian pemberitahuan keputusan tapi juga sebagai pelaksana upaya paksa dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Batasan Diskresi

Dalam suatu negara hukum modern *(welfare state)*, negara berkewajiban untuk turut serta dalam menyejahterakan warga negaranya. Oleh karenanya negara dapat turut campur hampir dalam semua bidang kehidupan masyarakat. Konsep *welfare state* ini merupakan antithesa dari konsep *nachwachterstaat* pada masa awal ekonomi liberal di abad XIX hingga awal abad XX. Menurut konsep ini negara tidak boleh ikut campur dalam kehidupan warga negara, kecuali dalam urusan keamanan, ketertiban, dan hubungan luar. Sehingga pada awal abad XX peranan negara sebagai penjaga malam *(nachwachterstaat*), berubah menjadi negara kesejahteraan *(welfare state)*. Konsekuensi dari negara kesejahteraan *(welfare state*), maka tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah semakin luas dan terus berkembang. Pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada warga negara harus melayani segala kebutuhan warga negara yang sangat kompleks dan rumit. Konsep negara kesejahteraan diharuskan pula menjalankan asas legalitas, di mana semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan kepada hukum. Namun begitu luas dan kompleksnya masalah kehidupan masyarakat dan tidak semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan diatur secara lengkap atau tersedia dalam bentuk aturan hukum yang tertulis. Untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan diskresi, di mana pemerintah diberikan kewenangan bebas untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah konkret yang dihadapi, sedangkan peraturan untuk menyelesaikan masalah yang konkret tersebut belum ada, atau samar-samar, sangat sumir, dan bersifat sangat umum. Prinsipnya, diskresi merupakan pelengkap dari asas legalitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan penjelasan umum UUD 1945 yang menentukan: "bahwa Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, di samping Undang-Undang Dasar berlaku pula hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis." Jika hanya bertumpukan kepada aturan hukum yang tertulis, maka akan banyak urusan pemerintahan yang tidak terjangkau atau tertangani. Penggunaan wewenang diskresi oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan hendaknya dilakukan dengan seselektif mungkin. Artinya sepanjang wewenang pemerintahan tersebut telah diatur secara lengkap dan tegas dalam hukum tertulis, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut terikat pada hukum yang tertulis tersebut. Sebab apabila wewenang terikat tersebut dituangkan dalam bentuk diskresi, akan dimungkinkan munculnya penyalahgunaan wewenang untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum tertulis, atau tujuan diberikannya diskresi tersebut.

Dalam hubungannya dengan keputusan, Pasal 6 RUU Administrasi Pemerintahan secara tegas membatasi penggunaan diskresi. Dalam pembuatan suatu keputusan pejabat yang bersangkutan wajib memerhatikan tujuan pemberian diskresi, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diskresi, dan asas-

asas umum pemerintahan yang baik. Di antara asas-asas umum pemerintahan yang baik dan paling mendasar adalah larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang.

8. Ganti Kerugian

Dalam RUU Administrasi Pemerintah ketentuan tentang ganti rugi dirumuskan dalam Pasal 41: "pencabutan dan/atau pembatalan terhadap Keputusan Pemerintahan wajib memuat ketentuan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan yang besarnya harus memenuhi unsur keadilan dan kelayakan, yakni sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat keputusan pemerintahan." Ketentuan ini mengandung makna bahwa yang menetapkan besarnya ganti kerugian adalah badan atau pejabat yang berwenang dalam mencabut dan/atau ,membatalkan keputusan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No. 9 Tahun 2004 menentukan bahwa "orang atau badan hukum perdata yang merasa durugikan oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ganti rugi." Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1991 yang menyatakan: "bahwa ganti rugi minimal adalah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp5.000.000,-(lima juta rupiah). Adapun sumber pembiayaan ganti rugi tersebut adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Keputusan Tata Usaha Negara Pusat, dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Keputusan Tata Usaha Negara Daerah. Adanya ketentuan ganti rugi dalam PP ini, tidaklah berarti menutup kemungkinan pengajuan gugatan ganti rugi melalui hakim perdata berdasarkan Pasal 1365 BW.

Dengan mengacu pada PP tersebut, apabila seseorang atau Badan Hukum Perdata telah dimenangkan melalui Peradilan TUN merasa tidak puas karena keputusan tentang ganti rugi tidak layak dan masih harus melakukan lagi gugatan kepada pengadilan negeri karena alasan perbuatan melanggar hukum. Namun, dengan adanya ketentuan Ganti Rugi dalam RUU Administrasi Pemerintahan, memungkinkan pemberian ganti rugi dalam Putusan Peradilan TUN yang adil dan layak (seimbang) dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan perluasan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, juga meliputi gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (OOD). Ini berarti seseorang atau badan hukum perdata yang telah dirugikan oleh sebuah keputusan TUN tak perlu lagi mengajukan dua bentuk gugatan, yaitu gugatan pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara ke Peradilan Tata Usaha Negara, dan gugatan perbuatan melanggar hukum (*OOD)* berkenaan dengan ganti rugi di pengadilan negeri. Sehubungan dengan ketentuan tentang pembatasan besarnya gugatan ganti rugi dalam PP tersebut konsekuensinya harus dihapus. Besarnya ganti kerugian itu akan ditentukan oleh hakim dalam putusannya berdasarkan unsur keadilan dan kelayakan.

9. Sanksi Administratif dan Upaya Paksa

Saksi Administratif dan Upaya Paksa diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (4) RUU Administrasi Pemerintahan. Sanksi administrasi akan dikenakan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara: "tidak berdasarkan kepada asas legalitas, asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas-asas umum pemerintahan yang baik; tidak memiliki wewenang; adanya unsur kepentingan pribadi; tidak memenuhi syarat formal; dan tidak cermat dalam menggunakan diskresi. Sedangkan ketentuan mengenai upaya paksa diatur dalam Pasal 43 ayat (7), (8), dan ayat (9). Ada dua hal yang sangat menarik dari ketentuan pasal ini: *Pertama*; makin tegasnya tugas jurusita dalam pelaksanaan upaya paksa. *Kedua*; Ketentuan Pasal 43 ayat (9) menyatakan: "bahwa pembayaran uang paksa dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan". Meskipun ketentuan RUU ini belum secara eksplisit menyebutkan sumber pembayaran uang paksa, namun dilihat dari kalimat "pejabat yang bersangkutan" memberikan arti bahwa sumber pembayaran uang paksa bukan uang negara, namun uang pribadi yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori "*fautes personelles*" pejabat publik atas kerugian pihak ketiga. Ada dua teori tentang tanggung-gugat badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu *pertama*: tanggung-gugat atas kesalahan pribadi (*fautes pesonalles*) dan *kedua*; kesalahan jabatan (*fautes de service)*. Teori Kesalahan Pribadi *(fautes personalles*) menyatakan; kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan karena tindakannya telah menimbulkan kerugian. Sedangkan teori kesalahan jabatan (*fautes de service*) menyatakan; kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi pejabat yang besangkutan. Secara teoretik badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang pemerintahan, berarti sedang melaksanakan urusan atau fungsi pemerintahan. Oleh karenanya manakala dalam menjalankan fungsi pemerintahan tersebut menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata, sepanjang fungsi tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum, maka kerugian yang diderita oleh warga negara tersebut dibebankan pembayarannya kepada negara, karena itu tergolong kesalahan jabatan. Berbeda halnya ketika seorang pejabat bertindak tidak berdasarkan pada hukum, maka dalam hal yang demikian pejabat tersebut tidak berperan sebagai jabatan, sehingga risiko dari ketidakpatuhan terhadap hukum tersebut tidak dapat dibebankan kepada keuangan negara, tetapi harus ditanggung oleh secara pribadi dari orang yang menjabat tersebut, karena tergolong pada kesalahan pribadi pejabat yang bersangkutan.

Dengan demikian, Perubahan substansi UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berkenaan dengan sanksi administratif dan upaya paksa adalah dengan mencantumkan jurusita sebagai eksekutor upaya paksa dan menyatakan bahwa sumber pembiayaan atas uang paksa adalah dari sumber uang pribadi pejabat yang bersangkutan.



Penutup

Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan akan membawa perubahan terhadap perlindungan hukum terhadap warga masyarakat dari berbagai tindakan hukum dan tindakan materiil atau *factual* yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Dengan RUU ini di satu sisi sebagai pedoman atau payung hukum bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi atau urusan pemerintahan, dan pada sisi lain dengan RUU ini ke depan akan membawa perubahan terhadap substansi UU. No. 5 Tahun 1986 jo. UU. No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kompetensi mengadili, upaya administratif, kedudukan jurusita, ganti rugi, sanksi administratif dan upaya paksa.

Daftar Referensi

Atamimi, Hamid, A. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Alga, N.E. et.al. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*. Belanda Indonesia. Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Belifate, AD. *Kort begrip van het administratief recht*, Terjemahan Boerhanoeddin Soetan Batoeh, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Hadjon, M. Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. kelima, 2005.

Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.

Marpaung, Arifin. *Implementasi Teknis Pelaksanaan Lembaga-lembaga Baru dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Solusi Pemecahannya*. Makalah, Rakernas MARI, Denpasar 18-22 September, 2005.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku II, Jakarta: Sinar Harapan, 2003.

37

KEJAHATAN INTERNASIONAL DALAM RUU KUHP

Oleh:
*Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H.**

Pendahuluan

Makalah ini secara khusus saya persembahkan untuk sahabat karib Prof. Dr. Zudan Arief Fakrullah, S.H., M.H. yang lewat pertengahan tahun ini memperingati usia 40 (empat puluh) tahun. Pada hakikatnya, semakin bertambah usia anak manusia, maka semakin berkurang usia yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. Tapi saya tetap berharap, semoga semakin bertambah pula pengabdian terhadap kepentingan perkembangan dunia ilmu yang selama ini kita tekuni.

Pemilihan tema makalah ini lebih pada pertimbangan kesesuaian dengan disiplin ilmu yang saya geluti selama ini, yakni di bidang ilmu hukum pidana dan kriminologi. Selain itu, konsep RUU KUHP kita yang sudah dirancang sejak kurang lebih empat puluh tahun lalu, hingga kini meskipun sudah final dibuat oleh Tim Penyusun RUU KUHP, masih tetap berada di meja Presiden RI untuk—entah kapan—diteruskan ke meja DPR RI. Semoga makalah singkat ini juga bisa bermanfaat untuk sumbang pikir bagi pembahasan RUU KUHP kelak di parlemen.

Pada prinsipnya, setiap upaya kriminalisasi suatu perbuatan ke dalam peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang telah disepakati dalam doktrin atau asas-asas hukum pidana maupun yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berkaitan dengan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional, maka harus diperhatikan pula instrumen-instrumen internasional mengingat

*Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H. adalah dosen tetap Fakultas Hukum dan PPs Universitas Bhayangkara Surabaya. Alumni Program Doktor Universitas Diponegoro Semarang.

kejahatan tersebut termasuk ruang lingkup hukum internasional dan/atau hukum humaniter internasional. Dalam pembahasan ini, dari tiga hal yang harus jadi acuan itu akan dirangkum dalam satu bahasan yang lebih didasarkan pada asas-asas, doktrin atau ajaran-ajaran ilmu hukum pidana.

Untuk lebih mudah dipahami substansi makalah singkat ini, uraiannya secara sistematis akan difokuskan pada dua dari tiga persoalan pokok dalam hukum pidana, yakni masalah rumusan tindak pidana dan sistem sanksinya. Pertimbangan seperti ini didasarkan pada kebutuhan untuk mem-peroleh konsep yang jelas dan tepat tentang rumusan norma yang berkaitan dengan kejahatan internasional dalam RUU KUHP Nasional.



Pembahasan

Kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk kejahatan internasional telah dirumuskan dalam RUU KUHP pada Bab IX yang diberi judul "TINDAK PIDANA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA". Ada empat bentuk kejahatan internasional yang dikriminalisasikan, yaitu:

1. **Tindak Pidana Genosida**, dalam Pasal 394 yang terdiri dari 2 ayat.

Penetapan tindak pidana ini didasarkan pada "*Convention on the Prevention and Punishment of The Crime of Genoside*" (9 Desember 1948). Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah suatu perbuatan yang semata-mata bertujuan meniadakan eksistensi kelompok masyarakat berdasarkan warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, dan cacat mental atau fisik (Lihat Penjelasan pasal tersebut). Macam-macam dari bentuk perbuatan tersebut sudah diakomodir pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e. Sedangkan pada ayat (2) menetapkan 'permufakatan jahat' terhadap macam-macam perbuatan sebagaimana ditentukan pada ayat (1) juga dipidana. Sangat disayangkan, norma-norma mengenai 'penghasutan secara langsung di depan umum untuk melakukan genosida' dan 'keterlibatan dalam mempersiapkan perbuatan genosida' belum dikriminalisasikan. Padahal kedua norma tersebut diatur dalam Pasal 3 Konvensi Internasional tentang Genosida, juga dalam Statuta ICTY dan ICTR. Karena itu, saya sependapat dengan draft usulan ICRC Jenewa yang menambahkan dua ayat yang berisi kedua norma tersebut ke dalam Tindak Pidana Genosida. Hanya saja ketiga norma dalam tindak pidana 'genosida' itu seyogianya dirumuskan dalam pasal tersendiri karena merupakan satuan aturan yang memuat satu norma sehingga perlu dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas (Lihat Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam UU No. 10 Tahun 2004).

Mengenai sistem sanksi yang terdapat dalam Tindak Pidana Genosida tersebut perlu ada perbaikan untuk disesuaikan dengan 'Ketentuan Umum' Buku I RUU KUHP. Sanksi terberat 'pidana mati' yang tercantum dalam Pasal

394 ayat (!) sudah proporsional dengan perbuatan yang dilarang dan hendak dilindungi oleh kepentingan hukum, seperti memusnahkan kelompok ras, pembunuhan, dan mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat. Dari aspek bobot delik, perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan 'sangat serius' yang ancaman sanksi terberatnya adalah 'pidana mati'. Tentu saja, pola perumusan pidananya bersifat alternatif, seperti yang tercantum dalam Pasal 394 ayat (1) di atas. Secara umum, kejahatan yang berkaitan dengan perampasan terhadap nyawa, selalu diancam dengan sanksi pidana mati. Hal ini dapat dibandingkan pula dengan pembunuhan berencana (*moord*) yang diatur dalam Pasal 572 RUU KUHP. Karena itu, dirasakan tidak konsisten baik dilihat secara teknis perundang-undangan maupun dari aspek kebijakan kriminal (*criminal policy*), bila pelanggaran terhadap norma yang berkaitan dengan perampasan nyawa, tidak diberi ancaman sanksi pidana mati. Apalagi norma tersebut telah menjadi kesepakatan dunia internasional untuk memeranginya.

Ancaman pidana penjara dalam Pasal 394 ayat (2) yang semula 'paling lama 5 tahun' harus disesuaikan pula dengan Ketentuan Umum Pasal 13 ayat (4) yang menegaskan bahwa "permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama tujuh tahun".

Untuk rumusan yang terdapat dalam Pasal 394 ayat (3) seperti draft usulan ICRC Jenewa tentang 'persiapan melakukan tindak pidana genosida' sudah benar diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) RUU KUHP.

Sedangkan rumusan tindak pidana 'penghasutan secara langsung di depan umum untuk melakukan genosida' seperti draft usulan ICRC Jenewa dalam Pasal 394 ayat (4) dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama tiga puluh tahun, perlu dipertimbangkan lagi, terutama soal pola berat-ringannya sanksi (*strafmaat*). Sanksi pidana penjara paling lama tiga puluh tahun tersebut mengacu pada '*international law*' atau lebih tepatnya Statuta Roma Pasal 77. Pola berat-ringannya sanksi pidana penjara untuk waktu tertentu, dalam hal bagaimanapun tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 69 ayat (4) RUU KUHP. Kalaupun 'berkehendak' menetapkan sanksi berat terhadap tindak pidana tersebut agar terjadi harmonisasi dengan hukum internasional, maka ancaman sanksinya dapat ditetapkan menjadi 'pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun'. Pendapat saya, tindak pidana 'penghasutan secara langsung di depan umum untuk melakukan genosida' adalah 'delik selesai', sehingga bobot pelanggarannya tidak lebih berat dibanding tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 394 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e. Oleh sebab itu, selain tindak pidana tersebut penempatan rumusannya dalam pasal tersendiri, juga seyogianya hanya dikenakan ancaman sanksi 'pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun'.

2. **Tindak Pidana Kemanusiaan**, dalam Pasal 395 yang terdiri dari 2 ayat

Rumusan norma dalam Pasal 395 ayat (1) sebenarnya berasal dari ketentuan norma yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998, kecuali huruf (k). Secara prinsip, rumusan tindak pidana dan ancaman sanksinya dalam pasal tersebut dapat disetujui. Argumentasinya sama dengan Pasal 394 ayat (1) di atas. Namun, dalam Pasal 395 ayat (2) saya berpendapat semacam ada '*contradictio in terminis*'. Rumusan ayat ini mengandung pertentangan dengan asas dan/atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum pidana. Seperti 'percobaan (*poging*)', 'permufakatan jahat (*samenspanning*)' dan 'pembantuan melakukan tindak pidana (*medeplichtig*)' mempunyai kedudukan sendiri-sendiri dan memerlukan analisis terpisah. Secara doktrinal, melakukan 'percobaan' tindak pidana, tidak boleh dikenakan sanksi yang sama dengan pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang selesai diperbuat. Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP dalam Pasal 17 s.d. Pasal 20 tentang "Percobaan" tidak mengatur secara tegas ancaman sanksi yang dapat dikenakan terhadap delik percobaan. Hanya dalam Pasal 20 secara tersirat dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana untuk 'delik percobaan' tidak boleh lebih dari ½ (satu per dua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju. Ini bisa dibandingkan juga dengan KUHP dalam Pasal 53 ayat (3) yang menegaskan bahwa jika suatu 'delik' itu diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi percobaan dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Perlu saya tambahkan di sini, bahwa delik 'percobaan' dapat dikatakan sebagai 'delik selesai'. Mengapa? Karena ancaman sanksinya sudah diatur tersendiri. Tanpa ditetapkan dalam rumusan pasal, 'delik percobaan' terhadap suatu tindak pidana, tetap dapat dikenakan sanksi pidana. Penetapan rumusan 'delik percobaan' secara tersendiri, menurut pendapat saya dirasakan berlebihan.

Sedangkan 'pembantuan melakukan tindak pidana', secara doktrinal kedudukan hukumnya berbeda dengan 'pelaku (*plegen*, *dader*)' tindak pidana itu sendiri. Setiap orang yang melakukan pembantuan tindak pidana, diancam dengan pidana yang tidak sama seperti pelakunya. Yakni hanya dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika suatu 'delik' itu diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Karenanya, tidak perlu dirumuskan dalam 'pasal' atau pada 'ayat' tersendiri.

Mengenai 'permufakatan jahat', seyogianya dirumuskan dalam pasal tersendiri karena merupakan norma yang berdiri sendiri. Tidak semua permufakatan jahat dapat dipidana kecuali hanya terhadap beberapa tindak pidana yang sangat serius dan ditentukan secara tegas dalam rumusan tindak pidana (Lihat Penjelasan Pasal 13 ayat (1) dalam RUU KUHP). Sedangkan ancaman sanksinya, hanya dapat dikenakan 'pidana penjara paling lama tujuh tahun'.

3. **Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata**

Tindak pidana ini terdiri dari delapan pasal, mulai Pasal 396 s.d. Pasal 403. Banyaknya rumusan pasal 'Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata' ini untuk mengakomodir norma-norma hukum internasional yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*). Hal ini sebagai konsekuensi Negara Indonesia yang telah meratifikasi empat Konvensi Jenewa tersebut melalui UU Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Empat konvensi tersebut adalah:

1. Konvensi Jenewa tentang Perbaikan Nasib Anggota-anggota yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Darat (*Geneva Convention for The Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Fild of August 12, 1949*).
2. Konvensi Jenewa tentang Perbaikan Nasib Anggota-anggota yang Luka, Sakit, dan Korban-korban Karam dari Angkatan Perang di Laut (*Geneva Convention for The Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces of Sea of August 12, 1949*).
3. Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949*).
4. Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Rakyat Sipil dalam Masa Perang (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilion Persons in Time of War of August 12, 1949*).

Kriminalisasi norma-norma hukum internasional di atas ke dalam RUU KUHP tidak saya komentari karena sudah dapat dibaca dalam makalah Tim ICRC (*International Committe of the Red Cross*) yang disampaikan oleh Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.H. dari Universitas Negeri Jember dan saya sendiri pada saat Seminar Nasional "*Problema Kejahatan Perang dalam Hukum Pidana di Indonesia*", tanggal 12 Juli 2005 di Bandung. Namun yang perlu digarisbawahi, saya sependapat dengan penetapan sistem sanksinya yang terberat, yakni pidana mati. Kalau kita amati, perbuatan yang dilarang dalam pasal-pasal tersebut, semuanya tercantum bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana 'sangat serius' dalam Statuta Roma atau dipandang sebagai '*Grave breaches*' dalam Konvensi Jenewa yang dapat diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.

Mengenai rumusan norma dalam Pasal 401, substansinya sudah sejalan dengan *Article* 33 Statuta Roma yang menetapkan tiga syarat bagi seorang bawahan untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan karena perintah atasannya. Syarat *pertama*, bawahan tersebut berada dalam kewajiban hukum untuk mematuhi perintah dari pemerintah atau atasannya; *Kedua*, bawahan tersebut tidak tahu bahwa perintahnya melanggar hukum; dan syarat *ketiga*, perintahnya tidak jelas melawan hukum. Ketiga

syarat itu bersifat kumulatif. Semuanya harus dipenuhi. Jika tidak, bawahan tersebut dapat dipidana. Dengan kata lain, seorang bawahan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang diperintahkan atasannya, bila dia tahu perintah itu melanggar hukum, jelas-jelas melawan hukum dan dia tidak berada dalam posisi kewajiban melaksanakan perintah tersebut.

Meskipun rumusan Pasal 401 sesuai dengan ide dari *Article 33* Statuta Roma, tetapi penempatan rumusannya lebih tepat bila ditetapkan dalam Buku Kesatu Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Pertimbangannya, ketentuan Pasal 401 tersebut menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan untuk tidak dipidana terhadap perbuatan seorang bawahan yang melaksanakan perintah atasan. Jadi, termasuk dalam lingkup persoalan pertanggungjawaban pidana yang dimaafkan. Oleh sebab itu, lebih tepat dimasukkan ke Paragraf 5 tentang Alasan Pemaaf dalam Pasal 45 ayat (2), yang rumusannya sebagai berikut:

> *"Penghapusan pidana terhadap seorang bawahan yang melaksanakan perintah jabatan harus memenuhi syarat sebagai berikut.*
>
> 1. *bawahan tersebut berada dalam suatu kewajiban hukum untuk mematuhi perintah atasan;*
> 2. *bawahan tersebut tidak tahu bahwa perintah atasannya melanggar hukum;*
> 3. *perintah tersebut tidak jelas melawan hukum".*

Selanjutnya untuk rumusan Pasal 402 ayat (2) yang menegaskan bahwa tindak pidana dalam masa perang atau konflik bersenjata tidak terikat pada batas daluwarsa untuk penuntutannya. Karena hal ini terkait dengan 'aturan umum', maka atas dasar kesamaan materi dan sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, seyogianya lebih tepat ditempatkan dalam Pasal 145 ayat (2), sehingga berbunyi demikian:

> *"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi tindak pidana dalam masa perang atau konflik bersenjata."*

Dengan demikian, materi hukum kejahatan perang yang *notabene* sebagai implementasi untuk pengaturan norma-norma hukum internasional ke dalam hukum nasional itu, diatur dalam Buku Kedua Bab IX di bawah judul "Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia". Kejahatan perang dalam Bab tersebut diletakkan pada 'Bagian Ketiga' dengan sub-judul 'Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata' setelah 'Tindak Pidana Genosida' dan 'Tindak Pidana Kemanusiaan'. Oleh karena itu, kejahatan perang bila mengacu pada RUU KUHP dapat dipandang sebagai salah satu macam dari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

4. Tindak Pidana Penyiksaan (*Torture*)

Penetapan tindak pidana ini sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 5 Tahun 1998 yang merupakan ratifikasi Konvensi Internasional tentang "*Convention*

against Torture and Other Cruel, inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10 December 1984". Pada intinya subjek hukum dari pasal ini adalah 'pejabat publik', yang dapat diartikan sebagai pegawai negeri (*ambtenaar*). Dalam pengertian pegawai negeri terdapat unsur-unsur: (1) diangkat oleh instansi publik; (2) memangku jabatan publik; (3) melakukan sebagian dari tugas pemerintah. Jadi, pegawai negeri adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi penjabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya (Lihat dalam: R. Soesilo, 1991:100).

Tindak pidana penyiksaan (*torture*) yang dicantumkan dalam RUU KUHP pada Pasal 404 ini, sesungguhnya dimaksudkan untuk perlindungan terhadap HAM yang sering dilanggar oleh pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Misalnya, penyidik yang melakukan intimidasi atau menyiksa seorang tersangka untuk mendapatkan pengakuan tentang suatu kejahatan yang telah dilakukan, seperti: kasus penganiayaan Abu Sayyaf alias Joko Wibowo di sel Mapolda Jateng (*Jawa Pos*; Minggu 12 Februari 2006, hlm. 11). Pasal ini juga dapat dikenakan pada setiap orang yang digerakkan atau sepengetahuan pejabat publik untuk menyiksa seseorang dengan maksud mengintimidasi atau memaksa. Fenomena perlakuan pejabat publik seperti ini bukan saja dilakukan orang per orang (oknum), tapi sering mengarah pada kelembagaan dengan alasan terdesak oleh keadaan. Untuk menghindari kesewenang-wenangan pejabat publik, Pasal 2 Konvensi tersebut di atas menegaskan bahwa keadaan darurat atau mendesak (*exceptional circumstance* atau *public emergency*) tidak dapat digunakan sebagai dalih untuk memberikan dasar pembenaran terjadinya penyiksaan (*torture*).

Berdasar pada uraian di atas, penamaan judul Bab IX sebagai "Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia" dalam RUU KUHP, bila dilihat dari aspek bentuk-bentuk perbuatan keempat macam tindak pidana tersebut, dapat dikatakan sudah tepat. Kalau kita cermati hampir semua bentuk-bentuk perbuatan yang dikriminalisasikan dari keempat macam tindak pidana itu, berupa pelanggaran terhadap HAM. Contohnya: pembunuhan atau perampasan terhadap nyawa merupakan pelanggaran terhadap "*Right to live*". "Hak untuk Hidup" ini adalah hak yang paling utama dilindungi dari segala perampasannya, baik yang melalui cara-cara *legal* maupun *illegal*. Cara *legal*, seperti penetapan sanksi pidana mati dalam suatu perundang-undangan pidana, sistem perumusannya selalu bersifat alternatif terakhir. Bahkan sesudah penjatuhan *vonis*, terpidana mati juga masih diberi hak untuk meminta grasi kepada kepala negara. Cara *illegal*, seperti perbuatan polisi yang melakukan '*extralegal excecutions*' (pelaksanaan tembak mati yang sewenang-wenang) terhadap seorang penjahat, atau tentara yang melakukan pembunuhan terhadap penduduk sipil dalam masa perang.

Contohnya lagi adalah "Hak Bebas dari Penyiksaan atau Tindakan/ Pemidanaan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Kemanusiaan." Penyiksaan atau tindakan tidak manusiawi ini kerapkali terjadi pada

proses penyelidikan dan/atau penyidikan dalam sistem peradilan pidana, khususnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Juga dapat terjadi pada masa perang atau konflik bersenjata yang dilakukan oleh tentara terhadap tawanan perang, termasuk praktik-praktik *apartheid* dan perbuatan lain yang merendahkan martabat kemanusiaan, yang didasarkan pada diskriminasi ras.

Bertolak dari alasan di atas, dapat ditegaskan bahwa istilah '*Crime Against Humanity*' tidak sama dengan pengertian 'Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia'. Pada yang *pertama*, secara akademis, istilah tersebut terdapat dalam disiplin '*criminology*', sedangkan yang *kedua*, dipakai dalam disiplin ilmu hukum pidana. Dalam beberapa macam dan bentuk dari tindak pidana terhadap hak asasi manusia, terdapat 'kejahatan terhadap kemanusiaan' atau '*crime against humanity*'. Tetapi tidak sebaliknya. Dalam kejahatan terhadap kemanusiaan belum tentu ditemukan perbuatan yang disebut 'tindak pidana terhadap hak asasi manusia', karena belum atau tidak dikriminalisasikan dalam suatu perundang-undangan pidana.

Semua bentuk dari keempat macam tindak pidana terhadap hak asasi manusia tersebut sudah menjadi kesepakatan internasional untuk memeranginya karena sudah menjadi fenomena kejahatan internasional. Terbukti dengan dimasukkannya dalam berbagai konvensi internasional yang kemudian menjelma sebagai hukum internasional. Dengan demikian, istilah 'Tindak Pidana Terhadap Hukum Internasional' atau 'Tindak Pidana Melawan Hukum Internasional' seperti draft usulan ICRC Jenewa kurang tepat, baik ditinjau dari makna tata bahasanya maupun konsepnya. Pada prinsipnya, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Lihat Pasal 11 ayat (2) RUU KUHP). Jadi, dari aspek tata bahasa, penamaannya dapat dikatakan berlebihan. Juga secara konseptual, istilah 'tindak pidana' terkandung arti melawan hukum.



Penutup

Sudah menjadi konsensus masyarakat internasional bahwa bentuk-bentuk kejahatan pada dasarnya menghancurkan eksistensi kehidupan dan merendahkan martabat kemanusiaan harus ditentang dan dihadapi bersama. Salah satu kewajiban negara sebagai anggota PBB adalah segera menyesuaikan atau mengharmonisasikan peraturan perundang-undangannya dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Meskipun demikian, implementasi dari harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional itu tidak boleh mengabaikan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya bangsa. Termasuk pula harus tetap mempertimbangkan kepentingan arah perkembangan sistem hukum nasional itu sendiri.

38

PARTAI POLITIK DAN KUALITAS LEMBAGA LEGISLATIF

Oleh:
*Dr. Ir. Tri Pranadji, M.Si., APU***



Pendahuluan

SUATU KEPRIHATINAN yang mendalam bahwa dalam banyak ungkapan disebutkan bahwa lembaga perwakilan rakyat, khususnya DPR, sebagai lembaga yang paling korup dan tidak dapat dipercaya. Ungkapan ini tentu ditengarai dari masih "buruknya" perilaku orang-orang (baca Anggota DPR) yang duduk di lembaga tersebut yang "bocor" di ruang publik. Peran partai politik tidak dapat diseterilkan dari terbangunnya citra DPR yang buruk, karena partai politik merupakan bagian dari pangkal mata rantai dari hal tersebut. Otokritik dari kalangan internal DPR ternyata tidak cukup kuat dan efektif dalam mengendalikan citra "kolektif" orang-orang yang duduk dalam lembaga tersebut. Salahkan jika masyarakat, dengan caranya sendiri yang khas, menyampaikan kepeduliannya dalam bentuk bahasa kritik terhadap partai politik dan DPR?

Secara sosio-budaya, masyarakat Indonesia sangatlah pluralistik. Demikian pun dalam berbahasa untuk menyampaikan kritik terhadap lembaga publik, termasuk terhadap lembaga perwakilan di Senayan. Mengawali tulisan ini saya

---

*Isi tulisan dikembangkan dari makalah yang disampaikan pada Acara Diskusi "Mekanisme Partai Politik dalam Menjaring Calon Anggota Legislatif" pada 20 April 2009 yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Hotel Grand USSU - Cisarua, Bogor.

**Ahli Peneliti Utama pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Departemen Pertanian dan Tenaga Ahli Departemen Dalam Negeri (Pemerintah) untuk Undang-Undang bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Sekretaris Jenderal Ikatan Sosiologi Indonesia. Email: *pranadji@yahoo.com*.

kutipkan pernyataan Musisi Slank dalam menilai kualitas lembaga legislatif, khususnya DPR di Senayan, dalam bentuk kritikan (bahasa) sebuah syair lagu:

... Mau tau gak mafia di Senayan... Kerjanya tukang buat peraturan... Bikin UUD ujung-ujungnya duit...

Lirik lagu tersebut merupakan cerminan dari "omelan" kebanyakan masyarakat awam terhadap keangkuhan anggota DPR yang "sok suci dan hebat" namun dalam kenyataan tidak memberikan dampak yang berarti bagi kehidupan masyarakat banyak. Secara sosiologis dapat dikatakan bahwa citra "sok suci dan hebat" dalam kenyataan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Dapat dihipotesiskan bahwa masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara hasil konstitusional dari suatu pemilu legislatif dengan kenyataan (kinerja anggota dan kualitas lembaga legislatif) sosiologisnya.

Tatanan politik, termasuk elemen partai politik, di Indonesia masih belum memberikan gambaran yang menggembirakan. Pemilu legislatif yang telah selesai dilakukan bulan April 2009 lalu masih menyisakan berbagai permasalahan yang serius. Selain banyaknya warga negara yang "terampas" hak pilihnya (oleh KPU?) –sebagian lainnya (cukup besar jumlahnya) memang tidak berkehendak menggunakan hak pilihnya– hasil pemilu legislatif dinilai belum dapat menghasilkan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) yang lebih baik dibanding hasil pemilu legislatif 2004. Dengan kualitas anggota legislatif yang rendah, mustahil dapat dibentuk lembaga perwakilan rakyat yang berkualitas tinggi. Dapat diajukan pertanyaan: "Apakah mungkin pencapaian keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia terwujud dengan lembaga perwakilan rakyat yang kualitasnya diragukan?"

Pada era reformasi, membicarakan politik tidak lagi harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dua puluh tahun lalu, masyarakat pedesaan sangat takut bicara soal politik (Pranadji, 1984). Dalam 3-4 tahun terakhir penulis telah bertemu dengan banyak petani di banyak pelosok (yang terjangkau siaran TV nasional), mereka menyatakan bahwa calon anggota legislatif dari partai politik susah dipercaya' "ketika sedang kampanye (dalam rangka kemenangan ppemilu) berjanji muluk-muluk untuk memerhatikan (misalnya) nasib petani; namun ketika sudah terpilih dan menikmati keenakan duduk di lembaga legislatif banyak yang sama sekali lupa terhadap janjinya saat kampanye …". Dalam situasi di mana indikasi *socio-political distrust* di kalangan masyarakat luas hingga saat ini masih sangat tinggi akan sulit bagi partai politik mendapat simpati dari konstituennya dengan mudah, (misalnya tanpa adanya iming-iming imbalan uang). Dalam praktik di lapangan lebih banyak digunakan budaya politik dengan cara kasar.

Dalam dua tahun terakhir ini paling tidak ada tiga kejadian besar yang melibatkan Anggota DPR-RI atau lembaga DPR-RI diungkapkan oleh berbagai media massa (cetak dan elektronik) secara gencar. Kejadian *pertama* adalah dinyanyikannya lagu "Gosip Jalanan" (oleh Grup Musisi Slank) yang berlirik

sangat pedas mengritik betapa rendahnya integritas dan moral anggota DPR-RI. Kejadian *kedua*, pernyataan dan pengakuan terbuka Agus Tjondro (politisi senior dari PDIP; Anonimus, 2008) tentang keterlibatannya (beserta sejumlah anggota DPR-RI dari PDIP) dalam kasus *"traveller* cek" (aliran dana dari YPPI Bank Indonesia) yang melibatkan pejabat puncak Bank Indonesia. Kejadian *ketiga*, salah satu kesimpulan Disertasi Idrus Marham (2009) yang mengungkapkan bahwa kualitas sebagian besar (>60%) anggota DPR-RI rendah.

Menarik untuk dilacak lebih lanjut, misalnya dengan pertanyaan "apakah partai politik tidak membuat kriteria tertentu dalam merekrut atau menjaring calon anggota untuk duduk dalam lembaga legislatif?". Sulit dibayangkan jika sampai terjadi bahwa partai politik tidak membuat kriteria baku dalam merekrut anggotanya untuk dicalonkan sebagai anggota DPR-RI. Jika pun ada, mengapa dalam pemberitaan di media massa tidak terungkap mengenai mekanisme partai politik dalam menyeleksi angggotanya untuk didudukkan dalam lembaga legislatif. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa partai politik dalam menyeleksi atau merekrut anggotanya tidak menerapkan asas *good governance*, khususnya asas transparansi.

Kualitas lembaga perwakilan, khususnya DPR-RI, tergantung dari ketersediaan dan kualitas calon legislatif. Jika kualitas (bahan baku) anggota partai politik yang akan didudukkan dalam DPR-RI sangat rendah; akan sulit diharapkan kualitas kinerja kelembagaan DPR-RI menjadi lebih baik. Untuk memperoleh calon anggota lembaga legislatif yang bermutu, maka perlu dibuat suatu model mekanisme penjaringan partai politik yang secara publik dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme tersebut paling tidak harus memerhatikan beberapa aspek: *pertama*, kualitas bahan baku (anggota) yang akan didudukkan dalam lembaga legislatif. *Kedua*, kriteria (kompetensi) yang seperti apa yang akan digunakan dalam mekanisme seleksi anggota partai politik. *Ketiga*, diterapkannya prisip *good governance* dalam penjaringan (calon) anggota partai politik yang akan didudukkan dalam lembaga legislatif.



Penjaringan Calon Anggota Legislatif

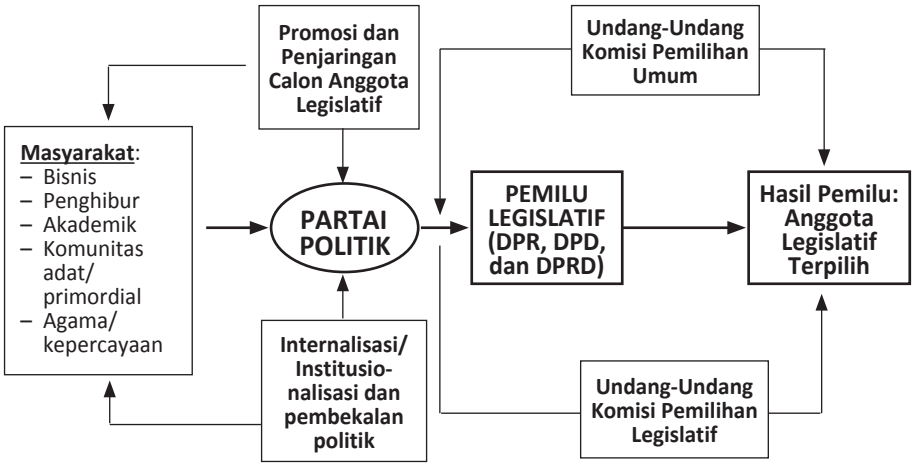
Lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), secara konstitusional didudukkan sebagai lembaga negara yang terhormat. (Dalam tata krama persidangan, misalnya dalam Rapat Panitia Kerja, antara pemerintah dan DPR, dalam menyebutkan Anggota DPR-RI wakil pemerintah harus menggunakan prasa: *"... Ibu dan Bapak anggota dewan yang terhormat..."*). Secara umum dapat dipersepsikan bahwa warga negara yang (terpilih) duduk dalam DPR harus didudukkan sebagai sosok bukan manusia biasa ("terhormat"). Bukan saja bagi kalangan *"job seeker"* yang memang benar-benar membutuhkan pekerjaan agar dapat memberikan imbalan pendapatan yang memadai, banyak dari kalangan yang sudah mapan pun, misalnya bintang film

("penghibur"), yang tergiur untuk menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat. Sangatlah wajar jika banyak warga negara, dan dengan segala caranya, mempunyai keinginan besar dan berupaya untuk menjadi anggota legislatif.

Jika "jaring" yang dibuat untuk menjaring calon anggota legislatif tidak jelas spesifikasinya, maka sulit diharapkan kualitas hasil jaringannya dapat diketahui secara spesifik. Ketika "jaring" dibuat terkesan secara "main-main", atau dengan kata lain tidak dilakukan validasi oleh lembaga pakar atau kumpulan orang yang memiliki kompetensi di bidang *socio-techno-ideologies* yang meyakinkan, maka sangat mungkin kualitas orang yang dihasilkan akan diragukan dan sulit dilacak kekeliruannya. Mengingat sangat strategisnya posisi anggota legislatif (baca: DPR), maka "efek domino" dari hasil penjaringan tersebut sangat mungkin dan berpotensi besar mendatangkan kerugian sosio-politik yang besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia di masa datang.

Keinginan menjadi anggota legislatif merupakan hak setiap orang, terlebih lagi di saat lapangan kerja produktif yang tersedia relatif sangat sempit. Namun demikian, tetap harus disadari bahwa tidak seharusnya dengan hanya bermodal keinginan, seseorang tidaklah mudah merealisasikan keinginannya menjadi anggota legislatif (yang bercitra terhormat). Agar secara sah dapat menjadi calon anggota legislatif seseorang harus melalui penyaringan melalui partai politik. Secara konstitusional, sebelum menjadi calon anggota lembaga legislatif seseorang terlebih dahulu harus menjadi anggota partai politik, (walaupun kebanyakan tidak harus dibuktikan bahwa seseorang tersebut telah terdaftar atau memiliki Kartu Anggota sebagai anggota partai politik tertentu). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU No. 10 Tahun 2008) hanya dengan itu, yaitu menjadi anggota partai politik, seseorang secara konstitusional dapat menjadi anggota lembaga legislatif (DPR dan DPRD) melalui pemilu legislatif. Pendeknya, anggota DPR-RI atau DPRD adalah berasal dari partai politik.

Gambar 38.1 menunjukkan tentang proses seorang warga masyarakat dapat menjadi anggota legislatif. Dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dapat diketahui bahwa menjadi anggota legislatif adalah hak setiap warga negara dengan ketentuan bagi yang telah berumur (dewasa), sehat jasmani dan rohani, diusulkan oleh partai poltik (untuk DPR), serta sejumlah persyaratan administrasi lainnya. Untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif, seorang warga negara harus menjadi anggota partai politik. Dapat dikatakan bahwa hanya dengan melalui partai politik seorang warga negara dijaring, dipersiapkan, dan didaftarkan menjadi calon anggota legislatif. Agar dapat menjadi anggota legislatif (terpilih), calon anggota legislatif harus ikut pemilu legislatif yang diselenggarakan oleh KPU. Layak dan tidaknya atau pantas dan tidaknya seseorang menjadi peserta pemilu legislatif sebagai calon anggota legislatif sangatlah tergantung dari partai politik yang mencalonkannya.



Gambar 38.1. Skema yang menjelaskan proses seorang dari warga negara menjadi anggota legislatif di Indonesia, 2009.

Sebelum seseorang didaftarkan sebagai calon angota legislatif oleh partai politik, paling tidak seseorang tersebut perlu mendapat perlakuan khusus (internalisasi proses politik) dalam kelembagaan partai politik. Untuk menjadi calon anggota legislatif seseorang seharusnya telah mendapat pembekalan atau pendidikan politik sehingga ia telah menjadi makhluk yang "melek politik" (*as a politician, she/he was politically well educated*). Dari calon anggota legislatif pada Pemilu Legislatif (April) 2009 lalu dapat diketahui ragam dari latar belakang karakteristikya. Paling tidak terdapat lima golongan karakteristik calon anggota legislatif, yaitu pedagang atau bisnismen, penghibur (misalnya; bintang film dan komedian), akademisi, tokoh komunitas adat, serta tokoh dari kalangan religius dan aliran kepercayaan.

Sebagaimana sebuah sajian makanan di suatu perjamuan ("Pemilu"), masyarakat pemilih tidak sepenuhnya bebas dalam menentukan (menu) pilihannya. Penyediaan "pilihan menu" atau paket calon anggota legislatif adalah kewenangan yang hanya dimiliki partai politik. Oleh sebab itu, baik dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Prsiden/Wakil Presiden, yang berhak menentukan adalah partai politik atau gabungan partai politik; (khusus untuk Pemilu Presiden/Wakil Presiden adalah partai politik yang telah melewati *parliamentary treshold*). Secara konstitusional tidak dikenal istilah "Golput" (Golongan Putih) atau calon Presiden/Wakil Presiden independen. Bahkan dapat dikatakan bahwa "gerakan" untuk menggalang "Golput": dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dinilai melanggar undang-undang. Dengan kata lain, dengan instrumen undang-undang politik yang ada, partai politik diberi hak monopoli untuk membentuk lembaga perwakilan dan kepresidenan.

Secara kasat mata, penyelenggaraan Pemilu Legislatif telah meninggalkan banyak keraguan. Walaupun penyelenggara pemilu secara kelembagaan dan

konstitusional adalah KPU, namun kesan bahwa KPU secara kesatria mengakui kesalahannya hampir tidak tampak. Selain hal ini mencerminkan sikap *"rai gedheg"* juga menggambarkan masih kuatnya budaya saling lempar tanggung jawab terhadap "keburukan"; dan hal ini hanya lumrah terjadi dalam masyarakat yang sistem ketetanegraannya masih mengandung *socio-political distrust* yang tinggi. Paling tidak, melalui penyediaan data penduduk yang tidak akurat, KPU mempunyai celah untuk menuding pemerintah sebagai bagian dari buruknya penyelenggaraan pemilu legislatif. Pemerintah pun, secara kelembagaan dan dengan alasan konstitusional, menempatkan KPU sebagai pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap buruknya penyelenggaraan Pemilu legislatif. (Apakah masih perlu dicari "kambing hitam" lain yang kecil kemungkinannya untuk melakukan tuduhan balik?).

Menyalahkan pihak yang lemah ("rakyat") terhadap buruknya penyelenggaraan Pemilu Legislatif secara rasional merupakan pilihan tindakan yang mengandung risiko terkecil. Namun demikian, perlu dikemukakan bahwa bukan rakyat yang patut disalahkan, melainkan partai politik (yang menyajikan "menu politik" dalam Pemilu Legislatif). Adalah sangat keliru jika dikatakan bahwa buruknya penyelenggaraan dan hasil pemilu adalah akibat dari tingkat kesadaran politik rakyat (pemilih) yang masih rendah. Lebih tepat jika dikatakan bahwa kualitas hasil pemilu sangat ditentukan oleh kinerja kelembagaan partai politik, terutama partai politik yang mendudukkan anggotanya di lembaga legislatif dan peserta pemilu.



Lagu "Gosip Jalanan"

Kritik terhadap anggota dan lembaga DPR-RI bukan saja dilakukan dalam gedung DPR-RI, melainkan juga dari kalangan awam di ruang publik. Grup Musisi Slank adalah salah satu grup musik yang kiprahnya sangat inten menyentuh masyarakat akar rumput. Lagu "Gosip Jalanan" yang dinyanyikannya seakan-akan telah mewakili bahasa dan mendapat persetujuan masyarakat kalangan awam yang berjumlah besar. Di bawah ini cuplikan beberapa bait (potongan) dari lagu "Gosip Jalanan" yang dinyanyikan Grup Musisi Slank pada April 2008 di depan kantor KPK:

.....
Apa bener ada mafia pemilu
Entah gaptek apa manipulasi data
Ujungnya beli suara rakyat

Mau tau gak mafia di Senayan
Kerjanya tukang buat peraturan
Bikin UUD ujung-ujungnya duit

.....

Beberapa bait dari lirik lagu Grup Musisi Slank di atas dapat dijadikan cerminan adanya kritik sosial yang mewakili suara publik kalangan awam. Sayang sekali, resistensi DPR terhadap kritik melalui lagu "Gosip Jalanan" sangat tinggi. Bahkan dalam siaran TV nasional alat kelengkapan, Badan Kehormatan DPR-RI (2004-2009), melalui wakilnya (Gayus Lumbun) berusaha keras tidak menerima kritikan ini. Tidak hanya berhenti di situ, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR-RI tersebut berbalik mengancam nyanyian "Gosip Jalanan" (yang dinilainya vulgar dan kasar) dituntut melalui peradilan. Juga sangat jelas tertangkap bahwa kritik tersebut ditolak karena "kritik tidak mengggunakan bahasa DPR" (mungkin harus dengan bahasa "terhormat"). Sangat disayangkan, substansi kritik yang begitu berkualitas tinggi dengan mudah dienyahkan begitu saja dengan alasan "bahasanya tidak etis").

Tindak korupsi yang (masih) meraja lela di kalangan anggota DPR-RI secara ilmiah telah banyak diungkap, termasuk dalam bentuk mengapresiasi potongan bait dari lagu "Gosip Jalanan". Peneliti *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) Rizal Sukma mengatakan, lirik lagu tersebut harusnya menjadi bahan refleksi dari hasil survei *Global Corruption Barometer* (GCB; 2007) oleh *Trasparency International Indonesia* yang menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup. (Citra lembaga dan negara terkorup ini sejalan dengan hasil kajian *Corruption Perception Index* 1998; Lipset dan Lenz, 2000). Kaum akademisi juga banyak yang mengungkapkan persetujuannya terhadap kritik Musisi Slank melalui lagu "Gosip Jalanan" tersebut. Salah satu akademisi mengatakan bahwa Badan Kehormatan DPR seharusnya tidak bersikap kebakaran jenggot sejak awal dalam menanggapi lagu Musisi Slank yang liriknya dinilai menuding DPR sebagai tukang korupsi.

Gejala *over reactive* kalangan anggota DPR dalam menanggapi kritik langsung dari masyarakat (lagu "Gosip Jalanan") menunjukkan betapa tingginya resistensi (anggota DPR terhadap kritik) dan belum dewasanya budaya politik yang terbangun di kalangan "komunitas anggota DPR" di Senayan. Slogan bahwa mereka adalah "wakil rakyat" masih sebatas harapan (yang masih jauh dari kenyataan). Dalam menanggapi resistensi DPR terhadap kritik lagu "Gosip Jalanan" Rizal Sukma menyatakan:

> *"saya kira biasa saja. Saya pikir itu kritik-kritik yang sangat umum ya. Ini merupakan juga refleksi yang sudah ditemukan di dalam berbagai survei toh,... yang mengatakan DPR itu adalah lembaga paling tidak dapat dipercaya dan sebagainya,"*

Sebagai wakil rakyat, yang seharusnya mampu menjaga kehormatan diri, agak mengherankan bahwa dalam berbagai persidangan (Panitia Kerja; PANJA) saya sering menemukan bahwa umumnya anggota DPR-RI sangat mudah mengritik pemerintah, (namun enggan menerima kritik). Kritik tersebut sering tidak diikuti dengan argumentasi yang mencerminkan standar kompetensi dan pengetahuan yang memadai sebagai anggota DPR. Lontaran kritik lebih

sering terkesan sebagai ekspresi sikap politik, bukan sebagai kritik profesional anggota parlemen. Juga sering dijumpai bahwa kritik yang dilakukan anggota DPR menggambarkan kesan *"waton suloyo"* dan tidak disertai penjelasan yang dilandaskan pada logika atau pengetahuan yang akurat.



Kriteria Ideal Calon Anggota Legislatif

Dalam ketatanegaraan Indonesia mempunyai lembaga legislatif, seperti DPR dan DPD, merupakan suatu keharusan konstitusional. Namun, keberadaan lembaga tersebut menjadi belum memadai ketika diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, tidak kredibel, tidak bermoral, tidak menyuarakan kepentingan masyarakat banyak atau pemilihnya, dan beberapa tambahan kriteria lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU No. 10 Tahun 2008) telah menyebutkan sejumlah persyaratan umum untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Sejumlah persyaratan tersebut lebih menekankan kelayakan di bidang administrasi.

Tidak mudah diperoleh jawaban tegas ketika ditanyakan: "kriteria ideal seperti apa calon anggota legislatif itu?" Jika calon anggota lembaga legislatif diidealkan harus sensitif untuk mendengarkan keluhan masyarakat, mengapa ketika mendapat kritik dari Grup Musisi Slank reaksinya sangat jauh dari citra "pembela kepentingan rakyat banyak?" Jika calon anggota lembaga legislatif diidealkan sebagai pemimpin yang bersifat negarawan, mengapa masih banyak anggota legislatif melakukan praktik korupsi dalam menyusun peraturan perundang-undangan? Jika calon anggota lembaga legislatif diidealkan sebagai tokoh yang visioner, mengapa masih banyak anggota legislatif yang sangat pragmatis dalam mendapatkan uang? Jika calon anggota lembaga legislatif diidealkan sebagai sosok penjunjung tinggi moralitas dan kejujuran masyarakat bangsa, mengapa masih banyak anggota legislatif yang terlibat dalam praktik asusila baik di dalam gedung maupun di luar lingkungan DPR?

Dari pemberitaan media massa dalam 2-3 tahun terakhir telah banyak dilakukan otokritik terhadap rendahnya kualitas anggota DPR; antara lain oleh Permadi, Agus Tjondro, dan Idrus Marham. Dalam disertasinya, Marham (2009) menyebutkan bahwa dalam berbagai persidangan, banyak anggota DPR tidak disiplin dalam kehadiran. Selain kehadiran dalam persidangan sangatlah kurang memadai, kualitas kinerjanya dalam persidangan pun juga tidak menggembirakan. Banyak kelakuan anggota DPR seperti anak-anak baru belajar sekolah, yang untuk menunjukkan kehadirannya dengan cara menitipkan absen pada temannya. Sikap tidak taat hukum, ambivalensi, dan inkompetensi lainnya masih menjadi gambaran yang memprihatinkan dalam diri anggota legislatif.

Idealnya perlu ada kriteria penjaringan bagi seseorang yang akan dicalonkan menjadi anggota legislatif. Beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab untuk kriteria calon anggota lembaga legislatif, adalah:

(1) Apakah dalam diri calon anggota legislatif harus dijumpai mencirikan seorang yang mempunyai kepedulian terhadap pentingnya menciptakan kehidupan yang lebih baik (*well being*) bagi seluruh masyarakat Indonesia?

(2) Apakah dalam diri calon anggota legislatif harus mencirikan seorang yang mempunyai moralitas dan kejujuran dalam menjalankan amanah kepentingan rakyat?

(3) Apakah dalam diri calon anggota legislatif harus mencirikan seorang yang mempunyai keteladanan kemuliaan pribadi dan sosial (*social dan human nobility*) dalam memerankan dirinya sebagai tokoh atau figur publik di lembaga negara? (Apa dapat disamakan begitu saja antara kriteria *public figure* dalam sinetron atau perfilman dengan *public figure* dalam lembaga negara?)

(4) Apakah dalam diri calon anggota legislatif harus mencirikan seorang yang mempunyai visi dan pemikiran jauh ke depan?

(5) Apakah dalam diri calon anggota legislatif harus mencirikan seorang yang mempunyai sifat kepuasan dalam berkorban (*"altruistic satisfaction"*) demi kejayaan bangsa dan negara?

(6) Apakah dalam diri calon anggota legislatif harus mencirikan seorang yang mempunyai *nation and social responsibility* yang tinggi ketika menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif?

(7) Apakah dalam diri calon anggota legislatif harus mencirikan seorang yang mempunyai *nation pride and dignity* sebagai representasi masyarakat yang memilihnya?

(8) Apakah dalam diri calon anggota legislatif harus mencirikan seorang yang mempunyai kematangan sosial (*socio-emotional maturity*) dan kemampuan untuk bekerja secara *team work* dan mudah bersinergi dengan anggota lembaga legislatif lainnya?

(9) Apakah dalam diri calon anggota legislatif harus mencirikan seorang negarawan (*statement characters*) yang mempunyai pemikiran yang tidak partisan dan lebih memikirkan kepentingan yang bersifat holistik kenegaraaan?

Jika dilihat dari kenyataan empirik di lapangan, jarak atau kesenjangan antara kriteria ideal dan yang diperankan sejumlah anggota legislatif dan kenyataannya masih sangat besar. Pencalonan anggota legislatif, menurut UU No. 10 Tahun 2008, hanya dapat diajukan oleh partai politik peserta pemilu legislatif. Ketika para calon anggota legislatif yang dijaring partai politik tidak didasarkan mekanisme yang transparan dan akuntabel, maka hasilnya diprediksi akan bersifat random. Belum ada jaminan yang memadai bahwa penjaringan

calon anggota legislatif saat ini akan memberikan gambaran bentuk lembaga perwakilan rakyat yang sesuai dengan slogan partai politik, terutama ketika sedang berkampanye dalam pemilu legislatif.

Menjadi menarik untuk dicermati, bagaimana seharusnya dalam tubuh partai politik dibangun mekanisme yang dapat diandalkan dalam menyeleksi calon anggotanya yang akan didudukkan dalam lembaga legislatif. Secara teoretis dapat dikatakan bahwa jika mekanisme partai politik dalam menjaring calon anggota legislatif menerapkan asas pengelolaan manajemen yang baik (*good governance*), maka hal ini akan membuka peluang lebih besar bagi partai politik untuk berperan membangun lembaga perwakilan rakyat yang lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Berkaitan dengan ini, partai politik perlu membuka diri menerima kritik dan masukan dari berbagai pihak untuk mewujudkan partai politik yang kredibel, modern, dan akuntabel.



Good Governance dan Partai Politik

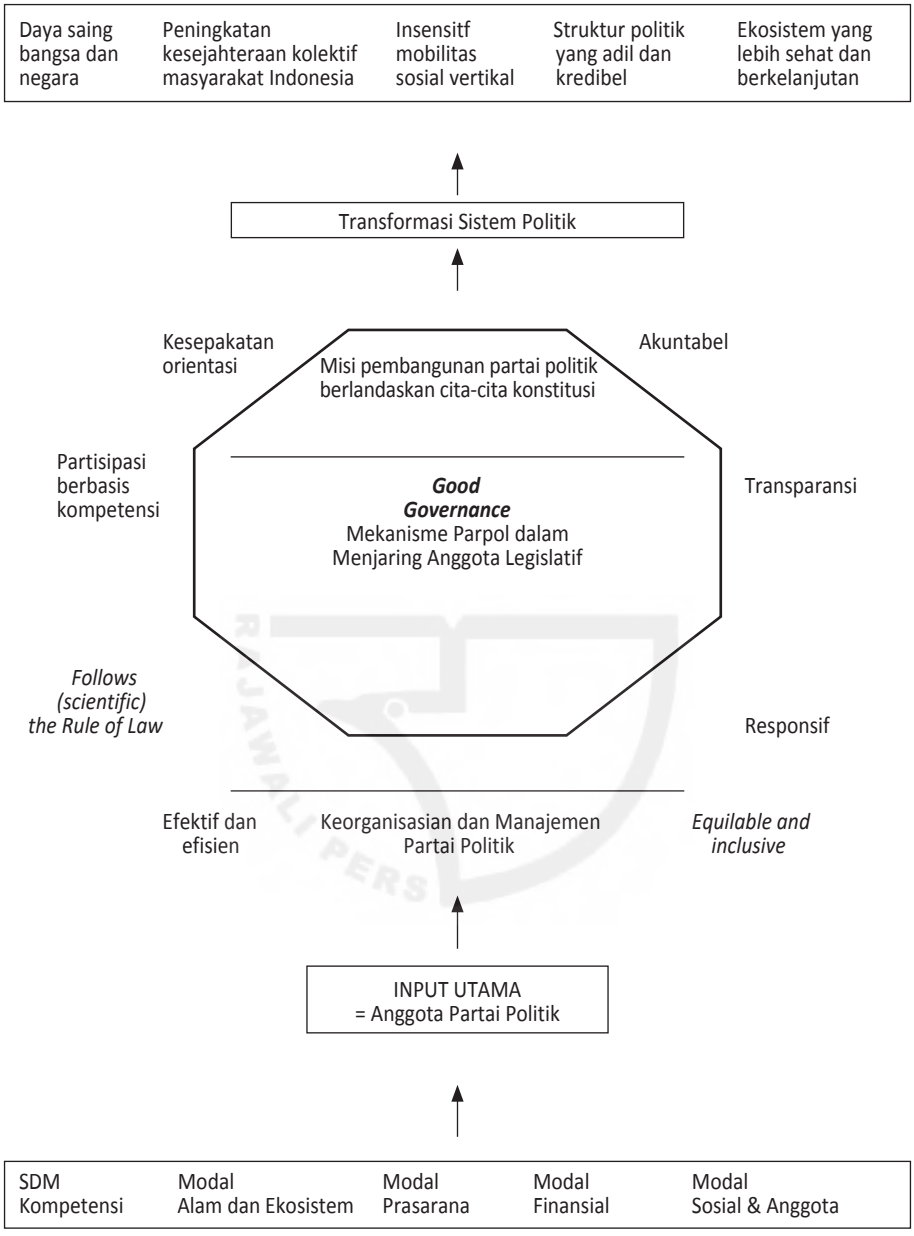
Kenyataan (*das sein*) tidak dapat dijadikan ukuran ideal suatu penyelenggaraan kelembagaan publik yang dijalankan oleh anggota legislatif. Dari pertanyaan di atas sangat terasa bahwa secara *das sollen* (”idealnya”) anggota legislatif bukan saja figur publik yang harus menjaga kehormatannya, melainkan juga sebagai penggerak perubahan (*change agents*) yang kreatif dan inovatif untuk ikut berperan aktif mendorong dan membawa keseluruhan kehidupan masyarakat ke tingkat yang lebih mulia, lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih adil. Tidak seharusnya hal ini dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan dari masyarakat luas mengingat berbagai bentuk kehormatan yang diberikan masyarakat terhadap anggota legislatif secara konstitusional pun sangatlah besar. Suatu hak dan (sekaligus) kewajiban memang melekat dan dilekatkan dalam diri anggota legislatif, dan keduanya harus dijalankan secara proporsional ketika seorang anggota legislatif menjalankan perannya di lembaga perwakilan rakyat.

Secara konstitusional, anggota legislatif (DPR) secara perorangan dibekali hak protokoler dan keuangan, menyampaikan pendapat, dan imunitas. Tanpa rambu-rambu hukum dan integritas moral yang kuat, hak-hak tersebut dengan mudah dapat dikonversi menjadi kekuatan alat tukar (”bargaining position”) dalam ”praktik jual beli” kewenangan dengan pihak yang mempunyai kekuasaan dalam mengelola aset publik dan sumber daya berharga lainnya. Bagaimanapun juga, dilihat dari perspektif ekonomi politik, bayangan bahwa anggota DPR adalah spesies ”makhluk rasional” tidak dapat diabaikan begitu saja. Ketika peluang (”*opportunity*”) untuk mendapatkan manfaat (”*benefit*”) terbuka, tak ada jaminan peluang tersebut, baik secara personal maupun kolektif (jamaah), dibiarkan lewat secara percuma.

Saat ini hanya partai politik peserta pemilu yang mempunyai hak untuk mencalonkan anggotanya untuk duduk dalam lembaga legislatif, khususnya DPR. (Untuk lembaga DPD, pencalonan dilakukan secara perorangan). Jika dalam pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), seseorang yang dapat memperoleh suara mencukupi untuk duduk dalam lembaga legislatif, maka ia berhak duduk di lembaga legislatif. (Dalam kaitan ini partai politik sangat menentukan untuk menyeleksi anggotanya yang akan dipertandingkan dalam pemilu legislatif. Dengan kata lain, jika partai politik tidak mengusulkan seseorang untuk menjadi calon anggota legislatif, maka tidak ada jalur lain seseorang akan dapat menjadi calon anggota legislatif.

(Pengistimewaan partai politik dalam rezim politik pemilu juga berlanjut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus melalui partai politik atau gabungan partai politik yang melewati ambang batas parlemen; *parliamentary treshold*. Secara konstitusional pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara perorangan masih belum dikenal, walaupun dalam banyak pandangan secara sosiologis mekanisme ini seharusnya terakomodasi – terlebih lagi proporsi jumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif diperkirakan melebihi 25 persen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak warga negara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden belum sepenuhnya ditegakkan dan terakomodasi secara meyakinkan).

Sebagai lembaga publik, partai politik harus memasok calon anggota legislatif dengan kualifikasi seideal mungkin dan dengan kriteria yang transparan. Untuk itu, partai politik perlu dengan sungguh-sungguh menerapkan asas *good governance* dalam menyeleksi atau merekrut anggotanya yang akan didudukkan sebagai calon anggota legislatif. Dalam Gambar 38.2 dijelaskan pemikiran dalam kerangka *good governance*, suatu mekanisme partai politik yang relatif dapat diandalkan dalam merekrut dan mendudukkan anggotanya dalam lembaga legislatif. Partai politik dapat dipandang sebagai bagian hulu dari pembangunan sistem politik (Apter, 1987), termasuk untuk kehidupan politik di Indonesia. Sangat jelas bahwa secara kelembagaan partai politik harus bertanggung jawab terhadap kualitas anggotanya yang dicalonkan untuk duduk di lembaga legislatif.



Gambar 38.2 Kerangka *Good Governance* sebagai mekanisme partai politik dalam menjaring anggota legislatif.

Tampak dari Gambar 38.2 bahwa dalam mekanisme penjaringan calon anggota legislatif partai politik harus menerapkan asas partisipatif dan inklusif. Keterbukaan informasi bagi publik terhadap partai politik merupakan bagian dari indikasi sehat dan tidaknya sistem pengelolaan partai politik. Sebagai ilustrasi, bahwa penerapan aspek ketaatan pada hukum dan keilmuan untuk menetapkan seseorang sebagai calon anggota legislatif tidak dapat diabaikan hanya karena seseorang tersebut bukan loyalis buta (*"chauvinistic"*) terhadap partai politik; atau terhadap tokoh atau elite yang mendominasi pengelolaan partai politik. Dalam rangka memperoleh calon legislatif yang berkualitas, penerapan asas rasionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan untuk menentukan seseorang memenuhi syarat dicalonkan menjadi anggota legislatif juga tidak dapat diabaikan begitu saja.



Kesenjangan "Jatidiri" dan Komunikasi Politik

Anggota DPR seharusnya mencerminkan bukan saja seorang komunikator politik ulung dalam mengemban amanah rakyat, melainkan juga sebagai pemimpin yang memiliki sifat negarawan yang visioner. Sejalan dengan nasihat Ali bin Abi Thalib (2009), sebagai negarawan, Anggota DPR harus menjaga hubungan baik ("silaturahmi") dengan rakyat jelata dan memerhatikan kesejahteraan mereka. Sangatlah tidak patut jika mereka justru berusaha melanggar aturan, meminta (dari masyarakat) lebih daripada yang mereka berikan, dan enggan memberikan penghargaan atau ucapan terima kasih atas kebaikan (melalui negara) yang diberikan kepada mereka. Tidaklah patut bagi Anggota DPR jika mereka dalam posisi sebagai pihak yang paling lambat dan paling malas meminta maaf ketika ditahan, dan paling cepat tersinggung ketika mendapat kritikan.

Tidak terwakilinya kepentingan rakyat secara meyakinkan dalam lembaga legislatif (baca: DPR) memberikan petunjuk mengenai tidak ditemukannya "jatidiri" yang kuat pada diri anggota DPR. Dari "kriteria ideal" anggota DPR seperti dijelaskan sebelumnya dapat digambarkan mengenai seberapa jauh kesenjangan antara "jatidiri" anggota DPR yang seharusnya ("ideal") dan yang ditunjukkan di wilayah publik. Semakin besar kesenjangan yang dimaksud menunjukkan semakin buruknya komunikasi politik (Pranadji, 2008; Berlo, 1960) yang dijalankan anggota DPR dan masyarakat. Keburukan tersebut merupakan cerminan rendahnya tingkat representasi anggota DPR terhadap masyarakat konstituennya secara khusus, dan terhadap masyarakat luas secara umum. Tabel 38.1 secara hipotetik menggambarkan masih besarnya kesenjangan jatidiri anggota DPR dan sekaligus (betapa masih) buruknya komunikasi politik yang dijalankan anggota DPR.

Tingkat akuntabilitas dan kepedulian terhadap perbaikan kehidupan masyarakat secara menyeluruh tidak tampak meyakinkan. Masih banyaknya jumlah penduduk miskin (lebih dari 30 juta) dan sangat rendahnya tingkat pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat pedesaan (Pranadji, 2005) merupakan indikasi masih lemahnya tanggung jawab dan kepedulian anggota DPR terhadap perbaikan kehidupan secara kolektif. Dalam bentuk gaya hidup (*"life style"*) apa yang ditunjukkan anggota DPR baik di dalam maupun di luar kompleks Senayan lebih menunjukkan bahwa anggota DPR sebagai bagian dari strata elite masyarakat perkotaan yang bersifat eksklusif. Dari banyak orang desa yang saya temui di pedesaan, umumnya mereka berpendapat bahwa hanya pada saat kampanye mau pemilu saja para calon anggota DPR dapat menunjukkan perkataan ("slogan politik") yang menyejukkan masyarakat … namun begitu terpilih menjadi anggota DPR umumnya mereka tidak ingat lagi janji atau slogan yang pernah diucapkan saat kampanye.

Kesadaran tentang pentingnya membangun dan melaksanakan sistem komunikasi politik yang baik antara anggota DPR dan masyarakat luas tampaknya masih lemah. Pada gilirannya hal ini membentuk buruknya kualitas komunikasi politik antara anggota DPR, lembaga negara lain dan juga masyarakat luas. Buruknya komunikasi anggota DPR juga ditunjukkan dalam bentuk keteladanan sikap dan perilaku anggota DPR yang rendah. Gambaran anggota DPR sebagai "pembela nasib rakyat banyak" hanya dapat dilihat secara orang per orang yang bersifat sangat spesifik, dan secara umum masih banyak menjadi bahan "cemooh" masyarakat luas. Sikap tidak menunjukkan rasa malu dan perilaku yang berbau "premanisme" pada diri anggota DPR umumnya masih tertangkap sangat kentara oleh kalangan masyarakat luas. Baik yang dapat ditemukan dari berbagai hasil poling pendapat maupun pemberitaan media massa, citra anggota DPR sebagai "pembela nasib rakyat banyak" hampir tenggelam dalam hiruk pikuknya rasa jengkel dan muak masyarakat terhadap integritas moral anggota DPR.

Dilihat dari perilaku yang ditunjukkan sehari-hari, visi yang dijalankan oleh kebanyakan anggota DPR lebih bersifat (jangka) pendek dan pragmatis dibandingkan dengan yang bersifat (jangka) panjang dan idealistik. Gejala sikap altruistik semu, yang hanya terbatas dalam slogan (saat kampanye), dapat dijadikan penjelas bahwa sikap amanah dan empati anggota DPR terhadap tingkat kehidupan masyarakat pada umumnya masih relatif rendah. Struktur ketatanegaraan yang menempatkan anggota DPR sebagai warga negara yang serba terhormat, melalui proses pemilihan umum, memang telah menunjukkan adanya modernisasi (formal) dalam tatanan politik. Moderninasi yang tidak sejalan dengan substansi ideal peran anggota DPR menunjukkan pembangunan politik masih mengalami kemacetan serius. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa modernisasi politik memang telah dilakukan, namun pembangunan politik masih jalan di tempat; (*modernization without development*).

Tabel 38.1 Kesenjangan antara ciri aktual dan ideal yang melekat pada ”jatidiri” calon anggota legislatif di Indonesia

Ciri Aktual	Elemen Ciri	Ciri Ideal
Terbatas untuk kalangan elite dan bersifat eksklusif	Tanggung Jawab dan Kepedulian terhadap Perbaikan Kehidupan Kolektif	Terdistribusi relatif merata dan bersifat inklusif
Tidak jelas rujukan ideal; cenderung acak (“*diffuse*”) dan ke arah “premanisme”	Integritas Moral (Jujur dan Amanah)	Jelas rujukan ideal; cenderung determistik dan ke arah ”altruisme”
Tidak terlalu dihiraukan dan cenderung *rai gedheg*	Keteladanan Sikap dan Perilaku	Sangat dihiraukan dengan dasar empati dan rasa malu
Pendek dan pragmatis	Ke-visi-an	Panjang dan idealistik
Searah dan mendikte	Komunikasi Politik	Timbal balik dan inspiratif
Terbatas dalam slogan verbal	Sikap Altruistik	Tuntutan dalam tindakan
Partikularistik dalam bingkai primordialisme	Tanggung Jawab Sosial	Holistik dalam bingkai universalisme
Rata-rata rendah dan tidak berbeda dengan orang awam	Kematangan Emosional sebagai Negarawan	Harus tinggi dan di atas rata-rata orang awam
Sekadarnya dan dianggap tidak terlalu penting	*Socio-techno-ideologies Capacity*	Tinggi dan harus dianggap sebagai hal yang esensial

Transformasi peradaban politik dari budaya feodal ke arah budaya demokrasi, sebagaimana diketengahkan Moore (1972), dalam kelembagaan DPR tampak belum berproses secara sempurna. Budaya politik di lembaga perwakilan masih terkontaminasi budaya sosial masyarakat feodal kuno, sebagaimana terjadi di Eropa abad pertengahan dan elite birokrat masyarakat masa Orde Baru. Budaya feodal masih mewarnai dinamika di pentas politik, walaupun telah dibungkus dengan slogan atau ”baju” demokrasi. Atas nama demokrasi, perilaku anggota DPR masih mencerminkan kaum elite feodal. Reformasi politik awal 1998 dilaksanakan agak kebablasan, sehingga penggunaan slogan demokrasi dalam politik sering digunakan untuk memojokkan ”lawan politik” secara semena-mena. Pada tangan aktor politik di lembaga perwakilan yang integritas moralnya diragukan, hubungan pelaksanaan demokrasi politik dan pencapaian keadilan menjadi kehilangan makna esensialnya.

Menjadi lebih memprihatinkan lagi ternyata masih banyak kalangan masyarakat berpendapat bahwa secara umum kematangan emosional anggota DPR sebagai negarawan masih diragukan (baca “sangat rendah”). Beberapa anggota DPR (berasal dari kalangan intelektual), baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak mau lagi menjadi anggota DPR, secara khusus mengatakan pada saya bahwa ia membenarkan pendapat umum tersebut. Saya telah mendapat keluhan dari seorang mantan anggota DPR bahwa: *“ia menyesal menjadi anggota DPR,... ia merasa sangat lebih baik jika menekuni pekerjaannya sebagai pendidik dan guru besar di perguruan tinggi*”. Keinginannya menerapkan kekuatan

intelektualnya, sebagai ekspresi sikap seorang negarawan di lembaga perwakilan yang terhormat di Senayan terbentur "tembok kejumudan" mayoritas anggota DPR yang umumnya masih mencirikan tindakan seorang yang berwawasan partikularistik dan sangat primordial.

Di kalangan analisis sitem dan analisis statistika dikenal istilah *"garbage in garbage out*. Data input yang buruk akan menghasilkan output yang buruk. Dalam arti lain bahwa jika bahan baku (calon anggota DPR) yang diajukan partai politik kualitasnya buruk, maka setelah masuk lembaga perwakilan tetap saja buruk; dan akan buruk pula keseluruhan lembaga perwakilan tersebut. (Banyaknya partai politik peserta pemilu legislatif 2009 menambah kesulitan "keikutsertaan" masyarakat dalam mengontrol calon anggota DPR. Umumnya masyarakat mengeluhkan tentang terlalu banyaknya partai politik peserta pemilu legislatif, karena hal itu lebih membingungkan masyarakat dalam menentukan pilihannya). Umumnya masyarakat menilai bahwa beberapa partai politik yang telah mapan dan berjam terbang tinggi pun masih buruk dalam melakukan komunikasi politik. Hal ini dapat diketahui dari kemampuan anggota DPR yang telah menduduki kursi di DPR. Buruknya kemampuan komunikasi politik anggota DPR ini sedikit banyak terkait dengan kapasitas yang pas-pasan pada umumnya Anggota DPR di bidang *socio-techno-ideologies*.



Penutup

Secara sosio-politik kehadiran anggota DPR di ranah publik telah diterima sebagai kenyataan. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa kehadiran anggota DPR harus ada, karena lembaga perwakilan rakyat (DPR) diisi oleh anggota DPR yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu legislatif. Masalahnya adalah apakah orang-orang yang terpilih menjadi anggota DPR tersebut mempunyai kapasitas kerja yang dapat memenuhi harapan masyarakat ataukah tidak? Buruknya kapasitas kerja anggota DPR tidak dapat dilepaskan dari sistem penjaringan calon anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik. Mengapa partai politik perlu disoroti dalam penentuan kualitas lembaga perwakilan, hal ini dapat dijelaskan seperti di bawah ini.

Konstitusi negara Indonesia menyatakan bahwa kehadiran partai politik sangat diperlukan dalam pengelolaan pemerintahan negara. Secara sosiopolitik peran partai politik dalam menentukan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegera Indonesia sangatlah besar. Hanya saja dalam kenyataan secara normatif dan kultural peran dan kinerja partai politik masih jauh dari ideal. Salah satu penyebab utamanya adalah bahwa kader-kader partai politik yang duduk dalam lembaga legislatif jauh dari gambaran ideal sebagai figur publik, atau tokoh penggerak perubahan ke arah Indonesia yang kuat, berdaya saing tinggi, terhormat, dan menjunjung tinggi asas keadilan. Dengan kata lain, kapasitas anggota DPR di bidang *sosio-techno-idelogies* masih rendah.

Citra lembaga legislatif sebagai lembaga yang buruk dan tidak kredibel harus diperbaiki, dan hal ini harus diawali dengan perbaikan pengelolaan partai politik. Untuk itu, diperlukan orang-orang yang selektif (kapabel dan kredibel) dalam mengelola partai politik dan yang dicalonkan menjadi anggota legislatif. Untuk mencapai gambaran sosok calon anggota legislatif yang ideal diperlukan partai politik yang mampu membangun mekanisme yang akuntabel dan transparan dalam penjaringan calon anggota legislatif. Sebagai lembaga publik, partai politik harus menerapkan asas *good governance* dalam penjaringan calon anggotanya yang akan didudukkan dalam lembaga legislatif.

Tetap harus disadari bahwa kehadiran partai politik bukan satu-satunya penentu kemajuan masyarakat bangsa Indonesia, terlebih lagi saat tatanan sosio-budaya, ekonomi dan politik masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan masih jauh dari ideal. Transisi tatanan politik, dari budaya feodal ke arah demokrasi belum sepenuhnya berjalan sempurna. Agar kelembagaan partai politik secara sepihak tidak dijadikan alat elite politik untuk memperebutkan "aset publik" maka keterwakilan masyarakat secara budaya dan ideologis harus tercermin pada tindakan elite politik dalam menjalankan perannya baik di dalam maupun di luar lembaga perwakilan rakyat. Kesenjangan antara slogan politik dan tindakan politik para elite partai politik perlu dipersempit melalui penguatan integritas diri; dari elite politik yang mencirikan sifat keserakahan tidak terkendali ke arah yang mencirikan makhluk politik yang cenderung altruistik.

Daftar Referensi

Abi Thalib, A bin. *The Best Advices of Sayyidina Ali for Leader*; (Nasihat-nasihat Imam Ali r.a. Kepada Negtarawan). Jakarta: Gema Insani. 2009.

Anonimous. Elements of Governance. Asian Development Bank. http://www.adb.org/governance/gov_elemens.asp [05/11/06]. 2006.

Anonimous. What is Good Governance? Human Settlements, United Nations Economics and Social Comission for Asia and the Pacific. http://www.unescap.org/huset/gg/ governance. html. [05/11/06]. 2006.

Anonimous. Promoting Democracy and Good Governance. USAID: From the American People. http://www.uasid.gov/our_work/democracy_governance.html [02/02/08]. 2008.

Anonimous. BK DPR Periksa Kasus Agus Tjondro. Suarasurabaya.net. http://www.suarasurabaya.net/v05/politik/?id=69b196397e282b8d678224653689c365200855731. [20/04/09]. 2008.

Apter, D.E. The Politic of Modernization. University of Chicago. Chicago. (Telah di-Indonesiakan oleh Hermawan Sulistyo dan Wardah Hafidz; Politik Modernisasi, Jakarta: Penerbit PT Gramedia). 1965.

Berlo, D.K. *The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1960.

Clark, T. Mechanism of Corporate Rule. http://homepages.ihug.co.nzl~sai/mecoprule.htm. [05/11/06].

Harrison, L.E. and S.P. Huntington. *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books, 2000.

Lipset, S.M. and G.S. Lenz. *Corruption, Culture, and Market*. *In* Culture Matters: How Values Shape Human Progress (Edited by L.E. Harrison and S.P. Huntington). New York: Basic Books. 2000.

Marham, I. Demokrasi Setengah Hati. Studi Kasus Elite Politik di DPR RI tahun 1999-2004. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Disertasi. http://politik.vivanews.com/ news/read/22680-_anggota_dpr_hanya_datang_dan_isi_absensi_ [18/04/09].

Moore, Jr, B. *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Boston: Beacon Press, 1972.

Pranadji, T. Peranan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Tingkat Desa dalam Pembangunan Berencana di Pedesaan: Studi Kasus di Desa Kedungpoh dan Katongan, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurusan Penyuluhan Pertanian, Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor. (Karya Tulis Ilmiah, tidak diterbitkan), 1984.

————————. Pemikiran ke Arah Pengembangan Nilai-nilai Sosial Budaya Bangsa. Jurnal Sosiologi Indonesia, (7): 44-58, 2005.

————————. Ormas dan Peningkatan Komunikasi Politik: Upaya Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Peningkatan Stabilitas Nasional di Wilayah Rawan Konflik. Makalah disampaikan pada kegiatan "Penguatan Ruang Publik Melalui Forum Dialog Kebangsaan Bagi Masyarakat di Wilayah Rawan Konflik dan Komunikasi Politik di Kalangan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik – Depdagri, tanggal 30 Oktober 2008, Hotel Mercure – Jakarta, 2008 (belum diterbitkan).

Saul, J.R. The Collapse of Globalism: and the Rebird of Nationalism. Global Policy Forum. http://www.globalpolicy.org/globaliz/define/2004/03nationalism.htm [05/11/06]. 2004.

Slank. Lirik Lagu Gosip Jalanan Slank. http://www.dipta78.co.cc/lirik-lagu-gosip-jalanan-slank.htm [18/04/09]. 2009.

Sukma, R. Lirik Lagu Slank Harusnya Jadi Refleksi DPR (Harian *Kompas*, 10 April 2008. http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/10/1956498/lirik.lagu.slank. harusnya.jadi.refleksi.dpr. [19/04/09], 2008.

39

REFORMASI DAN MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN NASIONAL DALAM KERANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK*

Oleh:
*Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.***



Pendahuluan

TAHUN 1983 merupakan awal dari kebijakan pembaruan perpajakan (*tax reform)* di Indonesia dengan dilakukannya perombakan total atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembaruan itu dilakukan antara lain melalui penyederhanaan jenis-jenis pajak; penyederhanaan ketentuan cara pemenuhan kewajiban pajak; dan pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (*self assessment system)*. Selain itu, peraturan perundang-undangan perpajakan (hukum positif), yaitu Undang-Undang KUP yang mengatur mengenai hukum pajak formal dipisahkan dari hukum materiil seperti, Undang-Undang PPh, Undang-Undang PBB, dan PPN dan PPnBM.

Pada 1994 dilakukan perbaikan pertama terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan karena terdapat beberapa kelemahan antara lain, kurang berhasilnya *self assessment system* sebagai sistem penetapan pajak yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada WP dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kepada negara. Selain itu *law enforcement* juga masih dinilai lemah (Jamal Wiwoho, 1996: 28). Oleh karena itu, perlu ada peninjauan kembali terhadap kebijakan pembaruan perpajakan agar kondusif dan kompetitif dengan negara-negara lain.

---

*Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional tentang "Modernisasi Perpajakan Suatu Upaya Untuk Menghapus KKN" yang diselenggarakan oleh Tax Centre UNS bekerja sama dengan Ditjen Pajak pada tanggal 29 Mei 2008 di Auditorium UNS Surakarta.

**Dosen Fakultas Hukum UNS/Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum UNS/Ketua Tax Centre UNS. Pendidikan S1 UNS, S2 dan S3 UNDIP.

Selanjutnya pada 1997 dilakukan perbaikan kedua terhadap Undang-Undang KUP yang pertama sebelum adanya perbaikan kebijakan perpajakan pertama, karena yang dijadikan latar belakang adalah perlunya Undang-Undang Pengadilan Pajak (kemudian pada tahun itu muncul Badan Penyelesaian Sengketa Pajak- BPSP), Undang-undang yang mengatur Pajak Daerah, Undang-undang yang mengatur Penagihan Pajak, dan Pungutan Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagai Pengganti Bea Balik Nama. Selanjutnya, pada 2000 dilakukan perbaikan ketiga, yaitu terhadap Undang-Undang KUP yang pernah diperbaiki (pertama) setelah *tax reform,* dan sebagian lagi perbaikan ketentuan undang-undang lainnya juga pernah diperbaiki pada perbaikan kedua. Reformasi perpajakan terakhir secara nyata terdapat dalam UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740).

Pemerintah pada dasarnya menyadari bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang KUP masih terdapat hal-hal yang belum tertampung sehingga perlu penyempurnaan yang sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi, oleh karena itu kebijakan terhadap perbaikan peraturan perundang-undangan perpajakan diarahkan untuk tercapainya kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembangunan (B Wiwoho, 2001: 39).

Apabila dicermati sejak *tax reform* 1983 sampai sekarang dan beberapa kali perbaikan, kebijakan perpajakan secara komprehensif sudah banyak mengalami perubahan terhadap hukum administrasi negara khususnya hukum pajak (peraturan perundang-undangan perpajakan) formal, materiil, dan termasuk peradilan pajak (sekarang diselenggarakan oleh pengadilan pajak) dalam menunjang kebijakan perpajakan secara nasional. Namun, pemerintah tetap memandang perlunya kembali melakukan perombakan total terhadap kebijakan perpajakan yang tentunya akan mengubah peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jika diperhatikan secara saksama, ada dua hal penting yang harus dilaksanakan pemerintah dalam reformasi perpajakan. *Pertama*, pembenahan administrasi dan kebijakan di bidang perpajakan. *Kedua*, menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dengan mengubah persepsi masyarakat terhadap pajak.

Modernisasi Sistem Perpajakan Nasional dalam Rangka *Good Corporate Governance*

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak diperlukan adanya perbaikan administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip *Good Corporate Governance* yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil. Hal ini pada gilirannya akan mendukung Visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Menjadi Model Pelayanan Masyarakat yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia yang Dipercaya dan Dibanggakan oleh Masyarakat. Dalam sistem baru ini di mana organisasi dirancang berdasarkan fungsinya akan memungkinkan pemberian pelayanan prima karena adanya Staf Pendukung Pelayanan Khusus atau *Account Representatwe* (AR) yang dipilih, dan bekerja secara profesional dengan kompetensi tinggi yang disertai kompensasi yang memadai. Hal ini akan membuat semua kegiatan pelayanan mulai dari Penyuluhan, Pembinaan, dan Pengawasan Wajib Pajak lebih terarah dan terukur.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan membawa konsekuensi terjadinya perubahan yang mendasar baik menyangkut struktur organisasi maupun paradigma pelayanan kepada Wajib Pajak. Struktur organisasi baru ini relatif lebih ramping, rentang kendali (*span of control)* lebih singkat di mana KPP Madya juga menangani pemeriksaan, tidak seperti selama ini pemeriksaan ditangani oleh unit yang berbeda seperti Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. *Account Representative* (*AR*) berfungsi untuk menjembatani antara KPP dengan Wajib Pajak serta mengoptimalkan fungsi bimbingan, konsultasi, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Dengan kata lain *AR* adalah pegawai yang ditunjuk sebagai *liaison officer* antara KPP dengan Wajib Pajak, yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan pelayanan secara langsung, edukasi, asistensi, serta mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Berbagai fasilitas untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi (*IT*). Fasilitas tersebut antara lain *website, call centre, complaint centre, e-filling, e-SPT, On-Line Payment*. Untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak serta meningkatkan produktivitas aparat, akan didukung oleh sistem administrasi yang berbasis teknologi informasi. Secara bertahap sistem informasi baru ini, yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP) akan diterapkan. Sistem ini menerapkan *Case Management* (Manajemen Kasus) dan *work flow system* (alur kerja), sehingga memungkinkan setiap proses kegiatan menjadi terukur dan terkontrol.

Karakteristik sistem administrasi perpajakan modern ini, antara lain seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi informasi terkini seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui, kantor penerima pembayaran secara *on-line s*eluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (*e-SPT*); monitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara intensif de-

ngan pemanfaatan profit Wajib Pajak; dan Wajib Pajak yang diadministrasikan di KPP Madya hanya wajib pajak tertentu saja, yaitu sekitar 500 WP.

Di samping hal tersebut di atas modernisasi strategi organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain (Marcus Taufan Sofyan, 2000: 42-44):

1) Kampanye sadar dan peduli pajak

   Kampanye dan sosialisasi perpajakan sebagai bagian dan *good governance framework* melalui berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, tokoh agama, dan juga melalui media massa, portal *website*, serta pemasangan billboard di tempat-tempat strategi dan meningkatkan kinerja penyuluhan sebagai *information service* dan *public relation*.

2) Simplifikasi administrasi perpajakan

   Dukungan teknologi informasi mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan di mana basis data dikembangkan dalam jaringan *online* memungkinkan kecepatan akses informasi dan juga pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak secara *online* mengurangi *administrative cost* dan *compliance cost*.

3) Intensifikasi penerimaan pajak, di antaranya dengan:
   i) melaksanakan pemeriksaan terhadap sektor industri tertentu yang tingkat kepatuhannya masih rendah dan/atau potensi perpajakannya masih dapat digali;
   ii) meningkatkan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk memberikan *detterent effect* yang positif;
   iii) melaksanakan kegiatan penagihan pajak melalui penyitaan rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak, pencegahan, dan penyanderaan;

4) Mengembangkan mekanisme *internal quality control* atas pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan dan melaksanakan pelatihan tentang metode dan teknik pelayanan prima; membangun sistem komunikasi yang efektif untuk mendapatkan *feedback*.

5) Merancang, mengusulkan, dan merealisasikan kebutuhan investasi sehubungan dengan reorganisasi dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern.

Hal yang tidak kalah penting dalam modernisasi sistem perpajakan adalah modernisasi budaya organisasi yang dapat dilakukan dengan program penerapan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*), menerapkan kode etik terhadap seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, pembentukan Komite Kode Etik, meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dan kerja sama dengan Komisi Ombudsman Nasional, penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional, antara lain melalui pelaksanaan *fit and proper test* secara ketat, penempatan pegawai yang disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan, dan program pengembangan *self capacity*,

reward and punishmen, reformasi moral dan etika; Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) kepada Pegawai Pajak.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Direktorat Jenderal Pajak berikut unit-unit di bawahnya semestinya menerapkan perangkat dan sistem untuk mendukung terciptanya *Good Corporate Governance*. Perangkat yang tersedia, yaitu Kode Etik Pegawai DJP, Komite Kode Etik untuk mengawasi pelaksanaan kode etik, kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas pengawasan, konsolidasi internal secara berkesinambungan. Pegawai yang ditempatkan di lingkungan KPP Madya telah memenuhi standar atau kualifikasi tertentu berdasarkan beberapa tahapan seleksi yang dilakukan secara ketat.

Dengan reformasi dan modernisasi perpajakan, diharapkan Wajib Pajak dapat memperoleh manfaat antara lain. Wajib Pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik karena didukung oleh pegawai yang profesional. Permasalahan perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak dapat diselesaikan secara lebih cepat sehingga kepastian hukum lebih terjamin. Hak dan Kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Jamal Wiwoho, 2008: 7).

Kantor Pelayanan Pajak Madya dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan sistem dan prosedur yang modern. Dengan dikembangkannya praktik-praktik *Good Corporate Governance* secara sungguh-sungguh, diharapkan dapat meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak serta menghindarkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat perpajakan.

Dalam sistem perpajakan secara menyeluruh *(integrated-comprehensive)*, administrasi pajak (fiskus) harus efisien dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu tidak menyulitkan baik pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak maupun WP dalam melakukan kewajibannya. Kemudahan tersebut dikemukakan oleh Fritz Neumark seperti dikutip oleh Safri Nurmantu (1987: 17), yaitu *ease of administration and compliance* yang dibagi menjadi empat persyaratan sebagai berikut:

a. *The requirement of clarity,* yaitu dalam proses pemungutan pajak terdapat kejelasan mengenai subjek, objek, tarif, kapan pajak harus dibayar, di mana harus dibayar, hak-hak WP, sanksi hukum bagi WP maupun bagi pejabat pajak, dan sebagainya.
b. *The requirement of continuity,* yaitu menyangkut perlunya kesinambungan kebijakan, karena peraturan perundang-undangan dapat berubah-ubah dan bervariasi, tetapi tetap dalam kerangka kebijakan umum perpajakan.
c. *The requirement of economy,* yaitu menghendaki agar organisasi dan administrasi pajak (fiskus) dilaksanakan seefisien mungkin, karena biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk pemungutan pajak harus seimbang. Efisiensi ini bukan hanya dari segi fiskus, tetapi juga dari segi WP.

d. *The requirement of convenience*, yaitu menghendaki supaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan WP merasa nyaman tidak tertekan, atau merasa diburu atas kewajiban membayar pajak. Rasa nyaman bisa timbul misalnya, karena dapat mencicil utang pajak atau merasa nyaman, karena tidak dipersulit dalam memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajaknya.

Modernisasi Menuju Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Dalam hal pemenuhan pembayaran pajak, pada masyarakat tertentu timbul suatu anggapan bahwa orang pada umumnya tidak suka membayar pajak. Hanya sekelompok kecil saja yang merasa bahwa baik pajak maupun pajak daerah tidak memberatkan mereka, karena mereka merasa membayar pajak terlalu sedikit jika dibandingkan dengan sejumlah kewajiban yang harus mereka bayar. Di Indonesia menurut penelitian majalah TEMPO edisi 22 Agustus 1987, dari 991 responden yang diwawancarai terdapat 8,89 persen responden mengatakan bahwa mereka membayar pajak dalam jumlah yang kecil karena mereka beranggapan kurangnya pelayanan kepada masyarakat. Basil survei di Prancis, Inggris, Jerman, dan Denmark menunjukkan bahwa orang tidak selalu mengharapkan pajaknya selalu diturunkan. Misalnya penelitian yang dilakukan di negara tersebut menunjukkan bahwa yang bersedia pajaknya dinaikkan bila pelayanan masyarakat ditingkatkan jauh lebih besar dari persentase orang yang minta pajaknya diturunkan. Hal ini tampak dari Tabel 39.1 di bawah ini.

Tabel 39.1 Tentang distribusi responden menurut dukungan terhadap pemotongan pajak dan pelayanan masyarakat

Pilihan Kebijakan	Inggris	Francis	Jerman	Denmark
Kurangi Pajak -Kurangi Pelayanan	38	25	29	37
Naikkan Pajak-Naikkan Pelayanan	44	47	41	43
Tidak Tahu		16	22	14
Menolak menjawab	18*	12	8	5
Jumlah (100 %)	100	100	100	99
N	1133	1268	1002	1002

Catatan: (*) Jawaban tidak tahu dan menolak menjawab digabung.

Dari Tabel 39.1 sekilas terkesan bahwa orang tidak selalu anti terhadap pembayaran pajak, namun penelitian jangka panjang di Amerika juga menunjukkan bahwa adanya kecenderungan orang semakin antipati terhadap pembayaran pajak. Pada 1987 terdapat 61 persen responden *gallup pool* menjawab bahwa pajak yang mereka bayar terlalu tinggi. Pada 1996 angka tersebut meningkat menjadi 72 persen. Survei yang dilakukan oleh Haris Pool di Amerika menunjukkan bahwa pada 1989 terdapat 54 persen responden yang menyatakan bahwa mereka sudah sampai titik puncak *(breaking point)* dalam hal pembayaran

pajak. Pada 1988 terdapat 66 persen yang sudah sampai pada titik puncak. Hasil survei tersebut menunjukkan adanya kecenderungan orang menjadi semakin antipati untuk membayar pajak.

Antipati untuk membayar pajak hanyalah salah satu bentuk ketidaksukaan wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Bentuk lainnya adalah upaya menghindarkan diri dari kewajiban membayar pajak.

Upaya untuk menghindarkan diri dari pajak pada umumnya dapat dikategorikan dalam tiga tipe (Dean. P. et.al: 1992; 57). Tipe pertama adalah menghindarkan diri secara legal *(tax avoidance)*. Dalam tipe ini wajib pajak berusaha mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mencari kelemahan-kelemahan dari peraturan perpajakan *(loopholes)*. Sedangkan tipe yang kedua adalah menghindarkan diri untuk tidak membayar pajak secara ilegal *(tax evasion)*. Dalam tipe ini wajib pajak dengan sengaja untuk tidak melaporkan kekayaan dan penghasilan yang semestinya harus dibayar kepada kas negara dalam bentuk pajak. Sedangkan tipe yang ketiga adalah penunggakan pembayaran pajak. Penunggakan pajak (karena memang tidak mau membayar) adalah tipe lain dari ketidakmampuan membayar pajak, sehingga sama dengan *tax evasion,* penunggakan pajak dapat dikenakan hukuman.

Walaupun terdapat perbedaan dalam gradasi, perbuatan *tax avoidance, tax evasion,* dan penunggakan pajak, ini merupakan refleksi dari ketidakgairahan orang untuk membayar pajak. Pada kasus *tax avoidance,* motivasi untuk membayar jauh lebih baik daripada kasus-kasus *tax evasion*. Orang-orang yang melakukan *tax avoidance* tidak semata-mata karena rendahnya kesadaran untuk membayar pajak, akan tetapi juga dipengaruhi oleh motivasi untuk memperoleh keuntungan finansial yang banyak/sebesar-besarnya. Dimata wajib pajak tersebut perilaku *tax avoidance* adalah halal dan tidak melanggar hukum. Sedangkan pada *tax evasion* kegairahan untuk membayar pajak jauh lebih rendah karena perilaku untuk tidak membayar pajak adalah ilegal. Perilaku *tax evasion* tersebut merupakan salah satu ciri umum dari wajib pajak yang biasanya berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarnya dengan cara melaporkan sesedikit mungkin jumlah penghasilan dan kekayaan yang dapat dikenakan pajak.

Dilain pihak jika ditinjau dari segi psikologi sosial, maka orang yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak itu bermacam-macam motif (Herbert Kelman. 1996: 78). *Pertama*, wajib pajak membayar pajak itu karena takut akan adanya sanksi hukum atau takut dihukum bila ia menyembunyikan pajak atau tidak membayar pajak. Perilaku yang demikian ini disebut dengan istilah *compliance*. Pada tingkatan ini orang membayar pajak bukan didasarkan atas kesadaran atas pentingnya membayar pajak bagi negara dan diri sendiri, akan tetapi karena pengaruh pengenaan sanksi/hukuman yang dikenakan sangat berat.

Kedua, orang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak adalah apa yang dinamakan *identification,* di mana orang yang membayar pajak didorong oleh karena rasa senang dan rasa hormat kepada petugas pemerintah/aparat negara, khususnya aparat pajak. Bila pegawai pajak bisa bertindak adil dan jujur maka wajib pajak akan bergairah untuk membayar pajak. Akan tetapi ,jika sikap yang demikian ini tidak dimiliki oleh aparat pemerintah, maka wajib pajak akan tidak berminat untuk membayar pajak. Dalam keadaan seperti ini, tampaknya perlu sekali upaya yang bersifat persuasif di dalam membuat petugas pemerintah lebih simpatik kepada rakyat.

Motif *ketiga*, yang mendasari keinginan wajib pajak membayar pajak adalah apa yang dinamakan *internalization* Pada tingkat ini wajib pajak membayar pajak disebabkan oleh kepatuhan atau kesadaran bahwa pajak itu memang berguna untuk dirinya sendiri maupun masyarakat luas. Dengan kata lain, pada tingkatan ini wajib pajak sudah menginternalisasikan norma hidup bersama yang memang memerlukan pajak untuk kepentingan bersama. Tanpa adanya ancaman hukuman pun wajib pajak yang sudah sampai pada level ini akan membayar pajak dengan sukarela. Untuk mencapai tingkatan ini tentunya bukanlah suatu hal yang mudah dalam mencapainya. Tampaknya tidaklah mudah mengupayakan suatu negara di dunia ini yang dapat membuat semua pembayar pajak dapat mencapai tingkatan *internalisasi* ini.

Menurut Safri Nurmantu, kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai "suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya." Terdapat dua macam kepatuhan (Safri Nurmantu, 1987: 148) yakni:

> Kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan materiil, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan materiil adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Dalam lingkup yang lebih luas kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan menjadi agenda penting di negara-negara maju, apalagi di negara-negara berkembang. Isu ini menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya untuk menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan *fraud* dan illegal yang disebut *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara. (Marcus Taufan Sofyan, 2000: 45). Berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan merupakan pengukuran yang lebih akurat atas efektivitas administrasi perpajakan. Penyebab *tax gap* terutama lemahnya administrasi perpajakan. Keberhasilan pengumpulan pajak hanyalah merupakan akibat semakin sempitnya jurang kepatuhan. Semakin patuh rakyat membayar pajak berarti jurang kepatuhan semakin sempit dan berarti pemungutan pajak lebih berhasil. Sebaliknya, semakin lebar jurang kepatuhan, maka semakin sedikit pajak yang berhasil dikumpulkan. Upaya mengurangi kesenjangan kepatuhan dilakukan melalui penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. Rendahnya *tax ratio* menunjukkan terdapatnya kesenjangan yang tajam di mana hal ini terkait erat dengan administrasi pajak. Masalah lemahnya administrasi perpajakan dialami oleh banyak negara sedang berkembang (Richard Bird & Oliver Oldman, 1984: 69).

Ada tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu *pertama,* dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi Wajib Pajak yang belum patuh, *kedua,* adalah meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan, *ketiga,* meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan (*combatting noncompliance*) (Hadi Purnomo, 2004: 218-223).

Pada hakikatnya, kepatuhan Wajib Pajak banyak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. (Liberty Pandianagan, 2002: 78). Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak melalui dua cara, yaitu *pertama,* Wajib Pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. *Kedua,* Wajib Pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdekteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain.

Sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Peningkatan kepatuhan sangat penting dalam reformasi perpajakan dan mungkin lebih penting daripada perubahan struktural dalam sistem perpajakan.



Penutup

Reformasi dan modernisasi perpajakan nasional menjadi agenda yang penting di Indonesia mengingat penerimaan dalam negeri dalam bentuk pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat (dalam skala nasional APBN 2005 sebesar 542,4 T; penerimaan pajak 347,03 T; APBN 2006 sebesar 609, 1 T; penerimaan pajak sebesar 414,32 T; dan APBN 2007 sebesar 684, 47 T dengan penerimaan pajak sebesar 502,69 T.

Peran pajak demikian berarti untuk kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu upaya untuk selalu meningkatkan kepatuhan atau kesadaran membayar pajak selalu ditingkatkan karena tidak semua wajib pajak sadar untuk membayar pajak, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan penekanan tindakan untuk membayar pajak dengan pendekatan hukum dan memberikan perlindungan hukum pula. Penindakan ini sangat perlu terhadap wajib pajak yang jumlah penyelewengan pajaknya sangat besar. Adanya tindakan ini akan dapat membentuk *image* yang positif terhadap pemerintah untuk menindak para pelanggar pajak. Kalau penindakan ini hanya ditujukan kepada pelanggar kecil saja maka akan terlihat kurang seriusnya petugas pajak menindak bagi pelanggar pajak. Keadaan ini akan menimbulkan perasaan yang kurang adil bagi kalangan masyarakat.

Daftar Referensi

Bird. Richard, and Oliver Oldman. *Reading On Taxation In Developing Countries*. Baltimore: The Johns Hopkins Press. 1984.

Dean, P. et. al. Tax payers attitude to income tax evasion: an empirical study. *British Tax Review*. 1980.

Glenn P. Jenkins dan Gangadhar P. Shukla. *Public Finance in Open Economies*. Harvard International Tax Program. Harvard Institute for International Development, 1997.

Hadi Pranoto. *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Fiskal, dan Implementasi*. Jakarta. Buku Kampus. 2004.

Hector S. De Leon. *The Fundamentals of Taxation*. Rex Book Store. Manila. Philippines. 1993.

Jamal Wiwoho. Keberatan dan Banding Atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Serta Permasalahan Pembentukan Badan Peradilan Pajak, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1996.

————————. *Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak yang Berkeadilan*. Surakarta, UNS Press, 2008.

Kelman. Herbert. Compliance, Identification, and Internalization: Three Process of Attitude Change, dalam *Problem in Social Psychology*. New York: McGrawHill, 1966.

Marcus Taufan Sofyan. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar, *Skripsi*. Tangerang, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2000.

Lewis. A. *The Psychology of Taxation*. Oxford: Martin Robertson, 1982.

Liberty Pandiangan. Pajak Pusat dan Pajak Pusat dalam Kerangka Sistem Perpajakan Nasional. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 1, No. 7. 2002.

Rochmat Soemitro. *Pajak Penghasilan*. Bandung: PT Eresco, 1990.

Safri Nurmantu. *Kepatuhan Perpajakan sebagai Objek Penelitian*. Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1987.

Upal. JS. *Taxation in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.

Wiwoho. B dkk. *Zakat dan Pajak*. Jakarta. Yayasan Bina Pembangunan, 1991.

40

EKSISTENSI KELEMBAGAAN MEDIASI PERBANKAN DALAM PERATURAN BANK INDONESIA TERHADAP SISTEM ATURAN HUKUM*

Oleh:
*Dr. Febrian, S.H., M.H.***

Pendahuluan

PENYELENGGARAAN LEMBAGA MEDIASI perbankan diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/5/PBI/2006. Apakah tepat pengaturan mediasi perbankan dengan payung hukum PBI? Seperti apakah PBI dimaksud? Bagaimana figur hukum PBI dalam sistem aturan hukum (peraturan perundang-undangan)? Pertanyaan beruntun ini paling tidak menunjukkan: *pertama* ketidakpahaman terhadap bentuk aturan hukum. *Kedua*, ketidakharmonisan aturan hukum dalam suatu sistem; dan *ketiga*, dalam bentuk pertanyaan bagaimana PBI dapat diberlakukan tanpa menimbulkan sengketa norma?

Kajian tulisan ini akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sistem sehingga diharapkan dapat menjawab persoalan hukum dan sekaligus memberi solusi hukum terhadap payung hukum lembaga mediasi perbankan. Dalam analisis bentuk aturan hukum PBI nantinya akan selalu berkait dengan materi muatan (*het onderwerp*) dari norma pengaturan PBI, karena dua hal ini, baik bentuk maupun norma kadangkala saling menggantikan dan ketergantungan.

---

*Makalah ini telah direvisi dan pernah disampaikan pada "Diskusi Terbatas Mengenai Mediasi Perbankan", Kerja sama BI dengan Kajian Hukum Bisnis FH UNSRI 12 April 2007, Hotel Aston Palembang; Di samping materi makalah yang masih relevan dengan kondisi saat ini, makalah ini secara khusus diperuntukkan untuk menyambut ulang tahun yang amat terpelajar Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, S.H., M.H.

**Staf Pengajar Fakultas Hukum Unsri, Doktor ilmu hukum bidang peraturan perundang-undangan pada Pascasarjana UNAIR 2004 dengan judul disertasi "Hirarki Aturan Hukum di Indonesia", Mobile: +628163285762, e-mail: febrian_zen@yahoo.com.sg



Aturan Hukum PBI

PBI adalah aturan hukum.[1] Diakui, baik dalam praktik perundang-undangan maupun dalam hukum positif, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004 yang berbunyi:

> "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."

Jenis aturan hukum tersebut dapat dilihat dari Penjelasan, yang menyatakan:

> "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat dan dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."

Dari pengaturan tentang pengakuan bentuk aturan hukum PBI di atas, maka pertanyaan hukum yang timbul, yaitu bagaimana kedudukan hukum PBI dalam sistem aturan hukum? Mengingat PBI tidak tercantum dalam hierarki aturan hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10/04. Sementara itu, ketentuan Pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa PBI diakui keberadaannya dan sepanjang diperintahkan oleh aturan hukum yang lebih tinggi. Apakah aturan hukum yang lebih tinggi tersebut adalah aturan hukum yang dijelaskan oleh Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan:

> "Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
> a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
> b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
> c. Peraturan Pemerintah;
> d. Peraturan Presiden;
> e. Peraturan Daerah.

[1]Frasa "aturan hukum" adalah penggunaan secara teori yang penulis gunakan, yang dalam bahasa perundang-undangan sering kali disebut dengan istilah peraturan perundang-undangan, peraturan hukum, dan beberapa istilah lainnya.

Pertanyaan yang gampang-sulit menjawabnya. Tafsiran sistematis bisa saja membenarkan bahwa ayat (4) tidak boleh bertentangan dengan ayat (1) pada pasal yang sama. Kalau tafsiran ini dipahami sebagai "tepat", maka apakah PBI berada di bawah Perda? Suatu contoh ekstrem dialektika hukum, karena praktik aturan hukum jelas-jelas tidak akan membenarkan bentuk aturan hukum Perda di atas PBI. Selanjutnya, apakah PBI berkedudukan di bawah Perpres atau PP atau UU/Perpu atau UUD?

Bagi penulis tidaklah tepat mendasarkan pada hierarki hukum dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 10/04 tersebut. Bukankah dalam praktik hukum kondisi demikian membuat kebingungan dan menimbulkan ketidakpastian?

Jawaban sementara untuk memahami PBI seyogianya juga dilandasi pada apa figur hukum PBI tersebut. Selain itu, walaupun diatur dan diakui bentuk/jenis PBI, tetapi UU No. 10/2004 tidak menjelaskan atau mengatur materi muatan PBI, termasuk beberapa jenis aturan hukum lainnya.

Mengapa materi muatan menjadi penting? Hal ini tidak lain karena materi muatan sebagai norma hukum (sekumpulan) untuk bergeraknya hukum dalam kenyataan (perbuatan hukum), hingga akibat hukum dari perbuatan hukum dapat diukur. Kondisi semacam ini dalam praktik akan dengan sangat gampang menjadi sengketa norma, karena:

(a) tidak ditopang dengan bentuk aturan hukum; dan
(b) norma hukum pbi pada umumnya bersifat terbuka.

Dari dua hal itu, menjadi suatu pertanyaan besar, apakah Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pembentuk PBI memiliki kewenangan pembentukan (*wetgeving*) sebagaimana lembaga legislatif. Persoalan ini menjadi krusial ketika penetapan pengaturan (*te regelt*) oleh PBI pada akhirnya akan menimbulkan persoalan baru manakala hukum diberlakukan (*rechtstoepassing*).



Sumber Wewenang Pembentukan PBI

Melalui pendekatan konseptual, Pasal 1 ayat (2) UU No. 10/2004 aturan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur:

- peraturan tertulis;
- dibentuk oleh lembaga negara;
- pejabat yang berwenang; dan
- mengikat umum.

Dari unsur-unsur ini dapatlah diuji apakah konsep PBI memiliki kapasitas aturan hukum, khususnya terhadap materi muatan mediasi perbankan. *Pertama*, PBI adalah peraturan tertulis. *Kedua*, PBI dibentuk oleh BI yang berstatus sebagai lembaga negara. *Ketiga*, berkait erat dengan nomor dua, maka

pejabat BI yang berwenang dapat menerbitkan PBI, dan *keempat*, PBI yang mengatur materi muatan perbankan adalah mengikat umum.

Dari analisis teori ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004, maka jelas PBI termasuk salah satu aturan hukum (bentuk). Akan tetapi, ketentuan dalam UU No. 10/2004 tidak menjelaskan lebih jauh terhadap materi apa yang dapat diatur oleh PBI; yang dalam penerapannya kemudian dapat menimbulkan persoalan hukum terhadap kedudukan PBI, seperti apakah hakim tunduk atau wajib menggunakan PBI untuk menyelesaikan sengketa perbankan, dan lain sebagainya.

UU No. 10/2004 sebagaimana juga pengaturan sebelumnya dalam Tap MPR No. III/MPR/2000[2] masih saja menggunakan *nomenclature* peraturan perundang-undangan, tidak berdasarkan pada sifat pembagian kekuasaan negara[3] dan tanpa membedakan aturan hukum (peraturan perundang-undangan) yang merupakan produk legislatif dan produk eksekutif. Baik legislasi maupun regulasi memiliki karakteristik berbeda dalam sistem aturan hukum. Produk legislasi merupakan kewenangan legislatif DPR-RI berupa Undang-Undang (UU) (Pasal 20 (1) UUD 1945) dan legislatif DPRD berupa Perda (UU No. 23/03 jo UU No. 32/04). Lalu, di mana letak regulasi? Dalam ilmu perundang-undangan regulasi merupakan kewenangan eksekutif dan dikategorikan sebagai *delegated legislation*.[4]

Dari dua pengkategorian ini, apakah sumber wewenang pembentukan PBI adalah legislasi atau regulasi? Pembedaan demikian sebenarnya sudah menjawab dan memudahkan pengaturan terhadap materi muatan (mediasi perbankan). *Delegated legislation* hanya dimiliki oleh UU dan Perda, terdelegasi

---

[2]Tap MPR No. III/MPR/2000 adalah perubahan terhadap Tap MPRS N. XX/MPRS/1966. Berdasarkan ketentuan Tap MPR No. I/MPR/2003, salah satu ketentuannya mengatur jika dengan terbentuknya UU dengan materi yang sama, maka ketetapan tersebut selanjutnya tidak memiliki daya laku lagi.

[3]Pembagian kekuasaan negara dibedakan dalam pembagian kekuasaan horizontal, berupa kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial, sedangkan pembagian kekuasaan vertikal adalah pembagiaan kekuasaan pemerintah pusat dan kekuasaaan pemerintah daerah.

[4]Dalam hukum Prancis fungsi legislasi adalah merupakan kekuasaan legislatif (*legislative role for Parliament's Law Making Powers*) untuk membedakan secara jelas kekuasaan eksekutif dengan fungsi regulasi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 34 mengenai materi *la loi* (*matters for statute*). Kutipan berikut jelas menggambarkan arti dari kekuasaan legislatif dimaksud yang membedakan dengan yuridiksi fungsi regulasi dari kekuasaan pemerintah, yaitu: "*Statutes are passed by Parliament*. The areas covered by *statute*, which are all set out in article 34 of the Constitution, include the following essentials: public liberties, the determination of serious crimes and other major offences, taxation, the budget and the fundamental principles of national defence, the self-government of territorial units, education, the regime governing ownership, labour law and social security. In 1996 the field was extended to include the financing of social security. *Other areas are matters for regulation* and consequently fall within the Government's jurisdiction. It is for the Constitutional Council and the Conseil d'Etat to ensure that the distinction between statute and regulation is observed." Lihat http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp. Perhatikan juga Febrian, Hirarki Aturan Hukum, Disertasi Pascasarjana UNAIR 2004, hlm. 86.

pada PP dan Perpres untuk UU dan Peraturan Kepala Daerah untuk Perda. Apakah UU dapat mendelegasikan pengaturan materi tertentu pada PBI?



Materi Muatan Mediasi Perbankan

Secara analogi, terhadap pertanyaan hukum apakah UU dapat mendelegasikan pengaturan materi muatan tertentu pada PBI bisa kita lihat dari ketentuan Pasal 79 UU No. 14/1985 tentang MA yang menyatakan:

> "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini"

Dalam UU No. 7/92 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/98, UU No. 23/99 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/04 dan UU No. 30/99, pada pasalnya tidak diatur secara eksplisit mengamanatkan pengaturan penyusunan PBI mediasi perbankan oleh BI. Analogi tersebut tidak mampu menjawab apakah PBI mendapatkan delegasi kewenangan dari UU.

Apabila kita mengaitkan dengan UU No. 10/04 dan pengkategorian sumber wewenang pembentukan, maka jelas dan tegas bahwa PBI dibentuk berdasarkan aturan hukum (peraturan perundang-undangan) yang lebih tinggi. Dengan catatan tidak harus berpegangan/mengikat berdasarkan ketentuan hierarki aturan hukum, tetapi didasarkan pada figur hukum *delegated legislation*.[5]

Jika memerhatikan materi muatan mediasi perbankan dalam PBI No. 8/5/PBI/2006, tepatnya pada Penjelasan Umum alinea 3, kalimat terakhir menyatakan:

> "…. Dengan demikian, fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan BI hanya terbatas pada penyediaan tempat, membantu nasabah dan bank untuk mengemukakan pokok permasalahan yang menjadi sengketa, penyediaan narasumber, dan mengupayakan tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank."

Cetak miring penulis menunjukkan bahwa ada *excuse* dari konsideran PBI. Padahal teknis pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, konsideran seyogianya berisikan hakikat filosofi, efektivitas sosial, dan memiliki daya ikat hukum. Di samping materi muatan lainnya yang harusnya juga memuat kedudukan, tugas dan wewenang, serta proses beracara sarana mediasi tersebut. Oleh karena itu, PBI tentang Mediasi Perbankan ini perlu penyempurnaan yang lebih komprehensif, baik dari materi muatan maupun bentuk aturan hukumnya.

---

[5]*Delegated legislation* terbatas pada satu aturan hukum di bawahnya, terlarang untuk aturan hukum yang bersumber pada delegasi untuk didelegasikan lagi. Konsep ini dikenal dengan sebutan subdelegasi atau dalam bahasa latin disebut *"delegatus non potest delegare."*



Penutup

Akhirnya, sebagai penutup tulisan, solusi hukum yang dapat digunakan sebagai payung hukum pengaturan mediasi perbankan adalah:

1. menggunakan UU; atau
2. menggunakan PBI dengan meminta UU mendelegasikan/mengamanatkan pengaturannya.

Daftar Referensi

Brown, L Neville, et. al. *French Administrative Law*. Clarendon Press, Oxford, 1998.

Febrian. "Hirarki Aturan Hukum", *Disertasi*, Pascasarjana UNAIR, 2004.

————————. "Kualifikasi Yuridis Materi Muatan UU Berdasarkan UUD 1945", makalah, 2001.

UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, LN RI Tahun 2004 No. 7, TLNRI No. 4357.

UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, LN RI Tahun 2004 No. 9, TLN RI N0. 4359.

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, LN RI Tahun 2003 No. 92, TLN RI No. 4310.

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia LNRI TAHUN 1999 NOMOR 66, TLNRI No. 3843.

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LNRI Tahun 1999 No. 138, TLNRI No. 3872.

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN RI Tahun 1985 No. 73, TLN RI No. 3316.

PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA-RI.

Surat Edaran No. 8/14/DPNP tentang Mediasi Perbankan yang ditujukan kepada Semua Bank dan Nasabah Bank di Indonesia, tanggal 1 Juni 2006.

41

PENGELOLAAN KONFLIK PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN DALAM MEWUJUDKAN HAK MASYARAKAT LOKAL

Oleh:
*Dr. Agus Surono, S.H., M.H.**

Pendahuluan

Di sekitar kawasan hutan, hidup masyarakat asli atau masyarakat adat yang berdasarkan hukum adatnya memiliki hak sumber daya alam di sekitar hutan. Hukum adat menetapkan bahwa masyarakat adat tersebut mempunyai hak atas hutan di sekitar mereka berupa hak untuk menggunakan lahan di teritorialnya, hak untuk tinggal dalam jangka waktu tertentu di sekitar kawasan, serta hak untuk memanfaatkan hutan di sekitar kawasan.[1] Dalam perkembangannya di suatu kawasan lahir masyarakat lokal yaitu masyarakat yang berasal dari daerah lain, tetapi kemudian menetap untuk jangka waktu yang lama di kawasan tersebut, seperti terjadi di kawasan Tangkahan.

Perkembangan sosial ekonomi telah melahirkan konflik antara masyarakat lokal dan negara mengenai pelaksanaan hak-hak mereka tersebut, seperti yang terjadi di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

---

*Penulis adalah Ketua Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, Dosen S2 pada Universitas Borobudur, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammadiyah Palembang, dan Senior Legal Analys pada Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, serta Partners pada Kantor Hukum Prasetyo & Partners.

[1]Van Voollenhoven membedakan apa yang disebut dengan hak ulayat (*disposal right*) dan yang dipegang oleh anggotanya. Van Vollenhoven memberikan enam ciri hak ulayat, yaitu 1) masyarakat dan anggotanya diperbolehkan secara bebas untuk menggunakan lahan-lahan perawan (*virgin lands*) di dalam teritorialnya; 2) pihak luar diizinkan untuk menggunakan lahan-lahan tersebut setelah mendapat izin jaminan oleh masyarakat; 3) kompensasi bagai penggunaan tersebut harus dibayar oleh pihak luar; 4) masyarakat selalu memelihara kontrol lahan-lahan bekas ditanam di dalam teritorialnya; 5) orang yang bersalah harus bertanggung jawab dan menanggung biaya, dan menjadi tanggung jawab bersama jika pelanggar tak dikenal; 6) masyarakat tidak dapat mengalihkan secara permanen hak ulayatnya.

Penelitian mengenai hak-hak masyarakat lokal dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser tersebut penting setidak-tidaknya karena lima sebab. *Pertama*, belum adanya konsep yang jelas tentang perlindungan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan di kawasan Tangkahan, Taman Nasional Gunung Leuser. Belum adanya konsep tentang perlindungan masyarakat lokal dapat dibuktikan bahwa dalam kenyataannya masih banyak kesulitan ekonomi masyarakat sekitar kawasan Tangkahan, Taman Nasional Gunung Leuser.

Kedua, adanya konflik yang terjadi di berbagai kawasan Tangkahan, Taman Nasional Gunung Leuser yang melibatkan berbagai pihak, termasuk juga masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat lokal dalam konflik ini dikarenakan adanya beberapa faktor seperti adanya pengungsi dari Aceh, para pelaku perambah hutan, adanya praktik *illegal logging*, yang bersumber pada alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketiga, adanya masalah otonomi daerah, dalam hubungannya dengan pengaturan hak masyarakat lokal untuk ikut serta mengelola sumber daya hutan di kawasan Tangkahan, Taman Nasional Gunung Leuser. Selama ini masya-rakat yang hidup di sekitar kawasan Tangkahan, Taman Nasional Gunung Leuser mempunyai tradisi memanfaatkan sumber daya hutan yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Pandangan ini menyebabkan mereka beranggapan mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dengan otonomi daerah yang menjadikan daerah mempunyai hak yang lebih untuk memanfaatkan sumber daya hutan, maka berimbas kepada adanya larangan bagi masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan hutan, sehingga sering menimbulkan konflik.

Keempat, belum adanya pola yang jelas mengenai penyelesaian sengketa antara masyarakat lokal dan negara mengenai pengelolaan sumber daya hutan. Pola-pola penyelesaian yang ditawarkan saat ini masih cenderung berpihak kepada kepentingan pemerintah, atau bahkan belum menyentuh hal yang bersifat mendasar.

Kelima, bila dapat diciptakan konsep dan pola yang jelas dalam pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat lokal, maka konsep dan pola tersebut mungkin dapat diterapkan pula pada Taman Nasional di daerah lainnya di Indonesia.

Taman Nasional Gunung Leuser merupakan salah satu dari lima Taman Nasional yang ditetapkan pertama kali oleh Pemerintah Indonesia pada 1980. Ketika itu Menteri Pertanian mendeklarasikan TN Gunung Leuser, TN Gunung Gede Pangrango, TN Ujung Kulon, TN Baluran, dan TN Komodo seluas total 1,4 juta Ha menjadi Kawasan Taman Nasional.[2]

---

[2]Balai Taman Nasional Gunung Leuser, "Sejarah Taman Nasional Gunung Leuser", (Kuta Cane: Penerbit TNGL, 2004).

Sejarah konservasi di kawasan Leuser dimulai sejak 1914 ketika para pemuka adat Aceh meminta pemerintah Kolonial Belanda untuk melindungi hutan Singkil dan Alas Laden dengan melarang eksploitasi kayu dan aktivitas logging di kawasan tersebut. Pada 1928 seorang ahli geologi (yang juga penanam karet) berkebangsaan Belanda, tuan F.C Van Heurn menyusun sebuah konsep permohonan untuk usaha-usaha perlindungan kawasan di wilayah Aceh Barat, yang disampaikan pada suatu forum "*Netherlandse Commissi Voor Internationale Natuur Bescherming*", tepatnya pada 9 Mei 1928. Pada perkembangan selanjutnya, konsep-konsep ini disempurnakan dan diajukan lagi pada 1932, dan pada 1934 kawasan perlindungan sumber daya alam Gunung Leuser secara resmi ditetapkan. Gubernur Aceh saat itu, Van Aken menetapkan areal seluas 416.500 Ha sebagai kawasan perlindungan. Sementara sumber lain, seperti disebutkan dalam RPTN Gunung Leuser 1995-2020 (Buku I) menyebutkan bahwa untuk pertama kali pada 1934 tuan A. Ph. Van Ahen, Gubernur Aceh saat itu menetapkan secara resmi pembentukan kawasan Suaka Margasatwa Gunung Leuser dengan luas ka-wasan 142.800 Ha melalui Surat Keputusan (Wildreservaat Goenoeng Leoeser) ZB No. 317/35 tanggal 3 Juli 1934.[3]

Kemudian pada 1936, ditetapkan lagi kawasan hutan rawa Kluet seluas 20.000 Ha, dan pada 1938 kawasan perlindungan sumber daya alam ini mengalami penambahan areal melalui penetapan dari Pemerintah Hindia Belanda waktu itu, yaitu dengan pembentukan Suaka Alam Sekundur (79.100 Ha), dan Suaka Alam Langkat Barat dan Selatan (127.075 Ha).[4]

Lebih dari tiga dekade kemudian, dibangun dua buah stasiun yang kemudian berperan penting dalam kebijakan bidang penelitian dan pengembangan, perlindungan, dan ekoturisme di kawasan TNGL. Pada 1972 Herman dan Ans Rijksen, yang berkebangsaan Belanda memulai pembangunan pusat penelitian dan rehabilitasi serta perkembangan/monitoring Orang Utan di Ketambe. Satu tahun kemudian, pusat penelitian Orang Utan lainnya, mulai dirintis oleh Monica Borner dan Regina Frey di Sungai Bohorok, Langkat. Pada 1976 Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertanian menetapkan Suaka Margasatwa Kappi seluas 150.000 Ha.[5]

Pada 6 Maret 1980, pemerintah melalui Menteri Pertanian mengumumkan secara resmi tentang pembentukan Taman Nasional Gunung Leuser dalam forum KTT Bumi.[6]

---

[3]*Ibid*., hlm.3.
[4]*Ibid*.
[5]*Ibid*.
[6]Selanjutnya melalui SK Menteri Pertanian No. 913/Kpts/UM/10/1982 tanggal 30 Oktober 1982, Taman Nasional Gunung Leuser ditetapkan dengan luasan 792.675 Ha. Dan, melalui SK Direktur Jenderal PHPA No. 46/Kpts/VI-Sek/84 tanggal 11 Desember 1984 menetapkan areal Taman Nasional telah bertambah luasan menjadi 862.975 Ha meliputi lima kawasan perlindungan

Dalam perkembangannya Taman Nasional Gunung Leuser melahirkan berbagai masalah, sedikitnya dalam empat bentuk. *Pertama*, masalah yang berkaitan dengan perambahan atau penguasaan lahan yang melibatkan masyarakat lokal. Aktivitas para pengungsi maupun "perambah yang berkedok sebagai pengungsi" ini makin hari makin meresahkan. Kondisi kawasan TNGL menjadi sangat memprihatinkan sehingga mekanisme ekosistem dan habitat satwa serta pengembangan hayati sudah sangat terganggu. Menurut catatan Yayasan Leuser Indonesia (YLI), pengungsi menguasai lahan TNGL rata-rata 10 – 15 rantai tanah (0,5 Ha/KK), sebagai lahan untuk bertanam. Sembilan puluh persen (90%) pengungsi bekerja sebagai pelaku dan buruh *illegal logging*. Dokumentasi YLI yang menyebutkan sebanyak 50 unit *chainsaw* setiap hari beroperasi menghancurkan kawasan TNGL, dengan estimasi volume kayu yang keluar setiap hari sebesar 50 m^3.[7]

Pada waktu Aceh masih dalam keadaan konflik, pengungsi bertambah jumlahnya, mengingat lokasi taman nasional sangat strategis bagi tempat tinggal para pengungsi. Konflik keamanan yang terjadi di wilayah Aceh sebagian besar disikapi oleh masyarakat dengan meninggalkan domisili dan mencari hunian baru untuk menyelamatkan diri. Beberapa di antara kelompok yang eksodus dari Aceh tersebut ada yang berdiam di kawasan TNGL Langkat. Semula komunitas masyarakat yang eksodus dari Aceh menuju kawasan TNGL terbilang kecil, namun belakangan jumlah KK semakin bertambah karena telah terjalin komunikasi dengan para penghuni lama tentang tempat hunian baru di kawasan ini. Seiring berjalannya waktu, masyarakat pengungsi sepertinya mulai senang berdiam di tempat hunian ini. Mereka mulai menanami pekarangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, mereka mulai berpikir untuk mendapat tambahan lain sambil menunggu hasil tanaman pekarangan, yaitu dengan membuka hutan dan mengeksploitasi kayu. Keadaan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain sehingga minat masyarakat untuk eksodus ke wilayah ini dan ikut bermain seperti rekan-rekannya semakin bertambah. Beberapa kemudahan yang menjurus kepada penipuan identitas dilakukan untuk masuk ke areal ini "berkedok sebagai pengungsi", difasilitasi oleh pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan keadaan dan memiliki kepen-

satwa liar di Gunung Leuser, Gunung Kappi, Langkat, Kluet, dan Sikundur, 1 buah areal hutan wisata di Lawe Gurah, serta 2 hutan lindung di wilayah Serbolangit dan Sembabala. Pada 1987, melalui SK Dirjen PHPA No.48/Kpts/DJ-VI/1987 tanggal 12 Desember tentang penunjukan mintakat, diperoleh wilayah berdasarkan pemintakatan ini seluas 802.185 Ha. Sepuluh tahun kemudian melalui SK Menteri Kehutanan No. 276/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997, luas wilayah TNGL yang ditetapkan adalah 1.094.692 Ha. Kemudian luasan ini berubah lagi setelah diterbitkannya Keputusan Presiden No. 33 1998 tanggal 28 Februari tentang pengelolaan ekosistem Leuser, yaitu menjadi seluas 1.097.000 Ha. Mulai 1997, telah banyak dihasilkan bermacam deklarasi melalui pertemuan dengan para alim ulama, tokoh adat, tokoh agama, Pemda, dan tokoh masyarakat di berbagai wilayah TNGL, misalnya adalah Deklarasi Leuser pada 1997, Deklarasi Langkat 1998, Deklarasi Karo 1999, dan Deklarasi Dairi 1999.

[7] *Ibid*.

tingan.[8] Masalah pengungsi, pemukiman dan *illegal logging* sebagian besar terjadi di Damar Hitam, Sei Lepan, Sekoci, Sei Minyak, Tower, Barak Induk, Barak Gajah, Sei Bamban dan Lou Gedang. Pada tahun 2000, sebanyak 38 KK pengungsi melakukan perambahan di kawasan Damar Hitam, Kecamatan Sei Lepan. Berdasarkan laporan pihak YLI pada akhir tahun 2004 sebanyak ± 2000 kk perambah liar (bukan pengungsi) telah menguasai lahan TNGL. Berdasarkan laporan dari petugas lapangan TNGL, terdata 600 KK sebagai perambah liar, dan estimasi luas kerusakan ± 35.000 ha.

Perladangan liar telah lama terjadi di kawasan ini, tercatat mulai marak dan mengancam keberadaan kawasan pada dekade 90-an. Ancaman ini berupa klaim kawasan, dan kemudian berkembang karena para penggarap didukung oleh spekulan lahan.[9]

Kedua, masalah *illegal logging* terutama dalam skala besar yang dilakukan oleh pihak luar (pengusaha) yang melibatkan masyarakat lokal dan didukung oleh oknum aparat. Masyarakat lokal di sekitar lokasi saat ini cenderung sebagai "massa mengambang", yang sebagian menentang keberadaan pengungsi dan perambah ilegal serta sebagian mendukung bahkan ikut terlibat. Masyarakat yang mendukung melihat fenomena ini sebagai alternatif sumber ekonomi baru dalam memenuhi kebutuhan akan lahan dan mendapatkan pendapatan tambahan.

Pemanfaatan tradisional yang diperbolehkan hanyalah pemanfaatan potensi kawasan berupa hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau mempertahankan kebutuhan hidup atau pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakat lokal/setempat/sekitar kawasan konservasi yang dilaksanakan oleh masyarakat lokal/setempat/sekitar Taman Nasional sendiri dengan mempergunakan peralatan tradisional dan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi.[10]

Ketiga, kedua manfaat tersebut di atas mengakibatkan kaburnya hak-hak masyarakat lokal untuk mengelola kawasan hutan di sekitar kampung mereka. Dari sudut pandang wewenang, siapakah yang berhak mengatur dan mengawasi kawasan hutan suatu Taman Nasional. Adakah suatu kebijakan pemerintah pusat terhadap eksistensi Taman Nasional dan hak-hak masyarakat lokal atas

---

[8] *Ibid*.

[9] Pada 12 November 2000 telah dilakukan relokasi pengungsi sebanyak ± 200 KK ke Provinsi Riau. Kegiatan relokasi lainnya pernah dilakukan dengan memindahkan para pengungsi ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan estimasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat, jumlah perambah saat ini mencapai ± 3.000 KK dan jumlah pengungsi lebih dari 400 KK. Pendataan tentang jumlah perambah, pengungsi, dan pemukim dari masyarakat sekitar hutan sulit dilakukan karena penolakan massa untuk memasuki wilayah. Wawancara dengan Wiratno, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Leuser, 26 Juni 2006.

[10] Dikaitkan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kegiatan pemanfatan tradisional dilaksanakan pada zona pemanfaatan tradisional Taman Nasional.

kawasan tersebut, atau apakah kebijakan dan pengawasan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah?

Keempat, bagaimana seharusnya penyelesaian konflik yang timbul di kawasan taman nasional tersebut? Adakah suatu kebijakan untuk mengelola konflik yang lahir antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang atau konflik antara masyarakat dan negara yang timbul di kawasan taman nasional tersebut?

Keempat permasalahan tersebut telah menjadi satu mata rantai yang terkait dengan demikian kuatnya, sehingga diperlukan upaya pemecahan yang terintegrasi, cara pandang yang mengena ke substansi masalah, dan penyelesaian secara menyeluruh dan terpadu oleh semua pihak.

Pihak-pihak yang antara lain mempunyai posisi sentral sebagai pihak yang berkonflik dapat dibedakan:[11]

Pertama, adalah pihak Pengungsi Aceh. Sikap para pengungsi ini secara umum adalah menentang pengusiran paksa atas areal yang telah diusahakan, dan menuntut perhatian negara terhadap jaminan hidup selanjutnya. Seperti halnya masyarakat lokal, sebagian kelompok pengungsi telah teragitasi hingga menuntut status areal yang mereka diami saat ini dilegalkan. Saat ini yang dibutuhkan oleh mereka adalah kejelasan status sosial sebagai bagian dari penduduk yang sah. Sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah bagi mereka apabila harus meninggalkan wilayah TNGL yang mereka diami saat ini. Namun untuk menyambung hidup, mereka terpaksa bertahan dan bersedia melakukan apa saja. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang notabene memiliki modal uang dan pengetahuan untuk memuluskan tujuan mereka mengeksploitasi sumber daya alam dalam pemenuhan lahan untuk perkebunan dan mengambil kayu secara ilegal dari dalam kawasan.

Kedua, adalah pihak perambah ilegal. Kelompok ini adalah para pendatang yang dibayar untuk membuka lahan oleh para cukong. Berlatar belakang kebutuhan ekonomi ditambah pengaruh dari para "aktor intelektual", mereka tidak mengakui wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayah TNGL, menuntut perubahan status, dan pengakuan administratif pemerintah terkait.[12]

---

[11] *Ibid.*

[12] Faktor-faktor penghambat dalam upaya pemecahan masalah diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, belum kondusifnya keamanan di Aceh menjadi alasan bagi sebagian orang yang ingin mandapat lahan. Mereka mengikuti jejak para pendahulu sesama pengungsi yang telah memiliki lahan dan mata pencaharian di tempat baru. Identitas mereka kadang sulit ditelusuri apakah benar-benar pengungsi dari Aceh atau perambah. *Kedua*, tata batas dan tanda batas yang jelas di lapangan mutlak diperlukan untuk menata ulang dan menjamin keutuhan kawasan. Di lapangan saat ini tanda batas sudah banyak yang hilang dan bergeser. Proses hukum ke depan akan sangat tergantung dari kejelasan status kepemilikan kawasan yang direpresentasikan oleh pal batas yang jelas di lapangan.

Ketiga, pemerintah kabupaten dan provinsi di mana kawasan Taman Nasional itu terletak sedang terjadi konflik-konflik, sementara pemerintah pusat yang bertanggung jawab mengelola suatu Taman Nasional. Adakah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan suatu kawasan taman nasional?



Tumpang Tindih dan Konflik Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Sejak implementasi otonomi daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, persoalan utama yang dihadapi dalam pengembangan konservasi di Indonesia adalah pembagian kewenangan pusat dan daerah. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, kewenangan konservasi masih ada di tangan pemerintah pusat, padahal ada banyak inisiatif di tingkat daerah mengenai peraturan pengelolaan kawasan konservasi yang belum terakomodasi oleh pemerintah pusat.

Potensi peranan daerah perlu dipahami, karena secara *de-facto* kawasan-kawasan yang ditetapkan dengan fungsi konservasi (dan juga fungsi lainnya seperti produksi dan lindung) berada di wilayah administratif daerah. Masyarakat di daerah sangat memahami kondisi aktual dan kebutuhan bagi pengelolaan yang terbaik. Di samping itu, karena kawasan konservasi di masa lalu sering kali tidak disertai dengan data dan informasi yang memadai. Dalam

---

Ketiga, lemahnya supervisi pihak TNGL selaku pengelolaan kawasan selama ini menjadi salah satu sebab maraknya perambahan. Hal ini diperparah oleh kurang pahamnya aparatur non kehutanan dalam memandang sistem pengelolaan kawasan. Pola keproyekan dan luncuran dana dari pusat turut menambah kusutnya permasalahan. Kemitraan yang terjalin, yang pada awalnya diharapkan bisa meminimalisasi hambatan dalam pola keproyekan pun belum berjalan selaras. Dalam hal ini masing-masing pihak berjalan sendiri beradu konsep penyelesaian dan kadang melemparkan tanggung jawab begitu saja. Di sinilah menjadi sangat penting untuk selalu mengedepankan upaya penyelesaian kolaboratif dengan memanfaatkan potensi tiap institusi/*stakeholder* terkait. *Keempat*, masalah jangka waktu penyelesaian. Hambatan ini erat kaitannya dengan pola keproyekan dan komitmen *stakeholder* dalam penyelesaian masalah secara tuntas. Sering schedule yang telah tersusun tidak bisa berjalan karena terhambat dalam hal pendanaan dan inkonsistensi prioritas kegiatan oleh insitusi tertentu. Padahal tuntasnya masalah ini butuh konsistensi dan jaminan kelancaran perangkat pendukungnya. Pada akhirnya para objek pelaku baik aktor intelektual/pemodal maupun para pelaku di lapangan semakin berani menjalankan aksinya karena menganggap semua ini hanya proyek yang akan selesai pada waktunya tanpa ada kelanjutan. *Kelima*, keterlibatan oknum pemerintah. Hasil investigasi menunjukkan bahwa sebagian aktor pelaku adalah oknum pemerintah yang jelas-jelas telah menyalahgunakan kekuasaan untuk memuluskan aksi mereka. Pengungsi, perambah, dan masyarakat lokal hanyalah objek yang dimanfaatkan oleh oknum ini dengan memanfaatkan kondisi mereka yang lemah secara ekonomi. Penegakan hukum perlu secara tegas diberikan kepada mereka bahkan perlu dipublikasikan kepada khalayak sebagaimana seorang koruptor yang jelas-jelas telah merugikan negara dan membohongi masyarakat. Wiratno, "Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser", makalah disampaikan pada Shared Learning," Tangkahan: Pusat Informasi Lingkungan Indonesia bekerja sama dengan CIFOR, 22 Juni 2006.

kondisi tanpa kewenangan, maka mengomunikasikan kepentingan konservasi keanekaragaman hayati dengan kepentingan kehidupan masyarakat di dalam dan di luar kawasan menjadi sulit dilaksanakan oleh daerah.[13]

Konservasi sumber daya alam hayati dakam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuannya untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.[14]

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa peraturan konservasi masih merupakan kewenangan pemerintah pusat. Peraturan ini menunjukkan secara jelas bahwa belum terjadi desentralisasi di bidang konservasi, padahal banyak inisiatif di tingkat kabupaten dan masyarakat yang dapat melengkapi peraturan konservasi tersebut. Pengelolaan sentralistik diperparah oleh proses perencanaan, penataan kawasan, perlindungan dan pengawasan dan berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konvensi yang sering kali dikembangkan secara tidak transparan oleh pemerintah pusat. Dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pengelolaan konservasi sangat rendah.[15]

Konservasi dalam perspektif Undang-Undang Konservasi Nomor 5 Tahun 1990 dijabarkan dengan berbagai bentuk pengelolaan kawasan yang mencakup Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Cagar Biosfer dan Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam). Dalam pengelolaan ketiga bentuk kawasan ini sama sekali tidak dicantumkan bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut. Masyarakat hanya dilibatkan sebagai peserta untuk diberi pendidikan dan penyuluhan mengenai konservasi.

Konsep pengelolaan bersama dengan masyarakat dan pihak pemerintah daerah sebenarnya telah dicoba di beberapa Taman Nasional yang ada di Indonesia. Taman Nasional Kayan Mentarang, Kalimantan Timur misalnya, telah mengembangkan manajemen kolaboratif dengan melibatkan pihak kabupaten dan masyarakat setempat untuk pengelolaan bersama lewat Forum Musyawarah Masyarakat Adat.

---

[13]Ciriacy Wantrup, "Common Property as A Concept in Natural Resources Policy, "Natural Resources Journal, 1975, hlm. 713-737.

[14]Dixon, J.A dan Paul B. Sherman, *Economic of Protected Areas: A New Look at Benefit and Cost*, (London: East-West Center, 1990), hlm. 15-16.

[15]*Ibid.*

Merujuk perspektif yang termuat dalam peraturan tersebut, ada beberapa hal di tingkat daerah dan masyarakat yang perlu dicermati, terutama bagi pemerintah pusat untuk meninjau kembali peraturan yang ada. Masalah tersebut antara lain:

Pertama, masyarakat sekitar kawasan konservasi masih kurang dilibatkan dalam pengelolaan bersama kawasan konservasi. Bahkan dianggap sebagai musuh yang selalu merambah kawasan. Oleh karenanya adanya asumsi harus diberi pendidikan dan penyuluhan mengenai konservasi.

Kedua, pola insentif yang dikembangkan untuk pengelolaan bersama tidak jelas arah dan tujuannya. Pemerintah hanya berharap masyarakat dapat membantu memelihara kawasan saja tanpa adanya perjanjian yang jelas. Jika terjadi masalah terkait dengan kawasan tersebut, masyarakat merasa tidak bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapi.

Ketiga, Di lapangan telah terjadi tumpang tindih peraturan pusat dengan daerah, terutama dalam masa desentralisasi ini. Permasalahan yang timbul terkait dengan pengelolaan kawasan, tata ruang wilayah dan pemanfaatan lahan. Pemerintah daerah setempat dengan semangat desentralisasi merasa memiliki untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya.

Keempat, pandangan bahwa belum adanya contoh kegiatan konservasi yang dapat memberikan andil nyata kepada pemerintah daerah setempat dan masyarakat dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkaitan dengan hal ini, perlu dijelaskan adanya beberapa kegiatan konservasi yang dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat seperti ekowisata, penelitian berdampak bagi masyarakat, dan kegiatan sejenis lainnya.

Keempat permasalahan tersebut di atas mulai berkembang secara intensif setelah era otonomi daerah. Ironisnya, perkembangan isu ini tidak diimbangi dengan kemauan daerah untuk meningkatkan kegiatan konservasi, tetapi karena mau meningkatkan perkembangan daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal. Permasalahan yang muncul di tingkat daerah berkaitan dengan kawasan konservasi yang masih dikelola oleh pusat antara lain: Taman Nasional, Cagar Alam, Hutan Wisata dalam era otonomi ini semakin meluas dan parah terkait dengan pembagian kewenangan tersebut. Munculnya kepentingan yang berbeda antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Di satu sisi pemerintah pusat lebih mempertahankan kawasan konservasi sesuai dengan pembentukannya, sedangkan pihak daerah dengan konsep "pembangunan" untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PAD berusaha untuk melepaskan kawasan tersebut dari kawasan hutan negara. Sementara itu, masyarakat yang berada di sekitar kawasan merasa berhak untuk dapat menikmati hasil dari kawasan tersebut dalam masa desentralisasi.

Adanya pengakuan secara hukum di tingkat pemerintah daerah atas upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung kegiatan konservasi, menunjukkan adanya kebijakan daerah untuk membantu masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan konservasi. Kebijakan tersebut seharusnya didukung dan ditegakkan oleh Departemen Kehutanan yang dapat memberikan masukan konsep-konsep pengelolaan hutan secara nasional yang selanjutnya dijabarkan oleh pihak daerah sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.

Departemen Kehutanan dan pemerintah daerah sebenarnya memiliki konsep konservasi dasar yang sama, yaitu memberikan perlindungan dan pengawetan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Dari aspek pemanfaatan Departemen Kehutanan memberikan zona pemanfaatan dalam kawasan konservasi bagi masyarakat secara terbatas. Sedangkan pemerintah daerah memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat untuk mengembangkan kawasan konservasi lokal dengan berbagai model pengelolaan dan peruntukannya.

Dari aspek pendekatan kebijakan, Departemen Kehutanan cenderung bertindak secara *'top down'* tanpa memerhatikan kebutuhan yang diperlukan di lapangan. Pendekatan ini mengakibatkan munculnya permasalahan di kawasan konservasi, baik dengan pemerintah setempat maupun masyarakat, antara lain konflik pemanfaatan kawasan baik dengan masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Sementara pemerintah daerah berusaha mengembangkan konsep *'bottom up'* yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan konservasi lokal, yang kemungkinan terpaksa mengakomodasi masyarakat dengan peraturan yang dibuatnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi dasar bagi daerah untuk mengelola otonom kehutanan di tingkat daerah. Dinas Kehutanan baik provinsi maupun kabupaten dan kota dapat berperan aktif untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di pusat, daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan yang mendukung kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengacu pada kebijakan pusat. Demikian juga dapat menjabarkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah yang diperlukan dalam hal ini kebijakan konservasi. Adanya pembagian peran tersebut, maka upaya penyelesaian konflik yang terjadi selama ini dapat teratasi.

Berkaitan dengan permasalahan pembagian peran dan koordinasi yang menjadi kendala utama yang dihadapi oleh Departemen Kehutanan, pemerintah daerah dan masyarakat dalam kegiatan konservasi, diperlukan suatu mekanisme yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh Departemen Kehutanan maupun oleh pemerintah daerah adalah mekanisme konsultasi publik yaitu suatu rangkaian proses yang dijalankan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang

berkepentingan sebagai lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat, kalangan perguruan tinggi, masyarakat dan pihak lain yang memiliki inisiatif yang sama dalam pembuatan kebijakan kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan konservasi.

Sejak era otonomi daerah mulai bergulir, persoalan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan konservasi di Indonesia adalah pembagian kewenangan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pada akhir tahun 80-an dan sepanjang dekade tahun 90-an, gerakan rakyat di tingkat lokal yang melawan ketidakadilan dalam pelaksanaan pembangunan meningkat tajam. Kasus yang mencuat bervariasi dari kasus individual, keluarga, sampai yang melibatkan sebuah komunitas lokal, baik itu berbentuk suku, kampung maupun beberapa kampung sekaligus.[16] Seiring dengan itu, menjamur pula organisasi-organisasi non-pemerintah[17] yang melakukan advokasi "pembelaan"[18] hak-hak rakyat dan penyelamatan lingkungan. Dan dengan itu merebak pula isu yang dibawa dalam kasus-kasus itu. Pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, otonomi daerah dan desa, dan kebijakan-kebijakan negara.

Otonomi yang mencakup kontrol atas wilayah adat dan sumber daya agraria, *self-governance* dan ekspresi hak-hak sosial budaya merupakan substansi yang tak terpisahkan meskipun dapat dibedakan. Dinamika internal dari ketiga faktor ini dan interaksi dengan pihak lain melahirkan apa yang disebut identitas sebagai sebuah proses. Menguraikan ketiga hal itu sebagai bagian sendiri-sendiri hanya akan melahirkan paham identitas sebagai sesuatu yang terberi dan rigid. Pemahaman seperti ini bermuara pada dikotomi "kita" dan "mereka" yang potensial konflik. Sementara melihat ketiga faktor itu sebagai sebuah makna "tritunggal" akan melahirkan sebuah masyarakat yang siap bertransformasi dalam proses.

---

[16]Data kasus konflik agraria yang dikeluarkan oleh KPA yang merekam sengketa agraria di Indonesia sejak 1953 sampai dengan 2000, berjumlah 1455 kasus, melibatkan 242.088 Keluarga, 533.866 jiwa dan lahan seluas 1.456.773 hektar yang merupakan lahan masyarakat adat dan lokal. Lawan masyarakat dalam seluruh konflik ini adalah pemerintah, perusahaan negara, dan perusahaan swasta. Ini menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia antara masyarakat adat dan lokal dengan pemerintah dan para pemilik modal adalah konflik struktural akibat pengambil-alihan hak masyarakat oleh negara untuk para pemilik modal. Sampai tingkat tertentu dapat disaksikan dalam data tersebut bahwa aparat negara selalu menjadi pihak yang diperhadapkan dengan masyarakat. Dalam seluruh kasus ini pandangan bahwa negara adalah alat bagi kapitalisme untuk menguasai sumber daya agraria di dunia mendapat pembenaran yang signifikan, baik dari aspek legislasinya maupun dalam operasionalisasi peraturan perundangannya.

[17]Dapat dilihat dalam "*Prosiding Seminar SMERU; Wawasan Tentang LSM Indonesia: Sejarah, Perkembangan Serta Prospeknya*"; 15 Agustus 2000. Dalam uraian tentang perkembangan LSM di Aceh sebagai salah satu daerah yang dikaji, tampak bahwa dalam era 70-an baru ada beberapa LSM di Aceh. Dalam era 80-an berkembang menjadi belasan dan dalam 90-an telah ada puluhan LSM di Aceh. Perkembangan ini berjalan melalui proses "membelah diri", sebuah istilah yang diambil dari khazanah biologi tentang pembelahan sel atau organisme mikro.

[18]James Petras dan Henry Veltmeyer, *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century*, dalam edisi terjemahan, (Jakarta: Kreasi Wacana, 2002), hlm. 235-257.

Transformasi yang bagaimana kiranya tak perlu diragukan lagi, yakni merengkuh cita-cita pembebasan. Pembebasan yang berarti merebut otonomi yang ditandai oleh otonomi dalam ketiga faktor tersebut: keleluasaan untuk mengurus diri sendiri, hak atas tanah dan sumber daya agraria dalam wilayah yang diklaim sebagai ruang hidup mereka dan kemerdekaan (bukan kebebasan) mengekspresikan hak-hak sosial budaya. Dan jika ini yang menjadi makna dari isu gerakan *indigenous peoples* dan sejauh ini dapat dibaca demikian, maka secara substansial ada persambungan yang sangat kuat antara kedua terminologi itu.

Dengan demikian, masyarakat adat semestinya dipahami sebagai sebuah kategori politis yang ditentukan oleh rangkaian terpadu (integral) masa lalu, kekinian dan tujuan atau cita-cita politiknya dan model-model perjuangannya.

Kedua, identitas yang dipahami dengan baik dalam lingkup masyarakat adat maupun oleh pihak di luar masyarakat adat adalah landasan utama dalam mengusung cita-cita pembebasan yang disebutkan di atas: Kedaulatan mengurus diri sendiri atau secara lebih berkerangka disebutkan sebagai "otonomi komunitas masyarakat adat" yang dicirikan oleh *self-governance*, hak atas tanah dan sumber daya agraria, dan hak-hak sosial budaya.

Keleluasaan untuk mengurus diri sendiri (*self-governance*) adalah sebuah "warisan sejarah politik" dalam komunitas-komunitas masyarakat adat. Disebut warisan politik karena sistem pengurusan diri sendiri itu lahir dan bertumbuh dari sebuah proses internal dan interaksi yang lama dengan lingkungan dan komunitas masyarakat sekitar. Dalam beberapa contoh yang disebutkan di atas dapat ditemukan apa yang disebut sebagai hukum adat, lembaga adat dengan strukturnya masing-masing dan wilayah adat. Dan di atas itu ada orang-orang anggota komunitas tersebut yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunitas itu. Dengan adanya wilayah, hukum dan lembaga serta masyarakatnya sendiri, maka bukan sebuah keanehan bahwa mereka kemudian harus memiliki sistem pengurusan diri sendiri.

Otonomi itulah yang membentuk mereka menjadi sebuah entitas politik dengan hak-hak yang melekat atau bawaan dan bukan hak-hak berian. Dalam sistem penyelenggaraan Negara Indonesia selama ini, terjadi perampasan atau pengambilalihan hak-hak itu. Pengambilalihan hak bawaan ini kemudian dipolitisasi menjadi pengaturan hak-hak berian oleh negara. Inilah sejarah kelam komunitas-komunitas masyarakat adat ketika diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979. Celakanya, setelah UU ini dicabut dan tidak diberlakukan lagi dengan dikeluarkannya UU No. 22/1999 dan kemudian UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, paradigma hak bawaan dan hak berian terhadap komunitas masyarakat adat tidak berubah. Masih tetap dengan paradigma lama, yaitu mencerabut hak bawaan masyarakat adat dan lokal, kemudian diperlakukan sebagai hak berian negara. Ini jelas terlihat dalam konsep hak atas tanah.

Hak atas tanah dan sumber daya agraria lainnya sesungguhnya telah cukup jelas arahnya dalam TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Agraria. Pasal 6 TAP ini menyatakan bahwa arah kebijakan pembaruan agraria antara lain adalah:[19]

> "Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini" (ayat 1 butir a);
>
> "Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini" (ayat 1 butir b)
>
> "Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini" (ayat 1 butir d).

Sementara arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya agraria antara lain adalah:[20]

> "Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini" (ayat 2 butir a);
>
> "Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya agraria di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional" (ayat 2 butir c); dan
>
> "Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini (ayat 2 butir e)."

---

[19]Pasal 6 TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Agraria.

[20]*Ibid.*, Pasal 5.

Meskipun arah reformasi agraria dan pengelolaan sumber daya agraria sudah cukup jelas dalam TAP tersebut, namun dalam pelaksanaannya konsistensi pemerintah dalam mewujudkan amanat TAP tersebut masih sangat lemah. Bahkan dapat dikatakan tidak ada kemauan politik pemerintah untuk melaksanakannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejumlah kebijakan politik yang lahir setelah ditetapkannya TAP No. IX/2001 tersebut. UU No. 19/2004 yang memberikan izin bagi pertambangan di hutan lindung; Perpres 36/2005 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang telah direvisi namun tidak meninggalkan roh eksploitasi hak rakyat banyak dalam Perpres No. 65/2006. Pasal 13 Perpres 65 ini misalnya, menyatakan bahwa ganti rugi yang diberikan bisa berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali dan atau gabungan dari itu atau bentuk ganti rugi yang lain. Kedua peraturan perundangan ini dibuat dalam dua tahun terakhir, yang berarti *setelah* penetapan TAP IX/2001.

Inkonsistensi ini dengan mudah dapat terjadi di Indonesia, karena pada tataran konstitusi masih terdapat pengakuan bersyarat terhadap masyarakat adat, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 18 B dan Pasal 28 I Amandemen II UUD 1945, di mana persyaratan sepanjang masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan diatur dengan undang-undang telah membuka ruang manipulasi politik hukum terhadap masyarakat adat. Tidak mengherankan jika kita kemudian melihat kondisionalitas yang sama dalam UUPA 1960 dan bahkan yang lebih buruk lagi adalah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU Pertambangan dan berbagai peraturan organik, termasuk Perpres 36/2005 dan Perpres No. 65/2006 yang telah disebutkan di atas.

Pengelolaan hutan secara umum dan khusus dalam rangka pengelolaan keanekaragaman hayati hutan di Indonesia berlandaskan pada berbagai kebijakan mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Keputusan/Surat Edaran Direktur Jenderal. Kebijakan pemerintah yang telah dibuat merupakan landasan bagi seluruh *stakeholder* (aparat pemerintah, pengusaha, LSM, masyarakat akademis dan umum) dalam melaksanakan pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya secara berkelanjutan.

Berbagai ancaman terhadap kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Dualisme kebijakan pemerintah antara mengkonservasi dan mengeksploitasi sumber daya hutan baik inter maupun antardepartemen, sering mengakibatkan upaya konservasi sering dikalahkan oleh upaya eksploitasi.

Kedua, Kuatnya egosektoral (inter dan antarsektoral) telah mengakibatkan banyak kawasan hutan (produksi dan konservasi) yang harus berubah fungsi

untuk kegiatan pembangungan di sektor lain, contoh kasus antara Departemen Kehutanan dengan Departemen Pertambangan kaitannya dengan pemanfaatan kawasan konservasi yang terdapat bahan tambang potensial di dalamnya. Pertimbangan atas nilai ekonomi bahan tambang dan ketidakmampuan mengungkapkan nilai ekonomi kawasan konservasi, akan menjadi ancaman bagi keutuhan kawasan-kawasan konservasi yang di dalamnya terdapat bahan tambang yang potensial.

Ketiga, Kebijakan dalam penentuan kawasan sebagai hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung lebih mendasarkan pada kondisi lahan (jenis tanah, kelerengan, curah hujan) dan tidak mendasarkan pada potensi dan kepentingan keanekaragaman hayatinya, sehingga hutan dataran rendah yang memiliki kekayaan keanekaragaman paling tinggi justru dialokasikan sebagai hutan produksi, bahkan dialokasikan untuk dikonversi bagi pembangunan sektor lain (perkebunan, transmigrasi).

Keempat, Kebijakan pengelolaan hutan yang mengakibatkan tertutupnya akses masyarakat lokal terhadap kawasan hutan (produksi dan konservasi), telah mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat lokal.

Kelima, Pengalihan kewenangan pengelolaan hutan kepada daerah ternyata telah mengakibatkan semakin maraknya eksploitasi hutan yang tidak lagi mengindahkan aspek-aspek kelestarian. Hal ini dapat terjadi karena kesadaran para pejabat pemerintah daerah untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati dan melestarikan sumber daya hutan masih rendah. Keinginan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mudah dan cepat telah mengakibatkan meningkatnya eksploitasi hutan (seperti terjadi di Riau dan Kalimantan Timur), tanpa mengindahkan aspek kelestarian.

Keenam, Kebijakan pemerintah dalam memberikan izin industri kayu yang izin ini diberikan *bukan oleh* Departemen Kehutanan telah mengakibatkan permintaan kayu nasional lebih besar daripada pasokan legal (Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri, Izin Pengelolaan Kawasan) sehingga marak terjadi pencurian kayu (pasokan kayu ilegal) untuk memenuhi kebutuhan kayu nasional tersebut.

Ketujuh, Keberpihakan pemerintah kepada konglomerat (pengusaha) dalam pengelolaan hutan telah menimbulkan 'dendam dan sakit hati' bagi masyarakat lokal yang merasa juga berhak memiliki hutan, sehingga setelah reformasi bergulir, sebagian masyarakat lokal berlomba untuk memperoleh haknya kembali dengan memanen hasil hutan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selama ini masyarakat hanya diperlakukan sebagai penonton terhadap eksploitasi hutan di daerahnya, yang telah memberikan kekayaan yang sangat besar bagi pengusaha.

Kedelapan, Tidak terjaminnya kepastian usaha dalam pengusahaan hutan (bagi HPH) mengakibatkan terjadinya eksploitasi habis-habisan (over eksplitasi) oleh para pengusaha HPH untuk memperoleh keuntungan sebanyak-

banyaknya dalam waktu singkat dan untuk mengimbangi (membayar) pungutan-pungutan baik yang sifatnya resmi maupun tidak resmi.

Kesembilan, Kayu hutan tidak ditetapkan sebagai aset tetap dalam pengusahaan hutan sehingga untuk memperoleh keuntungan maksimal maka HPH mengekploitasi hutan habis-habisan.

Kesepuluh, Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menilai kinerja sebuah HPH tidak berdasarkan pada kondisi hutan paska eksploitasi tidak berdasar pada kelestarian hutan, tetapi lebih kepada akuntansi kehutanan. Kinerja dikatakan baik jika akuntabilitasnya tinggi. Untuk memperoleh akuntabilitas yang tinggi maka HPH akan cenderung untuk memperbesar eksploitasi.

Di samping kesepuluh kebijakan yang menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan sumber daya hutan, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya masalah tumpang tindih tersebut.

Pertama, penggabungan banyak HPH yang kinerjanya buruk di luar Jawa dengan PT INHUTANI (I sampai V) semakin memperparah kerusakan hutan yang terjadi karena pada kenyataannya di lapangan mereka juga (para pemegang HPH) yang masih melaksanakan eksploitasi ditambah beban harus berbagi hasil dengan PT INHUTANI.

Kedua, kegiatan AMDAL, yaitu kebijakan yang mewajibkan HPH melaksanakan perlindungan terhadap flora fauna (terutama yang dilindungi), pengalokasian dan pengelolaan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, pada kenyataannya masih bersifat formalitas, implementasi dan monitoringnya di lapangan masih sangat kurang. Sanksi dan penegakan hukum bagi HPH yang melanggar ketentuan ini juga masih lemah. Hal ini mengakibatkan HPH tidak peduli terhadap keberadaan satwa dan tumbuhan yang dilindungi yang berada di dalam areal konsesinya.

Ketiga, kawasan konservasi di Indonesia sangat luas dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang selama ini dikelola secara sentralistik, mempunyaii banyak kelemahan terutama dalam perlindungan dan pengamanannya. Keterbatasan sumber daya manusia, dana, prasarana dan sarana yang lainnya, mengakibatkan tidak kemampuannya dalam menanggulangi gangguan terhadap kawasan maupun perburuan liar.

Keempat, konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yang dilaksanakan selama ini masih cenderung kepada perlindungan dan pengawetan, belum mengarah kepada aspek pemanfaatan sehingga konservasi masih dianggap sebagai kegiatan yang memerlukan banyak dana sehingga sering dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis pemanfaatannya untuk kepentingan lain.

Kelima, masih sangat kurangnya *penilaian ekonomi* terhadap kawasan konservasi secara *integrated* telah mengakibatkan kawasan ini sering dikalahkan oleh kepentingan lain (oleh sektor) lain yang merasa mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi.

Keenam, euforia reformasi bagi sebagian masyarakat lokal yang tadinya aksesnya terhadap sumber daya hutan tertutup, telah mengakibatkan masyarakat merasa punya hak dan bebas memanen hasil hutan sesuai dengan keinginan mereka.

Ketujuh, masih lemahnya penegakan hukum bagi para perambah kawasan hutan (konservasi, produksi dan hutan lindung), mengakibatkan perambahan hutan cenderung terus meningkat.

Kedelapan, pengawasan peredaran satwa dan tumbuhan juga masih lemah. Selain itu adanya kesulitan untuk menelusuri asal tumbuhan dan satwa yang diperdagangkan apakah berasal dari hasil penangkaran atau tangkapan alam (perburuan liar).

Kegiatan sektor-sektor lainnya seperti Departemen Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum telah menyebabkan dampak terhadap keanekaragaman hayati yang harus dipertimbangkan. BAPPENAS sebagai perencana pembangunan nasional dan BAPPEDA di provinsi dan kabupaten juga memiliki tanggung jawab kunci untuk konservasi keanekaragaman hayati. LSM-LSM Indonesia telah memainkan peran aktif dalam merangsang ketertarikan umum dalam isu-isu keanekaragaman hayati. Di Indonesia terdapat lebih dari 400 LSM di seluruh nusantara yang bekerja bersama masyarakat lokal untuk menekan perusakan dan degradasi habitat alam, seperti rehabilitasi mangrove, pembinaan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, penelitian-penelitian dan kajian keanekaragaman hayati dan kegiatan-kegiatan konservasi yang lainnya.[21]

Hambatan serius bagi keefektifan program-program konservasi ditinjau dari kelembagaan adalah banyaknya lembaga yang bertanggung jawab secara langsung pada perlindungan keanekaragaman hayati dan kurang terkoordinasikannya lembaga-lembaga tersebut di dalam merencanakan dan melaksanakan program aksi konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu dengan bergulirnya desentralisasi, maka diperlukan suatu mekanisme yang tepat yang mengatur keterkaitan antara lembaga yang ada di pusat dan yang di daerah di dalam program pengelolaan keanekaragaman hayati.

Secara umum pendanaan untuk pengelolaan sumber daya hayati masih sangat terbatas, terutama semenjak krisis ekonomi tahun 1997, pendanaan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati ini semakin terbatas. Pendanaan yang semakin terbatas ini sebagian besar dialokasikan ke kantor pusat dan taman nasional, yang alokasinya sebagian besar digunakan untuk membayar gaji staf. Bantuan pendanaan dari lembaga-lembaga donor secara umum juga masih terkonsentrasi pada kawasan taman nasional, ini pun tidak tersebar

[21]Chip Fay & Martua Sirait, *Mereformasi Para Reformis di Indonesia Pasca Soeharto*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 156-158.

secara merata, sedangkan pendanaan untuk kawasan konservasi yang lain masih sangat terbatas.[22]

Jumlah sumber daya manusia yang memadai secara kuantitas dan kualitas dalam pengelolaan keanekaragaman hayati juga masih terbatas dan belum tersebar merata. Hal ini juga menjadi hambatan besar di dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Apalagi jika dikaitkan dengan desentralisasi, maka jumlah dan kualitas sumber daya hayati di daerah yang dapat diandalkan dalam pengelolaan sumber daya hayati juga semakin terbatas.



Penyelesaian Kolaboratif Sebagai Solusi Terbaik

Perkembangan pendekatan kolaborasi di Indonesia atau kemitraan istilah yang populer di Indonesia secara konseptual dan praktik sebenarnya telah menjadi perdebatan dan pengkajian yang intensif. Di Indonesia pada awal 1990-an, manajemen kolaborasi yang lebih dikenal sebagai pola kemitraan sering dikonotasikan dengan manajemen inti-plasma antara petani dengan perusahaan perkebunan atau model bapak angkat antara pengusaha kecil dan pengusaha besar.[23]

Jika dilihat dari sejarahnya, perkembangan pendekatan kolaborasi mulai muncul sebagai respons atas tuntutan kebutuhan akan manajemen pengelolaan sumber daya yang baru, demokratis, lebih mengakui perluasan yang besar atas dimensi manusia dalam mengelola pilihan-pilihan, mengelola ketidakpastian, mengelola kerumitan dari potensi keputusan dan membangun kesepahaman, dukungan, kepemilikan atas pilihan-pilihan bersama.[24]

Oleh karena itu, pendekatan kolaborasi ini sering disebut sebagai jembatan (*bridges*) untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Sebagai jembatan penyeberangan yang berfungsi mengintegrasikan batas-batas yang dibatasi oleh geografi, kepentingan dan persepsi.[25]

Secara lebih spesifik, Wondolleck dan Yaffee misalnya, melihat pendekatan proses kolaborasi dari segi empat kegunaan utamanya, yaitu:[26]

Pertama, membangun pemahaman melalui peningkatan pertukaran informasi dan gagasan antara pemerintah, organisasi dan publik serta memberikan

---

[22]Sumardja, *Beberapa Sumbangan Pemikiran Untuk Pembentukan Sistem Taman Nasional*, (Michigan: School of Natural Resources The University of Michigan, 1997), hlm. 40.

[23]Suporahardjo, *Strategi dan Praktik Kolaborasi: Sebuah Tinjauan*, (Bogor: Pustaka LATIN, 2005), hlm. 3.

[24]Julia M. Wondolleck dan Steven L. Yaffee, *Making Collaboration Work: Lesson from Innovation in Natural Resource Management*, (California: Island Press, 2000), hlm. 14.

[25]Ibid., hlm. 12.

[26]Suporahardjo, *Manajemen Kolaborasi: Memahami Plurasisme Membangun Konsensus*, (Bogor: Pustaka LATIN, 2005), hlm. 5.

suatu mekanisme untuk penyelesaian ketidakpastian.

Kedua, memberikan suatu mekanisme untuk pembuatan keputusan yang efektif melalui proses-proses yang memfokuskan pada problem bersama dan membangun dukungan untuk keputusan.

Ketiga, menghasilkan suatu alat untuk membuat kerja yang bagus melalui koordinasi aktivitas lintas batas, meningkatkan manajemen bersama, dan memobilisasi suatu perluasan skenario sumber daya.

Keempat, pengembangan kapasitas lembaga pemerintah, organisasi dan komunitas untuk menghadapi tantangan-tantangan masa depan.

Ada tiga pola kemitraan yang munghkin terjadi pada organisasi seperti yang diidentifikasi oleh Huxham dan Macdonald, yaitu: 1) koordinasi, di mana mungkin tidak ada interaksi langsung antara organisasi, tetapi di mana organisasi mempertimbangkan kegiatan pihak yang lain dalam perencanaan yang dimilikinya; 2) Co-operation (kerja sama), di mana organisasi berinteraksi untuk mencapai misinya yang dimiliki mereka dan tujuan yang lebih efektif; 3) *collaboration* (kolaborasi) di mana organisasi bekerja sama untuk mencapai suatu meta-misi sementara juga mengejar misi dan tujuan yang bersifat individual yang mereka miliki.[27]

Di dalam konteks pengelolaan sumber daya alam pola kemitraan dikenal dengan skema *"joint management"* atau *"co-management"*, atau *"collaborative management"*. Kemitraan biasanya didefinisikan sebagai tanggung jawab dan/atau kewenangan antara pemerintah dan pengguna sumber daya lokal dalam mengelola sumber daya tertentu.[28]

Spektrum manajemen kemitraan ini dapat dikelompokkan dalam beberapa tipe. *Pertama*, bersifat instruksi di mana ada pertukaran informasi yang minimal antara pemerintah dan pengguna.

Kedua, bersifat konsultasi, di mana ada mekanisme untuk pemerintah mengkonsultasikan dengan pengguna, tetapi seluruh keputusan masih dibuat oleh pemerintah.

Ketiga, bersifat bekerja sama (*cooperative*) di mana pemerintah dan pengguna bekerja sama bersama-sama sebagai partner yang setara di dalam pembuatan keputusan. Tipe ini yang disebut sebagai pola kemitraan yang sesungguhnya.

Keempat, bersifat menasihati (*advisory*), pengguna memberikan saran kepada pemerintah atas sebuah keputusan yang seharusnya diambil dan pemerintah mendukung keputusan itu.[29]

---

[27]*Ibid.*, hlm.7.
[28]*Ibid.*, hlm.8.
[29]Jamie Ferguson dkk," Seminar Prospektus: Co-management and Resolving Conflict in Environmental Management," dalam website: www.uogelph.ca/-jford01/6280/prospectus.pdf. hlm. 5.

Kesuksesan dalam mempraktikkan pendekatan penyelesaian kolaborasi ini oleh Wondollack dan Yaffee, disebabkan karena beberapa alasan.[30]

Pertama, kolaborasi dapat berjalan sukses bila dapat membangun *common ground* (pandangan yang sama), kepentingan bersama atau menemukan cara menjembatani kecocokan kepentingan yang masih berbeda.

Kedua, pentingnya menciptakan kesempatan baru untuk berinteraksi. Misalnya melalui upaya membangun jalur komunikasi baru dan menetapkan struktur baru, baik melalui mekanisme formal maupun informal.

Ketiga, pentingnya melibatkan *stakeholder* ke dalam proses interaksi, bukan hanya produk akhir. Diyakini bahwa interaksi yang intensif dan berkualitas dalam proses pembuatan keputusan akan menghasilkan keputusan yang efektif dan menghasilkan kepuasan seluruh stakeholder.

Keempat, pentingnya memfokuskan mengatasi problem dengan cara-cara baru dan berbeda. Kebanyakan kolaborasi berhasil karena ada kemauan mencoba perilaku baru dan cara-cara berbeda dalam berinteraksi.

Kelima, pentingnya meningkatkan kepekaan terhadap tanggung jawab dan komitmen. Para pihak yang terlibat dalam kerja kolaborasi harus bekerja keras untuk mentransformasikan mereka (*them*) menjadi kami (*us*). Tantanganya adalah bagaimana menghentikan secara cepat dari situasi permusuhan di antara para pihak dan membantu terlibat dari pernyataan diri sebagai musuh menuju layaknya hidup bersama sebagai tetangga, yang akhirnya harus berkolaborasi.

Keenam, bentuk inti dari kemitraan yang kolaboratif adalah hubungan (*relationship*) antara individu-individu, bukan antara organisasi. Sehingga disimpulkan bahwa kemitraan adalah orang-orang yang bergabung berdasarkan hubungan. Karena oranglah yang dianggap mewakili lembaga pemerintah, organisasi atau pekerjaan di dalam suatu proses kolaborasi.

Ketujuh, banyak kasus kemitraan kolaboratif sukses karena upaya-upaya yang penuh dengan pengabdian, energik secara individual dengan pendekatan pro aktif dan berani memulai dengan upaya-upaya baru.

Kedelapan, banyak kasus kemitraan kolaboratif sukses karena orang-orang berusaha mendapatkan dan mengakui pihak lain. Mereka mengusahakan dana dari luar dan mendaftar bantuan-bantuan yang dapat membantu mengelola proses interaksi antara kelompok ketika mereka tidak mempunyai keahlian atau tidak yakin bagaimana memulainya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses resolusi konflik diambil melalui kegiatan fasilitasi secara intensif untuk mendapatkan strategi penyelesaian melalui pola kolaboratif, yaitu:[31]

---

[30]Wondollack dan Yaffee, *op. cit*., hlm. 16.

[31]Suporahardjo, dkk, *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*, (Bogor: Pustaka LATIN, 2000), hlm. 17-19.

1. Merumuskan persepsi dan kronologis konflik secara lengkap.

   Sejarah kejadian yang lengkap menjadi dasar analisis untuk mendapatkan visi, misi, serta melakukan jajak pendapat antar*stakeholder*. Cara pandang masing-masing *stakeholder* menjadi dasar untuk memunculkan komit-men bersama, mencari alternatif penyelesaian terbaik.

2. Menggulirkan konsep *Konsesi Rehabilitasi Terpadu* sebagai solusi utama.

   Pada tahap ini kelompok konservasi diharapkan muncul untuk menawarkan konsep rehabilitasi guna memulihkan kondisi dan menjaga keutuhan kawasan TNGL.

3. Membangun kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

   Kolaborasi dibutuhkan untuk mengawal proses penyelesaian, berbagi beban kerja, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengambil peran. Lebih penting lagi dari semua itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan mengaktualisasikan komitmen yang telah terbentuk pada tahap sebelumnya.

4. Tahapan pelaksanaan secara legal formal.

   Tahapan ini dilakukan setelah terjadi penguatan organisasi dalam bentuk manajemen kolaborasi yang dipandang cukup kuat untuk menjamin semua proses dan pelaksanaan kegiatan terjadi dengan semestinya.

5. Evaluasi dan Pemantauan.

   Evaluasi dan pemantauan dilakukan pada tiap tahap kegiatan. Ada kemungkinan muncul alternatif penyelesaian lain sesuai perkembangan masalah yang terjadi. Evaluasi akhir dibutuhkan sebagai bahan refleksi untuk kegiatan selanjutnya.

   Dibutuhkan strategi penanganan yang efektif. Strategi tersebut harus bisa dipastikan akan berjalan secara konsisten dan komprehensif. Pihak TNGL menawarkan strategi penyelesaian secara menyeluruh yang dilaksanakan bersama dalam suatu pola manajemen kolaboratif. Tahapan strategi adalah sebagai berikut:[32]

   a. Penguatan organisasi melalui upaya fasilitasi untuk membangun pola kolaborasi.
      Target yang harus dicapai adalah pemaparan visi, misi, dan jajak pendapat masing-masing pihak, rapat koordinasi, pengumpulan data-data primer/sekunder, hingga pembentukan tim penyelesaian

   b. Relokasi pengungsi.
      Pelaksanaan relokasi dilakukan setelah proses penyiapan lokasi baru

[32]Wiratno, "Penyelesaian Konflik di Taman Nasional Gunung Leuser Secara Kolaboratif," makalah disampaikan pada Sheared Learning di Tangkahan, Taman Nasional Gunung Leuser, 13-22 Februari 2006, hlm. 3-4.

bagi pengungsi sudah mendapat kepastian. Selanjutnya dilakukan sosialisasi relokasi secara terpadu dan penanganan awal bagi penduduk non pengungsi termasuk para pekerja perambah. Aspek lain yang perlu diselesaikan dalam upaya relokasi yaitu penyediaan dana terminasi dan pendampingan pengungsi di lokasi baru.

c. Penangkapan dan penegakan hukum bagi perambah.
Pada saat lain, pihak yang berwenang melakukan penangkapan aktor intelektual, juga para perambah dan memastikan proses hukum berjalan. Proses ini memerlukan data tentang siapa pengungsi dan siapa perambah, mengingat mereka telah membaur di dalam pemukiman.

d. Isolasi Kawasan.
Beberapa kegiatan dalam isolasi kawasan ini adalah: penutupan kawasan dengan membangun pos jaga dan membentuk satuan pengamanan swakarsa, dan sosialisasi awal untuk proses selanjutnya yaitu rehabilitasi.

e. Rehabilitasi Kawasan.
Rehabilitasi diawali dengan pembersihan lokasi bekas pengungsi dan perambah. Setelah pengukuran batas dan luas kerusakan, rehabilitasi bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan rehabilitasi yang telah disusun bersama, termasuk teknis perawatan tanaman nantinya.

f. *Community Development*.
Kegiatan pendampingan dan penyadaran perlu secara intensif dilakukan pada masyarakat di sekitar areal rehabilitasi. Jangan sampai kejadian serupa terulang. Diharapkan dengan pola *community development* terbangun hubungan timbal balik yang harmonis antara manusia dengan alam, antara masyarakat dengan kawasan taman nasional.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pengelolaan konservasi pada program pembangunan kehutanan bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, selain tiga pilar konservasi yaitu fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari, diperlukan dukungan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan mekanisme penyelesaian konflik.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu arahan dan strategi yang merupakan hasil kesepakatan bersama, bersifat partisipatif, kolaboratif dan memiliki akuntabilitas serta dilaksanakan sesuai dengan komitmen yang telah dibangun secara bersama-sama pula. Arahan dan strategi inilah nantinya yang akan dipakai dalam penyelesaian masalah secara menyeluruh sehingga kawasan dapat direhabilitasi dan kembali berfungsi seperti semula sebagai kawasan konservasi.

Dalam era keterbukaan ini pengelolaan didasarkan pada paradigma baru yaitu *community based management* dan *participatory approach*. Pengelolaan konservasi melibatkan banyak komponen instansi dan masyarakat untuk mendapatkan sinergi dalam pelaksanaannya. Strategi partisipatif, kolaboratif dan

akuntabilitas diterapkan untuk menghimpun kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam berperan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan juga dalam monitoring dan evaluasinya. Pelibatan masyarakat diharapkan mulai dari individu, kelompok, LSM, pemerhati dan pelaku ekonomi sehingga semuanya akan memiliki rasa tanggung jawab untuk keberhasilannya.

Strategi ini menjadi sangat penting dan bisa aplikatif dalam upaya mengawal perjalanan otonomi daerah, karena setiap daerah juga diharapkan terlibat dalam pengelolaan konservasi. Dengan pola seperti ini diharapkan konflik antarinstansi dan masyarakat dapat dihindari dan ditemukan jalan keluar penyelesaian konflik yang terjadi. Pengelolaan konservasi ini sangat membutuhkan harmonisasi berbagai pihak, sehingga diperlukan keterbukaan (*akuntabilitas*) dari dan kepada semua pihak.

Potensi dari sumber daya alam yang terdapat di kawasan, bila dibandingkan dengan lokasi yang sama di Kabupaten Langkat, maka Tangkahan dapat menjadi sebuah kawasan ekowisata bila dikembangkan dengan baik. Hal ini didukung oleh informasi yang didapatkan dari Buku Panduan Sumatera Utara yang ditulis oleh Mahmud Bangkaru. Menurutnya Tangkahan adalah alternatif lain bagi Bukit Lawang. melalui perencanaan yang partisipasif dan ramah lingkungan. Diharapkan bahwa Tangkahan dapat berkembang menjadi kawasan ekowisata dan wisata alam yang baru.[33]

Objek wisata alam di kawasan Tangkahan yang telah diidentifikasi oleh pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Langkat adalah Pemandian Sei Buluh. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai kawasan masih sangat terbatas. Sementara objek wisata alam dan wisata minat khusus lainnya yang dapat dikemas menjadi Produk-produk Ekowisata yang dapat dikembangkan, telah diindentifikasi oleh Lembaga Pariwisata Tangkahan.

Produk ekowisata tersebut meliputi:[34]

a. Produk Wisata Petualangan.

   Produk wisata ini bertujuan untuk menambah pengalaman menjelajah hutan hujan tropis dataran rendah dan peningkatan pengetahuan mengenai jenis-jenis satwa yang terdapat di Taman Nasional. Jalur jalan setapak akan menyediakan sarana untuk berpetualang dan juga menara–menara pengamatan satwa, di akhir perjalanan produk wisata ini dapat pula ditambahkan dengan menyusur goa dan tubing. Produk ini hanya akan diperuntukkan bagi mereka yang memiliki standar kesehatan dan stamina yang baik. Produk wisata ini dapat juga dilakukan dengan paket Elephant Riding Patroll dengan empat ekor Gajah Leuser CRU (Conservations Respons Unit) kerja sama Flora dan Fauna Internationals dengan Balai KSDA, Balai TNGL dan Lembaga Pariwisata Tangkahan.

---

[33] *Ibid.*, hlm. 4-6.
[34] *Ibid.*

b. Produk Wisata Agro.

Produk wisata Agro yang dapat dikembangkan di antaranya adalah mengunjungi perkebunan tanaman keras dan buah milik masyarakat. Melalui kegiatan ini dan pengetahuan pengunjung akan kegiatan perkebunan penduduk dapat ditingkatkan. Jalur-jalur Interpretasi wisata Agro yang disiapkan melalui wawasan berbagai jenis perkebunan masyararakat sekaligus mendapatkan pengalaman langsung di lapangan untuk memetik hasilnya, seperti menyadap karet, memetik jeruk, durian, dan lainnya. kegiatan ini dapat dilakukan dengan berjalan kaki, berkuda dan bersepeda. Dan dapat juga dilakukan Interpretasi di Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet milik BUMN maupun Swasta yang terdapat di Kawasan Ekowisata dengan menerangkan proses Hulu sampai Hilir Produksinya. Hal ini dapat menjadi manfaat ganda bagi masyarakat maupun pengunjung

c. Produk Wisata Tirta.

Di kawasan Tangkahan terdapat sungai-sungai yang memberikan peluang untuk dikembangkannya Wisata Tirta seperti wisata pemandian yang telah berkembang saat ini. Tujuan dari wisata tirta ini lebih banyak untuk mendapatkan unsur rekreasi, sehingga biasanya bersifat massal (pada kawasan-kawasan tertentu yang telah ditunjuk) beberapa kegiatan dari wisata tirta yang dapat dilakukan di Tangkahan adalah berenang, menyusuri sungai dengan Tubbing (ban karet) dan paket safari sungai dengan Rubber boat dengan Standard safety Pelampung, helmet dan team Rescue. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk pengembangan Rafting, kayaking/canoing.

d. Berkemah.

Dalam hal berkemah di Tangkahan akan dikembangkan dua jenis perkemahanan. Pertama adalah perkemahan massal yang akan dikembangkan pada lokasi yang jauh dari Taman Nasional dan secara Zonasi pun merupakan Zonasi untuk kegiatan Rekreasi, akan tetapi nilai-nilai kebersihan, pelestarian kawasan dan juga kemungkinan sistem reservasi akan mulai diberikan secara bertahap. Sementara jenis yang kedua adalah Perkemahan terbatas yang terdapat di dalam Taman Nasional, didalam perkemahan ini pengunjung akan benar-benar belajar berkemah yang ramah lingkungan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Flora Fauna di Taman Nasional dengan sistem Reservasi yang terbatas.

e. Produk Wisata Budaya.

Merupakan salah satu produk wisata yang juga dapat ditawarkan di Kawasan Ekowisata Tangkahan. Tujuan dari produk wisata ini adalah pengunjung dapat mempelajari serta meningkatkan apresiasi terhadap adat istiadat karo, kesenian Karo dan pengobatan tradisional serta kearifan masyarakat lokal.

Proses pengembangan Kawasan Ekowisata Tangkahan pada prinsipnya dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat lokal. Adapun model dan ruang lingkup partisipatif masyarakat dalam mengembangakan Kawasan Ekowisata Tangkahan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Bukti bahwa pengembangan kawasan ekowisata Tangkahan ini dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat lokal, dapat dibuktikan oleh beberapa hal.

Pertama, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat lokal berupa: pendidikan, pelatihan dan studi banding serta mengikuti berbagai forum dan even di berbagai tingkatan dengan bantuan dan kerja sama berbagai pihak (BTNGL, Disbudpar, UML, INDECON, FFI, CII, PAN ECO, dan lainnya).

Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapat masyarakat tersebut dilakukan dengan: 1) terbukanya peluang usaha di bidang Pariwisata alam jasa, objek dan daya tarik serta sarana dan prasarana, 2) memacu pembangunan wilayah setempat baik tingkat lokal, regional maupun nasional, 3) berkembangnya mitra usaha investasi dengan masyarakat di sekitarnya dan terbukanya akses pasar, 4) terjaminya kesinambungan usaha, 5) memberikan keuntungan ekonomi bagi para pengelola kawasan, pengusaha pariwisata alam dan masyarakat setempat, 6) menciptakan *multiflier effect* bagi berbagai sektor ikutan di berbagai tingkatan.

Ketiga, peningkatan peran serta masyarakat, dengan menciptakan partisipasi kolektif masyarakat di Desa Namo Sialang dan Desa Sei Serdang melalui Peraturan Desa.

Keempat, menciptakan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Mempertemukan antara penawaran objek dan daya tarik wisata alam sebagai produk ekowisata dengan permintaan pasar sehingga dapat memberikan manfaat pada para pihak yang seharusnya terlibat terutama masyarakat.

Kelima, meningkatkan kapasitas dan penguatan pengelolaan. Peningkatan kapasitas Lembaga Pariwisata Tangkahan dalam pengelolaan kawasan secara intensif dan komprehensif.

Arah dan alur pengembangan investasi di Kawasan Ekowisata Tangkahan adalah berorientasi pengembangan mikro ekonomi pedesaan. Sehingga diharapkan ke depannya dapat mengarahkan kebijakan pembangunan Daerah dan nasional di pedesaan-pedesaan yang berbatasan dengan Taman Nasional. Dan kawasan di sekitar Taman Nasional dapat menjadi kawasan perekonomian yang menggairahkan (*ekologi-cluster*). Untuk menuju ke arah sana membutuhkan kerja keras dan sangat panjang sehingga dibutuhkan infrastruktur sosial yang konsisten dan berkesinambungan dalam sebuah manajemen terpadu dan kolaboratif. Diharapkan kedepannya akan disepakati bersama oleh berbagai pihak untuk dapat membentuk sebuah *Badan Investasi Kawasan* sebagai manajemen penataan dan pengendalian serta mengoptimalisasi potensi inves-

tasi dan modal di Kawasan Ekowisata Tangkahan. Di samping memiliki tujuan untuk dapat mempromosikan dan membuka pintu bagi investasi dari luar dengan tetap dapat mempertahankan orientasi ekologi dan peranan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Selama proses perencanaan pengembangan pariwisata di tingkat masyarakat, telah disusun bersama-sama antara masyarakat lokal dan Balai Taman Nasional. Antisipasi dampak pengembangan wisata di antaranya adalah:

a. Mengurangi dampak penggunaan kawasan dengan cara membuat zona-zona di kawasan pengembangan secara tidak langsung telah membatasi pengunjung yang masuk ke kawasan-kawasan yang rentan.
b. Membuat peraturan di tingkat desa dan dikuatkan dengan peraturan di tingkat daerah, tentang pembatasan pembangunan sarana dan prasarana, yang didasarkan pada hasil zonasi dan kesepakatan bersama.
c. Mengatur tipe pemanfaatan dan perilaku pengunjung, seperti mengajarkan etika di alam bebas, mengatur jumlah orang dalam satu kelompok, dan lain-lain.
d. Mengatur harapan pengunjung, hal ini dapat dicapai dengan cara memberikan informasi mengenai apa yang harus dipakai/digunakan oleh pengunjung, dan memberikan informasi tentang keadaan yang akan mereka hadapi.

Pengelolaan secara kolaboratif ini tampak jelas diatur dalam Pasal 3 Peraturan Desa yang menyatakan bahwa Kawasan Ekowisata Tangkahan dikelola menurut asas dan prinsip kebersamaan, keterbukaan, kekeluargaan, dan mengedepankan kepentingan bersama menurut aturan dan mekanisme yang telah disepakati.

Berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat Desa Namo Sialang dan Desa Sei Serdang untuk membentuk Lembaga Pariwisata Tangkahan pada 19 Mei 2001 sebagai lembaga masyarakat lokal, maka Pemerintah Desa Namo Sialang dan Desa Sei Serdang menetapkan beberapa hal.

Pertama, Lembaga Pariwisata Tangkahan disingkat LPT adalah lembaga resmi yang mengelola Kawasan Ekowisata Tangkahan.

Kedua, Pengelolaan ekowisata dalam Kawasan Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser dilaksanakan secara bersama-sama antara Lembaga Pariwisata Tangkahan dan Balai Taman Nasional Gunung leuser.

Ketiga, di dalam pelaksanaannya, Lembaga Pariwisata Tangkahan dan Balai Taman Nasional Gunung Leuser dapat bekerja sama dengan para pihak terkait melalui kesepakatan bersama yang disusun menurut mekanisme dan aturan yang berlaku.

Keempat, mengenai masalah Lembaga Pariwisata Tangkahan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Pariwisata Tangkahan.

Pengaturan tentang pengelolaan kawasan Tangkahan secara kolaboratif ini tampak jelas dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam Perdes. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa seluruh masyarakat berkewajiban untuk melindungi, menjaga dan melestarikan tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Lubuk Larangan di Kawasan Ekowisata Tangkahan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan memancing, di mana dalam penyelenggaraannya melalui mekanisme dan aturan sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) dan Balai Taman Nasional Gunung Leuser untuk kawasan di dalam Taman Nasional dan Pemerintahan Desa untuk kawasan di luar Taman Nasional (Pasal 9).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa adanya kolaborasi dalam mengelola kawasan Tangkahan. Pengelolaan ini cukup efektif dan mempunyai hasil yang signifikan, bila dibandingkan dengan penyelesaian yang lain seperti mediasi dan musyawarah. Meskipun kedua penyelesaian tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja, karena keduanya merupakan latar belakang lahirnya penyelesaian dan pengelolaan kawasan Tangkahan yang dilakukan secara kolaboratif.

Dalam rangka meningkatkan manfaat masyarakat lokal akan hutan, maka ada suatu ketentuan untuk melestarikan ekosistem di luar kawasan Tangkahan, di mana masyarakat berkewajiban untuk menyelenggarakan hutan-hutan cadangan dengan tanaman produktif dan berdaya guna untuk ekowisata dan pertanian masyarakat (Pasal 10). Di samping itu, seluruh masyarakat dan Balai Taman Nasional Gunung Leuser berkewajiban untuk menentang dan melarang upaya pertambangan yang dilakukan di dalam Kawasan Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser.

Hal lain yang menarik untuk dikembangkan secara kolaboratif meskipun tanpa harus meninggalkan keaslian adat istiadat Suku Karo, maka masyarakat lokal bekerja sama dengan pihak Balai Taman Nasional dengan didukung oleh Indecon melakukan upaya penguatan, pelestarian dan penggunaan budaya lokal. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam rangka penguatan dan pelestarian budaya lokal adalah:

a. Setiap ada kunjungan wisata atau kunjungan dari pihak luar, maka masyarakat lokal senantiasa menampilkan dan menyajikan upacara adat seperti Marga Silima, Tutur Siwaluh, Rakut Sitelu dan Sumbang Sisiwah.
b. Rumah adat Suku Karo yang sudah semakin sulit didapatkan saat ini, dicoba untuk disosialisasikan dan dilestarikan meskipun saat ini cukup sulit ditemukan di masyarakat di kedua desa yaitu Desa Namo Sialang dan Desa Sei Serdang.
c. Pada upacara adat, baik untuk menyambut para tamu, upacara perkawinan, atau upacara adat lainnya maka senantiasa menggunakan pakaian adat sesuai acara adat tersebut. Hal ini agar tetap menjaga keaslian adat Karo yang memang menjadi mayoritas penduduk di kedua desa tersebut.

Upacara adat tersebut merupakan kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap ada tamu wisatawan dan setiap ada upacara adat resmi yang diselenggarakan oleh masyarakat di suatu tempat di atas sungai Batang Serangan. Setiap masyarakat/pengunjung pendatang diwajibkan untuk menghormati tata cara dan adat istiadat yang berlaku di Kawasan Tangkahan. Masyarakat mempercayai apabila ini dilanggar maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik yang akan menimpa masyarakat lokal maupun pengunjung /pendatang tersebut.



Kesimpulan

Pengelolaan sumber daya hutan di berbagai kawasan Taman Nasional di beberapa kawasan sering kali menimbulkan persoalan. Persoalan tersebut antara lain adalah adanya konflik pemanfaatan sumber daya hutan. Konflik yang terjadi antara lain disebabkan oleh karena adanya tumpang tindih berbagai peraturan baik antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah, maupun antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Daerah.

Akibat dari adanya tumpang tindih antara berbagai peraturan, menimbulkan adanya pemahaman yang salah tentang bagaimana seharusnya mengelola hutan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat lokal yang tinggal di kawasan hutan.

Oleh karena itu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, karena pengelolaan sumber daya hutan maka solusi yang paling baik adalah menerapkan pola penyelesaian kolaborasi/kemitraan, antara masyarakat lokal dengan pemerintah. Dalam kasus yang terjadi di Tangkahan maka masyarakat lokal menyelesaikan dengan penyelesaian kolaboratif antara Balai Taman Nasional dengan masyarakat lokal. Penyelesaian kolaboratif tersebut dapat dibuktikan dengan pengelolaan ekowisata di kawasan Tangkahan, yang sampai saat ini cukup berjalan dengan baik meskipun masih perlu ditingkatkan lagi.

Daftar Referensi

Ahmad Kusworo. *Perambah Hutan* atau *Kambing Hitam?* Potret Sengketa Kawasan Hutan di Lampung. Bogor: Pustaka Latin, 2000.

Arimbi Heroepoetri, Julia Kalmirah dan Niken Sekar Palupi. Seri Konvensi Internasional Lingkungan: Konvensi Washington, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi Perubahan Iklim. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bekerja sama dengan FH UNIKA Atmajaya, 1999.

Ari Susanti, dkk. *Proceeding Lokakarya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat*. Yogyakarta: Lembaga ARUPA, 2000.

Ben Phillips, Hashim dan Wahyu Widodo. Program-program Daerah Penyangga, Work Shop, Program daerah penyangga, Bogor, 17-28 Oktober, 1992.

Black, Donald & Maureen Mileski (Eds). *The Social Organization of Law*. New York: Seminar Press, 1973.

Bruggink, H. J.J. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa Arief Sidharta. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Budiarjo, dkk. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cyber Consult, 2000.

Budi Riyanto. *Selayang Pandang Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004.

————————. *Pengaturan Hukum Adat di Indonesia*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004.

————————. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap Debt for Nature Swaps. Bogor: Lembaga Pengkajian Kehutanan dan Lingkungan, 2004.

Budi Riyanto dan Dudi Mempawardi Saragih. *Tanya Jawab Lengkap Hukum Konservasi Hayati*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2004.

————————. *Himpunan Ringkasan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan dan Konservasi Hayati*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004.

Budi Riyanto dan Samedi. *Dinamika Konservasi Hayati di Indonesia*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004.

Cotterel, Roger. *Law's Community, Legal Theory in Sociological Perspective*. Oxford: Clarendo Press, 1995.

David, J.Whittaker. *Conflik and Reconciliation in the Contemporary World: Making of the Contemporary World*. Cornwall: TJ International Ltd, 1999.

Dey, Thomas R. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Engelwoodcliff Hall, 1978.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Taman Nasional Di Indonesia, 1994.

Departemen Kehutanan. Nuansa dan Harapan Reformasi Kehutanan dan Perkebunan, Perjalanan 250 hari Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, 1999.

Didik Suhardjito. *Hak-Hak Penguasaan Atas Hutan di Indonesia*. Bogor: P3KM, 1999.

————————. dkk. *Pengelolaan Hutan Berbasiskan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.

Efendi Saman, dkk. *Politik Hukum Penguasaan Hutan di Indonesia*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 1993.

Faisal H. Fuad dan Siti Maskanah. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Pustaka LATIN, 2000.

George Junus Aditjondro. *Pola-pola Gerakan Lingkungan: Refleksi Untuk Menyelamatkan Lingkungan Dari Ekspansi Modal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

————————. *Korban-korban Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Hadi S. Ali Kodra dan Syaukani. *Bumi Makin Panas Banjir Makin Luas*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2004.

Ichsan Malik, dkk. *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik Atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala, 2003.

Ifdhal Kasim dan Johanes da Masenus Arus. *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001.

Ilya Moelyono, dkk. *Memadukan Kepentingan Memenangkan Kehidupan*. Bandung: Driya Media, 2003.

J. Linch, Owen dan Kirk Talbott. *Keseimbangan Tindakan: Sistem Pengelolaan Hutan Kerakyatan dan Hukum Negara di Asia dan Pasifik*. Jakarta, ELSAM, 2001.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Lauriel Heydir, dkk. *Pengakuan Hak-hak Masyarakat Untuk Pengembangan Community Forestry Abad 21*. Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Mari Fitzduff. *Keterampilan Komunitas Dalam Menghadapi Konflik*: Buku Pegangan untuk Kerja Kelompok di Irlandia Utara. Jakarta: British Council, 2002.

Mas Achmad Santosa dan Sulaiman Sembiring. *Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 1997.

Mitchell, Bruce, B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: PT Alumni, 2002.

Moh Askin. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR-RI*. Jakarta: Yasrif Watampoene, 2003.

Mudrajad Kuncoro. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.

Mustofa Agung Sardjono. *Mosaik Sosiologi Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumber Daya/*Mustofa Agung Sardjono. Yogyakarta: Debut Press, 2004.

Myrna A. Safitri. *Desa, Institusi Lokal dan Pengelolaan Hutan: Refleksi Kebijakan dan Praktik*. Jakarta: ELSAM, 2000.

Noer Fauzi dan I Nyoman Nurjaya. *Sumber Daya Alam Untuk Rakyat: Modul Lokakarya Penelitian Hukum Kritis-Partisipatif bagi Pendamping Hukum Rakyat*. Jakarta: ELSAM, 2000.

Revrisond Baswir, dkk. *Pembangunan Tanpa Perasaan: Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: ELSAM, 2003.

Riyatno. *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.

Rich, Bruce. *Menggadaikan Bumi*. Infid, 1999.

Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV Utomo, 2004.

————————. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

San Afri Awang dkk. *Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan*. Yogyakarta: CV Debut Press, 2001.

Schaffmeister, D, *Kekhawatiran Masa Kini: Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktik*. Diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1994.

Shaw Dj. William Shawcross. Deliver US From Evil: Worlords and Peacekeepers In A World Of Endless Conflict.-- London: Bloomsbury publishing, 2000

Simon Fisher. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak/ SIMON FISHER.-- Indonesia: The British Council, 2001.

Storey, Gordon dan A. Marzuki. Survey Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan: Contoh untuk Perencanaan dan Pelaksanaan di Tingkat Operasional, Jakarta, Departemen Kehutanan, 2002.

Sudharto P.Hadi. *Resolusi Konflik Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2004.

Tim Peneliti CIFOR, *Analisa Konflik Kehutanan di Indonesia 1997-2003*, CIFOR, 2004.

Tim Peneliti ARUPA. *Proceeding Lokakarya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat*. Yogyakarta: Lembaga ARUPA, 2000.

Untung Iskandar. *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Issue dan Agenda Mendesak*/Untung Iskandar. Yogyakarta: Debut Press, 2004.

Wiratno, dkk. *Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*. Jakarta: Forest Press, 2004.

Yuliana Cahya Wulan, dkk. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*. Bogor: Center for International Forestry Research, 2004.

42

BEDA KARAKTER YURIDIS ANTARA NOTARIS DAN PPAT SERTA AKTA NOTARIS – PPAT

Oleh:
*Dr. Habib Adjie, S.H., M.H.**

Menulis sesuatu dalam atau untuk dunia notaris dan PPAT senantiasa akan berhubungan dengan suasana atau nuansa yang ada sekitar permasalahan yang ada pada waktu itu. Suasana atau nuansa yang ada pada waktu itu, antara lain yaitu setelah para pengurus organisasi jabatan notaris berhasil bekerja sama dengan Menteri Negara dan Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang *Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi,* yang telah memberikan atribut kepada Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi. Pada waktu itu saya punya kekhawatiran, jika notaris sebagai Pejabat Umum (Publik) yang mempunyai wewenang umum dalam pembuatan akta (apa saja) sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain, jika akan membuat akta tertentu harus diberikan atribut tertentu. Kalau hal tersebut dilakukan terus-menerus, jangan-jangan instansi lain meminta hal yang sama, sudah tentu jika hal ini akan terjadi penggerogotan terhadap wewenang notaris sebagai Pejabat Umum. Dalam pikiran saya, cukup sudah pemberian atribut seperti itu, apa ada yang kurang dengan pemberian kualifikasi kepada notaris sebagai Pejabat Umum.

Sebenarnya untuk tindakan hukum tertentu kepada notaris tidak perlu diikrarkan atribut lain seperti tersebut di atas, tapi cukup menyebutkan dan menegaskan, bahwa untuk tindakkan hukum tertentu wajib atau harus dilakukan dengan akta notaris, contohnya:

1. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* menegaskan bahwa perseroan terbatas didirikan dengan akta notaris.

---

*Notaris & PPAT di Surabaya tahun 2000 - sekarang. Dosen Magister Kenotariatan/Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Dosen di Fakultas Hukum (S1/S2) Universitas Narotama Surabaya, Dosen di Magister Hukum Bisnis – Fak. Hukum UII Yogyakarta.

2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia* menegaskan bahwa akta Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris.
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang *Yayasan* menegaskan bahwa Yayasan didirikan dengan akta notaris.
4. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Partai Politik,* menentukan bahwa pendirian partai politik harus dengan akta notaris.
5. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang *Badan Hukum Pendidikan,* menentukan bahwa pendirian Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) wajib dengan akta notaris.

Ada nuansa yang lain lagi ketika UUJN menjadi satu-satunya (unifikasi) pengaturan hukum di Indonesia, dan yang menjadi topik yang tetap hangat dan cenderung panas sampai hari ini, yaitu mengenai kewenangan notaris dalam bidang pertanahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, dan terjadi tarik-menarik kewenangan antara Notaris dan PPAT, di sisi yang lain, organisasi notaris dan PPAT tidak memberikan "*official statement*" yang mengikat para notaris dan PPAT atau siapa saja, tapi cenderung membiarkannya bagaikan bola liar, sehingga menimbulkan berbagai macam penafsiran mengenai ketentuan Pasal 15 ayat (2) f UUJN, bahkan petinggi Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia tidak mampu memberikan penjelasan dan penyelesaiannya. Dan petinggi tersebut menyarankan jika timbul permasalahan dari kewenangan tersebut, dipersilahkan untuk diselesaikan di pengadilan saja. Ini memang aneh, pemerintah dan DPR yang membuat undang-undang tersebut tidak mampu untuk menyelesaikannya.

Bahwa notaris dan PPAT merupakan lembaga atau institusi yuridis yang mempunyai karakter sendiri-sendiri, sebagaimana juga manusia mempunyai karakter sendiri-sendiri.

Untuk menyelesaikan hal tersebut saya memberikan penafsiran dari adanya perbedaan karakter yuridis akta notaris dan PPAT. Perbedaan karakter yuridis tersebut didasarkan pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

1. KARAKTER YURIDIS AKTA NOTARIS

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973:

   Judex factie dalam amar putusannya membatalkan akta notaris, hal ini adalah tidak dapat dibenarkan, karena notaris fungsinya hanya mencatat-kan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut.

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994:

Akta autentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo 265 Rbg jo 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya.

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1140 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998:

Suatu akta notaris sebagai akta autentik yang isinya memuat dua perbuatan hukum, yaitu (1). Pengakuan hutang, dan (2) kuasa mutlak untuk menjual tanah. Maka akta notaris ini telah melanggar adagium. Bahwa satu akta autentik hanya berisi satu perbuatan hukum saja. Akta notaris yang demikian itu tidak memiliki *executorial titel ex* Pasal 224 HIR dan tidak sah.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka karakter yuridis notaris dan akta notaris, yaitu:

1. Pembatalan akta notaris oleh hakim tidak dapat dibenarkan, karena akta tersebut merupakan kehendak para penghadap.
2. Fungsi notaris hanya mencatatkan keinginan penghadap yang dikemukakan di hadapan notaris.
3. Notaris tidak mempunyai kewajiban materiil atas hal-hal yang dikemukakan di hadapan notaris.
4. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, para ahli warisnya dan siapa saja yang mendapat hak dari akta tersebut.
5. Tiap akta notaris (atau satu akta notaris) hanya memuat satu tindakan atau perbuatan hukum saja. Jika satu akta notaris memuat lebih dari satu perbuatan hukum, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan title eksekutorial dan tidak sah.

2. KARAKTER YURIDIS AKTA PPAT

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 62 K/TUN/1988, tanggal 27 Juli 2001:

Bahwa akta-akta yang diterbitkan oleh PPAT adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Sub. 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara, karena meskipun dibuat oleh PPAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, namun dalam hal ini pejabat tersebut bertindak sebagai Pejabat Umum dalam bidang perdata.

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K/TUN/1999, tanggal 8 Februari 2000:

PPAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara karena melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan Peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 10 Tahun 1961, akan tetapi (akta jual beli) yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifat bilateral (kontraktual), tidak bersifat unilateral yang merupakan sifat Keputusan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka karakter yuridis PPAT dan akta PPAT, yaitu:

1. PPAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, karena menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan atau dalam bidang pendaftaran tanah dengan membuat akta PPAT sesuai aturan hukum yang berlaku.
2. Akta PPAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, meskipun PPAT dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Dalam kedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, PPAT tetap bertindak sebagai Pejabat Umum dalam bidang Hukum Perdata.
4. Akta PPAT tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena akta PPAT bersifat bilateral (kontraktual), sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara bersifat unilateral.

Mencermati adanya perbedaan karakter yuridis antara notaris dan PPAT, maka suatu hal yang sangat tidak mungkin dua karakter yang berbeda dijadikan satu. Menyatukan dua karakter yuridis yang berbeda hanya merupakan upaya pemaksaan yang tidak dilandasi dasar hukum yang jelas.

Berdasarkan alasan tersebut di atas karena ada perbedaan karakter yuridis, pada akhirnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, harus diberi batasan, bahwa notaris mempunyai kewenangan di bidang pertanahan, yang bukan sepanjang kewenangan yang selama ini ada pada PPAT. Dengan demikian, eksistensi lembaga Notariat dan PPAT tetap ada dengan segala kewenangannya menurut aturan hukum yang mengatur jabatan notaris dan PPAT. Sehingga tidak perlu diributkan (kembali) substansi Pasal 15 ayat (2) huruf UUJN tersebut. Lebih baik lembaga Notariat dan PPAT dibina sebaik-baiknya karena kedua lembaga tersebut hadir untuk kepentingan masyarakat, dan sudah menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

43

MEMBANGUN PARADIGMA BARU HUBUNGAN NEGARA DENGAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL*

Oleh:
*Dr. Cecep Effendi***

Pendahuluan

Runtuhnya Pemerintah Orde Baru pada 1998 mengubah secara dramatik hubungan antara negara dan organisasi masyarakat sipil. Pilar penyangga Pemerintah Orde Baru seperti Golongan Karya, Tentara Nasional Indonesia dan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia kehilangan legitimasi dan kekuasaannya untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat dan birokrasi. Hal ini memberi ruang bagi peran organisasi masyarakat sipil yang lebih besar. Diperlemah oleh krisis ekonomi nasional, konflik komunal di Kalimantan dan Sulawesi dan berkembangnya tuntutan kemerdekaan di Provinsi Aceh dan Provinsi Papua, negara Pasca Orde Baru kehilangan legitimasi untuk mengatur dan mengontrol organisasi masyarakat sipil yang jumlahnya semakin bertambah sejak 1998.

Didorong oleh peran ikut menjatuhkan Pemerintah Orde Baru, organisasi masyarakat sipil menuntut peran yang lebih aktif dalam ruang publik. Aktivitas organisasi masyarakat sipil dalam ruang publik yang semakin besar ini telah melahirkan berbagai macam organisasi masyarakat sipil. Suharko membagi empat kategori yaitu DJANGOs *(Development, Justice and Advocacy)*, TANGO *(Traditional Non-Governmental Organizations)* FUNDANGOs (*Funding Agency Non-Governmental Organizations*) and MUNGOs *(Mutan Non-Governmental Organizations)* (Suharko, 2005: 87)

---

*Tulisan ini merupakan kajian awal dari sebuah buku dengan judul *Redefining State-Civil Society Relations In Indonesia's Democracy Era* yang tengah dipersiapkan oleh penulis dengan dukungan dari German Technical Cooperation Advisory Services Support for Decentralization (GTZ-ASSD).

**Dr. Cecep Effendi, adalah Anggota Dewan Pengarah Jaringan Kerja Tata Pemerintahan Asia - Kerja Sama Pembangunan Jerman dan Senior National Advisor Advisory Services Support for Decentralization, German Technical Cooperation (GTZ-ASSD) di Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Desakan menuntut perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah lama menjadi wacana. Namun, mengingat bahwa masalah-masalah yang diatur di dalam undang-undang ini terkait dengan puluhan bahkan ratusan OMS perubahan terhadap undang-undang ini tidak segera dilakukan. Pemerintah Habibie dan para penerusnya Pemerintah Wahid dan Pemerintah Megawati. Bahkan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono untuk beberapa waktu tidak merasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang ini. Dampak yang terjadi terhadap kegagalan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang ini adalah bahwa organisasi masyarakat sipil tidak merasa secara hukum terikat oleh keberadaan undang-undang ini dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka.

Tulisan berikut ini bertujuan memberikan gambaran awal mengenai upaya membangun paradigma baru hubungan antara negara dengan organisasi masyarakat sipil melalui revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi masyarakat sipil yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri. Tulisan ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama membahas mengenai ruang lingkup OMS dengan memberikan definisi dan karakteristik dari OMS. Bagian kedua membahas upaya melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi antardepartemen yang bertanggung jawab terhadap OMS. Bagian ketiga membahas mengenai problematika penyusunan Rancangan Undang-Undang organisasi masyarakat sipil yang dihadapi oleh Departemen Dalam Negeri. Bagian keempat membahas mengenai Komisi organisasi masyarakat sipil. Bagian keenam membahas beberapa persoalan yang harus diselesaikan dalam rangka memperkuat keberadaan OMS di Indonesia.



Ruang Lingkup Organisasi Masyarakat Sipil

Pembahasan mengenai upaya menata kembali hubungan antara Negara dan organisasi masyarakat sipil harus dimulai dengan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan masyarakat sipil itu sendiri. Pembahasan di sini dimaksudkan hanya untuk memberikan sedikit ulasan tentang apa itu organisasi masyarakat sipil. Pembahasan yang lengkap mengenai penjelasan teoretis tentang organisasi masyarakat sipil telah menjadi kajian dari berbagai ahli yang dapat dirujuk pada daftar kepustakaan yang diberikan di akhir tulisan ini.

Definisi mengenai apa yang dimaksud dengan masyarakat sipil (*civil society*) dan organisasi masyarakat sipil *(civil society organization*) telah menjadi pembahasan yang mendalam di kalangan para ahli. Bahkan perdebatan mengenai organisasi masyarakat sipil telah menjadi menyita banyak perhatian para ahli. Lee Hock Guan menyatakan bahwa konsep masyarakat sipil telah berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki banyak makna sehingga kehilangan kredibilitasnya (Lee Hock Guan, 2004).

Terminologi organisasi masyarakat sipil yang dimaksudkan di sini juga dikenal dengan nama yang lain seperti Organisasi Non-Pemerintah (NGO) atau yang lebih populer dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tulisan ini tidak akan membahas polemik di sekitar nama-nama tersebut yang berlangsung di tahun 1980-an karena berada di luar cakupan dari tulisan ini.

Shinnnichi Shigetomi menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan organisasi masyarakat sipil itu adalah suatu organisasi yang memiliki enam karakteristik yaitu *pertama*, bukan organisasi pemerintah; *kedua*, bersifat tidak mencari keuntungan; *ketiga*, bersifat sukarela; *keempat*, berkesinambungan dan terlembaga; (Shigetomi, 2002: 7).

Karakteristik pertama bukan organisasi pemerintah (*non-governmental organization*) dimaksudkan di sini adalah organisasi masyarakat sipil harus melaksanakan keputusan organisasinya bebas dari campur tangan pemerintah. Karakteristik kedua yaitu bersifat tidak mencari keuntungan (nirlaba) dimaksudkan di sini adalah kegiatan organisasi masyarakat sipil tidak didorong oleh motivasi mencari keuntungan dan keuntungan apa pun yang didapat dari kegiatan organisasi masyarakat sipil tidak akan dibagi-bagikan kepada anggota-anggotanya untuk keuntungan pribadi. Karakteristik ketiga yaitu bersifat sukarela yang dimaksudkan di sini adalah syarat keanggotaan dari organisasi masyarakat sipil semata-mata keinginan untuk turut berpartisipasi. Partisipasi tidak boleh dipenuhi dengan banyak persyaratan. Karakteristik keempat berkesinambungan dan terlembaga yang dimaksudkan di sini adalah berbeda dengan berbagai macam kegiatan sukarela yang dilaksanakan secara sementara, organisasi masyarakat sipil merupakan suatu lembaga yang berkesinambungan dengan bentuk kelembagaan yang jelas.

Menurut Shinnichi Shigetomi (Shigetomi, 2002: 6) keempat karakteristik yang disebutkan di atas dapat ditemui di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Namun, menurutnya di negara-negara berkembang perlu ditambahkan dua karakteristik tambahan yaitu tidak mementingkan diri sendiri (*altruistic*) yang berarti bahwa tujuan jangka pendek dari organisasi masyarakat sipil adalah melakukan aktivitas untuk kepentingan orang lain dan bukan kepentingan organisasi atau anggota organisasi itu sendiri. Karakteristik kedua adalah cinta kepada kemanusiaan (*philanthropic*) yang berarti organisasi masyarakat sipil sedikit sekali memiliki kemungkinan akan memperoleh bayaran dari orang-orang yang dilayaninya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa warga masyarakat yang memperoleh layanan dari organisasi masyarakat sipil di negara-negara berkembang umumnya adalah mereka yang secara ekonomi miskin dan secara sosial tertindas.

Mengingat bahwa pengaturan mengenai organisasi masyarakat sipil menjadi kewenangan pemerintah, maka perlu di sini dibahas bagaimana pemerintah mendefinisikan organisasi masyarakat sipil itu. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan Departemen Sosial tidak menggunakan terminologi organisasi non-pemerintah. Pemerintah tampaknya melihat bahwa

penggunaan terminologi organisasi non-pemerintah sarat dengan karakteristik yang bertentangan dengan pemerintah. Namun bila ditelusuri peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi masyarakat sipil ini dapat ditemukan tiga terminologi yang dipakai yaitu organisasi kemasyarakatan seperti yang dapat ditemui pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kesejahteraan Sosial seperti yang dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti yang didapati pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tentang Lembaga Swadaya Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menegaskan bahwa kecuali partai politik dan Golongan Karya, pegawai negeri, perusahaan dan koperasi yang secara khusus diatur oleh undang-undang tersendiri, organisasi yang bukan pemerintah secara hukum dapat dipandang sebagai organisasi kemasyarakatan yang pengaturannya ditetapkan oleh undang-undang ini. Selanjutnya undang-undang ini mendefinisikan yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan *adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia berdasarkan kesamaan dalam kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan untuk serta dalam pembangunan nasional yang diarahkan kepada pencapaian tujuan nasional, di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.*

Organisasi masyarakat sipil yang berbadan hukum yayasan pada umumnya menolak dikelompokkan sebagai organisasi kemasyarakatan. Salah satu argumennya adalah bahwa mereka adalah organisasi tidak berbasiskan kepada anggota akan tetapi lebih kepada kegiatan. Oleh karena basis hukum dari orga-nisasi ini adalah yayasan, mereka umumnya tunduk kepada pengaturan yang dimuat oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan atau kepada undang-undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Di samping itu masih terdapat organisasi masyarakat sipil yang tidak memandang dirinya diatur baik oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ataupun oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ataupun Undang Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan akan tetapi merujuk pengaturan dirinya kepada pengaturan tentang perkumpulan yang dibuat oleh regim kolonial Belanda yaitu ***Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*** pada tahun ditetapkan oleh Raja Belanda pada 28 Maret 1870.

Persoalan bagaimana menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang berbasiskan kepada konsensus dari berbagai departemen pemerintah yang terlibat dalam pengaturan organisasi masyarakat sipil seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di satu pihak dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam berbagai tahap penyusunan rancangan undang-undang akan menjadi karakteristik

dari upaya untuk menata kembali hubungan antara negara dan organisasi masyarakat sipil di masa pasca Orde Baru.



Harmonisasi Lintas Departemen

Pengaturan terhadap organisasi masyarakat sipil sampai saat ini masih dilaksanakan oleh tiga departemen pemerintah yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Departemen Sosial. Di luar ketiga departemen tersebut masih ada organisasi masyarakat sipil yang juga berkaitan erat dengan fungsi yang dilaksanakan oleh Departemen Agama. Persoalannya adalah pengaturan dan pengurusan organisasi masyarakat sipil dilaksanakan secara terpisah dan tidak terjalin koordinasi di antara ketiga departemen pemerintah tersebut. Ketiga departemen pemerintah ini bekerja berdasarkan kepada landasan undang-undang yang pada awalnya diusulkan oleh masing-masing departemen.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pengusul Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2004. OMS yang berbadan hukum yayasan berada di bawah pembinaan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara itu, Departemen Dalam Negeri adalah pengusul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dapat dipahami apabila Departemen Dalam Negeri berpandangan bahwa departemen ini memiliki wewenang untuk mengurus OMS yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara itu, Departemen Sosial mengusulkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Departemen Sosial banyak mengatur peran dari OMS yang berada di pedesaan yang oleh departemen ini dinamakan organisasi sosial (ORSOS).

Ketika memutuskan untuk menyusun kembali Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Masyarakat, Departemen Dalam Negeri harus menghadapi persoalan tentang persepsi organisasi masyarakat sipil terhadap Departemen Dalam Negeri. Sebagai bagian dari warisan Pemerintah Orde Baru, Dalam pandangan organisasi masyarakat sipil Departemen Dalam Negeri dipandang sebagai departemen yang bertanggung jawab terhadap kebijakan represif yang dilakukan terhadap organisasi masyarakat sipil. Dapat dipahami apabila organisasi masyarakat sipil tidak memiliki cukup kepercayaan terhadap Departemen Dalam Negeri.

Direktorat Fasilitasi Organisasi Sosial dan Politik, Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik menjawab tantangan yang dihadapi oleh citra Departemen Dalam Negeri dihadapan organisasi masyarakat sipil dengan melakukan langkah-langkah strategis. *Pertama*, menggalang kerja sama dengan

GTZ-ASSD yang selama ini telah membantu Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam menyusun berbagai peraturan perundang-undangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Keterlibatan GTZ-ASSD memungkinkan terbangunnya jaringan organisasi masyarakat sipil, terutama dengan tokoh-tokoh seniornya yang dalam berbagai kesempatan telah menjadi mitra kerja GTZ-ASSD.

Direktorat Fasilitasi Organisasi Masyarakat dan Politik juga memutuskan untuk mengundang keterlibatan tokoh-tokoh organisasi masyarakat sipil baik yang berbasis anggota maupun yang tidak berbasis anggota. Di antara tokoh-tokoh tersebut yang dapat disebutkan di sini adalah Bambang Ismawan dari Bina Swadaya, Rustam Ibrahim yang pernah memimpin LP3ES, Dr. Sudibyo Markus, salah seorang pengurus Pimpinan Pusat Muhammadijah, Nasikhin dari Pengurus Pusat Nahdathul Ulama, Romo Benny Susetyo dari MAWI, Dr. Tri Pranadji dari Ikatan Sarjana Sosiologi Indonesia (ISI) dan Mossadeq Bahri, tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Indonesia dan pengurus Dewan Kesenian Depok. Dalam perjalanan, Dr. Bambang Sudibyo Markus, Nasikhin dan Romo Benny Susetyo tidak dapat terus terlibat karena kesibukan masing-masing. Vera Wenny dari Divisi Hukum MAWI akhirnya bertugas menggantikan Romo Benny.

Langkah lain yang dilaksanakan oleh Direktorat Fasilitasi Organisasi Masyarakat dan Politik bersama-sama GTZ-ASSD adalah membangun komitmen bersama-sama dengan Tim Pakar, bahwa Tim Pakar akan membuka akses bagi kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap naskah rancangan undang-undang ketika dipandang naskah rancangan undang-undang telah memperoleh bentuk dan muatan yang jelas.

Lebih jauh, kedua pihak sepakat untuk mengadakan Focus Group Discussion di lima provinsi yaitu di Banda Aceh, di Aceh, Makasar di Sulawesi Selatan, Mataram di Nusa Tenggara Barat, Balikpapan di Kalimantan Timur, Semarang di Jawa Tengah dan lokakarya nasional yang melibatkan organisasi masyarakat sipil baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dalam rangka menjamin bahwa proses penyusunan Rancangan Undang-Undang organisasi masyarakat sipil ini benar-benar dilaksanakan secara partisipatif dan transparan, maka Direktorat Fasilitasi Organisasi Sosial dan Politik menyerahkan proses pelaksanaan Focus Group Discussion dan workshop nasional kepada salah satu organisasi masyarakat sipil terkemuka yaitu LP3ES.



Problematika Penyusunan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil

Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang organisasi masyarakat sipil setelah melaksanakan serangkaian diskusi menetapkan persoalan yang akan menjadi substansi pokok Rancangan Undang-Undang organisasi masyarakat

sipil adalah penataan kembali hubungan antara negara dan masyarakat. hubungan antara negara dan masyarakat telah berubah secara mendasar semenjak kejatuhan Pemerintah Orde Baru pada akhir 1998. Pembatasan politik yang dilakukan secara ketat oleh Pemerintah Orde Baru dihentikan dan kebebasan politik untuk mendirikan berbagai organisasi sosial, ekonomi dan politik diberikan. Praktik pelaksanaan kesetiaan kepada satu organisasi untuk setiap jenis profesi yang diterapkan di selama masa kekuasaan Orde Baru ditinggalkan oleh pemerintah yang baru.

Peningkatan jumlah organisasi masyarakat yang sedemikian pesat terjadi berbarengan dengan pelaksanaan otonomi daerah pada Januari 2000 di mana kewenangan mengurus organisasi masyarakat sipil tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Bersama-sama dengan pers lokal, organisasi masyarakat sipil mengembangkan peran sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam menerjemahkan substansi pokok yang menjadi rumusan pasal dan ayat, Tim Penyusun memahami bahwa terdapat persepsi yang kuat di kalangan aktivis organisasi masyarakat sipil yang memandang, bahwa memberikan kewenangan mengatur (*regulatory power*) kepada Departemen Dalam Negeri akan mengundang penolakan keras dari organisasi masyarakat sipil. Sikap yang hampir sama juga dinyatakan oleh organisasi masyarakat sipil terhadap Badan Kesatuan Bangsa di provinsi dan kabupaten/kota.

Sekalipun Badan Kesatuan Bangsa kini tidak lagi menjadi perangkat organisasi pusat di daerah seperti di masa Pemerintah Orde Baru, namun sebagian organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam kegiatan Focus Group Discussion di lima provinsi masih melihat kebijakan yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa kepada organisasi masyarakat sipil masih tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa di masa Pemerintah Orde Baru.

Di sisi lain, Tim Penyusun juga melihat bahwa pertumbuhan jumlah organisasi masyarakat sipil yang sedemikian pesat mengundang persoalan sendiri. Persoalan-persoalan seperti bagaimana membedakan organisasi masyarakat sipil yang dibentuk untuk tujuan-tujuan advokasi ataupun pelayanan maupun pendidikan masyarakat dengan organisasi masyarakat sipil yang dalam melaksanakan tugasnya lebih berperan sebagai instrumen kepentingan politik atau bahkan dimanfaatkan menjadi alat penekan terhadap pejabat pemerintahan daerah agar mendapat manfaat-manfaat finansial.

Persoalan lain yang dihadapi oleh para penyusun Rancangan Undang-Undang organisasi masyarakat sipil adalah, bahwa departemen pemerintah seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Departemen Sosial berfungsi lebih sebagai lembaga penyelenggara pendaftaran dan pendataan organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat

sipil yang memiliki badan hukum Yayasan ataupun Perkumpulan memperoleh pengakuan sebagai badan hukum yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Departemen Sosial melaksanakan fungsi pendataan dan pemetaan terhadap berbagai organisasi sosial sipil yang hidup dan berkembang di tingkat akar rumput, terutama di pedesaan. Departemen Dalam Negeri sendiri mengurus organisasi masyarakat yang memiliki status organisasi masyarakat sipil tingkat nasional yang dikategorisasikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 dan tidak berbadan hukum.

Pelaksanaan urusan yang terkait dengan organisasi masyarakat sipil oleh ketiga departemen pemerintah tersebut selama ini lebih menitikberatkan pada aspek pengakuan pemerintah terhadap keberadaaan organisasi masyarakat sipil tertentu. Pelaksanaan kebijakan terkait dengan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil terkait dengan internal kelembagaannya, seperti bagaimana mengelola manajemen organisasi nirlaba, kapasitas untuk melakukan advokasi, kegiatan penggalangan dana dan laporan keuangan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas organisasi masyarakat sipil kepada publik, tidak mendapatkan perhatian secara serius oleh ketiga departemen pemerintah tersebut.

Persoalan siapa yang memikul tanggung jawab untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan internal organisasi masyarakat sipil setelah memperoleh status terdaftar atau memperoleh pengakuan sebagai badan hukum, tidak pernah menjadi kebijakan departemen pemerintah.



Substansi Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil

Berikut ini adalah beberapa substansi muatan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil. Substansi muatan ini merupakan jawaban anggota Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang organisasi masyarakat sipil terhadap persoalan-persoalan yang disebutkan di atas.

1. Komisi Organisasi Masyarakat Sipil (KORMAS)

Pilihan untuk membentuk Komisi Organisasi Masyarakat Sipil (KORMAS) memiliki beberapa pertimbangan: *Pertama*, praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dewasa ini dikenal keberadaan komisi sebagai lembaga pendukung (*auxiliary agency*) yang memiliki tugas khusus yang tidak selalu dapat dilaksanakan oleh negara. Untuk urusan penyelenggaraan pemilihan umum dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk memantau dan memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilaksanakan berlangsung secara adil dan bersaing, dibentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Terkait dengan pengawasan dan pemantauan terhadap siaran televisi maupun radio

yang dilaksanakan oleh station radio dan televisi swasta dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ketiga komisi tersebut adalah sedikit contoh tentang pembentukan lembaga *auxiliary agency*. Di dalam konteks penyelenggaraan urusan organisasi masyarakat sipil, negara dapat saja melaksanakan pengurusan organisasi masyarakat sipil, namun seperti yang telah disebutkan di atas terdapat penolakan campur tangan negara di dalam pengelolaan organisasi masyarakat sipil sehingga dibutuhkan alternatif siapa yang memiliki kewenangan untuk mengurus organisasi masyarakat sipil.

Model pengurusan organisasi masyarakat sipil yang dilaksanakan oleh Komisi juga terdapat di Inggris. Pengurusan organisasi masyarakat sipil tidak lagi secara langsung dilaksanakan oleh negara akan tetapi oleh sebuah komisi yaitu ***Charity Commission*** yang terdiri dari dua komponen yaitu unsur komisioner dan unsur sekretariat pendukung. Unsur komisioner didalam Charity Commission merupakan representasi dari wakil negara dan wakil organisasi masyarakat sipil yang bertindak sebagai regulator urusan organisasi masyarakat sipil di England dan Wales.

Pengaturan kewenangan *Charity Commission* dalam mengurus organisasi masyarakat sipil ditetapkan oleh **Charity Commission Act 2003** yang menjadi pedoman kerja Charity Commission. Di dalam pelaksanaan tugasnya, Charity Commission memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan yang lebih teknis. Charity Commission bertindak sebagai *executing agency* dari Kementerian Negara Sektor Ketiga yang merupakan kementerian yang berada di dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Kebijakan politik terhadap organisasi masyarakat sipil menjadi tanggung jawab Menteri Negara Sektor Ketiga ini dan Menteri mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada Parlemen.

Di samping Kementerian Negara Sektor Ketiga, Charity Commission, terdapat lembaga yang turut memainkan peran dalam pengembangan organisasi masyarakat sipil yaitu National Council for Volunteer Organizations (NCVO). Organisasi ini merupakan wadah bagi semua organisasi masyarakat sipil yang ada di England dan Wales. Apabila Charity Commission merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara dan bertindak atas nama negara, maka NCVO sepenuhnya dibentuk oleh organisasi masyarakat sipil dan bertindak atas nama organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berada di England dan Wales. Pembiayaan NCVO sepenuhnya ditanggung oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil yang menjadi anggotanya, negara memberikan subsidi yang jumlahnya hanya mencapai 15 (lima belas persen) dari jumlah total biaya yang dibutuhkan oleh NCVO.

Tim penyusun Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil memandang bahwa dalam konteks pengurusan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, keberadaan sebuah Komisi di mana duduk wakil-wakil negara dan wakil-wakil organisasi masyarakat sipil merupakan pilihan yang paling tepat.

Keberadaan Komisi akan dapat menjadi mediasi antara negara yang selama tiga dasawarsa dipandang telah melakukan tindakan pengawasan yang ketat terhadap organisasi masyarakat sipil. Negara juga tidak memiliki legitimasi untuk membuat kebijakan dan oleh karena itu keterlibatan organisasi masyarakat sipil di dalam proses penyusunan kebijakan menjadi suatu keharusan. Keberadaan Komisi akan menjawab kedua sudut pandang tersebut.

Tim penyusun Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil, Komisi mengusulkan agar Komisi ini memiliki anggota berjumlah tujuh orang dengan usia minimum 35 tahun, tiga orang di antaranya adalah perempuan. Keanggotaan Komisi ditentukan oleh suatu proses yang dilaksanakan oleh Sekretariat Seleksi yang akan dibentuk oleh Departemen Dalam Negeri. Rekrutmen dilaksanakan melalui pengumuman di berbagai media cetak dan elektronik untuk menjaring calon-calon terbaik untuk menjadi anggota Komisi Organisasi Masyarakat Sipil.

Dari jumlah pendaftar yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil, empat belas akan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai calon anggota Komisi dan dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengikuti ***fit dan proper test.*** DPR menetapkan tujuh orang dari empat belas orang yang dikirim oleh presiden menjadi anggota Komisi Organisasi Masyarakat Sipil.

Komisi Organisasi Masyarakat Sipil memiliki beberapa tugas. Tugas tersebut adalah menyelenggarakan pendaftaran atau registrasi bagi OMS; melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja OMS yang terdaftar; memfasilitasi kerja sama antar OMS; mengelola sistem data base OMS; menyusun pedoman peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan OMS; melakukan penelitian dan pengembangan OMS dan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan OMS. Perincian lebih jauh tentang tugas-tugas tersebut di atas akan diatur sendiri oleh Peraturan Komisi Organisasi Masyarakat Sipil.

Komisi ini akan dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih di antara tujuh orang anggota Komisi tersebut. Masa jabatan anggota Komisi akan berlaku selama lima tahun dan tidak boleh dipilih kembali.

Salah satu perdebatannya adalah mengenai tugas-tugas Komisi di antara anggota Tim Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil adalah apakah Komisi akan mengambil alih urusan-urusan yang selama ini menjadi urusan dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan Hak-Hak Asasi Manusia dan Departemen Sosial atau Komisi Organisasi Masyarakat Sipil hanya akan melaksanakan tugas-tugas yang selama ini belum dilaksanakan oleh masing-masing departemen. Pada urusan tugas yang disebutkan di atas yang menjadi tugas Komisi adalah melaksanakan urusan yang terkait dengan huruf a sampai g, sementara urusan yang menyangkut penyelenggaraan pendaftaran tetap menjadi urusan masing-masing departemen.

2. Kewenangan Negara Terhadap Organisasi Masyarakat Sipil

Salah satu faktor utama yang memengaruhi hubungan antara Pemerintah Orde Baru dengan organisasi masyarakat sipil adalah pengaturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang berkaitan dengan asas tunggal yang harus dianut oleh organisasi masyarakat sipil. Pasal 1 ayat 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Undang-Undang ini pada Pasal 13, 14 dan 15 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Orde Baru untuk membekukan dan membubarkan organisasi masyarakat sipil.

Sejarah mencatat bahwa pasal-pasal inilah yang menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Orde Baru untuk melakukan pengawasan yang ekstra ketat dan bahkan ancaman untuk membubarkan organisasi masyarakat sipil yang dalam pandangan pemerintah pada waktu itu tidak sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah Orde Baru juga melakukan upaya untuk mengkooptasi berbagai kekuatan yang ada di masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil ke dalam sistem monitoring negara. Bagi kelompok yang menolak kooptasi, Pemerintah Orde Baru melakukan tindakan represif kepada mereka. (Nyman, 2006: 41).

Penyusun Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil memahami benar bahwa upaya untuk menata kembali hubungan antara negara dengan organisasi masyarakat sipil di Indonesia tidak akan pernah dapat dilakukan apabila kewenangan pemerintah untuk melaksanakan ideologi tunggal dan kewenangan pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat sipil tetap dipertahankan dalam undang-undang yang akan datang.

Solusi terhadap persoalan ini dijawab oleh para penyusun Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil dengan menegaskan dua hal. Pertama, pemerintah tidak akan lagi melakukan intervensi kepada organisasi masyarakat sipil. Peran pemerintah, termasuk juga tugas-tugas teknis administratif yang selama ini dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri akan ditangani oleh sebuah Komisi yang di dalamnya akan diisi oleh wakil pemerintah maupun wakil dari organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap kegiatan organisasi masyarakat sipil. Bahkan di dalam Komisi yang akan dibentuk, wakil pemerintah akan duduk bersama-sama dengan wakil organisasi masyarakat sipil dan memutuskan hal-hal yang terkait dengan organisasi masyarakat sipil.

Dari segi pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil disepakati oleh Tim Penyusun bahwa berkenaan dengan asas organisasi masyarakat sipil tidak lagi bersifat asas tunggal yang dipaksakan sebagai yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 akan tetapi menegaskan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki keleluasaan untuk

menentukan asas mereka sejauh asas tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai kewenangan pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat sipil sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Tim Penyusun menyepakati sebagaimana yang termuat pada Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil tidak lagi memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut. Sanksi yang berbentuk pembekuan dan pembubaran organisasi masyarakat sipil hanya dilakukan berdasarkan kepada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



Catatan Penutup

Sebagaimana telah dinyatakan di awal, tulisan ini tidak berniat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai upaya membangun paradigma baru hubungan antara negara dan organisasi masyarakat sipil sebagaimana yang diproyeksikan dalam Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil.

Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil yang berlatar belakang organisasi masyarakat sipil selama dua atau tiga dasa warsa melihat bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil ini adalah momentum untuk membangun kembali paradigma hubungan antara organisasi masyarakat sipil dengan negara. Dapat dipahami apabila sudut pandang mereka adalah menolak substansi intervensi pemerintah terhadap organisasi masyarakat sipil sebagaimana yang termuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Berawal dari penolakan atas intervensi pemerintah terhadap organisasi masyarakat sipil maka dipandang perlu membentuk Komisi Organisasi Masyarakat Sipil sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengurus organisasi masyarakat sipil. Kehadiran Komisi akan menjadi faktor yang dapat diterima oleh organisasi masyarakat sipil yang tetap menaruh kecurigaan terhadap setiap bentuk intervensi pemerintah terhadap mereka. Sementara bagi pemerintah, kehadiran Komisi ini akan menjadi lembaga yang mampu melaksanakan tugas-tugas penguatan kelembagaan Organisasi Masyarakat Sipil yang selama ini tidak memperoleh perhatian dari pemerintah. (Ibrahim, 2007: 52)

Namun, upaya membangun kembali paradigma baru hubungan antara negara dengan organisasi masyarakat sipil juga sangat ditentukan oleh kesiapan departemen pemerintah yang menangani organisasi masyarakat sipil untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan mereka terhadap organisasi masyarakat sipil sehingga tidak terjadi kerancuan dalam proses pembuatan kebijakan. Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial dan

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah tiga departemen pemerintah yang mengurus organisasi masyarakat sipil. Masing-masing departemen memiliki peraturan perundang-undangan yang masing-masing tidak berhubungan dengan peraturan perundang-undangan di departemen lainnya.

Di masa yang akan tugas-tugas yang terkait dengan kebijakan organisasi masyarakat sipil akan menjadi tanggung jawab Komisi Organisasi Masyarakat Sipil sebagaimana yang diwacanakan dalam draft Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil. Namun, pembentukan Komisi Organisasi Masyarakat Sipil akan mengundang persoalan dengan ketiga departemen pemerintah. Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Organisasi Masyarakat Sipil adalah wilayah kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh ketiga departemen itu. Pertanyaannya adalah akankah ketiga departemen tersebut bersedia menyerahkan kewenangan mereka kepada Komisi.

Hal yang tidak kalah pentingnya terkait dengan Komisi adalah bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. Tim penyusun Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil masih harus menegaskan apakah Komisi juga akan dibentuk juga di provinsi atau bahkan sampai ke kabupaten/kota. Konsensus yang berkembang mengindikasikan, bahwa Komisi Organisasi Masyarakat Sipil harus juga di tingkat provinsi mengingat bahwa di provinsi terdapat cukup banyak organisasi masyarakat sipil.

Pertanyaan bagaimana relasi antara Komisi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di provinsi, masih belum dijawab oleh para penyusun rancangan undang-undang ini, demikian juga dengan sumber pendanaan dan lain-lain. Masalah inilah yang harus dapat dijawab oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang manakala Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama pemerintah.

Desakan dari organisasi masyarakat sipil yang menuntut agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik di provinsi maupun di kota/kabupaten melakukan reposisi menjustifikasi kebutuhan mendesak untuk menata kembali peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pelaksanaan otonomi daerah yang menempatkan posisi Badan ini sebagai bagian dari urusan daerah telah menyebabkan munculnya keragaman mengenai pentingnya posisi Badan ini. Ketidakjelasan relasi antara urusan yang dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota juga memengaruhi posisi Badan Kesatuan Bangsa. Ketidakjelasan ini perlu segera dijawab oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri sejalan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat Sipil yang akan menata kembali hubungan antara negara dan masyarakat.

Daftar Referensi

Abubakar, Irfan, Chaider S Bamualim, Eds. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2006).

Antlov, Hans, Rustam Ibrahim, Peter van Tujil. *NGO Governance and Accountability In Indonesia: Challenges In A Newly Democratizing* Country. Jakarta: July 2005.

Chandhoke, Neera. *State and Civil Society: Exploration In Political Theory*. New Delhi: Sage Publication, 1995.

Culla, Adi Suryadi. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2006.

Dharmawan, HCB, Ed. *Lembaga Swadaya Masyarakat: Masyarakat Nurani Menggapai Kesetaraan*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2004.

DeLue, Stephen M. *Political Thinking, Political Theory and Civil Society*. Boston: Allen and Bacon, 1997.

Guan, Lee Hock, Ed. *Civil Society In Southeast Asia*. Singapore: Institute for Southeast Asian Studies, 2004.

Habermas, Jurgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press, 1992.

Hayness Jeff. *Demokrasi dan Masyarakat Sipil Di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Kaum Terpinggir*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.

Hikam, Muhammad AS. *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.

Hopkins, Bruce. *Starting and Managing A Non-Profit Organization: A Legal Guide*. New York: John Wiley and Sons, 1993.

Kaviraj, Sudipta and Sunil Khilnani, Eds. *Civil Society History and Possibilities*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Nyman, Mikaela. *Democratising Indonesia: The Challenges of Civil Society In the Era of Reformasi*. Copenhagen: NIAS Press, 2006.

Rustam, Ibrahim. *A Long Journey To A Civil Society*. Jakarta: YAPPIKA, 2006.

Shigetomi, Shinnichi. *The State and NGOs Perspective From Asia*. Singapore: Institute for Southeast Asian Studies, 2002.

Silk, Thomas, Ed. *Philanthropy and Law In Asia: Comparative Study of the Non-Profit Legal System In Ten Asia-Pacific Societies*. San Francisco: Jossey Bass Publishers, 1999.

Suharko. *The Roles of NGOs in Rural Poverty Reduction: The Case of Indonesia and India*. Nagoya: Graduate School of International Development, Nagoya University, Oktober 2007.

Uhlin, Anders. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga Di Indonesia*. Bandung: Mizan Pustaka, 1998.

Yusron. *Elite Lokal dan Civil Society: Kediri Di Tengah Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES, 2009.

Walzer, Michael, Ed. *Toward A Global Civil Society*. Oxford: Berghahm Books, 1995.

RAJAWALI PERS

DAFTAR INDEKS

A

absolut, 83, 102, 245, 258, 453, 461

Aceh, 41, 42, 145, 343, 349, 514, 515, 516, 518, 523, 548, 553

Ade Saptomo, 38, 52

Administrasi, 86, 162, 163, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 290, 314, 320, 326, 363, 380, 384, 387, 390, 391, 456, 457, 466, 467, 506

Administrasi Pemerintahan, 456, 457, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 468, 469

Adrianus Meliala, 202

Ad Hoc, 399, 401, 402, 407

Afrika, 93, 95, 341, 345

Agus Surono, 513

Ali Mansyur, 153

Allah, 31, 100, 144, 154, 155, 157, 158, 470

Alternatif Penyelesaian Sengketa, 213, 417, 419, 512

Alvin Toffler, 92

Amerika Latin, 93, 335, 341

Aminudin Ilmar, 327

Anak, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445

Andi Hamzah, 167

APEC, 88, 89, 94

Appeldoorn, 423

Arbitrase, 417, 419

Aristoteles, 10, 105

Artidjo Alkostar, 99, 105, 117

Asas, 36, 86, 107, 110, 118, 169, 170, 173, 174, 177, 182, 207, 265, 290, 311, 317, 319, 384, 385, 390, 414, 463, 464

ASEAN, 92, 217

Asia, 93, 95, 161, 190, 193, 276, 379, 494, 542, 548, 561

B

Baharuddin Lopa, 166

Bambang Purnomo, 185

Banding, 386, 464, 505

Bank, 71, 91, 94, 95, 141, 148, 161, 168, 170, 171, 172, 173, 187, 189, 263, 335, 341, 355, 379, 480, 494, 507, 508, 509, , 512

BAPAS, 440, 441

Batak, 41

Belanda, 43, 48, 77, 89, 101, 196, 226, 280, 347, 443, 458, 462, 469, 515, 551

Beleid, 168, 176

Berhukum, 4

bestuur, 384, 385, 386, 456, 458, 459, 464

Birokrasi, 164, 322, 374, 377, 405

Boaventura de Sousa Santos, 35, 70, 197

Boeke, 41

BPUPKI, 108, 237, 243, 336, 337, 347, 348

Bruggink, J.J.H., 36
Bryce, 218
Budaya, 43, 94, 206, 224, 225, 226, 492, 495, 536, 542, 543, 553
budaya hukum, 9, 17, 31, 43, 44, 54, 67, 164, 166, 167, 185, 193, 258, 283, 314
budaya lokal, 43, 44, 338, 539
Bung Karno, 40, 108
Busang, 102

C

C.F.G. Sunaryati Hartono, 90, 106, 117, 240
cacat, 38, 462
cacat yuridis, 462
Cecep Effendi, 548
CEO, 179
Cessie, 161
check and balances, 233, 249, 259, 261, 262, 263
Cicero, 10, 78
Cina, 156, 199, 201
cita-cita moral, 98
cita hukum, 76, 91, 98, 101, 107, 108, 110, 111, 114, 115, 116, 339
Civil, 142, 406, 428, 548, 561, 562
civil war, 219
computer crime, 204, 205
consensus, 219
contractual process, 421, 422
corporate crime, 121, 199, 200, 202
corporate culture, 206, 211, 212
Court, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 239, 259, 391, 402, 404, 405
cracker, 203, 204
Crime, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 160, 162, 163, 186, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 445, 471, 477
Criminal, 121, 133, 145, 162, 194, 198, 199, 204, 206, 207, 212, 403, 445
Criminal Policy, 167
CSIS, 484
Cyber Crime, 204
Cyber Law, 182

D

Demokrasi, 12, 40, 97, 112, 227, 289, 364, 411, 495, 561
Demokrasi Ekonomi, 113
Depnaker, 415
Desa, 41, 48, 378, 459, 495, 508, 524, 537, 538, 539, 542
desa asli, 44
Desa Gaya Baru, 42
Dicey, 221, 256
Disaster, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432
Diskresi, 466
Diskriminasi, 271, 274, 286
Diversi, 442, 443, 445
Djamin, Awaludin, 424
Djumadi, 424
doelgerichte, 168, 169, 177
DPR, 55, 64, 108, 161, 176, 220, 238, 243, 244, 245, 246, 249, 251, 252, 255, 261, 262, 266, 267, 280, 281, 292, 293, 294, 304, 350, 352, 359, 360, 370, 372, 381, 401, 402, 405, 439, 445, 470, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 510, 512, 542, 545, 557
DPRD, 64, 161, 249, 262, 266, 267, 280, 281, 322, 338, 361, 364, 373, 405, 479, 481, 482, 485, 488, 510, 512
Dunia Maya, 179

E

economic crime, 177, 198, 199, 200, 202
Ehrlich, 45, 52

Ekonomi, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 101, 105, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 138, 196, 198, 206, 210, 290, 421, 424, 478, 495, 542, 543
ekonomi kapitalistik, 71
ekonomi pasar, 72, 73, 92
Eksekutif, 167
eksekutorial, 465, 546
eksploitatif, 14, 15, 21, 94
Eksternal, 165, 380
Electoral Court, 402
Emeliana Krisnawati, 178
Emil Salim, 112, 113, 117
Equal, 175, 176, 177
etatisme, 113
Etika, 104, 117, 246
extra ordinary power, 162

F

Faisal Santiago, 62, 68
Fakta, 28, 38, 298, 347, 364
Febrian, 507, 510, 512
feedback, 499
Feit, 170
Fichte, 221
fit and proper, 323, 499
fragmentasi, 57
Freies Ermessen, 169, 172
Friedman, W., 424
FX. Adji Samekto, 69

G

Gajo, 42
Gampong, 41, 42
Garuda Wiko, 6
GATT, 89, 92, 93
gemeinschaft, 41
Gender, 270, 271, 273, 275, 280, 282, 285, 286, 287, 289
Gerald Turkel, 70, 71
Girindro Pringgodigdo, 168
Globalisasi, 12, 57, 72, 88, 89, 92, 94, 95, 97, 101, 114, 117, 118, 119, 196, 378
Good Governance, 379, 487, 489, 494, 497
Grahame Thompson, 95, 118
Grand Design, 231, 232
Gustav Radbruch, 110
Gusti Ayu, 380

H

Habermas, 18, 97, 117, 561
Hacker, 203, 204
Hadjon, Philipus M., 424
Hak, 11, 47, 52, 71, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 108, 113, 115, 117, 181, 205, 224, 233, 261, 264, 278, 289, 290, 294, 301, 302, 307, 386, 395, 424, 438, 475, 476, 477, 478, 497, 500, 525, 527, 541, 542, 543, 551, 552, 554, 555, 557, 560
HaKI, 197, 209
Hakim, 4, 167, 172, 191, 293, 311, 383, 403, 419, 440
Hak Milik, 47
Hak Pakai, 47
Hak Pengelolaan, 47
Hak Ulayat, 47, 52
HAM, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 95, 126, 127, 128, 160, 165, 220, 221, 227, 254, 258, 264, 277, 285, 384, 476, 523, 545
Hamid S. Atamimi, 458
Hans-Peter Martin, 97
Hans Kelsen, 7, 48, 49, 228, 382
Hans Peter Martin, 97
Harald Schumann, 97, 118
Hari Purwadi, 54
Harmonisasi, 59, 60, 552
Harry F. Todd, Jr, 45, 53
Hermansyah, 13
HGU, 47

Holmes, Oliver Wendell, 5
Huala Adolf, 96, 117
Hubungan Industrial, 411, 412, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 424
Hukum, 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 44, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 72, 74, 82, 84, 87, 95, 100, 104, 108, 120, 123, 132, 133, 135, 138, 140, 146, 153, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 183, 193, 194, 195, 196, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 221, 222, 229, 230, 235, 237, 239, 244, 248, 260, 265, 266, 267, 268, 269, 289, 291, 293, 298, 299, 307, 311, 314, 317, 320, 363, 384, 385, 386, 391, 393, 395, 399, 405, 406, 408, 409, 421, 423, 424, 435, 436, 437, 438, 445, 446, 455, 456, 467, 469, 470, 474, 477, 478, 496, 507, 508, 510, 512, 513, 542, 543, 544, 545, 547, 551, 552, 553, 554, 555, 560
Hukum Adat, 42, 51, 52, 53, 238, 541
Hukum Ekonomi, 88, 90, 91, 92, 96, 97, 101, 105, 111, 112, 113, 114, 117, 119, 290
Hukum Islam, 141, 143, 148, 238, 290
Hukum Nasional, 8, 9, 12, 35, 36, 50, 52, 85, 86, 89, 90, 91, 99, 105, 106, 107, 110, 117, 118, 160, 220, 227, 231, 238, 240, 242, 243, 380, 388
Hukum Perdata Barat, 238
Hukum Progresif, 3, 20, 28, 73, 115
Humanistik, 95
Husni, Lalu, 424
Hutan, 519, 520, 521, 527, 532, 540, 541, 542, 543

I

ICAC, 161, 162, 167
idealita, 99, 100, 101
ideologi, 412
Iman Soepomo, 416
IMF, 71, 91, 94
imperatif, 106, 133, 176
imperialisme baru, 93
Indonesia, 1, 6, 7, 8, 12, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 86, 88, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 133, 135, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 179, 180, 181, 184, 185, 187, 188, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 202, 203, 204, 205, 207, 212, 217, 219, 220, 221, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 272, 275, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 286, 288, 289, 290, 295, 296, 298, 299, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 311, 313, 314, 315, 316, 319, 320, 324, 325, 326, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 357, 359, 361, 362, 364, 366, 367, 369, 374, 377, 378, 379, 384, 389, 390, 391, 395, 397, 399, 400, 401, 402, 404, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 415, 417, 423, 424, 425, 426, 435, 438, 439, 443, 448, 449, 469, 474, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 488, 489, 492, 493, 494, 495, 496, 501, 505, 506, 507, 508, 509, 512, 514, 515, 516, 519, 520, 523, 524, 526, 528, 529, 530, 540, 541, 543, 545, 546, 548, 549, 551, 553, 555, 556, 557, 558, 561, 562
Indrati Rini, 298, 307
Indriyanto Seno Adji, 160, 165, 318
Integrasi, 94, 96
Integritas, 492

Internal, 87, 380
IPTEK, 74, 89, 200, 203
Irmanputra Sidin, 244
ius constituendum, 239, 240, 241
ius constitutum, 240, 241, 438

J

Jackson, 217
Jamaika, 199
Jamal Wiwoho, 496, 500, 505
Jepang, 91, 201, 203, 412, 443
Jerome Frank, 8
Jimly Asshiddiqie, 217, 289
Joni Emirzon, 88, 307
Jusuf Kalla, 241

K

K. Berten, 103, 104, 117, 118
kawula pribumi, 43
kawula raja, 43
Keadilan, 10, 24, 28, 31, 35, 78, 99, 133, 155, 282, 395, 396, 405, 406, 561
keadilan formal, 73
Keadilan Sosial, 33, 34, 234, 235, 561
keadilan substansial, 73
Kebebasan, 15, 172, 257
Keberagaman, 8, 39, 44
Kebudayaan, 95, 117, 224, 273, 289
kebutuhan dasar, 55, 71, 72, 279, 491
Kedaulatan, 223, 227, 524
Kejahatan, 54, 60, 120, 121, 127, 138, 151, 160, 164, 176, 180, 182, 183, 186, 187, 192, 196, 198, 200, 202, 204, 213, 395, 474, 475
Kejaksaan Agung, 162, 163, 176, 177, 212
Kemerdekaan, 108, 230, 237, 243, 343, 347, 378
Kemiskinan, 70
Kepastian Hukum, 203, 311, 317, 385, 386
Kepentingan Umum, 311, 317, 385
Kesejahteraan, 12, 97, 224, 421, 424, 438, 444, 446, 551, 552
Kesepakatan Kerja Bersama, 414, 415, 424
Kleintjes, 41
kodifikasi, 173, 196, 238, 239
Komisi Konstitusi, 236, 237, 239, 242, 243
Kompetensi, 457, 489
Kompetisi, 298
Konflik, 50, 52, 474, 475, 495, 516, 519, 533, 540, 542, 543
konsiliator, 420, 421, 422
Konstitusi, 36, 183, 215, 217, 218, 219, 221, 224, 225, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 245, 248, 249, 251, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 280, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 298, 303, 304, 377, 401, 402, 403, 404, 405, 493, 508
konstitutif, 104, 110
Kontrol, 381, 382, 383, 391
korupsi, 26, 34, 71, 74, 122, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 188, 193, 203, 244, 261, 311, 312, 314, 323, 330, 331, 355, 454, 484, 485
KPK, 162, 163, 166, 176, 177, 388, 483
KPU, 161, 176, 250, 266, 322, 396, 397, 399, 406, 479, 481, 483, 555
Krisis, 97, 117, 198
KUHP, 125, 135, 137, 160, 173, 175, 196, 211, 212, 395, 396, 400, 438, 440, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477
Kuria, 41, 42

L

Law, 5, 6, 8, 12, 36, 37, 45, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 72, 73, 86, 87, 121, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 163, 164, 166, 167, 173,

174, 175, 176, 177, 179, 182, 183, 193, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 212, 217, 221, 223, 227, 228, 289, 290, 307, 314, 334, 388, 410, 424, 425, 428, 489, 510, 512, 541, 542, 561
Legal, 35, 37, 53, 58, 59, 60, 73, 164, 228, 294, 406, 407, 410, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 433, 513, 541, 561
legal culture, 67, 164, 166
Legislatif, 167, 213, 245, 250, 478, 480, 482, 483, 485, 489
Lembaga Perwakilan, 478
Lex, 173, 174, 175, 190
lex generalis, 173, 190
Lex Specialis, 173, 174, 175, 190
Liberal, 6, 411
liberalisasi, 73, 93, 196, 298
Lili Rasjidi, 117
Litigasi, 292
lokal, 14, 17, 21, 22, 29, 38, 39, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 57, 71, 72, 74, 91, 139, 195, 336, 338, 341, 342, 344, 346, 349, 368, 373, 374, 513, 514, 516, 517, 518, 519, 522, 523, 524, 527, 529, 531, 536, 537, 538, 539, 540, 554
lokal nusantara, 38, 39, 43
LSM, 270, 287, 322, 381, 399, 441, 523, 526, 529, 535, 550

M

machtsstaat, 221, 300
Mahkamah Agung, 165, 168, 170, 171, 175, 219, 249, 260, 262, 263, 388, 389, 390, 397, 399, 419, 508, 511, 512, 545, 546, 547
Mahkamah Konstitusi, 183, 217, 225, 248, 249, 251, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 280, 291, 292, 293, 294, 298, 303, 304, 401, 402, 404, 405, 508
Manulang, Sendjun, 424
Marcus Taufan, 499, 504, 506
Marga, 41, 42, 539
Marx, 411
Masyarakat, 14, 30, 42, 86, 111, 168, 183, 186, 195, 217, 227, 228, 301, 306, 363, 406, 455, 482, 495, 498, 517, 520, 540, 541, 543, 545, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561
Masyarakat Lokal, 542
Masyhur Effendi, 74, 85
materiel, 168, 175
Mayantara, 179
Mediasi, 507, 511, 512
Minangkabau, 41, 50, 51
Mochamad Isnaeni Ramdhan, 229, 232, 235
Mohammad Yamin, 289, 348
Money Laundering, 121, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 201
Moral, 154, 345, 492
Muchsin, 311
Muhammad Fauzan, 269
Muladi, 114, 115, 118, 174, 211
mutasi, 166, 324, 325, 326

N

N.E. Alga, 459
Nader, Laura, 45, 53
NAFTA, 89, 94
Nagari, 41, 42, 47
neo-kapitalisme, 90, 95
neo-liberalisme, 90, 94, 95
ninik mamak, 47
NKRI, 43, 325, 336, 359, 363, 367, 371, 373, 374
nomokrasi, 221
Norma, 8, 195, 223
Notaris, 104, 461, 544, 545, 546
Notonagoro, 118

O

Objek, 506, 535

objektif, 19, 70, 102, 103, 205, 294, 325, 411, 454, 458
Oemar Seno Adji, 160, 163, 165, 172
Oetojo Oesman, 118
Ombudsman, 165, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 381, 388, 391, 499
onrechtmatig, 462
onrechtmatige, 315, 383, 458, 462
Organized crime, 202
Otje Salman, 273, 290
Otonom, 369
Otonomi, 46, 101, 169, 289, 334, 336, 355, 359, 367, 372, 377, 379, 395, 398, 399, 400, 455, 523, 524, 542, 548, 553
Overheidsbeleid, 171, 172, 173

P

Padmo Wahjono, 237, 240, 243
Pajak, 173, 351, 355, 356, 446, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506
Palembang, 41, 507, 513
Pancasila, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 51, 63, 86, 90, 91, 92, 98, 101, 106, 108, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 146, 207, 223, 229, 230, 231, 232, 241, 253, 257, 258, 265, 298, 299, 301, 323, 339, 340, 343, 345, 346, 363, 377, 378, 379, 412, 413, 424, 443, 444, 446, 558, 559
Paradigma, 7, 8, 12, 14, 17, 36, 50, 52, 115, 232, 233, 262, 329, 450, 451, 455
Partai Politik, 253, 263, 267, 478, 487, 489, 545
Pasar Bebas, 92, 118
Paulus Hadi Suprapto, 435
Paul Hirst, 95, 118
PBB, 78, 84, 120, 121, 123, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 139, 160, 183, 186, 196, 198, 217, 245, 271, 341, 442, 443, 445, 477, 496
Pegawai Negeri, 323, 325, 548
Pekerja, 236, 303, 305, 401, 405, 407, 414, 418, 417, 440, 441
Pelanggaran, 174, 177, 395, 396, 406, 523
Pemilu, 203, 224, 251, 252, 255, 267, 366, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 479, 482, 483, 488
Pencucian Uang, 138, 160, 194, 210, 239
Penegak Hukum, 107, 161, 163, 380
Pengadilan, 86, 127, 136, 141, 148, 149, 160, 172, 175, 267, 290, 307, 389, 391, 396, 399, 400, 402, 403, 406, 420, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 464, 465, 497, 512
Pengadilan Negeri, 170, 301, 306, 397, 398, 419, 435
Pengadilan Tinggi, 170, 397, 419, 464, 465
Pengawasan, 376, 380, 381, 386, 387, 391, 406, 498, 555
Penghulu, 47
Peradilan Tata Usaha Negara, 172, 318, 383, 391, 418, 439, 456, 457, 460, 461, 464, 467, 468, 469
Peraturan, 64, 108, 218, 219, 222, 243, 267, 275, 281, 283, 286, 297, 353, 374, 396, 410, 417, 418, 424, 447, 448, 455, 463, 470, 471, 478, 507, 511, 512, 520, 537, 538, 541, 547, 552, 557
Peraturan Daerah, 38, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 239, 361, 363, 508, 540
Peraturan Pemerintah, 45, 48, 49, 51, 238, 239, 261, 300, 301, 307, 467, 508, 526, 540
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 238, 239, 508
Peraturan Presiden, 239, 301, 508
Peter Senge, 323
Phillips Hood, 217
Plato, 10, 103, 105, 221
PLN, 161, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307

pluralisme hukum, 19, 21, 22, 23, 238
polisional, 45
Politik Hukum, 12, 90, 117, 132, 138, 175, 231, 237, 240, 242, 243, 541
positivistik, 7, 14, 18, 21, 29, 450, 451, 453
Prancis, 40, 77, 78, 169, 219, 229, 501, 510
Prasetijo Rijadi, 24
Presidensial, 246
Principles, 37, 45, 52, 86, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 134, 174, 199, 428
Privatisasi, 88, 118
Prodjodikoro, Wirjono, 235
Profesi Hukum, 104, 107, 117, 388
Progresif, 3, 20, 28, 72, 73, 115, 452

R

Raju, 435, 436, 442
Ramesh Mishra, 197
Rechtsidee, 108
Reformasi, 36, 54, 57, 64, 65, 114, 115, 118, 219, 228, 251, 254, 255, 259, 262, 267, 289, 344, 376, 377, 380, 456, 492, 497, 505, 541, 542, 561
Regulasi, 193
Rene Descartes, 103
Responsif, 17, 489
Riris Ardhanariswari, 269
Roeslan Saleh, 110, 111, 118, 207
Ronny Nitibaskoro, 202
Rosabeth Moss Kanter, 92
Roscoe Pound, 8, 76, 450
Rule, 6, 36, 70, 71, 72, 87, 221, 290, 442, 489, 495
Rule of Law, 6, 36, 70, 72, 87, 221, 290, 489
Rusia, 199, 201, 219

S

Sampford, 37, 72
Satjipto Rahardjo, 3, 7, 20, 23, 28, 56, 68, 69, 114, 118, 397, 451, 455
Satya Arinanto, 290, 395
Sekretariat Negara, 237, 243, 377, 378
Sistem, 9, 12, 36, 68, 69, 72, 90, 91, 94, 107, 113, 117, 133, 164, 166, 167, 231, 232, 234, 235, 240, 242, 246, 251, 254, 255, 271, 290, 292, 297, 324, 325, 377, 378, 380, 391, 395, 405, 412, 489, 497, 498, 504, 506, 530, 542
Sistematik, 151
Sistem Hukum Modern, 69
Siti Nurbaya, 335
Slank, 479, 483, 484, 485, 495
social melee, 72
Socrates, 10, 105
Soemantri, Sri, 235, 267
Soetanto Soepiadhy, 236
Sosiologis, 35, 36, 40, 451
spesialitas, 317
Sri Redjeki Hartono, 118
Staatsbeleid, 168, 171, 172, 173
Sudarsono, 141, 148, 321
Sumber Daya Manusia, 62, 63, 64, 66, 68, 497
Supancana, 425
Supanto, 195

T

Tax, 379, 496, 505
Teori, 7, 11, 95, 148, , 290, 340, 342, 386, 387, 468, 543
Ter Haar, 41
tipe hukum, 19, 20, 23
Transformasi, 322, 489, 492, 524
Transnational Crime, 121, 198
trigger, 162, 165
Tri Pranadji, 478, 553
Trubek, David M., 73

U

UGM, 92, 118

Ulayat, 47, 50, 52

UNAFEI, 186, 201

Unger, Roberto Mangabeira, 12

Universitas, 3, 6, 12, 13, 20, 24, 38, 52, 54, 62, 69, 73, 88, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 133, 160, 168, 194, 196, 227, 229, 248, 289, 290, 298, 324, 326, 377, 380, 395, 423, 424, 435, 469, 470, 474, 495, 505, 513, 543, 544

Uni Eropa, 89, 92, 134, 184

UNS, 195, 496, 505

urusan pemerintahan, 46, 328, 329, 339, 348, 350, 374, 458, 459, 460, 466, 469, 547

UUD 1945, 6, 7, 8, 12, 25, 55, 63, 65, 68, 88, 89, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 125, 207, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 268, 277, 278, 279, 280, 288, 298, 299, 301, 303, 329, 339, 340, 343, 347, 348, 363, 364, 378, 401, 402, 404, 405, 458, 466, 510, 512, 526

V

Van Apeldoorn, 64

van Melsen, 103, 105, 118

Veltmeyer, 93, 523

virtual of Pancasila, 38, 39

Visi, 240, 242, 322, 498

Von Savigny, 100

Vrijspraak, 170

W

Wacana, 12, 14, 29, 289, 398, 523, 561

Wahyono, 248

Wajib, 355, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 506

welfare state, 466

Weltanschauung, 39, 232

Wewenang, 261, 262, 263, 265, 317, 320, 330, 509

white collar crime, 121, 160, 162, 163

wijsheid, 168, 169, 177

win-win solution, 421

Wiranto, 241, 267

wisdom, 105

Wondollack, 532

World Bank, 71, 335, 341, 379

WTO, 71, 89, 92, 93, 94, 217

Y

Yakuza, 122, 201, 203

Yuhari Robingu, 408

Yurisprudensi, 107, 169

Yusriyadi, 446, 455

Z

Zainal Asikin, 409

Zakat, 141, 149, 211, 506

Zudan Arif Fakrulloh, 69, 114, 118, 160, 311, 324, 325, 335

RAJAWALI PERS

BIODATA PENULIS

Prof. A. Masyhur Effendi, S.H., M.S.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan Perbanas. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta dan Hakim Agung *Adhoc* di Mahkamah Agung.

Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., S.U.

Guru Besar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan Universitas Trisakti Jakarta.

Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.

Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum Unair dan Program Notariat Unair.

Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.N.

Ketua Program Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijopranoto Semarang.

Dr. Agus Surono, S.H., M.H.

Ketua Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar. Dosen program Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Islam Riau dan Universitas Muhammadiyah Palembang. Senior legal analysis pada Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan serta Partner pada kantor hukum Prasetyo dan Partners.

Prof. Dr. Aminudin Ilmar, S.H., M.H.

Lahir di Sengkang 10 September 1964. Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum dan pengajar pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Hasanudin. Telah menulis beberapa buku dan sekarang sebagai Penasihat Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan tenaga Ahli DPRD Sulsel. Mengajar di berbagai program pascasarjana, PTN, dan PTS.

Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H.

Kolumnis dan Pengamat Hukum Tata Negara, Mantan Koordinator staf ahli Mahkamah Konstitusi dan mengajar Hukum Tata Negara di beberapa PTS di Jakarta. Lahir di Makassar 23 Desember 1974.

Prof. Dr. Bambang Purnomo, S.H.

Guru Besar Hukum Pidana di UGM dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya.

Dr. Cecep Effendi

Anggota Dewan Pengarah Jaringan Kerja Tata Pemerintahan Asia - Kerja Sama Pembangunan Jerman dan Senior National Advisor Advisory Services Support for Decentralization, German Technical Cooperation (GTZ-ASSD) di Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Prof. Dr. Emeliana Krisnawati, S.H., M.Si.

Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya.

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Lahir di Yogyakarta 28 Maret 1969. Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta. Dosen di berbagai PTN dan PTS di Jakarta. Peneliti di berbagai lembaga konsultan dan aktif dalam berbagai publikasi ilmiah, seminar dan diskusi.

Dr. Febrian, S.H., M.H.

Lahir di Jambi, 31 Januari 1962. Menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum di Unair Surabaya. Saat ini menjadi dosen di FH Universitas Sriwijaya dan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Tenaga Ahli DPD PAH 1 dan Anggota Dewan Pakar Dewan Ketahanan Nasional.

Prof. Dr. FX. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.

Lahir di Yogyakarta, 18 Januari 1962. Menempuh pendidikan formalnya (S1) di Fakultas Hukum Undip Semarang tahun 1981-1986. Menekuni dunia pendidikan hukum dengan menjadi Dosen di almamaternya sejak tahun 1987 di bidang kajian hukum internasional. Menempuh pendidikan Magister (S2) di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1991-1995, pada bidang kajian utama hukum internasional. Pengkajian hukum secara komprehensif dengan melibatkan faktor di luar ranah kajian positivistik, diperdalam ketika menempuh pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Undip tahun 1999–2004. Aktif dalam penulisan masalah hukum internasional, globalisasi dan hukum lingkungan yang dituangkan dalam buku maupun tulisan di media massa. Sekarang menjabat Sekretaris Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Undip.

Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si.

Lahir di Mempawah 28 Januari 1965. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat. Aktif sebagai pembicara dalam berbagai forum regional maupun nasional. Pengajar di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dr. Habib Adjie, S.H., M.H.

Notaris di Surabaya. Menyelesaikan program Magíster Ilmu Hukum di UNDIP dan Program Doktor di Unair. Pengajar di berbagai program Pascasarjana di PTN dan PTS di Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta.

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.

Lahir di Surabaya 1 Desember 1964. Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum UNS Surakarta, Program Magister dan Program Doktor Untag Surabaya. Senior Partner pada Eka Law Firm Surabaya.

Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Hukum dan program Magister Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Lahir 15 Mei 1965. Buku yang diterbitkan antara lain *Etika Pluralisme Hukum, Hukum Negara Versus Hukum Lokal* dan *Reproduksi Kekerasan Masyarakat: Studi Kritis terhadap Hukum Negara*.

Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.

Dosen Fakultas Hukum UNS dan pengajar program Pascasarjana Ilmu Hukum UNS.

Prof. Ida Bagus Rahmadi Supancana, S.H., M.H., Ph.D.

Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya. Menyelesaikan Program Doktor di Universitas Leiden Belanda bidang Hukum Udara dan Ruang Angkasa. Dosen di berbagai PTN dan PTS di Indonesia. Anggota Tim Ahli dalam penyusunan beberapa Undang-Undang dan sebagai Editor beberapa Jurnal Internasional.

Prof. Dr. Indrati Rini, S.H., M.S.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Menyelesaikan S1, S2 dan S3 Ilmu Hukum di Unair Surabaya.

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Pengajar pada program pascasarjana Ilmu Hukum UI, UNPAD, Universitas Pelita Harapan, Universitas Krisna Dwipayana, Anggota Senat Guru Besar PTIK. Tim Pakar Hukum (Pidana) senior Menteri Hukum dan HAM, Konsultan

Ahli Hukum (Pidana) BPHN. Tim perumus RUU Pengadilan Tipikor, RUU Pemberantasan Tipikor, RUU Pencucian Uang serta advokat senior pada Prof. Oemar Senoadji S.H. dan Rekan.

Dr. Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta. Anggota Tim Ahli Badan Legislasi DPR RI. Aktif dalam berbagai publikasi ilmiah dan seminar, workshop serta diskusi.

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum UNS, Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum UNS. Lahir di Magelang tahun 1962. Mengajar di S1 FH UNS, S2 dan S3 Ilmu Hukum UNS dan beberapa program pascasarjana PTN dan PTS di Indonesia.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Guru Besar Fakultas Hukum UI, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2004-2009 dan pengajar pascasarjana di berbagai PTN dan PTS di Indonesia.

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., MHum.

Guru Besar Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Aktif dalam berbagai forum akademik dan ratusan karya ilmiah sudah terpublikasikan dalam jurnal ilmiah maupun buku-buku.

Dr. Kamarullah, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum dan Program S2 Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Prof. Dr. HM. Ali Mansyur, S.H., M.Hum.

Guru Besar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

Lahir di Kotabaru, 1 Januari 1960. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum PTN dan PTS di Indonesia

Dr. Muhammad Fauzan, S.H., MHum dan Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.

Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H.

Lahir di Surabaya 21 Maret 1960. Dosen di Fakultas Hukum dan program S2 Ilmu Hukum Ubhara Surabaya. Telah menulis 3 buku tentang Hukum Pidana.

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Mantan Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya dan pengajar program Pascasarjana Ilmu Hukum di beberapa PTN dan PTS di Indonesia.

Prof. Dr. Paulus Hadi Suprapto, S.H., M.H.

Guru Besar Fakultas Hukum dan Pengajar S2, S3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Prof. Dr. Prasetijo Rijadi, S.H., M.S.

Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara.

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.

Guru Besar Sosiologi Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Pemikiran beliau tentang Hukum Progresif banyak mewarnai dalam pembelajaran Ilmu Hukum di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia.

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.

Lahir di Surabaya 16 November 1965. Guru Besar Tata Negara dan Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Penulis aktif dalam berbagai aktivitas akademik baik dalam fora nasional maupun internasional, di antaranya menjadi *visiting Professor* dalam rangka *Asia Link Program For Human Rights Education in Indonesia and Mongolia* pada The School of Law, The Queen's University of Belfast Northern Irelan UK tahun 2008.

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI). Pernah memangku jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri. Pengajar pada program Pascasarjana IPB.

Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya dan Ketua Pusat Kajian Konstitusi UNTAG Surabaya. Praktisi Hukum Tata Negara, Pengabdi dunia pendidikan sebagai Direktur "Soetanto Soepiadhy Private Library".

Dr. Ir. Sudarsono Harjosoekarto, M.A., S.H.

Dosen Fisipol Universitas Indonesia, pernah memangku jabatan sebagai Dirjen Pemerintahan Umum dan Daerah, Dirjen Otonomi Daerah, Kepala Badan Diklat dan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Departemen Dalam Negeri.

Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

Lahir di Klaten 7 November 1960. Dosen Fakultas Hukum UNS dan Pengajar program Pascasarjana Ilmu Hukum UNS. Aktif dalam berbagai publikasi ilmiah. Dosen teladan nasional perguruan tinggi tahun 1997 dan Dosen Berprestasi UNS tahun 2009.

Dr. Ir. Tri Pranadji, M.Si, A.P.U.

Ahli Peneliti Utama pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian di Departemen Pertanian, tenaga Ahli Departemen Dalam Negeri UU Bidang Politik dan Ormas, Sekjen Ikatan Sosiologi Indonesia.

Prof. Dr. Wahyono, S.H,. M.S.

Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di FH UGM, S2 Ilmu Hukum di Unair dan S3 Ilmu Hukum di Undip.

Prof. Dr. Hj. Yuhari Robingu, S.H., M.S.

Ketua Program Doktor dan Magister Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya.

Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.H.

Guru Besar Fakultas Hukum dan Pengajar S2, S3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

MEMAHAMI HUKUM

Dari Konstruksi sampai Implementasi

Buku ini didesain untuk mengetengahkan gagasan dari Empat Generasi Pemikir dalam Hukum Indonesia yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan bagian-bagian dari buku ini. Buku ini secara umum menggambarkan gagasan-gagasan tentang bagaimana cara berhukum dan memandang hukum dalam perspektif masing-masing generasi.

Di bagian awal buku ini dipaparkan tentang arah pembangunan hukum di Indonesia. Bagian ini menyadarkan bahwa hukum akan selalu berkelindan dengan persoalan keadilan, keberagaman, kemiskinan, ideologi negara, persoalan politik dan sosial kemasyarakatan lainnya. Pembahasan dilanjutkan dengan gagasan teoretik dan upaya mengantisipasi kejahatan sistematik seperti korupsi, *money laundering*, maupun kejahatan ekonomi global; upaya membangun budaya sadar berkonstitusi; dan gagasan tentang pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan. Uraian diakhiri dengan pembahasan tentang pengembangan lembaga dan pranata hukum di Indonesia.

Buku ini sangat berguna bagi aparatur penyelenggara pemerintahan di pusat maupun pemerintahan daerah, DPR maupun DPRD, praktisi, mahasiswa hukum, dan bagi siapa saja pemerhati dan peminat hukum di Indonesia.

Editor buku ini adalah Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara dan Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Ninuk Triyanti, S.H., M.H., dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 1992-1993 dengan jabatan akademik lektor dan aktif saat ini di Biro Hukum Departemen Dalam Negeri.

PT RajaGrafindo Persada
Jl. Pelepah Hijau IV Blok TN 1 No. 14-15
Kelapa Gading Permai Jakarta 14240
Telp. 021-4520951 Fax. 021-452 9409
Email: rajapers@rajagrafindo.com
www.rajagrafindo.com

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
978-979-769-278-0